

Suç Örgütleri

Prof. Dr. İzzet Özgenç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Suç Örgütleri

- ♦ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
- ♦ Terör Örgütü
- ♦ Terörizmin Finansmanı Suçu
- ♦ Terörizmin ve Terör Örgütünün Propagandası Suçu
- ♦ Anayasal Düzeni İhlal Suçları
- ♦ Devlet Sırları ve Ceza Hukuku

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş
15. Bası

SEÇKİN | Hukuk
Ankara 2023



Akademik ve Mesleki Yayınlar

Suç Örgütleri

İzzet ÖZGENÇ

SEÇKİN | Hukuk

No: 1042

ISBN 978-975-02-?

Onbeşinci Baskı: Ekim 2023

Sayfa Tasarımı:

Ayşegül GENÇ KEMEÇ

Kapak Tasarımı:

Seçkin Yayıncılık

? Sayfa, 16x23,5 cm.

1. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Kurulmuş Örgütü Yönetmek
2. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak
3. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Yardım Etmek
4. Terör Örgütü
5. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
6. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu
7. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
8. Suçluyu Kayırma Suçu
9. "Darbe Suçları"
10. Devlet Sırrı ve Ceza Sorumluluğu

© Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

Satış ve Dağıtım:

Yayınevi Merkezi

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sokak No: 13 Çankaya/ANKARA

Tel: 0-312-435 30 30 – Faks: 0-312-435 24 72 – seckin@seckin.com.tr

İstanbul Çağlayan Adliyesi Şubesi
D Blok 2. Bodrum Kat No: 5
Çağlayan
Tel: (212) 240 00 15
Faks: (212) 240 00 15
caglayan@seckin.com.tr

İstanbul Kartal Adliyesi Şubesi
C Blok Zemin Kat No: 29
Kartal
Tel: (216) 303 11 23
Faks: (216) 303 11 23
kartalsube@seckin.com.tr

İstanbul Şişli Şubesi
Abide-i Hürriyet Cad.
No: 183/A Şişli
Tel: (212) 234 34 77
Faks: (212) 231 24 69
sislisube@seckin.com.tr

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Şubesi
C Blok Zemin Kat No: 23
Kartal
Tel: (216) 303 20 00 / 5462
bamsube@seckin.com.tr

Ankara Sıhhiye Şubesi
Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye
Tel: (312) 230 52 62
Faks: (312) 230 52 62
ankarasube@seckin.com.tr

Web Sitesi: www.seckin.com.tr

Seçkin Yayıncılık Sertifika No: 45644

Baskı:

Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. – **Sertifika No: 49363**

İVOGSAN 1518 Sok. Mat-Sit İşmerkezi No: 2/40 Yenimahalle /ANKARA T: (0-312) 395 21 10

Sunuş

Elde edilmesi hedeflenen ekonomik çıkarlar veya erişilmesi hedeflenen siyasi amaçlar bakımından daha elverişli ortam oluşturması itibarıyla, bazı suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi yoluna gidilmektedir.

Keza, soruşturma makamları tarafından, ekonomik çıkar amacıyla veya siyasi amaçla işlenen bir suçun varlığı hususunda yeterli delile ulaşılamayan durumlarda, kişiler hakkında belirtilen hedefler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya kurulmuş örgütü yönetmek ya da örgüte üye olmak suçlarından birini işlediklerinden bahisle iddianame düzenlenmesi yoluna gidilmektedir.

Her iki uygulamanın da hukuk güvenliği ve toplum barışı bakımından büyük sakıncalar taşıdığı, izahtan varestedir. Suç örgütü fenomeninin, yeni Türk Ceza Kanunu ile 3713 s. Terörle Mücadele Kanununda 2006 yılında yapılan değişikliklerin redaksiyonunu deruhte eden bir akademisyen nazarıyla maddi ceza hukuku bakımından irdelenmesi, bu sakıncaların giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Belirtilen mülahazalarla hazırlanmış olan bu çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak ile işlenmesi amaçlanan suçların türünün kurulan örgütün niteliğinin belirlenmesi bakımından etkisi konularında açıklamalar yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek doğrudan doğruya gerek çeşitli uluslararası organizasyonlar aracılığıyla dolaylı olarak ülkemize dayatması sonucu kanunlaşan 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun**”nun ülkemiz insanı bakımından ne tür sakıncaların ortaya çıkardığına işaret etmek için, bu suça ilişkin açıklamalar, müstakil bir başlık altında yapılmıştır.

Kitabın ilk 13 basısında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ve bu suçla irtibatlı olan çeşitli suçlara ilişkin açıklamalara yer verilmişti. Bu yeni basıda, bu kısımlar kitaptan çıkarılmıştır. Bu kısımlar, ilgisi itibarıyla 2022 yılı içinde yayımlamayı planladığımız, **Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar** adlı kitabımızın ikinci basısında ve ayrıca, “**Devletin Yargı Fonksiyonu Aleyhine İşlenen Suçlar**” adıyla yayımlamayı planladığımız diğer bir kitapta yayımlanacaktır.

Kitabın yeni basısında, terörizmin finansmanı suçunu müteakiben, **terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuna** ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Kitapta ayrıca, anayasayı ihlal mahiyeti taşıyan suçlar ile maddî ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden hareketle devlet sırrı kavramına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunmaktadır.

Çalışmamızın, bu yanlış yöntem ve uygulamanın değişmesine katkı sağlayacağı ümidindeyiz.

Öneri ve düzeltmeleriyle çalışmanın 14. basısına katkılarından dolayı Yargıtay Üyesi Sayın Ergün ŞAHİN'e teşekkür ederim.

İçindekiler

Sunuş.....	5
§1. SUÇ ÖRGÜTÜ.....	11
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI.....	11
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER	12
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU	14
A. Suçun Maddî Unsurları.....	14
B. Suçun Manevî Unsurları	21
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU	22
A. Suçun Maddî Unsurları.....	22
B. Suçun Manevî Unsurları	23
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu	23
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkûmiyet Sorunu ve Türk Uygulaması	24
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ	24
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ	30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK	36
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME	49
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI	57
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI	61
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ.....	63
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ	73
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER	77
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ	79
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ	89
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU	96

EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU	99
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI	109
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ.....	112
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	118
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER	133
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE.....	140
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE	144
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU	146
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE	155
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER	159
EKSKURS 17: “İLTİSAK” İBARESİ ÜZERİNE	165
§2. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU	171
I. “KARAPARA” İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ	171
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ	173
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU	189
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”	208
§3. TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU	213
§4. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÜMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER	269
GİRİŞ	269
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)	270
A. Korunan Hukukî Değer	270
B. Suçun Maddi Unsurları	271
1) Suçun Konusu	271

2) Fiil	271
3) Fail ve Mağdur	284
C. Suçun Manevi Unsurları	285
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu.....	285
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu.....	286
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu	287
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311).....	288
A. Korunan Hukuki Değer	288
B. Suçun Maddi Unsurları.....	289
1) Suçun Konusu	289
2) Fiil	289
3) Fail ve Mağdur	290
C. Suçun Manevi Unsurları	290
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu	291
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu	291
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”	291
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312).....	291
A. Korunan Hukukî Değer	291
B. Suçun Maddi Unsurları.....	291
1) Suçun Konusu	291
2) Fiil	292
3) Fail ve Mağdur	294
C. Suçun Manevi Unsurları	294
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu.....	294
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu.....	294
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”	294
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316).....	294
SONUÇ.....	297
EKSKURS 18: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ.....	301
EKSKURS 19: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE	338
EKSKURS 20: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU - II.....	340
EKSKURS 21: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER.....	348
EKSKURS 22: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER.....	351
EKSKURS 23: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUIYETİ.....	355

§5. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU	359
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ	359
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ	359
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ	361
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI	363
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER	366
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU	384
Kaynakça	393

§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ

I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI

“Örgütlü suçluluk” (“*organisierte Kriminalität*”)¹ kavramı, daha ziyade **kriminolojik** bir kavramdır²; ancak, cezalandırılabilirliğin alanını hazırlık hareketlerine de sirayet ettirdiği için, maddi ceza hukuku ile önemli bir ilişkisi bulunmaktadır³. Örgütlü suçluluk bağlamında, suç işlemek için örgüt kurmaktan, yönetmekten veya bu örgüte üye olmaktan ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemekten söz edilebilir. Bu yönü itibarıyla da örgütlü suçluluğun maddi ceza hukuku ile ilişkisi vardır.

Örgütlü suçluluğun ceza muhakemesiyle de önemli bir ilgisi bulunmaktadır. Bir suç olgusunun “örgütlü suçluluk”la ilişkilendirilmesi, özellikle soruşturma evresinde koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemleri bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan suç olgusunun “örgüt”le ilişkilendirilmesi, ceza muhakemesi hukukunda bir bakıma “*maymuncuk*” olarak işe yaramaktadır. Bireysel suçlar bakımından işletilemeyen soruşturma ve delil toplama yöntemleri, başvurulamayan koruma tedbirleri, kullanılamayan yetkiler, suçun bir “örgüt”le ilişkilendirilmesi halinde, rahatlıkla işletilebilmektedir.

Suçun örgütle ilişkilendirilmesinin yaptırım hukuku bakımından da önemli sonuçları bulunmaktadır. Suç işlemek için örgüt kuran, yöneten veya bu örgüte üye olan ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işleyen kişi, “*örgüt mensubu suçlu*” (TCK, m. 6, f. 1, bent j) kabul edilecektir. Bu kişinin mahkûm olduğu ceza, diğer hükümlülere nazaran daha ağır şartlarda infaz edilecektir (Bkz. 5275 s. İnfaz K, m. 107, 108).

Suç olgusunun daha soruşturmanın başlangıcında “örgüt”le ilişkilendirilmesi, kişilerin suça karşı korunmasından ziyade, ceza muhakemesi müessesesele-

¹ Kavramla ilgili açıklama için bkz. DEGEN, Andreas: *Gesetzliche Mitwirkungspflichten der Kreditwirtschaft bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung, Eine verfassungsrechtliche Betrachtung aus Sicht der Bankkunden am Beispiel des Konten Screenings und des Kontendatenabrufverfahrens*, Frankfurt am Main, 2009, sh. 44 vd.

² Örgütlü suçluluğun en önemli özelliklerinden biri, kamu gücüne nüfuz etme çabasıdır. Örgüt mensubu kişiler tarafından, örneğin yolsuzluk bataklığına çekilmek suretiyle kamu görevlileri üzerinde nüfuz kullanılmaya çalışılmaktadır (DEGEN, sh. 59).

³ DEGEN, sh. 52.

rinin genel olarak toplumu izleme enstrümanları olarak kullanılmasına yol açmaktadır⁴.

Unutmamak gerekir ki, suçla ve suçlulukla mücadele amacı yalnız başına, soruşturma ve kovuşturmada izlenen yöntemlerin meşruluğunu sağlamaz. Ceza hukukunun amacı suçu önlemeye hasredilemez. Ceza hukuku, kişilerin hak ve hürriyetlerini aynı zamanda devlete karşı güvence altına almaktadır. Zira **hukukla sınırlandırılmayan devlet gücü, kolaylıkla organize suçluluk enstrümanı haline dönüşebilir**. Günümüzde yaşanan olaylar, bu tespitin açık kanıtıdır.

Bu itibarla, **tamamlanmış veya en azından teşebbüs aşamasında kalmış suçlardan soyut olarak suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından söz edilemez**. Böyle bir anlayış, ancak niyet okuma şeklinde tezahür edebilir.

Olması gereken, **işlenmiş olan birden fazla muhtelif suçlardan hareketle örgütün varlığının tespit edilmesi ve kişilerin kurucu, yönetici veya üye olarak sorumluluğu cihetine gidilmesidir**. Aksi takdirde, örgütten hareketle somut birtakım suçların işlendiği yargısına varılması halinde, insanlığın çok acı tecrübelerle kurtulmaya çalıştığı itham sistemine geri dönmüş olacaktır.

Keza, ticari alanda faaliyet icra etmek üzere kurulmuş olan bir şirketin faaliyeti çerçevesinde bir veya müteaddit sayıda suç işlenmiş olsa bile, şirket yapısının gerekli kıldığı ilişkinin dışında bir hiyerarşik yapılanmanın, bir üst ilişkisinin bulunmadığı durumlarda, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından söz edilemez. Aksi takdirde, yani ticari faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olan her suçtan hareketle, olayda ayrıca suç işlemek için kurulmuş örgütün varlığını kabul etmek gerekir ki, bu durum hukuk toplumu bakımından katlanılmaz sonuçların doğmasına sebebiyet verir.

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak, bu amaçla kurulmuş örgütü yönetmek ve bu örgütlere üye olmak, TCK'nın 220. maddesinde, işlenmesi amaçlanan suçlardan bağımsız suçlar olarak tanımlanmıştır.

Örgüt teşkili, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir **araç** niteliğindedir. Suç işlemek için örgüt kurmak, teşekkül meydana getirmek, top-

⁴ DEGEN, sh. 54.

lumda hakim olan düzeni **tehlikeye** maruz bırakmaktadır. İşte bu tehlike nedeniyledir ki, kanun koyucu esasta **hazırlık hareketi** niteliğindeki davranışları suç haline getirmiş ve suç işlemek için örgüt kurulmasını, işlenmesi amaçlanan suçlardan **bağımsız bir suç** olarak düzenlemiştir⁵.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı, kurulmuş örgütü yönetmeyi, bu örgüte üye olmayı suç olarak tanımlamakla korunan hukuki değer, esas itibarıyla **kamu güvenliği ve barışıdır**. Kamu güvenliği ve barışının bozulması ise, **bireyin güvenli, barış içinde yaşamak hakkını** da zedeleyecektir. Söz konusu fiilleri suç olarak tanımlamak suretiyle, bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik eylemlere karşı da korunması amaçlanmaktadır⁶.

Nitekim 220. maddenin **gereğince**inde, bu suç tanımı ile korunan hukuki değer bağlamında şu açıklamalara yer verilmiştir⁷:

*“Örgüt kurmak, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğindedir. Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, suç örgütü, amaçlanan suçları işlemeye bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından **hazırlık hareketi** niteliğinde olan bu fiiller, **ayrı suçlar** olarak tanımlanmıştır.*

*Bu suç tanımı ile korunan hukukî değer, **kamu güvenliği ve barışıdır**. Kamu güvenliği ve barışının bozulması ise, **bireyin güvenli, barış içinde yaşamak hakkını** da zedeleyecektir. Bu nedenle söz konusu düzenlemeyle aynı zamanda bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik fiillere karşı da korunması amaçlanmaktadır.”*

Söz konusu maddede, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla **örgüt kurmak veya yönetmek** ile, bu amaçla kurulmuş **örgüte üye olmak**, işlenmesi amaçlananlardan ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır.

Çalışmamızda bu suçların her biri ayrı ayrı incelenmektedir.

⁵ ÖZGENÇ, İzzet: *Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku*, in: 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu 22-23 Ekim 1998, Diyarbakır, sh. 180 vd. (224); aynı yazar: *Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, cilt LV, yıl 1997, sayı 3, sh. 51 vd.

⁶ ÖZEK, Çetin: *Organize Suç*, in: Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İstanbul, 1998, sh. 195 vd. Bu suçun koruduğu hukuki değer *kamu düzeni* olduğu yönündeki görüş için bkz. BAYRAKTAR, Köksal: *Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü*, İstanbul, 1997, sh. 96.

⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.

III. SUÇ İŞLEMELERİ AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU

A. Suçun Maddî Unsurları

TCK'nın 220. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suç, **kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak veya kurulmuş olan örgütü yönetmek** fiilleri oluşturmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu suç, **seçimlik hareketli** bir suçtur. Nitekim 220. maddenin gerekçesinde, bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir⁸:

“Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçu tanımlanmıştır. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmektir.”

Yukarıda da belirtildiği gibi, suç işlemek amacıyla örgüt kurulması, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından bir **hazırlık hareketi** mahiyetindedir.

Birinci seçimlik hareket, **kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmaktır**. Bu itibarla, söz konusu suçun oluşabilmesi için, oluşturulmuş bir örgütün, teşekkülün varlığı gereklidir.

Yapılanma biçimi ne olursa olsun, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla oluşturulmuş örgütlere; **suç örgütü** demekteyiz^{9,10}.

Suç örgütünün amaçlanan suçları işlemede sağladığı kolaylık, hem kemiyet, hem de keyfiyet itibarıyla. Amaçlanan suçları işlemek için ihtiyaç duyulan eleman ve malzeme, örgüt sayesinde kolaylıkla temin edilebilmektedir.

⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.

⁹ “Organize suçluluk” kavramı hakkında kriminolojik açıklamalar için bkz. SÖZÜER, Adem: *Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu Suçlulukla Mücadele İle İlgili Gelişmeler*, in: Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), cilt 9, yıl 1995, sayı 1-3, sh. 255 vd.

¹⁰ Özek'in kullandığı “organize suç” kavramının isabetli olmadığını düşünmekteyiz. Kriminolojik açıdan *organize suçluluk* kavramı kullanılabilir. Maddi ceza hukukunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan, kurulmuş örgütü yönetmekten, bu örgüte üye olmaktan ve bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemekten bahsedilebilir. Nitekim, yazar “organize suç” kavramıyla suç işlemek için teşekkül meydana getirilmesini kastetmekte ve tanımını buna göre yapmaktadır: «Birden fazla kişinin “hiyerarşik düzeyde”, “disiplinli”, “sürekli”, “kamu düzeni”ni bozduğu varsayılan “aynı amaca yönelik” suçları işlemek için oluşturulan örgütlenmedir.» (ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 195; aynı yazar: “Devletin Korunması”, “Terörle Mücadele Yasası” ve “Bilgilenme Hakkı”, in: Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, Edip F. Çelik’e Armağan, İstanbul 1995, s. 244 vd.).

Örgüt içinde bir araya gelen kişiler, bir dayanışma içinde oldukları için, amaçlanan suçları işlemekte tereddütsüzce, korkusuzca hareket edebilirler. Bu suçları işlemekte başarı gösteren kişiler, örgüt bünyesinde çeşitli suretlerde ödüllendirilmektedir, mükâfatlandırılmaktadır.

Örgüt, soyut bir birleşme olmayıp, bünyesinde **hiyerarşik bir yapının**, ast-üst ilişkisinin, emir-komuta zincirinin hakim olduğu yapılanmayı ifade eder. Böylece örgüt, mensupları üzerinde hakimiyet tesis eden bir güç kaynağı mahiyetini kazanmaktadır¹¹. Bu bağlamda, bir **organize güç aracından, organize güç enstrümanından** söz edebiliriz¹².

¹¹ Madde **gerekçesinde** bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Örgüt, soyut bir birleşme değildir, bünyesinde hiyerarşik bir ilişki hâkimdir. Bu hiyerarşik ilişki, bazı örgüt yapılanmalarında gevşek bir nitelik taşıyabilir. Bu ilişki dolayısıyla örgüt, mensupları üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

¹² “... suç işlemek için örgüt kurmak suçundan bahsedilebilmesi için,

a) Üye sayısının en az üç veya daha fazla kişi olması gerekmektedir.

b) Üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır. Örgütün varlığı için soyut bir birleşme yeterli olmayıp, örgüt yapılanmasına bağlı olarak gevşek veya sıkı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır.

c) Suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme yeterli olup, örgütün varlığının kabulü için suç işlenmesine gerek bulunmadığı gibi işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibarıyla somutlaştırılması mümkün olmakla birlikte, zorunluluk arz etmemektedir. Örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde, fail, örgütteki konumuna göre, üye veya yönetici sıfatıyla cezalandırılmasının yanında, ayrıca işlenen suçtan da cezalandırılacaktır.

d) Örgüt niteliği itibarıyla devamlılığı gerektirdiğinden, kişilerin belli bir suçu işlemek veya bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil ancak iştirak iradesinden söz edilebilecektir.

e) Amaçlanan suçları işlemeye elverişli, üye, araç ve gerece sahip olunması gerekmektedir.”: CGK, **3.4.2007**, E. 2006/10-253, K. 2007/80. Ayrıca bkz. CGK, **4.7.2006**, E. 2006/10-128, K. 2006/177; CGK, **31.10.2012**, E. 2011/10-577, K. 2012/1821; CGK, **2.5.2017**, E. 2016/5-1042, K. 2017/255.

TCK’nın 220. maddesinde tanımlanan suçların “işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için, üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil, gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmesi bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, (bu birleşmenin) niteliği itibarıyla devamlılık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da aranmalıdır. Soyut olarak sanık sayısının üç kişiden fazla olması, örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp, bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir. / Somut olayda; sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal yeterlikte oldukları anlaşılmakta ise de, aralarında hiyerarşik ilişki ve suç işleme iradelerinde devamlılık olduğuna ilişkin kanıtların neler olduğu denetime olanak sağlayacak şekilde karar yerinde açıklanıp gösterilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 220/1-2. maddeleri uyarınca yazılı şekilde uygulama yapılması,” bozmayı gerektirmiştir: 6. CD, 7.10.2008, E. 2007/23786, K. 2008/16408 (Gerçekler, Hasan: Türk Ceza Kanunu, Ankara 2011, sh. 2571). Ayrıca bkz. 6. CD, 7.2.2008, E. 2008/4964, K. 2008/14382 (Gerçekler, TCK, sh. 2593).

“5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen ‘suç işlemek için örgüt kurmak’ suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması,

Suç örgütünün varlığından söz edebilmek için belli bir amaç, maksat etrafındaki **fiili birleşme** yeterlidir. Bu örgütler, mahiyetleri itibarıyla, **devamlılık** arzederler^{13,14}. Bu itibarla, belli bir suçu işlemek için bir araya gelme halinde bir suç örgütünün varlığından bahsedilemez. Böyle bir durumda suç ortaklarının sorumluluk rejimi, Suç Teorisinin iştirake ilişkin hükümlerine göre tayin edilir. İştirak ilişkisinden bahsedebilmek için, suç ortakları nezdinde suçun, konu veya mağdur itibarıyla somutlaşması gerekir. Yani, suç ortaklarının hangi nesneye veya kime karşı suçu işleyeceklerini kendi aralarında tayin etmeleri gerekir. Buna karşılık, suç örgütünden söz edebilmek için örgüt mensuplarınca işlenecek suçların konu veya mağdur itibarıyla tayin edilmesi zorunlu değildir¹⁵.

Bu genel ayırıma rağmen, her somut olayda bir suç örgütünün var olup olmadığı, hakim takdir ve tayin edecektir. Bu takdir ve tayin yapılırken işlenen veya işlenmesi amaçlanan suçlar, bir araya gelen insan sayısı, suç işlemeye kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulmuş malzeme gibi somut dayanak noktaları dikkate alınmalıdır¹⁶.

Keza, kamu kurumlarının bünyesinde Anayasa, kanun ve sair mevzuatla belirlenmiş olan ve bu nedenle **yasal bir hiyerarşik ilişki** mevcuttur. Bu itibarla

üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmesi bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibarıyla devamlılık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da aranmalıdır. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibarıyla somutlaştırılması mümkün, ancak zorunlu değildir. Soyut olarak sanık sayısının üç kişi veya daha fazla olması örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir.”: 6. CD, 9.6.2009, E. 2009/1030, K. 2009/10354 (Gerçekler, TCK, sh. 2573 vd.).

¹³ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh. 52; aynı yazar, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 225; ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 197.

¹⁴ Ancak, belirtelim ki; Yargıtay, bir kararında cürüm işlemek için teşekkül oluşturulmasını mütemadi suç olarak kabul etmemiştir:

«Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçu, mahkemenin değerlendirdiği kriterlerde mütemadi suç özelliği taşımamaktadır.»: 8.CD., 9.7.1998, 8817/10786 (Ünver, M. Naci: *Uygulamada Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ve Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak*, Ankara, 2001, sh. 84 vd.).

Kanımızca bu karar isabetli değildir.

¹⁵ Madde **gerekçesinde** bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Örgütün varlığı için suç işlemek amacı etrafındaki fiili birleşme yeterlidir. Örgüt, niteliği itibarıyla, devamlılık arzeder. Bu itibarla, kişilerin belli bir suçu işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgüt değil, iştirak ilişkisi mevcuttur. İştirak ilişkisinden bahsedebilmek için, suç ortakları nezdinde suçun, konu veya mağdur bakımından somutlaşması gerekir. Buna karşılık, örgüt yapılanmasında, işlenmesi amaçlanan suçların konu veya mağdur itibarıyla somutlaştırılması zorunlu değildir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

¹⁶ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh. 52; aynı yazar, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 225.

kurum bünyesinde istihdam edilen kamu görevlileri arasında söz konusu hiyerarşiye uygun bir ilişki biçimi mevcut ise, burada suç işlemek için oluşturulmuş bir örgütten söz edilemez. Ancak, bu kişiler arasında **mevzuatla belirlenenin dışında bir hiyerarşik yapılanma** meydana gelmiş ise, suç işlemek için bir örgütlenmeden söz edilebilir. Ancak, bu yasal hiyerarşinin dışında bir ilişki biçiminin varlığının kabulü için somut dayanak noktalarının bulunması gerekir. Bu itibarla, bir kamu kurumunda mevcut olan yasal hiyerarşik ilişkinin gereklerine uygun hareket edildiği sürece, kamu görevlilerinin suç işlemek için örgüt kurduklarından söz edilemez. Şayet kamu görevlileri tarafından görevleri dolayısıyla işlenmiş suçlar söz konusu ise; bu durumda, ancak, kamu görevlilerinin hiyerarşik yapılanmadan kaynaklanan nüfuzlarını kötüye kullanmak suretiyle, söz konusu suçları işledikleri kabul edilebilir^{17, 18}.

¹⁷ Türkiye’de **genelkurmay başkanlığı** görevini yapmış ve bu görevden yaş haddinden emekli olarak ayrılmış olan bir kişinin, görevi başında iken terör örgütünün yöneticisi olarak faaliyet icra ettiğini iddia etmek, bir **akıl tutulması**nın yansımasıdır. Bu iddia, Cumhuriyet savcılığı görevi ile bağdaşır bir yaklaşım çerçevesinde yapılan bir değerlendirme sonucu varılan bir kanaat ürünü değildir. Aynı değerlendirme, söz konusu iddianın yer aldığı iddianameyi kabul eden hakimlerin kararı bakımından da geçerlidir.

İlgili davanın sanığı olan kişiyi, toprak altından çıkarılan bazı askeri mühimmat arasında yer alan havan toplarını, bu nedenle başlatılan soruşturmalar devam ederken televizyonlarda yaptığı açıklamalarla “su” veya “soba borusu”na benzetmekle, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten dolayı suçlayabilir ve yargılayabilirsiniz. Keza, bahsi geçen kişiyi, “darbe planı” olduğu ileri sürülen çeşitli askeri belge ve kaydı, bu nedenle başlatılan soruşturmalar devam ederken televizyonlarda yaptığı açıklamalarla “kağıt parçası”na benzetmekle, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten dolayı suçlayabilir ve yargılayabilirsiniz. Ama terör örgütünün yöneticisi olmaktan dolayı asla. Aksi takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bu devletin kurum ve kuruluşları arasında uyumlu çalışmayı sağlamakla görevli kamu otoritelerinin varlığını inkâr etmiş olursunuz.

Bahsi geçen kişinin terör örgütünün yöneticisi olmaktan dolayı tutuklanması yönünde verilen kararlar da, hukuken sorunludur. Bahsi geçen kişi, sadece genelkurmay başkanı olarak görev yaptığı sırada, genelkurmay başkanı olarak görev yaptığı sürece terör örgütünün yöneticisi olmakla suçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, iddianameye göre suçun işlendiği zaman, bahsi geçen kişinin genelkurmay başkanı olarak görev yaptığı süredir. Buna karşılık, bahsi geçen kişi, yaş haddinden emeklilik dolayısıyla genelkurmay başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonraki evre ile ilgili olarak terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanmamaktadır. Edindiğimiz izlenime göre, bahsi geçen kişinin, genelkurmay başkanlığı görevinden yaş haddinden emeklilik dolayısıyla ayrılması, “terör örgütü yöneticiliğinden de ayrılma sebebi” (?) olarak değerlendirilmiştir.

Hemen belirtmemiz gerekir ki, yetkili kamu otoritesi olarak **Hakimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu**, bu sorunla ilgili olarak kendisine terettüp eden **görevi yerine getirmemiştir**.

Eğer **hukuk siyasal gücün elinde bir araç durumuna irca edilirse**, suyun yükselişine veya çekilişine göre, haksızlığa uğrayan kişiler değişmekle birlikte, aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz:

Sular yükselince, balıklar karıncaları yer... Sular çekilince de karıncalar balıkları... Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir... Çünkü kimin kimi yiyeyeceğine, "suyun akışı" karar verir. (Afrika atasözü)

¹⁸ Bazı yargılar vardır, yargılama mevkiinde olmayan kişiler tarafından ifade edilir. Bu durumda “ben olsam bu kararı vermezdim” veya “ben olsam şu şekilde karar verirdim” denebilir. An-

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, mahiyet itibarıyla **çok failli** bir suçtur. Yani, bu suç, mahiyeti gereği ancak birden fazla kişinin fail olarak katılımıyla gerçekleşebilir¹⁹. Çok failli bir suç olan suç işlemek için teşekkül meydana getirilmesi, bir *tekarüb, yakınsama suçudur (Konvergenzdelikt)*.

Yakınsama suçunda, zorunlu olarak suçun işlenişine katılımda bulunan kişiler, aynı yönden hareket etmektedirler ve aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, ancak çok sayıda kişinin *fail* olarak katılımıyla gerçekleşebilen bir suçtur²⁰. Bu tür suçlarda suçun işlenişine zorunlu olarak katılması gereken kişilerin hepsi, işlenen suçtan fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Bunlar arasındaki ilişki, müşterek faillığe benzenmektedir. Yani, bütün bu kişiler, suç teşkil eden haksızlığın gerçekleşişi üzerinde müşterek hakimiyet kurmaktadır. Ancak, müşterek faillğin söz konusu olduğu suçlar bir kişi tarafından dahi işlenebildiği halde; yakınsama suçları ancak çok sayıda kişinin iştirakiyle gerçekleşebilmektedirler. Yakınsama suçlarının bu özelliği, söz konusu suçlara şerik olarak iştirak etmeye engel değildir. Bu suçlara azmettiren veya yardım eden olarak iştirak, her zaman mümkündür. Dikkat edilmelidir ki; söz konusu suçların işlenişine şerik (azmettiren veya yardım eden) olarak iştirak eden kişi(ler), örgüt kurma suçunun oluşumu için katılımı zorunlu olan failler haricindeki kişi(ler)dir.

Kanun “*örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.*” (m. 220, f. 1, ikinci cümle) demek suretiyle, örgütü oluşturacak kişi sayısının en az üç olmasını aramıştır. Böylece, mülga 765 s. TCK’dan farklı olarak iki kişi bir araya gelerek cürüm işlemek için örgüt oluşturamayacaklardır²¹.

Örgütü oluşturacak asgari kişi sayısı Kanunda belirlenmiş olmakla birlikte, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, **somut bir tehlike suçu**²² olduğu için,

cak yargı faaliyetini icra eden hakim ve savcılar üzerinde görevlerini hukuka uygun olarak icra etme konusunda gözetim görev ve yetkisi bulunan bir kurulun yetkilisi sıfatıyla basın aracılığıyla bu kabil açıklamaların yapılması doğru değildir. Buna rağmen, “ben olsam tutuklamazdım” kabilinden yapılan açıklama, açık bir **yalanı** ve toplumu oluşturan bireyleri hafife almayı ifade eder.

¹⁹ ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, *Cumhur: Uygulamalı Ceza Hukuku*, 3. bası, Ankara, 2000, sh. 319 vd., 466; ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 226; ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 211.

²⁰ Bkz. TCK., m. 313; 168; 403, bend 10: en az iki kişi (m. 313, f. 6; m. 403, bend 11).

²¹ Mülga 765 s. TCK’da “*Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur*” (m. 313, f. 6) denilmek suretiyle, örgütü oluşturacak kişi sayısının en az iki olması aranmıştı.

²² Bkz. ÖZEK, Çetin: *Terör ve “Terörle Mücadele Kanunu”*, in: İstanbul Barosu Dergisi (İBD), cilt 65, yıl 1991, sayı 4-5-6, sh. 363; aynı yazar, Kunter Armağanı, sh. 195; ayrıca, ÖZGEN,

oluşturulan örgütün, gerek üye sayısı gerek malzeme donanımı itibarıyla, güdülen amaçları gerçekleştirme açısından somut bir tehlike arz edip arz etmediği, hakim tarafından yapılacak değerlendirmeye belirlenecektir²³. Şöyle ki; meselâ sadece üç kişinin bir araya gelmesi, devletin ülke bütünlüğünü bozmaya matuf suçlar açısından somut bir tehlike arz etmeyebilir (!); buna karşılık, ekonomik çıkar teminine matuf suçların işlenmesine yönelik bir teşekkül olarak fevkalade tehlikeli bir mahiyet arz edebilir²⁴. Nitekim Kanunda, “**örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde,**” suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçunun oluşabileceği kabul edilmiştir (m. 220, f. 1).

Madde gerekçesinde bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir²⁵:

“Suç işlemek için örgüt kurulması bir somut tehlike suçudur. Her ne kadar en az üç kişinin²⁶ belli amaç etrafında suç işlemek üzere devamlı surette fiilen birleşmesi suretiyle örgüt meydana gelebilir de; kurulan örgüt, güdülen amaç bakımından somut bir tehlike oluşturmaya bilir. Bu nedenle, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması aranmalıdır. Bu bakımdan, örneğin sadece üç kişinin bir araya gel-

Eralp: *Terörizmle Mücadele Yasasının Değerlendirilmesi*, in: İstanbul Barosu Dergisi (İBD), cilt 65, yıl 1991, sayı 4-5-6, sh. 402; Yargıtay 5.CD, 17.1.2014, E. 2013/16791, K. 2014/516.

²³ Suç işlemek için teşekkül meydana getirilmesinde «hukuka aykırı fiil ... salt "amaç" olmayıp, amaç etrafında örgütlenmenin yaratabileceği "somut zarar tehlikesi" olduğuna göre; "örgüt yapısı", somut "zarar tehlikesi yaratacak" nitelikte olmalıdır. Bu nedenledir ki, her somut olayda, örgüt yapısının, korunan "hukukî yarar" açısından, somut zarar tehlikesini oluşturmaya uygunluğu için, "amacı gerçekleştirmeye yeterli üye"nin, "hiyerarşik örgüt yapısı"nın, "şiddete dayanan eylem programı"nın varlığı aranmak gerekir.» (ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 228/229).

²⁴ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh. 52; aynı yazar, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 227; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 132/133, 466/467.

²⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.

²⁶ TBMM Adalet Alt Komisyonunda kabul edilen madde metninde, örgütü oluşturabilecek asgari üye sayısı belirlenmemiştir. Ancak, TBMM Adalet Komisyonunda yapılan müzakereler sırasında örgütü oluşturabilecek asgari üye sayısının madde metninde belirlenmesi gerektiği yönünde bir irade oluşmuştur. Bu iradeye uygun olarak, söz konusu maddenin birinci fıkrasının sonuna “Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.” cümlesi eklenmiştir (TBMM, Adalet Komisyonu Müzakere Tutanakları, tarih 6.7.2004, sh. 71-73). Madde metninde bu yönde bir değişiklik yapılmakla birlikte, madde gerekçesinde yer alan “Madde metninde, suç işlemek amacıyla yönelik örgütün varlığı için asgari üye sayısı belirlenmemiştir.” şeklindeki cümlenin gerekçeden çıkarılması gözden kaçırılmıştır.

mesi, devletin ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik suçları işleme açısından somut bir tehlike taşımaz; buna karşılık, ekonomik çıkar sağlamaya yönelik suçlar açısından elverişli olabilir.”

Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün silahlı olup olmaması veya sahip olunan silahların cins, nitelik ve miktarı, bu **somut tehlikenin belirlenmesinde** dikkate alınmalıdır²⁷. Ancak, belirtmemiz gerekir ki; Kanun koyucu, suç işlemek için teşkil edilen örgütün **silahlı** olmasını bu suç bakımından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak öngörmüştür (m. 220, f. 3)²⁸. Silahlı olmak, örgütün önemli bir özelliği olarak tezahür etmektedir. Örgüt mensuplarının silahlar üzerinde tasarruf imkânının olması gerekli ve yeterlidir^{29,30}.

Suç örgütünün oluşabilmesi için fiilî birleşme yeterlidir. Ancak, muvazaalı bir şekilde mevzuat çerçevesinde kurulmuş siyasî parti, sendika, dernek, vakıf ve şirket görünümündeki oluşumlar da, suç örgütü mahiyeti arzedebilirler³¹. Şöyle ki; yürürlükte olan mevzuata göre kurulan bir teşekkül bünyesinde bilahare sistemli bir şekilde suç işlenebilir; bu teşekküller, suç faaliyetinin icrasında bir şemsiye görevi icra etmiş olabilir. Ancak, hukuka uygun bir şekilde kurulmuş olan ve hukuka uygun amaçlar çerçevesinde faaliyet icra eden bu teşekküller bünyesinde işlenmiş olan münferit suç vakıaları dolayısıyla bunları bir “suç örgütü” kabul etmek mümkün değildir³².

²⁷ EREL, Kemalettin: *Yargıtay Kararları Işığında Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK. m. 220)*, in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich, Yayına hazırlayanlar/Hrsg. HILGENDORF, Eric/ÜNVER, Yener; Yeditepe Üniversitesi yayını, İstanbul 2010, sh. 389.

Buna karşılık, Alman hukukunda söz konusu suç, bir *soyut tehlike suçu* olarak değerlendirilmektedir (KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, 12. Auflage, Berlin/New York, 2010, § 129, kn. 4).

²⁸ Madde **gereğince** bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Üçüncü fıkraya göre, örgütün silâhlı olması, bir ve ikinci fıkrafta tanımlanan suçların daha ağır ceza ile cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Suç örgütünün silâhlı olup olmaması veya sahip olunan silâhların cins, nitelik ve miktarı, **somut tehlikenin belirlenmesi** veya var olan **somut tehlikenin ağırlığı** bakımından dikkate alınmalıdır.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

²⁹ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 17.

³⁰ EREL, sh. 392.

³¹ Nitekim bkz. ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 221.

³² ÖZGENÇ, İÜHFMLV(1997), sh. 52/53; aynı yazar, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 228; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 467; SÖZÜER, Adem: *Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Muhakemesi Tedbirleri* (yayınlanmamış Doçentlik Çalışması), İstanbul 2000, sh. 100.

Birinci fıkrada tanımlanan suçu oluşturan ikinci seçimlik hareket ise, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan **örgütü yönetmektir**. Yönetmek fiili, **temadi eden (kesintisiz)** bir fiildir. Bu nedenle, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün yönetilmesi halinde, **kesintisiz (mütemadi) suç** söz konusu olmaktadır. Suç işlemek amacına yönelik olarak örgüt kuran kişiler aynı zamanda örgütü yönetmeyi üstlenmektedirler. Bu durumda, seçimlik hareketler olarak kurmak ve yönetmek fiilleri birlikte gerçekleşmektedir. Ancak, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgütün yönetimi bilahare, yani örgüt kurulduktan sonra da, deruhte edilmiş, üstlenilmiş olabilir³³.

B. Suçun Manevî Unsurları

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulmuş örgütü yönetme suçu, **kasten** işlenebilen bir suçtur. Ancak, bu suç aynı zamanda bir **amaç suç** niteliği taşımaktadır. Kişiler, **suç işlemek amacıyla** örgüt kurmakta veya yönetmektedirler. Başka bir deyişle, örgütü kuran veya yöneten kişiler, kime karşı, nerede ve ne zaman işleneceği henüz belli olmayan birtakım suçları işlemeyi amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla, bu suçun oluşumu için **doğrudan kastın** varlığı gerekmektedir. Bu suç, kanımızca, olası kastla işlenemez³⁴.

Bu itibarla, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulmuş örgütü yönetme, işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından bir **hazırlık hareketi** mahiyetini taşımaktadır³⁵.

Örgütün varlığı için suç işlemek amacının açık bir şekilde ortaya konuluş olması gerekir. Bu itibarla, örneğin bir ticari faaliyet için bir araya gelmiş

³³ Mülga 765 s. TCK'nın sisteminde, kurulmuş olan örgütün yöneticisi olmak, bu suçtan ayrı bir suç olarak tanımlanan örgüt kurma suçuna nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmaktaydı (m. 313, f. 4).

Bu düzenlemede Kanun koyucu, suç işlemek için örgüt kurmasının yanı sıra bu örgütün yöneticisi olması halinde, faile, her iki fiilden dolayı ayrı ayrı ceza verilmesini uygun görmemiş, örgüt kurmak suçundan dolayı verilecek olan cezanın belli oranda artırılmasını öngörmüştü (m. 313, f. 4).

³⁴ Kişinin katıldığı örgütün, suç işlemek amacıyla oluşturulduğu ve silahlı örgüt olduğu hususunda kasten hareket etmesi gerekir. Örgütün bu özelliklerine yönelik kast, doğrudan kast veya olası kast şeklinde tezahür edebilir. KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, §127, kn. 28.

³⁵ Nitekim, bkz. yukarıda dn. 8'deki kararlar. Ancak, *Özek*, suç işlemek için teşekkül meydana getirilmesini işlenmesi amaçlanan suçlar açısından bir hazırlık hareketi olmadığını iddia etmektedir. Buna karşılık, mülga 765 s. TCK'nın 168. maddesindeki silahlı çete teşkili suçunun işlenmesi amaçlanan suçlar açısından bir hazırlık hareketi olduğunu ve bu nedenle, bir "organize suç" niteliğini taşımadığını iddia etmektedir (ÖZEK, Kunter Armağanı, sh. 198).

olan kişilerin aralarındaki işbirliği çerçevesinde bazı suçların işlenebileceği ihtimalini öngörmüş olmaları, suç işlemek için örgüt kurma suçunun manevi unsurlarından amaç unsurunun varlığı için yeterli bulunmamaktadır³⁶. Suç işlemek amacının örgüt mensuplarının ortak amacı olarak belirlenmesi gerekir. Bu itibarla, örgütün yöneticisi suç işlemek amacıyla hareket etmekle birlikte, örgütün diğer mensuplarının bu amaçtan habersiz olmaları halinde, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından söz edilemez³⁷.

Bir oluşumun çekirdeğini oluşturan kişiler suç işlemek amacıyla hareket etmekle birlikte, oluşumun içinde yer alan ve fakat bu amaçtan habersiz olan kişiler, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüte üye olmaktan veya bu örgütü yönetmekten sorumlu tutulamazlar³⁸.

IV. SUÇ İŞLEMELERİ AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU

A. Suçun Maddi Unsurları

TCK'nın 220. maddesinin ikinci fıkrasında ayrı bir suç tanımı yapılmıştır. Bu fıkra hükmüne göre, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak, birinci fıkradaki suça nazaran **müstakil** bir suç oluşturmaktadır³⁹.

Örgüt üyeliği, daha önce kurulmuş olan bir örgüte iltihak, katılma şeklinde gerçekleşebilir. Örgüte üye olmak, **fiilî bir katılmayı** ifade eder. Üyelik için meselâ bir formun tanzimi gibi şeklî birtakım hususların gerçekleşmesi aranmaz. Üyelik için örgüt yöneticilerinin rızasının varlığına gerek yoktur. **Tek taraflı iradeyle** örgüte katılmak mümkündür⁴⁰.

³⁶ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 71.

³⁷ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 72.

³⁸ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 72.

³⁹ Alman Ceza Kanununda örgüte üye olmak, örgüt kurmak veya örgütü yönetmek fiillerinin yanında bir **seçimlik hareket** olarak belirlenmiştir (§ 129, f. 1).

⁴⁰ Ancak, Yargıtay aksi yönde içtihatla bulunmuştur:

“Yerleşik yargısal kararlarda belirlenen ilkelere göre, failin salt silahlı örgüte ilgi duyması, örgüte katılmak için zemin arayışına girmesi, bu amaçla kendisini örgüte ulaştırabilecek kişilerle temasa geçmeye çalışması ve **örgüt mensuplarıyla görüşüp buluşmadan** salt örgüte katılmak amacıyla başka bir bölgeye yolculuk yapması silahlı örgüt üyeliği suçunun oluşumu için yeterli değildir.” CGK **10.6.2008**, E. 2007/9-270, K. 2008/164. Ayrıca bkz. BGH, Urteil vom 14.8.2009, 3 StR 552/08, kn.13.

“Tek taraflı irade beyanıyla örgüte üye olmak imkânı bulunmamaktadır. (Örgüt üyeliği için.) örgüt yönetiminin açık ya da zımni bir kabulü olmalıdır.”: Yargıtay 16. CD, **5.7.2019**, E. 2019/521, K. 2019/4769.

Örgüt üyeliği, yönetmek fiili gibi, **temadi eden (kesintisiz)** bir fiildir. Bu nedenle, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte katılma halinde, **kesintisiz (mütemadi) suç** söz konusu olmaktadır ve suç, örgütün hiyerarşik yapısına bağlılık devam ettiği sürece işlenmeye devam edilmektedir. Örgütün hiyerarşik yapısına bağlılığın sona erdiği anda mütemati bitmiştir.

Ancak, önemle belirtelim ki; suç örgütünün bir güç, bir hakimiyet kaynağı olması ve örgüt içinde mevcut hiyerarşik yapı (**organize güç aracı**, organize güç enstrümanı) nedeniyle; kişilerin örgüte katılırken serbest iradeleriyle hareket ettiklerini söylemek, her zaman mümkün değildir. Bu husus, aşağıda açıklanacağı üzere, kusurluluk açısından göz önünde bulundurulmalıdır⁴¹.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme suçunun maddi unsurları kapsamında örgüt kavramı ile ilgili olarak yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar, bu suç bakımından da aynen geçerlidir.

B. Suçun Manevî Unsurları

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme suçunun manevî unsuru ile ilgili olarak yukarıda yaptığımız açıklamalar, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçu bakımından da geçerlidir. Tekrar belirtelim ki, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olan kişinin, bu **örgütün suç işlemek amacına yönelik olarak bir faaliyet icra ettiğini bilmesi** gerekir. Bu durumda söz konusu olan kast, kanımızca ancak **doğrudan kast** olabilir⁴².

C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu

Kanaatimizce Kanunda, kusurunun azlığını veya örgütün faaliyetine katkısının önemsizliğini dikkate almak suretiyle örgüt üyesine verilecek olan cezada indirim yapmak veya hiç ceza vermemek hususunda mahkemeye takdir yetkisinin tanınması gerekir. Ancak bunun için, kişinin örgütün faaliyeti çerçevesinde bir suç işlememiş veya işlenen suça iştirak etmemiş olması gerekir. Alman Ceza Kanununda mahkemeye, **örgüte katılan kişiye kusurunun azlığı veya örgütün faaliyetine katkısının önemsizliği nedeniyle ceza vermekten sarfınazar etme yetkisi** tanınmıştır (§ 129, f. 5).

⁴¹ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh. 53; aynı yazar, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 229/230.

⁴² ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 230; Yargıtay 16. CD, **2.3.2018**, E. 2018/588, K. 2018/718; Yargıtay 16. CD, **5.7.2019**, E. 2019/521, K. 2019/4769.

Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkûmiyet Sorunu ve Türk Uygulaması

Türk Ceza hukuku sistemi, alelîtlak örgüt üyeliğinden cezalandırılmaya müsait düzenleme içermemektedir. Türk ceza hukuku sisteminde, örgüt üyesi olmak dolayısıyla mahkûmiyet için,

a) örgütün faaliyeti çerçevesinde veya örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak (“örgüt adına”) bir **suç işlemesi**,

ya da

b) örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bu özelliğini bilerek ve isteyerek yardım etmesi,

gerekmektedir.

TCK ve TMK düzenlemeleri, bu fiiller olmadan örgüt üyeliğinden mahkûmiyete asla izin vermemektedir. Bu nedenledir ki, İnfaz Kanununda, örgüt üyeliğinden mahkûmiyet haline özgü olarak koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından bir hükme yer verilmiştir (m. 107, f. 4). Bu, bilinçli bir tercihtir⁴³.

V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgüte üye olmak fiillerinin cezalandırılabilmesi için, ayrıca örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmiş olması şart değildir. Ayrıca suç işlemesi halinde, örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olan kişi, hem 220. maddenin birinci veya ikinci fıkralarında tanımlanan suçlardan birinden, hem de örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlediği suçtan dolayı **gerçek içtima** kurallarına göre cezalandırılacaktır⁴⁴. Nitekim TCK’nın 220. maddesinin dördüncü fıkrasında,

⁴³ Belirtmek gerekir ki, Yargıtay, terör örgütüne yardım etmekten dolayı mahkûm edilen hükümlünün koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için mahkûm olduğu cezanın dörtte üçünü çekmesini gerekli görmekle beraber, bu hükümlü hakkında örgüt mensubu suçlu olarak denetimli serbestlik tedbiri **uygulanmamasına** karar vermiştir: Yargıtay 16. CD, 20.3.2017, E. 2016/4479, K. 2017/1161.

Keza, Yargıtay, terörizmin finansmanı suçundan mahkûm olan hükümlü hakkında da, örgüt mensubu suçlu olarak denetimli serbestlik tedbiri **uygulanmamasına** karar vermiştir: Yargıtay 16. CD, 17.5.2017, E. 2016/4762, K. 2017/4768.

⁴⁴ ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuku, sh. 228; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 468.

“Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.”

hükmüne yer verilmiştir⁴⁵.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, TCK’da tanımlanan çeşitli suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu suçların temel şekline nazaran daha ağır cezaya hükmolunacaktır⁴⁶. Bu durumda, kişi, (1) suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçundan ya da kurulmuş olan örgüte üye olmak suçundan dolayı, (2) örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği suçtan dolayı, mahkûm edilecektir; ayrıca, (3) kişiye örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği suçtan dolayı verilen ceza belli oranda artırılacaktır.

Örgüt yöneticilerinin, örgütün yönetimini elinde bulundurdukları süre zarfında örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olan suçlar dolayısıyla nasıl sorumlu tutulacağı hususu da ayrı bir sorun oluşturmaktadır.

Doktrinde bir görüş, suç işlemek için oluşturulmuş örgütteki işleyiş mekanizmasını dikkate alarak, yöneticilerin örgütün faaliyeti zımınında işlenen suçlardan dolayı sorumluluğunu iştirak ilişkisinden farklı bir şekilde izah etmek yoluna gitmiştir. Şöyle ki, bu örgütler öyle düzenli, sistemli işlemektedirler ki, kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun bir görev verilen kişi bu görevini yerine getirmezse, hemen yerine bir diğeri rahatlıkla

⁴⁵ Madde **gereğ**esinde bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Dördüncü fıkraya göre, örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacaktır. Bir veya ikinci fıkrada tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için, ayrıca örgütün amacı çerçevesinde bir suçun işlenmesi gerekmez. Örgütün faaliyeti çerçevesinde ayrıca suç işlenmesi hâlinde, hem bir veya ikinci fıkrada tanımlanan suçtan hem de amacı oluşturan suçtan dolayı gerçek içtima kurallarına göre cezaya hükmedilmelidir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

Ancak, mülga 765 s. TCK’da bu şekilde faile verilecek olan ceza miktarına bir sınırlama getirilmişti. Buna göre, *“verilecek cezaların toplamı, en ağır cezayı gerektiren fiilin cezasının azami haddini geçemez.”* (m. 313, f. 5). Yeni TCK’da böyle bir hükme bilinçli olarak yer verilmemiştir.

⁴⁶ **“Göçmen kaçakçılığı”** suçu bakımından TCK, m. 79, f. 2; **“Organ veya doku ticareti”** suçu bakımından TCK, m. 91, f. 4; **hırsızlık** suçunun konusunun **sıvı veya gaz halindeki enerji** olması ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde TCK, m. 142, f. 3, ikinci cümle; **“Dolandırıcılık”** suçu bakımından TCK, m. 158, f. 3, ikinci alternatif; **“Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”** suçu bakımından TCK, m. 174, f. 2; **“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”** suçu bakımından TCK, m. 188, f. 5; **“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”** suçu bakımından TCK, m. 282, f. 4.

ikame edilebilmektedir. Bu sistemli işleyiş mekanizması nedeniyle, her ne kadar fiili icra eden kişiler tamamen sorumlu failer olarak dikkate alınsalar da; örgütün bu işleyiş mekanizmasını elinde bulunduran kişiler, yani yöneticiler, "*dolaylı fail*" olarak sorumlu tutulacaklardır⁴⁷.

Ancak, bu durumda, suç teorisinin verilerinden ve özellikle iştirake ilişkin genel prensiplerden ayrılmaya gerek olmadığı kanısındayız. Şöyle ki, şayet örgütün işleyiş mekanizmasını elinde bulunduran yöneticiler suçun icraî hareketlerini gerçekleştiren kişiler üzerinde ve dolayısıyla, işledikleri fiiller üzerinde bir hakimiyet kuruyorlarsa, *dolaylı fail* olarak sorumlu tutulacaklardır. Buna karşılık, sadece fiilin işlenişleriyle ilgili planı yapıp, fiili icra edecek diğer suç ortaklarına talimat vermekle yetiniyorlarsa ve fakat, fiilin icrası aşamasında herhangi bir etkisi olmaksızın, olayın seyrini tamamen bunlara bırakıyorlarsa, *azmettiren* olarak sorumlu tutulacaklardır⁴⁸. Örgütün işleyiş mekanizmasını elinde bulunduranlar, fiilin işleniş planıyla yetinmeyip, diğer suç ortaklarına talimat verdikten sonra, ayrıca suçun icraî hareketlerinin gerçekleştirilişi sırasında, olay mahallinde olmamakla birlikte, diğer suç ortaklarını yönlendirmeleri, suçun işlenişini sevk ve idare etmeleri halinde, *müşterek fail* olarak sorumlu tutulacaklardır⁴⁹.

⁴⁷ "mittelbare Täterschaft kraft organisatorischer Machtapparate", "Organisationsherrschaft". Kavram, ilk defa Roxin tarafından ihdas edilmiştir: ROXIN, Claus: *Täterschaft und Taherrschaft*, 4. Auflage, Berlin/ New York, 1984, sh. 242-252, 612/613; aynı yazar, *LEIPZIGER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch*, 8. Auflage, 1957; 10 Auflage, 1978 ve müteakip yıllar, § 25, kn. 88-90; aynı yazar, *Bemerkungen zum "Täter hinter dem Täter"*, in: Festschrift für Richard Lange, 1976, sh. 173.

Roxin'in bu izahını benimseyen yazarlar: STRATENWERTH, Günter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat*, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn, 1981, kn. 791-792; CRAMER, Schöнке/Schröder (23), § 25, kn. 3; HERZBERG, Rolf Dietrich: *Mittelbare Täterschaft bei rechtmäßig oder unverboden handelndem Werkzeug*, Berlin, 1967, sh. 42 vd.; WESSELS, Johannes: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 19. Auflage, Heidelberg, 1989, sh. 159.

Roxin'in ihdas ettiği bu kavram, çeşitli yazarlarca değişik perspektiflerle ele alınıp izah edilmeye çalışılmıştır: SCHROEDER, Friedrich Christian: *Der Täter hinter dem Täter*, Berlin, 1965, sh. 166 vd.; SCHMIDHÄUSER, Eberhard: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 2. Auflage, Tübingen, 1975, § 14, kn. 50: "masabaşı faili" (= "Schreibtischtäter"). JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, 1988, sh. 607; SAMSON, *SYSTEMATISCHER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch*, 4. Auflage, 1983 ve müteakip yıllar, §25, kn. 36; kısmen JAKOBS, Günther: *Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, Berlin/New York, 1983, § 21, kn. 103: Müşterek faillik. BOCKELMANN, Paul/VOLK, Klaus: *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, München, 1987, § 24: "Yan yana müstakil faillik".

⁴⁸ Bkz. JAKOBS, Lb., § 21, kn. 103, dn. 190.

⁴⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suçta İştirakin Hukukî Esası ve Faillik*, İstanbul 1996, sh. 275, dn. 44; aynı yazar, İÜHFMLV(1997), sh.56.

Kanaatimizce, örgüt yöneticilerini, örgütün yönetimini elinde bulundurdukları süre zarfında örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olan suçlar dolayısıyla ayrıca sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak bu kişilerin örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde başkaları tarafından işlenen suçlardan dolayı sorumluluk statüsünü her somut suç bağlamında değerlendirip belirlemek gerekir.

Buna göre, örgütün işleyiş mekanizmasını elinde bulunduran kişi, suçun işleniş planıyla yetinmeyip, örgüt üyesi olan diğer suç ortaklarına talimat verdikten sonra, ayrıca suçun icrası sırasında olay yerinde bulunmamakla birlikte, diğer suç ortaklarını yönlendirmesi, suçun işlenişini sevk ve idare etmesi halinde, **müşterek fail** olarak sorumlu tutulacaktır. Hatta, şayet örgütün yöneticisi, somut olayda işlenen suçun icra hareketlerini gerçekleştiren kişilerin örneğin kusur yeteneğinin olmamasından veya işlenen suç bakımından kastının bulunmamasından yararlanarak bu kişiler üzerinde ve dolayısıyla, işledikleri fiiller üzerinde hakimiyet kurmuşsa, bu suç nedeniyle **dolaylı fail** olarak sorumlu tutulmalıdır.

Buna karşılık, suç planını yapıp, icrası hususunda diğer örgüt üyelerine talimat vermekle yetiniyorsa, bu suç nedeniyle **azmettiren** olarak sorumlu tutulacaktır.

Keza, örgüt üyelerinin işlemeyi planladıkları suçun icrası için gerekli silah ve sair malzemenin temini gibi katkılarda bulunulması halinde, örgüt yöneticilerinin bu suç nedeniyle **yardım eden** olarak sorumlu tutulmaları gerekmektedir.

Hatta bazı durumlarda, örgüt yöneticileri, örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlenen somut suçların işlendiğinden haberdar dahi olmayabilirler. Ancak bilinmelidir ki, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün yöneticileri, örgütün yönetimini elinde bulundurdukları süre zarfında örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde suçlar işleneceği öngörüsüyle ve beklentisiyle hareket etmektedirler; örgütün diğer üyeleri tarafından işlenen suçlara en azından müsamaha ile bakmaktadırlar. Bu itibarla, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün yöneticilerinin, yönetimini elinde bulundurdukları zaman zarfında örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlenen somut suçların işlendiğinden haberdar olmasalar dahi; bu suçların işleneceği **öngörüsüyle** ve **beklentisiyle** hareket ettikleri için, bu suçların işlenişine en azından müsamaha ile baktıkları için, bu suçlar nedeniyle **yardım eden** sıfatıyla sorumlu tutulmaları gerekmektedir⁵⁰.

⁵⁰ Türk doktrininde ileri sürülen, bu durumda örgüt yöneticilerinin sorumlu tutulmasının kusura dayalı sorumluluk ilkesiyle çeliştiği ve bunun bir “objektif sorumluluk” örneği oluşturduğu yönündeki görüşler, doğru değildir.

Bu çerçevede TCK'nın 220. maddesine bir hüküm konulması gerektiği mülahazasıyla Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonu çalışmaları sırasında hazırlamış bulunduğumuz önerge taslak metninde,

“Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.” (beşinci fıkra)⁵¹.

şeklinde bir hükme yer verilmiştir.

Hükmü bu şekilde formüle etmemizin sebebi, Komisyon üyelerinin,

“Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca *duruma göre fail veya şerik* olarak cezalandırılır.”

şeklinde bir hükmün kabulü yönünde ikna edilmelerini sağlamaktı. Ancak, Komisyon çalışmalarına katılan Yargıtay temsilcisi Keskin Kaylan'ın önerge taslak metninde formüle ettiğimiz hükmü benimsemesi karşısında, bu fıkra metninde **“duruma göre fail veya şerik olarak”** şeklinde değişiklik yapma hususundaki girişimimizde başarılı olamadık. Kanun değişikliği ile bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu itibarla, söz konusu hükmün suça iştirake ilişkin genel hükümlerle çelişen bir yönünün bulunduğu yönündeki eleştiri doğrudur⁵². Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu hüküm, ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralına aykırılık oluşturmamaktadır. Zira, yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı gibi, ortada suç işlemek amacıyla oluşturulmuş bir örgüt ve kişi de bu örgütün yöneticiliğini üstlenmiş bulunmaktadır. Yani, belirli mahiyette suçları işlemek üzere oluşturulmuş bir yapının yönetimini deruhte eden kişi, bu organizasyon çatısı altında her an herhangi bir suç işlenebileceğini öngörmektedir. Bu nedenle, örgüt yöneticisi yönetimini üstlendiği örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç bakımından en azından **olası kastla** hareket eden kişidir. Suç işle-

⁵¹ Madde gerekçesinde bu fıkra hükmü ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Maddenin beşinci fıkrasında, örgüt yöneticilerinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılması gerektiği kabul edilmiştir. Örgüt yapısı içinde, kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun bir görev verilen kişi bu görevini yerine getirmezse, hemen yerine bir diğeri rahatlıkla ikame edilebilmektedir. Bu nedenle, örgütün yöneticisi konumunda olan kişiler, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak sorumlu tutulmalıdırlar.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

⁵² Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 12. Ancak kararda yer verilen, söz konusu hükmün ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine bir “istisna” getirdiği yönündeki değerlendirme doğru değildir.

mek üzere kurulmuş bir güç aparatının yönetimini üstlenmiş olan kişinin bu aparatın işlemesi suretiyle işlenen suçlardan dolayı sorumlu tutulması, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle çelişmez⁵³.

Ancak, bu hükmün örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlar bakımından uygulanabilmesinde fiilî bir imkânsızlık mevcuttur. Bu durumda, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiği kabul edilen bütün suçlardan dolayı düzenlenen iddianamelerde, örgütün yöneticilerinin de şüpheli olarak gösterilmesi gerekmektedir. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı örgüt yöneticilerinin de sanık sıfatıyla yargılanmasına teşebbüs edilmesi, yargılama faaliyetini en azından olumsuz yönde etkileyeceği, muhakkaktır.

Bu nedenle, TCK, m. 220, f. 5 hükmünün, örgüt yöneticilerinin ancak işlenmesine muttali oldukları **somut suçlar** bakımından uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz.

Kişi, suç örgütünün yönetimini deruhte etmekle, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olan ve işlenmesine muttali olduğu suçların işlenmesini önlemek yükümlülüğü altına girmektedir. Bu durumda, **ön gelen fiil sebebiyle teminat yükümlülüğü** söz konusudur.

Genel olarak kişi, işlenmesine muttali olduğu bir suç olgusu karşısında gerek kendisi gerek üçüncü bir kişi lehine meşru savunma hak ve yetkisine sahiptir (bkz. TCK, m. 25, f. 1). Keza, bir suçun işlenmekte olduğu bilgisine muttali olan kişi, bu suçla ilgili olarak bildirim yükümlülüğü altındadır (bkz. TCK, m. 278 ve madde gerekçesindeki açıklamalar). Ancak, genel olarak kişiler, işlenmekte olan bir suçun işlenmesini önlemekle yükümlü değildir. Kişinin, işlenmekte olan bir suçun işlenmesini önlemekle yükümlü olabilmesi için, **teminat yükümlüsü** (garantör) sıfatını taşıması gerekir. Bu teminat yükümlülüğü, gözetim yükümlülüğünden veya koruma yükümlülüğünden kaynaklanabilir.⁵⁴ Kişi suç örgütünün yönetimini üstlenmekle, kendi hiyerarşisine tabi olan örgüt mensuplarının suç işlemesini önleme yükümlülüğü altına

⁵³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖNOK, R. Murat: *Yapısal Suçlarda Failin Tespiti: Müşterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik Doktrinleri*, Ankara, Mart 2019, sh. 553 vd.

⁵⁴ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İhmalî Suç Teorisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXV, sayı 4, Ekim 2021, sh. 303 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, 17. bası, Ankara, Eylül 2021, sh. 395 vd.

girmektedir. Bu yükümlülüğe rağmen, örgüt yöneticisi, kendi hiyerarşisine tabi olan örgüt mensuplarının işlemekte oldukları bir suça ilişkin bilgiye muttali olmasına rağmen, işlenişini önlemediği takdirde, bu suçun işlenişinden dolayı sorumlu tutulması gerekmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, örgüt yöneticisini örgütün faaliyeti çerçevesinde ve kendi bilgisi dahilinde işlenen **somut suçlardan** dolayı müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutmak gerekir. Bu bilginin suçun icrası sırasında mevcut olması gerekir. Örgüt yöneticisi, icrası tamamlandıktan sonra işlendiğine muttali olduğu bir suçun işlenişinden dolayı müşterek fail sıfatıyla cezalandırılmaz.

Keza belirtilmelidir ki, örgüt yöneticisi veya üyelerinin işlediği her suçun örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde işlenmiş suç olarak kabulü mümkün değildir. Kişi, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün yöneticisi veya üyesi olmakla birlikte, örgütün amacı ile ve örgütle ilgisi olmayan bir suç işlemiş olabilir.

VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ

Kişiler, örgüt bünyesindeki hiyerarşik ilişki içinde yer almamakla beraber, örgüte duydukları sempatinin etkisiyle, örgütün adını kullanarak çeşitli suçları işleyebilirler. Bu durumda, örgüt üyesi olmayan kişinin örgüt adına suç işlemesinden söz edilir⁵⁵.

Mevzuatımızda bu konuda ilk hüküm 3713 s. TMK'nın 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer almıştır:

“Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.”

Bu hükme göre örneğin terör örgütünün propagandasını yapan kişi, aynı zamanda örgüt üyesi olarak cezalandırılabilecektir⁵⁶.

⁵⁵ “Örgüt üyesi olmayan bir kişinin örgüt adına suç işlediğinin kabulü için, **bu suçun işlenmesinin örgüt tarafından istenmesi ya da örgütün bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.**”: Yargıtay 16. CD, **5.7.2019**, E. 2019/521, K. 2019/4769.

⁵⁶ Benzer bir hüküm, mülga 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı “*Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu*”nda bulunmakta idi:

Çıkar amacıyla oluşturulmuş bir “örgüt adına örgüt üyesi olmayanlar tarafından (aynı maddenin) *birinci fıkra(sın)da gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere işlenen suçların cezası ... üçte birden yarıya kadar artırılır.*” (m. 1. f. 6).

Anayasa Mahkemesi, norm denetimi çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda TMK, m. 2, f. 2 hükmünün aşağıdaki gerekçe ile Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir:⁵⁷

“İncelenen kural uyarınca bir kimsenin terör suçlusu sayılması, elbette terör örgütü mensubu olarak örgütün amacı doğrultusunda bir suç işlediğinin ya da böyle bir örgüte mensup olduğunun, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılama sonucu saptanmasına bağlıdır. Böyle bir nitelendirme temelde, yargı organının mahkûmiyet kararına dayanır. Kişi bu alandaki suçluluğu belirlendikten sonra terör suçlusu sayılacaktır. Bu bakımdan Yasa’da ‘suçsuzluk karinesi’ne aykırı bir düzenleme yoktur. Örgüt mensupları, başkalarının eylemi nedeniyle değil, kendi isteğiyle böyle bir örgüte girdikleri için 7. madde gereğince cezalandırılmakta ve bunun sonucu 2. madde uyarınca terör suçlusu sayılmaktadırlar. Bu durumda ceza sorumluluğunun kişisel olduğu ilkesi çiğnenmemektedir.”

Keza Anayasa Mahkemesinin bu kararında, söz konusu maddede “**örgüt adına suç işlemekten söz edildiğine göre suçun, örgütün bilgisi ve istemi içinde işlenmesi gerekir**” yönünde bir değerlendirmede bulunulmuştur.⁵⁸ Bu değerlendirmeyle söz konusu hükmün uygulama alanı önemli ölçüde daraltılmıştır.

Yargıtay da bu yönde uygulama geliştirmiştir.⁵⁹

Buna göre, kişi kanuna aykırı olarak gerçekleştiren bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne terör örgütünün çağrısı üzerine katılmış ve bu gösteri yürüyüşü sırasında çeşitli suçları işlemiş ise, bu suçlardan dolayı sorumluluğun yanı sıra ayrıca terör örgütü üyeliğinden dolayı cezalandırılacaktır. Buna karşılık, terör örgütünün propagandasını yapan kişi, şayet bu fiili örgütün “*bilgisi ve istemi*” dahilinde gerçekleştirmemiş ise, sadece propaganda yapma suçundan (TMK, m. 7, f. 2) dolayı cezalandırılabilecektir.

TMK, m. 2, f. 2’de, **2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla** değişiklik yapılarak, fıkra metninde yer alan “*ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar*” ibaresi, metinden çıkarılmıştır⁶⁰. Bu değişikliğe paralel olarak TCK’nın 220. maddesinin altıncı fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Terör örgütüne mensup olmasa bile

⁵⁷ Anayasa Mahkemesi, 31.3.1992, E.1991/18, K.1992/20.

⁵⁸ Anayasa Mahkemesi, 31.3.1992, E.1991/18, K.1992/20.

⁵⁹ Yargıtay CGK, **4.3.2008**, E. 2007/9-282, K. 2008/44; Yargıtay 16. CD, **18.3.2021**, E. 2020/2703, K. 2021/2819.

⁶⁰ M. 74; RG: 5 Temmuz 2012/28344.

örgüt adına suç işleyenlerin ceza sorumluluğunu belirleme bakımından TCK'nın 220. maddesinin altıncı fıkrası hükmünü ve bu bu hükme ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaları göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

TMK'nın 2. maddesinin 6352 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki düzenlemesinin yansımalarıyla TCK'nın 220. maddesinin altıncı fıkrasında şu hükme yer verilmişti:

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.”^{61, 62}

Kanımızca bu hüküm, uygulamada hükmolunacak ceza miktarları bakımından çok ağır sonuçlar meydana getirmeye elverişlidir. Bu nedenle söz konusu hükmün;

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.”

şeklinde değiştirilmesinin daha adil olacağını düşünmekteyiz. Bu durumda kişi örgüte hakim olan hiyerarşik ilişki içinde yer almamaktadır; ancak, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak bir suç işlemektedir. Örneğin yağma suçunu işleyen kişi, suç işlemek için kurulmuş olan ve bu özelliği bilinen bir örgütün üyesi olduğunu söyleyerek, mağdurun korkmasını ve kendisinden istenen maddi menfaati temin etmesini sağlar. Bu durumda kişi işlediği yağma suçunun yanı sıra, gerçek içtima hükümlerine göre, örgüte üye olma suçundan dolayı cezalandırılacaktır.

Nitekim TCK'da, çeşitli suçlar bağlamında suçun bir örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak işlenmesi, ilgili suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak tanımlanmıştır⁶³.

⁶¹ Madde gerekçesinde bu fıkra hükmü ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Altıncı fıkraya göre, örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ve bu nedenle de sorumlu tutulması gerekir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.).

⁶² *“Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüte üye olmak suçundan ayrı ayrı cezalandırılır.”* 6. CD, 30.4.2009, E. 2009/8377, K. 2009/7582 (Gerçekler, TCK, sh. 2577 vd.).

⁶³ Bkz. tehdit suçu ile ilgili olarak, TCK, m. 106, f. 2, bent d; eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma

Terör örgütünün propagandası amacıyla yapılan veya örgütün propagandasına dönüşen “nevrüz kutlamaları”na katılarak, kolluk görevlilerinin dağılın uyarılarına rağmen taş atarak dağılmamakta ısrar eden, terör örgütünün propagandası mahiyetinde sloganlar atan, döviz ve pankartlar taşıyan çocuklarla ilgili olarak yapılan yargılamalarda;

a) 2911 s. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nun 32 veya 33. maddelerinde tanımlanan suçlardan dolayı,

b) 3713 s. Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan dolayı,

c) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemiş olmaları nedeniyle ayrıca TCK’nın 314. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı,

hapis cezasına hükmedilmesi ve ayrıca hükmolunan cezanın 3713 s. Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yarı oranında artırılması yoluna gidilmekteydi.

Bu suretle çocuklar hakkında ölçüsüz ve orantısız cezalara hükmedilebilmekte idi. Bu uygulamanın toplumda oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle, 22.7.2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunla⁶⁴ 2911 s. Kanunun 32 ve 33. maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki şekilde yeni bir madde eklenmiştir:

“Çocuklar hakkında uygulanmayacak hüküm

MADDE 34/A – Bu Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak direnme suçunu veya katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında bu suçlara bağlı olarak ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

Söz konusu Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Genel Kurulunda müzakereleri sırasında verilen bir önerge ile değiştirilen bu maddenin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Yürürlükteki hükümler çerçevesinde yapılan uygulamada, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine **kitle psikolojisinin etkisinde kalarak** katılan çocukların bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütünün*

hürriyetinin ihlâli suçları ile ilgili olarak TCK, m. 119, f. 1, bent d; **yağma suçu** ile ilgili olarak, TCK, m. 149, f. 1, bent f; **görevi yaptırmamak için direnme suçu** ile ilgili olarak, TCK, m. 265, f. 4.

⁶⁴ RG: 25 Temmuz 2010/27652.

propagandası mahiyetinde fiil ve davranışlarda bulunması halinde, Türk Ceza Kanununun 28'inci maddesi hükmü dikkate alınmaksızın 2911 sayılı Kanunun 32 ve 33'üncü maddelerinde ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suçların yanı sıra 3713 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının hükmü gereğince ayrıca örgüt üyesi olmaktan dolayı mahkûm edilmeleri yönüne gidilmektedir. Bu uygulama, çocukların işledikleri suçlara nazaran çok ağır cezalar ile ölçüsüz bir şekilde cezalandırılmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Keza bu uygulamada terör örgütleri tarafından çocukların istismar edilmeleri bakımından büyük bir kolaylık oluşturmaktadır. Bu yanlış uygulamanın önüne geçmek amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.”

Bu düzenleme ile, TCK'nın 220. maddesinin altıncı fıkrası ile 3713 s. Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin olumsuz etkisinin çocuklar bakımından kısmen giderilmesi mümkün olmuştur⁶⁵.

TCK'nın 220. maddesinin altıncı fıkrasında, **2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla** aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.”

6352 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında söz konusu değişikliğin gerekçesi olarak şu açıklamalara yer verilmiştir⁶⁶.

“Mevcut düzenlemeler nedeniyle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen ya da örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler, Türk Ceza Kanununun 220'nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca örgüt üyesi olarak kabul edilmekte ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Örgütün silahlı olması durumunda ise, bu kişilere

⁶⁵ 6008 s. Kanunla,

- a) 2911 s. Kanunun 32. maddesinde yapılan değişiklikle, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması amacıyla yapılan ihtara veya zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar ederek direnme suçunun cezası indirilmiştir.
- b) 3713 s. Kanunun cezaların artırılmasını öngören 5. maddesi hükmü ile 13. maddesindeki “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağı”nın çocuklar bakımından uygulanmaması sağlanmıştır.

⁶⁶ TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, sh. 23.

verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısımının Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olanlar ise, 314'üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220'nci maddesinin altıncı fıkrasında, "Örgüte üye olmakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı" cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Esasen "örgüt adına suç işlemek" ibaresi, üyelik kavramına dâhil edilerek bu tür eylemlerde bulunanların davranışları örgüt üyeliğinin tipik hareketlerine eşdeğerde kabul edilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda, hiyerarşik ilişki içerisinde örgüt üyesi olmasa bile örneğin örgütün talimatı ile düzenlenen bir gösteriye katılıp örgütün propagandasını yapan yahut güvenlik güçlerine taş atıp yaralayan ya da molotofkokteyli atan veya mala zarar veren kişi, hem örgüt üyeliğinden, hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220'nci maddesinin dördüncü fıkrası nedeniyle suç teşkil eden diğer tüm eylemlerinden dolayı ayrıca cezalandırılmaktadır."

6352 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında, 220. maddenin altıncı fıkrasında, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye "örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza(da) yarı oranında" indirim yapılması öngörülmekte idi. TBMM Adalet Komisyonunda yapılan değişikliklerle bu indirim maktu olmaktan çıkarılmıştır. Bu değişiklik bağlamında TBMM Adalet Komisyonunun 12.6.2012 tarihli ve Esas: 1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326, Karar: 12 sayılı Raporunda **gerekçe** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir⁶⁷:

*Adalet Komisyonunca "yapılan değişikliklerle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek cezada maktu indirim yapılması yerine, hakime **indirim yapıp yapmama ve yapacaksa bu indirimin oranı konusunda takdir yetkisi** verilmiştir."*

TCK'nın 220. maddesinin altıncı fıkrası hükmünü terör örgütü üyesi olmakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin ceza sorumluluğunu belirleme bakımından da göz önünde bulundurmaktadır.

⁶⁷ TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, sh. 125.

VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya kurulmuş olan örgütü yönetmek suçu için Kanunda öngörülen ceza, “*iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası*”dır (TCK, m. 220, f. 1). Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçunun karşılığında ise, “*bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası*” öngörülmüştür (TCK, m. 220, f. 2).

Örgütün silahlı olması halinde, bu hükümlere göre “*verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.*” Cezanın artırılmasındaki oran, silahların nitelik ve miktarı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Türk Ceza Kanunu, İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki “*Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar*” başlıklı Birinci Bölümde yer alan suçları işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya bu örgüte üye olmak fiilleri ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır Buna göre, söz konusu bölümde tanımlanan “*yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.*” (TCK, m. 78, f. 1). Örgüt kurmak veya yönetmek suçu ile kurulmuş örgüte üye olmak suçuna ilişkin olarak yukarıdan beri yapmış bulunduğumuz açıklamalar, 78. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suçlar bakımından da dikkate alınmalıdır. Bu suçlar bakımından farklılık iki noktada ortaya çıkmaktadır. Birinci nokta, işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından bir sınırlama getirilmesidir; ikinci nokta ise, ceza miktarlarının artırılmış olmasıdır.

TCK’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçu ile kurulmuş örgüte üye olmak suçu bakımından **etkin pişmanlık** hükmüne yer verilmiştir:

Etkin pişmanlık

MADDE 221- (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgü-

tün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya el-verişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden⁶⁸ kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(6)⁶⁹ Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.

Bu düzenlemeler ile ilgili olarak madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir⁷⁰:

“Madde metninde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir.

Birinci fıkrada, örgüt kurucu veya yöneticileri ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek dolayısıyla haklarında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kişiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

*İkinci fıkrada, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olan kişilerle ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Örgüt üyesinin, etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmesi için, **örgütün faaliyeti çerçe-***

⁶⁸ 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, “ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden” ibaresi, fıkra metnine eklenmiştir (m. 26).

⁶⁹ Bu fıkra, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla madde metnine eklenmiştir (m. 8).

⁷⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 616 vd.

vesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş olması ve ayrıca, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi gerekir. Bu koşullar gerçekleşmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu koşullar gerçekleştikten sonra, kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan dolayı soruşturma başlatılmış olmasının veya örgütün faaliyeti çerçevesinde başkaları tarafından suç işlenmiş olmasının, etkin pişmanlıktan yararlanma açısından bir önemi bulunmamaktadır.

Üçüncü fıkra da ise, yakalanan örgüt üyesi ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Yakalanmış olmasına rağmen, bu fıkra da belirlenen şartların gerçekleşmesi hâlinde örgüt üyesi cezalandırılmayacaktır. Bu şartlardan birisi, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş olmak; diğeri ise, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermiş olmaktır. Verilen bilginin, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli olup olmadığını takdir yetkisi mahkemeye aittir.

Kişi, suç işlemek için kurulmuş olan örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmakla birlikte, örgütün ulaştığı yapılanma itibarıyla dağılmasını sağlama imkanından yoksun olabilir. Bu durumda bile, söz konusu sıfatları taşıyan kişilerin belli şartlarda etkin pişmanlıktan yararlanması sağlanabilmelidir. Bu düşüncelerle maddenin dördüncü fıkrası düzenlenmiştir. Buna göre, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır.

Kurucu, yönetici veya üyenin, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı hakkında verilecek cezada belli oranda indirim yapılması kabul edilmiştir.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan kişiler açısından güvenlik ve topluma uyum sorunu yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmelidir. Bu bir yıllık süre, kişinin serbest bırakıldığı andan itibaren işlemeye başlar. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması açısından, etkin pişmanlık nedeniyle kişi

hakkında cezaya hükmolunmaması ile indirilmiş cezaya hükmolunması arasında bir fark gözetilmemiştir. Uygulanmasına başlanan denetimli serbestlik tedbirinin süresi hâkim kararıyla uzatılabilecektir. Ancak süre üç yıldan fazla olamaz.”

Madde metnine, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla eklenen altıncı fıkranın **gerekçesi** şu şekildedir⁷¹:

“5237 sayılı Kanununun 221’inci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle örgütlü suçlulukta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya sınırlama getirilmiştir.”⁷²

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararlarında, söz konusu etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bağlamında yol göstericilik özelliği taşıyan açıklamalarda bulunulmuştur:

*“TCK’nun 221. maddesinin **birinci fıkrasına** göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle ceza soruşturmasına başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan örgüt kurucu veya yöneticileri hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu hükmün uygulanabilmesi için ilgili suç örgütü hakkında soruşturmaya başlanılmamış olması ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olması gerekmektedir.*

⁷¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 4.

⁷² “5237 sayılı TCK’nın etkin pişmanlığa ilişkin 221.maddesinin amaç, kapsam ve gerekçesi birlikte nazara alındığında dosya kapsamına göre silahlı terör örgütünün üyesi olduğu anlaşıldığı halde, **atılı suçlamayı reddeden sanığın etkin pişmanlığından söz edilemeyeceği** bu nedenle de anılan maddede aranan şartların bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,” bozmayı gerektirmiştir: 9. CD, 26.6.2007, E. 2006/8234, K. 2007/5611 (Gerçek, TCK, sh. 2605).

*“Sanıkların örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin yakalandıkları anlaşıldığından konumlarının 5237 sayılı TCK’nın 221/3. maddesine uyduğu ancak; tüm dosya kapsamından pişmanlık duyarak **örgütün dağılmasına veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermedikleri** ve Yasada aranan koşulların bu nedenle oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmaları, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”: 9. CD, 8.5.2007, E. 2007/2572, K. 2007/3890 (Gerçek, TCK, sh. 2606).*

*“Güvenlik güçlerince yakalanarak ele geçirilen hükümlünün örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yasanın aradığı anlamda **yeterli bilgi vermediği, açıklamaları ile terör örgütünün dağılmasına, meydana çıkarılmasına yardım etmediği ve terör örgütünün amaçladığı suç(ların) işlenmesine de engel olmadığı** gözetilmeden, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 221/4.maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından, ... bozma nedeni yapılmamış”tır: 9. CD, 07.11.2007, E. 2007/53, K. 2007/7991 (Gerçek, TCK, sh. 2606).*

Suç örgütü kurulmakla beraber herhangi bir amaç suç işlenmemiş fakat amaç suçları işlemek için bir takım hazırlık hareketi mahiyetinde fiillere girişilmiş ise diğer şartların da varlığı hâlinde bu hükmün uygulanması önünde herhangi bir engel yoktur. Örneğin suç işlemek amacıyla örgüt kuran kimseler işleyecekleri amaç suçlar için silah temin etme, plan program yapma gibi faaliyetlere girişmiş olabilirler. Kanun, **amaç suçların işlenmemesini şart olarak koştuğu için bu şekilde hazırlık hareketinde kalmış fiillerin varlığına rağmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Fakat eğer hazırlık hareketi niteliğindeki fiiller ayrıca bir suç oluşturuyor ise faillerin, bu fiilleri dolayısıyla cezai sorumlulukları saklıdır.** Örneğin, ruhsatsız silah veya patlayıcı madde temin eden failin cezai sorumluluğu doğacaktır. Bunun ötesinde eğer hazırlık hareketleri aşaması da geçilerek örgütün amacı doğrultusunda bir suç işlenmiş ise örgüt kurucu ve yöneticilerinin bu etkin pişmanlık hükmünden yararlanmaları imkân dahilinde değildir.

TCK'nun 221. maddesinin birinci fıkrasının aradığı bir diğer şart ise, örgüt kurucu ve yöneticilerinin bizzatı örgütü dağıtması ya da vermiş oldukları bilgilerle örgütün dağılmasını sağlamalarıdır. Bu bağlamda, eğer örgüt kurucu veya yöneticilerinin vermiş oldukları bilgiler önemsiz veya önemli olmakla beraber örgütün dağılmasını sağlayacak nitelikte değil ise kurucu ve yöneticilerin bu hükümden yararlanması mümkün değildir.

Buna göre; TCK'nun 221. maddesinin **birinci fıkrasının** uygulanabilmesi için;

- 1- Fail örgütün kurucusu veya yöneticisi olmalıdır,
- 2- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmamış ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olmalıdır,
- 3- Fail örgütü dağıtmalı veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlamalıdır.

TCK'nun 221. maddesinin **ikinci fıkrasına** göre; örgüt üyesi, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suça iştirak etmeksizin ve gönüllü olarak örgütten ayrıldığını yetkili makamlara bildirir ise etkin pişmanlık hükmünden yararlanacak ve ceza almayacaktır. Bu düzenlemede örgüt kurucu ve yöneticilerinde olduğu gibi "soruşturmaya başlanmadan önce" veya "örgütün dağılmasını sağlayacak bilgi verme" şartlarına yer verilmemiştir.

*Yine ilk fıkra da örgüt kurucu ve yöneticilerinin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için “örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olması” şart koşulmuş olmasına rağmen; ikinci fıkra da bu şart “örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemesi” olarak düzenlenmiştir. Nitekim TCK’nun 221. maddesinin ikinci fıkrası gereğince örgüt faaliyeti çerçevesinde amaç suçlardan bazılarının işlenmiş olması, örgüt üyesinin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel değildir. Zira **bu fıkra bakımından önemli olan örgüt faaliyeti çerçevesinde amaç suçların işlenmemesi olmayıp örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemesidir.** Bir başka anlatımla, TCK’nun 221. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan koşullar gerçekleştikten sonra, örgütün faaliyeti çerçevesinde başkaları tarafından suç işlenmiş olmasının etkin pişmanlıktan yararlanma açısından bir önemi bulunmamaktadır.*

TCK’nun 221. maddesinin ikinci fıkrasında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen herhangi bir suça iştirak etmemiş örgüt üyesinin, örgütten gönüllü ayrılması yanında ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi de ceza almamasının koşulu olarak yer almaktadır. Gönüllü olarak örgütten ayrılma ise, güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanmama, zorla ele geçirilmeme anlamını taşımaktadır.

*Buna göre; TCK’nun 221. maddesinin **ikinci fıkrasının** uygulanabilmesi için;*

1- İşlenen suçun örgüt üyeliğinden ibaret olması,

2- Sanığın örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmemesi,⁷³

⁷³ Uygulamamıza göre, bu fıkra hükmü bağlamında etkin pişmanlıktan yararlanmaya engel teşkil eden suçun, örgütün amacı doğrultusunda “**vahim**” bir suç olması gerekmektedir:

“Dairemizce de benimsenen yerleşik uygulamaya göre; (etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için) işlenen suçun, amaç suçlar (TCK 302 ve 309) yönünden öldürme ve öldürmeye teşebbüs, nitelikli yaralama, yağma, işkence, bir kısım nitelikli hürriyeti tahdit suçları gibi **vahim** nitelikte eylemlerden olmaması gerekir.”: Yargıtay 16. CD, **24.4.2017**, E. 2015/3, K. 2017/3.

“**Vahim eylem niteliğindeki araç suçun işlenmesi halinde etkin pişmanlık hükümleri.. uygulanmayaca**”ktır: Yargıtay 16. CD, **21.11.2017**, E. 2017/2685, K. 2017/5532.

Ayrıca bkz. BABA, Yasemin: *Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık*, İstanbul, 2013, sh. 82; ŞEN, Ersan/ERYILDIZ, H. Sefa: *Suç Örgütü*, 4. bası, Ankara, 2021, sh. 468; GÖKCAN, Ha-

3- Gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi gerekmektedir.^{74, 75, 76}

san Tahsin/ ARTUÇ, Mustafa: *Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Şerhi*, cilt V, Ankara, 2021, sh. 7443 vd.

- ⁷⁴ 2009 yılında yaşanan ve kamuoyunda “**Habur Vakası**” olarak bilinen olayda; PKK üyesi 34 kişi, adeta bir tören havasında Irak sınırından geçerek Türkiye’ye gelirler. Türkiye’ye gelen bu kişilerle ilgili olarak hemen soruşturma başlatılır. Fakat, soruşturma sürecinde bu kişilerin tamamı TCK, m. 221, f. 2 hükmünden yararlandırılarak serbest bırakılırlar.

Bu olay bakımından dikkat çekici olan hususlar şunlardır: Bu kişilerden hiçbiri TCK, m. 221 hükümlerinin haklarında uygulanmasını talep etmemişlerdir. Hatta, önemli bir kısmı, örgüte üye olduklarından pişman olmadıklarını, “önder” diye kabul ettikleri Öcalan’ın ve örgütün talimatı ile Türkiye’ye geldiklerini ifade etmişlerdir.

Bu kişilerin serbest bırakılmasını sağlayanların ceza hukuku sorumluluğunun bulunduğu izahtan varestedir.

- ⁷⁵ Söz konusu fıkra da yer alan “gönüllü olarak” ibaresi, Yargıtay uygulamasında geniş bir yorumlamaya tabi tutulmuştur:

“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun etkin pişmanlığa ilişkin 221. maddesinin 2. fıkrası hükmünden yararlanabilmesi için, örgüt üyesinin örgüt adına işlenen suçlara iştirak etmeksizin örgütten çekilmesi ve bu durumu görevli makamlara bildirilmesi yeterli olup, temyiz davasına konu olayda; PKK terör örgütüne üye olarak Irak’ın Kuzey’indeki kamplarda 7 ay süreyle eğitim görmesine karşın uyum sağlayamayan ve gönüllü olarak örgütten çekilip kaçarak KDP güçlerine sığındıktan sonra Suriye’nin Kamışlı kentinde oturan amcasının yanına giden, kısa süre sonra yasal yoldan ülkeye giriş yapmak isteyen, ancak amcasının, pasaport ve herhangi bir kimlik belgesinin bulunmadığını, bu durumda evlerinde barındırmaları nedeniyle kendilerinin de sorumlu duruma düşecekleri kaygısını iletip, ülkeye hudut kapısı dışından girmesini söylemesi nedeniyle bu kez yasadışı yoldan ülkeye giriş yaptığı sırada kendisinden kuşkulanan Pasaport Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan ve hakkında örgüt mensubu olduğuna ilişkin bilgisi bulunmayan, kayıtlarda sorgulama yapmalarına karşın bu yolda bir bilgi ve belge de edinmeyen kolluk güçlerine, silahlı terör örgütü mensubu iken suça katılmaksızın örgütten gönüllü olarak çekildiğini bildiren sanık hakkında TCK’nın 221/2 maddesi uyarınca hükmolunan ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın isabetli bulunması karşısında, tebliğnamede hükmün bozulmasını öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.”: Yargıtay 9. CD, 9.11.2009, E. 2008/5368, K. 2009/11189.

“(H)ükümlünün ... silahlı terör örgütüne katıldığı, camilerde ders alarak, başkalarına ders verdiği, örgüte öz geçmiş raporu verdiği, vahim olmayan örgüt üyeliği faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir kısım eylemlerde yer aldığı, ... tarihine kadar örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair kuşku yok ise de, örgütten ayrılmak istemesi üzerine, örgütün diğer mensuplarınınca el ve ağız bağlanıp çuval içine konulmak suretiyle hürriyeti tahdit edildikten sonra sorgulanmak üzere götürülürken yardım istemesi üzerine güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı, bu tarih itibarıyla örgütte ayrılmış olduğunun kabulü gerekeceği ...” Yargıtay 16. CD, 16.3.2017, E. 2016/7164, K. 2017/1112.

- ⁷⁶ Bu bağlamda sorun, ilgili makamlara bildirimde bulunmadan örgütten ayrılma halinde, söz konusu etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanamayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Örgüte üye olan ve bu üyelik sürecinde örgütün çatısı altında çeşitli faaliyetlerde bulunan ve fakat bilahare örgütten ayrılarak normal hayata dönen, öğrenimine devam eden, bir işte çalışan ve hatta askerlik görevini yerine getiren kişilerle ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği sorun oluşturabilmektedir. Bu sorunun, söz konusu fıkra düzenlemesinde değişiklik yapılmadan, her somut olayın özellikleri itibarıyla uygulamada çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtmekle yetinmek gerekir (Bkz. GÖKCAN/ARTUÇ, V, sh. 7447 vd. Ayrıca bkz. Yargıtay 16.

*TCK'nun 221. maddesinin **üçüncü fıkrasına** göre; suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesi hakkında, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi hâlinde ceza verilmeyecektir.*

*TCK'nun 221. maddesinin üçüncü fıkrasında, ikinci fıkradan farklı olarak **yakalanmış olan örgüt üyesine** ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Kendiliğinden teslim olmaksızın yakalanan örgüt üyesi hakkında cezaya hükmolunmaması, amaç suçlara iştirak etmemiş olmasına ve pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesine bağlıdır. Çünkü bu durumda fail, yetkili makamlara kendiliğinden teslim olmamış, kolluk tarafından yakalanmıştır. Kanun; bu durumdaki örgüt mensuplarının da yetkili makamlara örgütün etkisizleştirilmesi amacıyla matuf bilgiler sunması kaydıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını kabul etmiştir.*

Failin vermiş olduğu elverişli bilgilere rağmen örgütün dağılması veya mensupların yakalanması sağlanamamış olabilir. Önemli olan nitelikli bilginin verilmesi olup verilen bilginin, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli olup olmadığını takdir yetkisi mahkemeye aittir.

*Buna göre; TCK'nun 221. maddesinin **üçüncü fıkrasının** uygulanabilmesi için;*

- 1- Fail örgüt üyesi olmalıdır,*
- 2- Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş olmalıdır,*
- 3- Yakalanmış olmalıdır,⁷⁷*

CD, **16.1.2018**, E. 2017/3429, K. 2018/220; Yargıtay 16. CD, **19.3.2018**, E. 2017/2669, K. 2018/848.).

⁷⁷ Uygulamamızda bu fıkra hükmü bağlamında “yakalama” ibaresi dar yorumlanarak, somut olayda üçüncü fıkra hükmünün değil, **ikinci** fıkra hükmünün uygulanması yoluna gidilmiştir:

“Görüldüğü üzere, adli yakalama halleri özgürlüğü kısıtlayıcı koruma tedbirlerinden olması sebebiyle yasada tahdidi olarak sayılmıştır. Genişletilmesi mümkün değildir. Yasada öngörülen hallerin dışında kişinin tutulması, muhakeme hukuku anlamında yakalama işlemi olarak nitelendirilemeyeceğinden, etkin pişmanlıkta yer alan ‘yakalanma’ sonuçlarını da doğurmaz. Şüpheli veya sanık kaçak olmayıp adresi belli olan, kendisine kolaylıkla ulaşılabilecek veya

4- Pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermelidir.

TCK'nun 221. maddesinin **dördüncü fıkrası**, ilk üç fıkra düzenlenen suçların faillerinin yanı sıra örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişileri de kapsamaktadır. Yine, ilk üç fıkra düzenlenen etkin pişmanlık hâllerinden farklı olarak bu fıkra etkin pişmanlığın “örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce” veya “örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemesinden önce” ya da “soruşturmaya başlanmadan önce” vuku bulması şart koşulmamıştır.

TCK'nun 221. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesine göre; örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden failin, gönüllü olarak teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. Anılan fıkranın ikinci cümlesine göre ise; gönüllü olarak yetkili makamlara teslim olmamakla birlikte yakalandıktan sonra bahsedilen nitelikteki bilgileri veren failin cezasında üçte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılacaktır. Bu indirim oranı belirlenirken failin vermiş olduğu bilgilerin niteliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Buna göre; TCK'nun 221. maddesinin **dördüncü fıkrasının**;

Birinci cümlesinin uygulanabilmesi için;

1- Fail, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden olmalıdır,

2- Gönüllü olarak teslim olmalıdır,⁷⁸

çağrıldığında gelebilecek durumda bulunan kişilerden ise, çağrı yapılmadan kolluk tarafından tutulması TCK'nın 221. maddesi yönünden ‘yakalanma’ sayılmayacaktır.”: Yargıtay 16. CD, **24.4.2017**, E. 2015/3, K. 2017/3.

⁷⁸ Uygulamamızda bu fıkra hükmü bağlamında “gönüllü olarak” ibaresi geniş yorumlanmaktadır:

“Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan **hakkında soruşturma ve yakalama kararı bulunduğu** öğrenmesi üzerine vekili aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için Türkiye’ye dönmek istediğini beyan eden ve bilahare geleceği tarihi de bildiren sanık hakkında, gönüllü olarak teslim olan örgüt üyelerinin etkin pişmanlığını düzenleyen TCK’nın 221/4. madde 1. cümlesinin uygulanması gerekirken, değerlendirmede hataya

3- Örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermelidir.^{79, 80}

düşülerek yakalanan örgüt üyelerinin etkin pişmanlığını düzenleyen TCK'nın 221/3. maddesinin uygulanması...": Yargıtay 16. CD, **24.5.2017**, E. 2017/1339, K. 2017/4686.

Ancak, Yargıtay'ın aşağıdaki kararları bu kabulde çelişmektedir:

"(Örgütsel faaliyetlere devam ederken hakkında soruşturma açıldığını ve yakalama müzakeresi düzenlendiğini bilmesine rağmen bu soruşturmayı sonuçsuz kılmak için kaçan failin makul olmayan bir zaman sonra **gelip teslim olmasının gönüllü teslim olarak kabul edilmesine de yasal olanak bulunmamaktadır**."": Yargıtay 16. CD, **14.7.2020**, E. 2019/5902, K. 2020/3674.

"Suç işleyen ya da suç şüphesi ile takip edilen/soruşturulan kişilerin belli ölçüde yakalanma korkusu taşıyacağına doğal bir durum olduğu da gözetildiğinde, kural olarak gıyabında düzenlenmiş yakalama emri bulunsun da kendiliğinden/gönüllü olarak teslim olup örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermesi halinde TCK'nın 221/4 maddesinin ikinci cümlesi gereğince cezasından indirim yapılması gerekecektir."": Yargıtay 3. CD, **6.12.2021**, E. 2021/8399, K. 2021/10524.

⁷⁹ "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için failin, örgütün dağılmasına veya mensuplarının yakalanmasına, örgütün yapısına ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili elverişli bilgi vermesi gerekir. Bu bilginin elverişliliği, **örgütün örgütlenme biçimi, failin örgüt yapılanmasındaki konumu ile örgütte geçirdiği süre ve katıldığı faaliyetler gibi kıstaslar** göz önüne alınarak mahkemece takdir edilecektir. Tam bir gizlilik esasına ve hücre tipi yapılanmaya dayanan örgütlerde her örgüt mensubundan örgütü dağıtacak, yapılanma şemasını ortaya koyacak bilgiler vermesi beklenemez. Ancak konumu gereği bilmesi beklenen bilgileri de samimi olarak ortaya koymalıdır. Her halükarda elverişli bilgi, örgütte zafiyet yaratacak, örgüte önemli boyutta zarar verecek, örgüt faaliyetlerini belli ölçüde sekteye uğratabilecek boyutta olmalıdır."": Yargıtay 16. CD, **24.4.2017**, E. 2015/3, K. 2017/3. Yargıtay 16. CD, **20.11.2018**, 2018/1901 E., K. 2018/4373.

Bu bağlamda verilen bilginin örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen somut suçlara ilişkin olması gerekir. Bu etkin pişmanlık hükümlerinin herhangi bir somut suçla ilgili olmayan bilgilere dayalı olarak işletilmesi, suçlulukla mücadele bakımından bir önem taşımaz; aksine, toplumda **tezviratçılığın** ve **düşmanlıkların önünü açar**. Bu nedenle Yargıtay 16. Ceza Dairesinin aşağıdaki kararlarını ihtiyatla karşılamak gerekir.

Yargıtay 16. CD, **25.5.2018**, E. 2018/986, K. 2018/1740; Yargıtay 16. CD, **11.7.2018**, E. 2018/910, K. 2018/2482; Yargıtay 16. CD, **20.11.2018**, E. 2018/1901, K. 2018/4374; Yargıtay 16. CD, **10.12.2018**, E. 2018/4572, K. 2018/5016; Yargıtay 16. CD, **27.12.2018**, E. 2018/4557, K. 2018/5435, Yargıtay 16. CD, **6.2.2019**, E. 2018/1743, K. 2019/574; Yargıtay 16. CD, **18.11.2019**, E. 2019/3879, K. 2019/6975; Yargıtay 16. CD, **25.1.2021**, E. 2018/5580, K. 2021/32. Yargıtay 16. CD, **22.2.2021**, E. 2020/3584, K. 2021/1506; Yargıtay 3. CD, **22.11.2021**, E. 2021/2766, K. 2021/10128; Yargıtay 3. CD, **25.10.2021**, E. 2021/2025, K. 2021/9730; Yargıtay 3. CD, **20.10.2021**, E. 2021/2080, K. 2021/9667; Yargıtay 3. CD, **20.10.2021**, E. 2021/1253, K. 2021/9660; Yargıtay 3. CD, **1.12.2021**, E. 2021/2102, K. 2021/10275.

⁸⁰ "Suç tarihi itibarıyla 1996 doğumlu olup İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi olan sanığın, ... programını kullandığını kabul etmesi, örgütte kaldığı süre ve konumuna uygun bilgiler vererek suçun aydınlatılmasına katkıda bulunması, TCK'nın 221/4-2. cümlesindeki düzenlemeye göre de **'verilen bilgilerin örgütün çözülmesine ya da örgüt mensuplarının yakalanmasını sağlar nitelikte bulunmasının' gerekmediği** hususları nazara alındığında; soruşturma başlamasından sonra yakalanan sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 221/4-2. cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması ...": Yargıtay 16. CD, **8.6.2020**, E. 2019/12181, K. 2020/2904.

"TCK'nın etkin pişmanlığa ilişkin 221. maddesinin amaç, kapsam ve gerekçesi birlikte nazara alındığında, failin bilgisi dahilinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili ifade vermesinin yeterli olaca-

İkinci cümlesinin uygulanabilmesi için;

1- Fail, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden olmalıdır,

2- Yakalanmış olmalıdır,

3- Örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermelidir.

Görüldüğü üzere; TCK'nun 221. maddesinin ilk dört fıkrasındaki açık düzenlemeler gereği, ancak örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçlarında etkin pişmanlık hükümleri tatbik edilebilecek olup örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen diğer suçlar yönünden bu maddede belirtilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden fail hakkında TCK'nun 221. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği suçlar, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçlarından ibarettir.

Bununla birlikte, "pişmanlık" kavramının, TCK'nun 221. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin tatbiki bakımından irdelenmesine gelince;

TCK'nun 221. maddesinin uygulanabilmesi için, etkin pişmanlık kurumunun doğası ve anılan madde başlığının "etkin pişmanlık" olması karşısında; failin pişman olması esasen ön koşul niteliğindedir. Bu nedenle, TCK'nun 221. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin uygulanması bakımından failin yalnızca maddi gerçeğin ortaya çıkması için yararlı bilgiler vermesi yeterli olmayıp bu pişmanlığını yargılamanın her aşamasında sürdürmesi, bu bağlamda pişmanlık duyarak örgütün yapısı çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgileri içeren ifadesini inkâr etmemesi gerekir. Pişmanlık duyarak verdiği ifadeyi inkâr eden kişinin o aşamada pişmanlığından söz edilemez.

ğının ve bu bilgilerin daha önceden güvenlik güçlerinin elinde olup olmadığının önem arz etmeyeceğinin anlaşılması karşısında, dosya kapsamına göre sanığın etkin pişmanlık iradesi göstererek gerek kendisi ve gerekse birlikte yakalandığı kişilerin eylemlerini açıkça ifade etmek şeklindeki durumunun etkin pişmanlık olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, 4959 sayılı Kanunun 4/c maddesinde gösterilen şartların oluşmadığından bahisle yazılı şekilde uygulamaya yapılmak suretiyle fazla ceza tayini...": Yargıtay 16. CD, 12.5.2015, E. 2015/1426, K. 2015/1292

Diğer taraftan, "etkin pişmanlık" başlıklı 221. maddenin üçüncü fıkrasında "pişmanlık duyarak" ibaresi kullanıldığından, bu koşulun dördüncü fıkranın ikinci cümlesi bakımından aranmayacağı ileri sürülebilir ise de; Adalet Komisyonu raporunda da vurgulandığı üzere madde başlığının, maddenin tüm fıkralarının yorumu bakımından ayrılmaz bir parça olması, üçüncü fıkranın uygulanma koşullarının, dördüncü fıkranın ikinci cümlesine göre daha ağır şartlara bağlı tutulması ve madde gerekçesinde belirtildiği üzere, dördüncü fıkranın, üçüncü fıkroda belirtilen nitelikte bilgi verme imkânından yoksun failer bakımından ihdas edilen bir düzenleme olması nazara alındığında, dördüncü fıkranın ikinci cümlesinin uygulanması bakımından, diğer koşulların yanı sıra failin pişmanlık duyması koşulunun da gerçekleşmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, örgütlü suçluluğa ilişkin etkin pişmanlığı düzenleyen TCK'nun 221. maddesinde yer alan fıkraların her birinin uygulanabilmesi bakımından failin pişmanlık duyması ön koşul niteliğinde olduğundan, maddenin "pişmanlık duyarak" ibaresine yer verilmeyen fıkraları açısından da failin pişman olmasının gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bununla birlikte, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren failin, vermiş olduğu bilgileri aşamalarda inkâr etmesi hâli, maddenin "failin örgütten koparılıp tekrar topluma kazandırılması ve örgüt faaliyeti çerçevesinde tekrar suç işlemesinin önlenmesi" şeklinde belirtilen amacıyla bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla, failerin yakalandıktan sonra usule uygun olarak verdikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması hususunda delil niteliği taşıyan itiraf içerikli beyanları hükme esas alınabilir ise de; bu beyanları sonradan reddeden failerin pişmanlık duyduklarından söz edilemeyeceği, böylelikle maddede öngörülen amaca aykırı davrandıkları anlaşıldığından, haklarında TCK'nun 221. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

TCK'nun 221. maddesinin birinci fıkrasına göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle ceza soruşturmasına başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan örgüt kurucu veya yöneticileri hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu hükmün uygulanabilmesi için ilgili suç örgütü hakkında soruşturmaya başlanılmamış olması ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olması gerekmektedir. Suç örgütü kurulmakla beraber herhangi bir amaç suç işlenmemiş

fakat amaç suçları işlemek için bir takım hazırlık hareketi mahiyetinde fiillere girişilmiş ise diğer şartların da varlığı hâlinde bu hükmün uygulanması önünde herhangi bir engel yoktur. Örneğin suç işlemek amacıyla örgüt kuran kimseler işleyecekleri amaç suçlar için silah temin etme, plan program yapma gibi faaliyetlere girişmiş olabilirler. Kanun, amaç suçların işlenmemesini şart olarak koştuğu için bu şekilde hazırlık hareketinde kalmış fiillerin varlığına rağmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Fakat eğer hazırlık hareketi niteliğindeki fiiller ayrıca bir suç oluşturuyor ise faillerin, bu fiilleri dolayısıyla cezai sorumlulukları saklıdır. Örneğin, ruhsatsız silah veya patlayıcı madde temin eden failin cezai sorumluluğu doğacaktır. Bunun ötesinde eğer hazırlık hareketleri aşaması da geçilerek örgütün amacı doğrultusunda bir suç işlenmiş ise örgüt kurucu ve yöneticilerinin bu etkin pişmanlık hükmünden yararlanmaları imkân dahilinde değildir.”⁸¹

TCK, m. 221’de düzenlenen örgütlü suçluluk bağlamındaki etkin pişmanlık hükümleri, terör örgütleri bakımından da uygulanacaktır (Bkz. TCK, m. 314, f. 3; 3713 s. K, m. 7, f. 1)⁸².

Yukarıda da belirtildiği gibi, verilen bilginin bir suç olgusunu açığa çıkarmaya ve suç örgütünün mensuplarının, yönetici veya üyelerinin yakalanmasını sağlamaya elverişli olması gerekmektedir.

Söz konusu etkin pişmanlık hükümleri, mahkûmiyet hükmü kesinleşinceye kadar uygulanabilir⁸³.

⁸¹ Yargıtay CGK, **27.3.2018**, E. 2017/1118, K. 2018/121. Ayrıca bkz. CGK, **2.7.2019**, E. 2019/312, K. 2019/514.

⁸² “3713 sayılı Kanun’un ‘terör örgütleri’ başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında TCK’nın 314. maddesine atf yapılması nedeniyle, TCK’nın 314. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı örgüt suçu açısından da uygulanacağından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından ‘diğer hükümler’ kapsamında olan TCK’nın 221. maddesinin, aynı Kanun’un 314. maddesi yönünden de tatbiki gerekmektedir. Zira bir anlamda TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen örgüt suçu tipine tam olarak bağlı olan TCK’nın 221. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hâli, aynı Kanun’un 314. maddesinin de ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.” Yargıtay CGK, **2.7.2019**, E. 2019/312, K. 2019/514; aynı yönde CGK, **27.3.2018**, E. 2017/1118, K. 2018/121.

“Türk Ceza Kanunu’nun 314/3. maddesindeki atf nedeniyle, anılan Kanunun 220. maddesine bağlı olarak düzenlenen 221. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün, TCK’nın 314. maddesinde tanımlanan silahlı örgüt mensupları ile 3713 Sayılı TMK kapsamında kalan terör örgütleri bakımından da uygulanabileceğinde kuşku yoktur”: Yargıtay 16. CD, **24.04.2017**, E. 2015/3, K. 2017/3.

⁸³ Yargıtay 16. CD, **4.7.2018**, E. 2018/1479, K. 2018/2313.

VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME

Suç işlemek amacıyla kurulmuş *örgüt mensuplarına yardım ve yataklık etme* fiilleri, mülga 765 s. TCK'da, müstakil bir suç olarak tanımlanmaktaydı (m. 314)⁸⁴. Yeni TCK'da ise, bu şekilde bağımsız bir suç tanımına yer verilmiş değildir. 220. maddenin yedinci fıkrasına göre,

“Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.”

Madde gerekçesinde bu fıkra hükmü ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir⁸⁵:

“Yedinci fıkroda, örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişinin, örgüt üyesi kabul edilerek cezalandırılması öngörülmüştür. Bu nedenle, “örgüte yardım ve yataklık” adıyla ayrı bir suç tanımlaması yapılmamıştır. Bu kavram altında söz konusu edilen fiiller, nitelik bakımından örgüte üye olmak dolayısıyla sorumluluğu gerektirmektedir.”

Ancak, 220. maddenin yedinci fıkrasında, **2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla** aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.”

⁸⁴ «Yukarıdaki madde uyarınca oluşturulan teşekküllerin mensuplarına bilerek ve isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya yardım edenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu yardım; dernek, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğrenim kurumlarında veya öğrenici yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa bu fıkradaki ceza, bir kat artırılır.» (1. fıkra)

«Bu suretle usul ve fîruundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kardeşinden birine barınacak yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan kişi hakkında bu cezalar yarısından üçte ikisine kadar azaltılır.» (2. fıkra)

Madde metninde cürüm işlemek için oluşturulmuş *teşekkül mensuplarına yardım veya yataklık etme* fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştı. Buna karşılık, teşekkül mensuplarına değil de, *teşekküle* yardım yapılması durumu ise, madde metninde müstakil bir suç olarak cezalandırılmış değildi. Bir teşekkülün oluşturulmasıyla güdülen amaç doğrultusunda suç işlenmesi için ihtiyaç duyulan para ve sair malzeme temini gibi yardımlar, bu maddedeki tanım itibarıyla bağımsız bir suç oluşturmamaktaydı.

Kanun koyucu, yardım eden kişi ile yardım edilen ve teşekkül mensubu olan kişi arasındaki akrabalık ilişkisini, *cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsî sebep* olarak kabul etmişti.

⁸⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 614 vd.

6352 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında söz konusu değişikliğin **gerekçesi** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir⁸⁶.

“... 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220’nci maddesinin yedinci fıkrası, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314’üncü maddesinde yer alan örgüt mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etme suçuna karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı hüküm altına alınmış; böylelikle, örgüte yardım ve yataklık sayılan fiillerin nitelik bakımından örgüte üye olmak dolayısıyla sorumluluğu gerektirdiği vurgulanmıştır. Örgüt üyesi olmaksızın, örgütün niteliğini bilerek örgütün yararına herhangi bir iş, görev veya hizmet yapılması örgüt üyeliği ile eşdeğer kabul edilmekte ve örgüt üyeliği ile benzer şekilde cezalandırılmaktadır. Mevcut düzenlemeler gözönüne alındığında, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak, bu örgütün amaçları doğrultusunda diğer üyelerle birlikte veya tek başına aktif olarak suç işleyen örgüt üyelerine verilecek ceza ile söz konusu hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgütün çağrısı üzerine herhangi bir eyleme katılana örgüt üyesi gibi ceza verilmesi, ceza adaleti yönünden uygun görülmemiştir. Bu itibarla maddede yapılan değişikliklerle bu adaletin sağlanması amaçlanmaktadır.”

220. maddenin yedinci fıkrasında 6352 sayılı Kanunla yapılan bu değişikliklerle, hakime, örgüte yapılan yardımın miktar ve mahiyetini dikkate alarak, örgüt üyeliğinden dolayı faile verilecek cezada **indirim yapıp yapmama ve yapacaksa bu indirimin oranı konusunda takdir yetkisi** tanınmıştır.

Bu yardım, örgüt üyelerine barınacak yer göstermek, doğrudan örgüte veya mensuplarına (yönetici veya üyelerine) malzeme temin etmek, bunların ihtiyaçlarını gidermek suretiyle gerçekleştirilebilir. Burada söz konusu olan yardım, maddî bir yardım olmayabilir. Meselâ örgüt mensuplarına belli husta bilgi temini dahi yardım olarak mütalâa edilmelidir^{87,88}.

⁸⁶ TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, sh. 23.

⁸⁷ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh.55. Örgüte yardımla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. BGH, Urteil vom 14.8.2009, 3 StR 552/08, kn. 138 – 141.

⁸⁸ Hukuk sistemimizde, terör örgütüne silah sağlama (TCK, m. 315) ve terörizmin finansmanı (6415 s. Kanun, m. 4) suçlarına ilişkin hükümler, örgüte yardım suçu bakımından özel hüküm

Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte **bilerek ve isteyerek** yardım edilmiş olması gerekir. Başka bir ifadeyle, yardım fiilinin, *örgütün suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu bilinerek* gerçekleştirilmiş olması gerekir. Fıkra metninde geçen “**bilerek**” ibaresi, **doğrudan kastı** ifade eder⁸⁹. Doğrudan örgüte değil de örgüt mensuplarına yardım edilmesi halinde, *yardım edilen kişilerin suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubu oldukları*nın da bilinmesi gerekmektedir.

Ayrıca, örgüte yardımın “**isteyerek**” yapılmış olması gerekir. Ceza sorumluluğu için, yardım eden kişinin iradesinin cebir veya tehdit etkisiyle ifsat edilmemiş olduğunun sabit olması gereklidir. Yardım etmeye mecbur edilmesi halinde kişi bu davranışın aksini yapmayı irade ve ihtiyar etme yetkisini artık haiz değildir⁹⁰.

mahiyeti taşımaktadırlar: Yargıtay 16. CD, **30.9.2020**, E. 2020/1029, K. 2020/4660; Yargıtay 16. CD, **30.4.2020**, E. 2020/399, K. 2020/2066.

⁸⁹ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh.54. Ayrıca bkz. Yargıtay CGK, **13.2.2018**, E. 2017/692, K. 2018/41; Yargıtay CGK, **12.3.2019**, E. 2017/691, K. 2019/202; Yargıtay CGK, **12.3.2019**, E. 2018/437, K. 2019/203; Yargıtay 16. CD, **17.6.2019**, E. 2018/4588, K. 2019/4231; Yargıtay 16. CD, **2.3.2018**, E. 2018/588, K. 2018/718.

⁹⁰ Zorunluluk halinin özellikle bir "hukuka uygunluk sebebi" mi yoksa KUSURLULUĞU ET-KİLEYEN bir SEBEP mi olduğu konusundaki doktriner tartışmaların aksine, ceza hukuku mevzuatımızda yer alan bu konudaki hükümlerin değerlendirmesine ve uygulanmasına ilişkin içtihatlarla pek nadir rastlanmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına konu teşkil eden ve zorunluluk haline ilişkin hükümlerin uygulanması bakımından önem arz ettiğini düşündüğümüz iki olay, aşağıda özetlenerek değerlendirilmiştir:

I. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun **12.3.2019** tarihli ve E. 2018/437, K. 2019/203 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ... İli ... İlçesi ... Köyünde ikamet eden S, evine gelen **terör örgütü mensubu silahlı iki kişinin** kendisinden gübre ve yiyecek istemesi üzerine önce bu talebi reddeder. Ancak bu kişilerin kendisini **tehdit** etmesi üzerine yardımda bulunmayı kabul eder ve örgüt mensuplarınca verilen para karşılığında kendisinden istenen malzemeleri ilçe merkezinden alıp köye döndükten bir gün sonra söz konusu malzemeyi evinin yakınında bulunan ve bu kişilerce tarif edilen yere bırakarak teslim almalarını sağlar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile, bu olayda S'nin TCK, m. 28 hükmünden yararlanamayacağına karar vermiştir:

Söz konusu olayda terör örgütü mensubu silahlı kişilerin “S’yi **tehdit** ettikten sonra evden ayrılmış olmaları, böylece tehdit eyleminden söz konusu malzemelerin teslim edildiği ana kadar geçen bir günlük süre zarfında örgüt mensuplarınca yapılan tehdidin ağırlığını ve korkutucu etkisini kaybetmesi, bu süre içerisinde köyden ayrılıp ilçe merkezine giden S’nin olayla ilgili ihbarda bulunma ve örgüt mensuplarını yakalatma olanağına kavuşmasına rağmen bu yola başvurmayarak suça konu malzemeleri alıp örgüt mensuplarına teslim etmesi ve olaydan sonra da ihbarda bulunmaması karşısında, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen tehdidin başta ağır ve korkutucu etkisinin bulunduğu kabul edilebilir ise de bu etkinin suça konu malzemelerin örgüt mensuplarına teslim edildiği ana kadar devam etmediği ve S’nin bu tehdidin etkisinden geçici süreyle de olsa kurtulduğu anlaşılmakla; S’nin maruz kaldığı **tehdidin** örgüte yardım etme **kastını ortadan kaldırarak nitelikte karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı**

Örgüte üye kazandırma yönündeki çabalar da, örgüt üyesi olarak cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Örgütün ihtiyacı olan malzemenin para karşılığında veya karşılıksız olarak temin edilmiş olmasının, suçun oluşumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır⁹¹.

Yapılan yardımdan örgüt mensupları tarafından fiilen yararlanılmış olması gerekmemektedir. Yapılan yardımın örgüt mensuplarının istifadesine sunulmuş olması, örgüt mensuplarının bunlar üzerinde tasarruf imkanının doğması, suçun tamamlanması için yeterlidir⁹².

Örgüt mensuplarına yapılan yardım, aynı zamanda örgüte yapılan yardım olarak değerlendirilmek gerekir. Ancak, bu yardımın **örgütün amacını gerçek-**

ağır ve muhakkak nitelikte olmadığından, sanığa atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulü gerekmektedir.”

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kusurluluğu kaldıran cebir ve tehdit etkisinde hareket etmeye ilişkin TCK, m. 28 hükmünü uygularken genişletici yorum yöntemini işletmek gerekir. Tehdit edenlerin terör örgütü mensubu silahlı kişiler olduğunu ve mensup oldukları terör örgütünün S'nin ikamet ettiği yerleşim bölgesinde varlığını sürdürdüğü vakıalarını göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi takdirde bu içtihatlar terör örgütüne insan devşirme sonucu doğurur.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, söz konusu karar gerekçesi, maddi ceza hukuku bakımından da tutarsızdır. Cebir veya tehdit etkisinde kalınarak bir fiilin işlenmesi halinde, maruz kalanın cebir veya tehdit, bu fiile ilişkin kastı ortadan kaldırmaz, sadece kusurluluğu etkiler. Dolayısıyla, söz konusu olayda TCK, m. 28 hükümlerinin uygulanması halinde de terör örgütüne yardım suçunun oluşacağını ve fakat, yardım eden kişinin maruz kaldığı cebir veya tehdidin etkisiyle kusurunun bulunmadığını kabul etmek gerekirdi.

II. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.02.2019 tarihli ve E. 2017/1104, K. 2019/137 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ayrılıkçı terör örgütünün faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölgede bir köy kırsalında eşi ve eşinin ağabeyiyle birlikte oturan A'nın evine gece geç saatlerde silahlı vaziyette gelen terör örgütü mensupları, bir miktar (330 TL) para vererek, ihtiyaç duydukları bazı gıda ve sair malzemeyi satın alıp kendilerine getirmesi için A'yı sabahleyin ilçe merkezine gönderirler. A da sipariş verilen malzemeleri satın alır. Ancak, kendisine verilen para yetersiz kalınca cebinden 50 TL daha harcar. A, temin ettiği bu malzemeleri evine gelen ve kendisi dönünceye kadar evinde kalmaya devam eden örgüt mensuplarına verir.

Bu olayla ilgili olarak merciler arasında A'nın terör örgütüne yardım suçundan dolayı mı yoksa terörizmin finansmanı suçundan dolayı mı mahkûm edilmesi gerektiği tartışma konusu olmuştur. Sonuçta kişinin terörizmin finansmanı suçunu işlediği kabul edilerek hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

Ancak, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyelerinden birinin karşı oyuna ilişkin gerekçenin dışında, bu olay bağlamında mercilerce verilen kararların hiçbirinde, A'nın içinde bulunduğu koşullar itibarıyla başka türlü hareket etme imkan ve iktidarının bulunup bulunmadığı tartışılmamıştır.

Bu tarz uygulamalar, ancak terör örgütünün amaçlarına hizmet eder ve bölge halkının terör örgütünün korkutucu gücüne boyun eğmesini sağlar.

⁹¹ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 27.

⁹² KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 35.

leştirmeye hizmet eden bir yardım olması gerekmektedir. Bu nedenle, örgüt mensuplarına yapılan her türlü yardımı suç olarak tavsif etmemek gerektiği kanısındayız. Meselâ, hasta veya yaralı olan örgüt mensubuna iyileşmesi için tıbbî müdahalede bulunulması, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Ancak, meselâ gerektiğinde tıbbî müdahalede bulunmak üzere kendisini örgüte, örgüt mensuplarına hizmete adanmış olan ve bu amaç çerçevesinde örgüt mensuplarına tıbbî yardımda bulunan kişiyi, örgüt üyesi olarak cezalandırmak gerekir^{93,94}.

Keza, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubu olsa bile, meselâ aç kalan, donma tehlikesiyle karşı karşıya gelen bir kişiye yapılan yardım, esas itibarıyla, suç olarak nitelendirilemez.

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubuna sırf insanî mülahazalarla yardımda bulunulması, suç teşkil etmemekte ise de; yardımda bulunan, yardım ettiği kişinin bir örgüt mensubu olduğunu bilmesi halinde, durumu derhal suçu takibe yetkili makamlara **haber verme yükümlülüğü** altındadır⁹⁵. Bu yükümlülüğe aykırı davranış, TCK'da müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır (m. 278, f. 1: “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”). Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte mensubiyet devam ettiği sürece, işlenmekte olan (mütemadi, kesintisiz) bir suç söz konusudur.

Örgüte yardım fiili bağlamında dikkat edilmesi gereken birinci husus, **yardım fiili başlı başına bir suç oluşturmaya bile** örgüte yardım eden kişiye TCK'nın 220. maddesinin yedinci fıkrası ile 314. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine istinaden ceza verilecektir. Örneğin örgütle hiyerarşik bağlantı-

⁹³ ÖZGENÇ, İÜHFM LV(1997), sh.55.

“Örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteren ... mensuplarını evlerinde barındırma ve dış tedavilerini sağlama şeklinde gerçekleşen ve örgütün amacına hizmet eden eylemler.. örgüte yardım etme suçunu oluştur”ur: Yargıtay 16. CD, 13.2.2020, E. 2019/2837, K. 2020/1096.

“Örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteren mensuplarına gıda malzemesi sağlama, şoförlüğünü yapma ve bilgi aktarma şeklinde gerçekleşen ve örgütün amacına hizmet eden eylemler.. örgüte yardım etme suçunu oluştur”ur: Yargıtay 16. CD, 8.6.2020, E. 2020/1306, K. 2020/2410.

“Örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteren mensuplarını evinde barındırma, sınırdan geçmelerine yardımcı olma ve gıda malzemesi verme şeklinde gerçekleşen ve örgütün amacına hizmet eden eylemler.. örgüte yardım etme suçunu oluştur”ur: Yargıtay 16. CD, 1.6.2020, E. 2020/1314, K. 2020/2141.

⁹⁴ Güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürülen terör örgütü mensubunun defnedildiği mezarlıkta mezar yapımıyla ilgili olarak çimento taşıyan kişinin fiili, terör örgütüne yardım olarak değerlendirilmiştir (?): Yargıtay 16. CD, 26.11.2020, E. 2019/9151, K. 2020/5876.

⁹⁵ *Rebmann*'ın aynı doğrultuda görüşü için bkz. *Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele*, İstanbul 1996, sh. 82 vd.

sı bulunmayan araç sahibi bir kişinin örgüt mensuplarının veya örgüte ait malzemenin bir yerden başka bir yere naklini gerçekleştirmesi halinde, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte yardım etmiş olmaktadır.

Örgüte **yardım fiilinin başlı başına bir suç oluşturmaması** halinde ise, örneğin şayet örgüte silah temininde bulunulmuş ise, bu durumda TCK'nın **farklı nev'iden fikri içtimaa** ilişkin hükümleri (m. 44) göz önünde bulundurularak, bu suçlardan (silah temini suçundan veya örgüt üyeliğinden) dolayı verilecek cezalardan hangisi daha ağır ise, kişinin sadece bu suçun cezası ile cezalandırılmasıyla yetinilmesi gerekmektedir^{96, 97}.

Ancak belirtmek gerekir ki, 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı **Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun** 4. maddesinde **terör örgütüne salt fon sağlamak**, “**Terörizmin finansmanı suçu**” olarak tanımlanmıştır. Bu suç, TCK'nın 220. maddesinin yedinci fıkrası ile 314. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine nazaran **özel bir hüküm** mahiyeti taşımaktadır. Dolayısıyla, terör örgütüne “*para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belge*” olarak tanımlanan **fön** sağlanması halinde, kişi örgüte yardım etmek dolayısıyla değil, terörizmin finansmanı suçundan dolayı cezalandırılacaktır⁹⁸.

⁹⁶ Örneğin TCK'nın 314. maddesinde tanımlanan suçun konusunu oluşturan silahlı örgüte silah temini 315. maddede bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 315. maddede tanımlanan suçun cezası, 314. maddede tanımlanan silahlı örgüt üyeliği suçuna nazaran daha ağır olduğu için, silah temin eden kişinin, silahlı örgüt üyeliği suçundan (m. 314, f. 2) dolayı değil, 315. maddede tanımlanan suçtan dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

Dikkat edilmelidir ki, 315. maddede tanımlanan suç, ancak 314. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan silahlı örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmayan kişiler tarafından işlenebilir. Başka bir ifadeyle, 314. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan silahlı örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olan kişiler, 315. maddede tanımlanan suçun faili olarak sorumlu tutulamazlar.

⁹⁷ Bir olayda, kamu görevlisi olan ve suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgütün üyesi oldukları kabul edilen kişilere, görevleriyle bağlantılı bir işin gördürülmesini sağlamak amacıyla rüşvet verilmiş olmakla, aynı zamanda örgüte yardım edilmiştir. Bu durumda, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün üyesi kabul edilen kamu görevlilerine görevleriyle bağlantılı bir işin gördürülmesi amacıyla menfaat sağlanmış olmakla, hem suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte yardım etmek hem de rüşvet suçlarından dolayı ayrı ayrı cezaya değil, **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümlerine göre **sadece daha ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı** tek cezaya hükmetmek gerekir.

Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **23.2.2010** tarihli ve E. 2010/9-7, K. 2010/37 sayılı Kararında “... **Lisesi duvarına terör örgütünün propagandası niteliğinde yazı yazılması**” fiili, **silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu** oluşturduğu ve bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

⁹⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM, Zeki: *Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma*, Ankara, 2013, sh. 85 vd.

İkinci husus ise, **yardım eden kişinin örgüt mensubu olmaması gerekir**⁹⁹. Şayet kişi örgüt üyesi olarak örgütün ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak amacıyla yönelik olarak başlı başına suç oluşturmeyen birtakım faaliyet icra etmiş ise, TCK'nın 220. maddesinin yedinci fıkrası delaleti ile değil, doğrudan örgüt üyesi olmak dolayısıyla (TCK, m. 220, f. 2 ; m. 314, f. 2) cezalandırılmak gerekir. Örneğin örgüt üyesi olan kişinin örgütün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tahsis edilmiş fırında ekmek pişirmesi, örgüte mahsus terzihanede örgüt mensuplarının ihtiyacı olan giyecekleri dikmesi halinde, kişi esasında örgütün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olduğu ve dolayısıyla örgüt üyesi sıfatını taşıdığı için, doğrudan örgüt üyesi olmak dolayısıyla (TCK, m. 220, f. 2; m. 314, f. 2) cezalandırılması gerekir.

Bu itibarla, kişinin örgüte yardım dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, örgütün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmaması ve dolayısıyla, örgüt üyesi sıfatını taşıması gerekir¹⁰⁰.

⁹⁹ Ancak işaret etmemiz gerekir ki, terör örgütüne fon toplayan kişi, 314. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan silahlı örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olabilir. Bu durumda fon toplayan kişinin, hem 314. madde hükümlerine istinaden, hem de 6415 sayılı **Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun**un 4. maddesinde tanımlanan "**Terörizmin finansmanı suçu**"ndan dolayı, cezalandırılması gerekir.

Fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu,

¹⁰⁰ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun, **14.12.2010** tarihli ve E. 2010/9-88, K. 2010/255 sayılı Kararında, örgüte yardım etme fiilinin örgüt üyesi olarak cezalandırmayı gerektiren hükümlerine ilişkin şu değerlendirmede bulunulmuştur:

"5237 sayılı TCK'nın, 314. maddesinin 3. fıkrasında; *"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır"* hükmüne yer verilip, örgüt kurma suçuna ilişkin 220. maddenin 7. fıkrasında ise *"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak"* cezalandırılacağı belirtilmiş, anılan normun konuluş amacı, gerekçesinde; *"Örgüte hakim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişi, örgüt üyesi kabul edilerek cezalandırılır"* şeklinde açıklanmış, 765 sayılı TCK'nın sistematüğinden tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen maddede, örgütün faaliyetleri doğrultusunda işlenen suçlardan da ayrıca sorumluluk esası kabul edilmiş, yardım etme fiilleri de örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek, bağımsız bir şekilde örgüte yardım suçuna yer verilmemiş, gösterdiği vahamet dikkate alınarak örgüte silah sağlama şeklindeki yardım fiilleri 315. maddede bağımsız olarak, diğer yardım fiilleri ise örgütün niteliğine göre anılan Yasanın 220 ile 314. maddeleri kapsamında yaptırıma bağlanmıştır."

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **31.10.2012** tarihli ve E.2012/9-1234, K. 2012/1825 sayılı Kararında **örgüte yardımla** ilgili olarak şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

"765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistematüğinden tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen (yeni TCK'nın 314. maddesinin yollamada bulunduğu 220.) madde(sin)de, örgütün faaliyetleri doğrultusunda işlenen suçlardan da ayrıca sorumluluk esası kabul edilmiş, yardım etme eylemleri de yaptırım açısından örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek, bağımsız bir şekilde örgüte yardım suçuna yer verilmemiş, gösterdiği vahamet dikkate alınarak örgüte silah sağlama şeklindeki yardım

fiilleri 5237 sayılı TCK'nın 315. maddesinde bağımsız olarak, diğer yardım fiilleri ise örgütün niteliğine göre anılan Yasanın 220 ile 314. maddeleri kapsamında yaptırıma bağlanmıştır.

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı hüküm altına alınırken, örgüte yardım sayılan eylemlerin nitelik bakımından örgüt üyeliğine denk sorumluluğu gerektirdiği kabul edilmiştir. Buna göre, örgüt üyesi olmaksızın, bilerek ve isteyerek örgütün bir iş, görev ya da hizmetinin yerine getirilmesi eylemi örgüt üyeliği olarak cezalandırılmakta iken; (220.) maddenin 7. fıkrasında 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, yapılan yardımın niteliğine göre cezanın üçte birine kadar indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

...

Silahlı terör örgütlerinin amaç suçları işleme yolunda oluşturdukları yapılanmalarının ortak özellikleri dikkate alındığında, gizlilik ve güvenlik konularına aşırı duyarlı oldukları, gizlilik ve güvenlik ihtiyacı geniş bir alanda faaliyet gösterme durumuyla birleşince, detaylandırılmış bir işbölümü olgusunun ortaya çıktığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamış yani görev ve denetime bir örgüt üyesi düzeyinde henüz hazır olmayan yardım etme suçunun failleri bakımından eksik kalabilecek olan gizlilik ve güvenlik ihtiyacının, detaylı bir işbölümü ile sağlandığı, **yardım edenler zamanlarının büyük bir bölümünü örgüte hasretmiş kişiler olmayıp kendi hayatlarının akışı içerisinde bazen örgüte ait işleri kabul eden şahıslar olduğundan**, yardım faaliyetlerinin birden fazla bölümler halinde gerçekleştirilmesinin çoğu kez bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Örneğin, vücut ısıtıcısı gibi ülkede bulunması zor olan bir eşyanın yurt dışından satın alınıp kırsaldaki bir kampa iletilmesi biçimindeki yardım olayında, yurt dışından bu eşyayı satın alan ile bu eşyayı örgüt üyesine teslim edecek olan mevsimlik orman işçisi arasında, bu kişilerden farklı görevleri üstlenmiş birbirini tanıyan ya da tanımayan, farklı zamanlarda yakalanan ya da hiç yakalanmayan birden fazla kişi olabilecektir. Böyle durumlarda failin örgütçe verilen bir iş ya da görevi veya kendiliğinden örgüt nam ve hesabına üstlendiği bir iş ya da görevi, yardım olayının akışı içinde kendisinden önceki failin getirdiği aşamadan bağımsız olarak tamamlayıp tamamlamadığına bakılmalıdır. Söz konusu iş, görev ya da hizmet tamamlanmışsa failin yardım suçunun da tamamlandığı, buna karşılık, örgüte yardım etme eylemini gerçekleştirme kararı alarak elverişli hareketlerle iş ya da görevin doğrudan doğruya icrasına başlayan failin, elinde olmayan nedenlerle görevi tamamlayamaması ya da sonuç alamaması halinde de suçun teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilmeli, tüm bu olgular olaysal olarak değerlendirilip sanığın hukuksal durumu belirlenmelidir. Başka bir anlatımla; **örgüte yardım suçunun tamamlanıp tamamlanmadığı hususu, bu yardım konusuyla ilgili diğer kişi ya da failerin eylemlerinden bağımsız olarak fail tarafından üstlenilen ya da kendisine verilen görevin tamamlanıp tamamlanmadığına göre belirlenmelidir.**

...

Örgütsel faaliyetlerde “kullanılmak üzere bir kısım kişilerce hazırlanan propaganda malzemeleri, ilgililere ulaştırılmak üzere araçla nakledilirken görevlilerce ele geçiril(diğ)ine” göre, ... malzemelerin hazırlanmasında görev alan ... kişilerin görevlerinin tamamlandığı, buna karşın ... malzemelerin hazırlanma aşamasına katılmayıp yükleme ve nakil safhasında görev aldığı, böylelikle de örgüt üyesi olmayan sanığın söz konusu malzemeleri kullanılmak üzere nakletme biçiminde eylemine devam ederken istenen yere ulaştıramadan kendisine verilen ya da üstlendiği yardım görevini görevlilerin müdahalesi nedeniyle tamamlayamadığı ... (durumda), **silahlı örgüte yardım etme suçunun tamamlanmadığı ve teşebbüs aşamasında kaldığı** kabul edilmelidir.

Kaldı ki, failin hem propaganda malzemelerinin hazırlanması, hem de yerine ulaştırılması görevinin bulunduğu ve malzemelerin hazırlanması tamamlandıktan sonra **nakil sırasında yakalandığı kabul edilse bile, örgüte yardım suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilecektir.** Zira böyle bir halde, failin üstlendiği ya da kendisine verildiği anlaşılan görev sadece propaganda malzemesinin hazırlanması olmayıp aynı zamanda bunların istenen yere nakledilmesidir ki, fail henüz bu görevi elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamıştır. Somut olayda, kendisine verilen ya da üstlenilen görev sadece bu malzemelerin hazırlanmasından

Örgüte yardım fiili ani bir hareketle gerçekleşebileceği gibi, yukarıda vermiş bulunduğumuz nakliye işinin üstlenmesine ilişkin örnekte olduğu gibi, **temadi eden bir fiille** de gerçekleştirilebilir.

Örgüt mensubu olmayan kişinin yaptığı yardım, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen somut bir suçla bağlantılı olabilir. Bu durumda yapılan yardım, işlenen somut **suça iştirak** olarak değerlendirilmelidir. Örgüte hakim olan hiyerarşik yapı içinde yer almayan kişi, işlenen suça iştiraktan dolayı cezalandırılmakla beraber, ayrıca örgüt üyesi olarak cezalandırılmayacaktır.

IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENİ VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMELERİ AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI

Kanun koyucu, belli nitelikteki suçları işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulmuş örgütü yönetme ya da bu örgüte üye olma fiillerini ayrı suçlar olarak tanımlamıştır.

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım altındaki “**Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar**” başlıklı Dördüncü Bölümde ve “**Anayasal Düzen ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar**” başlıklı Beşinci Bölümde

ibaret olan bir sanığın eyleminin tamamlanmış şekilde örgüte yardım suçunu oluşturacağı kabul edilirken, görevi malzemelerin hem hazırlaması hem de nakli olan sanığın eyleminin örgüte yardıma teşebbüs olarak kabulü de bir çelişki oluşturmamaktadır. Hakim tarafından cezanın belirlenmesi sırasında 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler göz önüne alınacak, ayrıca 6352 sayılı Yasanın 85. maddesiyle değiştirilen 220. maddenin 7. fıkrası kapsamında yapılacak indirim miktarı "yardımın niteliğine göre" belirlenecek, böylece hakkaniyet uygun olarak ceza adaleti temin edilebilecektir.”

Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararına göre, silahlı terör örgütüne propaganda malzemesi üretilmesi, nakli ve teslimi işini üstlenmiş olan kişinin bu malzemeyi ürettikten sonra nakil sırasında kolluk görevlileri tarafından yakalanması halinde, terör örgütüne yardım suçu (TCK, m. 314, f. 2) teşebbüs aşamasında kalmaktadır. Bu tespit **doğrudur**. Ancak, propaganda malzemesinin üretilmesinden teslimine kadarki süreçte farklı kişilerin görev alması durumunda ise, Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararına göre, propaganda malzemesini üreten bakımından örgüte yardım suçu tamamlanmış ve fakat nakli sırasında yapılan aramada bulunan bu malzemeye elkonulmuş ise, nakleden kişi bakımından terör örgütüne yardım suçu (TCK, m. 314, f. 2) teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu kabul ise **doğru değildir**. Bu kabul, suça iştirak hükümlerini bertaraf eden bir sonuç doğurmaktadır. Oysa, propaganda malzemesi üretmek işi, terör örgütüne yardım suçunu oluşturur. Bu suçun icrasına propaganda malzemesinin üretilmesiyle başlanmakta ve suç, üretilen bu malzeme üzerinde örgüt mensuplarının tasarruf imkanının doğduğu anda, yani bu malzemenin örgüt mensuplarına teslimi ile tamamlanmaktadır. Söz konusu propaganda malzemesi üretilmekle birlikte, elde olmayan sebeplerle örgüt mensuplarına teslim edilememiş ise, iştirak halinde işlenen örgüte yardım suçunun bütün suç ortakları bakımından teşebbüs aşamasında kaldığını kabul etmek gerekir. Açıklanan nedenlerle, Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararını sorunlu görmekteyiz.

“**yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt**” kurmak veya yönetmek ya da bu örgüte üye olmak fiilleri, 220. maddeye nazaran daha ağır cezayı gerektiren müstakil suçlar olarak tanımlanmıştır (TCK, m. 314, f. 1, 2).

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler (TCK, m. 220, 221), 314. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçlar bakımından da aynen uygulanacaktır (TCK, m. 314, f. 3).

Madde **gerekçesinde** bu hususlara ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁰¹:

*“Maddenin birinci fıkrasında, bu fıkra kapsamına giren suçları işlemek amacıyla **silâhlı örgüt kurmak veya yönetmek**, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu nitelikleri taşıyan **örgüte üye olmak**, ayrı bir suç olarak yaptırım altına alınmıştır.*

*Maddede geçen temel kavram örgüttür. Dikkat edilmelidir ki, genel olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgüte üye olmak, kanunda yaptırım altına alınmış olmasına rağmen; bu maddede, **işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından** bir sınırlama getirilmiştir. Keza, her iki suç arasında örgütün niteliği bakımından da farklılık bulunmaktadır. Bu madde kapsamına giren **örgütün silâhlı olması** gerekmektedir. Başka bir deyişle, silâh, bu suçun bir unsurunu oluşturmaktadır. Ancak, örgütün bütün mensuplarının silâhlı olmaları zorunlu değildir; **hedeflenen suçların işlenmesini sağlayabilecek derecede** olmak üzere bazı üyelerin silâhlı olmaları, suçun oluşması için yeterlidir. Her hâlde silâh sayısının suçun oluşması bakımından yeterli olup olmadığının takdiri de hâkime aittir.*

Maddenin üçüncü fıkrasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümlerin, bu suç açısından da aynen uygulanacağı kabul edilmiştir.

Bu suça ilişkin diğer hususlar hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna ilişkin madde gerekçesi ile bu suçla bağlantılı etkin pişmanlık hükmünün gerekçesine bakılmalıdır.”

Kanunda, Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulmuş silâhlı örgüte silah temini bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır (m. 315):

¹⁰¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 702.

“Yukarıdaki maddede (TCK, m. 314) tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁰²:

*“Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere **silâh, cephan**e veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye’ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır.*

*Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, **örgütlerin amaçları bilinerek** gerçekleştirilmesidir.*

*Söz konusu maddelerin kullanılması suretiyle ve örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçların işlenmesi hâlinde; bu silâh ve cephaneyi temin eden kişiler, aslında bu suçların işlenişine yardım eden olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak, söz konusu fiiller bu madde kapsamında müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, **sadece bu suçtan dolayı** cezaya hükmetmek gerekecektir.”*¹⁰³

¹⁰² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 702.

¹⁰³ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **24.2.2009** tarihli ve E. 2008/9-78, K. 2009/39 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, M ve Z ye ait evin kömürlüğünde patlayıcı madde ele geçirilir.

CGK, söz konusu kararında, aşağıdaki gerekçelerle, sanıklar hakkında sadece TCK’nın 315. maddesi hükmüne istinaden mahkûmiyet hükmü kurulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

“765 sayılı TCK’nın silahlı çetenin sair efradı olmak suçunu ve yaptırımını düzenleyen 168/2 ve silahlı çete mensuplarının hal ve sıfatlarını bilerek yardım ve yataklık etmek suçunu ve yaptırımını öngören 169. maddeleri kaldırılmış, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’da örgütlü suçlar yönünden yeni ve farklı bir düzenleme benimsenmiştir. Bu yasada suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin hükümlere 220. maddede yer verilip, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçları ise, 314. maddenin 1 ve 2. fıkralarında tanımlanıp yaptırımı bağlanmış, 314. maddenin 3. fıkrasında; “*Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler*”in, bu suç açısından da aynen uygulanacağı belirtilmiştir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin 220. maddenin 6. fıkrasında, “*Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı*” cezalandırılacağı hükmüne yer verilip, anılan normun konuluş amacı gerekçesinde; “*Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır*” şeklinde açıklanmış, aynı maddenin 7. fıkrasında da; “*örgüt içindeki hiyerar-*

şik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi'nin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı belirtilmiş, böylece örgüt mensubu olmasa bile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmiş olanlar ile örgüt adına suç işleyenlerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü gibi, 765 s. TCK'nın sistematüğinden tamamen farklı bir anlayışla yapılan bu düzenlemelerde örgütün faaliyetleri doğrultusunda işlenen suçlardan da ayrıca sorumluluk esas kabul edilmiş, yardım etme eylemleri de örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek, bağımsız bir yardım suçuna kural olarak yer verilmemiştir.

Ancak, gösterdiği vahamet dikkate alınarak örgüte silah sağlama şeklindeki yardım eylemleri, bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş, 5237 sayılı TCK'nın, "*Silah sağlama*" başlığını taşıyan 315. maddesinde, "*Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır*" hükmüne yer verilmiştir.

Maddede düzenlenen suç, örgüte yardımın özel bir şekli olup, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bunların amaçlarını bilerek, üretmek, satın almak ve ülkeye sokmak suretiyle silah, cephane veya nitelik ve nicelik yönünden vahim olan benzeri maddelerin temin edilmesi, nakledilmesi ve depolanması bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş ve daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Nitekim madde gerekçesinde,

"Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere silâh, cephane veya benzeri maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye'ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır.

Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçları bilinerek gerçekleştirilmesidir.

Söz konusu maddelerin kullanılması suretiyle ve örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçların işlenmesi hâlinde; bu silâh ve cephaneyi temin eden kişiler, aslında bu suçların işlenişine yardım eden olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak, söz konusu fiiller bu madde kapsamında müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, sadece bu suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir."

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu suçun oluşması için failin, örgütün faaliyetlerinde kullanılacağını bilerek "üretmek, satın almak, ülkeye sokmak suretiyle silah temin etmek" veya "nakletmek" ya da "depolamak" şeklinde sayılan, seçimsiz eylemlerden birisini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Suçun manevî unsuru ise, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere söz konusu eylemlerin, örgütün amaçlarını bilerek gerçekleştirilmesi, yani kasttır."

CGK'nın kararına göre, "*yakalanan (doğrusu, arama yapılarak bulunup elkonulan) bu malzemelerin yasa dışı PKK/KONGRA-GEL örgütüne ait olduğu konusunda kuşku yoktur. ... Sanıkların, amacını bildikleri yasa dışı silahlı örgüte ait vahim miktardaki patlayıcı maddeleri saklamak eylemleri, silahlı örgütler bakımından "yardım eden" kavramı ile ilgili özel bir düzenleme olan 5237 sayılı TCK'nın 315. maddesinde düzenlenen suça uymaktadır."*

Buna karşılık, Esas Mahkemesi olarak direnme kararı veren İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi ile, CGK'nın söz konusu kararına muhalif kalan Kurul Üyesi Şerafettin İste'nin görüşüne göre ise, sanıklar hakkında TCK'nın 174. maddesinde tanımlanan suç (f. 1, 2) ile terör örgüt üyesi olmak suçundan dolayı (TCK, m. 314, f. 2) mahkûmiyet kararı verilmesi gerekir. İste'nin görüşüne göre, "*esasen örgüte ait olup, örgüt mensuplarınca her nasılsa elde edilmiş patlayıcı maddeleri, silahları onların uygun zamanda, belirlenen yerlerde patlatılana kadar geçici olarak muhafaza eden, yardımcı olan kişilere de 220/7. maddesi aracılığı ile 314/2. maddeden ceza verilecektir."*

X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun “**Terör örgütleri**” başlıklı 7. maddesinde “**terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar(ın) Türk Ceza Kanununun 314’üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırıl**”acakları hüküm altına alındıktan sonra, terör örgütünün propagandası müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır.

Mülga 765 s. TCK’nın sisteminde, 168 ve 313. maddelerde yapılan suç örgütü tanımlarının haricinde, Terörle Mücadele Kanununun değiştirilen 7. maddesinde ayrıca bir terör örgütü suçu tanımı yapılmaktaydı. Böylece, **üçlü bir örgüt suçu tanımlaması** sistemi mevzuatımıza sokulmuştu. Keyfi uygulamalara sebebiyet verecek bir mahiyet taşıyan bu düzenleme, 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 5532 s. Kanunla değiştirilen 7. madde düzenlemeyle, yeni Türk Ceza Kanununun 220 ve 314’üncü maddelerine işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Buna göre, Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesindeki amaçları gerçekleştirmek için; cebir ve şiddet kullanılarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle suç işlemek üzere kurulan **silahlı örgütler**, terör örgütü olarak kabul edilmiştir.

Buna karşılık, suç işlemek için kurulmuş olmakla birlikte, silahlı olmayan örgütlerle ilgili olarak, Terörle Mücadele Kanunu hükümlerinin değil, genel

CGK’nın kararında kabul edildiği üzere, M ve Z terör örgütü üyesidirler. Elkonulan silah ve patlayıcı maddeleri bu kişiler temin etmemişlerdir. Örgüt tarafından herhangi bir surette temin edilmiş olan bu silah ve patlayıcı maddeler, örgüt üyesi M ve Z tarafından saklanmışlardır. Bu nedenle, Karara konu teşkil eden olayda 315. madde hükmünün uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır. Aksi takdirde, örgüt üyesi olup da elinde silah veya patlayıcı madde bulunduran, bu malzemeleri üreten, saklayan, nakleden herkesin sadece TCK’nın 315. maddesi hükmüne istinaden cezalandırılması yolu açılmış olur; yani bu durumda kişinin ayrıca örgüt üyesi ve hatta yöneticisi olarak cezalandırılması yoluna gidilemez. Bu durumda ise, söz konusu kişiler hakkında mevzuatımızın örgüt mensubu suçlulara ilişkin hükümleri (TCK, m. 58, İnfaz K, m. 107, 108) uygulanamaz.

Nitekim 3713 s. Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanuna ilişkin TBMM Adalet Komisyonunun 26.6.2006 tarihli ve Esas: 1/1194, Karar: 106 sayılı Raporunda bu bağlamda şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Türk Ceza Kanununun 315’inci maddesinde tanımlanan örgüte silah sağlama suçu ancak, örgüte mensup olmayan, örgütün yöneticisi veya üyesi olmayan kişiler tarafından işlenebilen özel bir suçtur.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, Eylül 2006 sh. 29; Terörle Mücadele Kanunu, Değişiklikler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Raporları, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Yayını [yayın yılı belirtilmemiş], sh. 263).

Bu mülahazalarla, **CGK’nın söz konusu kararını sonuç itibarıyla doğru bulmuyoruz.**

olarak TCK'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin hükümlerinin (m. 220, 221) uygulanması gerekecektir¹⁰⁴.

Maddenin ikinci fıkrasında terör örgütünün propagandası niteliğini taşıyan belirli fiillere açıklık getirilerek, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır^{105, 106, 107}.

¹⁰⁴ Terör örgütünün mahiyeti, terör örgütü kurucu veya yöneticiliği, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne yardım, terörizmin finansmanı, terörizmin propagandası, terör suçlarından sorumluluk, terör suçlarından dolayı cezalandırılabilirliğin alanını genişletme, sorumluluk alanını öne çekme konularında bir karşılaştırmalı hukuk çalışması için bkz. **Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu, 25.03.2019**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRK/CE-MER) yayını.

¹⁰⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **12.2.2008** tarihli ve E. 2007/9-230, K. 2008/23 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; sanıklar "amacı Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını silahlı mücadele vererek devlet idaresinden ayırıp bu bölgede (ayrı bir devlet) kurmak olan PKK terör örgütü elebaşının yakalanması üzerine, örgüt tarafından Kürdistan Demokratik Konfederalizm önderi olarak kabul edilen Abdullah Öcalan'ı sahiplenme kampanyası çerçevesinde ... örgütün ve amacının toplum içinde benimsenmesini sağlamaya yönelik olarak; "ben bir Kürdistanlı olarak, Kürdistan'da sayın Abdullah Öcalan'ı bir siyasal irade olarak görüyorum ve kabul ediyorum" ibarelerini içeren bildirileri kişilere imzalatırlar.

CGK, bu olayda aşağıdaki gerekçe ile terör örgütü üyeliği suçundan dolayı değil, terör örgütünün propagandası suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

"3713 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 7/2. maddesinde;

"...örgüt mensuplarına yardım edenlere veya şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca..." cezalandırılacağı belirtilmiş,

5237 sayılı TCK'nın 220/7. maddesinde ise; "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır." hükmüne yer verilmiş, terör örgütüne üye olmak ise aynı Yasanın 314/2. maddesinde yaptırma bağlanmıştır.

3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 220/7. maddesinin unsurları benzerlik arzietmekte ve bir kısım fiiller her iki maddede de düzenlenmiş bulunmakta ise de, uygulamada benimsenen en ayırıcı ölçüt yardım fiillerinin maddi nitelikte bulunup bulunmamasıdır. **Maddi nitelikteki yardım fiilleri** suç tarihinde yürürlükte bulunan normlar dikkate alınmak suretiyle 5237 sayılı **TCK'nın 220/7. maddesi kapsamında, maddi nitelikte olmayan fiiller ise 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.**"

Benzer bir olayla ilgili olarak verilmiş aynı yönde diğer bir karar için ayrıca bkz. CGK, **3.3.2009**, E. 2008/9-184, K. 2009/43.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **23.2.2010** tarihli ve E. 2010/9-7, K. 2010/37 sayılı Kararında, "... **Lisesi duvarına terör örgütünün propagandası niteliğinde yazı yazılması**" fiili, **silahlı terör örgütüne yardım etme** suçunu oluşturduğu ve bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

¹⁰⁶ Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin, terör örgütünün propagandası fiillerini ceza yaptırımına altına alan ikinci fıkrası düzenlemelerinde çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Mesela, yüzünü tanınmayacak şekilde kapatarak izinsiz bir gösteriye katılan kişi de terör örgütünün propagandası suçunu işlemiş kabul edilmektedir (3713 s. K, m. 7. f. 2, bent a). Oysa salt bu fiil, propaganda suçunu oluşturmaz.

Bir toplantıya veya gösteri yürüyüşüne kimliğinin tespitine imkan vermeyecek şekilde katılmak propaganda suçundan ayrı bir suç veya kabahat olarak tanımlanabilir. Ya da kimliğinin

EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ

Kamuoyunda, "özel yetkili mahkemeler" olarak bilinen ve Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesi ve bilahare Terörle Mücadele Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre, terör suçlarına ve belirli örgütlü suçlara bakmakla görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile bu mahkemeler nezdinde görev yapan Cumhuriyet savcılarının üzerinden yapılan tartışmanın, bu mahkemelerin **varlığına** yönelik olduğu gözlemlenmektedir.

Ancak asıl sorunun, bu mahkemeler nezdinde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının yetkilerini hukuk zemininde kullanıp kullanmaması sorunudur. Nitekim bu "özel yetkili mahkemeler" in kuruluşunun dayanağını oluşturan söz konusu kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, benzer sorunlar günümüzde de yaşanmaya devam etmektedir. Hatta, söz konusu kanun hükümleriyle özel yetkili mahkemelere ve bu mahkemeler nezdinde görev yapan Cumhuriyet savcılarının verilen yetkiler, bu arada yapılan kanuni düzenlemelerle genel hüküm haline getirilmiş ve bütün soruşturma ve kovuşturmalar bakımından uygulanır hale getirilmiştir.

Ülkemizdeki asıl sorunun bir uygulama sorunu olduğu aşağıdaki örneklerle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Örnek 1: Ceza muhakemesindeki özel delil elde etme yöntemlerinden yararlanabilmek için "suç örgütü" nün varlığından bahisle soruşturma başlatılmaktadır.

tespitine imkan vermeyecek şekilde bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan kişinin bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında işlemiş bulunduğu suçtan dolayı verilecek cezanın bu nedenle belirli bir oranda artırılması yoluna gidilebilir.

¹⁰⁷ Terörle Mücadele Kanununun, Yükseköğretim Kanununa karşı düzenlenen yürüyüşü veya hükümet aleyhtarı bir toplu gösteriyi de "terör suçu" olarak kabul edebilen bir yapıda olduğu yönünde eleştirilerde bulunmaktadır.

2006 yılında yapılan değişikliklerin redaksiyon görevini yürütmüş bir akademisyen olarak, Terörle Mücadele Kanununda eleştiri konusu olan ve düzeltilmesi gereken çok yönler olduğunun bilincindeyiz.

Ancak, güncel olarak yaşadığımız sorunlar kanun düzenlemelerinden kaynaklanmamaktadır. Bunların önemli birer **uygulama sorunu** olduğunu kabul etmemiz gerekir. Genelkurmay başkanı olarak görev yapmış bir kişinin göreviyle bağlantılı olarak "terör örgütü yöneticisi" olmakla suçlanması, bunun en canlı örneğidir.

Sistemli bir şekilde yapılan bu uygulamalar, hakimlerin ve C. savcılarının bireysel değerlendirmeye hatalarına dayanmamaktadır. Bu uygulamalar karşısında, başta Hakimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu olmak üzere ilgili kamu otoriteleri, üzerine düşen görevleri yerine getirmemiştir ve halende getirmemektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununun belirli suçlara özgü delil elde etme yöntemlerinin kötüye kullanılmasını temin zımnında, daha soruşturmanın başlangıcında, henüz hiç bir somut delil elde mevcut olmamasına rağmen, kişiler arasındaki ilişkinin suç işlemek amacına yönelik örgütsel bir ilişki olduğu "kabul" edilmektedir.

Bu suretle, Ceza Muhakemesi Kanununun belirli suçlara özgü delil elde etme yöntemleri kötüye kullanılmaktadır.

Çoğu zaman bir suç örgütünün varlığı şüphesinden hareketle soruşturmanın yapılmasına ve iddianame düzenlenmesine rağmen, hüküm kurulurken olayda bir suç örgütünün bulunmadığı ve bu nedenle beraat kararının verildiği gözlemlenmektedir.

Hatta, bazı durumlarda, bir suç örgütünün varlığı şüphesinden hareketle soruşturma başlatılmasına ve CMK'nın özel delil elde etme yöntemlerine başvurulmasına rağmen, soruşturma sonucunda örgüt suçundan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmekte ve münferit diğer suçlardan dolayı iddianame düzenlenmektedir.

Bu uygulamalar, gelecekte Yüksek Mahkememiz içtihatlarında hukuka aykırı delil tartışmasının önemli bir yer tutmasına sebebiyet verecektir.

Keza, örgüt kavramının alanının gereksiz yere genişletmek, **yargılama faaliyetini de güçleştirmektedir.**

Pek çok suçun bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği ön kabulünden hareketle çok sayıda kişi hakkında oldukça kabarık sayfalı iddianameler düzenlenmektedir. Telefon konuşma tapelerinin kes-yapıştır yöntemiyle yer verildiği yüzlerce ve hatta **binlerce sayfadan oluşan iddianamelerin** duruşmada okunması bağlamında sorunlarla karşılaşmıştır. İddianamenin okunması, uygulamayı alaya alacak şekilde, günlerce sürebilmiştir. İddianameyi hazırlayan ve iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısı tarafından **bizzat** okuması gerekirken; iddianamenin, **TRT spikerleri** tarafından ve hatta, "**özet**"nin (!?) okutulması yoluna da gidilmiştir. İşaret etmemiz gerekir ki, bu garabetin önüne geçmek amacıyla bu arada, içeriğini doğru bulmadığımız bir kanuni düzenleme yapılmıştır¹⁰⁸.

Davaların ayrı ayrı görülmesi halinde pek çok suçu kısa bir zaman zarfında aydınlığa kavuşturmak ve hükme bağlamak mümkün iken, suçların **bir ör-**

¹⁰⁸ Ceza Muhakemesi Kanununun konuyu düzenleyen 191. maddesinin üçüncü fıkrasının b bendi, 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

güt faaliyeti çerçevesinde işlendiği ön kabulünden hareketle gereksiz yere davalar birleştirilmekte ve birbirleriyle ilgisi olmayan pek çok suç aynı davanın konusunu oluşturur ve birbirlerini tanımayan pek çok sanık aynı dava kapsamında yargılanabilir hale getirilmektedir.

Bu uygulama, **mahkemelerin hüküm vermesini oldukça güçleştireceği** gibi, vereceği kararları da toplumu oluşturan bireyleri tatmin etme bakımından kuşkulu kılacaktır.

Örnek 2: Soruşturmanın gizliliği ve bu suretle, kişilerin haberleşmelerinin ve özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmektedir.

Kişilerin haberleşme gizliliklerinin, özel hayatlarının gizliliklerinin korunması, özellikle masumluk karinesinden yararlanabilmeleri, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve suç delillerinin korunması amacıyla, **soruşturma evresinin gizliliği** kabul edilmiştir. Bu gizlilik, kural olarak soruşturmanın süjesi olmayan kişilere karşıdır. Bu itibarla, **soruşturmanın süjesi olan kişilere**, özellikle **şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar gizli tutulamaz** (CMK, m. 153, f. 3).

Ancak, uygulamamızda, soruşturma evresinde hakimden gizlilik kararı alınarak, dosya içeriğinden **şüpheli müdafinin de bilgi sahibi kılınmasının önüne geçilmektedir**. Bu uygulamayla **savunma hakkı** önemli ölçüde **kısıtlanmaktadır**. Bu gizlilik, soruşturmanın süjelerine ve özellikle müdafie karşı ancak istisnai işlemlerle sınırlı olarak söz konusu olabilmelidir. Soruşturmanın müdafie karşı gizliliği kural değil, ancak istisna olabilmelidir. Ancak, ülkemizde belirli suçluluk profili veya profilleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda, müdafie karşı gizlilik, uygulama itibarıyla, istisna değil kural haline dönüştürülmüştür.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, edindiğimiz tecrübeye göre, bazı soruşturma dosyalarının müdafie karşı gizli tutulmasının sebebini, dosya içeriğinde soruşturulan kişi hakkında somut bir suç isnadı konusunda yeterli bilgi bulunmaması oluşturmaktadır.

İşin başka bir ilginç yanı, uygulamamızda, hakkında soruşturma yapılan kişiye (şüpheliye) ve müdafisine gizli tutulan soruşturma dosyası içeriklerinin, bazı basın ve yayın organlarında yayımlanmasıdır. Avukat tarafından incelenmesine imkan tanınmayan bazı soruşturma işlemlerinin, şüpheli ve tanık ifadelerinin içeriği, televizyonlarda ve gazetelerde yayımlanabilmekte-

dir. Müdafinin görmesine ve incelemesine imkan verilmeyen tanık ifadesi gibi bazı soruşturma işlemleri, TCK'nın 285. maddesinde tanımlanan suç görmezlikten gelinerek, medya organlarında yayımlanmaktadır. Bu uygulama karşısında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Cumhuriyet savcıları tamamen duyarsız davranmakta ve hukuken kendilerine terettüp eden görevleri yerine getirmemektedirler.

Soruşturma evresinde CMK, m. 135 hükümlerine göre başvuru ile telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti kapsamında kayda alınan ve fakat soruşturma konusu olayla ilgili olmayan, **kişinin tamamen özel hayat alanı ile ilgili konuşma içeriklerinin, soruşturma dosyasında yer almaması gerekirken**, basın ve yayın organlarında yayımlanabilmektedir.

Bütün bu hukuka aykırı fiillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmasına ve karşılığında etkin yaptırımlar öngörülmesine rağmen, uygulamada bu hükümlerin caydırıcılık etkisi gösterecek şekilde işletilmediğini, ceza hukukçuları olarak gözlemlemekteyiz.

Bu sakıncaların giderilebilmesi amacıyla, Türk Ceza Kanununun 132, 133 ve 134. maddelerinde 2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır (m. 79-81). Bu düzenlemelerle, hukuka aykırı olarak ifşa edilen kişilerin haberleşme içeriklerinin ve özel hayatına ilişkin ses veya görüntülerin, haber verme hakkının sınırları aşılarak, aynen yayımlanması halinde, yayımlayan kişiler hakkında da ceza yaptırımı uygulanmasına vurgu yapılmıştır (TCK, m. 132, f. 3; m. 133, f. 3; m. 134, f. 2)¹⁰⁹.

¹⁰⁹ TBMM Adalet Komisyonunun 6352 sayılı Kanuna ilişkin 12.6.2012 tarihli ve Esas: 1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326, Karar: 12 sayılı Raporunda söz konusu değişikliklerin **gerekçesi** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

132. maddenin "üçüncü fıkrasına Komisyonumuzca kabul edilen bir önergeyle "İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur." cümlesi eklenmiştir. Bu suretle, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan haberleşme içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de, faillerin bu fıkra hükmüne göre cezalandırılmasına imkan tanınmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu hükme göre cezaya hükmolmek için, haber verme hakkının sınırlarının aşılması gerekir. Bu itibarla, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan haberleşme içeriklerinin haber verme hakkının sınırları dahilinde haber konusu yapılması, söz konusu suçu oluşturmayacaktır."

133. maddenin "üçüncü fıkrasına, "İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur." cümlesi eklenmiştir. Bu suretle, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan konuşma içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de, faillerin bu fıkra hükmüne göre cezalandırılmasına imkan tanınmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu hükme göre cezaya hükmolmek için, haber verme hakkının sınırlarının aşılması gerekir. Bu itibarla, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan konuşma içeriklerinin haber verme hakkının sınırları dahilinde haber konusu yapılması, söz konusu suçu oluşturmayacaktır."

Soruşturmanın gizliliğinin, haberleşmenin gizliliğinin, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği pek çok olayda, elde edilen bu gizli bilgileri **sadece yayımlayanlar hakkında** soruşturma ve kovuşturma yapıldığını gözlemlemekteyiz. Burada dikkatimizi çeken önemli nokta, **bu bilgileri basın ve yayın organlarına servis yapan kamu görevlileri hakkında bu nedenle herhangi bir soruşturma yapılmamasıdır.**

Dikkatimizi çeken bir diğer nokta da, kamunun ilgisini özellikle çeken belirli olaylarla ilgili olarak basın ve yayın organlarında yapılan haberlerde haber verme hakkının sınırları aşarak, toplumda **kişilerin suçlu oldukları yönünde bir kanaat oluşturulmasını sağlayacak** ve hatta **sağlamaya yönelik bir üslubun** kullanılmasıdır.

Bu bağlamda ayrıca işaret etmek gerekir ki, uygulamamızda, soruşturma konusu bir olayla ilgili olarak **yayın yasağı** kararı verilmesi yoluna da gidilebilmektedir.

Soruşturma konusu yapılan bir olayla ilgili yayın yapılması, Cumhuriyet savcısının talebi ve hakimin kararı ile yasaklanabilmektedir. Dikkat edilmedir ki, bu uygulama ile, **haber verme hakkının sınırları dahilinde de olsa**, soruşturma konusu yapılan bir olayla ilgili **yayın yapılması yasaklanabilmektedir.** Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulama karşısında sessiz kalınması, dikkatimizi çekmektedir.

Örnek 3: Azami gözaltı süreleri istismar edilmektedir.

Hukuk sistemimizde, yakalanan kişi, soruşturma konusu suçun mahiyeti ve şüpheli sayısı göz önünde bulundurularak, ancak belirli bir süreye kadar gözaltında tutulabilmektedir (CMK, m. 91).

Uygulamada, gözaltına alınan kişiler, Kanunda belirlenen azami sürenin son saatinde tutuklanma talebiyle hakim huzuruna çıkarılabilmektedir. Örneğin soruşturma dosyasının **yetmiş klasöre** ve şüpheli sayısının **yirmi kişiye** balığ olduğu bir soruşturmada, tutuklanma talebiyle son saatte huzuruna

Aynı şekilde 134. maddenin "ikinci fıkrasına, "İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur." cümlesi eklenmiştir. Bu suretle, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan özel hayata ilişkin görüntü veya seslerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de, faillerin bu fıkra hükmüne göre cezalandırılmasına imkan tanınmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu hükme göre cezaya hükmedebilmek için, haber verme hakkının sınırlarının aşılması gerekir. Bu itibarla, hukuka aykırı olarak ifşa edilmiş olan özel hayata ilişkin görüntü veya seslerin **haber verme hakkının sınırları dahilinde haber konusu yapılması, söz konusu suçu oluşturmaz.**"

çıkarılan bu kişilerle ilgili olarak, hakim hakkaniyete uygun bir karar verebilmesi için, önce soruşturma dosyasını okuması ve bilahare de her bir şüpheliyi tek tek dinlemesi gerekir.

Tutuklanma talebiyle huzuruna çıkarılmak üzere kapısının önünde yirmi kişinin beklemekte olduğu bir durumda, hakim yetmiş klasörden oluşan soruşturma dosyasını ne kadar zamanda inceleyecek ve bu kişilere yöneltilen suçlamalar ile deliller hakkında nasıl yeterli bilgi sahibi olacaktır?

Örneğin dört günlük gözaltı süresinin son saatinde sorguları yapılmak üzere, hakim kapısına dayandırılan bu kişiler, kapı önünde **yorgun** ve **uykusuz** bir şekilde saatlerce kendilerine gelecek sorgu sırasını beklemektedirler. Gecenin geç saatlerinde veya sabahın erken saatlerinde sorgu sırası kendisine gelen kişinin, bu şartlar altında savunmasını sağlıklı yapması imkansızdır. Sadece şüpheli değil, başta sorguyu yapan hakim olmak üzere soruşturmanın diğer bütün süjeleri de **yorgunluk** ve **bitkinlikten** nasibini almaktadır. Bu şartlar altında verilen kararların sağlıklı, adil, gerçekçi ve gerekçeli olması imkansızdır.

Bu yanlışlıklar, kanundan kaynaklanmamaktadır. Gözaltı süresi otuz güne çıkarılsa bile, disipline edilmeyen uygulama şüpheliyi tutuklanma talebiyle yine bu sürenin **son gününün son saatinde** hakim huzuruna çıkarır.

Burada sorun, disipline edilmeyen ve insan hakları konusunda duyarsız olan uygulamadan kaynaklanmaktadır.

Örnek 4: Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri, "genel müsadere cezası" izlenimi uyandıracak şekilde kullanılmaktadır.

Yeni Türk Ceza Kanununun ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlarla bağlantılı olarak benimsediği iki ana prensip bulunmaktadır.

1. Prensip: **Hukuk toplumunda suç işlemek, bir kazanç elde etme yolu olarak görülemez.**
2. Prensip: **Suç işlemek suretiyle elde edilmiş olan kazanç, kişinin yanında kâr olarak bırakılamaz.**

Bu temel düşünceyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinde, ancak belirli suçların işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma kararı verilebileceği hüküm altına alınmış ve bu karara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, **ancak belirli suçlarla ilgili olarak**

başlatılan soruşturmalarda taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma kararı verilebilecektir. Daha da önemlisi, bu elkoyma tedbiri, ancak belirli suçların işlenmesi suretiyle elde edildiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunan taşınmazlar, hak ve alacaklar bakımından uygulanabilir. Buna karşılık, kişi ekonomik kazanç elde etmek amacıyla bir suç işlemiş olsa bile, kendisine isnat edilen suçtan elde edilmediği açık seçik olarak belli olan malvarlığı ile ilgili olarak bu elkoyma tedbiri uygulanamaz.

Kanuni düzenleme bu şekilde olmasına rağmen, uygulamada bu madde hükmü "**genel müsadere cezası**" çağrışımında bulunacak şekilde uygulanmaktadır. Kişiye örneğin **miras yolu ile intikal etmiş olan malvarlığına** da, müsnet suçun ekonomik bir mahiyet taşıması nedeniyle, **elkonulması** cihe-tine gidilmektedir. Kişinin, işlediği ileri sürülen suçla irtibatının olup olmadığına bakılmaksızın, bu elkoyma tedbiri **bütün malvarlığı bakımından** uygulanmaktadır¹¹⁰. Hatta daha da ileri gidilerek, **bu tedbir, kişinin ortağı olduğu şirketin/şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulmasını, dondurulmasını, bu şirketlere elkonulmasını sonuçlayacak şekilde de uygulanabilmektedir.**

Bu uygulamaların hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Telafisi imkansız mağduriyetlere sebebiyet veren bu uygulamalar karşısında, CMK'nın 128. maddesini kaleme alan bir akademisyen olarak "**acaba bu düzenlemeyle bir yanlışlık mı yaptık?**" diye kendimi sorguladığımı itiraf etmem gerekir.

Örnek 5: Türk yargılama sisteminde yanlış ama genel kabul görmüş bir uygulama bulunmaktadır: Mahkemelerde hakimler, hükmü önce verip açıklamakta ve bilahare, aradan bir zaman geçtikten sonra gerekçeli kararını yazmaktadırlar.

1980'li yıllarda Türkiye'de yaşanan bir olay vardı. Bir asliye ceza mahkemesinde görev yapan hakim, yargılama sonucunda hükmünü verip açıklamıştı; ancak gerekçeli kararı yazamadan ölmüştü. Bu olayda gerekçeli kararın kimin tarafından ne suretle yazılması gerektiği bir hukuki sorun olarak ortaya çıkmıştı.

¹¹⁰ Anayasa Mahkemesinin **6.10.2021** tarihli ve 2019/2031 Bireysel Başvuru sayılı kararına konu teşkil eden olayda; B'nin oğlu S hakkında TCK, m. 328'de tanımlanan **devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme suçu**nu işlediği şüphesiyle başlatılan soruşturma sürecinde CMK, m. 128 hükmüne istinaden **B'nin bütün mal varlığına** el konulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde, ölen hakimin kararının gerekçesini bilahare bu mahkemeye atanan hakim tarafından yazılması gerektiği yönünde karar vermişti.

Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında, Komisyona akademisyen sıfatıyla katılan birisi olarak, Kanunun 232. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bağlamında bu konuyu gündeme getirmiştım. Bu çerçevede kanuna mahkeme kararlarının ancak gerekçesi yazıldıktan sonra açıklanabileceğine dair bir hüküm konulması yönünde öneride bulunmuştım. Ancak, Yargıtay'ı temsilen Komisyona katılan üyelerden biri, ender rastlanan bir durum olması sebebiyle ve özellikle bu suretle hakimlerin “baskı” altında tutulabileceği “endişesi”yle, bu yönde bir düzenleme yapılmasına karşı çıktığı için, önerim Komisyonda kabul görmemişti.

15 Temmuz 2016 sonrasında, “terör örgütü üyesi” olduğu gerekçesiyle sayıları birkaç binle ifade edilen yüzlerce hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Bu hakimler tarafından verilmiş ve açıklanmış olup da gerekçesi henüz yazılmamış olan binlerce karar bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kararların gerekçelerinin kimin tarafından ve ne suretle yazılması gerektiği bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

Bu sorunun “çözümü” amacıyla 2 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6763 sayılı Kanunla CMK’nın 232. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Hukuki temeli olmayan bu değişikliğin içeriği, birçok yönden sorunlu bulunmaktadır. Bu değişiklik bağlamında bazı hususlara işaret etmek isterim:

- 1) “Terör örgütü üyesi” olduğu gerekçesiyle görevine son verilen hakimler tarafından verilen kararlar “hukuken muteber” kararlar olarak addedilmiştir.
- 2) Bu hakimler tarafından verilip açıklanan ve fakat gerekçesi henüz yazılmamış olan kararların gerekçesi, olayla ilgili yargılama faaliyetine katılmamış olan, sanıkları, mağdurları, tanıkları tanımayan, sadece dosya üzerinden uyuşmazlığa ve delillere “vakıf” olan bir başka hakime yazdırılacaktır.
- 3) Gerekçesini yazmakla yükümlü kılınan hakimin, kararın doğruluğunu sorgulama yetkisi bulunmamaktadır.

Her zaman ifade ettiğim gibi, hukukta bir yanlış diğer bir yanlışla telafi edilememektedir. Yanlıştan geri dönüp, gömleğin düğmelerini baştan itibaren doğru bir şekilde iliklemeye başlamamız gerekmektedir.

Örnek 6: Hukuk uygulamamızda soruşturma başlar başlamaz, birilerine “şüpheli” sıfatı izafe edilmekte ve hemen bu sıfatla ifadesi alınmaktadır.

Cumhuriyet savcısı, bir ihbar veya şikâyet üzerine soruşturma başlatabilir. Soruşturmanın başlatılması, mutlaka ve behemehal belirli bir kişinin veya kişilerin “şüpheli” sıfatını iktisap etmesini gerektirmemektedir. Soruşturmanın seyrine göre, bilahare belirli bir kişi veya kişiler “şüpheli” sıfatını kazanabilir.

Başlatılan soruşturma sonucunda, belirli bir kişi şüpheli sıfatını iktisap etmeden de, örneğin suçun işlenmediğinin anlaşılması halinde “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verilebilir (CMK, m. 172).

Ancak uygulamamız hala “**şüpheliden delile ulaşma**” yöntemine göre çalıştığı için, bir soruşturma başlatılınca, ilk yapılması gereken iş olarak, belirli bir kişi veya kişilerin celp edilip “şüpheli” sıfatıyla dinlenmesi yoluna gidilmektedir. Başka bir ifadeyle, hukuk uygulamamızda, soruşturmanın başlatılması ile genellikle belirli bir kişi veya kişiler behemehal “şüpheli” olarak gösterilmektedir. Bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmiş ise kimin tarafından işlendiği konusunda herhangi bir araştırma yapmadan, salt ihbar ve şikâyete bağlı olarak kişilere “şüpheli” sıfatının izafe edilmesi, **masumluk ilkesi**yle bağdaşmaz. Bu yanlış uygulamanın ortaya çıkardığı sakıncayı gidermek amacıyla ki, CMK’nın 158. maddesine 15.8.2017 tarihli ve 674 sayılı KHK (ve bu KHK’yı bilahare kanunlaştıran 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanun) ile altıncı fıkra olarak eklenen yanlış bir hükümle “*soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar*” diye yeni bir karar türü ihdas edilmiştir.

Bir ihbar ve şikâyete bağlı olarak soruşturmanın başlatılması halinde, behemehal ihbar ve şikâyetin konusunu oluşturan fiilin işlendiği hususunda araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak, araştırma için **ilk iş olarak kişilerin şüpheli sıfatıyla dinlenmesi yoluna gidilmemelidir**. Eğer dinlenmesini gereken bir durum mevcut ise, kişi önce, olay hakkında bilgi sahibi olan olarak, yani “tanık” sıfatıyla dinlenir. Bilahare, şayet suç oluşturan fiili kendisinin işlediği ya da işlenişine iştirak ettiği yönünde somut şüphe sebepleri ortaya çıkarsa, bu kişiye “şüpheli” sıfatını izafe etmek mümkündür.

Bu yöntem izlendiğinde, kişi ancak soruşturma belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra, deliller bir ölçüde toplandıktan sonra, yani suç oluşturan fiili kendisinin işlediği ya da işlenişine iştirak ettiği yönünde somut şüphe sebepleri ortaya çıktıktan sonra, “şüpheli” sıfatıyla dinlenmeye çağrılabilir, zorla getirilebilir ve hatta, yakalanabilir.

Oysa uygulamamızda, bir soruşturma çerçevesinde kişilerin, örneğin ifa ettikleri görevler itibarıyla çağrıldığında gelebilecek durumda olmalarına rağmen, yakalanarak getirilmesi sağlanmaktadır. Hatta, yakalama işleminin gece geç saatlerde, gereksiz olmasına rağmen çok sayıda kolluk görevlisi marifetiyle icrası yoluna gidilmektedir. Bu şekilde icra edilen yakalama yönteminin, kişiler bakımından başlı başına bir **cezalandırma** işlevi gördüğü, toplum nezdinde **itibar zedelemesi** etkisi doğurduğu tartışmasızdır.

Bu yanlış yöntem dolayısıyladır ki, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Numaralı “**Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi**”nin eki “1 Sayılı Cetvel”de yer alan, **Cumhurbaşkanı tarafından ataması gerçekleştirilen bazı kamu görevlileri** ile ilgili olarak da, “terör suçu şüphelisi” sıfatıyla doğrudan doğruya Cumhuriyet savcıları tarafından sabahın erken saatlerinde celp işlemlerine başvurulmuştur.

Hatta, bu soruşturmalar bağlamında Cumhuriyet savcılarının, “şüpheli” sıfatıyla celp işleminden bilahare çeşitli sebeplerle sarfinazar ettikleri de müşahade edilmiştir.

EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN'IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah Öcalan, cezasını halen infaz kurumunda çekmekte olan ve bu nedenle, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bir hükümlüdür. Adı geçen kişi, gözaltına alınıp tutuklanmadan önce, PKK terör örgütünü ve onun türevlerini fiilen yönetmekte olan bir kişi idi.

Ancak, gözaltı ve tutukluluk sürecinde ve bilahare mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde, bu kişinin terör örgütünü yöneten bir kişi olarak kabul edilmesi mümkün değildir¹¹¹.

Buna rağmen terör örgütü mensupları Abdullah Öcalan'ı “lider” olarak görebilirler ve görmektedirler. Bu algı, hukuki gerçeği değiştirmez.

Kamuya yansıyan bilgilere göre, Abdullah Öcalan, infaz kurumunda cezasını çekmekte iken, belirli kişilere siyasi içerikli çok sayıda mektup göndermiştir. Bu mektupların Devletin bilgisi dışında gönderilmesi mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, halen cezasını infaz kurumunda çekmekte olan Abdullah Öcalan bu haliyle ancak Devletin yönlendirmesiyle bu mektupları belirli kişilere gönderebilir. Aksinin kabulü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olgusunun inkârı anlamına gelir.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu mektup trafiği bağlamında önemli hatalar bulunmaktadır.

Birincisi, devlet suçla, terörle mücadele bağlamında bir hükümlüden yararlanabilir ve bu çerçevede bir hükümlünün belirli kişi veya kişilere mesaj göndermesini uygun ve hatta gerekli görebilir. Ancak, bu durumda, devletin bu mesaj gönderme sürecini tamamen kontrol ve denetimi altında tutması gerekirdi. Oysa Abdullah Öcalan tarafından belirli kişilere gönderilen mektuplardan bir kısmı, “KCK operasyonları” bağlamında çeşitli kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunmuş ve bunlara elkonulmuştur. Bu göstermektedir ki, devlet bu sürece hakim olamamıştır.

¹¹¹ Yargıtay Ceza Genel Kurulunun çeşitli kararlarında, Abdullah Öcalan'ın mülga 765 s. TCK'nın 125. maddesinde tanımlanan suçtan dolayı sonuçta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş ve bu cezasını infaz kurumunda çekmekte olmasına rağmen, adı geçen kişiden bahsedilirken “PKK terör örgütü elebaşı”, “PKK silahlı terör örgütü lideri” gibi ibareler kullanılmıştır. CGK, 31.10.2012, E. 2012/9-1234, K. 2012/1825; CGK, 12.2.2008, E. 2007/9-230, K. 2008/23.

İkincisi, çeşitli suçlar bağlamında yapılan aramalar sırasında bu mektupların ilgisiz kişilerin elinde bulunduğunun ortaya çıkması halinde, bu bilgiler bit pazarına düşmeden devletin duruma hakim olması gerekirdi. Oysa bu olmamış ve Abdullah Öcalan tarafından belirli kişilere gönderilen mektuplar, çeşitli kişiler hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma dosyalarının içerisinde yer almıştır.

Bu yönleri itibarıyla sorun, içinden çıkılmaz bir hale bürünmüştür. MİT Kanununda¹¹² yapılan değişiklik, minareyi gizlemeye yetmemiştir.

Abdullah Öcalan'ın bugün dahi terör örgütünün yöneticisi olarak kabulü, toplumumuzu içinden çıkılmaz sorunlara sürükler^{113,114,115}. Böyle bir kabul,

¹¹² 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26. maddesinde, 17.2.2012 tarihli ve 6278 sayılı Kanunla (RG. 18 Şubat 2012/28208) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Soruşturma izni

MADDE 26– MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.”

Yine, söz konusu Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 4– Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlen devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda da 26'ncı madde hükümleri uygulanır.”

¹¹³ MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hükümlü Abdullah Öcalan ile ceza infaz kurumundaki görüşmesi bağlamında önemli yanlışlar yapılmıştır.

BİRİNCİ YANLIŞ: İçeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış ise de, bu görüşme aleni olarak yapılmıştır.

Oysa, terörle mücadele amacına münhasır olan bu tür görüşmelerin gizlilik içinde yapılması gerekir.

İKİNCİ YANLIŞ: Bu görüşme ile ilgili olarak devlet televizyonu TRT'de verilen haberlerde “PKK lideri Abdullah Öcalan” ibaresi kullanılmıştır.

Yukarıda açıkladığım gibi; **suçlulukla, terörle mücadele amacıyla gerektiğinde hükümlü olan kişilerle ve dolayısıyla, Abdullah Öcalan'la görüşülebilir.**

Bu görüşme, görüşülen kişinin daha önce içinde bulunduğu suç olgusunun sonlandırılması ve bu bağlamda bazı suçların aydınlanması amacıyla yapılabilir.

Bu görüşme, terör örgütünün varlığının sonlandırılması veya en azından etkisizleştirilmesi amacıyla yapılabilir.

Oysa yapılan görüşme ile, PKK siyasi muhataplık düzeyine çıkarılmıştır.

Bunun, kabul edilemez bir zaaf ve yanlış olduğunu kimse inkar edemez.

Sonucu ne olursa olsun, bu görüşmelerden her halde PKK ve siyasetteki uzantıları karlı çıkmıştır.

Toplum olarak siyaseten ifrat ve tefrit arasında gel gitler yaşamaktayız.

Zira diğer yandan, bazı yerel gazetelerde verilen haberlerde Abdullah Öcalan'la ilgili olarak “PKK lideri” sıfatı kullanılması dolayısıyla ilgililer hakkında TCK'nın 214. maddesinde tanımlanan “suçluyu övme suçu”nu işledikleri iddiasıyla soruşturmalar başlatılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, hukukta iki yanlış bir doğru etmez. Yani bir yanlışla diğer bir yanlış düzeltilemez.

- ¹¹⁴ Malum “çözüm süreci” bağlamında PKK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu otoriteleri tarafından dolayı da olsa muhatap alınmaktadır. Oysa bu süreçte PKK ve örgüt mensupları süje olarak değil, obje olarak muamele görmeliydi. Yani müzakerelerin tarafı değil konusunu oluşturmalıydı. Elbette ki bu süreçte örgütün yönetimini deruhte eden bazı kişilerle sınırlı bir şekilde görüşme yapılabilirdi. Ancak bu görüşmeler, örgüt yöneticilerini müzakerelerin tarafı konumuna çıkarmamalıdır.

Söz konusu süreçte örgütün silahlı mensuplarının ülkeyi terk etmesinin sağlanması düşünülmektedir. Ancak bunun, yapılmasının merama hizmet eden yönünün olup olmadığı bir yana, nasıl yapılacağı da hukuki bir sorun oluşturmaktadır.

Ülkeyi terk edecek kişilerin ne suretle belirleneceği ve terk sürecinin ne kadar zaman alacağı bir sorundur.

Ülkeyi terk etmesi düşünülen örgüt mensuplarının elinde olan silahların akıbetinin ne olacağı bir sorundur.

Güvenlik kuvvetlerinin bu terk sürecinde nasıl bir yol izleyecekleri belirsizdir.

Ülkeyi terk eden kişilerin nereye gidebilecekleri ve gittikleri ülkede hangi statüde, ne sıfatla ve ne kadar süreyle kalabilecekleri bir sorundur.

Belirtelim ki, bir **milletlerarası anlaşma** olmadan bu kişilerin bir başka ülkeye gönderilmelelerini ve bu ülkede kalmalarını hukuki bir zemine oturtma imkanı bulunmamaktadır.

Görünen odur ki, bu kişiler Kuzey Irak'a örgütün kamplarına gidecekler ve hukuka aykırı olarak orada kalacaklardır.

Bu durumda, ülkeyi terk eden kişilerin tekrar silahlı olarak ve eylemlerde bulunmak amacıyla geri gelme tehlikesi mevcut olmayacak mıdır? Bunun güvencesi ne olacaktır?

Ülkeyi terk eden kişilerin Kuzey Irak'ta örgütün amacı doğrultusunda silahlı/silahsız eğitim görmeleri, örgütün Kuzey Irak'taki unsurlarının silahlı olması, malum süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından bir tehdit oluşturmayacak ve siyasi kararların alınmasında kamu otoritelerine karşı bir baskı unsuru olarak kullanılmayacak mıdır?

Terör sorununun halli, iyiniyetli ve ideal bir amaçtır. Ancak bu amaca varmak için izlenen söz konusu yol kanaatimizce doğru değildir.

Sözün kısası, yanlış hesap Bağdat'tan geri dönecektir.

- ¹¹⁵ Malum “çözüm süreci”nde örgütün yönetiminde görev yapmış olan belirli kişilerle, terörü sonlandırmak amacıyla yönelik olarak belirli bir yöntem çerçevesinde görüşme yapılabileceğini ifade etmiştik.

Ancak bu görüşmelerin, örgütün ve yöneticilerinin müzakere süjesi olarak algılanmasına yol açacak bir surette yapılmaması gerekir.

Oysa söz konusu süreçte yapılan görüşmelerle, Abdullah Öcalan bir siyasi aktör seviyesine yükselmiştir.

Devletin gözetim ve denetimi altında gerçekleştirilen bu görüşmelerle topluma “Sayın” Öcalan menşeli mesajlar verilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz.

Bir suçlu ve hükümlü olan Öcalan'ın bu özelliklerini örtecek şekilde, toplumun bir kesiminin “lider”i olduğu izlenimi oluşturacak şekilde kamuya mesajlar verilmesinin, ilgili kişiler bakımından ceza sorumluluğunu gerektirdiği kuşkusuzdur.

terör örgütünün ve Abdullah Öcalan'ın işine yarar. Çünkü böyle bir kabul halinde, adı geçen kişinin bugün görülmekte olan çeşitli davalar bağlamında yargılanmasına devam edilmesi gerekir. Bu durum, sürekli gündemde kalmak, bağlılarına ve genel olarak topluma mesaj verebilmek bakımından, terör örgütü ve Abdullah Öcalan için önemli bir fırsat oluşturur.

Bu mesajların TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını taşıyan bir kişi üzerinden verdirilmesi, malum sürecin terör ve Kürt sorununu çözmek amacını aşmıştır. Malum süreç, terör örgütünün meşrulaştırılması ve ağır suçlar işlemiş örgüt mensuplarının affedilmesi sonucunu doğuracaktır.

Sayın Başbakan, bir gazeteci ile yaptığı mülakatta, malum "çözüm süreci"nde muhatabın Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu açıklamasında bulunmuştur.

Burada sorun Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına muhatabın TBMM veya Hükümet olması değildir. Bu farklılığın hukuki bakımdan hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olanın bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına kiminle muhatap olunduğudur. Yanlışlık, açıklanmayan bu noktadadır.

EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Abdullah Öcalan, yürürlükten kaldırılan 765 s. Türk Ceza Kanununun 125. maddesi hükmüne göre, “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koymağa veya devletin istiklâlini tenkise veya birliğini bozmağa veya Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf” fiiller işlediği gerekçesiyle **idam cezasına** mahkûm olmuş; bu ceza, nihayetinde **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına** dönüşmüş ve bu cezanın infazı, halen devam etmektedir.

Abdullah Öcalan, halen varlığı ve faaliyetine devam eden "PKK" ("Partiya Karkeren Kurdistan", "Kürdistan İşçi Partisi") adlı terör örgütünü kurmuş ve yönetmiş olan bir kişidir. Ancak, her ne kadar adı geçen kişi yakalandıktan sonraki süreçte dahi mensupları tarafından örgütün lideri olarak görülmekte ise de; bir hükümlü olarak Abdullah Öcalan'ın, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması, bütün hal ve hareketlerinin Devletin gözetim ve denetimi altında olması sebebiyle, cezasının infaz kurumundaki infazı sürecinde bu örgütün yöneticiliğini deruhte etmesi mümkün değildir.

Anayasa'da, "**üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek**" Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır (m. 87). Anayasa'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu af yetkisine sadece **orman suçları** bakımından bir sınırlama getirilmiştir: "... münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz." (m. 169). Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu af yetkisini **Devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar**la ilgili olarak da kullanabilir.

Keza, Anayasa'da, Cumhurbaşkanıya "**sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak**" yetkisi verilmiştir (m. 104). "Özel af"fin bir türü olan bu yetkinin kullanılması bağlamında, hükümlünün işlediği suçun mahiyeti ve mahkûm olduğu cezanın türü veya miktarı bir sınırlama sebebi olarak görülmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanı tarafından bu yetki, hükümlünün "sürekli hasta" veya "sakat" olması ya da "kocaması" sebebiyle kullanılabilecektir. Dikkat edilmelidir ki, burada hastalığın türü ve sakatlığın kişinin hayat fonksiyonları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmamış ve kocamanın ölçüsü belirlenmemiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından bu yetkinin kullanılması bağlamında, hükümlünün mahkûm olduğu **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz süresinin kısaltılması** yoluna da gidilebilir.

Keza, hükümlünün **cezasının kalan kısmının** infaz kurumunda değil de, **konutunda çektirilmesine** karar verilmesi ve bu suretle infaz kurumundan çıkarılması, cezasının "hafifletilmesi" olarak değerlendirilmelidir.

Bu durum karşısında, Cumhurbaşkanı, **Anayasa'da sayılan sebeplerin varlığı halinde**, hükümlünün, mahkûm olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ölünceye veya belirleyeceği bir tarihe kadar "konutunda çektirilmesine" ya da infazının kaldırılmasına karar verebilir.

5275 sayılı İnfaz Kanununun 110. maddesi hükümlerine göre uzun süreli, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının konutta çektirilmesi mümkün değildir. Bu maddede yapılabilecek bir değişiklikte, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının konutta çektirilmesinin yolu da açılmaz.

İnfazı ömür boyu devam edecek olan bir cezanın konutta çektirilmesine ve bu infazın kontrol altında tutulmasına fiilen imkan bulunmamaktadır.

Ancak buna rağmen, TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin temsilcileri tarafından Abdullah Öcalan'ın infazı devam eden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının,

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde nitelikli çoğunlukla kabul edilen bir kanunla affedilmesi,

veya en azından,

b) Cumhurbaşkanı tarafından, "sürekli hasta" veya "kocamış" olduğundan bahisle (!?), belirli bir süre daha konutunda çektirilmesi ve hatta infazının tamamen kaldırılması yönünde karar alınması,

hususla telaffuz edilmeye başlanmıştır.

EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ

Faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar göz önünde bulundurulduğunda, PKK’nın bir terör örgütü olduğunda hiçbir kuşku yoktur. PKK’nın bir terör örgütü olduğu gerçeğini kabullendirebilmek için, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçları dramatize edecek şekilde anlatmaya gerek bulunmamaktadır.

PKK’nın bir terör örgütü olduğu gerçeği, Türkiye nüfusunun önemli bir parçasını oluşturan Kürtlerle ilgili olarak yaşanan sosyal, siyasi ve dolayısıyla hukuki sorunların çözümüne yönelik amaçlarla örtülemez. Türkiye’de **Kürt nüfusla ilgili olarak yaşanmakta olan sosyal, siyasi ve dolayısıyla, hukuki sorunlar** nedeniyle; bir terör örgütü olmasına rağmen, PKK’nın **halk desteği** bulduğu da bir gerçektir. Bu sosyal, siyasi ve hukuki sorunlar nedeniyle; PKK ve güdümüyle oluşturulan siyasi oluşumlar, **uluslararası alanda siyasi ve ekonomik¹¹⁶ destek** bulabilmektedir. Ülke topraklarının belli bir kısmı üzerinde devlet hâkimiyetini zayıflatarak göreceli bir egemenlik oluşturan bu örgütün, halk desteği olmaksızın bu egemenliği sağlaması mümkün değildir¹¹⁷.

¹¹⁶ Kolluk kökenli bazı kaynaklarda, “uyuşturucu madde kaçakçılığı”nın PKK’nın önemli bir gelir kaynağını oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu çerçevede PKK’nın elde ettiği gelir miktarına yönelik olarak **tahmin**lerde de bulunmaktadır (Bkz. YILDIRIM, Zeki: *Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi*, Ankara, 2012, sh. 85 vd.). Ancak belirtmemiz gerekir ki, PKK’nın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile bağlantısını ortaya koyan ülkemizde veya yurt dışında verilmiş herhangi bir mahkeme kararına şahsen henüz vakıf olmuş değiliz.

¹¹⁷ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 4.3.2008 tarihli ve E. 2007/9-282, K. 2008/44 sayılı Kararında, söz konusu örgütün yapılanması, icra ettiği eylem yöntemleri ve nispeten kazandığı halk desteği konusunda yer verilen şu açıklamalar önem taşımaktadır:

“Amacı Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını silahlı mücadele vererek devlet idaresinden ayırıp bu bölgede (ayrı bir devlet) kurmak olan PKK terör örgütü, elebaşının yakalanması üzerine yurtdışında faaliyet gösteren yandaşları ve üyeleri ile yeni politikalar üretme yoluna gitmiş, bu amaçla silahlı terör örgütünün sözde Başkanlık Konseyi tarafından 02-23 Ocak 2000 tarihinde “7. Kongre” yapılmış ve bu kongrede amaçlarına ulaşabilmek için “*Demokratikleşme ve Barış Projesi*” ismini verdikleri yeni bir eylem tarzını benimsemiş, ayrıca “*Merkez Komite*” – “*Parti Meclisi*”, ARGK-HPG (*Kürdistan Halk Savunma Kuvvetleri*), ERNK-YDK (*Kürdistan Demokratik Halk Birlikleri*) olarak değiştirilmiş ve yeni parti tüzüğü hazırlanıp, örgüt amblemi değiştirilmiştir.

“7. Kongre”de alınan kararların uygulamaya geçirilmesi amacıyla 05-22-Ağustos 2001 tarihinde “6. Ulusal Konferans” ismini verdikleri konferans gerçekleştirilmiş, örgütün nihai amacına ulaşması için geliştirdiği yeni stratejisi gereği, **şiddete dayalı olmayan ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasalarına aykırı şekilde devlet güçlerini ve devleti uluslararası alanda zor durumda bırakmak için “Sivil itaatsizlik-Serhildan (Başkaldırı)”** adı verilen yeni bir eylem tarzı uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda;

1-Örgüt sempatzanı ve üyesi öğrencilerin organizesinde **Kürtçe dersinin seçmeli dersler** kapsamında Üniversite bünyesinde okutulmasına ilişkin Üniversite Rektörlüklerine matbu dilekçe verilmesi,

2-İlk ve Orta Öğretim öğrenci velileri tarafından "**Çocuğuma Kürtçe Eğitim verilmesini istiyorum**" şeklinde Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçeler verilerek kitlesel baskı oluşturulması,

3-Sempatzan teşkilatları organizesinde kadınlar tarafından yöresel kıyafetler giyilmesi,

4-Nüfus Müdürlüklerine veya Mahkemelere "**Kimliğime Kürt yazdırmak istiyorum**" talepleriyle başvurulması,

5-"**Bende PKK'lıyım ve PKK'nın yeni stratejisini destekliyorum**" şeklinde başvurular yapılması,

6-Örgüt sempatzanı üniversite öğrencileri tarafından sürdürülen **Kürtçe eğitim kampanyasının** PKK sözde başkanlık konseyince Lise ve İlköğretim okullarında da yaygınlaştırılması yeni bir eylem tarzı olarak benimsenip uygulamaya konulmuştur.

04-10 Nisan 2002 tarihinde gerçekleştirilen 8.Kongrede PKK ismi KADEK (Kongra Azadi U Demokrasi A Kürdistane-Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi) olarak değiştirilmiş ve bu kongre "**1. Kuruluş Kongresi**" olarak ilan edilmiştir.

Bu kongreden sonra özellikle bazı sivil toplum örgütleri tarafından "**Anadilde eğitim**, İdamın kaldırılması, **Genel Af ve Kürtçe Yayın**" gibi konular her platformda dile getirilmeye başlanmış,

26 Ekim-15 Kasım 2003 tarihinde yapılan "9. Kongre"de KADEK ismi bu kez KONGRA-GEL (**Kürt Halk Kongresi**) olarak değiştirilip, bu kongre "**1. Kuruluş Kongresi**" olarak ilan edilmiş,

Bu kongreden sonra, 2003 yılı içerisinde "**Siyasi Serhildan**" hareketi kapsamında yukarıda belirtilen kampanyalar sürdürülmüş,

Bu bağlamda;

1- 16-26 Mayıs 2004 tarihinde Kuzey Irak'ta bulunan **Kandil** dağında "2. Olağanüstü Kongre" olarak adlandırılan "**10. Kongre**" gerçekleştirilmiş ve örgüt içinde yaşanan hizipleşmeler nedeniyle Abdullah Öcalan'ın liderliğinin zafiyete uğraması, Avrupa Birliğinin sözde siyasal açılımlara itibar etmeyerek KONGRA-GEL'i terör örgütleri listesine alması, örgütün son beş yıl içinde hedeflenen başarıya ulaşamaması ile genel af, siyasi faaliyetlerin yasallaştırılması, kültürel kimliğin anayasal düzeyde kabulü gibi istekler güncelleştirilerek tabandaki dağınıklığın giderilmesi amacıyla örgütün silahlı savunma gücü HPG (**Halk Savunma Gücü**) militanlarının pasif durumdan aktif duruma geçirilmesi ve güvenlik güçlerince örgüt mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda verilen kayıplara **misilleme olarak eylemler** gerçekleştirilmesi ve örgüte sempati duyan kişi ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla.

a) Ayrımsız **genel bir af** çıkarılması,

b) Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması,

c) Kürt halkına **anayasal yurttaşlık hakkının** tanınması,

ç) İki taraflı **ateşkes** yapılması ve barışın sağlanması,

d) **Çatışmasız ortamın** devam etmesi için devletin **Kürt sorunu** ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ile ilgili somut adımlar atması,

konuları, her platformda gündeme getirilip kamuoyu yaratılmaya ve **uluslararası alanda devlet aleyhine baskı oluşturulmaya** çalışılmış; 04.04.2005 tarihinde, halen cezaevinde olan Abdullah Öcalan'ın doğum gününde örgüt adı tekrar "PKK" ("**Partiye Karkerani Kürdistan**" – "**Kürdistan İşçi Partisi**") olarak değiştirilip kamuoyuna duyurulmuştur.

2- 24.03.2006 tarihinde 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerince yasadışı PKK terör örgütü mensuplarına yönelik Bingöl ili ile Muş ili sınırlarını kapsayan bölgede yapılan operasyon sonucunda Şenyayla mıntıkası olarak bili-

nen ve Solhan ilçesi kırsalına yakın yerde 14 örgüt militanı ölü ele geçirilmiş, otopsi ve adli işlemleri Malatya'da yapılarak, ölen militanlardan 4'ünün cenazesinin Diyarbakır'da gömülmesine karar verilmiştir. Cenazeler yakınları tarafından teslim alınarak 28.03.2006 tarihinde defnedilmek üzere Diyarbakır'a getirilmiş, saat 07:00 sıralarında 4 örgüt mensubunun cenazeleri Bağlar Medine bulvarı üzerinde bulunan Şerif Efendi camiine götürülmüş, burada yolu da trafiğe kapatmak suretiyle toplanan yaklaşık 1500-2000 civarında kişi cenazeleri taşıyıp, **örgüt** ve örgüt elebaşısı **lehine** bölücü ve **şiddet içerikli** Türkçe ve Kürtçe **sloganlar** atmış, örgütün sözde "*gençlik marşı*" olan "*Hernepeş*" – "*İleri*" marşını söylemiş, ayrıca yol üzerinde lastik yakmak suretiyle ateşler yakılmış, grup içerisinde maskeli ve maskesiz bazı göstericiler kalın sopalara takılmış vaziyette örgütü simgeleyen flamalar ve Abdullah Öcalan'a ait posterler açmış, ayrıca 2x1 metre ebadında büyük harflerle üzerinde "**Şehitler Onurumuzdur**" ve "PKK" yazılı pankart taşınmıştır.

Güvenlik güçlerinin yasadışı slogan atmamaları, örgüt propagandası yapmamaları ve yasadışı bayrak açmamaları hususunda kitleyi uyarmasına rağmen, kalabalık galeyana gelerek öncelikle **görevli polis memurlarını taşlamış, pek çok polis memurunu yaralamış, sokağa dağılan göstericilerin tekrar toplanarak güvenlik güçlerine, kamu binalarına, banka şubelerine ve vatandaşlara ait çok sayıda iş yeri, resmi ve sivil otoyola, taş ve molotof kokteyl atarak saldırıda bulunmaları sonucunda büyük çaplı maddi hasarlar meydana gelmiştir.**

Çok sayıda aracın kundaklanarak yakıldığı, bazı işyerlerinden hırsızlık yapıldığı, taşlı ve molotof kokteylli saldırıların özellikle açık bulunan işyerlerine yöneldiği, göstericilerin yolu trafiğe kapatarak polisleri ve polis panzerlerine taşlı, sopalı ve molotof kokteylli saldırıda bulundukları, bir banka şubesinin molotof kokteyli atılmak suretiyle kundaklandığı ve Türk Bayrağının indirilip yakıldığı eylemler 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde de sürdürülmüştür.

Bu eylemler öncesi **örgütün yayın organları** olan;

"**Fırat Haber Ajansı**"nın internet sayfasında "**PKK Halk Savunma Komitesi**" adına örgütün üst düzey yöneticisi Turan Kalkan'ın "... *Kürt halkı özgürlük ve demokrasi taleplerinde Önder Apo'yu sahiplenmede ne kadar kararlı, ısrarlı olduğunu bütünlüklü olduğunu netçe, herkesin görebileceği biçimde ortaya koydu. Bu direnişi yıl boyu çok değişik biçimlerde sürdüreceğinden kuşku duyulamaz. Başta Kürt gençliği ve kadınları olmak üzere tüm emekçi halkın 2006 yılını Önder Apo'ya özgürlük ve Kürt sorununa demokratik çözüm şiarıyla boydan boya bir serhildan yılı haline getirme kararlılığı içinde olduğu bilinmelidir. Newroz bunun en önemli, en görkemli zirvelerinden biri olmuştur. Şimdi kahramanlık günümüz, haftamız dolayısıyla her alanda halkın şehitlerimizi anma, sahiplenme, anlama temelinde demokratik eylemlerini geliştirme sürüyor. Nisan ayı boyunca önderlik gününden işçi ve emekçilerin 1 Mayıs bayramına kadar uzanan süreçte bu devam edecektir...*",

"HPG'nin internet sitesinde benzer şekilde halkı sivil itaatsizlik adı verdikleri **serhildan eylemlerine** katılması için "*Ey Amed ...! Sana karşı top yekûn savaş başlatmışlar, uyuşturucusundan, fuhuşçusuna, tinercisinden, kapkaççısına, jopundan işkencesine, kurşunundan soykırımına kadar tüm kirliliği savaş yöntemleri devreye sokulmuştur... bil bunları, bil ve isyana dur, ordu, polis, mit, jitemi hepsi birer cellat örgütleri...*",

Örgüte yakınlığı ile bilinen "**Komalen Cîwan**"ın internet sayfasında "...*Kürt halkı Newroz Bayramı'nı barış çağrılarında kutlarken, savaşta ısrar eden güçler halkımıza karşı katliamlarını kimyasal silahlarla devam ettirmektedirler. Son olarak Muş Şenyayla'da halkımızın kahraman evlatlarından 14 gerillanın katledilmesi ile sarsılmış bulunmaktayız. Acımız derindir. Bu katliamı şiddetle protesto etmek ve Kürt halkının yiğit direnişçilerine sahip çıkmak, tüm Kürt halkının ve Amed halkının onur borcudur. Bu amaçla 28 Mart günü, tam da tarihimizdeki kahramanlık haftasına yakışır bir şekilde, Amed'e gelen 6 şehidimize sahip çıkmak amacıyla tüm halkımıza o gün **kepenklerini kapatma, işe gitmeme, cenaze törenine kitlesel bir şekilde katılma çağrısında** bulunuyoruz...*" şeklinde halkı kitlesel eylemlere yönlendirme çağrısı yapılmış,

Keza, bu destek dolayısıyladır ki, güvenlik kuvvetleri, örgütün desteklenmesine yönelik kitlesel hadiselerle ihtiyatla yaklaşmaktadır.

Terör örgütüne sağlanan bu **halk desteği**, yabancı devletlerin veya uluslararası girişimlerin desteğini önemsiz (!) kılacak bir mahiyet kazanmıştır.

Arkasına **halk desteğini** almış olan örgüte karşı verilen **salt** silahlı mücadelenin uzun vadede işe yarayan bir yönünün olmayacağı gerçeği artık görülmelidir¹¹⁸.

27.03.2006 tarihinde Diyarbakır'da aynı ifadelerin yazılı olduğu bildiriler değişik yerlerde halka dağıtılmıştır.

Örgütün yayın organı niteliğindeki bu internet siteleri ile ayrıca örgütün sesi konumundaki **“Roj TV”** olay öncesinde sık sık yapmış olduğu yayınlarla ortamı germiş, **halkın işe gitmesini, kepenklerini kapatmasını, çocukların okula gitmemesini** sağlamış, eylem çağrıları ve provakatif yayınlar sonucu ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katılan kişiler belirtilen eylemleri gerçekleştirmiş, aynı şekilde başta Batman, Siirt, İstanbul ve Mersin olmak üzere pek çok il ve ilçeye de olaylar yayılmış, yurt çapındaki bu olaylar esnasında **200’ün üzerinde polis yaralanmış, pek çok araç kullanılmayacak şekilde kundaklanmış, sayısı tespit edilemeyen yüzlerce işyerinin camları kırılmış, pek çok kamu binası kundaklanmış, meydana gelen bu olaylarda 9 kişi ölmüş, 41 kişi de yaralanmıştır.**

Diyarbakır’daki olaylar ile ilgili olarak yakalanan 400 civarındaki kişinin arşiv kayıtları incelendiğinde belirli bir bölümünün daha önce PKK terör örgütüne üyelik, yardım, örgüt lehine propaganda yapmak gibi suçlar kapsamında soruşturma geçirmiş kişiler, bir bölümünün ise gasp, hırsızlık gibi suçlardan mahkûm olan kişiler oldukları ve bu kişilerin 3-4 gün süren **kaos ortamını** fırsat bulup değerlendirmeye çalıştıkları saptanmış, olaylara karıştıkları tespit edilen 26’sı 18 yaşından küçük toplam 77 kişi gözaltına alınmıştır.”

(Ayrıca bkz. CGK, **30.6.2009**, E. 2008/9-169, K. 2009/186).

¹¹⁸ Yukarıda açıkladığımız gibi, PKK halk desteği kazanmış bir terör örgütüdür. Bu nedenle, PKK ile sadece Terörle Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanması ve bu çerçevede askeri yöntemlere başvurulması ile baş edilemez.

PKK’ya destek veren halk kitlelerinin meşru taleplerinin hukuk zemininde karşılanması gerekir.

PKK’ya destek verenlerin önemli özelliği, “terörle mücadele”de bir yakınlarının hayatını yitirmiş veya hapse girmiş olmasıdır. “Terörle mücadele” uygulamamızın semeresi, suçun işlenmesini önlemek ve suçluların ıslahını sağlamak olmamış; suç ve özellikle suçlu üretmek olmuştur.

“Terörle mücadele” bağlamında bugün görülmekte olan “Ergenekon” ve “KCK” davaları, suçlu üretmekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır. Ancak bunun başlıca sebebi “terörle mücadele” mevzuatımız değildir; “terörle mücadele”deki yanlış anlayışımız ve uygulamamızdır. Terörle Mücadele Kanununda önemli hukuk hataları vardır. Bunların düzeltilmesi gerekir. Ancak, “terörle mücadele”deki yanlış anlayışımız ve uygulamamız değişmedikçe, yeni kanun yapmanın bir anlamı olmayacaktır. 2012 yılının son aylarında ülkemiz siyasetinde yaşanan “dokunulmazlık” tartışması, bu yanlış anlayış ve uygulamamızın bir yansımasıdır.

Kürt sorununa ve PKK’nın etkisizleştirilmesine ilişkin olarak ayrıca şunu belirtmemiz gerekir:

“Terörle mücadele”de düzenli ordu birlikleri kural olarak kullanılamaz. Düzenli ordu birlikleri ve sahip bulundukları ağır silah ve sair teçhizat, “terörist”lere karşı kullanılamaz. Bunun bazı istisnaları var. Örnek 1: İsrail ordusu Filistin “terör”üne karşı savaş vermektedir.

Örnek 2. Amerikan ordusu Afganistan’da Taliban “terör”üne karşı savaşım vermektedir.

Terör örgütüne sağlanan bu **halk desteğinin** kaldırılabilmesi için, **desteği sağlayan toplum kesimlerinin meşru zemindeki siyasi taleplerinin vakit geçirmeksizin karşılanması gerekir.**

Önemle belirtmek gerekir ki, bu taleplerin karşılanmasına yönelik süreci de **hukuk zemininde işletmek gerekir**^{119, 120}.

Türkiye de bu örneklerden hareketle PKK terörüne karşı düzenli ordu birlikleri ile savaşım vermektedir. Bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünmekteyiz.

Terör bir kolluk sorunudur. Terörle mücadelede ülkemizde genel kolluk olarak polis ve jandarma görev yapmalıdır. Ancak arızı hallerde ordu birlikleri genel kolluğa destek sağlamak üzere ve genel kolluğun yanında terörle mücadelede görev yapabilir.

Aksi takdirde, yani düzenli ordu birliklerinin ağır silah ve sair teçhizatı kullanmak üzere görevlendirildiği savaşımın adı, terörle mücadele değil, savaştır.

Düzenli ordu birlikleri PKK terörüyle mücadelede görevlendirilmemelidir.

Düzenli ordu birliklerinin PKK'ya karşı kullanılması halinde örgütün zayıflığı yüksek olabilir. Bu ağır insan zayıflığı ise PKK'ya ancak kitlesel destek sağlama sonucu doğurur.

Türkiye bu görevlendirmenin ağır sonuçlarına katlanamaz. Esasında PKK da uluslararası alanda böyle bir kabul için mücadele vermektedir. Böyle bir kabul,

1) PKK'yı "taraf" konumuna yükseltir.

2) Taraflar arasında uygulanacak hukukun değişmesine yani savaş hukukunun uygulanmasına sebebiyet verir.

3) Bu savaşımın kaybedeninin Türkiye olması sonucunu doğurur.

¹¹⁹ 1982 Anayasasına göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmî dili Türkçedir (m. 3).

Anayasa ile eğitim ve öğretim dilinin Türkçeye münhasır kılınması suretiyle, Türkçeden başka bir ana dile sahip olan vatandaşların kendi dillerinde eğitim ve öğretim görmesine fırsat tanınmamıştır.

1982 Anayasasına göre; "Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez." (m. 42).

Ancak, Anayasada "Milletlerarası anlaşma hükümleri saklıdır" demek suretiyle, Lozan anlaşmasının kapsamına giren gayrimüslim vatandaşların çocuklarıyla ilgili olarak kendi ana dillerinde eğitim yapılması imkânı (Lozan Anlaşması, m. 41) korunmuştur.

Anayasanın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlığını taşıyan 26. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, "düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz."

Anayasanın söz konusu maddesinde, bu yasağa aykırı olarak basılmış olan kitap, gazete, dergi vs.nin toplatılacağı hüküm altına alındıktan sonra, bu toplatmanın usul ve esasları da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Keza, Anayasanın "Basın hürriyeti"ni düzenleyen 28. maddesinin ikinci fıkrasına göre, "kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz."

Anayasadaki bu hükümlere istinaden 19.10.1983 tarihli ve 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun" çıkarılmıştı.

Bu kanunla "Türk devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhangi bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasak"lanmıştır (m. 2).

Söz konusu Kanunda ırk veya etnik köken ayırımı yapılmaksızın "Türk vatandaşı olan herkesin ana dilinin Türkçe olduğu" hüküm altına alınmış ve "Türkçeden başka dillerin ana dili olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyet" yasaklanmıştı (m. 3).

Ancak, bu Kanun, 1991 yılında 3713 sayılı kanunla (m. 23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz Anayasadaki hükümler her ne kadar yürürlükte iseler de; bu hükümlerin uygulamasını sağlayacak bir kanun hükmü artık mevcut değildir.

Düşünme, kendi varlığının şuurunda olan insanın, çevresindeki vakıaları, olguları algılaması ve bunlardan belli sonuçlar çıkarması sürecidir. Düşünebilmek için, insanın önce anlama ve algılama kabiliyetinin gelişmiş olması gerekir. Düşüncenin dışı yansıma biçimlerinden biri, bunun sözle, yazıyla veya şekille *açıklanması*dır. Düşünmek, insan için doğal bir hak olduğuna göre; düşündüklerini açıklamak da insanın bu doğal hakkının vazgeçilmez sonucudur.

Ancak, düşünce açıklamasının sınırsız olduğu söylenemez. Düşünce açıklamak suretiyle; insanlar suç işlemeye tahrik ve teşvik edilemezler; suçlar ve suçlular övülemezler; insanlar birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa davet edilemezler.

Buna karşılık, toplumun bir parçasını oluşturan belli dine veya ırka mensup, belli dili konuşan insanların esasen sahip oldukları haklara siyasî iktidarlar ve kamu gücünü kullanan görevliler tarafından riayet edilmemesinin veya insan olmaları itibarıyla sahip oldukları hakların kullanılmasını engelleyen mevzuat hükümlerinin eleştirilmesi, ülke bütünlüğünü bozmaya matuf bir propaganda olarak mütalaa edilemez.

Keza, toplumda sosyal ve ekonomik bakımdan geri bırakılmış, kamu hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanamayan insanların *insan* olmaları itibarıyla sahip oldukları hakları fiilen kullanabilmelerini temine matuf düşünce açıklamaları, şiddet içeren fiillere tahrik ve teşvikte bulunulmadığı sürece, *hukuka uygun davranışlardır*.

Dil, insanın duygu ve düşüncelerini ifade edebilme hususunda ihtiyaç duyduğu bir araçtır. İnsan, duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde kendi ana diliyle ifade edebilir. Bu itibarla, herhangi bir ayırım yapmaksızın bir toplumda yaşayan bütün insanların kendi ana dillerini öğrenme, kullanma ve geliştirme imkânına sahip olmaları gerekir. Ülkede bir başka dilin “resmî dil” olarak kabul edilmiş olması, insanların kendi ana dillerini öğrenme ve kullanma hakkından yoksun bırakılması için bir sebep teşkil etmez.

İnsanların kendi ana dillerini sadece aile ortamında veya sokakta öğrenme veya konuşma imkânına sahip olması ile bu hak kullanılmış olmaz. İnsanlar, ana dillerini kurumlaşmış bir ortamda, eğitim ve öğretim kurumlarında bilimsel esaslara uygun bir şekilde öğrenebilmeye imkânına sahip olabilmelidirler. Bu hususta devlet, malî imkânları ölçüsünde ve adaletli bir şekilde insanlara destek sağlamalıdır.

Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Anayasa’nın halen yürürlükte olan metnine göre,

“Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.”

Anayasa’nın bu hükmüne rağmen, Kürt vatandaşlarımıza, seçmeli ders olarak da olsa, Kürtçenin öğretilmesine yönelik idari düzenleme yapılmasının, hukuki bakımdan sorunlu olduğu ortadadır. Dikkat edilmelidir ki, Kürtçe, isteyen kişilere, sadece bir yabancı dil olarak değil, kendi **ana dili olarak** da öğretilebilecektir. Başka bir ifadeyle, bu uygulama karşısında, isteyen kişiler, Kürtçeyi kendi ana dili olarak; Türkçeyi ise, resmi dil olarak öğrenebilecekler.

Bu uygulamanın anayasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu türden bir uygulamaya, anayasal dayanak oluşturularak başlanması gerektiği, malumun ilamıdır. Anayasal dayanak oluşturmadan başlatılan bu uygulamanın, pek çok soruna yol açacağı kuşkusuzdur. Daha şimdiden, bu uygulamanın beklentiyi karşılamadığı itirazlarıyla karşı karşıya gelinmiştir. 2012-2013 öğretim yılında Kürtçeyi seçmeli ders olarak öğrenmek isteyen kişi sayısının azlığı, bu düzenlemenin tatmin edici bulunmadığının açık göstergesidir.

Sayın Başbakanın 30 Ekim 2012 tarihinde partisinin grup toplantısında yapmış bulunduğu konuşmada, PKK ve siyasetteki uzantıları tarafından yapılan **çocukların okula gönderilmesi** yönündeki **çağrıya** bazı illerimizde *“ciddi oranda”* uyulduğu şeklindeki açıklaması, **PKK’nın bir başarısını** ifade etmektedir.

¹²⁰ “**KCK davaları**” olarak ifade edilen bazı davalarla ilgili olarak medyada, “*ana dilde savunma hakkı*” tartışma konusu yapılmaktadır. İktidar gücünü kullanan siyaset de bu tartışmalara “haklılığını” teslim eden bir söylem kullanmaktadır.

Söz konusu davalardaki sanıkların önemli bir kısmının, Türkçeyi ana dilleri Kürtçeden daha iyi konuştukları bilinen bir gerçektir. Belirtmemiz gerekir ki, hukukumuzda ana dilde savunma hakkını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu davalarda bazı sanıklar tarafından dile getirilen husus, “*ana dilde savunma hakkı*” değil, “**ana dilde yargılanma hakkı**”dır. Bu talep, **Kürtçenin** eğitim kurumlarında ana dili olarak öğrenilmesinin dışında, **resmi dil** olarak kabul edilmesini ifade etmektedir. Bu davaların bir kısmında **yargı otoritesinin zaafa uğratılmasından** yararlanılarak, bu talep sıklıkla dile getirilmektedir. Siyasilerimiz tarafından bu gerçeğin görmezlikten gelinmesi düşündürücüdür.

PKK’nın ve siyasetteki uzantılarının talebi, “ana dilde savunma hakkı” değil, “anadilde yargılanma hakkı” olduğu için; **Ceza Muhakemesi Kanununun tercüman bulundurmaya ilişkin düzenleme içeren 202. maddesinde** 24.1.2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanunla yapılan **değişiklik, PKK ve siyasetteki uzantılarının beklentilerine cevap vermemektedir.**

Buna rağmen, söz konusu davalarda tutuklu bulunan kişilerin savunma haklarının kullanılması bağlamında başlattıkları açlık grevlerini sonlandırma uğruna yapılmış olan bu değişiklik, Kürtçenin resmi dil olarak kabulü yönündeki talepler karşısında **Devletin bir tavizi** olarak değerlendirilmelidir.

CMK’nın 202. maddesinde değişiklik yapan 24.1.2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında şahsıma verilen söz üzerine yapmış bulunduğum açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

“Bir kanuni düzenleme yapılırken önce bir sorun teşhisi yapılması lazım gelir. Yani uygulamada ortaya çıkan sorun nedir? Bu sorunu doğru bir şekilde teşhis ettikten sonra bu sorunun çözümünün uygulamayla mı yoksa bir kanuni düzenlemeyle mi yapılması gerektiği üzerinde düşünce üretme yoluna gitmekteyiz. Süreç itibarıyla böyle bir yol izlenmesi gerekir.

Bu süreçte ortaya konulacak olan alternatif çözüm modellerinden birisi eğer kanuni düzenleme ise önerilen kanuni düzenleme formülasyonlarının Anayasaya uygunluğu veya aykırılığı tartışma konusu yapılabilir.

Ama bu aşamaya gelmeden önce bizim önce iki hususu açıklığa kavuşturmamız lazım gelir. Birincisi, sorun var mı, yok mu ve bu sorun nereden kaynaklanıyor? Savunma hakkının kullanılmasında kullanılan dil bağlamında bir sorunla karşı karşıyayız. Ama bu sorun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesinin formülasyonundan kaynaklanan bir sorun değil. 202’nci madde 2005 yılında yürürlüğe giren bir maddedir. Bu maddenin formülasyonu yapılırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dil hakkının kullanılması bağlamında vermiş bulunduğu kararlar göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesinin formülasyonunda herhangi bir sorunla karşı karşıya bulunmuyoruz, yani böyle bir tespitimiz yok.

Fakat belirli mahkemelerde savunma hakkının kullanılması bağlamında ana dil kullanılması talepleriyle bağlantılı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle bir gerçekliğimiz var. Bu gerçeklik, davaların özellikle siyasi içerikli davalar olması itibarıyla kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Yani şunu bilmemiz lazım gelir ki: Siyasi içerikli olmayan davalardaki savunmalar bakımından dil yönü itibarıyla savunma hakkının kullanılmasında herhangi bir sorun bize yansımış değil. Ancak dil bağlamında, yani, savunma hakkının kullanılması bağlamında ileri sürülen birtakım taleplerle karşı karşıyayız. Ama bu taleplerin hiçbirisi somut davadaki savunmanın efektif bir şekilde yapılmasıyla ilgili de değildir. Bu davalardan bir tanesi, Diyarbakır’da yürüten davadır, şu veya bu isimle yürüten dava demek istemiyorum. Ama orada yürüten bir davadır. Bu davanın yürütülüşü sırasında yargı otoritesi etkinliği bakımından biraz zaafa uğramıştır; bu gerçekliği burada ifade etmem lazım idi.

Hukuk sistemimizde bir duruşma açıldığında bunun nasıl, hangi usul sırası itibarıyla icra edileceği kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Ama daha bir duruşmada henüz iddianame okunmadan önce, henüz daha sanıkların kimlikleri tespit edilmeden önce sanıklar temsilcisi diye sanıklar adına bir kişi kalkıp davanın esasıyla ilgili olmayan konularda saatlerce hatta günlerce anlatımda bulunmasına müsaade edilmesiyle **yargı otoritesi o davalarda zaafa uğratılmıştır.**

Şimdi, sorununuz şu: Zaafa uğrayan bu yargılama faaliyetinde iddianame okunmadan önce yapılan bütün konuşmalar Türkçe yapılmaktadır ve bu sanıkların –bu konuşma yapan sanıkların- hiçbirisi Türkçeyi bilmediği yönünde, Türkçeyi yeterince bilmediği yönünde Kürtçeyi Türkçeden daha iyi bildiği yönünde bir iddia da bulunmamaktadır. Sadece tırnak içinde “ana dilde savunma hakkı” kavramını kullanmaktadırlar. Ama gerçekte dile getirdikleri husus, “**ana dilde yargılanma hakkı**”dır. Böyle bir hak var mıdır, yok mudur, o ayrı tartışma konusu olan bir husus. Ama dile getirilen husus ana dilde savunma hakkı değil, ana dilde yargılanma hakkıdır. Yani sadece meramlarını kendi ana dillerinde sözlü olarak ifade etmekle yetinmek istemiyorlar. Bütün bu **yargılama faaliyeti sırasındaki bütün yazılı, sözlü işlemlerin hepsinin kendi ana dilleri çerçevesinde icra edilmesi yönünde bir talepte** bulunuyorlar.

Şimdi, bu talep o davanın esasıyla ilgili bir talep değil. O davanın esası bakımından, kendilerine yöneltilen suçlamalarla bağlantılı eğer bir savunma yapacaksa bunu dinleyebiliriz ama o davadaki yargılama faaliyeti çerçevesinde **bir siyasi talep** dile getirilmektedir. Bu siyasi talep karşılanırsa, karşılanmaz, bu konu siyasetin bileceği bir konu; ama eğer **bu siyasi talep karşılanacaksa bunun karşılanacağı yer Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesi değil. Böyle bir talebin karşılanması bir anayasal sorun olarak karşımıza çıkar.** Yani bunu biz anayasa değişikliğiyle ancak dile getirebiliriz ve bu konu resmî dil tartışması bağlamında ele alınması gereken bir konudur. Eğer biz, resmî dil konusundaki tartışmayı bir kenara iter de Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesinde tasarı metninde olduğu gibi bir değişiklik yapma yoluna gittiğimizde bu birtakım sorunları belki çözme yönünde bir ilüzyon oluşturabilir. Ama gerçekte ise o düzenleme hayata geçtiğinde daha başka problemlerle karşı karşıya geleceğiz.

En basit karşılaştığımız problem şudur: **Sadece belirli yargılama işlemleri bağlamında** kişilere kendi “ana dilinde savunma imkânı” tanıyoruz. Tırnak içinde, “hak” demiyoruz ona çünkü madde “hak” kavramını kullanmıyor “imkân” diyor, “savunma imkânı” veriyoruz. Bu çerçevede mesela bir kişi iddianame okunduktan sonra sözlü savunması bağlamında kendi ana dilini veya istediği bir başka dili -Türkçe dışında bir başka dili- kullanabilecektir. Ama mesela bir bilirkişi raporuna diyeceği sorulduğunda “Onu hayır, onu Türkçe anlatacağsın.” diyeceğiz bu kişiye. Yani yargılama faaliyetinin başlangıcında Türkçe dışında bir dili savunma dili olarak kullanacak, yargılama faaliyeti devam ederken Türkçeye tekrar geri döneceğiz ve yargılama faaliyeti sonucunda Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra “Sen ne diyorsun?” diye sözüün bağlanacağı bir noktada yine tercih ettiği bir başka dile geri döneceğiz. Bu başlangıçtaki dil olabileceği gibi onun dışında başka bir dil de olabilir. Böyle bir yargılama biçimi yok. Ve bu tartışma karşımıza yarın başka tartışmaları da çıkarmaktadır, o da şu: Neden bu sadece kovuşturma evresinde; soruşturma evresinde değil; neden mesela soruşturma evresinde tutuklanma talebiyle hâkimin huzuruna çıkarıldığında bu imkândan yararlanılmayacağım? şeklinde bir taleple karşı karşıya geleceğim. Yine bu çerçevede, neden bu sorun sadece ceza davasıyla sınırlı olarak tutuluyor. ... Özel hukuk davasında veya diğer bir başka davada ceza hukuku dışındaki diğer davalarda sözlü olarak özellikle taleplerin dile getirilmesi bağlamında bu hak nasıl kullanılacaktır? Sanık bakımından kabul ettiğimiz bu imkânın, tanık bakımından kabul edilebilir olup olmadığı konusu da tartışma konusu yapılabilir.

Sözün kısası şu: Çok özür diliyorum, bu konularda aslında Alt Komisyonda da düşüncemizi arz etme imkânı bulmuştuk. Ama orada kayıt edilme imkânı yoktu. **Talebin ceza muhakemesi sürecinde ortaya çıkan bir sorunun çözümüne yönelik olmaktan ziyade siyasi bir talep olduğunu ifade etmekle yetinmek isterim.**”

Aksi takdirde, gelişmelerin gayrimeşru zeminde olanların başarısı olarak algılanması veya gayrimeşru taleplere boyun eğildiğinden bahisle sorumluluk süreçlerinin işletilmesi gibi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden biri, Türkiye'de Kürt nüfusla ilgili sosyal, siyasi ve dolayısıyla, hukuki sorunların varlığını kabul etmediği için, bugünkü politik duruşu itibarıyla PKK sorunun gerçekçilik temeline dayalı çözümüne kapalı bulunmaktadır.

İktidar ve anamuhalefet görevi ifa eden siyasi partiler tarafından bu sorunun çözümüne yönelik olarak oluşturulmuş ve bütün toplum kesimleriyle paylaşılan somut bir siyasi reçete henüz mevcut değildir.

Sorunun hassasiyeti nedeniyle, iktidar ve anamuhalefet partileri bu bağlamdaki çözümlerini netlik taşımayan bir dille ifade etmek ve süreç içerisinde bazı "çözüm"ler oluşturmak yolunu tercih etmektedirler.

Görünen odur ki, Türkiye, bu konuda kendi inisiyatifiyle bir çözüm üretmezse, bu sorunun "çözüm"ü bağlamında, "Arap Baharı"na benzer bir biçimde uluslararası bir dayatma ile karşı karşıya kalacaktır.

Görüşümüze göre, Türkiye'de Kürt nüfusla ilgili olarak yaşanan sorunların çözümüne yönelik reçetenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulması gerekir.

Bu amaçla, TBMM'de üyesi veya grubu bulunan bütün siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, yerine göre, bir idari düzenleyici işlem yapılmasını, kanun değişikliğini ve hatta anayasa değişikliğini gerektiren önerilerde bulunabilmelidir.

Milli Güvenlik Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu komisyon çalışmalarının yürütülmesine katkısı sağlanmalıdır.

Söz konusu sorunların çözümü bağlamında yurt içinde veya yurt dışında belirli kişilerle, kuruluş veya organizasyon temsilcileriyle görüşme yapıp yapılmamasına bu komisyon karar verebilmeli ve yapılacaksa, bu görüşme komisyon üyesi milletvekilleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

(Bkz. TBMM Adalek Komisyonunun 27.11.2012 tarihinde yapmış bulunduğu toplantıya ilişkin tutanaklar).

Türkiye Barolar Birliğini temsilen toplantıya katılan Sayın Av. Özcan ÇİNE yaptığı konuşmada bu açıklamalarıma aynen katıldığını ifade etmiştir.

Bu komisyon tarafından yapılan çalışmaların kural olarak gizlilik içinde yürütülmesi sağlanmalıdır. Ancak, komisyon gerek gördüğünde, alacağı kararla, çalışmaların belirli bir kısmının içeriğiyle ilgili olarak kamuya açıklama yapılmasını sağlayabilmelidir.

Komisyon tarafından yapılan bütün çalışmalar, tutanağa kaydedilmelidir. Bu komisyon çalışmalarının gizlilik içinde yürütülen kısımlarına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların devlet sırrı olarak koruma altına alınması sağlanmalıdır.

Komisyon, yaptığı çalışmalar sonucunda, anayasa ve yürürlükte olan kanunların izin verdiği ölçüde, belirli konularda idari düzenleyici işlem yapılması ve uygulamada bulunulması hususlarında Hükümete önerilerde bulunabilmelidir.

Komisyonun önerdiği kanun değişiklikleri, tasarı olarak değil, teklif olarak TBMM Başkanlığına verilebilmelidir.

Bu yöntemin izlenmesi halinde,

- 1) Türkiye’deki Kürt nüfusla ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak bulunulan girişimlerin toplum kesimleri tarafından tasvip edilmesi ve sonuç vermesi sağlanabilir.
- 2) Türkiye’nin, bu sorunların “çözüm”ü bağlamında, “Arap Baharı”na benzer bir biçimde uluslararası bir dayatma ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilebilir.
- 3) Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak Hükümet tarafından bulunulan bazı girişimlerin akim kalmasının önüne geçilebilir.
- 4) “Oslo görüşmeleri” ve Öcalan’a ait olduğu söylenen mektupların içeriklerinin bit pazarına düşmesi bağlamında yaşanan krizler gibi sorunların önüne geçilebilir.

Nihayet;

- 5) Ülke bütünlüğümüz korunabilir ve kan dökmeye sebep olan PKK terör örgütünün varlığına son verilebilir veya en azında etkisizleştirilmesi sağlanabilir.

EKSKURS 5: PKK'YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ¹²¹

I- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 Aralık 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 10 Ocak 2000 tarihinde New York'ta imzaya açılmış olan “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”, 11 Eylül 2001 tarihi itibarıyla sadece dört devlet tarafından onaylanmış iken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373(2001) sayılı Kararı gereğince çok sayıda devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Türkiye de bu Sözleşmeyi 27 Eylül 2001 tarihinde imzalamıştır¹²².

Sözleşmeye göre,

“Niteliği veya kapsamı itibariyle, bir halkı korkutmak, ya da bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacını gütmesi halinde, bir sivil ya da bir silâhlı çatışma durumunda muhasemata doğrudan katılmayan herhangi başka bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya yönelik diğer tüm eylemler”,

“terör eylemi” olarak nitelendirilebilecektir (m. 2, f. 1, bent b).

Dikkat edilmelidir ki, bu hüküm, öldürme ve ağır şekilde yaralama fiillerinin “**bir silâhlı çatışma durumunda muhasemata doğrudan**” katılan kişilere karşı işlenmiş olmasını terör suçu olarak kabule imkan tanımamaktadır. Başka bir ifadeyle, bir silahlı çatışma söz konusu ise, bu çatışmaya doğrudan katılan tarafların birbirlerine karşı işlemiş bulundukları öldürme ve ağır yaralama fiilleri **terör suçu olarak kabul edilemeyecektir**. Bu hükmün dolaylı sonucu, bir devlet ile silahlı çatışmanın varlığı halinde çatışmanın tarafı olan devlet dışı örgütlenmelere silah ve sair ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fon sağlanması, “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**” kapsamında terörün finansmanı suçu oluşturmayacaktır. Söz konusu Sözleşmenin dikkat edilmesi gereken noktalarından birisi bu hükümdür.

Söz konusu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti adına 27 Eylül 2001 tarihinde New York'ta imzalanırken, bu hükümle ilgili olarak **beyanda** bulunulmuş-

¹²¹ Bu başlık altındaki bilgiler, Sayın Cumhurbaşkanına 8.11.2015 tarihinde bir Bilgi Notu olarak arz edilmiştir.

¹²² Söz konusu Sözleşmenin onaylanması, 10.1.2002 tarihli ve 4738 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme, Bakanlar Kurulu'nun 01.03.2002 tarihli ve 2002/3801 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Sözleşme metni, **01 Nisan 2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazetede** yayımlanmıştır.

tur¹²³. Ancak, Türkiye'nin bu hükümle ilgili olarak beyanda bulunması, Sözleşmeye taraf olan devletler bakımından söz konusu hükmün uygulamada göz önünde bulundurulmasına engel teşkil etmemektedir. Bu itibarla, **Sözleşmeye taraf olan devletler, örneğin PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile silahlı çatışma halinde bulunduğunu, bu silahlı çatışmanın taraflarının doğrudan birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri öldürme veya ağır yaralama fiillerini terör suçu olarak kabul etmeyebilecektir.** Bunun sonucu olarak, PKK'nın silahlı çatışma halinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik görevlilerine karşı öldürme veya ağır yaralama fiillerini gerçekleştirse bile, bu örgüte yapılan yardımları “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme” hükümlerini ihlal ve dolayısıyla suç olarak değerlendirmeyecektir.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve bazı Avrupa devletlerinin hükümetleri tarafından hazırlanan “terör örgütü listeleri”nde PKK'nın veya PKK ile irtibatlı bazı organizasyonların adlarının yer alması, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bir “jest”i ifadeden ibaret sembolik bir anlam taşımaktadır. Önemli olan söz konusu terör örgütüne mali destek sağlayan kişi, kuruluş ve organizasyonların bu listelerde yer almasını sağlamaktır. Zira hukuki kişiliği olmayan terör örgütü ile malvarlığı arasında sahiplik ilişkisinden söz edilemeyeceği izahtan varestedir.

Ancak belirtilmelidir ki, söz konusu Listelerde PKK'ya finansal destek sağlayan hiçbir kişi, kuruluş ve organizasyonun ismi yer almamaktadır. Bu nedendir ki, **Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi devletlerin hiçbirinde PKK'ya finansal destek sağlayan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili olarak bu sebeple malvarlığının dondurulması tedbiri uygulanmamaktadır.**

II- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 15 Ekim 1999 tarihli ve 1267 sayılı Kararına istinaden Birleşmiş Milletler bünyesinde Güvenlik Konse-

¹²³ Bu hükümle ilgili beyan metninde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“1. Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşmenin 2'nci maddesinin 1(b) paragrafının uygulanmasının bir silahlı çatışmanın varlığına işaret etmeyeceğini, **silahlı çatışma tabirinin**, örgütlü bir biçimde olsun veya olmasın, ceza hukuku kapsamında **terörizm suçunu oluşturan fiillerin işlenmesinden farklı olan bir durumu betimlediğini** beyan eder.

2. Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşmenin 2'nci maddesinin 1(b) paragrafının, 21 inci maddede de ifade edildiği üzere, devletlerin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine, özellikle başka devletlerin topraklarında faaliyet gösteren terörist ve silahlı gruplara finansal destek sağlamama yükümlülüğüne zarar vermeyeceğini beyan eder.”

yine üye devletlerin temsilcilerinin katılımıyla bir “**Komite**” oluşturulmuştur (“*Yaptırımlar komitesi*”). Bu “**Komite**”, Afganistan’da işgalcilere karşı savaşan Taliban örgütü başta olmak üzere, terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları gerekçesiyle sahibi oldukları veya kontrolü altında bulundukları malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonları belirleyerek liste oluşturacaktır. Bu Kararla, üye devletler, söz konusu “**Komite**”nin hazırladığı listede yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların sahibi oldukları veya kontrolü altında tuttukları **malvarlıklarını dondurmaları** için gerekli tedbirleri almaya çağırılmışlardır.

Avrupa Birliği’nin karar organlarından biri olan **Avrupa Birliği Konseyi** de, Birleşmiş Milletler “*Yaptırımlar Komitesi*”nin oluşturduğu malvarlığı dondurulacaklar listesinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyon isimlerinin de yer aldığı ayrı bir karar almaktadır.

Avrupa Birliği Konseyinin bu çerçevede aldığı **2.5.2002** tarihli ve **2002/334/EC** sayılı Kararın eki olan Listedeki ‘**Kurdistan Workers’ Party**’ – ‘**PKK**’, (a.k.a. ‘**KADEK**’, a.k.a. ‘**KONGRA-GEL**’) yer almaktadır.

Bu ve bunu takip eden **17.6.2002** tarihli ve **2002/460/EC** sayılı Kararın iptali için, Avrupa Birliği organlarının karar ve işlemlerine karşı başvurulabilen özel bir yargı organı olan “**Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi**” nezdinde **PKK “adına”** dava açılmıştır (Case T-229/02 PKK and KNK v. Council)¹²⁴.

Bu dava PKK’yı “temsilen” **Osman Öcalan** adlı bir şahıs tarafından açılmıştır.

Mahkeme bu davayı 15 Şubat 2005 tarihli kararı ile reddetmiş¹²⁵ ise de, bu kararda, PKK’nın **hukuki kişiliğe sahip bir organizasyon** olduğu kabul edilmiştir (Karar metni, Kn. 32).

Avrupa Birliği Adalet Divanı da, bu kararın temyizi üzerine yaptığı incelemesi sonucunda verdiği kararda, **PKK’nın “hukuki” varlığını ve ayrıca**

¹²⁴ Söz konusu kararların iptali için ikinci bir dava dilekçesi daha verilmiştir. PKK adına açılan dava ile birleştirilerek görülen bu dava, aralarında PKK ve devamı mahiyetindeki KADEK’in de bulunduğu otuz kadar organizasyonun oluşturduğu bir **dernek** olarak merkezi Brüksel’de bulunan “**Kürdistan Milli Kongresi**”ni (**KNK**) temsilen “Başkan” sıfatıyla **Şerif Vanlı**’nın verdiği vekaletnameyle görevlendirilen Avukatlar tarafından açılmıştır. Konumuzla doğrudan bağlantısı olmadığı için, burada KNK adına açılan davanın akıbetine ilişkin bilgi verilmemiştir.

¹²⁵ Case T-229/02 PKK and KNK v Council [2005] EU:T:2005:48; <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=53194&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=35206>.

Osman Öcalan’ın bu örgütü “temsil yetkisi”nin olduğunu kabul etmiştir (Case C-229/05 P PKK and KNK v. Council)¹²⁶.

PKK mensupları, 4-10 Nisan 2002 tarihleri arasında Irak’ın kuzey bölgesinde “8. Kongre” namıyla gerçekleştirdikleri toplantıda, örgütün adını “**Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistanê**” (“KADEK”, “Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi”) olarak değiştirmişlerdir.

İlk Derece Mahkemesi, Osman Öcalan adlı kişi tarafından açılan davayı PKK’nın bir terör örgütü olması, hukuki kişiliğe ve dolayısıyla dava ehliyetine sahip olmaması sebebiyle değil, Örgütün 4 Nisan 2002 tarihi itibarıyla varlığına son verdiğini, davanın açıldığı tarih itibarıyla bu adla bir örgütün bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

Ancak, Avrupa Adalet Divanı yaptığı temyiz incelemesi sonucunda 18 Ocak 2007 tarihinde verdiği kararda, 4-10 Nisan 2002 tarihinde yapılan “8. *PKK Kongresi*”nde PKK’nın tasfiyesine yönelik karar alınmadığını, örgütte yapısal değişikliğin yanı sıra **isim ve amaç değişikliğinin** yapıldığını kabul etmiştir. Divan’ın kabulüne göre, söz konusu “Kongre”de yapılan değişikliklerle Örgüt cebir ve şiddet içeren faaliyetlerden sarfınazar etmiştir (Kn. 42, 43, 44, 47, 48, 50).

Divan, verdiği kararda, isim ve amaç değişikliğiyle birlikte, **PKK’nın** varlığını devam ettirdiği ve “**dava ehliyeti’nin bulunduğu**” sonucuna varmıştır. (Kn. 107, 108)

III- Osman Öcalan isimli şahıs, Avrupa Adalet Divanı önünde görülmekte olan davayı takiple görevlendirdiği avukatlara verdiği vekâletnamede, “PKK eski üyesi” sıfatıyla tavsif edilmiştir. Bunun dışında dava dosyasında adı geçen kişinin “PKK’yı temsil yetkisi”ni haiz olduğu hususunda sadece sözlü açıklamalar bulunmaktadır. Osman Öcalan tarafından vekâlet verilen Avukatlardan Mark Muller, ilk derece mahkemesi huzurunda bu bağlamda yaptığı sözlü savunmada, adı geçen kişinin PKK’nın ve onun devamı olan KADEK’in “**yüksek düzeyde temsilcisi**” olduğunu ifade etmiştir.

Bu açıklamalara dayanarak, Avrupa Adalet Divanı, Osman Öcalan isimli şahsın “**PKK’yı temsil yetkisi’nin olduğunu** ve bu yetkiye istinaden avukatları vekil tayin edebileceğini kabul etmiştir. (Kn. 122).

¹²⁶ Case C-229/05 PKK and KNK v. Council [2007] EU:C:2007:32; <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65123&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=35206>.

Divan, bu kabulüne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12 Mayıs 2005 tarihli Abdullah Öcalan/Türkiye (Başvuru numarası 46221/99) kararını dayanak göstermiştir¹²⁷. Söz konusu kararın ilişkin olduğu davada da Avukat Mark Muller, Abdullah Öcalan'ın vekili sıfatıyla görev yapmıştır. Adı geçen Avukatın Mahkemede yaptığı sözlü açıklamada, “müvekkili”nin hükümlü olarak Türkiye’de cezaevinde bulunduğunu, kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, bu ziyareti sırasında Abdullah Öcalan'ın kendisine PKK'nın Avrupa’da yasaklanmasına yönelik kararlara karşı dava açması talimatı verdiğini ifade etmiştir. Keza, gerek PKK gerek devamı mahiyetindeki KADEK üst düzey yöneticilerinin kendisine bu amaca yönelik olarak dava açması ve bu davayı takip etmesi talimatı verdiğini ifade etmiştir (Kn. 117).

IV- Avrupa Birliği Adalet Divanı, 18 Ocak 2007 tarihli Kararı ile, PKK “adına” açılan davada İlk Derece Mahkemesinin verdiği ret kararını Konseyin 17.6.2002 tarihli ve 2002/460/EC sayılı Kararı ile sınırlı olarak bozmuştur. Bozmadan sonra dosyayı tekrar ele alan İlk Derece Mahkemesi, **3 Nisan 2008 tarihli kararı ile, Konseyin 17.6.2002 tarihli ve 2002/460/EC sayılı Kararını PKK yönünden ve PKK lehine iptal etmiştir**^{128, 129}.

V- Söz konusu iptal kararına rağmen, bu tarihten sonraki Avrupa Birliği Konseyi “CFSP: common foreign and security policy” (“GASP: Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik”) kararlarında PKK, KADEK, KONGRA-GEL, ile “TAK: Tyrêbazên Azadîya Kurdistan” (“Kürdistan Özgürlük Şahinleri”) adlı örgütün ismi yer almaktadır¹³⁰.

¹²⁷ Kanımızca, Divan'ın bu kabulüne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin söz konusu kararında dayanak oluşturacak bir açıklama bulunmamaktadır. Kararda mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun vekâletname olmadan avukatın müdafî sıfatıyla kullanabileceği yetkilere ilişkin hükümlerinden (m. 144) söz edilmektedir.

¹²⁸ Karar metni için bkz: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0%part=1&mode=req&docid=71034&occ=first&dir=&cid=21589.

¹²⁹ Söz konusu Karardaki iptal sebebini, PKK'nın malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin listeye neden alındığı hususunda açıklayıcı gerekçe gösterilmemesi oluşturmaktadır (Karar, Kn. 65).

Her ne kadar PKK'yı temsilen açılan bu davaya ilişkin Konsey'in savunmasında PKK'nın Listeye alınmasının gerekçeleri açıklanmış ise de, İlk Derece Mahkemesi, bunu yeterli görmemiştir (Karar, Kn. 68, 69).

¹³⁰ Bu bağlamda alınmış son karar için bkz.

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/147 of 3 February 2022

(Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 4.2.2022, L.25/1).

VI- Tespitimize göre, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi¹³¹ nezdinde halen derdest olan ikinci bir dava daha bulunmaktadır (**Case T-316/14 PKK v. Council**). Bu dava 1 Mayıs 2014 tarihinde açılmıştır. Bu dava da PKK “adına” açılmıştır¹³².

Söz konusu dava, Avrupa Birliği Konseyinin 10.02.2014 tarihli ve (EU) 125/2014 sayılı Uygulama Direktifinin¹³³ eki listede PKK’nın yer almasına ilişkin kısmının iptali amacıyla açılmıştır.

Mahkeme, 15 Kasım 2018 tarihinde verdiği karar ile Avrupa Birliği Konseyinin 10.02.2014 tarihli ve (EU) 125/2014 sayılı Uygulama Direktifi ile 04.08.2017 tarihli ve (EU) 2017/1420 sayılı Uygulama Direktifini ve bu arada alınan diğer kararların eki listede PKK’nın yer almasına ilişkin kısımlarını iptal etmiştir¹³⁴. Ancak, bu iptal kararı, açıkça PKK’nın bir terör örgütü olmadığı yönündeki kabule dayanmamaktadır. AB Konseyi Kararlarında PKK’nın bir terör örgütü olarak listeye alınması bakımından dayanakların gösterilmemesi gerekçe olarak belirtilmiştir. Bu yönü itibarıyla ki, söz konusu karar, Avrupa Birliği Konseyinin bilahare aldığı kararlar ekindeki listelerde PKK’nın da yer almasına engel teşkil etmemektedir. Nitekim, örgüt adı, bilahare alınan kararlar ekindeki listelerde yer almaya halen devam etmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, PKK’nın söz konusu listelerde yer almasının sadece simgesel bir önemi bulunmaktadır. Örgütün adının listede yer almasının, AB üyesi devletlerde bulunan örgütlerle ilgili kişi kuruluş ve organizasyonlar bakımından herhangi bir tedbire başvurulmasını sağlama yönünde efektif bir etkisi bulunmamaktadır.

Aksine, Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği kararın iki önemli sonucu bulunmaktadır. Birincisi, karar metninde açıkça belirtilmese bile, açılan da-

¹³¹ Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin ismi 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma ile Avrupa Birliği Antlaşması’nı Değiştiren Antlaşma (Lizbon Antlaşması)” ile “Genel Mahkeme” olarak değiştirilmiştir. (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, [2007] OJ C 306/1, 17.12.2007).

¹³² Bu dava içeriğine ilişkin bilgi için bkz. Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 28.7.2014, C.245/22).

¹³³ Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 11.2.2014, L.40/9).

¹³⁴ Karar metni için bkz: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=5EA866A50D46D9DB8E541FCEf1EF31E7?text=&docid=207801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5039662>.

vada PKK’nın taraf olma ehliyetinin varlığı kabul edilmiştir. Keza, söz konusu kararda, PKK’nın bir terör örgütü vasfını haiz olduğu hususu, esasında tartışmalı bir konu olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, kanun yolunun açık olması itibarıyla henüz yargılama süreci tamamlanmamış olan söz konusu davaya, Türkiye’nin AB Konseyi yanında katılma talebi bulunmamaktadır. Bunun, önemli bir ihmal olduğunu değerlendirmekteyiz.

EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU

I. Örgütün varlığı için suç işlemek amacının açık bir şekilde ortaya konulmuş olması gerekir. Bu itibarla, örneğin bir ticari faaliyet için bir araya gelmiş olan kişilerin aralarındaki işbirliği çerçevesinde bazı suçların işlenebileceği ihtimalini öngörmüş olmaları, suç işlemek için örgüt kurma suçunun manevi unsurlarından amaç unsurunun varlığı için yeterli bulunmamaktadır¹³⁵. Suç işlemek amacının örgüt mensuplarının ortak amacı olarak belirlenmesi gerekir. Bu itibarla, örgütün yöneticisi suç işlemek amacıyla hareket etmekle birlikte, örgütün diğer mensuplarının bu amaçtan habersiz olmaları halinde, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından söz edilemez¹³⁶.

Bir oluşumun çekirdeğini oluşturan kişiler suç işlemek amacıyla hareket etmekle birlikte, oluşumun içinde yer alan ve fakat bu amaçtan habersiz olan kişiler, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüte üye olmaktan veya bu örgütü yönetmekten sorumlu tutulamazlar¹³⁷.

Hukuk, ancak **meşru bir amaca yönelik örgütlenmeleri** örgütlenme hürriyetinin kapsamında değerlendirmektedir. Meşru bir amaca yönelik olmayan örgütlenmelere ve bu yöndeki faaliyetlere hukuk toplumlarında izin verilmez. İdarenin, tesis edilmiş örgütlenmelerle ilgili gözetim ve denetim faaliyetinde bulunarak, gayrimeşru bir amaç güdüp gütmediklerini ve bu amaç doğrultusunda faaliyet icra edip etmediklerini denetlemesi doğaldır. Bu denetim faaliyetiyle idare, tesis edilmiş olan örgütlenmelerin meşru amaçlar doğrultusunda ve hukuka uygun biçimde faaliyet icrasını sağlayabilir.

Bir örgütlenme bünyesinde gayrimeşru faaliyet icra edilmiş olsa ve hatta bu faaliyet çerçevesinde suç işlenmiş olsa bile, başvurulacak ilk çare, bu örgütlenmenin hukuki varlığına son vermek, hukuki varlığını sonlandırmaya zorlamak yerine, bu örgütlenme bünyesindeki **gayrimeşru faaliyetin sonlandırılmasını sağlamak ve suç işlenmesini önlemek** olmalıdır. Ancak bunun mümkün olamaması halinde, yani ancak son çare olarak, bir örgütlenmenin hukuki varlığına son verilebilmelidir. Başka bir ifadeyle, bir örgütlenme bünyesindeki gayrimeşru faaliyet icrası ve hatta suç işlenmesi çeşitli idari

¹³⁵ **LEIPZIGER KOMMENTAR** zum Strafgesetzbuch, Band 5, 12. Auflage, Berlin/New York, 2010, § 127 (Mathias KRAUß), kn. 71.

¹³⁶ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 72.

¹³⁷ KRAUß, Mathias: Leipziger Kommentar StGB, Band 5, § 127, kn. 72.

tedbirlerle önlenebilir ise, bu örgütlenmenin hukuki varlığına son vermemek gerekir. Keza bir örgütlenmenin hukuki varlığına ancak **mahkeme kararıyla** son verilebilmelidir. Başka bir ifadeyle, meşru bir örgütlenme, bilahare bünyesinde icra edilen gayrimeşru faaliyetler ve hatta işlenen suçlar sebebiyle gayrimeşru bir örgütlenmeye dönüşebilir. Uygulanan idari tedbirlerle bu örgütlenme bünyesindeki gayrimeşru faaliyetlerin icrasına son verilemediği, suç işlenmesinin önlenemediği durumlarda, mahkeme kararıyla bu örgütlenmenin hukuki varlığına son verilebilmelidir¹³⁸.

II. Avrupa Birliği hukuk uygulamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi kararları göz önünde bulundurularak, özellikle terörün finansmanının önlenmesi amacıyla, ancak yabancılik unsuru taşıyan örgütlenmeler bakımından, bunların ve mensuplarının faaliyetleri ile ilgili olarak, kısıtlayıcı idari tedbirler alınabilmektedir. Örneğin idari bir kararla yabancılik unsuru taşıyan bazı örgütlenmeler terör örgütü olarak listelenerek, bu örgütlenmelerin, mensuplarının, bu örgütlenmelere finans desteği sağlayan kişi, kuruluş veya organizasyonların faaliyetlerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler alınması yoluna gidilebilmektedir.

Avrupa Birliği Konseyi, bu çerçevede çeşitli kararlar almaktadır^{139, 140}. Alınan bu kararlarla, üye devletlerin terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçmeye yönelik tedbirler alması sağlanmaktadır. Keza Konsey, **yabancılik unsuru taşıyan “terör” örgütleri** ile, bu örgütlere finansal destek sağladığı düşünülen kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak belirli periyotla listeler yayımlamaktadır¹⁴¹. Belirli periyotla yayımlanan listelerde zamanla revizyonlar yapılmakta, yeni isimler listeye alınmakta ve mevcut

¹³⁸ Dikkat edilmesi gerekir ki, idarece icra edilen söz konusu gözetim ve denetim faaliyetinin taciz, yıldırma ve itibarsızlaştırma amacıyla kötüye kullanılmaması gerekir.

Önemle vurgulamamız gerekir ki, efektif bir denetim faaliyetinin bulunmaması ve hatta denetim faaliyetini icra eden kamu görevlilerinin müsamahası, örgütlenmeler bünyesinde gayrimeşru faaliyette bulunulmasına ve hatta suç işlenmesine zemin oluşturmaktadır. Keza, kamu görevlilerinin bu denetim faaliyetini efektif bir şekilde icra etmemeleri, toplum bakımından katlanılamaz düzeyde ağır neticelere sebebiyet verse bile, yaptırımsız bırakılmaktadır. Ülkemiz bakımından sıklıkla karşılaşılan durum budur.

¹³⁹ Bkz. Avrupa Birliği Konseyinin 2580/2001 sayılı Direktifi (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union), L 344, 28.12.2001, sh. 70 vd.).

¹⁴⁰ Bkz. Avrupa Birliği Konseyinin "CFSP: common foreign and security policy" ("GASP: Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik") kararları.

¹⁴¹ Tespitimize göre bu bağlamda alınmış son karar, 22 Aralık 2016 tarihli ve CFSP, GASP 2016/2384 sayılı Karardır (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2016, L352/92).

isimler listeden çıkarılabilmektedir. Bu listeler, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. Üye devletler, bu listelerde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan malvarlığını idari tedbir olarak dondurmaktadır; bankalarda bunlar adına gerçekleştirilen para hareketleri durdurulmakta ve isimleri listede yer aldığı sürece bu paralar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlandırılmakta ve hatta kaldırılmaktadır. Listede yer alan “terör” örgütlerinin mensuplarının ülkeye girişine, bu kişilere oturma izni verilmesine **idari tedbir** olarak kısıtlamalar getirilmektedir.

Önemle vurgulamamız gerekir ki, Avrupa Birliği üyesi devletlerde, bu oluşumlar mensuplarıyla ilgili olarak yapılan yargılamalarda, mahkemeler, münhasıran oluşum adının söz konusu listelerde yer almasını, bunun “terör örgütü” olarak, mensuplarının da “terörist” olarak kabulü için dayanak itti-haz etmemektedir. Yapılan yargılamalarda, kişilerin Avrupa Birliği üyesi devletlerde icra ettikleri esasen **suç oluşturan faaliyetleri** göz önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu kararlarında toplum barışı, kamu güvenliği ve kamu düzeni bakımından belirli sosyal oluşumlara işaret edilmesi, bu oluşumlarla ve mensuplarıyla ilgili **idari tedbirler bakımından** bir önem taşımaktadır.

Kanun gereği gizliliği söz konusu olan söz konusu karar içerikleri, alenileştirilerek, bir soruşturmaya, bir soruşturma bağlamında herhangi bir koruma tedbirine yönelik karar itti-hazına dayanak oluşturamaz.

EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU¹⁴²

I. 15 Temmuz 2016 günü akşamı Millet olarak karşı karşıya kaldığımız bade, bir örgütlü suçun varlığına işaret etmektedir. Olaylar göstermektedir ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde mevzu hukuka göre oluşmuş hiyerarşik ilişkinin dışında bir yapılanma oluşturulmuştur. Bu yapılanma ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki mevzu hukuka göre oluşmuş yasama ve yürütme organları işlevsiz hale getirilerek, bunların yerine fiili bir durum oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli kişiler, mevzu hukuka göre tanımlanmış görevlerinin dışında görev üstlenmişlerdir. Belirlenen amacın gerçekleşmesi için, görev üstlenen kişiler, güvenlik görevlisi olması sebebiyle vaziyet ettikleri kamu malı silah ve mühimmatı kullanmışlar veya kullanılmasını sağlamışlardır. Bu suretle, kamu görevlisi olsun veya olmasın yüzlerle ifade edilen kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermişlerdir. Söz konusu teşebbüs başarısız olsa bile, güdülen amacın, mütemadi (kesintisiz) bir suç olgusunu ortaya çıkardığı kuşkusuzdur. Bu nedenle, olayda, Türk Ceza Kanununun 310, 311, 312 ve 314. maddeleri bağlamında bir **örgütlü suçluluk** söz konusudur.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bir oluşumun 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği “darbe” teşebbüsünün bir **örgüt faaliyeti** olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Zira bu “darbe” teşebbüsünde bulunanlar arasında, güvenlik kuvvetlerinin kendi teşkilat yapısının dışında başka bir hiyerarşik ilişki bulunmaktadır. Söz konusu “darbe” teşebbüsü ani bir kararla icra edilmiş değildir. Bunun bir hazırlık evresini gerekli kıldığı ortadadır. Bu “darbe” teşebbüsüne ilişkin olarak hazırlanmış planların olması gerekir. “Balyoz Darbe Planları”nda olduğu gibi¹⁴³, bu planlarda da hazırlık, icra ve darbe sonrası olmak üzere üç evre söz konusu olmalıdır. Bu planlarda, darbenin ne suretle icra edileceğinin, darbenin icrası sırasında kimin hangi görevi ifa edeceğinin, kamu kurum ve kuruluşları ile stratejik önemi bulunan tesislerin kontrol ve yönetiminin ne

¹⁴² Bu başlık altında yer alan açıklamalar, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “**15 Temmuz Darbe Girişimi Bağlamında Ceza Sorumluluğu**” konulu Konferans ile, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından 4 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen “**15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Bağlamında Ceza Sorumluluğu**” konulu Konferansta tebliğ olarak sunulmuştur.

¹⁴³ Bkz. aşağıda “Ekskurs 10” altında yer alan açıklamalar.

suretle ele geçirileceğinin, seçilmiş ve atanmış yüksek düzeydeki kamu görevlilerinin akıbetinin ne olacağının, bunların yerine kimlerin görevlendirileceğinin tek tek belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu planlarda, ülke yönetimi kontrol altına alındıktan sonra örneğin bakanlar kurulunun kimler tarafından teşkil edileceğinin de isim isim belirlenmiş olması gerekmektedir. Bugün itibarıyla, söz konusu darbe teşebbüsüne ilişkin planların içeriğine henüz muttali olabilmemiş değiliz.

Söz konusu darbe teşebbüsünün icrası çerçevesinde harekete geçen silah ve sair askeri teçhizatla donatılmış olan kişiler suçüstü halinde yakalanmıştır. Bu nedenle, suçüstü yakalanan kişilerle ilgili olarak soruşturmaların bir an evvel tamalanıp davaların açılması ve karara bağlanması gerekirken, bu alanda önemli bir gecikmenin olduğu gözlemlenmiştir.

Bu süreçte söz konusu soruşturmalar çerçevesinde yapılan yanlışlar, siyasi-ler tarafından yapılan açıklamalar, uluslararası alanda, Türkiye’de halen işkence ve kötü muamele uygulamalarının devam ettiği, idam cezasının tekrar geri getirilip geçmişe sâri bir şekilde uygulanmasının yolunun açılacağı yönünde algıların oluşmasına sebebiyet vermiş ve bunun sonucu olarak, iade ve milletlerarası adli müzaheret mekanizmalarının işletilmesinde başarısız olunmuştur.

Nitekim, **Yunanistan Temyiz Mahkemesinin 19 ilâ 25 Ocak 2017** tarihleri arasında vermiş bulunduğu 135/2017, 136/2017, 137/2017, 138/2017, 139/2017, 140/2017, 141/2017 sayılı Kararları ile, 15 Temmuz darbe teşebbüsü akabinde bu ülkeye kaçarak sığınma talebinde bulunan askerlerle ilgili olarak Türkiye’nin iade talebi reddedilmiştir.

Bu ret kararlarında, diğer bazı hususların yanı sıra, esas itibarıyla,

a) **Söz konusu darbe teşebbüsü sonrasında medya organlarında yer alan darbeci askerlere ilişkin görüntülerin, iadesi talep edilen kişilerin de iade edildikleri takdirde Türkiye’de işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılabilecekleri,**

b) **Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ölüm cezasının tekrar geri getirilmesi yönünde temadi eder mahiyette yapılan açıklamaların, idam cezasının geri getirilmesi halinde, bunun geçmişe etkili olabilecek şekilde uygulanabileceği,**

hususlarında **endişeyi** mucip olması, gerekçe olarak gösterilmiştir.

II. Söz konusu darbe teşebbüsü sebebiyle, TBMM'nin 21.7.2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı¹⁴⁴ ile onaylanan Bakanlar Kurulunun 20.7.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Kararı¹⁴⁵ ile “ülke genelinde 21.7.2016 Perşembe günü saat 01.00’den itibaren” **olağanüstü hal** ilan edilmiştir.

Bu olağanüstü hal ilanı üzerine, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu KHK’lerde, hukuki bakımdan sorunlu olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Hukuk Devleti” olma vasfını örseler mahiyette hükümlere yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu olağanüstü hal, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen “darbe” teşebbüsü sebebiyle ilan edilmiştir. Başka bir ifadeyle, söz konusu olağanüstü halin sebebinin, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen “darbe” teşebbüsü, bu teşebbüsün icrasına yönelik olan örgütlenme ve hazırlık çalışmaları oluşturmaktadır. Bu itibarla, söz konusu olağanüstü hal rejimi dolayısıyla çıkarılacak olan düzenleyici işlemlerin konusunun, olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylarla sınırlı olması gerekir.

Oysa söz konusu KHK’lerle getirilen hükümlerin önemli bir kısmı, 15 Temmuz 2016 tarihli suç olgusuyla ilgisi henüz kurulmamış, herhangi bir terör olayına ve sair bir suça bulaştığı şüphesine binaen 15 Temmuz günü akşamına kadar hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılmamış, disiplin soruşturması açılmamış, herhangi bir idari tedbire başvurulmamış olan kişilerin de **kamu görevinden ihraç edilmesine** kadar varan bir uygulamaya yol açmıştır.

Hatta söz konusu **KHK’lerle, özellikle mahkemelerin yerine geçilerek, suç oluşturan belirli bir olayın sübutuna, kişileri belirli bir haktan yoksun kılmaya ve hatta cezalandırmaya yönelik karar mahiyetinde düzenlemeler** yapılmıştır.

Söz konusu KHK’ler ile usulüne uygun olarak **savunma hakkı tanınmadan** kamu görevinden çıkarma gibi ağır sonuçları olan bir “yaptırım” uygulanması yolu açılmıştır¹⁴⁶.

¹⁴⁴ RG: 22 Temmuz 2016/29778.

¹⁴⁵ RG: 21 Temmuz 2016/29777.

¹⁴⁶ Olağanüstü hal KHK’leri ile, Türk “Hukuk”una yeni bir ceza türü kazandırılmıştır: **Ağaç kabuğu veya kökü yiyerek hayata tutunmaya mahkûmiyet cezası.**

Usulüne uygun olarak savunma hakkı tanınmadan yaptırım uygulaması, muhakkak surette iki sonuç ortaya çıkarır.

Birinci sonuç olarak, bu uygulama muhakkak surette ortaya mağduriyetler çıkarır. Ortaya mağduriyet çıkaran bir uygulama, mağdur edilenlerin sayısının az veya çok olması fark etmez, gayri meşrudur ve hiçbir sebeple mazur gösterilemez. Keza bu uygulama, kimin suçlu kimin mağdur edildiğinin bilahare devlet tarafından doğru bir şekilde tespiti de çoğu zaman imkansız kılar. Bu tespitin mümkün olduğu durumlarda, bazı mağduriyetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar kısmen giderilmiş olsa bile, mağdur edilen insanlar mağdur edilmemiş duruma irca edilemezler¹⁴⁷.

İkinci sonuç olarak, bu uygulama, gerçekten suç işlemiş olmaları sebebiyle kamu görevinden çıkarılmayı hak etmiş olan kişilerin bilahare “mağdur” edilmiş izlenimi oluşturacak şekilde ortada dolaşmasını sağlar. Böylece, bu kişilerin gerçekten işlemiş bulundukları suçların üzeri örtülür.

Söz konusu düzenleme ve uygulamaların kişiler bakımından ortaya çıkardığı, çıkaracağı mağduriyetler, olağanüstü hal rejimi bilahare sona erse bile, zaman geçtikçe daha da ağırlaşacak ve etkileri ilgililerle sınırlı olmaksızın bütün topluma sirayet ederek daha da hissedilir hale gelecektir.

Hemen belirtmemiz gerekir ki, bu değerlendirmemiz, hakkında karar alınan, işlem tesis edilen kişilerle ilgili bir tezkiye ifade etmemektedir.

Bu arada, 2.1.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen ve 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 685 sayılı KHK ile kamu

Bu ceza ile cezalandırılabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarında tanımlanmış herhangi bir suçun işlenmesi gerekmektedir.

Bu ceza ile cezalandırılabilmek için, kişi hakkında adli soruşturma yapılmasına ve kişinin usulüne uygun savunma yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Hatta, bu ceza ile cezalandırılabilmek için, yargı kararına da gerek bulunmamaktadır.

Bu cezanın belirli bir süresi de bulunmamaktadır.

Bu ceza ile cezalandırılmak, sadece hakkında karar verilen kişi bakımından sonuç doğurmamaktadır; bu kişinin iâşe ve ibatesini karşılamakla yükümlü olduğu bütün aile bireylerinin cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır.

¹⁴⁷ Belli bir “terör örgütü”ne yönelik olarak yürütülen operasyonlarda, haklarında herhangi bir somut suç şüphesine binaen henüz adli ve hatta idari soruşturma başlatılmamış olan kamu görevlilerinin, haklarındaki açığa alma veya kamu görevinden çıkarma işleminden haberdar olmaları üzerine verdikleri ani kararlar intihar ettiklerine dair haberler, herkesin malumdur.

Bu elim olaylar karşısında, söz konusu operasyonlarla ilgili politikaları belirleyen seçilmiş veya atanmış kamu görevlilerinin, başını iki elinin arasına alarak, nerede veya nerelerde yanlış yaptıklarının muhasebesini yapmaları gerekmektedir.

görevinden ihraç edilen kişilerin başvurularını değerlendirmek üzere bir komisyon ihdas edilmiştir. Ancak, ihdas edilen söz konusu Komisyonun, bu kişiler hakkında verilen ihraç kararlarını hangi hukuk kurallarını esas alarak ve hangi usule göre inceleyeceği henüz belli değildir.

Olağanüstü hal ilanı, kişiler hakkında sorgusuz sualsiz herhangi bir yaptırım uygulanmasının yolunu açmamaktadır. İnsanın en doğal hakkı, maruz kaldığı herhangi bir suçlama karşısında kendisini savunabilmesidir. Suç işlemiş olsa bile, işlediği suçun ağırlığı ne olursa olsun, hatta suçüstü halinde yakalanmış olsa bile, bu sebeple hakkında yaptırım uygulayabilmek için, kişiye savunma hakkını tanımak gerekir.

Bu hak kullandırılmadan verilen yaptırım kararları, kişi suçüstü halinde yakalanmış olsa bile, kaldırılmalıdır ve hakkında bu sebeple usulüne göre bir soruşturma süreci başlatılmalıdır.

685 s. KHK ile ihdas edilen Komisyonun böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu Komisyona başvuru imkanının tanınması, savunma hakkının kullanılmasının yerine ikame edilemez. Zira bu başvuru yolu, hakkında yaptırım kararı verildikten ve hatta uygulandıktan sonra kullanılabilecektir. Oysa savunma hakkının kişiye, hakkında henüz bir yaptırım kararı verilmeden önce kullandırılması gerekir.

Bu durum karşısında, eğer yargı doğru işleyecek olursa, **somut suçla ilişkilendirilmeyen ihraç kararlarının iptal edilmesi** mukadderdir^{148, 149}.

III. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bir oluşumun 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği “darbe” teşebbüsünün bir **örgüt faaliyeti** olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, olağanüstü hal KHK’lerinde ve hatta TBMM Genel Kurulunda alınan kararlarda¹⁵⁰ söz konusu örgütlenmenin mahiyetine ilişkin olarak ve

¹⁴⁸ Bu Komisyon, esas itibarıyla, söz konusu ihraçlarla ilgili olarak yargı yolunun işletilebilmesi için bir ön şartın sağlanması işlevini yerine getirecektir. Bunun dışında bu komisyondan bir beklenti içinde olmamak gerekir.

¹⁴⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, ilgili Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin ekini oluşturan, kamu görevinden ihraç edilen kişilere ilişkin listelerin iptali talebini reddetmiştir: Anayasa Mahkemesi, **24.6.2021** tarihli ve E. 2018/81, K. 2021/45 (RG: 26 Ocak 2022/31731).

¹⁵⁰ TBMM Genel Kurulunda alınan;

a) 26.7.2016 tarihli ve 1117 sayılı Karar (RG: 2 Ağustos 2016/29789).

hatta isimlendirilmesi yönünde yer verilen ifadeler, hukuken sorunludur. Bu tür nitelendirmelerin söz konusu darbe teşebbüsü bağlamında yapılmakta olan yargılamalarda mahkemeleri zora sokacağı endişesini taşımaktayız¹⁵¹.

Çünkü somut suçlarla ilişkilendirilmeksizin, somut suçlara ilişkin yargı kararları henüz ortaya çıkmadan, düzenleyici işlemlerle terör örgütünün belirlenmesi, bu terör örgütünün ne zamandan beri mevcut olduğu konusunda bir belirsizliği beraberinde getirmiştir.

Oysa suç ve terör örgütünün varlığına ancak işlendiği sabit olan somut suçlardan hareketle karar verilmelidir ve bu kararın da bir ceza mahkemesi tarafından verilmesi gerekir.

Her bir somut suçun işleniş bağlamında bir suç örgütünün varlığına ve işlenen suçun bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiğine mahkemenin karar vermesi gerekir. Aksi takdirde, yani somut suçlardan bağımsız şekilde bir suç veya terör örgütünün varlığının kabul edilmesi halinde, bu örgütün ne zamandan itibaren varlığının kabul edileceği, bu örgütsel yapı ile ilişki içinde bulunan kişilerin suç işleyip işlemediği sorunları ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır.

Nitekim bu sebeptendir ki, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün akabinde ilan edilen olağanüstü hal sürecinde, düzenleyici işlemlerle “terör örgütü” olduğu kabul edilen örgütsel yapı ile herhangi bir şekilde irtibatı bulunan kişiler, kendilerine herhangi bir somut suç isnat edilmediği halde, “terör örgütü üyesi” olarak tutuklanmışlardır. Bu tutuklananlar arasında çok sayıda **yüksek mahkeme üyesinin** yanı sıra **vali** ve **müsteşar** gibi bürokratin bulunması düşündürücüdür^{152,153}.

b) 19.8.2016 tarihli ve 1127 sayılı Karar (RG: 7 Ekim 2016/29850).

¹⁵¹ Keza, henüz soruşturması devam etmekte olan bir suç olgusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırılmasına yönelik olarak komisyon teşkili, bu komisyon tarafından icra edilen/edilecek olan araştırma faaliyetleri ve düzenlenecek olan rapor, söz konusu darbe teşebbüsü sebebiyle başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar bakımından büyük sakıncalar ortaya çıkaracaktır.

¹⁵² Sayın **Cumhurbaşkanına** arzettiğim 25.9.2016 tarihli **Bilgi Notunda** şu açıklama ve değerlendirmelere yer vermiş bulunmaktayım:

15 Temmuz “darbe teşebbüsü”ne iştirak etmesi hali saklı kalmak kaydıyla, devlette müsteşar, vali gibi görevlerde bulunmuş olan bir kişi, görevi bağlamında dahli bulunduğu iş ve işlemler dolayısıyla, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçla, terör örgütü üyeliğiyle ve hatta terör örgütü yöneticiliğiyle asla itham edilemez.

Bir vali veya müsteşarın, terör örgütü üyeliğiyle suçlanarak tutuklanmasına karar verilmesi, Türkiye’deki kadim **yargı bağımsızlığı sorununun** bir tezahürüdür. Dün, Türkiye Cumhuri-

IV. Bu süreçte başlatılan soruşturmalarda gözaltına alınan veya tutuklanan bazı kişilerin “itirafçı” oldukları gerekçesiyle, serbest bırakıldıklarını görürüz veya duyuyoruz.

Bu kişiler “itiraf” olarak, öğrenim gördüğü sırada ilişki içinde bulundukları çevrelere, özellikle **kamuda görev alma sürecine, görevde yükselme sürecine, bu süreçlerde kendilerine referans olan kişilere ilişkin bilgiler** vermektedirler.

Bu kişilerin suç işleyip işlemediği ve dolayısıyla, suçlu oldukları henüz yargı kararı ile tespit edilmiş değildir. Ancak bu kişiler, bugün itibarıyla, en

yeti devletinde genelkurmay başkanı olarak görev yapmış olan bir kişinin terör örgütü yöneticiliğiyle itham edilmesi ve hakkında verilen tutuklama kararında suçun icrasına başlama tarihinin kişinin genelkurmay başkanlığı görevine atama tarihi, bitiş tarihinin de genelkurmay başkanlığından emekliye ayrılma tarihi olarak gösterilmesi, nasıl bir akıl tutulması idiye; bugün bir müsteşarın, valinin terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanması da aynı **akıl tutulmasının** bir devamıdır.

Bu akıl tutulmasının devamının, gelecekte iki şekilde tezahürü mümkün olabilir.

Birinci ihtimal olarak, dün genelkurmay başkanını terör örgütü yönetmek suçlamasıyla tutuklayanların bugün uğradığı akıbetin, bir müsteşarın, valinin terör örgütü üyeliğiyle suçlanarak tutuklanmasına karar verenlerin de başına gelmesi mukadder olabilir.

İkinci ihtimal olarak, bugün bir müsteşarı, valiyi terör örgütü üyeliğiyle suçlayarak tutuklanmasına karar verenlerin, yarın bunları atayan hükümet üyelerini de terör örgütü yönetmekle suçlayarak haklarında işlem tesis etme cesaretini elde edebilecekleri bir ortama sürüklenmiş olabiliriz.

Sözü edilen kamu görevlileri, görevleriyle bağlantılı olsun veya olmasın, herhangi bir suç işleyebilirler, bu sebeple haklarında soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilir. Ancak, bu görevlere atanmış olan kişilerin terör örgütü yöneticiliği veya üyeliğiyle suçlanması, hukuken kabul edilebilir bir durum değildir. Yukarıda da belirttiğim gibi, bunun tek istisnası, kısaca “darbe teşebbüsü” olarak ifade edilen suçların işlenmesine iştirak olabilir.

Görebildiğimiz kadarıyla, haklarında verilen tutuklama kararlarında bu müsteşar ve valilere 15 Temmuz günü yaşanan “darbe teşebbüsü”ne iştirak yönünde bir isnatta bulunulmamıştır.

Bu durum karşısında çağrım, bir an önce hukuka geri dönülmesidir. Hukuka geri dönülmediği takdirde, toplum olarak maruz kaldığımız meteor yağmurundan herhangi bir kimsenin etkilenmemesi mümkün olmayacaktır.

¹⁵³ **Adalet Bakanlığı** Eski Müsteşarının şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet savcılarına vermiş bulunduğu ifade, medya organlarına sızdırılmıştır. Bu suretle, soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiştir (TCK, m. 285).

Daha vahim nokta şudur: Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmış bir kişi, bu görevi bağlamında dahli olduğu iş ve işlemler dolayısıyla “**silahlı terör örgütü yöneticiliği**” ile suçlanmaktadır.

Hatta daha da önemlisi: Söz konusu Müsteşarın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, “*mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre*” görev yapması gereken (Any, m. 159, f. 1) HS(Y)K’nın Yargıtay üyeliğine yaptığı seçimde belirlenen adaylarla ilgili olarak **Başbakan**dan “**icazet**” alındığı yönünde açıklama yer almaktadır.

Bu açıklamalar, söz konusu soruşturmaların nerelere uzanacağı konusunda ipuçları vermektedir.

azından “**terör örgütü üyesi** olmak” suçundan dolayı şüpheli veya sanık konumundadır.

Bu kişilerden “itiraf” çerçevesinde alınan bilgiler somut bir suç vakıasına ilişkin olmadığı takdirde, bu “itiraf”ların TCK, m. 221 hükümleri çerçevesinde etkin pişmanlık olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu suretle, tahliye beklentisiyle, tutuklu kişilerle “**at pazarlığı**” yapılmaktadır. Gördüğümüz kadarıyla, kişilerden tahliye beklentisiyle alınan bilgiler, bir suç olgusuna ilişkin bulunmamaktadır. Aksine, bu “itiraf”ların, Türkiye’de halen hükümet eden siyasilere bürokratlarının, yarın “terör örgütüne yardım ve yataklık etme” suçundan sorgulanmaları ve yargılanmaları sonucunu doğuracak mahiyet taşıdığını söylemek yanlış olmaz^{154,155,156}. Zira kişilerin öğrencilik döneminden

¹⁵⁴ Türkiye’de, malum “cemaat” yapılanması ile “irtibatlı” ve “iltisaklı” olduğu iddialarına dayalı olarak bir tezvirat süreci yaşanmaktadır.

Soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan kamu görevlileri de “itiraf” senaryolarıyla bu sürece önemli destek vermektedirler. Öyle ki bu senaryolar, dönüp dolaşıp, destek veren kamu görevlilerini de etkilemeye başlamıştır.

Bu senaryolar sebebiyle kamu kurumlarındaki çalışma barışının ve verimliliğinin de olumsuz yönde önemli ölçüde etkilendiği malumdur.

Türkiye, Nazi Almanyasında, Alman toplumunun yaşadığı tezviratın acı tecrübelerinden ders almamışa benzemektedir.

¹⁵⁵ Türkiye’de, malum “cemaat” yapılanması ile “irtibatlı” ve “iltisaklı” olduğu iddialarına dayalı olarak yaşanan tezvirat sürecinin “meşrulaştırılması” işini yargı mensupları üstlenmiştir.

Bu sürecin “meşrulaştırılmasına yönelik ilk adım, Anayasa Mahkemesi atmıştır:

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4.8.2016 tarihli ve E. 2016/6 [Değişik İşler], K. 2016/12 sayılı Kararı, bu sürecin yolunu açan ilk adım olmuştur. Yüksek mahkemenin iki üyesinin görevden ihracına ilişkin söz konusu kararda gerekçeler arasında “**sosyal çevre bilgisi**”ne yer verilmiştir. Her ne kadar söz konusu karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca alınmış ise de, mahiyeti itibarıyla idari bir karardır; yargı kararı değildir. Zira bu özelliği sebebiyledir ki, söz konusu Karar, Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.

Keza **Hakimler ve Savcılar** (Yüksek) **Kurulu** Genel Kurulunun verdiği muhtelif kararlarla da bu uygulama “meşruiyet” zemini bulmuş görüntüsü kazanmıştır:

HSYK Genel Kurulunun 24.8.2016 tarihli ve 2016/426 sayılı kararı (RG: 25 ağustos 2016/29812).

HSYK Genel Kurulunun 13.2.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı kararı (RG: 21 şubat 2017/29986).

HSYK Genel Kurulunun 17.3.2017 tarihli ve 2017/113 sayılı kararı (RG: 18 mart 2017/30011).

HSYK Genel Kurulunun 3.4.2017 tarihli ve 2017/665 sayılı kararı (RG: 4 nisan 2017/30028).

HSYK Genel Kurulunun 5.5.2017 tarihli ve 2017/682 sayılı kararı (RG: 6 mayıs 2017/30058).

İzahat kısmı itibarıyla birbirinin aynısı olan söz konusu kararlarda görevden ihraç edilen hakim ve savcıların ihraç “gerekçeleri” arasında yer verilen “**sosyal çevre bilgileri**” ibaresiyle başlayan açıklamalar, bu süreci “meşrulaştırma” gayretinin bir yansımasıdır.

itibaren ilişki içinde bulunduğu çevrelere, kamu görevine atamalarında referans olmuş bürokratların ve hatta siyasilerin isimlerine kadar bilgiler, ifade ve hatta tutuklama/tahliye tutanaklarına dercedilmektedir.

Yolun neresinde olunursa olunsun, yanlıştan dönmek, erdemliliklerdir. Hukuk uygulamamızı çıkmış olduğu rayına oturtmak, hepimizin ivedi görevidir.

V. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan olarak görev yapan bir hakim, kolluk görevlileri tarafından duruşma sırasında yakalama işlemine tabi tutulmuş ve gözaltına alınmıştır. Bu işlemle, kamu gücü kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen hukuk ihlalleri bakımından tuzun koktuğu noktaya varmış bulunmaktayız. Bir hakim hakkında, göreviyle bağlantılı olsun veya olmasın, işlediğinden şüphelenilen bir suç sebebiyle soruşturma yapılabilir. Ancak, suçüstü (meşhut suç) hali hariç olmak üzere, bir hakim hakkında duruşma yaptığı sırada yakalama işlemi yapılamaz. Duruşma sırasında Mahkeme Başkanı hakkında yakalama işleminin yapılması, bu işlemle hukukun dışında başka bir amacın güdüldüğünü ortaya koymaktadır.

Belirli bir kamu görevi ifa eden kişinin, özellikle hakim ve savcılarının terör örgütü üyeliğiyle suçlanabilmesi için, bu suçlamanın somut bir suç vakıası ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bir kamu görevlisinin, somut bir suç vakıası ile ilişkilendirilmeden, soyut bir şekilde terör örgütü üyeliği veya yöneticiliğiyle suçlanması, bununla hukuk dışında başka bir amacın güdüldüğünü gösterir.

Bir kişinin mobil telefon cihazında veya bilgisayarında, özel bir iletişim ağına dahil olduğuna dair bir program bulunabilir. Bu özel iletişim ağını sadece belirli kişilerin kullanabilmesi ve bu ağa girebilmek için ağ kullanan bir veya birkaç kişinin referansına gerek bulunması, başlı başına suç oluşturmaz. Ancak, bu iletişim ağının suç işlemek amacıyla oluşturulmuş ve münhasıran bir suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağ olduğunun somut delillere dayanması halinde, bu ağa dahil olan kişiye

¹⁵⁶ “FETÖ”, bir örgütsel yapıya belli bir kişiyle ilişkilendirilerek **Devlet marifetiyle (!) verilen** bir **addir**. Bunun teknik hukuk bakımından doğruluğu, tartışılabilir bir durumdur.

Ancak bu isim, bugün bir suç örgütüyle hatta herhangi bir suçla ilişkilendirilmeyi gerektirmeden, kişilerin menfi anlamda yaftalanma aracına dönüşmüştür.

Beğenilmeyen, hoş gitmeyen düşünceleri açıklayan, kamu gücünü kullananları eleştiren herkesin, “cadı” ilan edilerek, “engizisyon” usulü yargılamaya bile gerek olmadan, yargısız olarak mahkûm edilebildiği bir manzara ile karşı karşıyayız.

Bu manzara bize, orta çağ Avrupası uygulamalarını hatırlatmaktadır.

“şüpheli” sıfatının izafe edilmesinde herhangi bir sorun yoktur. Bunun için, ağa dahil olan kişinin, ağ içinde başka bir kişiyle görüşme yapmış olması da gerekmez. Kişiye belli bir suçla bağlantılı olarak “şüpheli” sıfatının izafe edilmesi, bu nedenle hakkında yakalama, gözaltına alma ve tutuklama gibi tedbirlerin uygulanmasını zorunlu kılmaz.

Kişinin, suç işlemek amacıyla oluşturulmuş ve münhasıran bir suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağa bu özelliğini bilerek (kasten) dahil olması ve hatta bu ağı iletişim için kullanması, iletişim içerikleri tespit edilemese bile, hakkında en azından bu suç örgütüne üye olmaktan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulması için yeterli kabul edilmelidir.

Önemle belirtmem gerekir ki, bu açıklamalar, herhangi bir özel iletişim programı ile ilgili değildir. Bu açıklamalar, belirtilen koşullar çerçevesinde özel bir iletişim ağına dahil olmanın ceza sorumluluğunu gerektirip gerektirmediğini belirleme amacını taşımaktadır¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Son zamanlarda düzenlenen iddianameler incelendiğinde görülmektedir ki; kişiler hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasında bulunulurken, dayanak olarak, “ByLock” programının telefonunda kayıtlı olması ve bu program üzerinden kişilerle iletişim kurması gösterilmektedir.

Bu çerçevede doğru ve adil bir karar verebilmek için, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla yönelik olarak;

- a) Kişinin hangi tarih itibarıyla “Bylock” programını **kullanmaya** başladığının,
- b) Kişinin bu program üzerinden kimlerle, ne zaman ve hangi zaman aralığında iletişime geçtiğinin,
- c) Söz konusu iletişimlerden hangilerinin **yazılı** olarak yapıldığının ve bunların **içeriklerinin**, tespit edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu “ByLock” programına, bu program üzerinden yapılan iletişimlerin içeriğine ilişkin tespit ve değerlendirmeler için bkz. aşağıda “Ekskurs 10” altında yapılan açıklamalar.

EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

I. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre, “Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır” (m. 15, f. 1).

II. 6.11.1997 tarihinde Strazburg’da kabul edilen Avrupa Konseyi “Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi”, 8 Nisan 2015 tarihi itibarıyla Türkiye tarafından imzalanmış değildir.

Söz konusu Sözleşmeye göre, “Yabancı askeri kuvvetlerin hizmetinde gönüllü olarak bulunmak” (m. 7, paragraf 1, bent c) veya “Taraf Devletin önemli menfaatlerine ciddi surette zarar veren fiillerde bulunmak” (m. 7, paragraf 1, bent d), vatandaşlığın kaybı sebebi oluşturabilir. Ancak bu sebeplerle kişinin vatandaşlıktan çıkarılabilmesi için, vatansız kalmaması gerekir. Aksi takdirde vatandaşlığın kaybedilmesine yönelik işlem tesis edilemez (Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, m. 7, paragraf 3). Çünkü “herkes vatandaşlık hakkına sahiptir” (Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, m. 4, bent a) ve “vatansızlıktan kaçınılmalıdır” (Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, m. 4, bent b). Başka bir ifadeyle, söz konusu Sözleşmenin güttüğü amaçlardan biri, vatansızlığın önlenmesidir. Keza, bu sebeplerle kişinin vatandaşlığı kaybetmesi, çocuklar üzerinde etkili olmamaktadır (Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, m. 7, paragraf 2).

Taraf devletler, Sözleşmede sayılan, kanun hükmü icabı veya yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kaybı sebeplerini milli hukuklarında genişletme yasağını kabul etmişlerdir (Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, m. 7, paragraf 1).

III. 1982 Anayasasına göre; “Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.” (m. 66, f. 4). Keza, “Vatandaşlık, ... ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.” (m. 66, f. 4). Bu düzenlemeye göre, ancak kanunda belirtilen sebeplerle vatandaşlığın kaybı yönünde karar alınabilir ve vatandaşlık kaybedilebilir.

IV. 29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığını kaybettirme” başlıklı 29. maddesine göre;

“(1) Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaybettirilebilir.

a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından

bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.

b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Cumhurbaşkanının izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.

c) İzin olmaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.”

Her ne kadar **Türkiye** yukarıda hükümleri açıklanan **Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesini** henüz **imzalamamış** ise de; Avrupa Konseyi üyesi olması ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini henüz tamamlamamış bulunması sebebiyle, yapacağı **kanuni düzenlemelerde söz konusu Sözleşme hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini** düşünmekteyim.

Buna göre, idari işlemle (Cumhurbaşkanı Kararı ile) **vatandaşlığın kaybettirilmesi halinde şayet kişi vatansız kalacaksa, bu yönde karar alınması gerekir.**

Ayrıca belirtmek gerekir ki, **kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının suçla ve suçlulukla mücadele bakımından hiçbir olumlu katkısı bulunmamaktadır.** Aksine, özellikle terör suçları ile suçlananlarla bağlantılı olarak Devletin uluslararası alanda çok daha zor durumlara maruz bırakılması sonucunu doğurur.

V. Terör suçları bağlamında Türkiye’de gündeme getirilen vatandaşlığın kaybettirilmesi/vatandaşlıktan çıkarma sorunu ile ilgili olarak, konunun Fransa’da da tartışıldığı ve orada konunun kabul gördüğü yönündeki gelişmeler olduğu ifade edilmektedir.

Öncelikle belirtmem gerekir ki, Fransa, “*Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi*”ni henüz onaylamamıştır.

Keza, Fransa’da vatandaşlıktan çıkarılması düşünülen kişiler bilahare Fransız vatandaşlığını iktisap etmiş olan kişilerdir. Bu kişiler, çoğunlukla Kuzey Afrika kökenli olup, dini mensubiyeti itibarıyla “Müslüman” olarak bilinen kişilerdir. Başka bir ifadeyle, bu kişiler Fransa vatandaşlığını taşımakla birlikte milliyeti itibarıyla Fransız sayılmayan kişilerdir.

Fransa’da yapılan tartışmayı kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Türkiye’deki koşullar ile Fransa’daki koşulların birbirinden çok farklı olduğu izahtan varestedir.

VI. Ancak, bu arada 2.1.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen ve 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı KHK ile (m. 75), 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir:

*“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle **hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşamayan vatandaşlar**, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça Resmî Gazetede yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla **kaybettirilebilir.**”*

Bu düzenlemenin suçla ve suçlulukla mücadele bakımından olumlu yönde herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Aksine, bu tür düzenlemeler, hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan kişilerin bulundukları yabancı ülke devletleri nezdinde daha fazla himaye görmelerini sağlayan bir etki meydana getirmektedir.

EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ

Soruşturma konusu suçla ilgili olarak bir **delil elde etme yöntemi** olan “*şirket yönetimi için kayyım tayini*” koruma tedbiri olarak elkoymanın özel bir türüdür.

Bu koruma tedbirine başvurabilmek için **icrası halen devam etmekte olan** bir **suçun** varlığı gereklidir. Bu itibarla, icrası tamamlanmış olan bir suçla ilgili olarak bu koruma tedbirine başvurulamaz. Bu yönü itibarıyla söz konusu koruma tedbiri, bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda **kuvvetli şüphe sebepleri** bulunan **kesintisiz (mütemadi) suçlarla** ilgili olarak veya **bir suçun müteselsilen, zincirleme bir şekilde işlenmesi** halinde uygulanabilir.

Bu çerçevede örneğin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin (karaparanın) aklanması suçu bağlamında şirket yönetimine kayyım tayin edilebilir. Söz konusu suç, **müteselsilen** işlenebileceği gibi, **kesintisiz suç** şeklinde de işlenebilir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen kazancın, yabancı sermayeyi teşvik mevzuatının sağladığı kolaylıklardan yararlanılarak her defasında yabancı sermaye olarak ülkeye girişinin sağlanması, söz konusu suçun müteselsilen işlenmesine örnek gösterilebilir. Keza, suçtan elde edilmiş olan bir kazancın, belirli bir taşınmazla ilgili olarak düzenlenen göstermelik kira sözleşmesine istinaden tahsil edilen kira geliri olarak gösterilmesi, 282. maddede tanımlanan suçun temadi eder şekilde (kesintisiz suç olarak) işlenmesine örnek olarak gösterilebilir.

İkinci bir örnek olarak, terörizmin finansmanı suçu gösterilebilir. Meşru bir kaynaktan elde edilmiş olsun veya olmasın, şirket kaynaklarının belirli terör faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullanılması halinde, zincirleme suç ve hatta kesintisiz suç söz konusudur. Bu gibi durumlarda, işlenmekte olan söz konusu suça ilişkin delil elde etmek ve suçun işlenmesinin önüne geçmek amacıyla şirket yönetimine kayyım tayin edilebilir.

Ticari hayat ve mülkiyet hakkı üzerindeki ağır etkileri dolayısıyla, Kanun koyucu **ancak belirli ağırlıktaki suçlarla ilgili olarak** bu koruma tedbirinin uygulanmasına izin vermiştir (CMK, m. 133, f. 4). Sınırlı sayıdaki bu suçların dışında başka bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla şirket yönetimine kayyım tayin edilemez.

Keza, bu koruma tedbiri, sayılan suçlardan birinin bir şirket faaliyeti çerçevesinde icrasına devam edildiği hususunda ancak kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması halinde uygulanabilir.

Söz konusu koruma tedbirinin uygulanmasıyla, **şirketin faaliyetleri içeriden denetlenecek ve soruşturma konusu suçun icrasına ilişkin delil elde edilecektir.**

CMK'nın 133. maddesi hükümleri karşısında, kayyım tayini bağlamında **iki yöntem** izlenebilir.

Birinci yöntem olarak, şirketin mevcut yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği için onay vermek üzere kayyım tayin edilebilir. Bu durumda şirketin iş ve işlemleri daha önce usulüne göre görevlendirilmiş olan ve halen görevine devam eden yönetim kurulu, genel müdür, müdür ve sair öneticiler tarafından takip edilir. Ancak bu kişilerin yaptığı iş ve işlemlerin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için atanan kayyımın onayından geçmesi şarttır. Bu suretle, ekonomik faaliyet icrası bağlamında şirketin iç işleyişine karışılmamakta; ancak getirilen onay sistemiyle, şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunan suçla ilgili delillerin toplanması sağlanmaktadır.

İkinci yöntem olarak, şirketin mevcut yönetim organı yerine kaim olacak şekilde kayyım tayinidir. Bu durumda mesela anonim şirketin mevcut yönetim kurulu, limited şirketin mevcut müdürünün görevi sona ermektedir. Bu durumda görevlendirilen kayyım, **soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde** şirketin iş ve işlemlerine müdahale edebilir. Bu durumda her ne kadar yönetim organının tüm yetkileri kayıma devredilmekte ise de, kayyım, şirketin ticari faaliyetini, şirketin üretim ve ticaret politikalarını olumsuz olarak etkileyebilecek tasarruflarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Aksi takdirde, yani yönetimini üstlendiği şirketin zararına sebebiyet vermesi halinde, kayyımın, bu zarar sebebiyle şirket ortaklarına karşı genel hükümlere göre sorumluluğu yoluna gidilebilir.

Önemle vurgulamak gerekir ki, bu durumda da **kayyımın asıl görevi şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunan muayyen suçla/suçlarla ilgili delilleri toplamak ve suçun işlenmesini önlemektir.**

Delillerin toplanmasının tamamlanması veya delile ulaşılabilmesi halinde, kayyımın görevinin derhal sona erdirilmesi gerekir. Her ne kadar kanunda bu hususta muayyen bir süre öngörülmemiş ise de, kayyım tayinine gerek gören Cumhuriyet savcısı, sözü edilen durumların ortaya çıkması halinde, kayyımın görevini derhal sonlandırmalıdır. Delile ulaşılabilmesine rağmen, kayyım marifetiyle şirketin yönetimine devam edilmesi, haksız elkoymanın hukuki sonuçlarını doğurur.

Bir suç soruşturması bağlamında şirket yönetimine tayin edilen kayyımın şirket ortaklarının ortaklık paylarıyla ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisi mevcut değildir. Ancak, kayyım, yönetimine atandığı şirketin ortağı olduğu başka bir şirketteki ortaklık payı ve bu payla ilgili örneğin temettü üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesinin birinci fıkrasında 1.7.2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunla yapılan değişikliği bu çerçevede anlamak gerekir. Bu itibarla, şirket yönetimine tayin edilen **kayyım, şirket ortaklarının payları üzerinde satış ve sair surette tasarrufta bulunamaz**. Keza, şirket yönetimine tayin edilen **kayyım, bu şirketin tasfiyesine yönelik olarak herhangi bir tasarrufta bulunamaz**. Ancak kayyım, yönetimine tayin edildiği şirketin ortağı olduğu diğer bir şirketin tasfiyesi bağlamında ortaklık ilişkisinden ve temsil yetkisinden hareketle tasarrufta bulunabilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun 15.8.2016 tarihli toplantısında kabul edilen 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede¹⁵⁸ ve bu KHK'yı kanunlaştıran 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunda¹⁵⁹, “*terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle*” CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır (m. 19, f. 1). Keza, “*olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanununun 133'üncü maddesi uyarınca şirketlere ... kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır.*” (m. 19, f. 2). Bu suretle gerçek kişilerin kayyım olarak atanmasına hukuk sistemimizde bir istisna getirilmiştir. CMK, m. 133 hükmüne göre ancak gerçek kişiler kayyım olarak atanabilirken, söz konusu düzenlemeyle bir kurumun da kayyım olarak atanmasının yolu açılmıştır. Bu suretle TMSF, kayyım olarak atandığı şirketlerin yöneticilerini belirleme ve atama yetkisini iktisap etmiş bulunmaktadır.

Hatta, 674 sayılı KHK ve bu KHK'yı kanunlaştıran 6758 sayılı Kanunla CMK, m. 128'e eklenen onuncu fıkra ile, bu madde hükümlerine göre, elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların yönetimi amacıyla kayyım atanmasının da yolu açılmıştır (m. 13).

¹⁵⁸ RG: 1 Eylül 2016 / 29818 2.Mükerrer.

¹⁵⁹ RG: 24 Kasım 2016-29898.

Dikkat edilmelidir ki, CMK, m. 128 hükmü, ancak bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla “elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde” bir malvarlığı değerine elkoymaya imkan tanımaktadır (f. 1). Bu itibarla, **128. madde hükmü, isnat edilen suç ne olursa olsun, bir suçun işlenmesiyle herhangi bir ilgisi bulunmayan malvarlığı değerine elkoymaya asla izin vermemektedir.** Her ne kadar maddenin ikinci fıkrasında 2.12.2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunla (m. 41) yapılan değişiklikle TCK, m. 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316’da tanımlanan “*Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar*”la ilgili olarak söz konusu madde hükümlerinin uygulanmasının yolu açılmış ise de; **bu hükmü sadece söz konusu suçlardan birinin işlenmesi suretiyle veya işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan malvarlığı değerleri ile sınırlı olarak uygulamak mümkündür.** Bu itibarla, örneğin terör örgütlerinin “*faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi*”nin (TCK, m. 315) bu faaliyetleriyle bağlantılı olarak elde ettiği malvarlığı değerlerine CMK, m. 128 hükümlerine göre elkonulabilecektir.

Önemle işaret etmek gereki ki, 674 sayılı KHK ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6758 sayılı Kanunla, TMSF bu “**şirketin yahut varlıklarının ... satılmasına, feshi ile tasfiyesine karar**” verme yetkisi ile donatılmıştır (m. 20). Bu suretle, “*terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle*” yönetimine kayyım atanan şirketler bağlamında TMSF’ye, şirket ortaklarının ortaklık payları ile ilgili olarak da tasarruflarda bulunma yetkisi verilmiştir.

CMK, m. 128 hükümlerine göre taşınmaz, hak ve alacaklara elkonulması, ekonomik değerinin muhafazasının yanı sıra, bunların elden çıkarılmasının ve bilahare TCK’nın kazanç müsadereesine ilişkin hükümleri (m. 55) çerçevesinde müsadere edilebilmesi gerektiğinde müsaderenin akim kalmasının önüne geçmek amacına hizmet etmektedir. Ancak 674 sayılı KHK ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6758 sayılı Kanun, bu amaç dışında şirket ortaklık payları ve sair malvarlığı değerleri üzerinde TMSF’ye tasarruflarda bulunma yetkisi vermektedir.

674 sayılı KHK ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6758 sayılı Kanunun 13, 19 ve 20. maddeleri hükümleri ile, CMK’nın 128. maddesi kapsamına girmesi sebebiyle elkonulan ve yönetimi için kayyım tayin edilen bu malvarlığı değerleriyle ilgili olarak TMSF’ye **henüz müsadere hükmü kurulmadan satış ve tasfiye gibi tasarruflarda bulunma yetkisi açıkça verilmiştir.**

Ancak bu satış ve tasfiye, sadece elkonulan malvarlığı değerinin muhafazasının güçlüğü, gün geçtikçe ekonomik değerinin azalması, borçlarının, giderlerinin ve zararlarının artması sebeplerinden birine binaen olabilir.

Bu satış ve tasfiye sonucunda “elde edilecek tutarlar **yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar** bir hesapta nemalandırılır.” (674 sayılı KHK ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6758 sayılı Kanun, m. 20, f. 1, son cümle). Bu hesabın, şüpheli veya sanık adına açılmış bir hesap olması gerekir. Nitekim, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun 2.1.2017 tarihli toplantısında kabul edilen 687 sayılı “**Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname**”nin “**Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve varlıklar**” başlıklı 1. maddesinde, şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır¹⁶⁰:

“4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilip 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19’uncu maddesine göre kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun İkinci Bölümü kapsamına giren suçlardan dolayı **müsaderesine karar verilmesi halinde** müsadere kararı; bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilir. **Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilir.**”

687 sayılı KHK’nin bu düzenlemesi karşısında, TMSF, yönetimine kayyım olarak atandığı şirketlerin, ortaklık paylarının ve sair malvarlığı değerlerinin

¹⁶⁰ RG: 9 Şubat 2017 / 29974

üzerinde alehltlak tasarruf yetkisini haiz değildir. Bu itibarla **TMSF bir şirketin tasfiyesine, ancak borçlarının veya giderlerinin fazlalığı yüzünden, devamı ekonomik bir getiri sağlamaktan ziyade, malvarlığının azalması sonucunu doğurduğu takdirde, bu durumun somut dayanak noktalarını göstererek, karar verebilir.**

Önemle belirtmek gerekir ki, **bu düzenlemeler, CMK, m. 128 hükümlerine göre elkonulmuş olan şirket ortaklık paylarının satışına, kesinleşmiş müsadere hükmüne kadar, hiçbir surette izin vermemektedir.**

EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İlk Derece Mahkemesi olarak yaptığı yargılama sonucunda vermiş bulunduğu **24.4.2017** tarihli ve E. 2015/3, K. 2017/3 sayılı Kararı ile, İstanbul’da asliye ceza mahkemelerinde hakim olarak görev yapan iki sanığın;

- görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini,
- bu suçu “FETÖ/PDY” olarak isimlendirilen “örgütün amaçları ve liderinin talimatı doğrultusunda karar vererek” işlediklerini,

ve dolayısıyla,

- terör örgütüne üye olmak suçunu işlediklerini,

kabul etmiştir.

Karara konu teşkil eden olayda, çok sayıda şüpheli ile ilgili olarak İstanbul sulh ceza hakimliklerinde görev yapan hakimler tarafından verilen muhtelif tutuklama kararlarına itiraz edilmiştir. Mevzuata göre bu itirazların bir diğer sulh ceza hakimi tarafından değerlendirilip karara bağlanması gereği karşısında, tutuklu şüphelilerin avukatları tarafından İstanbul sulh ceza hakimliklerinde görev yapan bütün hakimlerin reddi talep edilmiştir.

Bunun üzerine, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim olarak görev yapan M. Özçelik, mevzuattaki reddi hakim talebinin incelenmesine ilişkin usul hükümlerine aykırı olarak, bu reddi hakim taleplerini kabul etmiş ve tutuklama kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak üzere, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi M. Başer’in görevlendirilmesine karar vermiştir. Bu görevlendirme kararı üzerine, hakim M. Başer, ilgili soruşturma dosyalarını incelemeden vaki itirazların kabulüne ve tutuklu bulunan çok sayıda şüphelinin tahliyesine karar vermiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu suretle her iki hakimin de görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini kabul etmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ayrıca, sanık hakimlerin “silahlı” terör örgütü üyesi olduklarını ve söz konusu görevi kötüye kullanma suçunu, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediklerini kabul etmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, söz konusu örgütsel yapının, yargılama konusu fiillerin işlendiği tarih itibarıyla bir “*silahlı terör örgütü*” olduğu sonucuna,

“ByLock” iletişim programıyla yapılan yazılı haberleşme içeriklerini göz önünde bulundurarak varmaktadır.

Daire kararındaki ifadeye göre, sanık hakimler, *“örgütsel mensubiyetleri nedeniyle, örgüt liderinin talimatı üzerine harekete geçerek, örgütün amacı doğrultusunda, örgütsel bir güç gösterisi anlamına gelen, sözde hukuku kullanarak tutuklu diğer örgüt mensuplarını himaye etme adına mevcut hukuk düzenine başkaldırı mahiyetindeki tamamen kötü niyetli hukuka aykırı usul ve üslupla”* karar vermek suretiyle, görevlerini kötüye kullanmışlardır (Gerekçeli Karar, sh. 130).

Daire kararındaki diğer bir ifadeye göre; *“kamu düzenine ilişkin görevle ilgili kuralları görmezden gelip yargılama hukukuna ilişkin işleyiş ve düzeni yok sayarak, “mahkemeler üstü” bir tavırla örgüt liderinin talimatı üzerine kurgulandığında şüphe bulunmayan plan doğrultusunda tam bir örgütsel organizasyon, gizlilik ve adanmışlık hali içerisinde, fül ve eylem birliği ile, aynı örgüt mensubu olmaktan soruşturulan altmışüç şüpheli ile ilgili hakimnin reddi ve tahliye taleplerini, mutad işleyiş ve uygulama dışına çıkıp, mesai saati dışında, verilecek kararlarla ilgili denetim mekanizmalarını bertaraf edecek, olayı bir oldu bitti fırsatçılığı içerisinde sonuçlandıracak bir gizlilikle ve eşgüdümle hareket ederek görevli olmadıkları halde kabul eden sanıkların, karar verme süreci ile ilgili hukuka aykırı eylemleriyle görevlerinin gereklerine aykırı davrandıklarında şüphe yoktur.”* (Gerekçeli Karar, sh. 129).

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık hakimlerin *“FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları”*nı kabul etmiştir (Gerekçeli Karar, sh. 114, 119).

Keza Daire kararına göre, *“sanıkların, örgüt liderinin talimatı üzerine örgütün amacı doğrultusunda ve örgüt faaliyeti kapsamında, tam bir örgütsel organizasyon ve gizlilik içerisinde, aynı örgüt mensubu oldukları ve örgüt faaliyeti kapsamında bazı suçları işledikleri iddiasıyla yedi faklı soruşturma dosyasında soruşturulan, altmışüç şüpheli ile ilgili hakimnin reddi ve tahliye taleplerini, mutad işleyiş ve uygulama dışına çıkıp, mesai saati dışında, verilecek kararlarla ilgili denetim mekanizmalarını bertaraf edecek, olayı bir oldu bitti fırsatçılığı içerisinde sonuçlandıracak bir gizlilikle ve eşgüdümle hareket ederek görevli olmadıkları halde kabul ederek, bağımsızlık yönünden “genelde toplumdan, özelde ise karar vermek zorunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsız” kalmak, tarafsızlık yönünden, “sadece bizatihi karar için değil aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerli olan bu prensip bağla-*

mında, yargısal görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimasız olarak yerine getirmek, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve yargıç tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava taraflarının güvenini sağlayacak ve artıracak davranışlar içerisinde olmak”, dürüstlük yönünden de “objektif olarak bakıldığında tarafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü ya da şüphe doğuracak durumlardan kaçınmak” şeklinde ifade edilen gereklere aykırı davrandıkları, yoksa hakim ve savcılık görevinin ifasında yapılabilecek rutin hatalardan ibaret olmadığına kuşku bulunmamaktadır.” (Gerekçeli Karar, sh. 119).

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık hakimlerin söz konusu reddi hakim taleplerinin ve tutuklama kararlarına itirazların kabulüne ilişkin kararları, **terör örgütünün talimatı doğrultusunda** verdiklerini kabul etmiştir.

“Fetullah Gülen'in Herkul.org isimli internet sitesine 19/04/2014 tarihinde ... yüklediği konuşma metninin genel olarak dini motifli olduğu, ancak konuşmanın ilerleyen kısımlarında Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkarılmasından başlayarak mübarek insanların da hırpalanıp preslerden geçtiğini, adeta dibeklerde dövüldüğünü, bu tür imtihanlardan vareste tutulanların kendi durumundan şüphe duymasından bahisle,” bazılarınız çeker, bazılarınız da onların çektiğini paylaşır, onların ızdıraplarını ruhunda duyar, yapılması gerekli olan şeyler mevzuunda bir küheylan gibi şahlanır, bir üveyik gibi kanatlanır, Allah'ın izni inayetiyle işte o zaman paylaşıyor demektir. Evet, birileri içeride Medrese-i Yusufiye yaşarlar, berikiler de dışarda oturur, kalkar onlara dua ederler “onları en çabuk zamanda, çok rahatlıkla salıver Allah'ım”, salıver ve onlarla beraber bir sürü aileyi kırkbin tane aileyi, ellibin tane aileyi, yüzbin tane aileyi belki onmilyon aileyi sevindir Allah'ım' ” diyerek örgüt üyelerine şüphelileri tahliye etmeleri hususunda talimat ilettiği,” kabul edilmiştir (Gerekçeli Karar, sh. 81).

“... teknik özellikleri, indirme ve kullanma yöntemi, kullanıcıları ve muhtevası itibarıyla münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanması amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen ByLock iletişim sistemine bu özelliğini bilerek dahil olan ve bu sistemi bir çok kez kullanan, 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde meşruiyetini toplum nezdinde dini zemini, kamu otoritesi nezdinde ise hukuki zemini istismar ederek sağlama gelen örgütün, talimat ve haberleşmesinin tam bir örgütsel gizlilik ve kripto yöntemine dayanması nedeniyle ancak örgüt mensuplarınca anlaşılabilir olan örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in, 19/04/2015 günü örgütün yayın organlarından www.herkul.org

isimli internet sitesinde yayınlanan “Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları” başlıklı **sohbet ve dua görünümlü kriptolu talimatını** alarak, tamamının aynı örgüte üye olmak ve aynı örgüt kapsamında değerlendirilen ancak ayrı soruşturma konuları nedeniyle sevk maddeleri itibarıyla farklı suç gerekçeleri ile yedi ayrı soruşturma dosyasında tutuklu olan altmış üç kişinin müdafiliğini yapan ve bir kısmı hakkında aynı örgüte mensubiyetleri nedeniyle ceza soruşturması başlatılan yirmi avukatın, örgüt lideri **Fetullah GÜLEN'in talimatından bir gün sonra** 20.04.2015 tarihinde toplu halde verdikleri 51 adet dilekçelere istinaden dosya asıllarını fiziki veya UYAP sisteminden kısmen dahi olsa incelemeyen tamamının istisnasız olarak tahliyelerini teminen birlikte harekete geçen ve ... "görünürde hukukilik, Türk yargılama geleneği ve mutad uygulama" bakımından da ancak "adanmış" bir örgüt mensubunca yapılabilecek bir yöntem ve üslupla, tanık anlatımlarına göre hukuka açıkça aykırı bir zeminde bulunduklarını bilerek söz konusu kararları veren, keza ayrıntıları ByLock raporunda çözülen mesaj içeriklerinde gösterildiği üzere; yapılacak bir darbeye kadar mensubu oldukları yapının terör örgütü olduğunun mahkeme kararı ile tespitinin önüne geçilmesini teminen belirlenen örgüt stratejisi doğrultusunda, işbu yargılamayı, benzer diğer davalarda olduğu gibi muhakeme hukukunun tanıdığı tüm hakları istismar ederek uzatmaya ve tıkamaya matuf örgütsel tavır sergileyen, örgüt piramidi içindeki konumları itibarıyla "mahrem alan" kapsamında yer almaları ve meslekleri gözetildiğinde, örgütün nihai amacını, silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasını ve burada devletin her türden silahını elinde bulunduran örgüt mensuplarının gerektiğinde bu gücü örgütün amacı doğrultusunda kullanacaklarını bilmeleri beklenen sanıkların, **FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarında şüphe bulunma**”maktadır (Gerekçeli Karar, sh. 102 vd.).

“Sanıkların eğitim düzeyi, yaptıkları görev nedeniyle edindikleri bilgi, tecrübe ve örgütteki konumları itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda oldukları, **terör örgütünde silah unsur ise de unsur yanılığının da söz konusu olmadığı anlaşılm**”ıştır (Gerekçeli Karar, sh. 103).

Daire Kararına göre, Terörle Mücadele Kanunu, m. 7, f. 1’de “**silahlı olma-yan terör örgütlerini kurma, yönetme, ve üye olma suçları düzenlenmektedir.**” (Gerekçeli Karar, sh. 95). Söz konusu kabul, Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinde 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla yapılan değişikliği göz ardı eden **hukuk dışı** bir kabuldür. Söz konusu kabul, Gerekçeli Kararın 103. sahifesinde yer verilen ve yukarıda iktibas edilen açıklama ile çelişmektedir.

II. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gerekçeli Kararına göre, “FETÖ/PDY” olarak isimlendirilen ve “terör örgütü” olarak isimlendirilen örgütsel yapının “nihai amacının, Devletin Anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğunda ve bu amacını gerçekleştirmek için “mahrem alan” olarak örgütlendiği, devletin silahlı kuvvetlerindeki unsurları dikkate alındığında gerekli ve yeterli örgütsel güce sahip bulunduğu kuşku yoktur.” (Gerekçeli Karar, sh. 101).

Söz konusu örgütsel yapının “nihai amacının devletin anayasal kurumlarını ele geçirmek ve bu cümleden olarak hükûmeti ortadan kaldırmak, görevlerini engellemek olduğunda şüphe yoktur.” (Gerekçeli Karar, sh. 115).

Söz konusu örgütsel yapı, “Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, **Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak**, Türkiye Devletini ve varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkmak ve daha sonra ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş bir **terör örgütüdür.**” (Gerekçeli Karar, sh. 76)

Söz konusu örgütsel yapının “amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara gelmek olmayıp, örgütün yarattığı kaos ortamı sonucu ayrıca devletin yanında oluşturduğu Paralel Devlet Yapılanmasıyla demokratik olmayan yöntemlerle **cebir şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer Anayasal kurumları fesih edip iktidara gelmek olduğu**, bu amacı gerçekleştirmek için polis ve jandarma teşkilatı, MİT ve Genel Kurmay Başkanlığı gibi kuvvet kullanma yetkisini haiz kurumlardaki üyeleri vasıtasıyla **meşru organlara ve halka karşı silah kullanmak suretiyle amaç suça elverişli öldürme, yaralama gibi çok sayıda vahim eylem gerçekleştirdiğinin**, anılan örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden ya da örgüte mensubiyetlerinden dolayı açılıp bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt lider ve yöneticilerinin açık kaynaklardaki yazılı ve sözlü açıklamaları, **Emniyet Genel Müdürlüğü'nün örgüt hakkındaki raporu** gibi olgu ve tespitler dikkate alındığında, 3713 sayılı Kanunun 1. maddesinde tanımlanan, amaca ulaşmak için silah başta olmak üzere her türlü cebir ve şiddeti araç olarak kullanan 5237 sayılı TCK'nın 314/1-2 maddesi kapsamında **silahlı bir terör örgütü** olduğu anlaşılmıştır.” (Gerekçeli Karar, sh. 76)¹⁶¹.

¹⁶¹ Ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **11.2.2020**, E. 2019/8467, K. 2020/984; Yargıtay 16. CD, **25.12.2019**, E. 2019/2751, K. 2019/8469; Yargıtay 16. CD, **9.12.2019**, E. 2019/5014, K.

15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün bir örgütlü suçluluk olduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, **görülmekte olan davaya konu teşkil eden olayın sınırlarını aşarak**, söz konusu örgütsel yapının Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya kadar çeşitli amaçları olan bir “**terör örgütü**” **değerlendirmesi yapmasının bilimsel ve hukuki dayanakları** karar metninde **gösterilmiştir**. İlginçtir ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, bu konuda **Emniyet Genel Müdürlüğünün** düzenlemiş bulunduğu **raporu** dayanak ittihaz edilmiştir. Yani bir terör örgütünün varlığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş, **polis raporuna** dayanılarak bu örgütün varlığı kabul edilmiştir.

Söz konusu **polis raporu** esas alınarak verilmiş olan kararda, varlığı kabul edilen “terör örgütü”nün geçmişinin **1966 yılına** kadar gittiği vurgulanmıştır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, söz konusu “terör örgütü”nün varlığını kabul ederken, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 24.06.2008 tarihli ve E. 2008/9-82, K. 2008/181 sayılı kararı ile sonuçlanan ceza davasına ilişkin iddianamenin düzenlendiği tarih öncesindeki fiillerin bu yargılama kapsamında değerlendirme konusu yapılamayacağını göz ardı etmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararına konu teşkil eden olayda, sanıklara yüklenen görevi kötüye kullanma suçunun işlendiği hususunda kuşku bulunmamaktadır. Hatta söz konusu görevi kötüye kullanma suçunun bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin kabulünde de bir sorun görülmeyebilir. Ancak, **yargılama konusu olaydan hareketle, “FETÖ/PDY” adıyla genel mahiyette bir “terör örgütü”nün varlığına yönelik bir yargısal tespit faaliyeti henüz icra edilmiş değildir. Bu konuda izlenen yanlış yöntem sebebiyledir ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin söz konusu kararında, yargılama konusu fiilden çok sonra gerçekleşmiş olan darbe teşebbüsünden hareketle, söz konusu örgütsel yapıya “terör örgütü” vasfı izafe edilmeye çalışılmıştır.**

Müteaddit defa ifade ettiğimiz üzere, bir sosyal oluşumun suç örgütü ve daha da ileri gidilerek terör örgütü vasfını kazanabilmesi için, somut suçlara bağlı tespitlerde bulunulması gerekir. Başka bir ifadeyle, ancak somut suçlardan hareketle ve bu suçların işlenmesi bağlamında bir suç örgütünün veya terör örgütünün varlığı sonucuna ulaşmak gerekir.

2019/7639; Yargıtay 16. CD, **5.12.2019**, E. 2018/4735, K. 2019/7776; Yargıtay 16. CD, **3.11.2019**, E. 2018/5526, K. 2019/6842; Yargıtay 16. CD, **5.7.2019**, E. 2019/521, K. 2019/4769.

Oysa kararda, bir terör örgütünün varlığı kabul edilmekle birlikte, bu örgütün hangi somut suçlarla bağlantılı olarak ortaya çıktığına yönelik bir tespitte bulunulmamıştır. “Terör örgütü” olarak nitelendirilen söz konusu örgütsel yapının içinde kabul gören dini inanç ve uygulamalar, tasvip edilmez ve yanlış görülebilir. Somut bir suça sebebiyet vermediği sürece, bu durumun ceza hukuku sorumluluğunu ilgilendirmedeği izahtan varestedir. Hatta, hangi amaçla olursa olsun, bu örgütsel yapının mensuplarının çeşitli kamu kurumlarında görev alma çabası ve hatta görevlendirilmesi, bu çerçevede somut suçların işlenmesi hali ayırık tutulursa, ceza hukuku sorumluluğu bağlamında tartışma konusu yapılabilecek bir durum değildir.

Karara konu teşkil eden olayda sübut bulan, sadece iki hakim tarafından işlenmiş görevi kötüye kullanma suçlarıdır. Söz konusu kararda, bu görevi kötüye kullanma suçları dışında, bir terör örgütünün varlığına vücut veren başka hiçbir somut suçun sübutuna yönelik tespitte bulunulmuş değildir.

Önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu kararda hakim olarak görev yapan sanıkların, bilahare 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşmiş olan örgütlü darbe teşebbüsü suçu ile ilişkilendiren hiçbir tespitte bulunulmuş değildir.

İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülüp karara bağlanan davaya konu teşkil eden olayda, görevini kötüye kullanan hakimlerin, kendisini çeşitli sıfatlarla tavsif eden örgütsel yapının lideri konumundaki kişinin talimatıyla işleyip işlemedikleri, bir sübut sorunudur. Kararda bu konuda, bir dayanak noktasından hareket edilmiştir. Bu da söz konusu örgütsel yapının liderinin kendi kontrolündeki bir internet sitesinden yayımladığı aleni mesajıdır. Bu mesajın, sanık hakimler bakımından bir talimat niteliği taşıyıp taşımadığı, olay mahkemesinin takdirinde olan bir sübut sorunudur.

Ancak söz konusu Kararda, “ByLock” isimli özel iletişim programının kullanıcısı olduğu ve bu programla aynı veya farklı çok sayıda kişiyle iletişim kurduğu kabul edilen sanıklara, bu program aracılığıyla herhangi bir talimat ve mesajın gönderildiğine dair tespitte bulunulmamıştır.

Bu bağlamda iki sorun mevcuttur. Birincisi, sanıkların hakim sıfatıyla işledikleri görevi kötüye kullanma suçlarını, çeşitli sıfatlarla kendisini tavsif eden örgütsel yapının lideri konumundaki kişinin talimatı doğrultusunda işleyip işlemediği; ikincisi ise, şayet bir talimat çerçevesinde işlemişlerse, bu talimattan hareketle bu örgütsel yapının suç örgütü ve terör örgütü vasfını kazanıp kazanmadığı sorunudur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bunlardan birinci sorun, bir sübut sorunudur. İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıkların söz konusu görevi kötüye kullanma suçunu talimat doğrultusunda işledikleri tespit ve değerlendirmesinde bulunmuştur.

Bu tespitin doğru olduğu kabul edildiği takdirde; ikinci sorun olarak, böyle bir talimatın varlığı, söz konusu örgütsel yapıyı suç örgütüne ve hatta terör örgütüne dönüştürebilir mi sorusuna cevap aramak gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki, bir örgütsel yapının lideri konumundaki kişinin belli bir suçun işlenmesi yönündeki talimatı, bu örgütsel yapının suç örgütüne dönüştüğünün kabulü için tek başına yeterli olmaz.

Bir örgütsel yapının suç örgütüne dönüşmesi için, bu örgütsel yapı içerisinde gayrimuayyen suçların işlenmesinin amaç edinildiğinin somut vakıalara istinaden ortaya konulması gerekmektedir. Bu tespit, somut olayımız bağlamında yargılama konusu görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği tarih itibarıyla yapılmalıdır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin inceleme konusu kararında bu değerlendirmeye imkan tanıyacak delillerin varlığı konusunda herhangi bir tespitte bulunulmamıştır.

Bir an için bu örgütsel yapının, söz konusu görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği tarih itibarıyla, bu suçların işlenmesine yönelik talimat dahil başka veriler de dikkate alınarak, bir suç örgütüne dönüştüğü ve bu görevi kötüye kullanma suçlarının bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiği kabul edilecek olursa; sorgulanması gereken diğer bir husus, bu örgütsel yapının salt TCK, m. 220 kapsamında yaptırım uygulanmasını gerektiren mahiyette bir suç örgütü mü, yoksa TCK, m. 314 çerçevesinde yaptırım uygulanmasını gerekli kılan terör örgütü mü olduğunun tespiti sorunudur.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, yargılama konusu görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği tarih itibarıyla, bu örgütsel yapının bir “terör örgütü” mahiyeti iktisap ettiği yönünde bir değerlendirmeye imkan tanıyacak delillerin varlığı konusunda herhangi bir tespitte bulunulmamıştır.

Her ne kadar, söz konusu Karara aynen iktibas edilen, “ByLock” isimli özel iletişim programının mahiyetine yönelik bilgilerin verildiği **polis raporunda**, bazı iletişim içeriklerine yer verilmiş ise de, bu iletişim içeriklerinin kimine ait olduğu, kimler arasında kurulmuş olan iletişimler çerçevesinde gönderildiği hususunda hiçbir tespitte bulunulmamıştır. Polis raporunda yer verilen bu soyut bilgilerden hareketle, söz konusu örgütsel yapının “terör örgütü” mahiyeti iktisap ettiğini kabule hukuken imkan bulunmamaktadır.

Söz konusu Gerekçeli Kararda, malum örgütsel yapının “terör örgütü” vasfını haiz olduğu kabul edilmekle birlikte, bu vasfı hangi suçluluk olaylarıyla bağlantılı olarak iktisap ettiği hususunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Kararda “gerekçe” olarak yer verilen açıklamalardan, bu kabulün dayanağını işlenmiş somut suçların değil, örgütsel yapının mensuplarının **soyut beyanları**nın oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu kabulün hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Gerekçeli Karara aynen iktibas edilen polis raporunda, bu örgütsel yapı mensuplarının “ByLock” adlı özel iletişim programı üzerinden birbirlerine gönderdiği belirtilen bazı mesaj içerikleri, söz konusu örgütsel yapının “terör örgütü” vasfını kazandığı yönündeki kabulün bir dayanağını oluşturmaktadır (Gerekçeli Karar, sh. 53 vd.). Gerekçeli Kararda söz konusu mesajların kimler arasında teati edildiğine dair hiçbir bilgiye yer verilmemiştir.

Bu soyut mesaj içeriklerinden hareketle, bir örgütsel yapının terör örgütü vasfını kazandığını kabule hukuken imkan bulunmamaktadır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi söz konusu kararında, terör örgütüne yardım etmek ve bu bağlamda terör örgütü üyeliği suçlamaları ile ilgili olarak dikkate alınacak bazı tespit değerlendirmelerde bulunmuştur:

*“... bir suç örgütü baştan itibaren, suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı olabileceği gibi, legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum örgütünün sonradan bir suç örgütüne, hatta terör örgütüne dönüşmesi de mümkündür. Kuruluş amacı silahlı ya da silahsız yöntemlerle suç işlemek olan, bu amaç ve yöntemlerini açıkça deklare eden ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla bu durumu açıkça bilinen örgütlere üye olan veya bu örgütlere bilerek yardım edenlerin kusurluluğunda tartışılacak bir husus bulunmamakta ise de; **legal zeminde faaliyet gösteren ve nihai amacı gizli tutulması nedeniyle açıkça bilinmeyen yapılara dahil olan ya da yardım edenlerin, bu suçların doğrudan kast ve özel saikle işlenebilen suçlar olduğu hususu da gözetildiğinde, hukuki durumlarının kusurluluk ve hata bağlamında değerlendirilmesinde zaruret vardır.***

Genelde suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün, özelde terör örgütünün “amaç ve yöntemlerini bilen örgüt mensuplarının, örgütteki konumları gözetilerek cezalandırılacağı da açıktır. Örgütlenme piramidine göre, 5. 6. ve 7. tabakalarda ve kural olarak 3. ve 4. tabakalarda bulunan örgüt mensuplarının bu durumda olduklarının kabulü gerekir. Ancak önce dinî bir kült, ardından bir terör örgütü hâline dönüşen, eğitim-öğretim faaliyetleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, yerel ve uluslararası ticari işletmeler, basın-

yayın ve medya organları gibi legal yapılar ve Abant Toplantıları, Türkçe Olimpiyatları benzeri prestijli organizasyonlar üzerinden oluşturulan sempatizan halkasından insan ve maddi kaynak devşiren FETÖ/PDY'nin, başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve toplumun her katmanının büyük bir kesimince böyle algılanması da toplumsal bir gerçekliktir. Amaca ulaşmak için her yolu mubah gören, fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya çalışan örgütün, **silahlı bir terör örgütü olduğu gerçeğinin**, örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen hakkında Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2008/9-82,181 sayılı kararı ile kesinleşen beraat kararı da nazara alındığında, **özellikle örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan diğer tabakalardaki örgüt mensupları tarafından bilinip bilinmediğinin olaysal olarak toplanan deliller muvacehesinde TCK'nın 30.maddesi kapsamında değerlendirilmesi lazımdır.**

Ancak bu değerlendirme yapılırken, 2012 yılı ve sonrasında örgüt mensubu olan kamu görevlileri tarafından yapılan operasyonlar gibi, örgütün nihai amacını açıkça ortaya koymaya başladığı sansasyonel olaylar sonrasında; **Milli Güvenlik Kurulu'nun, 30 Ekim 2014, 29 Nisan 2015 ve 26 Mayıs 2016 tarihli toplantılarında alınan ve kamuoyu ile paylaşılan kararlarda sözde "hizmet hareketi" adlı, legal görünümlü illegal yapının, paralel bir devlet kurma amacıyla olan, devletin varlığına ve anayasal düzenine karşı ciddi tehdit oluşturan bir örgüt olarak kabul edilmesi, aynı tespit ve açıklamaların devlet ve hükümet yetkililerince de en üst düzeyde benimsenip, kamuoyu ile paylaşılması gibi olguların da göz ardı edilmemesi gerekir.** (Gerekçeli Karar, sh. 101 vd.).

Daire yaptığı bu değerlendirmeyeyle, söz konusu örgütsel yapının bir "terör örgütü" olduğu yönündeki kabulü, Milli Güvenlik Kurulunun aldığı çeşitli kararlara da dayandırmaktadır. Bu kabulün de hukuki temelini olmadığı açıktır. Münhasıran yürütme yönünden bir istişare organı olan Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarından hareketle, bir örgütsel yapının terör örgütü olduğunun kabulü, **münhasıran yargının görevi olan bir hususun idari organlara tevdi** olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu kararın bu yönü itibarıyla **hatalı** olduğu ve bunun hukuken kabul görmeyeceği açıktır.

Gerekçeli Kararda, sanık hakimlerin terör örgütü üyesi olarak kabul edilme-lerinin bir sebebi olarak, "ByLock" isimli kapalı devre iletişim ağını kullanmış olmaları gösterilmiştir.

“**ByLock**” adlı elektronik iletişim programı ile ilgili olarak söz konusu Kararın gerekçesinde yer alan bilgiler itibarıyla, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

Söz konusu programın internet üzerinden kapalı devre iletişim aracı olarak kullanılmasına 2014 yılının ilk aylarında başlanmış ve 2016 yılı ocak ayı itibarıyla kullanıma tamamen kapatılmıştır (Gerekçeli Karar, sh. 65).

Programın salt indirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu bağlamında sorun, programın kullanılmasıyla başlamaktadır (Gerekçeli Karar, sh. 56, 57, 64).

Gerekçeli Karardaki açıklamalara göre, söz konusu programın sadece akıllı telefona, bilgisayara indirilmesi, yüklenmesi iletişim kurmak için yeterli değildir. Söz konusu program üzerinden iletişim kurulabilmesi için, “**özel kurum**” gereklidir; başka bir ifadeyle, bunun “*için sistem tarafından kayıt olan kullanıcılara otomatik olarak atanan ve kullanıcıya özel olan ID (kimlik numarası) numarasının bilinmesi ve karşı taraftan onaylanması gerektiği, aksi halde kişiler listesine eklenemeyeceği ve mesajlaşma içeriğinin gerçekleşmeyeceği, programın kayıt esnasında kullanıcıdan sadece bir kullanıcı adı ile parola üretmesini istediği anlaşılmaktadır.*” (Gerekçeli Karar, sh. 64)¹⁶².

Bu bilgilere göre, indiren tarafından programın kullanılabilmesi için, programı kullanmakta olan bir başkasının tavassutuna, akreditasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Keza program, kullanıcı konumunu iktisap etmiş olan kişiler arasında **kapalı devre bir iletişim aracı** olarak kullanılmıştır (Gerekçeli Karar, sh. 46, 55, 56, 64).

16. Ceza Dairesinin söz konusu Kararında referans olarak alınan kaynaklarda, “ByLock”ın kapalı devre iletişim aracı olarak kullanılmasına 2014 yılı başları itibarıyla başlandığı belirtilmektedir. Ancak bu hususta kesin bir tarih verilmemektedir. Kanaatimizce bunun sebebi, söz konusu kaynaklarda yer alan bilgilerin, herhangi bir kişiye özgü olmaması, bir bütün olarak sistemin işleyişine ilişkin olmasıdır. Bu durum karşısında, her bir kullanıcının hangi tarih itibarıyla söz konusu iletişim programını kapalı devre iletişim aracı olarak kullandığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitin de, ancak Litvanya’daki yer sağlayıcının veri tabanındaki bilgiler itibarıyla mümkün olması gerekir. Buna karşılık, Türkiye’deki erişim veya servis sağlayıcılardan temin edilen trafik bilgilerinden bu tespitin yapılmasının mümkün olmaması gerekir.

¹⁶² Aynı yönde açıklamalar için bkz. Yargıtay 16. CD, **14.7.2017**, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 26.

Kısaca şunu ifade etmek isterim: Litvanya'daki yer sağlayıcının veri tabanında mevcut olan veriler dikkate alınmadan, söz konusu iletişim programını kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan kişilerle ilgili olarak adil bir kararın verilmesi mümkün gözükmemektedir.

Gerekçeli Kararda verilen bilgilere göre, söz konusu program üzerinden sözlü (sesli) veya yazılı iletişim kurulabilmekte ve hatta, elektronik posta¹⁶³ da gönderilebilmektedir (Gerekçeli Karar, sh. 64, 65).

Söz konusu program üzerinden kurulan sözlü, yazılı, e-posta gönderimi şeklindeki bütün iletişimler **özel bir şifreleme yöntemi** kullanılarak yapılmıştır (Gerekçeli Karar, sh. 64).

Bir diğer özellik, program üzerinden iletişime geçen kişilerin kullandığı cihazlardaki iletişim içeriklerinin, iletişimden itibaren belli bir sürenin geçmesiyle kendiliğinden silinmesidir. Ancak bu iletişim içerikleri, Litvanya'da bulunan yer sağlayıcının veri tabanında kriptolu vaziyette muhafaza edilmişlerdir.

Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmaları sonucunda, Litvanya'da bulunan yer sağlayıcının veri tabanındaki bütün veriler ele geçirilmiştir. Bu veri tabanında kayıtlı olan trafik ve içerik bilgilerinin önemli bir kısmı çözümlenmiş durumdadır. Çözümleme çalışmaları halen devam etmektedir.

Gerekçeli Kararda belirtildiği üzere,

- sanıklardan M. Başer'in, 21.9.2014 ile 21.11.2014 tarihleri arasında 19 farklı günde ByLock sistemi üzerinden 459 sefer iletişim kurmuş olduğu,
 - M. Öztürk'ün ise, 17.8.2014 ile 20.2.2015 tarihleri arasında 21 farklı günde ByLock sistemi üzerinden 405 sefer iletişim kurmuş olduğu,
- tespit edilmiştir (Gerekçeli Karar, sh. 57, 63 vd., 66).

Gerekçeli Kararda, sanıkların ByLock iletişim sistemini ne suretle kullandıklarına dair bir bilgiye yer verilmemiştir.

Söz konusu program üzerinden kurulan iletişimlere ilişkin **trafik bilgileri**, bu veri tabanından eksiksiz bir şekilde elde edilmiş durumdadır. Ancak bu

¹⁶³ Gönderilen “her bir e-posta için, e-postayı gönderen kullanıcı, e-postayı alan kullanıcı, e-postayı alan diğer kullanıcılar, konu e-posta içeriğinin şifreli hali, imza, e-postanın gönderilme zamanı, e-postanın gönderilen kişiye iletilme zamanı, bilgileri mail tablosunda saklandığı görülmüştür.”: Gerekçeli Karar, sh. 64; ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **14.7.2017**, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 26.

trafik bilgilerinden, iletişim kuran kişilerin gerçek isimlerini kullanma yerine, anonim isimler veya numaralar kullanma yoluna gittikleri anlaşılmıştır (Gerekçeli Karar, sh. 64, 65).

Yukarıda sözü edilen iletişimlerden sözlü olanların içeriğinin bilahare tespit edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Ancak, bu iletişimlerin, kod adıyla da olsa¹⁶⁴, kiminle ve hangi zaman aralığında kurulduğu, iletişim kurulan kişilerin suçla ve suçlulukla bir ilgisinin olup olmadığı en azından yer sağlayıcının veri tabanı üzerinden tespit edilebilir olmasına rağmen (Gerekçeli Karar, sh. 65)¹⁶⁵, söz konusu davada bu tespitler yapılmamıştır.

Keza, yukarıda sözü edilen iletişimlerden “yazılı mesaj, e-posta ve dosya transferi” gibi yazılı olanların içeriğine yer sağlayıcının veri tabanı üzerinden ulaşma imkanı olmasına rağmen, belirtilen iletişimlerden ne kadarının yazılı olduğu dahi tespit edilmemiştir.

Bu yazılı iletişimlerden sadece birinin içeriğine ilişkin olarak Gerekçeli Kararda bilgi verilmiştir. Bu da, sanıklardan M. Özçelik’in müdafii Avukat Celal Sis ile yine avukat olduğu belirtilen Ahmet Sivri arasındaki e-posta içeriğidir (Gerekçeli Karar, sh. 57 vd.). Ahmet Sivri, kararın ilişkin olduğu davada sanıklardan herhangi birinin müdafii değildir. Ancak avukat olduğu belirtilen bu kişinin sanıklardan birinin müdafilik görevini üstlenmiş avukatla arasındaki iletişim içeriğinin bu bağlamda bir delil olarak gösterilmesi, yanlış olmuştur. Zira, söz konusu e-posta içeriğinin terör örgütüyle veya herhangi bir suçla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu e-posta, içeriği, doğru veya yanlış, savunma ile ilgili çeşitli sorunlara ilişkin bulunmaktadır.

Oysa Gerekçeli Kararda da belirtildiği gibi, söz konusu iletişim ağı üzerinden “*haberleşmelerin kimlerle yapıldığı ve haberleşmenin içeriğinin tespiti mümkündür. ... Haberleşmelerin kimlerle yapıldığı ve içeriğinin tespit edilmesi kişinin yapının (terör örgütü) içindeki konumunu tespit etmeye yarayacak bilgilerdir. Diğer bir deyişle kişinin örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumunu (örgüt yöneticisi/örgüt üyesi) tespit etmeye yarayacak bilgilerdir.*” (Gerekçeli Karar, sh. 66).

Örneğin bir hakim, suçluluğuyla temayüz etmiş ve bir suç örgütüyle ilişkisi bulunan bir kişiyle herhangi bir iletişim aracı üzerinden görüşmeler yap-

¹⁶⁴ Gerekçeli Karar, sh. 65; ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 27.

¹⁶⁵ “ByLock iletişim sisteminde bağlantı tarihi, bağlantıyı yapan IP adresi, hangi tarihler arasında kaç kez bağlantı yapıldığı, *haberleşmelerin kimlerle yapıldığı ve haberleşmenin içeriğinin tespiti mümkündür.*”: Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 28.

miş olması, yapılan görüşme sayısı, görüşmelerin yapıldığı zaman aralığı gibi bilgiler, sözlü olması itibarıyla bu görüşmelerin içeriği tespit edilemese bile, görüşmeyi yapan hakimin suçla ve suçlulukla ilişkisini kurma bakımından başlı başına dikkate alınabilecek bir delil hüviyeti taşır.

Buna rağmen, söz konusu Gerekçeli Kararda, sanıkların alelittlak “ByLock” isimli özel iletişim programını kullanmış olmaları, terör örgütü üyesi suçundan mahkûm edilmeleri için yeterli delil olarak kabul edilmiştir.

Kişi, kapalı devre bir iletişim ağı olduğunu bilerek bu sisteme dahil olmuş olabilir. Ancak, salt bu bilgi ceza hukuku sorumluluğu için yeterli değildir.

Şayet kişi, bu programın bir suç örgütünün üyelerine münhasır kapalı devre bir iletişim aracı olduğu ve bu program üzerinden suç işlenmesine yönelik bir faaliyet icra edildiği bilgisine sahip ise, en azından suç örgütü üyeliğinden dolayı sorumluluğu cihetine gidilmesi gerekir.

Bu çerçevede ceza sorumluluğu bakımından, kişinin bu program üzerinden kimlerle iletişime geçtiğinin ve özellikle iletişim içeriklerinin büyük bir önemi bulunmaktadır.

Kişilerin söz konusu program üzerinden isimsiz veya anonim isimle iletişime geçmelerine rağmen, bu iletişimlere ilişkin **trafik bilgilerinin karşılaştırılması ve eşleştirilmesi** suretiyle, iletişim kuran veya kurulan kişilerin büyük bir kısmının gerçek kimliklerinin tespit edilebilir olduğunu düşünmekteyiz.

Keza, yazılı iletişim içeriklerinden hareketle de, iletişim kuran veya kurulan kişilerin gerçek kimliklerinin tespit edilebilir olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Trafik bilgilerinden hareketle, söz konusu program üzerinden iletişimlerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de bulunan kişiler arasında kurulduğu tespit edilmiştir. Keza, yazılı iletişim içeriklerinde kullanılan dil büyük ölçüde Türkçedir (Gerekçeli Karar, sh. 51 vd.). Hatta, programın kendi bünyesindeki mesajlar da Türkçedir (Gerekçeli Karar, sh. 65).

Litvanya’daki yer sağlayıcının veri tabanından elde edilen bilgilerin haricinde, özellikle Türkiye’deki erişim ve servis sağlayıcılardan temin edilmiş ve edilebilecek olan trafik bilgileri, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen bir kişinin iletişimleri ile ilgili Litvanya’daki yer sağlayıcının veri tabanından elde edilen trafik bilgilerinin, Türkiye’deki erişim ve servis sağ-

layıcılardan temin edilen veya edilebilecek olan trafik bilgileri ile karşılaştırılması ve eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin söz konusu kararında da açıkça belirtildiği üzere, **“ByLock” programı üzerinden yapılan yazılı iletişimlerin içeriğinin tespiti pekala mümkün** olduğuna göre; söz konusu programı kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan kişinin bu program üzerinden kurduğu iletişimlerin ne kadarının sözlü, ne kadarının yazılı olduğunun tespit edilmesi ve **yazılı olarak yapılan bütün iletişim içeriklerinin soruşturma ve kovuşturma dosyasına derç edilmesi gerekmektedir**. Aksi takdirde kurulan veya kurulacak olan hükümler, eksik incelemeye dayalı olacaktır.

III. Bu eleştirilerimize rağmen Gerekçeli Kararda yer verilen şu açıklamalara aynen iştirak etmekteyiz:

“Suç örgütleri veya silahlı terör örgütlerine yardım suçunun ancak doğrudan kastla işlenebileceği, yardımın örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet etmesi gerektiği, örgüt üyelerine yapılan yardımın da örgüte yapılmış gibi kabul edilmekle birlikte örgüt üyesinin mensup olduğu örgütün bilinmesi ve bu yardımın da insani mülahazalarla değil örgütün amaçlarını gerçekleştirme gayesiyle yapılması” gerekir (Gerekçeli Karar, sh. 89).

“Bir oluşumun çekirdeğini oluşturan kişiler suç işlemek amacıyla hareket etmekle birlikte, oluşumun içinde yer alan fakat bu amaçtan habersiz olan kişiler, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüte üye olmaktan veya bu örgütü yönetmekten sorumlu tutulamazlar.” (Gerekçeli Karar, sh. 86).

“Örgütün, silahlı örgüt vasfını kazanması için mensuplarının silah sahibi olmaları gerekmez. Silahlar üzerinde gerektiğinde tasarruf imkanının olması gerekli ve yeterlidir.” (Gerekçeli Karar, sh. 85).

EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

I. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kısaca “FETÖ” olarak isimlendirdiği örgütsel yapıya ilişkin E. 2017/3 ve K. 2017/4758 sayılı Kararlarında, söz konusu örgütsel yapının bir terör örgütü vasfını taşıdığı kabul edilmekle birlikte, bu vasfı hangi somut suç veya suçlarla bağlantılı olarak iktisap ettiği yönünde herhangi bir tespitte bulunulmamıştır.

Bu yönü itibarıyla söz konusu kararlarda önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Asıl sorun da bu eksiklikten kaynaklanmaktadır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bilahare verdiği K. 2017/5155 sayılı Karara yöneltilen eleştiriler de esasında bu belirsizlikten kaynaklanmaktadır.

Bugün PKK’nın adını kullanarak ve bu suretle söz konusu örgütün korkutucu gücünden yararlanarak şiddet içeren somut bir suç işlemiş olan kişinin bu suçun haricinde ayrıca terör örgütü üyeliğinden sorumlu tutulmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Keza, söz konusu örgüte yargı kararlarıyla açık bir şekilde terör örgütü vasfı izafe edildiği ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde belirli bir siyasi amaca matuf olarak, kamu görevlisi olsun veya olmasın binlerce kişinin kasten ve bir plan çerçevesinde öldürüldüğü ve sair şiddet içeren çok sayıda suçun işlendiği yargı kararlarıyla sabit bulunduğu için, terör örgütü vasfı temayüz etmiş olan PKK’ya maddi veya manevi yardımda bulunan, bu örgüte ait eğitim faaliyetlerine katılmış olan, bu örgüt bünyesindeki hiyerarşik yapıya emir ve talimat alma hususunda teslim olmuş olan kişinin alelittlak terör örgütü üyeliği suçundan dolayı sorumlu tutulması, sorun teşkil etmemektedir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin söz konusu kararları ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **26.9.2017** tarihli ve E. 2017/16.MD-956, K. 2017/370 sayılı kararı karşısında, bu kararlarla terör örgütü vasfı temayüz eden örgütsel yapıya söz konusu kararlardan sonra, bilerek ve isteyerek maddi veya manevi yardımda bulunan ve bu örgüte hakim olan hiyerarşik yapıya dahil olan kişilerin, işledikleri fiiller başka bağımsız bir suç oluşturmaya bile, alelittlak terör örgütü üyeliğinden dolayı sorumlu tutulacakları konusunda da tereddüt bulunmamaktadır.

Bütün sorun, Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu kararlarından önce ve hatta, bu kararlarla varlığı kabul edilen terör örgütünün sevk ve idaresiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü öncesinde herhangi somut bir suçun icrasına iştirak etmemiş

olan, salt hayrî mülahazalarla, çeşitli derneklere, vakıflara veya sosyal etkinliklere maddi veya manevi yardımda bulunan kişilerin ceza hukuku sorumluluğu bakımından ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararlarından önceki dönemde de olsa, kişinin işlenişine iştirak ettiği somut bir suçun bir örgütün ve hatta terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği kabul edilebilir. Bu durumda kişinin, işlenişine iştirak ettiği somut suçun yanı sıra, bu somut suç bağlamında varlığı kabul edilen suç örgütüne veya terör örgütüne üye olmaktan dolayı da ayrıca sorumlu tutulması gerekmektedir. Ancak bunun için, kişinin somut bir suç işlemesi, somut bir suçun işlenişine iştirak etmesi gerekmektedir. Bu itibarla, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsüne iştirak etmiş olan askerlerin, sair kamu görevlilerinin ve hatta sivil kişilerin hem TCK, m. 309'da tanımlanan suçtan, hem de terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği suçundan dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

Bu genel tespit ve değerlendirmelerimiz karşısında, özellikle 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü öncesinde, herhangi somut bir suçun icrasına iştirak etmemiş olmak kaydıyla, sırf hayrî mülahazalarla, çeşitli derneklere, vakıflara veya sosyal etkinliklere maddi veya manevi yardımda bulunan, çeşitli derneklere, vakıflarda veya şirketlerde kurucu veya ortak olan ya da yönetici olarak görev alan kişilerin aleltilak, sadece bu sebeple terör örgütü üyesi olarak ceza hukuku bakımından sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir.

II. Anayasa Mahkemesinin 17.7.2018 tarihli ve 2014/15428 bireysel başvuru sayılı Kararına¹⁶⁶ konu teşkil eden olayda başvuru, bir siyasi partinin seçim propagandaları çerçevesinde yaptığı açık alan toplantısında bir grup arkadaşıyla birlikte tanınmamak için yüzleri kapalı vaziyette kalabalığın arasına girerek, terör örgütüne ait işaret ve sembolleri taşımış, terör örgütü liderinin posterini açmış, örgütün propagandası mahiyetinde ifadelerin yer aldığı afiş açmış ve örgüt lehine sloganlar atmıştır.

İlk derece mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda başvurucuyu **terör örgütünün propagandası** suçunu işlediğini kabul ederek, sonuçta **bir yıl hapis cezasına** mahkûm etmiştir. Bu mahkûmiyet hükmü temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.

¹⁶⁶ RG: 28 Eylül 2018/30549.

Söz konusu toplantıda, toplantıda, başvuru ve arkadaşları tarafından “şiddet kullanan bir terör örgütünün eylemleri övülmüş; açıkça kin ve intikam duygularının oluşmasına çalışılmış ve şiddetin bir çözüm olduğu ifade edilmiştir. Miting alanında bulunan ve başvuru ve arkadaşlarının da içinde bulunduğu küçük bir grup taşıdıkları örgüte ait bayraklarla, attıkları ve kalabalığa söyletmeye çalıştıkları sloganlar ile süregelen şiddet eylemlerinin artmasına veya devamına destek olacak tarzda hareket etmiştir. Bir terör örgütü olan ve hedeflerine ulaşmak için şiddeti bir yöntem olarak benimseyen PKK'nın desteklediğinin söylenmesiyle demokratik topluma yönelik ciddi bir tehdit ortaya konulmuştur.” (pn. 67, 68).

Yüksek Mahkemeye göre, “bir terör örgütüne özgü olduğu konusunda şüphelenen sembollerin kullanılmasıyla örgütün yalnızca siyasi idealleri ya da hedeflerinin desteklediği, buna karşın aynı terör örgütünün yöntem olarak şiddeti benimsemiş olmasının meşru görülmediğinin söylenmesi güçtür.” (pn. 69)

“Bir terör örgütünün eylemlerini onaylayarak kamuoyu önünde ona sahip çıkmak, anılan örgütün işlediği cürümleri iyi görmek ve dolayısıyla desteklemek niteliğindedir. Bu kişiler bir terör örgütünün toplumsal bilinirliğinin ve kabul edilebilirliğinin artırılmasına, eylemlerinin meşru gösterilmesine, toplantı ve gösteri hakkının tanıdığı imkanlar kullanılarak güvenlik güçlerine ve devletin diğer kurumlarına karşı sürekli bir çatışma siyasetinin yöntem olarak benimsenmesine hizmet etmişlerdir. Dolayısıyla bu kişiler yönünden başvuruya konu toplantı barışçıl toplantı kavramı dışında kalmıştır.” (pn. 70)

“... şiddeti öven veya şiddetin daha da yaygınlaşmasına neden olan ifade açıklamalarının, mevcut düzene itiraz eden, toplumun genelini rahatsız etse de barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi savunulan ifade açıklamalarından titizlikle ayrılması gerekir. Zira şiddeti bir yöntem olarak benimseyen düşünceler demokratik toplumun varlığını tehlikeye düşürür ve demokratik bir hakkın kullanımı ile bağdaşmaz. Dolayısıyla bu tür düşünceler demokratik bir toplumda tahammül edilmesi gereken düşüncelerden sayılamaz.” (pn. 80)

Somut olayda “Anayasa Mahkemesi; başvuru ve arkadaşlarının **PKK terör örgütünün üyesi** veya destekçisi **olduklarını** belli edecek şekilde davranışlarda bulunduğunu, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını, söz ve davranışlarıyla bir bütün olarak güvenlik güçlerine karşı şiddeti teşvik ettiğini tespit etmiştir.” (pn. 82)

“Başvurucunun eylem ve sözlerinin bir terör örgütünün hedef veya talimatlarıyla örtüştüğü kanaatine ulaşılmıştır. Eylem ve sözleriyle şiddete ve demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasını teşvik eden başvurucunun eylemlerinin demokratik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturduğu kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla başvurucunun cezalandırılması acil bir toplumsal ihtiyacı karşılamaktadır.” (pn. 83)

“Başvurucunun cezalandırılması ile, PKK terör örgütünün yöntem olarak benimsediği şiddet eylemlerinin ortadan kaldırılması, demokratik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturan şiddetin devamına ve artmasına destek olacak tarzda hareket eden kişilerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Silahlı çatışma ortamının devam ettiği koşullarda **örgüte eleman kazandırmak, örgütün yandaş sayısını artırmak ve örgütün şiddet eylemlerini meşru göstermek amacıyla faaliyet** gösterdiği değerlendirilen başvurucuya verilen **bir yıl hapis cezasının** kamu gücünü kullanan organların ve mahkemelerin farklı menfaatleri dengelemek konusundaki takdir yetkileri de gözetildiğinde aynı zamanda **orantılı** olduğu sonucuna varılmıştır.” (pn. 84)

III. Keza, Anayasa Mahkemesinin 22.5.2019 tarihli ve 2014/15440 bireysel başvuru sayılı Kararına¹⁶⁷ konu teşkil eden olaylarda, başvuru, beraber hareket ettiği grupla birlikte, kanuna aykırı olarak düzenlenen ve terör örgütünün propagandasının yapıldığı, yol kesilerek geçen araçlara zarar verildiği, güvenlik görevlilerine, kamu binalarına ve işyerlerine taşlı ve molotoflu saldırıların gerçekleştiği, güvenlik görevlilerinin yaralandığı, silahlarının gasp edildiği çeşitli toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmış, bir kısmında katılanların kimliklerinin tespitini engellemek amacıyla yüzlerini kapadıkları bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerini organize etmiştir.

İlk derece mahkemesi, başvuru, temadi eden bu fiillerini göz önünde bulundurarak, **terör örgütü üyeliği** suçunu işlediğini kabul etmiş ve hakkında **7 yıl 6 ay** hapis cezasına hükmetmiştir. Buna karşılık, söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında kolluk görevlilerine karşı gerçekleştirilen direnme ve yaralama, kamu binalarına ve işyerlerine zarar verme fiillerinden dolayı başvurucunun beraatine hükmedilmiştir. Bu mahkûmiyet hükmü de temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu olay dolayısıyla kurulan mahkûmiyet hükmü bağlamında da bir hak ihlalinin gerçekleşmediği sonucuna varmıştır.

¹⁶⁷ RG: 12 Temmuz 2019/30829.

IV. Her iki karara konu teşkil eden olaylarda gerçekleştirilen fiillerin başlı başına suç oluşturduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. **17.7.2018** tarihli karara konu teşkil eden olayda sadece **terör örgütünün propagandası** suçundan dolayı; buna karşılık, **22.5.2019** tarihli karara konu teşkil eden olayda ise, sadece **terör örgütü üyeliği** suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulmuştur. Belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi, **17.7.2018** tarihli karara konu teşkil eden olayda da başvurucunun **terör örgütü üyesi** olduğu sonucuna varmıştır (Paragraf no. 82).

Öncelikle belirtmek gerekir ki, **terör örgütünün propagandası suçundan dolayı mahkûmiyet için, kişinin örgüt üyesi olmaması gerekir.** Keza, **terör örgütü üyesi olan kişinin ayrıca örgüt propagandası suçundan dolayı mahkûmiyeti yoluna gidilemez.** Aslında terör örgütünün propagandası fiili, örgüte yardım etme mahiyeti taşımaktadır. Ancak, propaganda, Kanunda yardım etme fiilinden ayrı, müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, bu suçtan mahkûmiyet halinde kişi hakkında ayrıca terör örgütü üyeliği suçundan dolayı hüküm kurulmamaktadır¹⁶⁸.

Bu temel prensipler göz önünde bulundurulmadığı için, her iki bireysel başvuru kararının konusunu teşkil eden olaylarda adliye mahkemeleri, suç nitelendirmelerindeki farklılık dolayısıyla birbirleriyle orantılı olmayan cezalara hükmetmişlerdir.

Anayasa Mahkemesinin **22.5.2019** tarihli ve 2014/15440 bireysel başvuru sayılı Kararında; örgüt üyeliği suçuyla bu suçtan dolayı cezalandırılabilirlik birbirine karıştırılmış ve bu bağlamda çelişkili açıklamalara yer verilmiş olmakla birlikte; sonuçta **doğru** bir şekilde, söz konusu suçtan dolayı mahkûmiyet için, esasında suç oluşturan somut vakıaların tespit edilmesi gerektiği değerlendirilmesinde bulunulmuştur:

Yüksek Mahkemeye göre; bir kişinin suç işlemek için kurulmuş örgüte üyelik suçundan dolayı “*cezalandırılabilmesi için henüz bir suç işlemiş olması gerekmez. Örgüt üyeliği başlı başına cezalandırılan bir suçtur. Bu itibarla örgüt üyesinin faaliyetinin mutlaka örgüt tarafından gerçekleştirilen suçlara katılma şeklinde olması da gerekmez. Örgüte üye olma suçu, üye ve hatta örgüt henüz bir suç işlememiş olsa dahi örgütün toplum için yarattığı*

¹⁶⁸ Birçok Batılı ülke mevzuatında ayrıca terör örgütünün propagandası suçu tanımına yer verilmemesinin sebebi budur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu, 25.03.2019**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve araştırma Merkezi (TÜRK/CE-MER) yayını.

tehlikeyi cezalandıran ve bu yönüyle bir yandan da örgüt faaliyetleri kapsamında suç işlenmesini engelleme amacı taşıyan bir suç türüdür. Çünkü birden fazla kişinin suç işlemek için organize olması toplum için daha açık ve yakın bir tehdit oluşturur.” (pn. 61)

“Bir kişinin terör örgütüne üye olma suçundan mahkûm edilebilmesi için henüz başka bir suç işlemesi gerekmediğinden maddi olayların tek tek ele alındığında kendi başına birer suç teşkil etmesi veya bir suça vücut vermesi gerekmemektedir.” (pn. 71)

Bu sorunlu açıklamalara rağmen, Yüksek Mahkeme, **doğru** bir şekilde, terör örgütü üyeliği suçundan dolayı mahkûmiyet için, esasında suç oluşturan somut vakıaların tespiti edilmesi gerektiği yargısına varmıştır:

“Terör örgütü üyeliği suçu uluslararası hukuk literatüründe statü suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda kişinin başka bir suç işlemesi gerekmemesinin yalnızca örgüte üye olmasının cezalandırılması kişisel cezai sorumluluktan ziyade, kolektif cezai sorumluluğa yol açma potansiyeline sahiptir. Fakat bu suçtan mahkûm edilmesi için kişinin, örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, örgütün bir parçası olmayı istemesi ve örgütün hayatta kalmasına, amaçlarının gerçekleştirilmesine devamlı bir irade ile katkı sağlaması gerekir. Örgüte üye olmak, fiilî bir katıldır. Dolayısıyla üyeliğin suç olarak kabul edilmesinin ve cezalandırılmasının altında yatan sebep, terör örgütü üyesi olan kişinin aslında bu şekilde terör örgütünün toplum için arz ettiği tehlikeye bilerek ve isteyerek katkı sağlamasıdır.” (pn. 62)

“Henüz ceza kanunlarında tanımlanan bir suçu dahi işlememiş kişilerin bir terör örgütü ile örgüt üyeliği olarak kabul edilecek kuvvette bir bağının olup olmadığının bu şekilde değerlendirilmesi ifade, örgütlenme, din ve vicdan özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı gibi temel haklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilecek potansiyele sahiptir.” (pn. 64)

“Terör örgütüne üye olma suçundan her türlü şüpheden uzak bir şekilde mahkûm edilebilmesi için -eylemlerinin sürekliliği, çeşitliliği ve yoğunluğu dikkate alındığında- kişinin örgütün hiyerarşik yapısına bilerek ve isteyerek dâhil olduğunun yeterli bir gerekçe ile ispat edilmesi şarttır. Klasik ceza hukukunda ispat, geçmişte meydana gelmiş bir olayın gerçek yönünü ortaya koyma ve kişilerde bu konuda bir kanaat oluşturma faaliyeti olarak kabul edilmiştir. Mesele örgüt üyeliği olunca ispat, iddia makamınca ortaya konulan maddi olayların gerçekleşip gerçekleşmediğinin yanı sıra söz konusu

suçun unsurlarının, nedensellik bağının, failin kusur yeteneğinin ve kastının onun örgüt üyesi olduğunu gösterip göstermediği olacaktır.” (pn. 67)

*“... bir kişinin terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılması için **örgüt faaliyeti çerçevesindeki eylemleri süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk göstermelidir. O hâlde her biri örgüt üyeliğine ilişkin bir parçayı açıklayan ve delil olarak kabul edilen faaliyetlerin birleştirilerek olayın bütününe anlaşılması sağlanmalıdır. Kişilerin terör örgütünün hiyerarşik yapısına dâhil olduğunu gösteren delillerin birlikte incelenmesi sonucunda delillerin sağlamlığı sınanmalı; her biri her terör örgütünün amacı, niteliği, bilinirliği, kullandığı şiddetin türü ve yoğunluğu ile somut olayın ilgili diğer koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Kişilerin delil olarak kabul edilen faaliyetleri birbiriyle sınanmalı ve sağlamaları yapılarak birbirlerini tamamlayıp tamamlamadığı ve tutarsızlık içerip içermediği tespit edilmelidir.” (pn. 72)***

V. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2.7.2019 tarihli ve E. 2019/9.MD-312, K. 2019/514 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; pek çok yerde **Cumhuriyet savcısı**, ardından sırasıyla **Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Üyesi, Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Üyesi** olarak görev yapmış olan bir kişi, “**silahlı terör örgütü üyesi**” olmaktan dolayı cezaya mahkûm edilmiştir.

Bir Hukuk Devletinde yaşama ülküsüne sahip olan Milletimizin istisnasız her bireyi bakımından kaygı verici bir durumla karşı karşıyayız.

Bu açıklamalar, mahkûm edilen kişinin Yargıtay Üyesi olarak herhangi bir suç işlemediği yönünde bir tezkiyeyi asla ifade etmemektedir.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde **Yargıtay Üyesi** olarak görev yapan bir kişinin **terör**le ilişkilendirilerek suçlanması, asla kabul edilebilir bir durum değildir. Başka bir ifadeyle, Yargıtay Üyesi olarak görev yapmış olan bir kişi, asla terör örgütü üyesi olarak suçlanamaz.

Bir Yargıtay Üyesinin göreviyle bağlantılı fiilleri dolayısıyla, bir terör suçuyla ilişkilendirilebileceği tek bir istisna olabilir. O da, Anayasal düzeni cebren değiştirmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya (“darbeye”) teşebbüs suçuna iştirak etmiş olmak, bu “darbe” teşebbüsü bağlamında bir görev üstlenmiş olmak, olabilir.

EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE

Sosyal, siyasi veya dini saiklerle oluşmuş değişik biçimlerdeki örgütsel yapılar, zaman içinde suç örgütüne veya terör örgütüne evrilebilir. Ancak bir örgütsel yapının suç veya terör örgütü olduğunun kabul edilebilmesi için, mutlaka bu yapının faaliyeti çerçevesinde birtakım suçların işlenmesi gerekir. Bir örgütsel yapının içinde herhangi bir suç işlenmesi, bu yapının aleltilak suç örgütü olarak kabul edilmesi için yeterli değildir. Bunun için, **örgütsel yapı içindeki hiyerarşik ilişkinin suç işlemek amacına yönelik olması ve bu çerçevede bir işlev görmesi gerekir**. Bu nedenledir ki, Kanunda “*örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi*” ibaresine yer verilmiştir (TCK, m. 220, f. 4).

Suç örgütü kurma veya yönetme ya da suç örgütüne üye olma suçlarından dolayı sorumluluk için, başka somut bir suçun işlenmesine gerek bulunmamaktadır. Zira, söz konusu suçlar, birer **somut tehlike suçlarıdır**. Ancak, bir örgütsel yapının suç örgütüne evrilmesi, bir maddi vakıa sorunudur. Aksi takdirde, salt niyet ve amaçtan hareketle, bir yapının suç örgütü olarak nitelendirilmesi yoluna gidilebilir ki, bu yaklaşım, düşünceyi açıklama ve örgütlenme hürriyeti bakımından büyük sakıncalar ortaya çıkaran bir uygulamaya sebebiyet verir.

Keza, bir örgütsel yapının mesela Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıyla suç örgütüne evrildiğini kabul etmenin ve bu karar tarihleri itibarıyla bir terör örgütünün kabulünün de yargı faaliyeti bakımından hiçbir öneminin bulunmadığını önemle vurgulamam gerekir.

Bir maddi vakıa sorunu olduğu için, ancak somut birtakım suçlardan hareketle, bir örgütsel yapının suç örgütüne evrildiğini kabul etmek mümkün olabilir. Bu kabul, sorumluluk bağlamında da sınırlayıcı bir etki doğurmaktadır. Somut suçlardan hareketle, bir örgütsel yapının suç örgütüne evrildiğinin kabulü halinde, evrilme öncesinde bu örgütsel yapı ile bir şekilde irtibat içinde olan kişilerin ceza sorumluluğunun olup olmadığını tartışma dışı bırakmak mümkün olabilir. Bu evrilme olgusu göz ardı edildiğinde, bu suç örgütünün bidayetini belirleme sorunu ile karşı karşıya kalınmış olur.

Suç örgütünün bidayetinin belirsizliği sorunu, **toplumda travma** etkisi meydana getiren bir uygulamaya sebebiyet vermiştir.

Konular **hukuk zemininde** ele alındığı takdirde, hiçbir “çözumsuz” sosyal sorundan söz etmek mümkün değildir.

Yargıtay'ın geliştirdiği içtihatlarda, suç işleme kastı olmaksızın hareket eden kişilerin fiilleri, bidayette “cemaat” veya “hizmet hareketi” olarak isimlendirilen ve bilahare “terör örgütü” olarak ilan ve kabul edilen malum örgütsel yapıyla ilişkileri dolayısıyla, “terör örgütüne yardım” (!?) olarak değerlendirilmiştir¹⁶⁹.

¹⁶⁹ “... örgüt liderinin talimatı doğrultusunda örgütle irtibatlı Bank Asya'daki hesabına para yatan sanığın eylemi.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **25.4.2018**, E. 2018/281, K. 2018/931; Yargıtay 16. CD, **26.9.2018**, E. 2017/3180, K. 2018/2858; Yargıtay 16. CD, **9.10.2018**, E. 2017/3677, K. 2018/3196; Yargıtay 16. CD, **10.10.2018**, E. 2017/3568, K. 2018/3276; Yargıtay 16. CD, **12.11.2018**, E. 2017/3948, K. 2018/4107; Yargıtay 16. CD, **12.11.2018**, E. 2018/1316, K. 2018/4092; Yargıtay 16. CD, **20.11.2018**, E. 2018/1902, K. 2018/4369; Yargıtay 16. CD, **21.11.2018**, E. 2018/1638, K. 2018/4420; Yargıtay 16. CD, **23.1.2019**, E. 2018/1512, K. 2019/370; Yargıtay 16. CD, **5.3.2019**, E. 2018/6423, K. 2019/1449; Yargıtay 16. CD, **24.6.2019**, E. 2018/5862, K. 2019/4413; Yargıtay 16. CD, **27.11.2019**, E. 2019/4294, K. 2019/7267; Yargıtay 16. CD, **18.12.2019**, E. 2019/8209, K. 2019/8039. Ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **1.11.2017**, E. 2017/1864, K. 2017/5865; Yargıtay 16. CD, **20.12.2017**, E. 2017/1862, K. 2017/5796; Yargıtay 16. CD, **15.3.2018**, E. 2017/3730, K. 2018/780; Yargıtay 16. CD, **15.10.2019**, E. 2019/1396, K. 2019/6115; Yargıtay 16. CD, **30.4.2020**, E. 2020/399, K. 2020/2066; Yargıtay 16. CD, **14.7.2020**, E. 2018/3564, K. 2020/3642; Yargıtay 16. CD, **23.9.2020**, E. 2020/4766, K. 2020/4306.

Dikkat edilmelidir ki, bu fiillerin işlendiği sırada, söz konusu banka, Türkiye’de devletin gözetim ve denetimi altında faaliyet icra etmeye devam etmektedir.

“... örgüt liderinin talimatı doğrultusunda örgütle irtibatlı Bank Asya'daki hesabına para yatan ve FETÖ terör örgütüne müzahir KOGİAD'a üye kazandıran sanığın eylemi.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **12.11.2018**, E. 2017/3938, K. 2018/4105.

“Örgüte müzahir kurumlarda öğretmen olarak çalışan sanığın, örgüt liderinin talimatı sonrasında 12.09.2014 tarihinde Şeker Bank A.Ş.den 10.000 TL kredi çekerek aynı gün eşi ...'in Asya Katılım Bankası A.Ş.deki hesabına 9.698 TL para yatırmak ve kurban bağıışı adı altında para vermekten ibaret eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **28.11.2018**, E. 2018/4114, K. 2018/4652.

“Örgüte müzahir kurumlarda öğretmen olarak çalışan sanığın, örgüt liderinin talimatı sonrasında dosyada mevcut rapora göre 22.01.2014 tarihinde Garanti Bankası A.Ş.den 12.500 TL ve 06.02.2015 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.den 10.000.-TL bireysel ihtiyaç kredileri çekerek 23.01.2014 tarihinde 12.285.-TL, 06.02.2015 tarihinde 9.915.TL olarak Asya Katılım Bankası A.Ş.deki hesabına para yatırmaktan ibaret eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **14.3.2019**, E. 2018/1672, K. 2019/1773.

“... örgüt liderinin talimatı doğrultusunda anılan örgütle irtibatlı Bank Asya'ya 2014 ve 2015 yılları içerisinde katılım hesabı açtırarak para yatırdığı ve örgütle irtibatlı Aktif-Sen'e üye olduğu ... tespit edilen sanığın ... faaliyetleri.. yardım suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **29.3.2018**, E. 2017/4046, K. 2018/931. Ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **17.4.2019**, E. 2018/2860, K. 2019/2706.

“FETÖ ile iltisaklı “... İşadamları ve Turizmciler Derneği” üyesi olmak dışında başkaca örgütsel faaliyeti bulunmayan sanığın FETÖ ile iltisaklı ... Eğitim Kurumları Yayıncılık Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'ne herhangi bedel ödemeksizin ortak olması ve örgütün görünen yüzü ortaya çıktığında da ortaklığa devam edip ancak 24.12.2015 tarihinde sahip olduğu %25 hissesini devretmesi nazara alındığında eylemi.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **2.7.2019**, E. 2018/7312, K. 2019/4638.

“Üçüncü şahıslara ilişkin Bylock mesajlaşmalarında örgüt ile ilgili davalarda görüşülmesi gereken avukat olarak bahsedilen sanığın, örgüt liderinin talimatı doğrultusunda örgüte müzahir Bank Asya nezdindeki hesabına Ocak 2014 tarihi itibarıyla 80.000TL para yatırmaktan ve örgüt ile iltisakı nedeniyle kapatılan Hukuk ve Yaşam Derneği başkan yardımcılığı yapmaktan ibaret eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **3.7.2019**, E. 2019/1486, K. 2019/4719.

“... hayvancılıkla uğraşan ve kar payı almadığını söyleyen sanığın, örgüt ile ilgili ceza soruşturmalarında muhtemel el koyma işlemlerinin engellenmesini teminen görünür yasalılık oluşturmak suretiyle örgütün Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu Hisar Özel Eğitim Kurumları A.Ş.'nin kurucu ortağı sıfatı ile 1998-2016 yılları arasında hisselerini elinde bulundurmaktan ibaret eylemi.. örgüte yardım suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **3.10.2019**, E. 2018/1286, K. 2019/5759.

Sanığın “... FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı ... A.Ş'deki bir kısım hisseleri bedel ödemeksizin devir alması ve örgüt liderinin talimatı doğrultusunda örgüt ile irtibatlı Bank Asya'daki hesabına para yatırması şeklinde gerçekleşen eylemleri.. örgüte yardım suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **20.3.2019**, E. 2018/2882, K. 2019/1926.

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait öğrenci yurtlarının bağlı bulunduğu şirket hisselerini, muhtemel ceza soruşturması ya da kovuşturması kapsamında el koyma veya müsadere işlemlerini engellemek amacıyla usulen uhdesinde bulundurmamak, örgüt ile iltisaklı derneğe üye olmak ve örgüt liderinin talimatı üzerine BankAsya'ya para yatırmaktan ibaret eylemleri.. anılan örgüte yardım suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **27.12.2019**, E. 2019/5533, K. 2019/8459.

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Erdek Gelişim Turizm Özel Eğitim Öğretim Gıda Temizlik İnşaat Yay. Tic. A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan, örgütün görünen yüzü ortaya çıktıktan sonra da ortaklığını devam ettiren ve daha önceki tarihlerde de örgütün toplantısına katıldığını beyan eden sanığın, adı geçen şirket üzerindeki taşınmazlardan birini devletin el koyacağı endişesi ile üzerine alması ve aynı şirketteki hisselerini 07.04.2016 tarihinde bedel ödemeksizin ilçe imamı olan diğer sanık ...'ya devir etmesi şeklinde gerçekleşen eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **30.9.2019**, E. 2019/1329, K. 2019/5631.

“... sanığın, terör örgütü ile irtibatlı Ufuk Sağlık-SEN isimli sendikaya üye olmak, HTS kayıtlarına göre 2012 yılında örgütün üst düzey yöneticilerinden birisi ile bir kez telefon görüşmesi yapmak ve Bank Asya'da FETÖ/PDY terör örgütü liderinin talimatı üzerine iki adet katılım hesabı açmak ve para yatırmaktan ibaret eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **9.9.2019**, E. 2018/1293, K. 2019/5095.

“... örgüt ile irtibatlı olduğu için kapatılmasına karar verilen sendikaya üye olan, örgüt liderinin talimatı doğrultusunda anılan örgüt ile irtibatlı Bank Asya'da katılım hesapları açtıran sanığın faaliyetleri.. yardım suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **16.9.2020**, E. 2020/2108, K. 2020/4071.

“... örgüt liderini yücelten ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünü tiyatro olarak gören açıklamalarda bulunan sanığın, örgüt liderinin talimatı doğrultusunda örgüt ile irtibatlı Bank Asya'daki hesabına para yatırmak ve 2015 yılına kadar müzahir gazete ve dergilerin dağıtımını yapmaktan ibaret eylemleri.. örgüte yardım etme suçunu” oluşturur: Yargıtay 16. CD, **9.10.2019**, E. 2019/1796, K. 2019/5919.

“Sanığın FETÖ/PDY'nin terör örgütü olarak ortaya çıkmasından çok önceki (2006 ve öncesi) tarihlerde bazı sohbet toplantılarına katılmak, 2014 yılı sonrasında ise bu örgüt ile iltisaklı bulunan dernek üyeliği, örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bankasya'ya para yatırmak ve örgüte sempati gösteren bazı sosyal medya paylaşımlarında bulunmak şeklindeki fiillerinin, örgüt hiyerarşisine dahil olduğunu gösterecek şekilde devamlılık, çeşitlilik ve yoğunluk içer-

Bir örgütsel yapının suç örgütüne evrilebilmesi için, bu yapının faaliyeti olarak suç işlenmesinin amaçlanması ve bu örgütün faaliyeti çerçevesinde somut suçların işlenmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, bir örgütsel yapının suç örgütü vasfını taşıyıp taşımadığını, faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan hareketle belirlemek gerekir. Bu itibarla, bu bağlamda izlenmesi gereken yöntem, **tümevarım yöntemi**dir.

Oysa hukuk uygulamamızda, **tümdengelim yöntemi** izlenmektedir. Buna göre, önce bir örgütsel yapının varlığı ve bu yapının suç örgütü vasfını kazandığı kabul edildikten sonra, somut birtakım suçların işlendiğinden söz edilmektedir. Bu yanlış yöntemin izlenmesiyle, aslında bir örgütsel yapının faaliyeti çerçevesinde herhangi somut bir suç işlenmediği halde veya işlenen somut birtakım suçların bir örgütsel yapının faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediği somut delillere dayalı olarak, somut dayanakları gösterilerek ortaya konmadan, bu örgütsel yapıya suç veya terör örgütü vasfı izafe edilebilmektedir.

memesi karşısında,” örgüt üyeliğinden dolayı değil, örgüte yardım etmek suçundan dolayı sorumluluğu yoluna gidilmesi gerekir: Yargıtay 16. CD, 23.1.2020, E. 2019/6091, K. 2020/598.

Bütün bunlara karşılık; sanıklar X ve Y’nin “çocuklarını örgütle iltisaklı okula göndermesi ve Zaman gazetesine abone olma eylemleri... müsnet (terör örgütü üyeliği) suç(u) yönünden delil ya da örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyece”ktir: Yargıtay 16. CD, 11.3.2020, E. 2019/501, K. 2020/1954.

Keza, “sanıkların örgüte müzahir Ufuk Büro Sendikası ile Aksaray Memurlar Yardımlaşma Derneği’ne üye olmak ve Zaman gazetesine abone olmaktan ibaret eylemleri.. (ve ayrıca,) örgütle irtibatlı Bank Asya nezdinde, açılış tarihleri itibarıyla örgütsel bir özellik göstermeyen hareketsiz hesap açtırmaları.. müsnet örgüt üyesi olmak ya da örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu” oluşturmaz: Yargıtay 16. CD, 19.10.2020, E. 2019/5604, K. 2020/5065.

EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE

Hukuk sistemimizde kolluk ve hatta herkes, suç şüphesi altında bulunan kişiyi belirli şartlarda yakalama yetkisi ile donatılmıştır.

Suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi bulunmaktadır.

Kolluk da herkes gibi, suçüstü halinde yakalama yetkisini haizdir.

Kolluk, herkesten farklı olarak, suçüstü hali olmadan da yakalama yetkisini haizdir.

Bunun için;

- a) Tutuklama kararı veya yakalama emri verilmesini gerektiren bir durumun mevcut olması gerekir.
- b) Kolluğun, Cumhuriyet savcısına veya hakime derhal başvurma imkanının olmaması gerekir.

Buna göre kolluk, normalde bu yetkisini Cumhuriyet savcısının yakalama emrine veya hakimin yakalama kararına binaen kullanır.

Ancak bazı durumlarda, kolluk Cumhuriyet savcısının emri veya hakimin kararı olmadan da bu yetkiyi kullanabilir (CMK, m. 90, f. 2).

Örneğin suçüstü hali olmamakla birlikte, belirli bir suçu işlediğinden şüphelenilen ve fakat kim olduğu henüz tespit edilememiş olan bir kişinin re’sen yakalanması kolluk bakımından bir görevdir.

Ancak belirtmek gerekir ki, aktüel uygulamamızda örgüt üyeliği suçlamasında bulunulan kişilerle ilgili olarak da suçüstü hali gerekçesiyle yakalama gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama ile, özellikle soruşturma ve kovuşturmasıyla ilgili olarak Kanunlarda özel hükümlerin vazedildiği yüksek düzeydeki kamu görevlileri bakımından çeşitli koruma tedbirlerine başvurabilmenin yolu açılmış olmaktadır. Bu uygulamayı yapanlar, kesintisiz (mütemadi) suç kavramı ile suçüstü halini birbirine karıştırmaktadır.

Bir olayda hem mütemadi suç hem de suçüstü hali birleşebilir. Örneğin mağduru hürriyetinden yoksun tutmaya devam ettiğine muttali olunan kişi bakımından herkesin yakalama yetkisi bulunmaktadır.

Örgüt üyeliği bir mütemadi (kesintisiz) suçtur; ancak bu suç bakımından alelittlak suçüstü hali söz konusu değildir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, davet edildiğinde bu davete icabet edecek olan kişilerle ilgili olarak yakalama veya zorla getirme kararı verilemez.

Dikkat edilmelidir ki, “terör örgütü üyeliği” suçundan dolayı suçüstü hali gerekçesiyle yapılan yakalamalar, salt kolluğun yanlışı değildir. Yakalama üzerine, hemen Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesi ve emirleri doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir (CMK, m. 90, f. 5). Bu itibarla, söz konusu uygulamalar, yargının tasvibiyle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yakalanan kişiler hakkında salt “terör örgütü üyeliği” suçlamasına dayalı olarak verilen tutuklama kararlarıyla uygulamanın bu yanlışı “görünmez” kılınmaktadır¹⁷⁰.

Bu uygulama, haklarında soruşturma yapılması hususunda ilgili kanunlarda özel hükümler vaz’edilmiş olmasına rağmen, “terör örgütü üyeliği” ile suçlanan üst düzey kamu görevlileri bakımından geliştirilmiş bulunmaktadır.

Yarın, haklarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin soruşturma kararı verilmesini gerektiren siyasiler bakımından da bu uygulamanın sürdürülme girişiminde bulunulabileceği öngörüsünün, bir kehanet olmaması gerekir.

¹⁷⁰ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu** da son tarihlerde verdiği müteaddit kararlarında kesintisiz (mütemadi) suç kavramı ile suçüstü halini birbirine karıştırarak, “silahlı terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli konumunda bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarını yakalandıkları anda “ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâli”nin mevcut olduğu” değerlendirmesinde bulunmuştur: CGK, **2.7.2019**, E. 2019/9.MD-312, K. 2019/514; CGK, **16.1.2018**, E. 2017/YYB-1148, K. 2018/15; CGK, **16.1.2018**, E. 2017/YYB-1143, K. 2018/14; CGK, **16.1.2018**, E. 2017/YYB-1134, K. 2018/13; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1129, K. 2017/533; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1128, K. 2017/532; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1120, K. 2017/531; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1113, K. 2017/530; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1112, K. 2017/529; CGK, **12.12.2017**, E. 2017/YYB-1013, K. 2017/528; CGK, **28.11.2017**, E. 2017/YYB-1099, K. 2017/508; CGK, **28.11.2017**, E. 2017/YYB-1096, K. 2017/507; CGK, **28.11.2017**, E. 2017/YYB-1095, K. 2017/506; CGK, **28.11.2017**, E. 2017/YYB-1094, K. 2017/505; CGK, **28.11.2017**, E. 2017/YYB-1093, K. 2017/504; CGK, **14.11.2017**, E. 2017/YYB-1079, K. 2017/474; CGK, **14.11.2017**, E. 2017/YYB-1068, K. 2017/473; CGK, **14.11.2017**, E. 2017/YYB-1058, K. 2017/472; CGK, **14.11.2017**, E. 2017/YYB-1075, K. 2017/471.

EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU

15 Temmuz 2016 tarihli “darbe teşebbüsü” suçunun işlenmesi dolayısıyla ilân edilen olağanüstü hal sürecinde yapılan kanuni düzenlemelerle, bu süreçte görev yapan kişilerle ilgili olarak **ceza hukuku bakımından sorumsuzluk** hükümlerine yer verilmiştir.

22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sını kanunlaştıran 18.10.2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunun 9. maddesinde şu hükme yer verilmiştir:

“Bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

Ayrıca, 8.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanununla aşağıdaki şekilde bir düzenleme yapılmıştır (m. 37):

“15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

Söz konusu maddeye 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile (m. 121) ile aşağıdaki **ikinci fıkra** eklenmiş ve bu düzenleme, söz konusu KHK’yi kanunlaştıran 1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunla (m. 113) aynen kabul edilmiştir:

“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Keza, söz konusu maddeye 5.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunla (m. 50) aşağıdaki **üçüncü fıkra** eklenmiştir:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum ve-

ya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve filleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

Bu düzenlemeler karşısında, aşağıda örnek olarak verilen işlemleri yapan veya uygulamaları gerçekleştiren kamu görevlilerinin **ceza hukuku sorumluluğu doğmayacaktır**¹⁷¹.

¹⁷¹ Söz konusu Kanun dışında çeşitli kanunlarda ve KHK’lerde benzer hükümlere yer verilmiştir:

I- 4734 sayılı **Kamu İhale Kanununda** 678 ve 684 s. OHAL KHK’leri ile yapılan değişiklikle, söz konusu Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent (g bendi) eklenmiştir. Bu bent hükmüne göre, “*Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler*”, kamu ihalelerinden yasaklanmaktadır. Buna göre, adli soruşturmaya konu edilmesine gerek olmadan, polis raporuna istinaden bir gerçek veya tüzel kişi, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanabilecektir.

Söz konusu Kanunun 11. maddesinin beşinci fıkrasına, 680 s. OHAL KHK’si ile yeni bir cümle eklenmiştir. Buna göre, adli soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmesine gerek olmadan, bir gerçek veya tüzel kişi ile ilgili olarak “*terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatı*” bulunduğu yönünde kamu kurumlarına bildirimde bulunan emniyet görevlileri ile, buna istinaden bildirim konusu gerçek veya tüzel kişiyi ihaleden meneden sair kamu görevlileri hakkında **ceza sorumluluğu doğmayacaktır**.

II- PKK terörünü sonlandırmak amacıyla başlatılan “**çözüm süreci**”nde 10.7.2014 tarihli ve 6551 sayılı “**Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun**”la Hükümete;

“a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirle(mek);

b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar ver(mek) ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendir(mek);

c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri al(mak)”

hususlarında yetki verilmiştir (m. 2, f. 1). Yine söz konusu Kanunun 4. maddesinde, bu çerçevede verilen “*görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz*” hükmüne yer verilmiştir (f. 2).

Buna göre, malum “**çözüm süreci**”nde, giydikleri üniforma görüntüsü arz eden kıyafetler ve hatta üzerlerinde taşıdıkları silahlar itibarıyla PKK terör örgütünün mensubu oldukları açıkça anlaşılan kişilerin, yurt dışına çıkmakta oldukları gerekçesiyle yakalanmaması yönünde talimat veren ve bu talimata uyarak, suçüstü haline rağmen, bu kişileri yakalamaktan sarfinazar eden kamu görevlileri **ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamayacaklardır**.

III- “**Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu**”nın kurulmasına ilişkin hükümleri içeren 685 s. OHAL KHK’sinin 4. maddesinin üçüncü fıkrası, 690 s.

Örnek 1. Olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylara katıldığı veya terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve bu çerçevede yakalanan kişi, gözaltına alındıktan sonra, gözaltı sürelerinin dolmasına rağmen, tutuklanma talebiyle hakim önüne çıkarılmayıp, içeride tutulmaya devam eder.

Örnek 2. Herhangi bir merciden izin ve karar almadan, olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylara katıldığından veya terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kişinin evine ve işyerine girilerek arama yapılır.

Örnek 3. Olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylara katıldığı veya terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişi, avukat yardımından yararlanmak istemesine rağmen, avukatı ile görüştürülmez.

Örnek 4. Olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylara katıldığı veya terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişinin soruşturma dosyası hiçbir şekilde avukatına gösterilmez ve dosyadan herhangi bir belgenin fotokopisini almasına izin verilmez.

Örnek 5. Hakkında herhangi bir suçtan dolayı adli soruşturma bulunmayan ve dolayısıyla, adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmemiş olan bir kişi, pasaportu mevcut olmasına rağmen, yurt dışına çıkışına izin verilmeyerek, sınır kapısından geri çevrilir.

Örnek 6. Olağanüstü halin ilanına sebebiyet veren olaylara katıldığı veya terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişi, işkenceye maruz bırakılır.

Örnek 7. Talep ve hatta karar tarihi itibarıyla hakkında herhangi bir suçtan dolayı adli ve idari soruşturma açılmamış olan bir kamu görevlisinin “*terör örgütüne iltisakı*” olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden çıkarılması talebinde bulunulur ve bu talep doğrultusunda kişi kamu görevinden çıkarılır.

Örnek 8. Terör örgütüne finans sağladığı şüphesiyle, bir şirketin yönetimine kayyım tayin edilir. Tayin edilen kayyımlar, şirketin mallarını haraç mezat satarlar.

OHAL KHK’si (ve bilahare Bu KHK’nin kabu edilmesine dair 1.2.2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanun) ile dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

*“Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin **hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları** hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.”*

Söz konusu düzenlemeyle yeni bir hukuka uygunluk sebebi ihdas edilmiş değildir. Yine söz konusu düzenlemeyle ceza hukuku bakımından sorumsuzluk, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen ve dolayısıyla, herhangi bir suç oluşturmayan fiillere inhisar ettirilmemiştir.

Söz konusu düzenleme ile, bu düzenleme kapsamına giren **fiillerin**, yapılan **işlemlerin** ve gerçekleştirilen **uygulamaların hukuka uygun olup olmadığına ve hatta suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın, faillerinin cezalandırılmaması amaçlanmıştır.**

Söz konusu düzenleme, kapsamına giren fiiller, yapılan işlemler ve gerçekleştirilen uygulamalar bağlamında, kamu görevlilerinin kusurluluğunu da ortadan kaldıran bir mahiyet taşımamaktadır. Başka bir ifadeyle, tahdidi olmaksızın yukarıda örnek olarak gösterilen ve bu düzenlemenin kapsamına girdiği belirtilen olaylarda, kamu görevlileri, kasten hareket etmiş olsalar bile, ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamayacaklardır. Kamu görevlilerinin, konusu suç oluşturan bu fiiller dolayısıyla kusurluluğunu ortadan kaldıran herhangi bir sebep mevcut değildir. Başka bir ifadeyle, kamu görevlileri, bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olmasına ve davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinin bulunmasına rağmen, suç oluşturan bu örnek fiillerden herhangi birini işlemesi halinde ceza hukuku sorumluluğu doğmayacaktır.

Bir sorumsuzluk hükmü içeren söz konusu düzenleme, bir **şahsi cezasızlık sebebi** mahiyeti taşımaktadır. İşlenen fiil, yapılan işlem, gerçekleştirilen uygulama esas itibarıyla suç oluştursa bile, olağanüstü hal döneminde uygulama tereddütlerini ortadan kaldırmak ve birer “**kurşun asker**” gibi “görev” ifa etmelerini sağlamak düşüncesiyle, kamu görevlileri bakımından kabul edilmiş olan bu sorumsuzluk hükmü, mahiyeti itibarıyla bir maddî ceza hukuku hükmüdür.

Söz konusu hükmün bu özelliği, sorumsuzluk kapsamına giren fiiller, işlem ve tasarruflar sebebiyle herhangi bir şekilde dava açılmış olması halinde verilecek karar bakımından önem taşımaktadır. Şöyle ki, örneğin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı açılmış olan davada mahkeme, fiilin söz konusu sorumsuzluk hükmü kapsamına girdiğini tespit etmesi halinde, CMK, m. 223, f. 4, bent b hükmü gereğince, sanık hakkında **ceza ve-rilmesine yer olmadığı kararı** verecektir.

Söz konusu kanun hükmünün **Anayasaya aykırı** olduğunu belirtmek gerekir. Suç işleyen kişiye, işlediği iddia edilen suçtan dolayı hakkında soruş-

turma ve kovuşturma yapılmasını engellemek ve ceza yaptırımını uygulanmasının önüne geçmek suretiyle imtiyaz tanınmasını sağlayan bu hükmün anayasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından **iptal** edilmesi yönünde yoğun bir beklentimiz bulunmaktaydı. Ancak, Anayasa Mahkemesi söz konusu hükümlerle ilgili olarak açılan iptal davalarını reddederek, bu beklentimizi boşa çıkarmıştır.

Anayasa Mahkemesi, 18.10.2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunun 9. maddesindeki hükmünün iptali talebiyle açılan davayı aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir:

“131. Kurala göre 6749 sayılı Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır. Kanun’da belirtilen söz konusu karar ve görevler incelendiğinde bunların olağanüstü halin ilanına neden olan koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin olarak verilen kanuni yetkilerin icra edilmesinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

*132. Kanunların verdiği yetkinin kullanılması ya da kanunlarca verilen görevlerin yerine getirilmesi veya bu kapsamda kararlar alınması, hukuk sistemimizce **hukuka uygunluk nedeni** olarak kabul edilmiştir. Bir fiilin hukuka uygunluğu onun hukuk sisteminin tamamıyla uyumlu olduğunu gösterir. Bu durum hukukun bütünlüğü ilkesinin bir sonucudur. Bu nedenle hukuka uygun bir fiil nedeniyle onu icra edenlerin sorumluluğu söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle hukuka uygun bir fiili gerçekleştirenlere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenebilir. Kanunla verilmiş olan bir görevin yerine getirilmesi ya da bu kapsamda bir karar alınması, kişiye verilmiş bir görevken aynı zamanda bu görevin yerine getirilmesinin hukuka aykırılık oluşturması çelişkiye sebep olur. Bu nedenle kişilerin kanunlarca verilmiş olan görevleri kanuni usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması tabiidir.*

133. Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında vurguladığı üzere demokratik ülkelerde olağanüstü yönetim usulleri hukuku dışlayan, keyfî yönetim anlamına gelmez. Olağanüstü yönetimler kaynağını Anayasa’da bulan, anayasal kurallara göre yürürlüğe konulan, yasama ve yargı organlarının denetiminde varlıklarını sürdüren rejimlerdir.

134. Bu bağlamda **kural bir yargılama engeli getirmemektedir**. Haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği ya da görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını aştığının tespit edilmesi hâlinde sorumluluk gündeme gelecektir. Kanun'da belirtilen **kişilere hukuka aykırı, haksız fiil veya suç işleme görev veya yetkisinin verilmediği ve verilemeyeceği** açık olduğuna göre **kuralın haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı** tartışmasızdır.

135. Dava konusu kuralın düzenlenme ihtiyacının, Kanun'da verilen görevlerin niteliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu görevlerin önemli bir kısmı olağanüstü hal dönemiyle sınırlı ve olağanüstü hâlde alınması gereken, dolayısıyla olağan dönemin hukuki düzenlemelerinden oldukça farklı olan tedbirlerin icrasına yöneliktir. Bu tedbirlerin anılan niteliği dikkate alındığında bunlara ilişkin olarak verilen görevlerin etkili biçimde uygulanması hususunda tereddüt oluşabilir. Bu bağlamda dava konusu kuralla kanun koyucunun olağanüstü hâlin sebeplerinin ortadan kaldırılmasında görevlilerin çalışmalarında başarılı olmalarını, çekinmeden görev yapmalarını ve bu suretle bir an önce olağan döneme geçilmesini amaçladığı anlaşılmaktadır.

136. Öte yandan kuralla Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin yerine getirdikleri görev ve kararları nedeniyle sorumlu tutulmamalarının nedeni bu kişilerin haksız fiil veya suç teşkil eden eylemlerine hukuki ve cezai bağışıklık tanıyarak bunlara kendileriyle aynı durumda bulunan kişilere nazaran özel bir imtiyaz ve ayrıcalık tanımak değildir. Bunun nedeni olağanüstü hal dönemiyle sınırlı ve olağanüstü halde alınması gereken dolayısıyla olağan dönemin hukuki düzenlemelerinden oldukça farklı olan tedbirlerin icrasına yönelik görevlerin herhangi bir endişe ve tereddüt duyulmadan yerine getirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla söz konusu kuralın eşitlik ilkesini zedeleyen bir yönü bulunmamaktadır.”¹⁷²

Anayasa Mahkemesi, yine, 6755 sayılı Kanunun yukarıda iktibas edilen 37. maddesinin **ikinci fıkrası** hükmünün iptali talebiyle açılan davayı aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir:

¹⁷² Anayasa Mahkemesi, 24.7.2019, E. 2016/205, K. 2019/63 (RG: 31 Ekim 2019/30934).

“30. Bu çerçevede dava konusu kuralda darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamındaki fiillerinden dolayı kişilerin hukuki, idari, malî ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı belirtilmiş olup **kuralın** bu kapsamda olmayan, **konusu haksız fiil ya da suç teşkil eden fiillerin icra edilmesi hâlinde sorumsuzluk öngördüğü söylenemez.** Zira kuralın lafzı ile yukarıda belirtilen getiriliş amacı dikkate alındığında kuraldan böyle bir sonuç çıkarmak mümkün görünmemektedir.

31. Anayasa’ya uygunluk karinesi uyarınca **bir hukuk devletinde Kanun’da belirtilen kişilere hukuka aykırı, haksız fiil veya suç işleme görev veya yetkisinin verilemeyeceği** açık olduğuna göre bu yönüyle **da kuralın haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığının kabul edilmesi gerekir.** ...

32. Diğer taraftan, dava konusu **kuralın bir yargılama engeli getirmediğinin** de vurgulanması gerekir. ... iptali istenen kuralın atıf yaptığı dönemdeki fiillere ilişkin olarak bir suç ya da haksız fiilin söz konusu olduğunun iddia edildiği somut olaylarda **yargı makamları, bu fiillerin bastırma kapsamında olup olmadığını ve hukuka uygunluk nedenlerinin bulunup bulunmadığını dikkate alacaklardır.** Bu değerlendirme sonucunda fiile ilişkin varılan sonucun anılan kapsamda olmadığına veya bunun sınırlarını aştığının tespit edilmesi hâlinde sorumluluk gündeme gelecektir.”¹⁷³

Hemen belirtmek gerekir ki, söz konusu düzenlemelerin uygulama alanının hukuka uygun fiil ve tasarruflarla sınırlı olduğu söylenemez. Bu değerlendirmeyi saygıyla karşılarız. Ancak söz konusu düzenlemelerle murat edilenin bu olduğunu söylemek güçtür. Hukuka uygun fiil ve tasarruflarla ilgili olarak böyle bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı, izahtan varestedir.

Hukuk uygulamamızın, Anayasa Mahkemesinin bu değerlendirmeleriyle uyum içinde olmadığını belirtmemiz gerekir:

Malum “darbe teşebbüsü” sonrasında ilan edilen olağanüstü hal sürecindeki işkence iddiaları ile ilgili olarak etkin ve hatta alelittlak soruşturma yapılmadığı bir gerçektir. Bir devlet üniversitesinde **rektör** olarak görev yapan ve **terör örgütü “mensubu”** olduğu şüphesiyle tutuklanana bir öğretim üyesi-

¹⁷³ Anayasa Mahkemesi, 16.7.2020, E. 2018/31, K. 2020/38 (RG: 11 Kasım 2020/31301).

nin ceza infaz kurumundan şahsıma gönderdiği mektupta yer alan, 28 günlük gözaltı sürecinde yaşadıkları ile ilgili şu anlatımları dikkat çekicidir (metin aynen iktibas edilmiştir):

“... Saat 17.00’de başlayan işkence 6-8 saat sürekli şiddetli dayak ile devam etti. Binlerce küfür. Ana, avrat, kız sürekli küfür. 6-8 kişi alkol-lü polis bayıltıncaya kadar dövdüler. Bayılmışım, tüm mesanem boşalmış. Ayıldım yine dövdüler. Sövdüler 28 gün her gün hakaret, her gün küfür 10 m², ışksız, penceresiz yataksız, havasız taş sedirleri olan pis bir odada günde 3 defa 2 dk tuvalet izniyle yaşadım. Aç kaldım 1 haftada 9 kg kaybettim. İnsülinimi ilaçlarımı vermediler. ... 28 gün banyo izni vermediler. 10. gün sidikli pantolonu yalvar yakar değiştirdiler. Her gün küfür, her gün hakaret, her gün tehdit ölüm gibi 28 gün. 3-4 kez kalp spazmı geçirdim. 3-4 kez şeker düşmesi yaşadım. Uzman doktor hastaneye sevkimi önerdi. Koğuşta monitör bağlayıp 112’i başımda tuttular. Hastaneye sevk etmediler. ... Adım öldü diye çıkmış. Hatta kayıt defterine böyle yazılmış. Dr’ler söyledi. Ama ölmedim. ...”

Bu mektubun bana ulaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile görüştüm. Bir rektörün görevini kötüye kullandığı iddiasında bulunulabileceği, bir rektöre zimmet, irtikâp, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi göreviyle bağlantılı somut bir suçun isnat edilebileceği, ancak bir rektörün terörist olamayacağı, bunun tek istisnasının malum “darbe teşebbüsü” suçuna iştirak olabileceği, eğer bir rektörün terör örgütü “mensubu” olmakla suçlanmasına izin verilirse, yarın YÖK Başkanının da bu suçlama ile karşı karşıya bırakılabileceğinden kuşkunun olmaması gerektiği yönünde kendisine açıklamalarda bulundum. Sayın Başkan, aynı içerikte bir mektubun kendisine ve hatta Sayın Cumhurbaşkanına da gönderilmiş olduğu bilgisini bana verdi. Gönderilen mektupları, bunların aynı tarihli ve aynı kalemle yazılmış olduğunu, aralarında sadece muhatap alınan kişiye yapılan açıklamalar dolaşısıyla sayfa sayısı farkının bulunduğunu gördüm. Bu mektupların ceza infaz kurumu yetkililerinin kontrolünden geçmiş olmasına rağmen, bu iddialarla ilgili olarak bir soruşturma ve kovuşturma yapıldığına dair bir bilgiye henüz ulaşamamıştır.

Sonuç olarak belirtmemiz gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarında yer verilen **bu düzenlemelerin bir muhakeme engeli oluşturmadiğı** yönündeki açıklamalar, son derece önemlidir.

Ancak belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi, 6755 sayılı Kanunun yukarıda iktibas edilen 37. maddesinin **üçüncü fıkrası** hükmünün iptali talebiyle açılan davayı reddederken kararını, ilk iki fıkrasından farklı olarak bu fıkra hükümlerinin “**suç oluşturan fiilleri**” de kapsadığı kabulünden hareketle gerekçelendirme yoluna gitmiştir:

*“30. Dava konusu kural 31/10/2019 tarihine kadar belirli şartlardaki kişilere yönelik sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvurularda karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle cezai sorumluluklarının olmadığı düzenlenmektedir. **Kamu görevlisinin cezai sorumluluklarını gündeme getirecek karar ve fiiller ceza hukuku anlamında suç oluşturan fiillerdir.***

*31. Dava konusu kural geçmişteki belirli bir dönemi kapsamına almakta ve soruşturma başlamış olsun ya da olmasın veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olsun ya da olmasın kamu görevlilerinin anılan dönemdeki tüm karar ve işlemlerinden dolayı **herhangi bir cezai sorumluluklarının olmadığı** düzenlediğinden nitelik itibarıyla **genel af** düzenlemesidir.*

...

33. Öte yandan, kural aynı zamanda kapsamındaki kamu görevlilerinin kuralda belirtilen karar ve fiilleri nedeniyle idari sorumluluklarının olmadığı da öngörmektedir. ...

34. ... devletle kamu görevlisi arasında gerçekleşen disiplin hukukunun sonucu olan idari sorumluluğun ortadan kaldırılması kanun koyucunun takdirindedir.”¹⁷⁴

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün bir “**genel af**” düzenlemesi olduğunu kabul ederken, genel af mahiyetindeki kanuni düzenlemelerin kabulüyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda aranan **nitelikli çoğunluk** şartının (Anayasa, m. 87) bu hüküm bakımından gerçekleşmiş olup olmadığı hususunda tespit ve değerlendirmelerde bulunmamıştır.

¹⁷⁴ Anayasa Mahkemesi, **3.6.2021**, E. 2020/18, K. 2021/38 (RG: 23 Eylül 2021/31607).

EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE

I. Bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla el konulmuş olan şirket ortaklık paylarının müsaderesine hükmedilmelidir. Buna karşılık, suçtan elde edildiği sabit olmayan şirket ortaklık payları hiçbir surette müsadere edilemez. Bir şirketin faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçlar işlenmiş, bu suçların işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla önemli kazançlar elde edilmiş olabilir. Bu durumda, şirket veya ortakları tarafından **elde edilmiş olan kazançların** müsadere edilmesi gerektiği ve edileceği konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda müsadere edilmesi gereken şirketin ortaklık payları değil, şirketin malvarlığına dahil edilmiş olan kazanç olacaktır. Şayet şirketin suç işlemek suretiyle elde ettiği kazanç ortaklara kâr payı olarak dağıtılmış ve ortaklar da bu parayı şirket sermayesinin artırılmasında kullanmış ise, bu payların müsaderesine hükmedilebilir.

Şirket ortaklık paylarına el konulabilir. Bu el koyma ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda özel bir usul öngörülmüştür (m. 128, f. 6):

“Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.”

Ancak belirtmek gerekir ki, bilahare, 1.2.2018 tarihli ve 7076 sayılı Kanunla (RG: 8 Mart 2018/30354 Mükerrer) kanunlaştırılan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesine (RG: 9 Şubat 2017/29974) göre;

*“4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilip 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun İkinci Bölümü kapsamına giren suçlardan dolayı **müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı; bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tara-***

*fından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilir. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilir.” (7076 s. **Kanun**, m. 1).*

Bu düzenlemeye göre, **müsaderesine hükmedilen şirket ortaklık paylarının tasfiyesi**, daha genel bir ifadeyle, **şirket ortaklık paylarının müsaderesinin infazı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerçekleştirilecektir.**

Söz konusu Kanun hükmü, sadece olağanüstü hale özgü olarak uygulanabilecek olan bir hüküm değil; olağanüstü hal sona erdikten sonra da uygulanabilecek olan ve uygulanan genel bir düzenleme mahiyeti taşımaktadır.

Keza, **müsadere hükmünün infazına** ilişkin söz konusu hükmün, kapsamına giren suçlar sınırlı olmakla birlikte, **infaz usulüne** ilişkin olması itibarıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, insan ticareti ve fuhuş, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlar bakımından da **kıyas** yoluyla uygulanabilirliğini kabul etmek gerekir.

II. İşaret etmek gerekir ki, söz konusu düzenleme, sadece müsaderesine hükmedilen şirket ortaklık paylarının ne suretle tasfiye edileceğini değil, dolaylı bir şekilde, Türk Ceza Kanununun müsadere hükümlerinin uygulama alanını da Anayasa’nın 38. maddesi hükümlerine aykırı olarak genişletmektedir.

Söz konusu düzenlemeye göre, örneğin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsüne ilişkin birtakım hazırlıklar, bir şirket bünyesinde ve bu şirketin faaliyeti çerçevesinde icra edilmiş ise, şirket ortaklarının ortaklık paylarının da müsaderesine hükmedilebilecektir. Bu durumda şirket ortaklık paylarının müsaderesine hükmedebilmek için, bu payların sahibi olan şirket ortaklarının da söz konusu suçun işlenişine iştirak etmesi gerektiği kuşkusuzdur. Söz konusu istisnai düzenlemeye gerek olmadan da, TCK hükümlerine göre bu durumda şirket ortaklık paylarının müsaderesine hükmedilebileceği izahtan varestedir.

Ancak söz konusu düzenleme, örneğin terörizmin finansmanı suçunun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde de, bu şirkete ilişkin ortaklık paylarının müsaderesine hükmedilmesinin yolunu açmaktadır.

Bir terör faaliyetinde kullanılacağını bilerek (doğrudan kastla) ve bu amaçla teröre ve terörizme finansman sağlayan kişinin, sağlanan fon somut bir terör suçunun işlenmesinde henüz kullanılmış olmasa bile, cezalandırılması gerektiği, izahtan varestedir.

Ancak uygulamamız bakımından iki sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, **sağlanan fonun bir terör faaliyetinin ve herhangi bir suçun icrasında kullanılacağı hususundaki bilinç ve amaç sorunudur. İkincisi ise, bu fonun bir şirket üzerinden sağlanması halinde, şirket ortaklarının ortaklık paylarının müsadere edilebilirliği sorunudur.**

Şayet bir şirket terör örgütü mensupları tarafından kurulmuş ve sermayesi terör örgütünün kaynaklarından sağlanmış ise; şayet bir şirket, parasal kaynakları ve faaliyetleri itibarıyla teröre ve terör örgütüne **tahsis** edilmiş ise, bu durumda söz konusu şirketin bütün malvarlığının ve dolayısıyla, görüşünde kuşku bulunmamaktadır. Bunun için TCK'nın müsadereye ilişkin hükümlerinin alanının genişletmeye gerek bulunmamaktadır.

Ancak, 7076 s. Kanunla, bu koşullar aranmadan da şirket ortaklık paylarının müsaderesinin yolu açılmak suretiyle, **hukuk dışına çıkmıştır**¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Anayasa Mahkemesinin **12.11.2019** tarihli ve 2016/80432 bireysel başvuru sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Cumhuriyet Başsavcılığı 2/9/2016 tarihinde, silahlı terör örgütüne üye olma ile cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından haklarında soruşturma yürütülen başvurucu dâhil bazı şüphelilerin mal varlığı hakkında elkoyma tedbiri uygulanmasını talep etmiştir.

Talebi kabul eden Sulh Ceza Hâkimliğince, başvurucu ile diğer şüphelilerin **taşınmazları, hak ve alacakları ile vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, maaşlı çalışanların ise maaş hesaplarına** son aldıkları maaşları kadar paranın aylık harcamalar için kullanılmak üzere o ay içerisinde çekilmesine izin verildikten sonra arta kalan tutar üzerine **elkoyma tedbiri** uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kararda, şüphelilerin maaş hesabının olmaması veya maaş ödemesinin sona ermiş olması hâlinde, kendisi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu kişilere aylık toplam tutarı 3.500 TL'yi aşmamak kaydıyla ödeme yapılmasına izin vermiştir.

Başvurucu bu tedbir kararına itiraz etmiş ise de, bu itirazla ilgili olarak *“herhangi bir karar verilmemiştir”* (Bireysel başvuru kararı, Paragraf no. 17).

Başvurucu, 12.12.2016 tarihinde yaptığı başvuruda, bu elkoyma kararıyla mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Başvurucu hakkında **silahlı terör örgütüne üye olma** suçunu işlediği iddiasıyla kamu davasının açılması üzerine yapılan yargılama sonucunda mahkeme bu suçu işlediğini kabul ederek TCK, m. 314, f. 2 ve Terörle Mücadele Kanunu, m. 5 hükümlerine istinaden **6 yıl 3 ay hapis cezasına** hükmetmiştir. 30.3.2017 tarihinde verilen bu mahkûmiyet hükmü, 12.11.2019 tarihi itibarıyla kanun yolu denetimi devam ettiği için henüz kesinleşmemiştir.

Anayasa Mahkemesince başvurunun mal varlığı yönünden uygulanan tedbirin devam edip etmediğinin sorulması üzerine, Mahkemece gönderilen cevabi yazıda, başvurunun mal varlığına konulan tedbirin devam etmekte olduğu ve ayrıca, bu tedbirin kaldırılması yönünde herhangi bir talebin bulunmadığı belirtilmiştir (Bireysel başvuru kararı, Paragraf no. 24).

Anayasa Mahkemesi, söz konusu olayda başvurunun, Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlâl edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin bu kararında gerekçe olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Başvurucunun mal varlığı hakkında elkoyma tedbirinin uygulandığı tarihte Türkiye’de OHAL yönetim usulü yürürlüktedir. Elkoyma kararında, başvurucunun darbe teşebbüsünün arkasındaki yapılanma olduğu belirtilen FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla başvurucunun şikâyet ettiği tedbire dayanak olan suçlamanın OHAL ilanını gerekli kılan olaylarla ilgili olduğu görülmektedir.” (Paragraf no. 45)

“Somut olayda başvurucunun mal varlığı değerleri yönünden bir ceza soruşturması sürecinde **suçtan elde edildiği şüphesiyle** ve muhtemel bir müsadereyi güvence altına almak için el konulmuştur.” (Paragraf no. 49)

“Somut olayda başvurucunun mal varlığına ilişkin olarak 5271 sayılı Kanunun 128. maddesi ve 668 sayılı KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi hükümlerine göre elkoyma tedbiri uygulanmıştır. Bununla birlikte başvurucunun cezalandırılması talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde **Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkûmiyete ilişkin kararda el konulan mal varlığı değerleri ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir.** Ancak Ağır Ceza Mahkemesi tedbirin devam ettiğini bildirmiştir. Diğer taraftan başvurucunun **elkoyma kararına karşı yaptığı itirazının ise yine elkoyma kararını veren mercii tarafından incelenerek reddedildiği** görülmektedir.” (Paragraf no. 53)

Sulh Ceza Hâkimliğince verilen mal varlığına elkoyma kararına başvurucunun “yaptığı **itiraz ise hiçbir mercii tarafından incelenmemiştir.**” (Paragraf no. 60)

Karara konu teşkil eden “olayda başvurucunun atılı suçtan cezalandırılmasına karar veren Ağır Ceza Mahkemesi **el konulan mal varlığı değerlerinin müsadereyi yönünde bir hüküm tesis etmemiştir.** Mahkeme böyle bir hüküm tesis etmediği gibi, **söz konusu mal varlığı değerlerine yönelik tedbirin devamı veya sona emesi yönünde de bir karar vermemiş,** Anayasa Mahkemesinin konu hakkındaki yazısı üzerine tedbirin devam ettiğini bildirmiştir.” (Paragraf no. 61)

“Dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma sürecine bir bütün olarak bakıldığında müsadere yönünde bir hüküm verilmediği hâlde elkoyma tedbirinin devamına niçin gerek duyulduğu anlaşılamamaktadır. Mahkeme tedbirin devamının gerekçesini ve kanuni dayanağını da göstermemiştir.” (Paragraf no. 61)

“Sonuç olarak başvurucunun hakkında yürütülen ceza soruşturmasında mal varlığı değerleri yönünden uygulanan tedbire ilişkin olarak kanunda öngörülen **itiraz sürecinin işletilmemesi, müsadere kararı verilmediği hâlde tedbirin fiilen devam ettirildiği, tedbirin devamı ile ilgili olarak bir karar verilmediği** gibi konu ile ilgili ve yeterli bir gerekçenin de gösterilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanun dışı veya keyfî ya da makul olmayan şekilde uygulandığına ilişkin savunma ve itirazlarını sorumlu makamlar önünde etkin bir biçimde ortaya koyabilme olanağının tanınmadığı ve **mülkiyet hakkının gerektirdiği usulî güvencelerin sağlanmadığı** kanaatine varılmıştır. Bu durumda elkoyma suretiyle yapılan müdahalenin kamu yararı amacı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunmasının gereklilikleri arasındaki adil denge başvuru aleyhine bozulmuştur. Başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale ölçüsüzdür.” (Paragraf no. 64)

“Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” (Paragraf no. 65).

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu olayda başvuru salt terör örgütü üyesi olmaktan dolayı mahkûm edilmiştir. Başka bir ifadeyle, elkoyma kararında, kararın konusunu oluşturan **malvarlığı değerlerinin somut bir suçla ilişkisi kurulmamıştır.** Hatta, şüphelinin **bütün malvarlığı ile ilgili olarak elkoyma kararı** verilmiştir. Oysa bir malvarlığı değerine elkonulabilmesi için,

- soruşturma ve kovuşturma konusu suç bakımından delil değerinin olması,
- soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olması ya da, bu suçun konusunu oluşturması,
- soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlenmesinde araç olarak kullanılmış olması, hususlarında somut şüphe sebeplerinin bulunması gerekir.

Anayasa Mahkemesinin kararında bu hususlara işaret etmemesi, önemli bir eksikliktir.

EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

11 Ocak 2016 tarihinde aleniyete kavuşturulan ve içeriği çok sayıda kişi tarafından çeşitli yollarla tasvip edilen bildiri içeriğinde; Türkiye’de terörü sona erdirmeye yönelik olarak ve fakat, hukuki temeli olmayan yöntemlerle başlatılan malum “*çözüm süreci*”nin¹⁷⁶ oluşturduğu ortamdan yararlanılarak başlatılan terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların eleştirisine yer verilmiştir.

Bu eleştiriler kapsamında, güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili olarak “**kasıtlı ve planlı kıyım**” ve “**katliam**” gibi ibareler kullanılmıştır.

Söz konusu bildiri akabinde, bu bildirinin içeriğini tasvip eden bir kısım kişiler tarafından **10 Mart 2016** tarihinde aleniyete kavuşturulan açıklamada, söz konusu bildirinin içeriğinin tasvip edildiği teyit edilmiş ve bazı ille-rimizde başlatılan yaygın terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesine yönelik olarak güvenlik görevlilerinin uygulamaları, “**Kürt illerindeki savaş**” olarak nitelendirilmiştir.

Bu bildiri ve akabinde yapılan açıklamalar dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu bağlamında iki sorun söz konusudur.

Bunlardan birincisi, söz konusu bildiri ve açıklamaların “PKK” adıyla maruf terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde gerçekleşmiş olup olmadığı sorunu-
dur.

Bu bildiri ve açıklamaların terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde icra edilmiş fiiller olarak kabul edilebilmesi için, içeriklerinin başlı başına bir suç oluşturup oluşturmadığı bir yana, bunları hazırlayan veya içeriklerini tasvip ettiğini çeşitli yöntemlerle beyan eden kişilerin terör örgütü bünyesindeki hiyerarşik ilişkiye dahil olması gerekmektedir. Bu çerçevede çeşitli ihtimal-
ler söz konusudur:

Birinci ihtimal: Söz konusu bildiri ve açıklamaların içeriği malum terör örgütünün yöneticisi veya üyesi olan kişiler tarafından hazırlanmıştır ve keza, içeriklerini tasvip ettiklerini çeşitli yöntemlerle beyan eden kişiler bu terör örgütü bünyesindeki hiyerarşik ilişkiye dahildir.

¹⁷⁶ Söz konusu “çözüm süreci” bağlamındaki uygulamaların hukuki bakımdan değerlendirmeleri için bkz. yukarıda “EKSKURS 4” altında yapılan açıklamalar.

Bu ihtimal dahilinde, içeriğinde yer alan ifadelerin başlı başına suç oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın, bu kişilerin tamamının, hiyerarşik ilişkideki konumları itibarıyla terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilmesi gerekir.

İkinci ihtimal: Söz konusu bildiri ve açıklamaların içeriği malum terör örgütünün yöneticisi veya üyesi olan kişiler tarafından hazırlanmıştır ve fakat, içeriklerini tasvip ettiklerini çeşitli yöntemlerle beyan eden kişiler bu terör örgütü bünyesindeki hiyerarşik ilişkiye dahil değildir.

Bu ihtimal bağlamında söz konusu bildiri ve açıklamaların içeriğini tasvip eden kişilerin ceza hukuku sorumluluğundan söz edebilmemiz için, bu metinlerin malum terör örgütünün yöneticisi veya üyesi olan kişiler tarafından, yani bu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde hazırlanmış olduğunu bilmeleri ya da bu bildiri ve açıklamaların içeriklerinin başlı başına bir suç oluşturması gerekir.

Üçüncü ihtimal: Söz konusu bildiri metinlerini hazırlayan ve içeriklerini tasvip ettiklerini beyan eden kişiler, malum terör örgütü bünyesindeki hiyerarşik ilişkiye dahil değildir.

Bu ihtimalde, ceza hukuku sorumluluğundan söz edebilmemiz için, söz konusu bildiri ve açıklamaların **içeriğinin başlı başına bir suç oluşturması gerekmektedir.**

Bu hususlar, ilgili davalara ilişkin dosya içeriğindeki deliller itibarıyla münhasıran mahkemenin takdirinde olan bir sübut sorunudur.

Yukarıda söz konusu edilen üçüncü ihtimal dahilinde, ilgili kişilerin ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için, bu bildiri ve açıklamaların içeriğinin, örneğin,

- a) Suç işlemeye tahrik (TCK, m. 214),
 - b) Suçu ve suçluyu övme (TCK, m. 215),
 - c) Halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama (TCK, m. 216),
 - ç) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK, m. 301).
 - d) Terör örgütünün propagandası (3713 s. K., m. 7, f. 2),
- suçlarından bir veya birkaçını oluşturması gerekmektedir.

Bu bildiri ve açıklamaları tasvip ettiğini çeşitli yöntemlerle beyan eden kişiler hakkında açılan davaların konusu uyuşmazlık bağlamında terör örgütünün propagandası suçu ile ilgili bazı hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu eleştiriler kapsamında dile getirilen güvenlik görevlilerine ve dolayısıyla Devlete izafe edilen uygulamaların gerçeklikle bağdaşp bağdaşmadığına bakılmaksızın; bunların salt eleştiri konusu yapılması ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez. Bu eleştiriler bağlamında kullanılan ifadeler mübalağalı da olsa ve hatta, “**kasıtlı ve planlı kıyım**” ve “**katliam**” gibi ibareler kullanılmış olsa bile, salt bu nedenle ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemez.

Ancak, bu eleştiriler çerçevesinde “**Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından**” söz edilirken, güvenlik görevlileri tarafından, yani Devlet eliyle gerçekleştirilen uygulamaların terör örgütüne, bu örgütün mensuplarına yönelik olmaktan ziyade, genel olarak “**Kürt halkı**”nı hedef aldığı izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Özellikle **10 Mart 2016** tarihli açıklamada, 2015 yılı ortaları itibarıyla bazı illerimizde başlatılan yaygın terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesine yönelik olarak güvenlik görevlilerinin uygulamaları “**Kürt illerindeki savaş**” olarak nitelendirilmiştir.

Bu açıklamalarla, malum terör örgütünün suç işlemek amacıyla kurulmuş ve faaliyet icra eden örgüt görüntüsünden ziyade, **bir halkın bağımsızlığı için mücadele veren örgüt** olduğu izlenimi oluşturulmak istendiği açıktır. Bu alanda önemli bir gerekçeyi, bu örgüte karşı askeri güç kullanılarak verilen mücadelenin oluşturduğunu belirtmek gerekir. PKK’ya karşı **kara ve hava birlikleri** tarafından **askeri silahlar** kullanılarak verilen mücadele, milletlerarası kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu örgütle “**savaş hali**”nde olduğu hususunda bir izlenim oluşturmaktadır.

Bu suretle, Türkiye’nin özellikle güneydoğu illerindeki yaygın terör eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin uygulamalarının **savaş hukukuna ilişkin 1949 Cenevre Mukaveleleri** hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin yolu açılmak istenmektedir.

Söz konusu **11 Ocak 2016** tarihli bildiri içeriğinde PKK terör örgütünün yaygın terör eylemlerini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen özellikle sokağa çıkma yasağı uygulamalarının hukuki dayanaktan yoksunluğuna

ilişkin olarak yer verilen eleştirilerin doğruluğuna rağmen; **10 Mart 2016** tarihli açıklamalar, dolaylı da olsa, “**terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapma**” suçunu oluşturacaktır.

Anayasa Mahkemesinin, **26.7.2019** tarihli ve 2018/17635 bireysel başvuru sayılı Kararında sadece **11 Ocak 2016** tarihli bildiri metni değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Söz konusu bildiri akabinde yapılan ve bu bildirinin içeriğini tasvip eden **10 Mart 2016** tarihli açıklamada ise, malum terör örgütünün suç işlemek amacıyla kurulmuş ve faaliyet icra eden örgüt görüntüsünden ziyade, **bir halkın bağımsızlığı için mücadele veren örgüt** olduğu izlenimi oluşturulmak suretiyle, Türkiye’nin özellikle güneydoğu illerindeki yaygın terör eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin uygulamalarının **savaş hukukuna ilişkin 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve bu Sözleşmelere ek Protokoller** hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin yolu açılmak istenmektedir.

“**Harb Felâketzedelerinin Himayesine Dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri**”, Türkiye tarafından, 21.01.1953 tarihli ve 6020 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Bu çerçevede Türkiye, tarafı olduğu,

- 1) Harb Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı İçin 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi,
- 2) Silahlı Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin Islahı İçin 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi,
- 3) Harp Esirleri Hakkında Tatbik Edilecek Muameleye Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi,
- 4) Harb Zamanında Sivillerin Korunması İçin 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi,

hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Keza, savaş hukukuna ilişkin olarak 08.06.1977 tarihli, 1949 Cenevre Sözleşmelerine aşağıdaki ek Protokoller hazırlanmış ve üye devletlerin imza ve onayına sunulmuştur.

- 1) Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunması Protokolü;
- 2) Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunması Protokolü.

Türkiye bu Protokolleri henüz imzalamış değildir.

PKK mensupları, Avrupa’da barınma ve propaganda zemini buldukları ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik kuvvetlerinin özellikle güneydoğu bölgemizde ve bu bölgedeki sınır boylarında gerçekleştirdiği operasyonların, söz konusu Sözleşmeler hükümlerine göre, **“BİR DEVLETİN HÜKÜMET KUVVETLERİ İLE HÜKÜMETE KARŞI GELEN SİLAHLI GRUPLAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMALAR”** olarak kabulü yönünde yoğun propaganda faaliyeti icra etmektedirler.

Özellikle 8.6.1977 tarihli Protokoller, **egemen ülke içinde, egemenlik kazanmak için yürütülen çatışmalar bakımından da, uluslararası nitelikte olmamalarına rağmen, savaş hukukuna ilişkin kuralların işletilmesini sağlamak amacını** taşımaktadır.

Güvenlik kuvvetleri tarafından PKK’ya karşı yürütülen operasyonların **“savaş”** olarak nitelendirilmesinin ve silahlı çatışma hukukuna tabi kılınmasının en önemli sonucu, bu çatışmalarda yakalanan PKK mensuplarının, söz konusu Sözleşmeler hükümlerine göre **“esir”, “tutsak”** muamelesine tabi tutulmasıdır. Bu itibarla, **PKK mensubu olup da işledikleri suçlar sebebiyle halen tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin statüsü ve bu kişilere uygulanacak olan hukuk değişmiş olacaktır.**

Keza, bu yöndeki kabul, PKK mensuplarının ellerinde **rehin** olarak tuttukları kamu görevlileri bakımından **“esir mübadelesine”** ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.

Anayasa Mahkemesinin bu ayrıntıların göz ardı edildiği söz konusu bireysel başvuru kararı, Türkiye’de de, PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik güçlerine karşı operasyonlarının **savaş hukuku** çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki propaganda faaliyetlerinin önünü açmış olmaktadır.

Bu bağlamda özellikle üzerinde durulması gereken nokta, güvenlik güçlerinin PKK’ya karşı operasyonlarının **“savaş”** olarak nitelendirilmesidir. Eğer bir savaştan söz ediliyorsa, bunun **“tarafı”**nın olması gerekir. Söz konusu

operasyonları “**savaş**” olarak nitelendirme çabası içinde olanlar, **PKK**’yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında “**taraf**” konumuna yükseltmektedirler ve **PKK**’nın nihai amacının “**meşru**” olduğunu kabul etmektedirler.

Bütün bu değerlendirmelerimden, güvenlik güçlerinin terörle mücadele çerçevesinde icra ettikleri operasyonların hukuk zemininde icra edildiğini aleltilak kabul ettiğim sonucu asla çıkarılamaz.

İşaret etmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin, **26.7.2019** tarihli ve 2018/17635 bireysel başvuru sayılı Kararının ilişkin olduğu başvuruda **10 Nisan 2016** tarihli açıklamadan hiç söz edilmemektedir. Başvurucuların bu ikinci açıklamayla bir ilgisi olmayabilir.

Özellikle üzerinde durduğumuz nokta, güvenlik güçlerinin **PKK**’ya karşı operasyonlarının “**savaş**” olarak nitelendirilmesidir. Eğer bir savaştan söz ediliyorsa, bunun “**taraf**ları”nın olması gerekir. Söz konusu operasyonları “**savaş**” olarak nitelendirme çabası içinde olanlar, **PKK**’yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında “**taraf**” konumuna yükseltmektedirler ve **PKK**’nın nihai amacının “**meşru**” olduğunu kabul etmektedirler.

EKSKURS 17: “İLTİSAK” İBARESİ ÜZERİNE¹⁷⁷

“İltisak” ibaresi pozitif hukuk metinlerimize ilk defa, 15 Temmuz 2016 tarihli “darbe” teşebbüsü sonrası ilen edilen olağanüstü hal sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde kullanılmıştır. Bu ibareye, bilahare olağan dönemde çıkarılan kanunlarda da yer verilmeye başlanmıştır.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Bu başlık altındaki açıklamalar, <https://izzetozgenc.com/data/contents/“iltisak”-ibaresi-uzerine.pdf> (Yayına giriş tarihi: 30.01.2022; Erişim tarihi: 8.2.2022) adresinde yayımlanmıştır.

¹⁷⁸ 22.7.2016 tarihli ve **667** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6749 sayılı Kanun.
22.7.2016 tarihli ve **668** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6755 sayılı Kanun.
25.7.2016 tarihli ve **669** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6756 sayılı Kanun.
15.8.2016 tarihli ve **670** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7091 sayılı Kanun.
15.8.2016 tarihli ve **671** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6757 sayılı Kanun.
15.8.2016 tarihli ve **672** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7080 sayılı Kanun.
15.8.2016 tarihli ve **673** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7081 sayılı Kanun.
15.8.2016 tarihli ve **674** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 6758 sayılı Kanun.
3.10.2016 tarihli ve **675** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7082 sayılı Kanun.
3.10.2016 tarihli ve **676** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7070 sayılı Kanun.
31.10.2016 tarihli ve **677** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7083 sayılı Kanun.
31.10.2016 tarihli ve **678** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7071 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **679** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7084 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **680** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7072 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **681** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7073 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **683** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7085 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **684** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7074 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **685** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7075 sayılı Kanun.
2.1.2017 tarihli ve **686** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7086 sayılı Kanun.

İlginçtir söz konusu ibare, malum “balyoz davası” dosyası içeriğindeki darbe hazırlığı mahiyetindeki “*Balyoz Güvenlik Harekât Planı*”nda ve bu davada **İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin** 21.9.2012 tarihli ve E: 2010/283, K: 2012/245 sayılı Gerekçeli Kararında kullanılmıştır.¹⁷⁹

“İltisak, Arapça kökenli bir kelime olup,

1. “bitişme, kavuşma, yapışma, birleşme”;
2. (biyolojide) “iki organın birbirine yapışması”

anlamlarına gelmektedir.¹⁸⁰

Söz konusu ibare, hukuki bir kavram değildir. Bu ibarenin hukuk metnlerinde kullanılması, beraberinde önemli bir belirsizlik barındırır.

Bir terör ve dolayısıyla suç örgütüyle irtibat,

- a) Örgütte yöneticilik yapmak,
- b) Somut bir suçun icrası bağlamında örgüt üyesi olmak,

17.4.2017 tarihli ve **689** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7088 sayılı Kanun.

17.4.2017 tarihli ve **690** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7077 sayılı Kanun.

5.6.2017 tarihli ve **691** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7069 sayılı Kanun.

15.8.2017 tarihli ve **694** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7078 sayılı Kanun.

20.11.2017 tarihli ve **695** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7092 sayılı Kanun.

20.11.2017 tarihli ve **696** sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ve bu KHK’yi kanunlaştıran 7079 sayılı Kanun.

22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sini kanunlaştıran 18.10.2016 tarihli ve **6749** sayılı Kanunun 9. maddesine 5.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunla (m. 50) eklenen üçüncü fıkra.

678 ve **684** s. Olağanüstü Hal KHK’leri ile 4734 sayılı **Kamu İhale Kanunu**’nun 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen g bendi.

680 s. OHAL KHK’si ile 4734 sayılı **Kamu İhale Kanunu**’nun 11. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle.

5.6.2017 tarihli ve **691** sayılı OHAL KHK’si ile 6754 sayılı **Bilirkişilik Kanunu**’nun 10. maddesinin birinci fıkrasına eklenen a bendi.

¹⁷⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda, “EKSURS 18” altında yapılan açıklamalar.

¹⁸⁰ DEVELLİOĞLU, Ferit: *Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat*, 3. Ofset Baskı, Ankara 1978, sh. 515.

- c) Örgüte yardım etmek, Bu çerçevede de,
- ca) Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek,
- cb) Örgütün propagandasını yapmak,

şekillerinde tezahür edebilir. Bu fiillerin de kanunlarda suç olarak tanımlandığı, suç oluşturduğu izahtan varestedir.

Bunların dışında bir suç ve terör örgütüne “iltisak”tan söz etmek, hukuken mümkün değildir. Bu ibareye yer veren pozitif hukuk metinlerinde, bundan neyin anlaşılması gerektiği hususunda hiçbir belirleme yapılmamıştır. İrtibat kavramıyla ilgili olarak yukarıda yapılan belirlemeler karşısında, söz konusu pozitif hukuk metinlerinde “iltisak” ibaresine yer verilmesinin en azından zait olduğunu belirtmek gerekir. Daha da önemlisi, irtibat kavramının yanında ve kendisine bu kavramdan ayrı bir anlam yüklenmeye çalışıldığı için, bu ibare, belirsizlik içermektedir ve hukuk güvenliği bakımından bir tehdit oluşturmaktadır.¹⁸¹ Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin kararında, bu “iltisak”ın varlığının “*olay, olgu, bilgi ve bulgu*”ya dayalı olarak tespit edilmesi gerektiği belirtilmişse de, bir hakkın kullanılmasına engel oluşturma sebebi olarak görülen bu ibareden neyin anlaşılması gerektiği hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.¹⁸²

Bu ibareye pozitif hukuk metinlerinde yer verilmesiyle, uygulamada da görüldüğü üzere, örneğin babasının veya kardeşinin bir terör örgütüyle irtibatından dolayı bir kişinin kamu görevine alınmasının, belli hakları kullanmasının önüne geçilmesinin yolu açılmıştır. Bu anlayışın, evrensel hukuk kuralı olan, **ceza sorumluluğunun şahsiliği** kuralıyla bağdaşmadığını belirtmekle iktifa etmek isterim.

İşin daha vahim yönü, bu ibare sadece terör örgütleriyle ilgili olarak değil, “*Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum veya gruplara*” “iltisak”ının varlığı halinde de kişinin bir takım hak yoksunluklarına maruz bırakılmasıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Anayasa’ya göre Milli Güvenlik Kurulu’nun böyle bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

¹⁸¹ Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu ibarenin içeriğinin yargı mercilerince belirlenebileceği yönünde içtihatla bulunmuştur: Anayasa Mahkemesi, 14.11.2019, E.2018/89, K.2019/84; Anayasa Mahkemesi, 24.6.2021, E. 2018/81, K. 2021/45.

¹⁸² Anayasa Mahkemesi, 14.11.2019, E.2018/89, K.2019/84, pn. 31 vd.

Anayasa'nın 118. maddesine göre, Milli Güvenlik Kurulu'nun doğrudan icraî karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Milli Güvenlik Kurulu, ancak **tavsiye mahiyetinde kararlar** alabilir. Bu tavsiye kararlarını ancak yürütme organı tarafından icraî karara dönüştürebilir. Başka bir ifadeyle, Milli Güvenlik Kurulu, ancak yürütme organı bakımından tavsiye kararları alabilir.¹⁸³

Milli Güvenlik Kurulu, yargı mercileri bakımından tavsiye mahiyetinde de olsa karar alma yetkisini haiz değildir. Anayasanın söz konusu hükümleri itibarıyla, bir örgütsel yapının terör örgütü mahiyetinde olup olmadığına Milli Güvenlik Kurulu karar veremez.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun sanki böyle bir anayasal yetkisi varmış gibi, **“Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum veya gruplar”** ibaresine yer verilmiştir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Milli Güvenlik Kurulu'nun “karar” vereceği bu **“yapı, oluşum veya gruplar”**ın bir **terör örgütü olması gerekmektedir.** Başka bir ifadeyle, bu **“yapı, oluşum veya gruplar”**ın faaliyeti çerçevesinde **herhangi bir suçun işlenmesi de şart değildir.**

Keza, terör örgütü mahiyeti taşımasa ve faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suç işlenmese bile **“Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum veya gruplar”**la ilgili olarak yürütme organının ne yapması, nasıl bir yol izlemesi gerektiği de hukuken belirsizdir.

Hukuk güvenliği bakımından en tehlikeli hükümler bunlardır. Zira, faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir suç işlenmediği halde, **“Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen”** bu **“yapı, oluşum veya gruplar”**a **“iltisakı”** olduğu kabul edilen kişiler **sakıncalı** görülerek kamu görevine alınmayacak ve belirli haklardan yararlanamayacaktır.

Anayasal dayanağı olmayan bu yetki kullanılarak, örneğin bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir siyasi partiye oy verdiği için, bu siyasi partinin toplantılarına katıldığı için, **“iltisaklı”** kabul edilebilecek ve

¹⁸³ Milli Güvenlik Kurulu'nun icraî karar alma yetkisinin bulunmadığı yönündeki bu açıklamalarımıza paralel değerlendirmeler için bkz. Anayasa Mahkemesi, **3.6.2021**, E. 2020/9, K. 2021/37 (RG: 5 Ekim 2021/31619); Anayasa Mahkemesi, **3.6.2021**, E. 2020/18, K. 2021/38 (RG: 23 Eylül 2021/31607); Anayasa Mahkemesi, **22.9.2021**, E. 2018/75, K. 2021/61 (RG: 2 Şubat 2022/31738); Anayasa Mahkemesi, **16.12.2021**, E. 2021/89, K. 2021/99 (RG: 16 Mart 2022/31780).

belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilecektir. Keza, mensup olduğu dinle ilgili bilgiyi edinmek için ailesi tarafından bir dinî oluşuma ait öğrenci yurduna, eve yerleştirilen, bu dini oluşumun açtığı kursa gönderilen çocuk, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilecektir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin pek çok kararında, “*iltisak*” ibaresi kullanılmakla birlikte, bir şirketin, bir derneğin **terör örgütü** “*ile iltisaklı*” olduğu kabul edilmekle birlikte, bunun ne anlama geldiği hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.¹⁸⁴ İlginçtir ki, söz konusu Dairenin bir kararında “**terör örgütü ile iltisaklı okul**” ifadesi kullanılmıştır.¹⁸⁵ İlgili kamu otoritelerinin izniyle kurulmuş olan ve Devletin gözetim ve denetimi altında faaliyet icra eden okulun faaliyetleri çerçevesinde hangi suçların işlendiği, hangi terör faaliyetinin organize edildiği konularında hiçbir tespitte bulunulmamıştır.

Bu uygulamaların ancak **faşizm**le telifi kabildir.

¹⁸⁴ Yargıtay 16. CD, **2.7.2019**, E. 2018/7312, K. 2019/4638; **3.7.2019**, E. 2019/1486, K. 2019/4719; **20.3.2019**, E. 2018/2882, K. 2019/1926; **27.12.2019**, E. 2019/5533, K. 2019/8459; **30.9.2019**, E. 2019/1329, K. 2019/5631; **23.1.2020**, E. 2019/6091, K. 2020/598.

¹⁸⁵ Yargıtay 16. CD, **11.3.2020**, E. 2019/501, K. 2020/1954.

§ 2. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

I. “KARAPARA” İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu ile “**terörizmin finansmanı**” fiilleri arasında ilişki kurulmaya çalışılarak, “karapara”nın yani suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin “terörizmin finansmanı” fiilleri ile ilgili olarak da uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu ile “terörizmin finansmanı” fiilleri arasında önemli **farklılıklar** bulunmaktadır.

Terörün finansmanında kullanılan veya kullanılmak üzere tedarik edilen para ve sair malvarlığı değerleri ekseriyetle **meşru kaynaklardan** elde edilmektedir. Buna karşılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun konusunu oluşturan para ve sair malvarlığı değerinin ise, belirli bir ağırlık derecesine ulaşmış olan **bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş** olması gerekir.

Söz konusu suçlar arasında **amaç bakımından** da **fark** bulunmaktadır. Ekseriyetle meşru bir yolla elde edilmiş olan para ve sair malvarlığı değerleri, **terörün finansmanı amacıyla**, gayri meşru ve hukuk dışı birtakım faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Buna karşılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunda, gayri meşru ve hukuk dışı yollarla elde edilmiş olan para ve sair malvarlığı değerleri, **meşru bir yolla elde edilmiş olduğu izlenimi uyandırmak amacıyla** çeşitli işlemlere tabi tutulmaktadır¹.

Bunlar arasında kurulmak istenen irtibat, her iki suçun da uluslararası finans sistemi kullanılmak suretiyle işlenmesine dayandırılmaktadır^{2,3}.

¹ VOGT, sh. 10, 11.

² 30/31 Ekim 2001 tarihlerinde Washington D.C.’de yapılan toplantıda FATF, “karapara”nın yani suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin önlenmesine ilişkin tedbirlerin terörizmin finansmanı için de kullanılabilmesini sağlama yönünde karar (Özel Tavsiye Kararı II) almıştır. “Karapara”nın yani suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin önlenmesine yönelik olarak alınabilecek olan tedbirler, önce FATF’ın tavsiye karalarıyla belirlenmekte ve bilahare devletler kendi iç mevzuatlarında bu kararlar doğrultusunda düzenlemeler yapmaktadırlar. Avrupa Birliğinde FATF’ın tavsiye karaları doğrultusunda düzenleme yapmalarını sağlamak için Birlik Parlamentosu ve Komisyonu önce üye devletler bakımından bağlayıcı kararlar almaktadır. Bu bağlayıcı kararlara istinaden üye devletler kendi iç mevzuatlarında düzenlemeler yapmaktadırlar.

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa'daki "İslami" dernek ve vakıflar aracılığıyla toplanan yardımlarla terörist faaliyetlerin finanse edildiği kabul edilmektedir⁴. Özellikle Kur'an kaynaklı mesajların kullanılması suretiyle camilerde toplanan yardımlar, Kafkaslarda, güney batı Asya'da, Orta doğuda,

Bu düzenlemeler, çok değişik alanlardaki kanunlarda yapılmaktadır. Örneğin Almanya'da "Geldwäschekämpfungsgesetz" in yanı sıra "Kreditwesensgesetz" de, önemli hükümlere yer verilmiştir (Bu hususlarda ayrıntılı bilgi için bkz. TEICHMANN, Helmut/ACHSNICH, Gernot: *Geldwäscheregelungen in anderen Gesetzen*, in: *Geldwäschekämpfung und Gewinnabschöpfung*, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 315 vd.; MÜLHAUSEN, Dieter: *Bekämpfung der Geldwäsche in der Kredit- und Finanzdienstleistungswirtschaft*, in: *Geldwäschekämpfung und Gewinnabschöpfung*, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 356 vd.).

Bu suretle "karapara"nın aklanmasının ve "terörizmin finansmanı"nın önlenmesi konusunda yeknesak düzenlemeler yapılması sağlanmaktadır.

Bildirim yükümlülüğü altında bulunan kişi veya kuruluşlar, bir finans hareketi ile ilgili olarak, **bunun bir suçtan kaynaklandığı** veya **bununla terörizmin finanse edileceği** hususunda **somut vakıaların** bulunması halinde suç duyurusunda bulunacaklardır. Böylece suç duyurusu sadece finans kaynağının suçtan elde edilmiş olduğu hususunda somut vakıaların bulunması ile sınırlı tutulmamaktadır. Aksine, finans kaynağı ile terörizmin, terörist grupların, terörist örgütlerin finanse "edileceği" hususunda somut vakıaların bulunması halinde de suç duyurusunda bulunma yükümlülüğü doğmaktadır (TEICHMANN/ACHSNICH, sh. 255 vd., 287.). Belirtmek gerekir ki, henüz suç alanına girilmemiş bir finans hareketiyle ilgili olarak bununla terörizmin finanse "edileceği" hususunda "somut vakıa"ların bulunmasından söz edilmesi, abesle iştigalden başka bir anlam taşımaz. Örneğin Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi'nin veya Avrupa Birliği Komisyonunun oluşturduğu "terörist listesi"nde bir kişinin veya kuruluşun adının, herhangi bir suç soruşturması olmaksızın, herhangi bir suç soruşturmasına dayanmaksızın, yer almış olması, bu kişi veya kuruluş adına veya bu kişi veya kuruluş lehine yapılan para transferleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulması için yeterli bir sebep olarak görülmektedir (TEICHMANN/ACHSNICH, sh. 287 vd.).

³ Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun önlenmesine yönelik denetim mekanizmasının, suçtan kaynaklanmamış olmakla beraber, terörizmin finansmanında kullanılabilme ihtimali/tehlikesi bulunan finans kaynaklarına da teşmil edilmesi istenmektedir. Bkz. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 26.10.2005 tarihli ve 2005/60/EG sayılı "*Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Finans Sisteminden Yararlanılmasının Önlenmesi Direktifi*" (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, I 309, 25.11.2005, sh. 15 vd.). Ayrıca bkz. FATF'ın 16 no'lu "40 Tavsiye Kararı" çerçevesinde çıkarılan Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 1.8.2006 tarihli ve 2006/70/EG sayılı Direktifi (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, I 214, 4.8.2006, sh. 29 vd.). Nitekim 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı "*Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun*" hükümleri, suç gelirlerinin aklanması suçunun yanı sıra "terörizmin finansmanı" suçu ile ilgili olarak da uygulanacaktır (m. 17, 18, 19).

Meşru bir yolla elde edilmiş olmasına rağmen, gayrimeşru bir yolla elde edildiği hususunda herhangi bir kuşku bulunmamasına rağmen, terörizmin finansmanında henüz kullanılmamış olan bir finans kaynağının hangi hallerde bu amaçla kullanılabileceği hususunda elde somut ölçüt bulunmadığı için Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 26.10.2005 tarihli ve 2005/60/EG sayılı Talimatı eleştirilmektedir (DEGEN, sh. 105).

⁴ VOGT, sh. 10.

Balkanlarda, Afrika’da “kriz bölgeleri”ne ulaştırılmakta; daha çok “*İslamî misyonerlik faaliyetlerinin icra edildiği bölgeler*”e gönderilmektedir⁵.

Yardımlar genellikle ihtiyaç sahibi ülkelerde örneğin eğitim veya sağlık kuruluşu inşası ya da mevcutların desteklenmesi vaadiyle toplanmakta; ancak bu paralarla gerçekte “ekstremist” veya terörist organizasyonların desteklendiği **düşünülmektedir**⁶. Zira söz konusu yardımlar, çoğu zaman bir finans kuruluşu aracılığıyla olmaksızın, kişilerin yanında nakit para olarak transfer edilmekte ya da bu yardım paralarıyla silah veya askeri teçhizat satın alındığı **düşünülmektedir**⁷.

Kişiler tarafından gayet masumane amaçlarla yapılan küçük miktarlardaki yardımlar toplanarak yardım organizasyonlarının hesaplarına yatırılmaktadır. Bu paralar bilahare ihtiyaç sahibi ülkelerde bulunan başka organizasyonların hesaplarına aktarılmaktadır. Ancak, bu para transferleri, herhangi bir sebep gösterilmeksizin veya yardım projelerinin finansmanı görüntüsüyle yapılmaktadır⁸.

II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Türkiye’nin de taraf olduğu, terörizmin önlenmesine yönelik milletlerarası sözleşmelerle yüklenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla iç hukukta çeşitli kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, bazı suçların yurt dışında işlenmiş, fail ve mağdurunun yabancı olması dolayısıyla yaptırımsız kalmasının önüne geçilmesi amacıyla, milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin gereği olarak TCK’da düzenlemeler yapılmıştır (m. 13). Aynı şekilde, Türkiye tarafından da imzalanan ve onaylanıp yürürlüğe konulan “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”nin gereği olarak, 3713 s. Terörle Mücadele Kanununda, 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, “*Terörün finansmanı*” suçu (m. 8) tanımına yer verilmiştir.

BM Genel Kurulunun 17 Aralık 1996 tarihli ve 51/210 sayılı, 15 Aralık 1997 tarihli ve 52/165 sayılı Kararlarında, üye devletler,

a) **Teröristlere** gerek doğrudan gerek kuruluşlar aracılığıyla **finansman sağlanmayı önlemek için tedbir almaya,**

⁵ VOGT, sh. 35.

⁶ DEGEN, sh. 67.

⁷ VOGT, sh. 35.

⁸ VOGT, sh. 35.

- b) Teröristlerin finansmanı amacıyla silâh kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti ve haraç toplama gibi hukuk dışı faaliyetleri önlemeye ve etkin ceza yaptırımına bağlamaya,
- c) Terörist amaçlara hizmet edeceğinden şüphelenilen kişi veya kuruluşların **mali kaynaklarını izlemeye**, bunların uluslararası alandaki hareketleri ile ilgili olarak daha yoğun ve daha hızlı bir şekilde **bilgi alışverişinde bulunmaya**,
- ç) Hatta, kişi veya kuruluşların, meşru yollarla finans kaynağı elde etmelerine ve bunların meşru amaçlar için kullanılmasına engel olmamak kaydıyla, **terörist amaçlar için kullanılacağından şüphelenilmesi halinde, malî kaynak edinmelerinin önlenmesi ve bunların hareketlerinin durdurulması için hukuki düzenlemeler yapmaya**,

davet edilmişlerdir.

Bu amaçlarla hazırlanan “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 Aralık 1999 tarihinde kabul edilmiştir; 10 Ocak 2000 tarihinde New York’ta imzaya açılmıştır. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli kentlerindeki belirli hedeflere gerçekleştirilen saldırılara kadar sadece dört devlet bakımından onaylanarak yürürlüğe konan Sözleşme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373(2001) sayılı Kararı gereğince çok sayıda devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Türkiye tarafından 27.09.2001 tarihinde imzalamış olan Sözleşmenin onaylanması, 10.1.2002 tarihli ve 4738 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 01.03.2002 tarihli ve 2002/3801 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Sözleşme metni, **01 Nisan 2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazetede** yayımlanmıştır.

Sözleşme ile taraf devletlere “*her ne suretle olursa olsun, tümüyle veya kısmen, (terör) eylemlerin(in) gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek, doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten,*” fon sağlanması veya toplanması fiillerinin suç olarak tanımlanması yönünde yükümlülük yüklenmektedir (m. 2, f. 1). Sözleşmede ayrıca hangi fiillerin “terör eylemi” olarak nitelendirilebileceğine, açıklık getirilmiştir. Buna göre,

a) Sözleşmenin eki olan listede yer alan milletlerarası anlaşmalar⁹ kapsamına giren ve bu anlaşmaların tarafı devletlere etkin ceza yaptırımı ile cezalandır-

⁹ Bu anlaşmalar sırasıyla şunlardır:

1) Uçakların Yasadışı Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (16 Aralık 1970, Lahey) – ICAO

rılması gereken suç olarak tanımlanması hususunda yükümlülük getirilen fiiller (m. 2, f. 1, bent a),

b) *“Niteliği veya kapsamı itibariyle, bir halkı korkutmak, ya da bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacını gütmesi halinde, bir sivilin ya da bir silâhlı çatışma durumunda muhasemata doğrudan katılmayan herhangi başka bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya yönelik diğer tüm eylemler”*,

“terör eylemi” olarak nitelendirilebilecektir. Bu itibarla, söz konusu Sözleşme, taraf devletlere kanunlarında bu fiillerin terör suçu olarak tanımlanması hususunda bir yükümlülük yüklemektedir.

(b) bendinde, *“niteliği veya kapsamı itibariyle, bir halkı korkutmak, ya da bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacı”* ile *“bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya yönelik ... eylemler”* “terör eylemi” olarak kabul edilmekle birlikte; bu hüküm, öldürme ve ağır şekilde yaralama fiillerinin **“bir silâhlı çatışma durumunda muhasemata doğrudan”** katılan kişilere karşı işlenmiş olmasını terör suçu olarak kabule imkan tanımamaktadır. Başka bir ifadeyle, bir silâhlı çatışma söz konusu ise, bu çatışmaya doğrudan katılan tarafların birbirlerine karşı işlemiş bulundukları öldürme ve ağır yaralama fiilleri terör suçu olarak kabul edilemeyecektir. Bu hükmün dolaylı sonucu, bir devlet ile silâhlı çatışmanın varlığı halinde çatışmanın tarafı olan devlet dışı örgütlenmelere silah ve sair ihtiyaçlarının karşılanması

2) Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (23 Eylül 1971, Montreal) – ICAO

3) Diplomatik Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (14 Aralık 1973, New York) – BMGK

4) Rehin Almalara Karşı Uluslararası Sözleşme (17 Aralık 1979, New York) – BMGK

5) Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi (3 Mart 1980, Viyana)

6) Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü, Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokol (24 Şubat 1988, Montreal) - ICAO,

7) Denizcilik Seferyollarının Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (10 Mart 1988, Roma) - IMO,

8) Kıta Sahanelerinde Kurulu Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Protokol (10 Mart 1988, Roma) - IMO,

9) Terörist Bombalamaların Önlenmesi Sözleşmesi (15 Aralık 1997, New York) – BMGK.

Türkiye bu anlaşmaların hepsine taraftır.

amacıyla fon sağlanması, “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**” kapsamında terörün finansmanı suçu oluşturmaya-caktır. Söz konusu Sözleşmenin dikkat edilmesi gereken noktalarından birisi bu hükümdür.

Söz konusu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti adına 27 Eylül 2001 tarihinde New York’ta imzalanırken, bu hükümle ilgili olarak **beyanda** bulunulmuş-tur¹⁰.

Türkiye’nin bu hükümle ilgili olarak beyanda bulunması, Sözleşmeye taraf olan devletler bakımından söz konusu hükmün uygulamada gözönünde bu-lundurulmasına engel teşkil etmemektedir. Bu itibarla, Sözleşmeye taraf olan devletler, örneğin PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile silahlı çatışma halinde bulunduğunu, bu silahlı çatışmanın taraflarının doğrudan birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri öldürme veya ağır yaralama fiillerini terör suçu olarak kabul etmeyebilecektir. Bunun sonucu olarak, PKK’nın silahlı çatışma halinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik görevlilerine karşı öldürme veya ağır yaralama fiillerini gerçekleştirse bile, bu örgüte yapılan yardımları “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme” hükümlerini ihlal ve dolayısıyla suç olarak değerlendirmeyecektir.

Bugün Amerika Birleşik Devletlerinin ve bazı Avrupa devletlerinin hükü-metleri tarafından hazırlanan “terör örgütü listeleri”nde PKK’nın veya PKK ile irtibatlı bazı organizasyonların adlarının yer alması, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bir “jest”i ifadeden ibaret sembolik bir anlam taşımaktadır.

Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik uygulamaları yerinde gör-mek amacıyla Türk heyeti¹¹ olarak 7 ve 8 Temmuz 2010 tarihlerinde İngilte-

¹⁰ Bu hükümle ilgili beyan metninde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“1. Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşmenin 2’nci maddesinin 1(b) paragrafının uygulanmasının bir silahlı çatışmanın varlığına işaret etmeyeceğini, **silahlı çatışma tabirinin, örgütlü bir bi-çimde olsun veya olmasın, ceza hukuku kapsamında terörizm suçunu oluşturan fiillerin iş-lenmesinden farklı olan bir durumu betimlediğini** beyan eder.

2. Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşmenin 2’nci maddesinin 1(b) paragrafının, 21 inci maddede de ifade edildiği üzere, devletlerin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan kaynak-lanan yükümlülüklerine, özellikle başka devletlerin topraklarında faaliyet gösteren terörist ve silahlı gruplara finansal destek sağlamama yükümlülüğüne zarar vermeyeceğini beyan eder.”

¹¹ Bu heyette, Kastamonu Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı KÖYLÜ, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve akademisyen olarak şahsım yer almıştır.

re'ye yaptığımız çalışma ziyaretinde Londra'da Birleşik Krallık Finans Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapmış bulduğumuz görüşmelerde, Birleşik Krallık makamları tarafından heyetimize PKK'ya finans sağladığı için sadece bir kişinin malvarlığı ile ilgili olarak “dondurma kararı” alındığı ancak, bu kişinin İngiltere’de malvarlığı bulunmadığı için bu kararın uygulanmadığı bilgisi verilmiştir. Nitekim Avrupa Birliği Konseyi tarafından malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlar arasında, ‘**Kurdistan Workers’ Party**’ – ‘**PKK**’, (a.k.a. ‘**KADEK**’, a.k.a. ‘**KONGRA-GEL**’) yer almaktadır¹².

Hukuki kişiliği olmayan terör örgütü ile malvarlığı arasında sahiplik ilişkisinden söz edilemez. Ancak terör örgütü, gerçek veya tüzel kişilerin maliki veya zilyedi olduğu malvarlığı değerlerini kontrolü altında tutmaktadır. Avrupa’nın pek çok devletinde icra edilen yayın faaliyeti ile her gün terör örgütünün propagandası yapılmaktadır. Keza, örgütün silah ve mühimmat dışındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak icra edilen sınai ve ticari faaliyetler kapsamındaki fon ve sair malvarlığı hareketleri, bu ülkelerde yaşayan gerçek kişiler veya bu ülkelerde oluşturulan tüzel kişiler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Terör örgütünün ve bağlı organizasyonlarından bazılarının adlarının, Avrupa Birliği Konseyinin oluşturduğu malvarlığı dondurulacak kişi kuruluş veya organizasyonlara ilişkin listeye alınması sağlanabilmiş ise de, Avrupa Birliği üyesi devletler üzerinden terör örgütüne finansman sağlanması henüz engellenebilmiş değildir.

Daha da önemlisi, PKK’nın elinde “**Sınırışan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamaları İle Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol**”¹³ kapsamına giren silahlar bulunmaktadır. Bu silahlar, yapılanmasına ilişkin bilgileriniz itibarıyla PKK’nın silahlı mensuplarının bulunduğu Türkiye, Irak, İran, Suriye, Lübnan ve Ermenistan’da örgütün kendi imkanları

¹² Bu bağlamda alınmış son karar için bkz.

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/147 of 3 February 2022

(Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 4.2.2022, L.25/1).

Dikat çekmek isteriz ki, bu listeler zaman zaman güncellenerek alınan son kararlar, bir önceki karar yürürlükten kaldırılmaktadır.

¹³ Türkiye bu Protokolü, 28 Haziran 2002 tarihinde imzalamıştır. Protokolün onaylanması, 12.2.2004 tarihli ve 5095 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Protokol, Bakanlar Kurulu’nun 30.03.2004 tarihli ve 2004/7097 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Protokol metni, **26 Nisan 2004 tarihli ve 25444 sayılı Resmi Gazetede** yayımlanmıştır.

ile üretilmemektedir. Aksine, başka devletlerde üretilen bu silahlar, satın alma veya bağış yoluyla PKK'ya temin edilmektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu bu Protokole göre, PKK'nın eline bu silahların geçmemesi gerekmektedir. Ancak, PKK'nın silahlı mensuplarının bulunduğu ülke devletlerinden bazıları ve her halde **Irak** ve bu ülkeyi işgali altında tutan **Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada tarafından bu örgüte ateşli silah temininin önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirler alınmamaktadır**. Özellikle Irak üzerinden Türkiye'ye gerçekleştirilen sızmalar üzerine gerçekleştirilen silahlı saldırılarda kullanılan ateşli silahların özellikleri, **Türkiye Cumhuriyeti Devletinin** söz konusu Protokol hükümlerini taraf olan ve hatta olmayan devletler¹⁴ nezdinde girişimde bulunarak işletme hususunda **başarılı olamadığını** göstermektedir.

Başka bir husus, PKK'nın yayın organı olduğu bilinen ve Türkiye'de isteyen herkes tarafından rahatlıkla izlenebilen televizyon kanalları, bazı Avrupa devletlerinde özgürce yayın faaliyetinde bulunabilmektedirler. Bu televizyonların yayın içeriklerinde, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı "Kürt halkının bağımsızlığı" için mücadele verdiği iddia edilmekte, bu mücadelede "düşman" olarak ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik güçleriyle girilen silahlı çatışmada güvenlik güçleri tarafından öldürülen örgüt mensupları "şehit", yakalananlar ise "esir", "tutsak" olarak nitelendirilmektedir. Bu yayın içeriklerinde, esasen suç oluşturan PKK eylemleri, **kendi geleceğini belirleme hakkı elinden alınmış olan bir halkın bağımsızlık mücadelesinin birer parçası olarak gösterilmektedir ve böylece, bu eylemlerin izleyici kitlesi tarafından bir terör faaliyeti olarak algılanması perdelenmektedir**. Türkiye adına, bu televizyon yayınlarının durdurulması için Danimarka gibi bazı devletler nezdinde girişimlerde bulunuldu ise de bu girişimlerinde başarılı olunamamıştır. Türkiye adına bu çerçevede sadece söz konusu yayın faaliyetinin icra edildiği yer tesislerinin bulunduğu devletler nezdinde girişimde bulunulmuştur. Ancak elimizde, bu yayınlara erişimi sağlamada önemli fonksiyon icra eden uyduların sahibi olan devletler nezdinde herhangi bir girişimde bulunulduğuna dair bilgi mevcut değildir.

¹⁴ Söz konusu Protokol, **3 Nisan 2017** tarihi itibarıyla **Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa ve Rusya Federasyonu** gibi silah üretimi ve ticareti bakımından önemli devletler tarafından henüz **imzalanmamıştır**. Keza, Protokol, **Almanya** (3 Eylül 2002), **Avustralya** (21 Aralık 2001), **Avusturya** (12 Kasım 2001), **Çin** (9 Aralık 2002), **İngiltere ve Kuzey İrlanda** (6 Mayıs 2002), **İzlanda** (15 Kasım 2001, **Japonya** (9 Aralık 2002), **Kanada** (20 Mart 2002), **Lüksemburg** (11 Aralık 2002) ve **Monako** (24 Haziran 2002) tarafından imzalanmış olmakla beraber, henüz **onaylanarak yürürlüğe konulmamıştır**.

PKK terör örgütünün suç işlemek amacıyla kurulmuş ve faaliyet icra eden örgüt görüntüsünden ziyade, bir halkın bağımsızlığı için mücadele veren örgüt olduğu izlenimi oluşturmaları bakımından uluslararası alanda önemli bir gerekeciyi, bu örgüte karşı **askeri güç kullanılarak** verilen mücadele oluşturmaktadır. PKK'ya karşı kara birlikleri tarafından **askeri silahlar kullanılarak** verilen mücadele, milletlerarası kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu örgütle “*savaş hali*”nde olduğu hususunda bir izlenim oluşturmaktadır.

Sözleşme, 2. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirlenen terör eylemlerinin “*gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağına bilerek, doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten, fon sağlamak veya toplamak*” fiillerinin müstakil bir suç olarak tanımlanmasını yükümlülük olarak yüklemektedir.

Maddenin Türkçe metninde İngilizce metnine nazaran hukuk tekniği bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin İngilizce metinde yer alan “*unlawfully and wilfully*” ibaresi, “*yasa dışı bir şekilde ve kasten*” olarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Halbuki bu ibare Türkçeye “**hukuka aykırı olarak ve isteyerek**” şeklinde tercüme edilmesi gerekmekte idi.

Söz konusu fıkranın İngilizce ve Türkçe metinleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda; suç olarak tanımlanması öngörülen **fon sağlamak veya fon toplamak** fiillerinin, maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirlenen **terör eylemlerinden** birini **işlemek amacıyla** gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, kişinin **terör eylemlerinin işlenmesinde kullanılacağına bilerek** fon toplaması veya sağlaması, suç olarak tanımlanmak gerekmektedir. Buna göre yeni tanımlanacak suçun ancak **doğrudan kastla** işlenebilen bir suç olması gerekmektedir (Sözleşme, m. 2, fıkra 5). Ancak, yeni tanımlanacak suçun oluşabilmesi için işlenmesi amaçlanan suçların kim tarafından, nerede, ne zaman ve kime karşı işleneceği hususlarında somutlaştırılmış olması gerekmektedir.

Fon sağlayan kişi bakımından fiilin suç oluşturabilmesi için bunun **isteyerek** gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu itibarla, örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak kişilerin fon sağlamaya, yardım etmeye zorlanması halinde, fon sağlayan ve yardım eden kişi bakımından ceza sorumluluğu söz konusu olamaz. Fon sağlayan ve yardım eden kişinin fiilinin suç oluşturabilmesi için, fon sağlamakla ve yardım etmekle hukuka aykırı bir iş yaptığının bilincinde olması gerekmektedir. Bu itibarla, sırf hayrî mülahazalarla, bağışta bulunan insanın fiili suç oluşturmayacaktır.

Fonun, **terör eylemlerini işlemek amacıyla, terör eylemlerinin işlenmesinde kullanılacağı bilinerek** sağlanmış olması, suçun oluşması için yeterli olacaktır. Bu itibarla, suçun oluşması için, sağlanan fonun, yapılan yardımın somut bir terör eyleminin gerçekleştirilmesinde kullanılmış olması şart değildir (Sözleşme, m. 2, fıkra 3).

Sözleşme ile taraf devletler, bu fiillerin **etkin yaptırımlar** gerektiren suç olarak tanımlamakla yükümlü kılınmışlardır (m. 4). Keza Sözleşme, fon sağlama veya toplama fiillerinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında da “*etkin, orantılı ve caydırıcı nitelikte*” yaptırım öngörülmesi hususunda hüküm içermektedir (m. 5).

Bütün bu fiiller, aslında mer’i mevzuatımızda suç olarak tanımlanmıştır. Yukarıda “*Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Yardım Etme*” başlığı altında yapmış bulunduğumuz açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda, belirli bir suçla ilişkilendirilmiş olmasa bile terör örgütüne finansal destek sağlayan kişinin, TCK’nın 220. maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince aynı Kanunun 314. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden **terör örgütü üyesi** olarak cezalandırılacağı açık bir şekilde görülecektir¹⁵. Keza, örgüt üyesi olmasa bile terör suçu işlemiş olan kişiye yardım edilmesi halinde, TCK’nın 283. maddesinde tanımlanan **suçluyu kayırma suçunun** oluşacağı kuşkusuzdur. Belli bir terör suçunu işlemek amacıyla bir kişiye finans sağlayan kimse, **işlenmesi amaçlanan suçu işlemeğe azmettirme** dolayısıyla TCK’nın 38. maddesi hükmüne istinaden cezalandırılabilecektir. Burada tek sorun, kişi belli bir suçu işlemeğe azmettirilmiş ve bu amaçla kendisine finans sağlanmış olmakla birlikte, azmettirme konusu suçu işlememiş, işlenmesi amaçlanan suçun icrasından sarfınazar etmiş olabilir. Bu durumda akim (sonuçsuz) kalmış azmettirme söz konusu olacaktır ve TCK’nın mevcut düzenlemelerine göre, akim kalmış azmettirme cezalan-

¹⁵ Alman CK’nın § 129a, Abs. 5’e göre, bir terör örgütünün desteklenmesi suçtur. § 129b’ye göre, § 129a’daki hükümler Almanya’da uzantısı bulunmayan yabancı terör örgütleri için de uygulanır. Bir teröristin desteklenmesi, § 27’ye istinaden, bu terörist tarafından işlenen suçta yardım olarak cezalandırılır.

Terörist organizasyonların finansal olarak desteklenmesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu bakımından öncül suç mahiyeti taşımaktadır.

Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve FATF üzerinden bütün dünyaya dayattığı “**terörizmin finansmanı**” fiilinin **müstakil bir suç olarak tanımlanmasına gerek görülmemiştir** (TEICHMANN, Helmut/ACHSNICH, Gernot: *Das Geldwäschegesetz – Überblick*, in: Geldwäsche-bekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 287; DEGEN, sh. 68)

dırılmamaktadır¹⁶. Halbuki, terörün finansmanını önlenmesine dair Sözleşme, bir terör suçunun işlenmesi amacıyla fon sağlayan kişinin, işlenmesi amaçlanan suç bilahare işlenmese bile, bu suçun işlenmesinden bilahare sarfinazar edilse bile, cezalandırılmasını sağlayan kanuni düzenleme yapılmasını amirdir.

Bu nedenle Türkiye, Sözleşmeden kaynaklanan bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla, Terörle Mücadele Kanununda 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla (m. 7) yapılan değişikliklerle, söz konusu Kanunun 8. maddesinde “**Terörün finansmanı**” başlığıyla yeni bir suç tanımı ihdas edilmiştir:

Terörün finansmanı

MADDE 8- (1) Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya değerli para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder.¹⁷

¹⁶ Bkz. Yargıtay CGK, **12.3.2019**, E. 2017/691, K. 2019/202; Yargıtay CGK, **13.2.2018**, E. 2017/692, K. 2018/41.

¹⁷ 5532 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında söz konusu 8. maddenin birinci fıkrası metni şu şekilde idi:

“Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlar veya toplarsa, hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüzelli günden binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Fon, kullanılmamış olsa dahi fail aynı şekilde cezalandırılır.”

Hükümet Tasarısıyla yeniden düzenlenen söz konusu 8. maddenin birinci fıkrası metninde TBMM Adalet Komisyonunda bazı değişiklikler yapılmış ve madde, TBMM Genel Kurulunda bu değişikliklerle kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Söz konusu 8. maddeyle ilgili **Hükümet Tasarısındaki gerekçe** şu şekildedir (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222):

“3713 sayılı Kanunun mülga 8’inci maddesi yeniden düzenlenerek, madde kapsamında terörün finansmanı suçu tanımlanmıştır. Bu suretle, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Ocak 2000 tarihinde imzaya açılan, Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan, 10/1/2002 tarihli ve 4738 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 1/3/2002 tarihli ve 2002/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”den kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerimize uygun düzenlemeler yapılmıştır.

Terör suçlarının işlenmesi amacıyla, bilerek ve isteyerek finansman sağlamak suç oluşturduğuna göre; bu suçun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı değerleri hakkında, Türk Ceza

Terörle Mücadele Kanununun 8. maddesine yöneltilen en önemli itiraz, “**terör suçu**” ibaresinin kapsamı ile ilgilidir. 3713 s. Kanunda sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini değiştirmek amacıyla sınırlı bir terör suçu tanımı yer almaktadır. Bu tanımlama, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”nin 2. maddesinde kapsamı belirlenen “terör eylemleri” kavramının içeriğiyle örtüşmemektedir. Bu nedenle, Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesindeki terör suçu ibaresinin kapsamının yeniden belirlenmesine yönelik bir kanuni düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır¹⁸.

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla 16 Şubat 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7.2.2013 tarihli 6415 sayılı “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun**”da yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeler bağlamında Terörle Mücadele Kanununun, 8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır (6415 s. K, m. 18).

6415 s. Kanunun 3 ve 4. maddelerinde terör suçlarının kapsamı bir ölçüde genişletilmiştir. Buna göre,

“a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri(;) ”

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller(;) ”

c) Türkiye’nin taraf olduğu;

Kanununun "Kazanç müsadereci" başlıklı 54'üncü maddesi hükümleri uygulanacağı açıktır. Bu nedenle, Kanuna bu konuya ilişkin ayrı bir hüküm konulması gereksiz görülmüştür.”

“Terörün finansmanı suçu”nun tanımlandığı 8. madde metninde TBMM Adalet Komisyonunda yapılan değişikliklerin gerekçesi şu şekildedir (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222):

“Tasarının çerçeve 7'nci maddesiyle yeniden düzenlenen 3713 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasındaki "doğrudan veya dolaylı olarak" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Ayrıca, bu fıkra da tanımlanan suçun işlenmesi halinde verilecek ceza bakımından, kişinin terör örgütünün üyesi olarak cezalandırılmasına imkan tanımaya yönelik olarak değişiklik yapılmıştır.”

¹⁸ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, 2006, sh. 19 vd.

- 1) *Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme,*
 - 2) *Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme,*
 - 3) *Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme,*
 - 4) *Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme,*
 - 5) *Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme,*
 - 6) *Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,*
 - 7) *Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme,*
 - 8) *Kıta Sahanelğinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,*
 - 9) *Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme,*
- yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller” (6415 s. K, m. 3);*

açık bir şekilde ifade edilmiş olmasa bile, **terör suçu** olarak kabul edilmiştir. Zira bu Kanunla yeniden tanımlanan ve terör suçu olarak belirlenen “**terörizmin finansmanı suçu**” bu “*fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek ... bir teröriste veya terör örgütlerine fon*” sağlamakla veya toplamakla oluşmaktadır:

Terörizmin finansmanı suçu

MADDE 4– (1) 3’üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)¹⁹ Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.

(3) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmaz.

(4) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.

(7) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu suç bakımından da uygulanır.

(8)²⁰ Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 133'üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,

b) 135'inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) 139'uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140'ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. Ayrıca, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.

Söz konusu suç tanımı ve uygulaması ile ilgili bazı temel açıklamalarda bulunmaya gerek bulunmaktadır:

¹⁹ Bu fıkra, 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla (m. 36), madde metnine eklenmiş ve sonraki fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

²⁰ 14.4.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunla (m. 29) madde metnine eklenmiş olan bu fıkrada, 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla (m. 36) değişiklik yapılmıştır.

1) Söz konusu suçun **konusunu** oluşturan “**fon**” ibaresi, ekonomik değeri olan her türlü malvarlığı değerini kapsamaktadır. Nitekim, 6415 s. Kanunda, “*Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi, ifade eder*” şeklinde tanımlanmıştır (m. 2, f. 1, bent c)²¹.

2) **Fon sağlama** fiili²², kişinin her halde terör örgütü üyesi olmasını gerekli kılmamaktadır²³. Fon sağlayan kişi, terör örgütü üyesi de olabilir. Belirtmek

²¹ “Yargıtayın istikrar kazanan uygulamalarına göre, örgüt mensuplarının geçici olarak barındırılması, evde yemek ikram edilmesi, örgütün verdiği para ile ihtiyaç listesindeki malzemelerin temin edilmesi gibi eylemler fon sağlama kapsamında değerlendirilmeyip TCK’nun 314. maddesinin üçüncü ve 220. maddesinin yedinci fıkraları delaletiyle uygulanacak olan ve TCK’nun 314. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen genel nitelikte silahlı terör örgütüne yardım suçu kapsamındadır.”: Yargıtay CGK, 13.2.2018, E. 2017/692, K. 2018/41.

²² Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12.3.2019 tarihli ve E. 2017/691, K. 2019/202 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; yapılan bir ihbar üzerine X’in sevk ve idaresinde hareket halinde olan kamyonet durdurularak arama yapılır, araçta, “on adet çakmak gazı, yüz seksen adet pil, bir adet 15 kg’lık peynir tenekesi, bir adet çadır brandası, on adet tırnak makası, üç adet kamuflaj desenli panço tipi yağmurluk, iki adet pense, bir adet yıldız tornavida, bir adet masat, bir adet satır, üç adet bıçak, üç adet 100’lük paketler halinde jilet, üç adet makas, on iki adet tıraş sabunu, iki adet çakmaktaşı paketi, iki adet dikiş iğnesi paketi, 2,5 kg kırmızı biber, 500 gr biber, 1 kg baharat, 500 gr karabiber, iki adet 1 kg’lık kolonya, iki adet 500 gr’lık kolonya, 10 kg’lık ince bulgur, 5 kg badem, üç adet 5 kg’lık karışık kuruyemiş, iki adet 5 kg’lık kabak çekirdeği, 5 kg leblebi, 5 kg antep fıstığı, 5 kg fındık, 5 kg ay çekirdeği, 10 kg tütün, üç adet çaydanlık, 5 kg çay, bir adet düdüklü tencere, içerisinde on iki adet yemek kaşığı bulunan üç adet kutu, on paket şeker, on sekiz adet şeffaf koli bandı, iki adet 1 kg’lık bakkaliye torbası, dokuz paket tütün kağıdı, kırk adet hazır kahve, beş kutu 750 gr’lık hurma, beş adet yaklaşık 100 gr’lık limon tuzu, iki adet 100 gr’lık hindistan cevizi, 500 gr pudra şekeri, iki paket 100 gr’lık tarçın, 100 gr susam, 100 gr siyah çörek otu, on altı paket puding, üç adet 100 gr’lık kakao, üç paket 50 gr’lık mahlep, on paket kabartma tozu, on paket vanilya, her birinin içerisinde kırk sekiz adet toz kahve bulunan dokuz paket, üç adet kazma, üç adet kazma sapı, üç adet makaraya sarılı iplik, 10 kg süt tozu, altı teneke sıvı tahin, 16 kg’lık beş teneke margarin, 10 kg’lık dört teneke zeytin, 25 kg’lık beş çuval küp şeker, üç adet leğen, yüz metre elektrik kablolu, 10 kg şeffaf çadır naylonu, beş adet yaklaşık 500 gr’lık ırmık, bir adet pilli el radyosu, bir adet 1 GB kapasiteli hafıza kartı, bir adet küçük el feneri, bir adet Casio marka kol saati, bir adet uyku tulumu, on beş adet çakmak ve bir adet mont” bulunduğu tespit edilir ve bu eşyaya el konulur.

Keza, X’in üzerinde yapılan aramada, ele geçirilen not defterinde bu malzemelere ilişkin listenin, her bir malzeme çeşidinin miktarının ve parasal değerinin yazılı olduğu tespit edilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda, doğru olarak, **terörizmin finansmanı** suçunun oluştuğu yönünde içtihatla bulunmuştur.

“PKK silahlı terör örgütünün varlığını koruması, 6415 sayılı Kanun’un 3. maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiilleri gerçekleştirebilmesi ve bu husustaki örgütsel faaliyetlerini sürdürülebilmesi amaçlarına uygun olarak, örgütün kırsalda faaliyet gösteren mensuplarına, sanıklardan X’in 2009 yılı bahar aylarında iki kez ekmek ile diğer erzak ve yaşam malzemesi, sanık Y’nin 2009 yılı mayıs ayında un, tereyağı, şeker, çay ve ekmek, 2010 yılı nisan ayında on kg un, 3-4 kg peynir, dört kg bulgur ve deterjan gibi erzak ve yaşam malzemesi, sanık Z’nin de 2009 yılına kadar yiyecek, koyun, kitap ile iki adet dijital kamera ve

gerekir ki, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, terörizmin finansmanı suçundan dolayı cezaya hükmetmek mümkün olacaktır. TCK, m. 314, f. 2 ve TMK, m. 5 hükümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, terör örgütü üyeliği, terörizmin finansmanı suçuna nazaran daha ağır cezayı gerektiren bir suç olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle, fon sağlayan kişinin aynı zamanda terör örgütü üyesi olması halinde, sadece **terör örgütü üyeliğinden** dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. Bu değerlendirmeler, fon toplama fiili bakımından da geçerlidir²⁴.

Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hukuki dayanağı olmadığı halde,

“Terörizmin finansmanı suçu, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun özel bir hâli olduğundan, bu suçun faili terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ya da üyesi olmayan her gerçek kişi olabilir”²⁵

sekinde bir içtihatla bulunmuştur. Bu içtihat dolayısıyla FATF tarafından Türkiye’ye yöneltilen eleştiriler karşısında, bilahare 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla 6415 sayılı Kanun, m. 4’e ikinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkroda sayılan fiillerin, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.”

Eklenen bu fıkra ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun söz konusu kararı etkisizleştirilmiş ise de, bu fıkra düzenlemesi FATF’nin eleştirisine açıktır. Zira

3.000 TL temin ettiği olayda; sanıklar tarafından temin edilen para ve diğer eşyanın niteliği itibarıyla 6415 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) bendinde tanımlanan “fon” kapsamında olduğu, dolayısıyla sanıkların terör örgütü mensuplarına fon sağlamaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, aynı Kanunun 4. maddesinde düzenlenen **terörizmin finansmanı suçunu** oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.”: Yargıtay CGK, 12.3.2019, E. 2017/692, K. 2018/41.

²³ TCK, m. 220, f. 7 hükmü, terör örgütüne yardım eden kişinin sadece “terör örgütü üyesi olarak” cezalandırılmasını amirdir.

²⁴ “Sanıkların **El-Nusra** silahlı **terör örgütü**nün finansmanı amacıyla yaptıkları banka hesapları üzerinden para gönderme şeklindeki eylemlerinin ... 6415 sayılı Kanunun 4. maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı gözetilmeden delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde örgüte yardımdan hüküm tesisi, Kanuna aykırı”dır: Yargıtay 16. CD, E. 2019/9328 K. 2020/4786. Bu kararda “El Nusra” adıyla bir terör örgütünün varlığının hangi fiillere bağlı olarak kabul edildiğine dair hiçbir açıklamaya yer verilmemesi, önemli bir eksiklikler.

²⁵ Yargıtay CGK, 13.2.2018, E. 2017/692, K. 2018/41; Yargıtay CGK, 12.3.2019, E. 2017/691, K. 2019/202.

bu düzenleme karşısında, fon sağlayan ve toplayan kişilere terörizmin finansmanı suçundan dolayı ceza verilmeyecek; terör örgütünü kurmak, yönetmek veya terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı verilecek cezanın artırılması yoluna gidilecektir.

3) Terörizmin finansmanı suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan **fon toplama** fiili bağlamında, kişilere karşı yağma suçunun oluşmasını sağlayacak ölçüde cebir veya tehdit kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde, yani şayet kişilere cebir veya tehdit kullanılarak fon toplanmış ise, bu durumda **yağma** suçunun (TCK, m. 149, f. 1) oluştuğunu kabul etmek gerekir.

Ancak belirtmek gerekir ki, fon toplama faaliyeti sırasında kişilere karşı yağma suçunun oluşmasına sebebiyet verecek ölçüde cebir veya tehdit kullanılmış olmamakla birlikte, kişilerin **çeşitli endişelerle** terör örgütüne yardım mahiyetinde fon sağlamış olmaları halinde, bu (fon sağlayan) kişiler bakımından sorunun **zorunluluk hali** bağlamında ele alınması gerekmektedir. Yani kişilerin **çeşitli endişelerle** talep edileni yerine getirmeleri halinde, yardım fiili **isteyerek** icra edilmemiştir. Suç siyaseti, bu kabulü gerekli kılmaktadır. Çünkü, isteyerek yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, terör örgütüne yardım etmek dolayısıyla özensiz bir şekilde soruşturma ve kovuşturma yapılmasıyla, kişiler terör örgütlerinin kucağına itilmektedirler. Bu durum, terör örgütlerinin beklentilerine daha fazla hizmet etmektedir²⁶.

²⁶ Zorunluluk halinin özellikle bir "hukuka uygunluk sebebi" mi yoksa KUSURLULUĞU ET-KİLEYEN bir SEBEP mi olduğu konusundaki doktriner tartışmaların aksine, ceza hukuku mevzuatımızda yer alan bu konudaki hükümlerin değerlendirmesine ve uygulanmasına ilişkin içtihatlarla pek nadir rastlanmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına konu teşkil eden ve zorunluluk haline ilişkin hükümlerin uygulanması bakımından önem arz ettiğini düşündüğümüz bir olay, aşağıda özetlenerek değerlendirilmiştir:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **26.02.2019** tarihli ve E. 2017/1104, K. 2019/137 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ayrılıkçı terör örgütünün faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölgede bir köy kırsalında eşi ve eşinin ağabeyiyle birlikte oturan A'nın evine gece geç saatlerde silahlı vaziyette gelen terör örgütü mensupları, bir miktar (330 TL) para vererek, ihtiyaç duydukları bazı gıda ve sair malzemeyi satın alıp kendilerine getirmesi için A'yı sabahleyin ilçe merkezine gönderirler. A da sipariş verilen malzemeleri satın alır. Ancak, kendisine verilen para yetersiz kalınca cebinden 50 TL daha harcar. A, temin ettiği bu malzemeleri evine gelen ve kendisi dönünceye kadar evinde kalmaya devam eden örgüt mensuplarına verir.

Bu olayla ilgili olarak merciler arasında A'nın terör örgütüne yardım suçundan dolayı mı yoksa terörizmin finansmanı suçundan dolayı mı mahkûm edilmesi gerektiği tartışma konusu olmuştur. Sonuçta kişinin **terörizmin finansmanı** suçunu işlediği kabul edilerek hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

Ancak, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyelerinden birinin karşı oyuna ilişkin gerekçenin dışında, bu olay bağlamında mercilerce verilen kararların hiçbirinde, A'nın içinde bulunduğu koşullar itibarıyla başka türlü hareket etme imkan ve iktidarının bulunup bulunmadığı tartışılmamıştır.

4) Sözleşme hükümleri bağlamında yukarıda da belirttiğimiz gibi, terörizmin finansmanı suçunun oluşabilmesi için fonun, 6415 sayılı Kanunun “3 üncü madde(s)i kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin” işlenmesinde “kullanılması **amacıyla** (ve) kullanılacağını **bilerek**” sağlanması veya toplanması gerekir. Bu itibarla, söz konusu suç ancak **doğrudan kastla** işlenebilen bir suç mahiyeti taşımaktadır²⁷.

Bu nedenledir ki, **kişinin fiili işlediği sırada, fon sağladığı veya topladığı örgütsel yapının bir terör örgütü olduğunu bilmesi gerekir**. Başka bir ifadeyle, **fon sağlayan ve yardım eden kişinin fiilinin suç oluşturabilmesi için, fon sağlamakla ve yardım etmekle hukuka aykırı bir iş yaptığının bilincinde olması gerekmektedir**. Bu itibarla, **sırf hayrî mülahazalarla, bağışta bulunan insanın fiili suç oluşturmayacaktır**.

5) Fon sağlama fiilinin tamamlanabilmesi için, sağlanan fonun terör örgütünün veya “terörist”in egemenlik alanına geçmesi, fon üzerinde terör örgütünün veya “terörist”in tasarrufta bulunma imkanını elde etmesi gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, fonun örneğin bir terör örgütü üyesine teslim edilmesiyle suç tamamlanmış olur.

Bir terör örgütüne fon sağlama fiili, müteaddit defa da işlenebilir. Bu durumda, zincileme suç hükümlerinin uygulanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu değerlendirmeler, fon toplama fiili bakımından da geçerlidir.

6) 6415 sayılı Kanun, m. 4’e bilahare son fıkra olarak eklenen hükümlerle, bazı özel delil toplama yöntemlerinin terörizmin finansmanı suçu bakımından da uygulanması sağlanmıştır:

“(8)²⁸ Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 133'üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,

b) 135'inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

Bu tarz uygulamalar, ancak terör örgütünün amaçlarına hizmet eder ve bölge halkının terör örgütünün korkutucu gücüne boyun eğmesini sağlar.

²⁷ GÖDEKLİ, Mehmet: *Terörizmin Finansmanı Suçu*, Ankara, Haziran 2017, sh. 311 vd. Ancak, belirtmek gerekir ki yazar, söz konusu suçun bir “taksirli suç” olarak tanımlanması gerektiği görüşündedir (!) (sh. 312).

²⁸ 14.4.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunla (m. 29) madde metnine eklenmiş olan bu fıkra, 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla (m. 36) değişiklik yapılmıştır.

c) 139'uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
 ç) 140'ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
 tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. Ayrıca, 13/11/1996 tarihli
 ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat
 tedbirine karar verilebilir.”

III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU

Ceza muhakemesi hukukunda, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edildiği hususunda şüphe sebepleri bulunan belirli malvarlığı değerleri ile ilgili olarak ya da bir kişi hakkında suç işlediği şüphesiyle yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma sürecinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için delil olma niteliği taşıyan eşya ile ilgili olarak **elkoyma koruma tedbirine** başvurulabilmektedir. Elkoyma koruma tedbirinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, başta Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ilgili kanunlarda²⁹ ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Ancak, elkoyma koruma tedbirinden ayrı olarak özellikle milletlerarası hukukta “**malvarlığının dondurulması**” veya genel olarak “**dondurma**” kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

“Dondurma” ibaresi milletlerarası hukuk metni olarak ilk defa “**Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi**”nde tanımlanmıştır:

“‘Dondurma’ veya ‘el koyma’ mahkeme veya başka bir yetkili makamın emrine dayanılarak, malvarlığının devrinin, tebdilinin, tasarrufunun veya hareketinin geçici olarak yasaklanması veya malvarlığının muhafazasının veya kontrolünün geçici olarak üstlenilmesi anlamına gelir.” (m. 2, bent f).

Bu tanımda, “dondurma” ibaresi “elkoyma” ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Buna göre, “dondurma” veya “elkoyma”, belirli bir **malvarlığı** ile ilgili olarak alınan bir **tedbir kararı** niteliğindedir. Bu tedbir kararı, ancak **geçici olarak** alınabilir. Bu kararlar, belli bir malvarlığı üzerindeki **mülkiyet veya zilyedliğin bir başkasına devri**, bu malvarlığının bir başka malvarlığı

²⁹ Ceza Muhakemesi Kanunu dışındaki kanunlarda yer alan elkoyma koruma tedbirine ilişkin hükümlere örnek olarak, 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı “**Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun**”un “**Elkoyma**” başlıklı 17. maddesi ile 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı “**Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu**”nun “**Arama ve elkoyma**” başlıklı 9. maddesi hükümleri gösterilebilir.

ile **değiştirilmesi**, bu malvarlığının tüketilmesini, nevinin değiştirilmesini, bu malvarlığı üzerinde bir başkasının aynı veya şahsi hak elde etmesini sağlayacak herhangi bir **tasarrufta bulunulması**, yasaklanabilmektedir. Bu tedbir kararını almak hususunda, **mahkeme** veya başka bir **adli veya idari makam** yetkili kılınabilir. Bu tedbir kararı, ancak ekonomik çıkar amacıyla işlenen belirli bir suçla ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma sürecinde alınabilir (Sözleşme, m. 18).

Keza, “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”de taraf devletler, “*gerektiğinde müsadere edilebilmeleri amacıyla, 2. maddede belirtilen suçların işlenmesi için kullanılan veya kullanılması için oluşturulan fonların veya bu suçlardan temin edilen kazançların tespiti, bulunması, dondurulması, (bunlara) el konulması için iç hukuku uyarınca gerekli tedbirleri al*”makla yükümlü kılınmıştır (m. 8, f. 1). Keza, Sözleşmede, dondurulan veya elkonulan fon veya kazancın, yargılama süreci sonunda **müsadere** edilmesi öngörülmüştür (m. 8, f. 2). Bu itibarla, söz konusu Sözleşmeye göre ancak suçtan elde edilmiş bir kazançla ilgili olarak, bir suçun konusunu oluşturan malvarlığı değeriyle ilgili olarak dondurma işlemi gerçekleştirilebilir.

Ancak uygulamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin **15 Ekim 1999 tarihli ve 1267 sayılı Kararı**na istinaden Birleşmiş Milletler bünyesinde Güvenlik Konseyine üye devletlerin temsilcilerinin katılımıyla bir “**Komite**” oluşturulmuştur (“*Yaptırımlar komitesi*”). Bu “**Komite**”, Afganistan’da işgalcilere karşı savaşan Taliban örgütü başta olmak üzere, terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları gerekçesiyle sahibi oldukları veya kontrolü altında bulundurdıkları malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonları belirleyerek liste oluşturacaktır. Bu Kararla, üye devletler, söz konusu “**Komite**”nin hazırladığı listede yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların sahibi oldukları veya kontrolü altında tuttıkları **malvarlıklarını dondurmaları** için gerekli tedbirleri almaya çağırılmışlardır³⁰.

³⁰ **RESOLUTION 1267 (1999)**

Adopted by the Security Council at its 4051st meeting on 15 October 1999

The Security Council,

Reaffirming its previous resolutions, in particular resolutions 1189 (1998) of 13 August 1998, 1193 (1998) of 28 August 1998 and 1214 (1998) of 8 December 1998, and the statements of its President on the situation in Afghanistan,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan, and its respect for Afghanistan’s cultural and historical heritage,

Reiterating its deep concern over the continuing violations of international humanitarian law and of human rights, particularly discrimination against women and girls, and over the significant rise in the illicit production of opium, and stressing that the capture by the Taliban of the Consulate-General of the Islamic Republic of Iran and the murder of Iranian diplomats and a journalist in Mazar-e-Sharif constituted flagrant violations of established international law,

Recalling the relevant international counter-terrorism conventions and in particular the obligations of parties to those conventions to extradite or prosecute terrorists,

Strongly condemning the continuing use of Afghan territory, especially areas controlled by the Taliban, for the sheltering and training of terrorists and planning of terrorist acts, and reaffirming its conviction that the suppression of international terrorism is essential for the maintenance of international peace and security,

Deploring the fact that the Taliban continues to provide safe haven to Usama bin Laden and to allow him and others associated with him to operate a network of terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Afghanistan as a base from which to sponsor international terrorist operations,

Noting the indictment of Usama bin Laden and his associates by the United States of America for, inter alia, the 7 August 1998 bombings of the United States embassies in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania and for conspiring to kill American nationals outside the United States, and noting also the request of the United States of America to the Taliban to surrender them for trial (S/1999/1021),

Determining that the failure of the Taliban authorities to respond to the demands in paragraph 13 of resolution 1214 (1998) constitutes a threat to international peace and security,

Stressing its determination to ensure respect for its resolutions,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Insists that the Afghan faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan, comply promptly with its previous resolutions and in particular cease the provision of sanctuary and training for international terrorists and their organizations, take appropriate effective measures to ensure that the territory under its control is not used for terrorist installations and camps, or for the preparation or organization of terrorist acts against other States or their citizens, and cooperate with efforts to bring indicted terrorists to justice;

2. Demands that the Taliban turn over Usama bin Laden without further delay to appropriate authorities in a country where he has been indicted, or to appropriate authorities in a country where he will be returned to such a country, or to appropriate authorities in a country where he will be arrested and effectively brought to justice;

3. Decides that on 14 November 1999 all States shall impose the measures set out in paragraph 4 below, unless the Council has previously decided, on the basis of a report of the Secretary-General, that the Taliban has fully complied with the obligation set out in paragraph 2 above;

4. Decides further that, in order to enforce paragraph 2 above, all States shall:

- (a) Deny permission for any aircraft to take off from or land in their territory if it is owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban as designated by the Committee established by paragraph 6 below, unless the particular flight has been approved in advance by the Committee on the grounds of humanitarian need, including religious obligation such as the performance of the Hajj;

- (b) Freeze funds and other financial resources, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any undertaking owned or controlled by the Taliban, as designated by the Committee established by paragraph 6 below, and ensure that neither they nor any other funds or financial resources so designated

are made available, by their nationals or by any persons within their territory, to or for the benefit of the Taliban or any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by the Taliban, except as may be authorized by the Committee on a case-by-case basis on the grounds of humanitarian need;

5. Urges all States to cooperate with efforts to fulfil the demand in paragraph 2 above, and to consider further measures against Usama bin Laden and his associates;

6. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council to undertake the following tasks and to report on its work to the Council with its observations and recommendations:

(a) To seek from all States further information regarding the action taken by them with a view to effectively implementing the measures imposed by paragraph 4 above;

(b) To consider information brought to its attention by States concerning violations of the measures imposed by paragraph 4 above and to recommend appropriate measures in response thereto;

(c) To make periodic reports to the Council on the impact, including the humanitarian implications, of the measures imposed by paragraph 4 above;

(d) To make periodic reports to the Council on information submitted to it regarding alleged violations of the measures imposed by paragraph 4 above, identifying where possible persons or entities reported to be engaged in such violations;

(e) To designate the aircraft and funds or other financial resources referred to in paragraph 4 above in order to facilitate the implementation of the measures imposed by that paragraph;

(f) To consider requests for exemptions from the measures imposed by paragraph 4 above as provided in that paragraph, and to decide on the granting of an exemption to these measures in respect of the payment by the International Air Transport Association (IATA) to the aeronautical authority of Afghanistan on behalf of international airlines for air traffic control services;

(g) To examine the reports submitted pursuant to paragraph 9 below;

7. Calls upon all States to act strictly in accordance with the provisions of this resolution, notwithstanding the existence of any rights or obligations conferred or imposed by any international agreement or any contract entered into or any licence or permit granted prior to the date of coming into force of the measures imposed by paragraph 4 above;

8. Calls upon States to bring proceedings against persons and entities within their jurisdiction that violate the measures imposed by paragraph 4 above and to impose appropriate penalties;

9. Calls upon all States to cooperate fully with the Committee established by paragraph 6 above in the fulfilment of its tasks, including supplying such information as may be required by the Committee in pursuance of this resolution;

10. Requests all States to report to the Committee established by paragraph 6 above within 30 days of the coming into force of the measures imposed by paragraph 4 above on the steps they have taken with a view to effectively implementing paragraph 4 above;

11. Requests the Secretary-General to provide all necessary assistance to the Committee established by paragraph 6 above and to make the necessary arrangements in the Secretariat for this purpose;

12. Requests the Committee established by paragraph 6 above to determine appropriate arrangements, on the basis of recommendations of the Secretariat, with competent international organizations, neighbouring and other States, and parties concerned with a view to improving the monitoring of the implementation of the measures imposed by paragraph 4 above;

13. Requests the Secretariat to submit for consideration by the Committee established by paragraph 6 above information received from Governments and public sources on possible violations of the measures imposed by paragraph 4 above;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli kentlere yapılan saldırıların hemen akabinde aldığı **28 Eylül 2001 tarihli ve 1373 sayılı Kararla**, üye devletler,

- a) “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”yi imzalamaya ve onaylayıp yürürlüğe koymaya,
- b) Terör eylemlerinin işlenmesi amacıyla finansman temin etme, fon sağlama fiillerini etkin ceza yaptırımı gerektiren suç olarak tanımlamaya,
- c) Terör eylemlerinin işlenmesi amacıyla finansman temin eden, fon sağlayan kişi, kuruluş veya organizasyonların sahibi oldukları veya kontrolü altında tuttukları malvarlıklarını dondurmaya,
- ç) Terör eylemlerini işleyenleri, bu eylemlerin işlenmesi amacıyla finansman temin edenleri, fon sağlayanları, terör eylemlerini organize edenleri, bunlara yardım edenleri sığınma hakkından yararlandırmamaya,
- d) Bu suçlarla mücadelede, bu suçlar nedeniyle yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda milletlerarası alanda daha etkin bir şekilde işbirliği yapmaya, çağırılmışlardır³¹.

14. Decides to terminate the measures imposed by paragraph 4 above once the Secretary-General reports to the Security Council that the Taliban has fulfilled the obligation set out in paragraph 2 above;

15. Expresses its readiness to consider the imposition of further measures, in accordance with its responsibility under the Charter of the United Nations, with the aim of achieving the full implementation of this resolution;

16. Decides to remain actively seized of the matter.

³¹ **RESOLUTION 1373 (2001)**

Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001

The Security Council,

Reaffirming its resolutions 1269 (1999) of 19 October 1999 and 1368 (2001) of 12 September 2001,

Reaffirming also its unequivocal condemnation of the terrorist attacks which took place in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania on 11 September 2001, and expressing its determination to prevent all such acts,

Reaffirming further that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security,

Reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001),

Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts,

Deeply concerned by the increase, in various regions of the world, of acts of terrorism motivated by intolerance or extremism,

Calling on States to work together urgently to prevent and suppress terrorist acts, including through increased cooperation and full implementation of the relevant international conventions relating to terrorism,

Recognizing the need for States to complement international cooperation by taking additional measures to prevent and suppress, in their territories through all lawful means, the financing and preparation of any acts of terrorism,

Reaffirming the principle established by the General Assembly in its declaration of October 1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that all States shall:

- (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
- (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;
- (c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;
- (d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons;

2. *Decides also* that all States shall:

- (a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;
- (b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other States by exchange of information;
- (c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;
- (d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;
- (e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;
- (f) Afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin;

a) 19 Aralık 2006 tarihli ve 1730 sayılı Kararı ile, malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak oluşturulan listeden çıkarılmada izlenecek usul kuralları belirlenmeye çalışılmıştır.

(g) Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;

3. *Calls* upon all States to:

(a) Find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information, especially regarding actions or movements of terrorist persons or networks; forged or falsified travel documents; traffic in arms, explosives or sensitive materials; use of communications technologies by terrorist groups; and the threat posed by the possession of weapons of mass destruction by terrorist groups;

(b) Exchange information in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts;

(c) Cooperate, particularly through bilateral and multilateral arrangements and agreements, to prevent and suppress terrorist attacks and take action against perpetrators of such acts;

(d) Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999;

(e) Increase cooperation and fully implement the relevant international conventions and protocols relating to terrorism and Security Council resolutions 1269 (1999) and 1368 (2001);

(f) Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts;

(g) Ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists;

4. *Notes* with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal armstrafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials, and in this regard *emphasizes* the need to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to international security;

5. *Declares* that acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations and that knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the United Nations;

6. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council, consisting of all the members of the Council, to monitor implementation of this resolution, with the assistance of appropriate expertise, and *calls upon* all States to report to the Committee, no later than 90 days from the date of adoption of this resolution and thereafter according to a timetable to be proposed by the Committee, on the steps they have taken to implement this resolution;

7. *Directs* the Committee to delineate its tasks, submit a work programme within 30 days of the adoption of this resolution, and to consider the support it requires, in consultation with the Secretary-General;

8. *Expresses* its determination to take all necessary steps in order to ensure the full implementation of this resolution, in accordance with its responsibilities under the Charter;

9. *Decides* to remain seized of this matter.

b) **22 Aralık 2006 tarihli ve 1735 sayılı Kararı** ile, üye devletlerin veya bölgesel örgütlerin malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak oluşturulan listeye ekleme yapılması hususundaki önerilerinin değerlendirilmesinde izlenecek usul kuralları belirlenmeye çalışılmıştır. Keza bu Kararla, listede yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlıklarının etkin bir şekilde ve gecikmeksizin dondurulması sağlanmaya çalışılmıştır.

c) **17 Aralık 2009 tarihli ve 1904 sayılı Kararı** ile, terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları düşüncesiyle malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak liste oluşturulması, listeden çıkarma ve dondurma işlemlerinin icrası aşamalarında karşılaşılan çeşitli sorunların çözümüne yönelik kurallar belirlenmeye çalışılmıştır³².

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, malvarlığı dondurulacak ve bu nedenle listede yer alması gereken kişi, kuruluş veya organizasyonların belirlenmesinde esas alınacak kriterler, bu kişi, kuruluş veya organizasyonlara uygulanacak yaptırımların belirlenmesi ve uygulanması bakımından ayrıca, a) 30 Temmuz 2001 tarihli ve **1363** sayılı, b) 16 Ocak 2002 tarihli ve **1390** sayılı, c) 13 Aralık 2002 tarihli ve **1450** sayılı, ç) 20 Aralık 2002 tarihli ve **1452** sayılı, d) 17 Ocak 2003 tarihli ve **1455** sayılı, e) 30 Ocak 2004 tarihli ve **1526** sayılı, f) 29 Temmuz 2005 tarihli ve **1617** sayılı, Kararlar alınmıştır³³.

Önemle vurgulamak gerekir ki, **terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları gerekçesiyle malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ait listeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile oluşturulmamaktadır**. Bu listeler, Güvenlik Konseyinin sözünü ettiğimiz kararlarında belirlenen esas ve usuller çerçevesinde oluşturulmakla beraber; **listelerde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların isimleri Güvenlik Konseyi tarafından belirlenmemektedir**. Terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları gerekçesiyle malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ait listeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 sayılı Kararı ile oluşturulan “*Komite*” tarafından hazırlanmaktadır. Bu listelere alınacak veya listelerden çıkarılacak kişi, kuruluş veya organizasyonlar,

³² Söz konusu kararların içeriğine yönelik bilgi için Türkçe kaynak olarak bkz. YILDIRIM, Hukuksal Açıdan ..., sh. 130 vd.

³³ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınmış olan karar metinlerine <http://www.un.org> internet sitesinden ulaşılabilir.

“*Komite*”yi oluşturan devlet temsilcileri arasındaki müzakere ve **pazarlıklarla** belirlenmektedir³⁴.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile oluşturulan “*Komite*” **tarafından** malvarlığının dondurulmasına **karar** verilen kişiler hakkında herhangi bir devlette **bir suç şüphesine binaen soruşturma ve kovuşturma yapılması şartı aranmamaktadır**. Keza, söz konusu “*Komite*” kararı ile dondurulması istenen malvarlığının belli bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilmiş veya belli bir suçun konusunu oluşturan malvarlığı olması gerekmektedir. Meşru veya gayri meşru yolla elde edilmiş olduğuna bakılmaksızın, kişinin **bütün malvarlığı ile ilgili olarak** dondurma kararı verilmektedir. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan “*Komite*” tarafından kişilerin malvarlığı ile ilgili olarak verilen dondurma kararının belirli bir **süre** ile **sınırlandırılması da söz konusu değildir**³⁵.

Bu özellikleri itibarıyla Birleşmiş milletler bünyesinde oluşturulan “Yaptırımlar Komitesi”nin oluşturduğu listede yer alan kişilerin malvarlığının dondurulması uygulaması, hükümlerini yukarıda açıkladığımız “**Sınır**

³⁴ Söz konusu listelerin oluşturulması sürecine ilişkin bilgi için bkz. MACKE, sh. 143 vd.; YILDIRIM, Hukuksal Açından ..., sh. 143 vd.

³⁵ Belirtmek gerekir ki, terörizmin finanse edildiği hususunda herhangi bir soruşturma işlemine başvurulmaksızın, kişilerin suçla ilgisi kurulmaksızın bütün malvarlığının süresiz bir şekilde dondurulması yönündeki uygulamalar, Milletlerarası Ceza Hukuku Birliği’nin 20-27 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği 18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresinin ana konularından birini oluşturmakla birlikte; Kongrede Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı uluslararası dayatmanın sonucunda gelişen uygulamaya karşı, *Passas*’ın ihtiyatlı yaklaşımı dışında, bilim insanı onuruyla bağdaşır bir tutum ortaya konulamamıştır: *Entschliessungen des XVIII. Internationalen Strafrechtskongress in Istanbul 2009*, in: *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft* (122(2010), Heft 2, s. 473 vd. Section II, Criminal Law, Special Part, Financing of Terrorism, in: *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft* (122(2010), Heft 2, s. 477 vd.

TELLENBACH, Silvia: *Bericht über die Verhandlungen der II. Sektion: Strafrecht Besonderer Teil: Terrorismusfinanzierung*, in: *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft* (122 (2010), Heft 2, s. 458 vd.

PASSAS, Nikos: *Terrorism Financing, General Report*, in *Revue Internationale de Droit Penal*, 79 (2008), 3, 4, sh. 325 vd. Söz konusu Raporun Türkçe tercümesi için bkz. PASSAS, Nikos: *Terörizmin Finansmanı*, in: 18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, İstanbul 20-27 Eylül 2009, The 18th. International Congress of Penal Law, İstanbul 20-27 September 2009, Hazırlık Hareketleri ve iştirakin Genişlemesi, Terörizmin Finansmanı, Özel Yargılama Tedbirleri ve İnsan Haklarının Korunması, Evrensel Yargı Yetkisi, Sorular, Ulusal Raporlar, Genel Raporlar, Karar Taslakları, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, İstanbul, Mart 2009, sh. 146 vd.

Passas’ın malvarlığının dondurulmasına yönelik eleştirel değerlendirmeler için bkz. PASSAS, *Revue Intern.* 79(2008), 3, 4, sh. 334 vd., 342; 18; aynı yazar, Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, sh. 157 vd., 166.

Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ile “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”ye aykırı bir uygulamadır. Çünkü her iki Sözleşmeye göre “dondurma” kararı, ancak belirli bir suçla ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma sürecinde **mahkeme** veya başka bir **adli veya idari makam** tarafından, şüpheli veya sanığa ait olan ya da şüpheli veya sanığın kontrolü altında bulunan belirli bir **malvarlığı** ile ilgili olarak alınan bir **tedbir kararı** niteliğindedir. Bu tedbir kararı, ancak **geçici olarak** alınabilir. “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”ye göre, dondurulan fon veya kazancın, yargılama süreci sonunda ya **müsadere** edilecek ya da sahibine iade edilecektir. Halbuki, “Yaptırımlar Komitesi” tarafından oluşturulan listede yer alan kişilerin **bütün malvarlığı**, haklarında **soruşturma ve kovuşturma yapılmasına gerek olmaksızın** ve **süresiz** olarak dondurulmaktadır. Kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma açılması gerekmediği için, **dondurulan malvarlığının akıbetinin ne olacağı da belli değildir**^{36,37}.

Bugün “Taliban”, “El Kaide” ve “Usame Bin Ladin” üçlüsüyle irtibatlandırılarak, **halkı Müslüman ülkelerin vatandaşı** olan kişilerin malvarlığı ile ilgili olarak yapılan bu uygulama, bazıları tarafından “makul” görülebilir ve görülmektedir. Ancak bu uygulamanın yarın kimleri mağdur edeceğini şimdiden öngörmek, bir kehanet değildir.

Amerika Birleşik Devletlerinin dayatmasıyla oluşturulan bu “hukuki” rejim gereğince Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan “Komite” kararıyla terörü finanse ettikleri, teröre fon sağladıkları gerekçesiyle malvarlığı dondurulacaklar listesinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların sahibi oldukları veya kontrolleri altında bulundurdıkları malvarlıklarının üye

³⁶ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin hazırladığı listelerde isminin yer almasının kişi bakımından ortaya çıkardığı sonuçların “ölçsüz” olduğu hususunda bkz. MACKE, Julia: *UN-Sicherheitsrat und Strafrecht, Legitimation und Grenzen einer internationalen Strafgesetzgebung*, Berlin, 2010, sh. 130 vd.

³⁷ Söz konusu listelerde isimlerinin yer alması dolayısıyla, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan kişilerin maruz kaldığı muamele biçimi, insan onuruyla bağdaşmamaktadır (Örnek için bkz. MACKE, sh. 133).

Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı *Papier*’in, 2008 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda sarfettiği şu sözler dikkat çekicidir:

“Bu listelerde adınızın yer alması halinde, hiçbir şey yapamazsınız.” (MACKE, sh. 133).

Dikkat edilmelidir ki, kişinin isminin terör listesinde yer alması için, kendisine somut bir suç isnadında bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu listeleme kararlarında, herhangi bir suç işlediğinden bahisle kişi hakkında bir tedbir uygulaması da söz konusu değildir (MACKE, sh. 134 vd.).

devletler tarafından ne suretle yerine getirileceği, bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ancak devletlere yönelik olarak yaptırım kararları alabilir. **Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin doğrudan kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönünde karar alma yetkisi bulunmamaktadır**³⁸. Kaldı ki, terör eylemlerini finanse ettikleri ve teröristlere fon sağladıkları gerekçesiyle malvarlığı dondurulacaklar listesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile değil, Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan “*Komite*” kararıyla oluşturulmaktadır. Bu “*Komite*”nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kararına istinaden oluşturulması, aldığı kararların Güvenlik Konseyi kararı niteliği kazanmasını sağlamaz³⁹.

Güvenlik Konseyinin kararları yayımlanmakla birlikte, “*Komite*”nin malvarlıklarının dondurulması amacıyla kişilerle ilgili olarak aldığı listeye alma kararları ve oluşan liste içerikleri Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmamaktadır. Bu liste içeriklerinden, aşağıda izah edileceği üzere, Türkiye’de Bakanlar Kurulunun; 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliğine ve bilahare 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK ile 6415 sayılı Kanunda (m. 5) yapılan değişikliğe istinaden Cumhurbaşkanının aldığı malvarlığı dondurma kararlarının eki olarak Resmi Gazetede yayımlanması dolayısıyla haberdar olabilmekteyiz.

Bütün bu hukuka aykırılıklara rağmen Amerika Birleşik Devletlerinin dayatmasıyla oluşturulan fiili durum karşısında, söz konusu “*Komite*”nin gerçek ve tüzel kişilerin sahibi oldukları veya kontrolleri altında bulundurdıkları malvarlığı ile ilgili olarak aldığı dondurma kararlarını yerine getirmeyi kendileri bakımından bir “yükümlülük” olarak hisseden üye devletlerde, bu

³⁸ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı yaptırım kararlarının kişi hak ve özgürlüklerini dolaylı olarak etkilemesi mümkündür. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Şartının 41. maddesi gereğince bir devletle ekonomik ilişkilerin kesilmesini öngören kararlar alabilir. Bu durumda, yaptırım uygulanan devlet vatandaşı olsun veya olmasın, bu ülke ile ticari ilişkileri bulunan, bu ülkeden mal ihraç eden, bu ülkeye mal satan kişilerin hakları dolaylı olarak etkilenmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kişi hak ve hürriyetleri üzerinde dolayısıyla etkili olan, **dolaylı olarak kişilere seyahat ve mali bakımdan sınırlama getiren kararlar** almaktadır (MACKE, sh. 68 vd.).

³⁹ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin hazırladığı listelerde isminin yer almasının kişi bakımından ortaya çıkardığı sonuçlara ilişkin olarak bkz. MACKE, sh. 95 vd.

Yaptırımlar Komitesinin kararlarının Güvenlik Konseyinin kararları gibi bağlayıcı olduğu yönündeki görüşün (MACKE, sh. 139) hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

kararların yerine getirilmesi bakımından hukuki düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Avrupa Birliği Konseyi, “hülle” yöntemi izleyerek, Birleşmiş Milletler “Yaptırımlar Komitesi”nin oluşturduğu malvarlığı dondurulacaklar listesinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyon isimlerinin de yer aldığı ayrı bir karar almaktadır^{40,41}. Avrupa Birliği Konseyinin aldığı kararların (“*Council*

⁴⁰ Birlik, terörle mücadele ve bu çerçevede **Birlik üyesi olmayan devletlerin kendi ülke-
rindeki terörist faaliyetlerle mücadelesini desteklenmesi** hususlarında görevli kılınmıştır
 (“Avrupa Birliğinin Çalışma Tarzına Dair Antlaşma” (“*Treaty on the Functioning of
the European Union*”, “*Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union*”:
“AEUV”, “Lizbon ABÇT Antlaşması”), m. 43, f. 1 (358 maddeden ibaret olan “Avrupa
Birliğinin Çalışma Tarzına Dair Antlaşma” metni için bkz. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
[Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union], C 115,
9.5.2008, sh. 47 vd.)

Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi, özellikle terörizm, insan ticareti, kadınların ve çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti, silah kaçakçılığı, yolsuzluk, ödeme araçlarında sahtecilik, bilgisayar suçluluğu ve örgütlü suçluluk gibi işleme tarzı veya etkileri bakımından ağır suçlarda, bunlara karşı ortak bir temele dayalı olarak mücadele edebilmek için, suç tanımları, yaptırım türleri ve ceza miktarları bakımından asgari kurallar belirlemeye görevli ve yetkili kılınmıştır (Lizbon ABÇT Antlaşması, m. 83, f. 1).

Avrupa Birliği Konseyi gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından da hukuki sonuçlar doğuran yaptırım kararları alabilmektedir (Lizbon ABÇT Antlaşması, m. 215, f. 21). Avrupa Birliği organlarının aldığı kararlar, üye devletler bakımından bağlayıcılığı haizdir (Lizbon ABÇT Antlaşması, m. 4, f. 3).

⁴¹ Avrupa Birliği Konseyinin bu çerçevede **Afganistan**’la bağlantılı olarak aldığı son kararlardan bazıları şunlardır:

a) 29.09.2011 tarihli karar ve eki liste. Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 257, 1.10.2011’de yayımlanmıştır.

b) 29.09.2011 tarihli karar ve eki liste. Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 276, 21.10.2011’de yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği Konseyinin **El Kaide** ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle malvarlığının dondurulmasına karar verdiği kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin son liste, Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 280, 27.10.2011’de yayımlanmıştır.

Keza, Avrupa Birliği Konseyi, **İran**’daki “**insan hakları ihlalleri**” ile bağlantılı olarak 10.10.2011 tarih ve 2011/235 CFSP sayılı ile, belirli kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulmasına karar vermiştir (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 267, 12.10.2011, sh. 13 vd.).

Bu Kararda, İran’da adalet bakanlığı, hakimlik ve savcılık gibi önemli görevlerde bulunmuş olan kişiler, tutuklu ve hükümlülere kefi muamelede bulunmak, adil yargılanma hakkını ihlal etmek, işledikleri ileri sürülen suçlar nedeniyle çok sayıda kişinin uzun süre tutuklu kalmalarını, idam cezasına mahkûm edilmelerini ve bu cezalarının infaz edilmesini sağlamakla sorumlu tutulmaktadır.

Bu nedenle, oluşturulan listede yer alan kişilerin, bunlarla irtibatlı olan sair kişi, kuruluş ve organizasyonların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan **para ve sair bütün malvarlığı değerlerinin dondurulmasına** karar verilmiştir: Avrupa Birliği Konseyinin 12.4.2011 tarihli ve 359/2011 (EU) sayılı Direktifi (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 100, 14.4.2011, sh. 1 vd.; ayrıca Avrupa Birliği Konseyinin 12.4.2011

Decision”) Birliğe üye olan devletler bakımından bağlayıcılığı olduğu için, bu devletlerde Birleşmiş Milletler “*Yaptırımlar Komitesi*”nin almış bulunduğu dondurma kararlarının yerine getirilmesi bakımından ortaya çıkan sorun bu şekilde aşılmış olmaktadır^{42,43,44}.

tarhli ve 2011/235/CFSP sayılı Kararı (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 100, 14.4.2011, sh. 51 vd.

⁴² Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak oluşturduğu listelerin Avrupa Birliği Konseyi tarafından hazırlanan listelere uyarlanması süreci ile ilgili bilgi için bkz. VERMEULEN, Gert/DE BOND, Wendy: *European Report: Listing of Terrorists, Finding the Right Balance Between Effective Measures and Fundamental Human Rights Guarantees*, in: Revue Internationale de Droit Penal, 79 (2008), 3, 4, sh. 379 vd.

⁴³ Avrupa Birliği Konseyinin terörizmi desteklediğinden bahisle kişi, kuruluş ve organizasyonların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan malvarlığı değerleriyle ilgili olarak aldığı son kararlar, **1.8.2011** tarihli ve **2011/486/CFSP** sayılı ve ayrıca, **1.8.2011** tarihli ve **2011/487/CFSP** sayılı Kararlardır (Kaynak: Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 199, 2.8.2011, sh. 57 vd., 73 vd.).

Dikat çekmek isteriz ki, malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin listeler zaman zaman güncellenerek alınan son kararlar, bir önceki karar yürürlükten kaldırılmaktadır.

⁴⁴ Avrupa Birliği Konseyinin oluşturduğu listelerdeki isimler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin oluşturduğu listelerde yer alan isimlerle sınırlı değildir. Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan devletlerin talepleriyle bu listelere yeni isimler dercedilebilmektedir. Bu listelere yeni isim dercedilebilmesinde şu yöntem izlenmektedir:

Bir devlet tarafından önce terör suçundan dolayı soruşturma başlatılır. Ancak, bu soruşturmadan, sadece adli soruşturma anlaşılmamalıdır.

Soruşturmanın yapıldığı devlet tarafından, bu soruşturma çerçevesinde Avrupa Birliği Konseyinin hakkında soruşturma yapılan kişilerin isimlerinin listeye alınması talep edilir.

Soruşturmayı yapan ve listeye alınma talebinde bulunan devletin mutlaka Avrupa Birliği üyesi devlet olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Konseyinin listeye alma kararı öncesinde ilgililerin dinlenmesi esas itibarıyla söz konusu değildir.

Konseyin aldığı kararlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.

Konsey listeye aldığı kişi, kuruluş veya organizasyonlarını durumunu her altı ayda bir gözden geçirmektedir. Bu süreçte ilgililer, karardan önce dinlenmektedir (ROBERTS, Marc: *Terrorismusfinanzierung, Zugleich ein Beitrag zum internationalen Verwaltungsrecht*, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, 2011, sh. 168 vd., 181). Gözden geçirme kararı da Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.

Konseyin listeye alma kararı bir **idari tedbir** mahiyeti taşımaktadır (ROBERTS, sh. 181 vd.).

Konseyin aldığı kararlar yargı denetimine tabidir.

Avrupa Birliği Konseyinin oluşturduğu listelerden birinde yer alan bir isimle ilgili olarak açılan bir davada, Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi, 3.9.2008 tarihli kararında, aşağıdaki esaslardan hareket etmiştir (Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi EuGH, C-402/05 P und C-415/05 P. Kararın İngilizce, Fransızca veya Almanca metni için bkz. “<http://eur-lex.europa.eu>”) Söz konusu Kararın değerlendirmesi için bkz. SCHMALENBACH, Kirsten: *Bedingt kooperationsbereit: Der Kontrollanspruch des EuGH bei gezielten Sanktionen der Vereinten Nationen, Zum Urteil des EuGH von 3.9.2008, Rs. C 402/05 u. C 415/05 – Kadi und*

Birleşmiş Milletler “Yaptırımlar Komitesi”nin malvarlıklarının dondurulması amacıyla kişilerle ilgili olarak aldığı listeye alma kararları ve oluşan liste içerikleri Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmamakla birlikte; bu liste içerikleri de göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği Konseyinin aldığı malvarlığı dondurma kararları ve malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin listeler, Birliğin resmi yayın organında⁴⁵ yayımlanmaktadır.

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik uygulamaları yerinde görmek amacıyla Türk heyeti⁴⁶ olarak 15 ve 16 Temmuz 2010 tarihlerinde İspanya’ya yaptığımız çalışma ziyaretinde Madrid’de İspanya Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapmış bulunduğumuz görüşmelerde, Avrupa Birliği Konseyi tarafından malvarlığı dondurulacak kişiler arasında Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarının bulunamayacağı heyetimize ifade edilmiştir. Nitekim, Avrupa Birliği Konseyi tarafından alınan kararların ekindeki listelere bakıldığında, terörü finanse ettikleri ve teröristlere fon sağladıkları gerekçesiyle malvarlığı dondurulacaklar olarak belirlenen kişilerin tamamına yakınının, **halkı Müslüman olan ülkeler vatandaşı** oldukları görülmektedir. Avrupa Birliği Konseyinin bu çerçevede **malvarlığının dondurulmasına karar verdiği şirket, vakıf ve derneklerin Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlerde ve özellikle halkı müslüman olan ülkelere kurulmuş olduğuna** ayrıca dikkat çekmek isteriz⁴⁷.

Birleşmiş Milletler “Yaptırımlar Komitesi”nin kişilerin malvarlığı ile ilgili olarak aldığı dondurma kararlarının ne suretle yerine getirileceği hususunda

Al Barakaat, in *Juristenzeitung (JZ)* 2009, sh. 35 vd.; ROSSI, Matthias, *Gemeinschaftsrechtlicher Grundrechtsschutz gegen europarechtlich umgesetzte VN-Sanktionen*, in: *Zeitschrift für das Juristische Studium (ZJS)*, 5, 2008, sh. 551 vd.; MACKE, sh. 153):

1. Birlik Mahkemeleri, Avrupa Birliği Konseyinin BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin oluşturduğu listeleri esas almak suretiyle aldığı malvarlığının dondurma kararlarının hukuki bakımdan denetleme yetkisini haizdir.

2. Her ne kadar Avrupa Birliği Konseyi BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin oluşturduğu listeleri esas almak suretiyle malvarlığı dondurma kararı almakta ise de; Birlik Mahkemeleri Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin kararlarını değil, bu kararları esas almış olsa bile, **Avrupa Birliği Konseyinin kararlarının hukukiliğini denetleme yetkisini haizdir**.

3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına dayansa bile, Avrupa Birliği organlarının almış bulundukları kararların, **Birliğin oluşumuna ilişkin Sözleşmelerde güvence altına alınan temel hakların ihlali bakımından denetime tabi tutulması gerekmektedir**.

⁴⁵ “Official Journal of the European Union” / “Amtsblatt der Europäischen Union”.

⁴⁶ Bu heyette, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile akademisyen olarak şahsım yer almıştır.

⁴⁷ Bu hususta bkz. Avrupa Birliği Konseyinin 27.5.2002 tarihli ve 881/2002 EG sayılı Direktifi (Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, L 139, 29.5.2002, sh. 9 vd.

Türkiye’de de sorunla karşılaşmıştır. **Türkiye’de Birleşmiş Milletler “Yaptırımlar Komitesi”**’nin aldığı kararlara istinaden çok sayıda **Bakanlar Kurulu Kararları** çıkarılmış ve halen de, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliğine ve bilahare 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK ile 6415 sayılı Kanunda (m. 5) yapılan değişikliğe istinaden **Cumhurbaşkanı Kararları** çıkarılmaya devam etmektedir⁴⁸.

7.2.1013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre Bakanlar Kurulunun kararından önce, belirli kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına yönelik bir kararın varlığı gereklidir. Ancak, söz konusu fıkra metninde bu kararın hangi organ veya mercie ait bir karar olması gerektiği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonun malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir karar alınmaması sebebiyle, söz konusu Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında bu fıkra hükmü, şahsımın katkısıyla, şu şekilde ifade edilmişti:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999) sayılı Kararıyla oluşturulan Yaptırımlar Komitesinin listesinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.”

Tasarıdaki bu düzenleme, Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında **Adalet Bakanlığı bürokratlarının yanlış yönlendirme-**

⁴⁸ Bu çerçevede 2018.12.21 tarihi itibarıyla çıkarılan son karar, **26 Kasım 2018 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanî Kararıdır** (RG: 27 Kasım 2018/30608).

siyle, kanunlaşan şekliyle değiştirilmiştir. Özensizce kaleme alınan TBMM Adalet Komisyonu Raporunda yer verilen bu değişiklik ile ilgili gerekçe de gerçeklikle bağdaşmamaktadır:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin görevini yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü yardımcı organlardan biri olan Yaptırımlar Komitesinin tali bir organ olması ve son karar merciin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ise üye devletlerin imza ve onayına gerek duyulmaksızın uygulamaya konulur ve üye devletler açısından bağlayıcıdır.”⁴⁹

İşaret etmek gerekir ki, içeriklerine ilişkin olarak yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 6415 s. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan BM Güvenlik Konseyi Kararlarında malvarlığının dondurulması bağlamında herhangi bir kişi, kuruluş veya organizasyon ismi belirlenmiş değildir.

Yaptırımlar Komitesinin oluşturduğu listelerle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından ayrıca bir karar alınmamaktadır. Dolayısıyla, belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış bir karar olmadığı için, bu listelerin Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye devletler bakımından bağlayıcılığından da hukuken söz edilemez.

Malvarlığının dondurulması istenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin listeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999) sayılı Kararıyla oluşturulan Yaptırımlar Komitesi tarafından bilahare oluşturulmaktadır. Bu Komite tarafından oluşturulan listelerin Teşkilata üye devletler bakımından bağlayıcılığından hukuken söz edilemez.

Ancak, uluslararası güçlere teslimiyetçi bir ruhun yansıması olarak, Türkiye, 6415 sayılı Kanunla söz konusu Komitenin oluşturduğu listelerin bağlayıcılığını kabul etmiş bulunmaktadır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, BM Güvenlik Konseyi bünyesinde teşkil edilen Yaptırımlar Komitesinin, malvarlığı dondurulacak kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin olarak oluşturduğu listeler esas alınarak Türkiye’de çok sayıda Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır; halen de 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliğine ve

⁴⁹ Bkz. TBMM Adalet Komisyonu’nun 30.1.2013 tarihli ve E. 1/489, K. 17 sayılı Raporu.

bilahare 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK ile 6415 sayılı Kanunda (m. 5) yapılan değişikliğe istinaden **Cumhurbaşkanı Kararları** çıkarılmaya devam etmektedir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanı kararları ile, bazen, BM Güvenlik Konseyi bünyesinde teşkil edilen Yaptırımlar Komitesinin oluşturduğu ve Türkiye olarak bizim aynen kabul ettiğimiz listeye yeni kişi, kuruluş veya organizasyonların isimleri dahil edilmekte; bazen, söz konusu listede yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların isimleri listeden çıkarılmakta; bazen de, söz konusu liste, içerdiği bilgiler itibarıyla güncellenmektedir⁵⁰.

6415 s. Kanun, m. 5'e 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla dördüncü fıkra olarak elenen hükme göre,

“3'üncü ve 4'üncü madde kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde listelerden çıkarılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine teklif edilebilir. Cumhurbaşkanı'nın teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir.”

6415 s. Kanuna göre, yabancı bir devlet tarafından belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığı ile ilgili olarak dondurma talebinde bulunulduğunda da, Türkiye bu talebi yerine getirecektir (m. 6). Ancak, yine söz konusu Kanuna ilişkin hazırlık çalışmaları sırasındaki şahsi katkılarım ile, bu yerine getirmenin karşılıklılık koşuluna bağlanması sağlanmıştır (m. 6, f. 1).

Takip edebildiğimiz kadarıyla Türkiye'den bugüne kadar herhangi bir yabancı devlet tarafından belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığı ile ilgili olarak dondurma talebinde bulunulmamıştır.

⁵⁰ Bütün bu kararlar gözden geçirildiğinde görülecektir ki, **bu malvarlığı dondurulanlar arasında PKK ile ilişkili hiçbir kişi, kuruluş veya organizasyon bulunmamaktadır.**

Bu düzenlemenin yapılmasını Türkiye’den isteyen özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’tır. Bu düzenlemeye göre Türkiye de terörle mücadelede “dayanışma” içinde olduğu ve “ortak strateji” izlediği devletlerden belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığı ile ilgili olarak dondurma talebinde bulunabilecektir (6415 s. K, m. 7).

Yine takip edebildiğimiz kadarıyla **Türkiye, devletin güvenliğine karşı somut bir tehdit oluşturan PKK ile irtibatı bulunan belirli bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığı ile ilgili olarak herhangi bir devletten dondurma talebinde bulunmuş değildir.**

Buna rağmen, Türkiye’ye karşı bir “dostluk” göstergesi, bir “cemile” olsun diye, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı devletler ve Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütleri listesinde göstermektedirler. Ancak, buna rağmen, bu devletler kendi ülkelerinde bulunan ve PKK’ya mali destek sağlayan kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığı ile ilgili olarak herhangi bir koruma tedbiri uygulanması veya dondurma yoluna gidilmemiştir.

6415 s. Kanun, m. 7’ye 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunla eklenen hükümlere göre;

“(3) 5’inci ve 6’ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3’üncü ve 4’üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhâl uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(5) *Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunar.*

(6) *İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılır. Komisyon, taleplere ilişkin önerisini ilgili bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler dördüncü fıkra uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.*

(7) *Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına Başkanlık tarafından karar verilir. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir.”*

Bu hükümlere göre; Türkiye’de **gerçek kişilerin veya şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişilerin malvarlığının dondurulmasına** “*Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.*” (f. 3). Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı bu kararı, **gerçek kişinin veya şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin** terörizmin finansmanı suçunu oluşturan “*filleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden*” verebileceklerdir (f. 3). Dikkat edilmelidir ki, **Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının malvarlığının dondurulmasına karar verebilmesi için, ilgili kişiler hakkında terörizmin finansmanı suçunu işledikleri şüphesine binaen adli soruşturma başlatılmış olması da bir şart olarak aranmamaktadır.** Ancak, bu suretle malvarlığının dondurulduktan sonra, MASAK Başkanlığı tarafından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilecektir (f. 7). MASAK Başkanlığının bu suç duyurusu ile ilgili olarak Kanunda azami bir süre belirlenmeyerek, açık bir **keyfilik kapısı** bırakılmıştır. Bu suç duyurusu üzerine ilgililer hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesi halinde, idari nitelikteki malvarlığı üzerindeki dondurma kararının kendiliğinden kalkmadığına dikkati çekmek isteriz.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu suretle malvarlığı dondurulmuş olan gerçek veya tüzel kişinin “*yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağla-*

yan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.” (6415 s. Kanun, m. 15, f. 2)

Bu **istibdad düzenlemelerinin** hukukla bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır.

IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”

16 Şubat 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7.2.2013 tarihli 6415 sayılı “**Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun**”, Amerika Birleşik Devletlerinin FATF üzerinden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkeleri zorlaması üzerine, hazırlanmış ve kanunlaşmıştır.

Öncelikle belirtelim ki, söz konusu Kanun, **Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadele bağlamında duyduğu ihtiyaca binaen hazırlanmış ve kabul edilmiş bir kanun değildir.** Söz konusu Kanun, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’ye dayatması sonucu kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun, **kişiler hakkında herhangi bir suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma başlatılmaksızın, suçla irtibatı olup olmadığının önemi olmaksızın, idari kararla bütün malvarlığının süresiz olarak dondurulmasını** sağlayan hükümler içermektedir. Bu Kanuna göre, **Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre kurulmuş bir şirketin, vakfın veya derneğin bütün malvarlığına hakim kararına ihtiyaç duyulmaksızın, bir suç nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmaksızın süresiz olarak elkonulabilecektir.** Bu yönü itibarıyla, söz konusu Kanun, yargı kararına dayanmaksızın “**genel müsadere cezası**” (Any., m. 38, f. 10) mahiyetinde uygulamaya imkan tanıyan hükümler içermektedir.

Bu Kanun, başka devletin idari organlarının talebi üzerine, **Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre kurulmuş bir şirketin, vakfın veya derneğin bütün malvarlığına hakim kararına ihtiyaç duyulmaksızın, bir suç nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmaksızın elkonulabilmesinin yolunu açmaktadır.**

İlginçtir ki, Ceza Muhakemesi Kanunu bir adli soruşturma bağlamında sadece **suçtan elde edildiği hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan malvarlığına** ancak **hakim kararıyla** elkonulmasına imkan tanımakta iken (m. 128); bu Kanun, bir adli soruşturmanın varlığına gerek olmaksızın, re’sen ve

hatta, bir başka devletin (Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, İs-rail'in) talepte bulunması üzerine alınacak olan bir **idari karar**la Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre kurulmuş bir şirketin, vakfın veya derneğin **bütün mal-varlığının** süresiz olarak dondurulmasına imkan vermektedir.

CMK'da ve ilgili diğer mevzuatta, bir suç nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde eşyaya, malvarlığı değerine, hak ve alacaklara “**elkoyma**” ibaresi kullanılmaktadır. Buna karşılık, 6415 sayılı Kanunda ise “**malvarlığının dondurulması**” ibaresi kullanılmıştır. Elkoyma gibi, malvarlığının dondurulması ibaresi de, “... **malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını, ... ifade**” etmektedir (6415 s. K, m. 2, f. 1, bent d).

Elkoyma kararı, ancak delil kıymetini taşıyan veya müsadere edilmesi gereken eşya ile ilgili olarak verilebilir (CMK, m. 123, f. 1). Elkoyma kararı, ancak suçun işlenmesi sırasında kullanılan, suçun konusunu oluşturan, suçtan elde edilen eşya ve sair malvarlığı ile ilgili olarak verilebilir.

Bu itibarla, elkoyma ancak soruşturma ve kovuşturma süresi ile sınırlı bir koruma tedbiridir.

Elkoyma kararı kural olarak **hakim** tarafından verilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. savcısının da elkoyma yetkisi bulunmakla birlikte; C. savcısının aldığı elkoyma kararı, bir itiraz olmasa bile, kanun gereği olarak hakim denetimine tabi tutulmuştur (CMK, m. 127; 5549 s. “Suç Gerirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”, m. 17).

Buna karşılık, **malvarlığının dondurulması kararı**, suçtan elde edilmiş olup olmadığına, bir suçun işlenmesinde kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın, verilebilmektedir. Dondurma kararı kişinin sahip bulunduğu **bütün malvarlığı** ile ilgili olarak verilebilecektir. Bu itibarla, somut bir suçla ilişkilendirilmese bile, **meşru bir yolla elde edilmiş malvarlığı hakkında da dondurma kararı verilebilecektir**.

Malvarlığının dondurulması kararı, bir süre ile sınırlandırılmış değildir. Kişinin meşru bir yolla sahip olduğu malvarlığı değeri üzerindeki tasarruf yetkisi **süresiz olarak** kaldırılabilir. Bu durumda kişiye meşru yolla sahip bulunduğu malvarlığından **ölmeyecek kadar yararlanabilme imkanı** oluşturulabilmektedir (6415 s. K, m. 13, f. 2).

Malvarlığı, bir **idari karar**la dondurulabilmektedir. Her ne kadar idarenin bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi ise de, ilgili kişi gerekli idari

yargı yoluna başvurmadiğı sürece malvarlığının dondurulması kararlarının hukukiliğinin denetlenmesi söz konusu değildir.

Bütün bu yönleriyle malvarlığının dondurulması, yargı kararına bile gerek olmaksızın, bir “**GENEL MÜSADERE CEZASI**” (Anayasa, m. 38, f. 10) uygulaması sonucunu doğuracak mahiyet taşımaktadır.

Bir başka devletin talebi üzerine alınan **malvarlığının dondurulması kararı**, talepte bulunan devlette belirli bir süre zarfında ilgili kişiler hakkında terörizmi finanse ettikleri veya finanse etmeye teşebbüs ettikleri şüphesiyle adli soruşturma başlatılmadığı takdirde, **kaldırılabilir** (6415 s. K, m. 6, f. 5). Bu hüküm, bir **müstemleke kanunu** mahiyeti taşıyan söz konusu Kanunun hazırlık çalışmaları sırasındaki ısrarlarımız üzerine Kanuna konulmuştur. Ancak, ısrarımıza rağmen, bir yıllık süre zarfında adli soruşturma açılmasa bile malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmayarak uygulanmasına devam edilebilecektir⁵¹.

Belirtmemiz gerekir ki, **Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, bu Kanuna itiraz (!?) etmektedirler:**

1) Bir başka devlet tarafından talepte bulunulması üzerine malvarlığının dondurulması kararı verilebilmesinin **karşılıklılık şartına** bağlanmış olmasına (6415 s. K, m. 6, f. 1, ikinci cümle) itiraz edilmektedir. Kanunda değişiklik yapılarak bu şartın kaldırılması talep edilmektedir.

2) Bir başka devlet tarafından talepte bulunulması üzerine malvarlığının dondurulması kararı verilebilmesi için, talepte bulunan devletten **teminat istenmesine** imkan tanınmasına (6415 s. K, m. 6, f. 3) itiraz edilmektedir. Kanunda değişiklik yapılarak bu hükmün yürürlükten kaldırılması talep edilmektedir.

3) Bir başka devlet tarafından talepte bulunulması üzerine verilen **malvarlığının dondurulması kararının** Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili kişiler hakkında talep eden devlet tarafından adli soruşturma başlatılmadığı takdirde bu kararın **kaldırılabilmesine** imkan tanınmasına (6415 s. K, m. 6, f. 5) itiraz edilmektedir. Kanunda değişiklik yapılarak bu hükmün yürürlükten kaldırılması talep edilmektedir.

⁵¹ Bu Kanunun hazırlık çalışmaları sırasında yapılan bir toplantıda, eleştirilerimi ifade etmem üzerine, Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan, bu eleştirilere tepki olarak, “**biraz da biz insan hakkı ihlal edelim**” cevabını vermiştir.

4) Malvarlığının dondurulması kararlarının **Bakanlar Kurulu** tarafından verilmesine (6415 s. K, m. 5, f. 1; m. 6, f. 1) itiraz edilmektedir. Bu bağlamda malvarlığının dondurulması kararlarının **MASAK** veya **Maliye Bakanı** tarafından verilmesi yönünde Kanunda değişiklik yapılması talep edilmektedir.

5) Terörizmin finansmanı suçunun “*yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması(nın) Adalet Bakanının talebine bağlı*” kılınmasına (6415 s. K. , m. 4, f. 5) itiraz edilmektedir. Kanunda değişiklik yapılarak bu hükmün yürürlükten kaldırılması talep edilmektedir.

Tekrar belirtmemiz gerekir ki, söz konusu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devletin maruz kaldığı terörist faaliyetlere karşı efektif olarak işletilebilecek düzenlemeler içermemektedir.

Bu Kanun, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin terörizmle bağlantı kurarak kişi ve kuruluşların malvarlığını dondurma yönündeki taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti kamu otoriteleri tarafından yerine getirilmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler içermektedir.

Bu Kanun hükümlerine dayanılarak, gerçek kişiler gibi, büyük sermaye şirketlerinin de bütün malvarlığı dondurulabilecektir. Yeter ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi bir başka devletin bu yönde bir talebi olsun.

2011 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin, İran kaynaklı ham petrolü işleyerek piyasaya sürdüğü gerekçesiyle TÜPRAŞ’ın malvarlığını dondurma yönündeki girişimi, bu bağlamda göz önünde bulundurulması gerekir.

Avrupa Birliği Konseyinin malvarlığı dondurulacak kişi ve kuruluşlara ilişkin olarak oluşturduğu listelerde onlarca şirket ismi yer almaktadır. Bu şirketlerin hepsi, Ortadoğu kökenli sermaye şirketleridir.

Bu nedenle, Arap sermayesi Avrupa Birliği ülkelerinden kaçmış ve kendisine güvenli bir liman arayışı bağlamında Türkiye’ye gelmiştir. Söz konusu Kanun sebebiyle, bu sermaye başka bir güvenli liman aramak gereği hissedecektir.

Bu Kanun, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin dayatması üzerine çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyi yapmaması halinde Türkiye, terörizmi finanse eden, terörizmi destekleyen devlet olarak hakkında yaptırım uygulanmakla tehdit edilmiştir.

§3. TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU¹

Giriş

Terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuna ilişkin uygulamamız, her zaman ifrat ve tefrit arasında sorunlarla maluldür. Bu sorunlara kanuni düzenlemelerimizin de sebebiyet verdiği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çalışmada, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuna ilişkin kanuni düzenlemelerdeki sorunlu alanlar, bu suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, verilen hükümlerde, bu hükümlerin kanun yolu denetimi ve bireysel başvuru üzerine yapılan denetim bağlamında yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Keza, tespit edilen bu sorunların hukuk zemininde çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

I. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1991 yılında kanunlaşan metninde, terör örgütü mensuplarına yardım ile terör örgütünün propagandası fiilleri, uygulama itibarıyla, “seçimlik” hareketli bir suç olarak tanımlanmıştı (m. 7, f. 2).² Bu tanımlama çeşitli yönlerden hukuk ve kanun yapma tekniği ile uyumlu değildi. Şöyle ki bu düzenlemede örgüte yardım ile örgüt mensuplarına yardım arasındaki ilişki ve fark göz ardı edilmişti. Keza bu düzenlemede, konuları ve mahiyetleri itibarıyla birbirinden farklı olan iki fiil, bir suçun “seçimlik” hareketleri olarak tanımlanmıştı. Bu düzenlemenin en mahzurlu yönü ise, suç tanımında “*fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca*” ibaresine yer verilerek, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmasına imkân tanınmaması, kişinin bir fiil sebebiyle mükerrer cezalandırılmasının yolunu açması idi.³

¹ Bu başlık altında yer alan açıklamalar, ÖZGENÇ, İzzet: *Terörizmin ve Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve Ceza Hukuku Sorumluluğu*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXV, sayı 2, Nisan 2021, sh. 373 vd.’nda makale olarak yayımlanmıştır.

² Terör örgütü “*mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.*”

³ 3713 s. Terörle Mücadele Kanununun terör örgütünün propagandası suçu ile ilgili hükümlerinde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi için bkz. YILDIRIM, Zeki: *İfade ve Basın özgürlüğü Bağlamında Terör Örgütünün Propagandası Suçu*, 2. bası, Ankara, Eylül 2020, sh. 239 vd.; TOPÇU, Namık Kemal: *Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu*, in: CHD Ceza Hukuku Dergisi, cilt X, sayı 28, Ağustos 2015, sh.108 vd.

TMK, m. 7, f. 2’de 2002 yılında 4744 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, terör örgütünün propagandası fiiline “açıklık” getirilmeye çalışılmıştı.⁴ Buna göre, “*terör yöntemlerine başvurmayla özendirerek şekilde örgütle ilgili propaganda*” yapılması, suç oluşturmaya. Ancak bu tanımda “*örgütle ilgili propaganda*”nın hangi hallerde suç oluşturmayaacağı hususu belirsizlikle maluldü.

Bu fıkra 2003 yılında 4963 sayılı Kanunla yeniden değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle “*şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda*” fiili, suç olarak tanımlanmıştı.⁵ Bu tanımlamada, propagandanın örgütle ilişkisi koparılmış; propaganda ile, suçu övme ve suç işlemeye teşvik suçları arasındaki ayırım ölçütü belirsiz bir hal almıştı. Ayrıca, şiddet dışında “diğer terör yöntemleri” ibaresiyle neyin anlatılmak istendiğinin izahı kabil değildi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, bu Kanun hükümleriyle uyumunun sağlanması amacıyla Terörle Mücadele Kanununda 2006 yılında 5532 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun değişikliği ile, terör suçu, terör amacıyla işlenen suç, terör örgütü ve terör örgütünün propagandası suçları yeniden tanımlanmıştır.

5532 sayılı Kanun değişikliği ile Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki suç tanımı, **terör örgütünün propagandası** suçuna özgülenmiştir. Terör örgütü mensuplarına yardım fiili ise, TCK, m. 220 hükümleri çerçevesinde örgüte yardım kapsamında değerlendirilmiştir. 3713 s Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki tanıma göre;

“Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu çalışmada, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçu bakımından iki temel husus üzerinde durulacaktır. Bunlardan birincisi suçun konusunu

⁴ 3713 s. Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 6.2.2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla (m. 3; RG: 19 Şubat 2002/24676) değiştirilen ikinci fıkrası hükmüne göre;

Terör örgütü “mensuplarına yardım edenlere veya **terör yöntemlerine başvurmayla özendirerek şekilde örgütle ilgili propaganda** yapanlara **fiilleri başka bir suç oluştursa bile** ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.”

⁵ 3713 s. Kanunun 7. maddesinin 30.7.2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunla (m. 30; RG: 7 Ağustos 2003/25192) değiştirilen ikinci fıkrası hükmüne göre;

Terör örgütü “mensuplarına yardım edenlere veya **şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda** yapanlara **fiilleri başka bir suç oluştursa bile** ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.”

oluşturan terör örgütü ibaresinden, diğeri ise suçu oluşturan fiil olarak propaganda yapmaktan neyin anlaşılması gerektiği hususudur.

Propaganda suçunun konusu, **terör örgütüdür, terör örgütünün faaliyetleridir, örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar** ve terör örgütünün **kurucu, yönetici** ve sair **üyeleridir**. Suçun oluşabilmesi için, **propaganda-nın belirli bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi gerekir**.⁶ Propagandanın özelliği, belirli veya belirsiz kişileri **muhatap** almasıdır;⁷ yani belirli veya belirsiz kişileri **etkilemek amacıyla** yapılmasıdır. Bu yönü itibarıyla propaganda suçu ancak **doğrudan kastla** işlenebilen bir **amaç suçu**dur.⁸ Ancak suçun tamamlanabilmesi için, başkalarının etkilenmiş olması gerekli değildir. Propaganda suçunun unsurları arasında aleniyet yer almamaktadır. Propagandanın alenen yapılması, toplumda erişebildiği kişi sayısı, temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınır.⁹

Propaganda suçu, somut bir suç şüphesine istinaden yapılan adli soruşturma ve kovuşturma neticesinde mahkeme hükmüyle terör örgütü olduğu tespit edilen bir örgütsel yapının varlığının ve faaliyetlerinin “meşruiyetini” kabul etmeleri yönünde kişilere bulunulan **çağrıyı** ifade etmektedir. Bu çağrı bağlamında **terör örgütü ve suç oluşturan faaliyetleri övülmektedir**.¹⁰ Bu itibarla örneğin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış olan bir siyasi partinin ve faaliyetlerinin övülmesi, bu siyasi partiye ait amblem ve işaretlerin gösteri-şe sunulması, gösteri amaçlı olarak kullanılması, terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmaz. Keza, salt idari bir kararla “terör örgütü” olduğu kabul ve ilan edilen bir örgütsel yapının, bu yapı bünyesinde icra edilen faaliyetlerin övülmesi, bu örgütsel yapıya ilişkin işaretlerin kullanılması, 3713 s. K, m. 7, f. 2’de tanımlanan terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmaz.

Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen **suçların ve faillerinin övülmesi** halinde, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçu oluşur. Terör-

⁶ BGH, Urteil vom 2.4.2015, 3 StR 197/14, kn. 12.

⁷ BGH, Urteil vom 2.4.2015, 3 StR 197/14, kn. 13.

⁸ Yargıtay 16.CD, 14.3.2017, E. 2016/7430, K. 2017/3637. Ayrıca bkz. TOPÇU, CHD, cilt X, sayı 28, Ağustos 2015, sh.126 vd.

⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, propagandanın basın ve yayın yoluyla yapılması, söz konusu suçun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Ayrıca bkz. AİHM, Zana/Türkiye Kararı, 25.11.1997.

¹⁰ Bkz. AİHM, Hocaogulları/Türkiye Kararı, 7.3.2006; AİHM, Sürek/Türkiye Kararı, 8.7.1999. Ayrıca bkz. ARSLAN, Zühtü: *İstisnanın Normalleş(tiril)mesi, Terör ve İfade Özgürlüğü: Türkiye Tecrübesi Üzerine Notlar*, in: İfade Özgürlüğü, İlkeler ve Türkiye, İstanbul, 2007, sh.191 vd.

rizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun oluşabilmesi için, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen ve övülen suçun mutlaka cebir, şiddet veya tehdit içermesi gerekmemektedir. Keza, işlenen suçlardan bahisle terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun işlenebilmesi için, övgüye mazhar kılınan suçların somutlaştırılmış olması gerekmemektedir. Propaganda suçu bakımından önemli olan, **kullanılan** “direniş”, “savaş”, “kutlu savaş”, “cihat” gibi **ifadelerin terör örgütüyle ilişkilendirilmesidir**. Kullanılan bu ve benzeri ifadelerin terör örgütüyle ilişkilendirilememesi durumunda, propaganda suçu oluşmaz. Bu bakımdan mesela genel olarak İslâmî cihattan bahsetmek, suç oluşturmaz. Ancak, “PKK”, “DAEŞ” veya “İŞİD” olarak isimlendirilen çeşitli örgütsel yapıların faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen ve çok sayıda insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılara işaretler “savaş”tan veya “cihat”tan söz etmek, propaganda suçunu oluşturur.

Bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsa bile, somut bir suçun işlenmesinden dolayı duyulan “memnuniyeti”, “sevinci” ifade zımında icra edilen fiiller, şayet terör örgütüyle ilişkilendirilmemiş iseler, TCK, m. 215’de tanımlanan suç ve suçluyu övme suçu bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar.

Terör örgütünün propagandası fiilinin aslında terör örgütüne yardım olarak değerlendirilmesi gerekir. Terör örgütünün propagandasının yapılmasıyla, örgüte bir nevi manevi yardımda bulunmaktadır. Propaganda faaliyeti, **terör örgütüne üye veya destekçi kazandırma çabasını**, ifade etmektedir. Propagandada, **örgüte üye veya destekçi kazanma amacı** güdülmektedir.¹¹ Yargıtay kararlarında da, terör örgütünün propagandası, örgüte **maddi nitelikte olmayan yardım** olarak değerlendirilmiştir.^{12, 13}

¹¹ Münchener Kommentar zum StGB (Schäfer), § 129, kn. 124.

¹² Yargıtay CGK, **3.3.2009**, E. 2008/9-184, K. 2009/43; Yargıtay CGK, **12.2.2008**, E. 2007/9-230, K. 2008/23; Yargıtay 16. CD, **12.9.2019**, E. 2019/7004, K. 2019/5220. Bu mülahazayla-
dır ki, “... **Lisesi duvarına terör örgütünün propagandası niteliğinde yazı yazılması**” fiili, **silahlı terör örgütüne yardım etme** suçunu oluşturduğu ve bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmesi gerektiği kabul edilmiştir (Yargıtay CGK, **23.2.2010**, E. 2010/9-7, K. 2010/37). Başka bir ifadeyle Yargıtay, **terör örgütünü öven ifadelerin spreyle boyayla duvarlara yazılması** fiilini, terör örgütünün propagandası olarak değil, **örgüte yardım** olarak değerlendirmiştir (Yargıtay 16. CD, **17.10.2019**, E. 2019/6477, K. 2019/6216). Keza, Yargıtay’a göre, terör örgütünün propagandası mahiyetinde içeriği sahip bulunan basılmış (matbu) materyalin dağıtılması, 3713 s. TMK, m. 7, f. 2’de tanımlanan suç değil, terör örgütüne yardım suçunu oluşturmaktadır (Yargıtay 16. CD, **26.2.2018**, E. 2017/3230, K. 2018/1016).

Bkz. YURTLU, Fatih: *Suç Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu*, in: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XX, sayı 3, Temmuz 2016, sh. 424; ÖZBEK, Uğur: *İfade Öz-*

gürlüğü Bağlamında Terör Örgütünün Propagandası Suçu, Ankara, Ocak 2020, sh. 110 vd.; TAŞTAN, Mehmet: *Terörle Mücadele Kanununun 7/2 Maddesi, (Terör örgütünün Propagandasını Yapmak Suçu)*, in: CHD Ceza Hukuku Dergisi, cilt III, sayı 6, Nisan 2008, sh.104.

- ¹³ Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, işlediği fiiller esasında terör örgütünün propagandası mahiyeti taşımasına rağmen, fiilin işleniş biçimini göz önünde bulundurarak, kişiyi **terör örgütüne yardım etmekten** dolayı mahkûm edilmesi gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **30.4.2019** tarihli ve E. 2017/693, K. 2019/352 sayılı Kararı'na konu teşkil eden olayda; PKK terör örgütü mensupları tarafından örgütün etkili olduğu bölgelerde **"Önder Apoyu yaşa ve yaşat", "Êdi Bes E!", "Artık Yeter!"** gibi adlarla çeşitli kampanyalar başlatılır. Bu suretle, örgüt mensuplarınca "lider" olarak kabul edilen ve halen hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan şahsın tekrar gündemleştirilmesi, bu kişiye izafe edilen görüş ve düşüncelerin toplumda canlı tutulması amaçlanır. Bu kampanya çerçevesinde, özellikle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulunan şahıslar tarafından adli mercilere **"Ben de Sayın Öcalan diyorum", "Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Öcalan diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum"** ibarelerini içeren matbu dilekçeler gönderilir. Keza, bu etkinliğin bir parçası olarak, Diyarbakır'da "Büyük Postane" önünde yapılan "basın açıklaması"nda;

"... Biz Kürtlere reva görülen, baskıcı yasaları ve yasakları ret ediyoruz. İrademize, söylemlerimize demokratik ve insani istemlerimize bile tahammül etmeyen zihniyet sürekli karşımıza anti demokratik yasalarını çıkararak bizleri en insani talep ve mücadelemizden uzaklaştırmak istiyor. Bu dayatmaları kabul etmedik etmeyeceğiz. En belirgin dayatma ve baskılar, on yıldır bir adada inşa edilen zindanda baskı altında yaşamaya mahkûm edilmiş ve milyonların iradesi olarak kabul görmüş sayın Öcalan'a uygulanan her türlü kısıtlayıcı, baskıcı uygulamalardır. En son uygulama olarak da zorla saçlarının kazıtılması olayını gayrı ahlaki ve gayrı insani bir uygulama olarak görüyor ve protesto ediyoruz. Biz Kürtler kimliğimize, dilimize inkarcı yaklaşımlardan, kime nasıl hitap edeceğimize dair izin almaya mecbur değiliz. Bu bağlamda kendini ihbar edenler olarak, imza dilekçelerimiz genel toplamda 25000 adettir. Biz ifade edilen sayıdaki kişiler olarak suç sayılan bu fiili tekrarlıyoruz. İmzaladığımız dilekçe örneğini bir daha tekrarlıyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na Küresel gelişmelerle birlikte Ortadoğu'daki güç dengelerinin değişmesi, Türkiye'nin içerisine düştüğü ulusal ve uluslararası çıkmazlarla barış ve demokrasiye olan tahammülsüzlüğü son noktaya gelmiştir. Başta Kürtlerin temel hak ve özgürlük taleplerinin reddi, inkarı ve çözümsüzlüğü olmak üzere, toplumdaki diğer temel sorunların kendi dinamikleri ile çözme yerine, her türlü şiddet ve baskı yöntemini tercih etme yolunu benimsemiştir. **Daha önce Kürt kelimesine karşı olan tahammülsüzlüğün yerini bugün de sayın Öcalan hitabı almıştır.** Temel sorunları çözme yerine yargı baskısı ile örtbas ederek sonuç alma yoluna gidilmiştir. Bu baskı o kadar ilerletilmiştir ki insanların hitapları dahi dava konusu yapılmıştır. Bunun en somut örneği, 9 yıldır tek başına Özel Tıp İmralı Kapalı Cezaevinde bulunan **sayın Öcalan'a 'sayın' olarak hitap edilmesidir.** Bugüne kadar binlerce soruşturma başlatılıp yüzlerce yurttaş, yönetici, aydın, siyasetçi ceza almıştır. En son avukatlarının resmi mercilere yaptıkları başvurularda geçen sayın sözcüğü nede niyle dahi soruşturma başlatılmıştır. **Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de sayın Öcalan diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum"**

ifadelerine yer verilir.

Aralarında A'nın da bulunduğu grup içindeki kişiler, **"Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de sayın Öcalan diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum"** içerikli matbu dilekçeleri imzalayarak zarf içinde PTT aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler.

Cumhuriyet Başsavcılığı, A hakkında **suçu ve suçluyu övme** ve silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği iddiasıyla iddianame düzenlemiştir.

İlk Derece Mahkemesi, A'nın silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğini kabul ederek, 3713 sayılı Kanun, m. 7, f. 2 ... hükümleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, A'nın ve grup içindeki diğer kişilerin fiillerinin “*silahlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu*” gerekçesi ile, bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

İlk Derece Mahkemesi, bu bozma kararına uyarak, A'nın fiilinin “*örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek*” suçunu oluşturduğunu kabul ederek, TCK, m. 314, f. 3 delaletiyle m. 220, f. 7; m. 314, f. 2; 3713 sayılı Kanun, m. 5... hükümleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İlk Derece Mahkemesinin bu mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıdaki gerekçe ile bu onama kararına itiraz etmiştir:

Terör örgütünün propagandası suçu ile terör örgütüne yardım suçları bakımından “*en ayırıcı ölçüt, yardım fiillerinin maddi nitelikte bulunup bulunmamasıdır. Maddi nitelikteki yardım fiilleri ... 5237 sayılı TCY'nın 220/7. maddesi kapsamında, maddi nitelikte olmayan fiiller ise 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.*”

Bu itibarla, sanıkların işlediği fiiller, “*nitelik ve yoğunlukları da dikkate alındığında maddi yardım niteliğinde görülmediğinden, 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur.*”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine karar vermiştir:

“*765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistematığından tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda, örgütün faaliyetleri doğrultusunda işlenen suçlardan da ayrıca sorumluluk esası kabul edilmiş, yardım etme eylemleri de yaptırım açısından örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek bağımsız bir şekilde örgüte yardım suçuna yer verilmemiş, gösterdiği vahamet dikkate alınarak örgüte silah sağlama şeklindeki yardım fiilleri 5237 sayılı TCK'nın 315. maddesinde bağımsız olarak, diğer yardım fiilleri ise örgütün niteliğine göre anılan Kanun'un 220 ile 314. maddeleri kapsamında yaptırıma bağlanmıştır.*

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı hüküm altına alınırken, **örgüte yardım sayılan eylemlerin nitelik bakımından örgüt üyeliğine denk sorumluluğu gerektirdiği** kabul edilmiştir. Buna göre, örgüt üyesi olmaksızın, bilerek ve isteyerek örgütün bir iş, görev ya da hizmetinin yerine getirilmesi eylemi örgüt üyeliği olarak cezalandırılmakta iken; ... yapılan yardımın niteliğine göre cezanın üçte birine kadar indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Silahlı terör örgütüne yardım fiilinin oluşması için, failin örgüt üyeleriyle önceden bir anlaşma yapması veya yapılan planlara dahil olması zorunlu değildir. Yardım fiilinin örgüt üyelerinin tamamına veya üyelerden birine yapılması arasında bir fark bulunmamaktadır. Fakat, örgütün amacı ve kollektif faaliyetleri bilinerek ve istenerek yardım edilmesi zorunludur. Yardım edenler zamanlarının büyük bir bölümünü örgüte hasretmiş kişiler olmayıp kendi hayatlarının akışı içerisinde bazen örgüte ait işleri kabul eden şahıslardır.”

A'nın söz konusu etkinlikler çerçevesinde hem “*...eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Öcalan diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum*” şeklindeki “*dilekçenin hem de başka kişilere ait aynı mahiyetteki çok sayıda dilekçenin posta yoluyla gönderilmesine yönelik işlemlerin tamamlanabilmesi için gereken zarflama ve zarflarda yer alan gönderici ve alıcı kısımlarını doldurma işlerini tamamlayıp söz konusu dilekçelerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere PTT Müdürlüğüne teslimi şeklindeki PKK terör örgütünün amacını gerçekleştirmeye hizmet eden faaliyetlerinin, silahlı terör örgütüne yardım etme niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.*”

Terör örgütünün “çözmeyi amaç” edindiği **hukuki, siyasi, sosyal veya ekonomik sorunlarla ilgili düşünce açıklamalarında bulunmak, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmaz.**¹⁴ Örneğin Kürtlerle ilgili olarak anadilde eğitim sorunundan söz etmek, Kürtçenin okullarda anadil olarak öğretilmesini ve hatta resmi dil olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmak, düşünce ve ifade özgürlüğünün bir tezahürüdür.^{15,16} Meğer

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu içtihatla bulunurken, bütün bu olayları kolluğun gözlemlediğini, A’nın bütün bu fiillerini kolluğun gözü önünde cereyan ettiğini, yapılan “basın açıklaması”na ve toplanmış olan binlerce dilekçenin zarflanarak postaya verilmesine engel olunmadığını değerlendirmeye tabi tutmamıştır.

Terör örgütünün propagandası ile örgüte yardım arasındaki ilişki bağlamında ayrıca bkz. Yargıtay CGK, **7.2.2017** tarihli ve E. 2013/383, K. 2017/60; Yargıtay 16. CD, **21.12.2017**, E. 2017/2155, K. 2017/5799.

¹⁴ Örneğin CEMAL, Hasan: 1930'lar Türkiye'sinden: *"Kürtçe konuşma, jandarma gelir!" "Pazarda Kürtçe konuştu diye jandarma gelir, elinden parasını alırdı. Bu bana çok acı geliyordu"*, in: T24.com.tr, 26 Şubat 2021.

¹⁵ Yargıtay 9. Ceza Dairesinin **9.5.2012** tarihli ve E. 2010/16268, K. 2012/5801 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; **Türkiye’de faaliyette bulunan bir siyasi partinin** Mardin Mazıdağı ilçe teşkilatının yönetici ve üyeleri ile halktan yaklaşık 250 kişilik bir grup, **26.1.2009** günü ilçe merkezindeki meydana toplanır. Bu toplantıda “basın açıklaması” adı altında **“Kürtçe Resmi Eğitim Dili Olsun”** başlıklı bir bildiri okunur. Bu bildiri içeriğinde şu ifadeler yer verilir:

“Artık Yeter. Bundan sonra **kendi anadilimizle eğitim istiyoruz** kampanyası TZPK tarafından daha önce başlatılmıştı. Bunu gören AKP hükümetini hemen telaş sardı ve adım attı, attığı adım ve amacı sahtekarlıkla Kürtçe dili ile din propagandasını yapmaktı. Her ne kadar AKP hükümeti mecbur kalıp adım attıysa da, bu atılan adım Kürt halkı için değildir. Bu Devletin ve AKP hükümetinin bir stratejisidir. İmha ve inkar politikalarını örtmek içindir. Kürt halkı yıllardır özgürlük ve Demokrasi mücadelesini vermektedir. Atılan bu adımların sahte olduğu halkımız tarafından bilinmelidir. AKP hükümetinin niyeti Kürt halkını kandırmak olduğu tarafımızdan ortaya çıkarılmıştır. Bir taraftan yeni bir Kürtçe dili ile yayın yapan TRT-6 yi açmak, diğer bir taraftan da **her gün Kürt diline yeni davalar açıyorlar. Tutuklular Kürtçe ile konuşamıyorlar konuştukları için ceza alıyorlar**, mecliste tutanaklarda hala **bilinmeyen dil** olarak kayıtlara geçiyor. Diğer taraftan her gün köyler, dağlar Kürdistanı uçaklarla bombalar yağıyorlar. Bunlar Gazzede İsrail eli ile yapılıyor. Kürdistan’da AKP ile yapılıyor. Bunların hepsi AKP’nin Kürtlere Sahte ve Kara yüzünü gösteriyor. Yine biz kendi halkımıza sesleniyoruz. TRT-6 adı altında oynanan oyuna alet olmayın. Yine biz Devlete ve AKP’ye sesleniyoruz. Söylüyoruz ki artık yeter kirli politikaları inkar ve imha politikalarınızı bırakın. Bu politikalar çözüm değildir. Çözüm için demokrasiyi geliştirin. Artık halkımız bu politikalarla kandırılmıyor. Biz söylüyoruz ki;

1- Kürt dilinin gelişimi için demokratik çözümün olması, oluşacak demokratik modelde Kürt halkının tanınması,

2- Kürt dilinin resmi bir dil olması ve Kürt dilinin üzerindeki baskılar ve engellerin kaldırılması ve dilin zenginleştirilmesi, dilin her alanda kullanılması bunun devlet tarafından görülmesi,

3- Kürt dilinin kirlilikten kurtarılması ve zenginleştirilmesi, Ana dilde eğitimin verilmesi, Kürt enstitüsünün açılması, tüm bunların devletin baskısı altından çıkarılması, oluşacak demokratik örgütlenme modelinde eğitimini verecektir.

4- Devletin attığı adımlarda samimi olsun, Kürt dili üzerindeki asimilasyonun kaldırılması, Kürt dili üzerindeki oluşan tahribatın giderilmesi, pozitif bir havanın verilmesi,

5- Geçmişte Kürt dili için cezaevine giren ve halen tutuklu olanların ve hakkında dava açanlar derhal cezaevinde bulunanların bırakılması, hakkında dava açılanların davalarının düşmesi gerekir.

6- İsmi değiştirilmiş **Kürtçe yerleşim yerlerinin isimlerinin iade edilmesini** istiyoruz.

7- **Dil eğitimi ve ibadetlerin Kürtçe olarak verilmesi**, bunun üzerine çağrıda bulunuyoruz tüm halkımıza diline sahip çıksınlar, **Kürt dili resmi eğitim dili olsun.**”.

Bu bildirinin okunması sırasında, kalabalık içinde bulunan kişiler tarafından “**Biji Serok Apo**” (“Yaşasın Başkan Apo”), “**Be Serok Jiyan Nabe**” (“Başkansız Yaşam Olmaz”) şeklinde sloganlar atılır ve ayrıca “**Be Zıman Jiyan Nabe**” (“Dilsiz Yaşam Olmaz”), “**Jin Jiyan Azade**” (“Kadın Yaşam Özgürlük”) şeklinde sloganlar atılır ve ayrıca, “**zımane me rumetya meye**”, (“**dilimiz onurumuzdur**”), “**dilimizi istiyoruz**”, “**zimene me hebuna meye**”, “**dilimiz var inkar ediliyor**”, “**em bi zımane dayika xwe penverdekiye dxawazın**”, “**biz kendi ana dilimizde konuşmak istiyoruz**” yazılı döviz ve pankartlar taşınır.

(Bu iktibaslar, temyiz konusu olan Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 7.5.2009 tarihli ve E. 2009/121, K. 2009/310 sayılı gerekçeli karar metninden edilmiştir.)

Bu açık hava toplantısına “yaklaşık **250 kişi**”nin katılmış olmasına rağmen, sadece **üç kişi** hakkında dava açılmış ve hüküm kurulmuştur. Bunlardan biri söz konusu bildiriyi okuyan kişi, diğer ikisi ise toplantıya katılarak kalabalık içinde slogan atan kişilerdir.

İlk derece mahkemesi her üç kişiyi de terör örgütünün propagandası suçunu işlediklerini kabul ederek mahkûm etmiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, bildiriyi okuyan kişi hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün, bildiri içeriğinin suç oluşturmadığı gerekçesiyle bozulmasına; buna karşılık, slogan atan diğer iki kişi hakkında terör örgütünün propagandası suçundan dolayı verilen mahkûmiyet hükmünün ise onanmasına karar vermiştir.

Bu karar, yargı eliyle PKK’nin değirmenine su taşınmasının bir örneğini oluşturmaktadır.

Bkz. <https://izzetozgenc.com/data/contents/pkk'nin-degirmenine-su-tasiyan-bir-yargitay-karari.pdf> (Yayına giriş tarihi: 8.3.2021; Erişim tarihi: 18.10.2022)

- ¹⁶ Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin **30.4.2019** tarihli ve E. 2019/2668, K. 2019/1200 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, bir sendikanın “Yürütme Kurulu” tarafından, UNESCO’nun 17.11.1999’da ilan ettiği “**21 Şubat Uluslararası Anadili Günü**” dolayısıyla alınan karara istinaden, Diyarbakır’da bir haftalık program çerçevesinde çeşitli etkinlikler icra edilir.

Bu etkinlikler çerçevesinde, ... İlkokulunda öğretmen olan A, “**22.2.2016 tarihine rastlayan pazartesi “günü 3. saatte bir dersi anadil ile ilgili işleyerek sınıf defterine müfredat dışı kazanım”** yazar.

Bu nedenle, A hakkında “**dersin programına göre işlenip ders defterinin de program dahilinde doldurulması gerekirken doldurmadıklarının, öğretmenlerin uyması gereken kanun, yönerge ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda ders programlarına uygun olarak program dahilinde ders işlemeleri gerekirken,**” ilgili sendikanın almış olduğu karar “**doğrultusunda hareket ederek yükümlülüklerini yerine getirmediği**” gerekçesiyle disiplin cezası uygulanır.

Diyarbakır İdare Mahkemesi, bu disiplin cezası uygulamasına ilişkin kararın iptali talebiyle açılan davanın reddine karar vermiştir.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, bu karara karşı istinaf başvurusunun aşağıdaki **gerekçe** ile kabulüne karar vermiştir:

“**Uyuşmazlıkta; davacının üyesi olduğu sendikanın, Türkiye'nin de üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı bir kuruluş olan UNESCO Genel Kurulunun 1999 yılında aldığı karar sonrası kutlanmaya başlanan 21 Şubat günü "Uluslararası Anadili Günü" ka-**

ki, bu sorunlarla ilgili düşünceler dile getirilirken açıkça terör örgütünün propagandası yapılmış olsun.^{17,18}

rarına atıf yapılarak bu günün anlam ve önemi ile ilgili olarak aldığı karar doğrultusunda ve bu kararın kapsam ve sınırları aşılmaksızın mahiyeti ile örtüşecek şekilde 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle bir ders saatinde anadilin anlam ve önemini belirtecek şekilde ders işleme eyleminin, eğitim ve öğretim mevzuatını/müfredatını değiştirme amacı ve niteliği taşımadığı, davacının üyesi olduğu sendikanın tabi olduğu tüzük hükümlerinde de anadilin öneminin savunulacağı hükmüne yer verildiği, yapılan bu eylemin ayırıcı veya ayırıştırıcı bir yönünün de bulunmadığı, bilakis sendikal faaliyet çevresinde bireylere topluluk halinde sosyal ve kültürel amaçlarını geliştirme inkanını sağladığı, sendika hakkını kullanan bireylerin, çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik gibi demokratik toplumun temel ilkelerinin korunmasını sağlayacağı ve yapılan eylemin, şiddete teşvik etme veya demokratik ilkelerin reddi niteliğinde olmadığı sürece sendikal faaliyet kapsamında değerlendirileceği açıktır.

Bu durumda, üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca gerçekleşen bu fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, aksi yönde düşünce ve değerlendirmeye, üzerine atılı fiilin disiplin suçu teşkil edip ... davacının ... cezası ile tecziyesine yönelik dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuata uyarlık, davanın reddine yönelik istinafa konu mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Önemle belirtmek gerekir ki, kişinin ilgili mercilere verilmek üzere **Kürtçe eğitim isteğine ilişkin dilekçe** hazırlaması ve hatta, hazırladığı dilekçeyi mesela Üniversite Rektörlüğüne vermesi, suç oluşturmamaktadır: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 18.6.2002, E. 2002/1391, K. 2002/1499; Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 23.10.2002, E. 2002/1448, K. 2002/2082.

Keza Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **13.11.2018** tarihli ve E. 2018/2433, K. 2018/4145 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, şehir merkezindeki bir meydanda, dış cephesine “**Ölümlere İzin Vermeyeceğiz**”, “**Taleplere Yanıt Verilsin**”, “**Açlık Grevi Direnişçilerini Selamlıyoruz**”, “**Anadilde Eğitim Talebi Kabul Edilsin**”, “**Öcalan’a Özgürlük**” ibareleri yazılı pankartlar asılan bir çadır kurulur. Çadırda, hükümlü Abdullah Öcalan’la ilgili olarak “*uygulanan sözde tecrit, avukatları ile görüştürülmemesi, mahkemelerdeki Kürtçe yasağının kaldırılması, okullarda Kürtçe eğitimin serbest bırakılması, terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla*” tertip edilen toplantıda, bu minvalde çeşitli konuşmalar yapılır.

Bu olayla ilgili olarak kişiler hakkında sadece **kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü** düzenlemekten ve bu toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmaktan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulmuş ve bu hüküm, Yargıtay tarafından fiilin suç oluşturmadağı gerekçesiyle bozulmuştur.

¹⁷ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 8.7.1999 tarihli **Sürek ve Özdemir/Türkiye Kararına** (BB no. 23927/94; 24277/94) konu teşkil eden olayda; bir derginin mahkeme kararıyla **toplatılan** 31 Mayıs ve 7 Haziran 1992 tarihli sayılarında, PKK terör örgütü yöneticilerinden Cemil Bayık ile “PKK’nın İkinci Başkanı” sıfatıyla yapılan bir röportaj metni iki bölüm halinde yayımlanır.

Bu röportaj metninde şu ifadelerle yer verilmiştir:

(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarındaki başvuru konusu yayın içeriklerine ilişkin iktibaslar, Türkiye’deki yayınların İngilizce veya Fransızca metinlerinden edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında, Türkiye’deki mahkeme kararlarına ilişkin bilgiler, yeterli açıklıkta gösterilmemektedir. Bu nedenle, karara konu teşkil eden yayın içerikleri, İngilizce veya Fransızca tercüme metinlerinin tekrar Türkçeye yapılan tercümelerine dayanmaktadır. Bu karara konu teşkil eden yayın içerikleri, tohav.org internet sitesinde yayımlanan gayri resmi karar tercüme metinlerinden iktibas edilmiştir.)

“Soru: [Seçimler] tehlike arz ediyordun kastınız nedir?

Cevap: ABD: “Kürtlere baskı uygulanıyor. Saddam onları öldürüyor. Biz Kürleri Saddam’ın katliamlarına karşı koruyoruz. Onların hayatta kalması bizim güvencemiz altındadır” diyor.

Ancak bunun büyük bir sahtekarlık olduğu barizdir. İddia ettikleri şekilde Kürtleri katliama karşı koruyor olsalardı, onları Türk Devletine karşı da korurlardı. Çünkü, Kuzeyde **bizim halkımıza karşı Türk Devleti tarafından yapılan katliamlar**, Saddam'ınkiler kadar korkunç. Aslında Saddam'ınkilerden daha kötü uygulamalar bile var. Bu nedenle, ABD aynı şeyi Türkiye'ye karşı da yapmalıdır. Çifte standart herkes tarafından görülecek kadar açıktır. ABD Saddam'a karşı harekete geçiyor, ancak **Türkiye'nin Kuzey ve Güneydeki Kürt halklarına karşı yaptığı katliamları** destekliyor. Buna ilişkin birçok emare mevcuttur ve halkımız da bunun bilincindedir. Seçimlerdeki hedefi, hem desteklemek istedikleri teşkilatlar üzerinden Güneydeki olumlu gelişmeleri sınırlandırmak, hem de genel olarak **Kürdistan'da geliştirmekte olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önünü tıkamaktır**. Tüm Kürt hareketlerini, halen kendilerinin [ABD] kontrolünde bulunan o iki teşkilatın kontrolü altına almak istiyorlar. Bu nedenle de Kürt halkı için tehlike arz ediyorlar.

Soru: Güney Kürdistan'da bir parlamento kurulur kurulmaz kanunlar yürürlüğe girecektir. Bir yandan Türkiye ve Irak gibi komşular ile ve diğer yandan ABD ile anlaşmalar imzalanacaktır. Türkiye'nin bu ülkelerden tek bir talebi olabilir, o da PKK'nın hariç tutulması. Kürt partileri anılan bir ortam içinde yer alırlarsa, PKK'nın tutumu ne olur?

Cevap: Türkiye ve/veya emperyalizmin, halkımızı ulusal kimlik ve mücadelesinden caydırmak niyetinde olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bir ulus olarak kimliğimizi elde etmek istiyoruz ve bizim baba topraklarımız var. Savaşımız bunun içindir. Bizleri topraklarımızdan söküp atmak istiyorlar; bizleri yok etmek veya bizleri değiştirmeye zorlamak istiyorlar. Ama **biz kendi topraklarımızda barış içinde yaşamak için SAVAŞIYORUZ**. ABD veya Türkiye veya Kürt kimliği adına hareket etmekte olduğunu söyleyen herhangi bir başka güç, ülkemizin herhangi bir bölümünden bizi zorla çıkarmaya çalışırsa, bulunduğumuz yerde kalmak için mücadele ederiz. Şu anda da mücadelemizin amacı budur. Türk Devleti bizleri topraklarımızdan atmak istiyor. İnsanları köylerinden sürüyor. Kürdistan'ın tamamen boşaltılmasını istiyor. Ama biz direniyoruz. Kimse bize çıkmamızı söyleyemez veya isteyemez. Biz başkalarının topraklarında değil; kendi topraklarımızdayız. Kimse bizden topraklarımızdan ayrılmanızı isteyemez. Kuzey ve Güney diye bir ayırım yapmıyoruz; bizler Kürdistan'dayız. Bizler halkımızın arasındayız. Topraklarımızdan ayrılmanızı istiyorlarsa, bunu asla kabul etmeyeceğimizi bilmeliler. **Bizler her şeyini kaybetmiş bir halkız ve kaybettiklerimizi geri kazanmak için çarpışıyoruz**. Bizim hareketimizin amacı bu. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kimsenin karşısında ezilmeyiz ve kimseden korkmuyoruz. Kaybedebileceğimiz tek şey köleliğimizdir. Bu nedenle korkusuzca hareket ediyoruz.

Soru: Türk Devlet televizyonlarında Kürtçe programların yayınlanmasının PKK'ya ödün verme şeklinde yorumlanacağı söylenmektedir. Bu doğru olabilir mi? Ayrıca PKK'nın bir TV kanalı kuracağı söylenmektedir. Bu doğru mudur?

Cevap: PKK'nın televizyon yayınına başlayacağı doğru değildir. Bu tür tesislerimiz yok. Uydu veya başka bir kanal üzerinden televizyon yayıncılığı PKK'nın işi değildir. Türkiye'de Kürt televizyonu konusunu Turgut Özal ABD ziyaretinde gündeme getirmiştir. Tartışılan husus budur. Halkın küçük bir çoğunluğu Özal'ın haklı olduğunu söylüyor, ancak büyük bir kısmı ise buna karşıdır. Kürt TV'nunu önerenler bunu kasıtlı olarak yapıyor. Hedef, sözde kitelerin etkilenmesi ve kazanılması ve böylece PKK'nın dışlanmasıdır. Fikir budur. Ama, Kürt TV, gerçekleşse dahi, bu onların işine yaramayacaktır. Bu yüzden buna karşılar. Kürt TV'ünü kurmak isteyenlerin amacı PKK'yı dışlamaktır. Çünkü, "Kendi dillerine sahip olan bir halk mevcuttur ve onların dilinde yayın yapmalıyız. O halka saygı duymalıyız. İnsanların dillerinin yasaklanması yanlıştır, bu aynı zamanda Türk halkına da zarar verir." şeklinde bir düşünce yoktur. Durum bunun aksinedir. Tartışmalar gerçek amaçlarını ortaya koymuştur: **"PKK'nın etkisini nasıl silebiliriz? PKK'yı nasıl yalnız bırakabiliriz? Kürt halkının gözlerini nasıl bağlayabiliriz?"**. Bu taktiksel bir yaklaşımdır. Bu bir oyundur. Ancak **ne adım atarlarsa at-sınlar, PKK'nın lehine çalışacaklardır. Türk Devleti şimdi Kürdistan'ı kaybetmiştir**. Bu bir gerçektir. Bundan sonra **Devletin Kürdistan'da yapacağı herhangi bir hareket, PKK'nın le-**

hine ve Türk Devletinin aleyhine çevrilecektir ... Türk basınının ilkeleri yoktur. Bu ahlaksız basın ile iletişimde bulunmakta herhangi bir fayda olmadığını düşünüyoruz. Basın ile herhangi bir temasta bulunmaktan kaçınmakla kalmayacağız; basının Kürdistan'a girişini engellemek için çaba harcayacağız.

Soru: Uludere saldırısında farklı bir taktik uygulanmıştı. Önceleri, saldırılar geceleri düzenleniyordu. Ama bu kez, saldırı gündüz gerçekleştirildi ve çarpışma gün boyunca sürdü. Bunun gerillalar için daha fazla risk taşıdığı söylenmektedir. Bunun nedeni neydi?

Cevap: Dedikleri doğrudur. Mücadelemiz belli bir düzeye ulaşmıştır. Bu düzeye uygun taktiklerin geliştirilmesi gereklidir çünkü daha düşük taktiklerle **savaşmak** bir hatadır. **Savaşta** ilerleme, halen ulaşılmış olan **harp** düzeyinde taktiklerin kullanımı ile elde edilebilir. Hareketin planlanma nedeni budur. Fikir, sabah **saldırmak** ve yerimizi korumak ve gün boyunca **çarpışmayı** sürdürmekti - ve sonunda **başarılı** da oldu. Bu bir deneydi. Bizim görüşümüzden, bundan çıkarılması gereken sonuçlar mevcuttur. Durumu inceliyoruz. Gelecekte yapacağımız eylemlerde bundan faydalanacağız.

Soru: Faili meçhul kişilerce Kürdistan'da düzenlenen suikastlar ve Hizbullah'ın üzerine aldığı eylemler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Hizbullah olarak bilinen bir örgütün olduğu doğru. Fakat güçsüz bir örgüt. Söylenildiği gibi, **katliamlar düzenleyen örgüt Hizbullah değil**. Örgüt güçsüz olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti örgüt mensuplarını çoğu yerde yakaladı. **Birçok katliam bu örgütün adı altında yürütülüyor ancak aslında bu cinayetlerin hepsi Türkiye Devleti tarafından işleniyor**. Bunu Hizbullah üyelerine anlatıyoruz: 'Eğer gerçekten Müslümansanız, şunu bilmelisiniz ki, İslam dini baskının ve adaletsizliğin karşısındadır, doğru ve adil olanın yanındadır. 'Türkiye Devletinin baskıcı olduğu ve çok sayıda katliam ve insanlık dışı eylem gerçekleştirdiği herkes tarafından bilinmektedir. Hizbullah bu eylemlere karşı çıkanlara saygı göstermelidir. Bu eylemlere karşı **savaşmak** istiyorlarsa diğer örgütlerle güçlerini birleştirmelidirler. Onlardan istediğimiz sadece budur. Birlikleri arasına sızan kontr-gerillaları püskürtmeleri gerektiği konusunda onları dostça uyarıyoruz. Bunu yapmazlarsa çok fazla üzülecekler. Şu ana kadar ciddi olarak bir tepki vermedik, sadece onları uyardık. Bu olayların Türkiye Devletine hizmet ettiğini söyledik onlara ve belirli kesimlerden olumlu yanıtlar aldık. Hizbullahçıların veya Müslümanların bu tür eylemlere katılmadıklarını ve bu eylemlerin Hizbullahçılar tarafından gerçekleştirilmediğini söylediler. Bu olumlu bir gelişme. Ancak, **Türkiye Devleti, Hizbullah adı altında çeşitli yerlerde katliamlarına hala devam ediyor ...**

Soru: Bundan sonra mücadeleniz hangi sınırlar içerisinde devam edecek?

Cevap: Etkileri kesin olarak belirlenmiş olmasa da, iklim koşulları savaşı etkiler. **1991-92 kışı** oldukça sertti; bu da bizim hareketlerimizi ve mücadele kapasitemizi etkiledi, hem bizim açımızdan hem de Türkiye Devleti açısından ciddi problemler yarattı. Ancak onların teknoloji avantajları var ve bunu sonuna kadar kullandılar. Tabii, bir işlerine yaramadı bu. Geçen kış bizi öldürücü darbelerle maruz bırakmaya çalıştılar. Bizi yıkacaklarını ve ilkbahara kadar püskürtmeyi başaracaklarını düşündüler. Ancak istediklerini elde edemediler. Sert kış koşullarından dolayı hareket kapasitemiz azaldı ve bunun bir sonucu olarak da geçen yıllarla kıyaslandığında adımlarımızı daha geç atabildik. Fakat yavaş yavaş mevsim normale dönüyor. Çoğu yerde, hala yerde kar var. Ancak bu bizim için fazla engel oluşturmuyor. **1992 yılı** diğer yıllarla karşılaştırıldığında **daha farklı bir yıl olacak**, ama hiç bir zaman şunu söylemiyoruz: 'Silahlı mücadelemizi artıralım ve daha geniş alanlara yayalım'. Eğer **savaşa** devam ediyor-sak, bunu yapmamız gerektiği içindir.

Farklı bir yaşam ve gelişme için yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bizim için tüm yollar kapandı. **Savaşı sürdürüyoruz**, çünkü bunu yapmaya zorlandık. **Savaşın büyüüp büyümemesi Türkiye Devleti'nin tavrına bağlı**. Devlet savaşı daha da körüklüyor. Bu yüzden de savaşı bu noktaya kadar getirdik. **Savaş daha da büyüyecek**. PKK'dan önce, Kürdistan'a karşı tek taraflı bir savaş vardı. Son birkaç yıldır **bu savaş iki taraflı oldu**. Eskiden, Türkiye sürdürdüğü

savaşın sonunda istediği her şeyi elde ediyordu ve bunun sonucunda da Kürdistan halkı hızla ortadan kalkıyordu. Ancak artık Kürt halkı 'Dur!' demeye başladı. Yok olmamak için direnmeye başladılar. **Savaşı başlatan devletti, savaşın sona ermesi de devlete bağlı olacak. Savaşı biz başlatmadık. Biz sadece bize karşı sürdürülen bir yok etme savaşında savunmaya geçtik. Türkiye, Kürdistan halkının isteklerini kabul etmedikçe bu savaş devam edecek: geriye tek bir adım bile atılmayacak. Bizim tarafımızda tek bir kişi kalana kadar bu savaş sürecektir** ...

Bazı bölgelerde Devletin sömürgeci otoritesi tamamen yok oldu ... **Savaşı idare edenler olarak, halkımızın herkes tarafından bilinen isteklerinin resmi olarak dile getirilmesini bekliyoruz. Bütün amacımız bu. Bu hedefe, Devletin egemenliğini çeşitli şekillerde ve yollarda zayıflatarak, çeşitli yerlerde popüler bir rejim kurarak ya da diğer bölgelerde ikinci bir rejim oluşturarak ulaşabiliriz. İşte bu halkımızın ve bizim gücümüz.** ...

PKK her türlü problemle karşılaşabilir, tüm bu sorunları çözer. Türkiye'ye hiçbir soru sormuyoruz. Onlarla konuşmuyoruz. Herkes ERNK Komitesiyle ya da bu komitenin yerel görevlileriyle konuşuyor. ERNK'nın yetkili olduğu düşünülüyor. Şu an için bizler halk temsilcilerimizi seçiyoruz."

Derginin 31 Mayıs 1992 tarihli sayısında ayrıca şu içerikte bir bildiri yayımlanmıştır.

"... Devlet terörüne karşı, Kürt halkına yapılan baskı ve zulme karşı, katliamlara, sokak ortasında islenen cinayetlere, ... karşı birleşelim; ...

Emperyalizmin ve işbirliği halinde olan yöneticilerin bize karşı yürüttüğü saldırılara karşı gelebiliriz. Bunu başarmak için, ortak isteklerimiz çerçevesinde güçlerimizi birleştirip **savaşa katılmamız**. Tarihteki devrimci rolünün bilincinde olarak, işçi sınıfı harekete geçmeli, eylemleri yönlendirmeli, sendika başkanlarına çağrıda bulunup, eylemlerimize müdahale etmek adına oluşturdukları engelleri ortadan kaldırmalı ve **savaşı** ve eylemleri **yaygınlaştırmalıdır**.

- Türk ordusu Kürdistan'dan çekilmelidir. Yargı sistemindeki çifte standarda bir son verilmeli ve tüm Kürt mahkûmlar serbest bırakılmalıdır.

- Türk parlamentosu, Kürdistan üzerinde kurduğu otoriteden vazgeçmelidir. Kürt halkı kendi kaderini belirlemede özgür bırakılmalıdır, buna ayrı bir Devlet kurulması da dahildir.

- MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ajanları, kontr-gerillalar ve özel birlikler tarafından gerçekleştirilen sokak infazlarına ve Devlet terörizmine bir son verilmelidir ve bu kişiler katliamların ve cinayetlerin hesabını vermelidirler. ..."

Bu makaleler dolayısıyla derginin yayın sorumluları hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından, TMK, m. 6'da tanımlanan Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını yayımlamak ve (bilahare mülga) m. 8'de tanımlanan "Devletin bölünmez bütünlüğüne karşı propaganda yapmak" suçlarından dolayı (27.5.1993 tarihli) mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.

Yargıtay, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, bu mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir (4.11.1993 tarihli karar).

AİHM, bu mahkûmiyet hükmüyle, İHAS, m. 10 ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. (pn. 64)

"Mahkeme ilk olarak, söz konusu röportajların yasa dışı bir örgütün bir üyesiyle yapılmış olması gerçeğinin başvuruların ifade özgürlüğü haklarına yapılan müdahaleyi haklı göstermeyeceğine dikkat çeker; ayrıca röportajların içerisinde resmi politikaya karşı getirilen ağır eleştiriler vardır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan rahatsızlıkların kaynağı ve sorumluluğuna ilişkin olarak tek taraflı bir yaklaşım benimsenmektedir. Röportajlarda kullanılan kelimelerden mesajın uzlaşmazlık olduğu ve **PKK'nın hedefleri garantiye alınmadıkça yetkililerle anlaşma olmayacağı** açıkça anlaşılmaktadır. **ANCAK METİNLER BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINDIĞINDA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİĞİ SÖYLENEMEZ.** Mahkeme, röportajların bu şekilde yorumlanabilecek bölümleri üzerinde dikkatle durmuştur. Ancak

Mahkemeye göre, “Bizden topraklarımızdan çıkmamız istenirse, bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir” veya “**Bizim tarafımızda tek bir kişi kalana kadar savaş devam edecek**” veya “Türkiye Devleti bizi topraklarımızdan atmak istiyor. İnsanları köylerinden çıkarıyor” veya “Bizi yok etmek istiyorlar” **gibi ifadeler, karşı tarafın amaçlarına devam etmek için çözümlerinin ve bu açıdan liderlerinin gösterdiği tavırların bir yansımasıdır. Bu açıdan bakıldığında, röportajlar Türkiye’nin güneydoğusundaki resmi politikaya muhalefetin ardındaki itici güçlerin psikolojisine ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmak ve bu ihtilafta yer alan çıkarları değerlendirmek açısından HABER niteliği taşımaktadır.**” (pn. 61)

Söz konusu röportaj metinlerinde “**ifade edilen görüşler, şiddete tahrik olarak değerlendirilemez; şiddete tahrik etmeye meyilli olarak da yorumlanamaz.**” (pn. 61)

“Mahkemeye göre **metnin içinde şiddete tahrik etme olarak yorumlanacak herhangi bir husus yoktur.**” (pn. 61)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, söz konusu kararda PKK’nin bir terör örgütü ve faaliyetlerinin terör eylemleri olduğunu ifade etmekten özellikle kaçınmıştır. Kararda, Türkiye’nin güneydoğu bölgesinden bahisle, “**bu bölge yaklaşık 1985 yılından beri çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve ... PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında meydana gelen rahatsız edici durumlar**”dan söz edilmiştir. (pn. 61)

Mahkeme söz konusu kararında Türkiye’deki yetkililere de bir ders vermeye tevessül etmiştir: Söz konusu Mahkeme, “... yetkililerin Türkiye’nin güneydoğusunda süregelen durumla ilgili olarak halkı farklı bir perspektiften, bu perspektif her ne kadar hoş olmasa da, bilgilendirmeleri hususunda gereken dikkati göstermedikleri görülmüştür.” (pn. 61)

Söz konusu yayın içeriklerinde yer alan ifadelerin, okuyucuda PKK’nin faaliyetinin bir “meşru savaş” olduğu kanaati oluşturmak amacına yönelik olduğu ve şiddeti teşvik edici mahiyet taşıdığı açıktır. Bu itibarla, esasında terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu oluşturan söz konusu yayın içeriklerinin “ifade özgürlüğü” çerçevesinde değerlendirilmesi, terör örgütü PKK’ye “meşruiyet” kazandırma çabasının bir tezahürüdür.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu maksatlı yorumlara, Türk yargı mercilerinin uygulamaları da zemin oluşturmuştur. Söz konusu olayda, yayın içerikleri bütün olarak bir suç, yani terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmaya rağmen, bir kuzudan iki post çıkarma şeklinde iki ayrı suç işlendiği kabul edilerek, gerçek içtima hükümlerine göre iki ayrı mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.

Bkz. <https://izzetozgenc.com/data/contents/avrupa-insan-haklari-mahkemesinin-terorizmin-ve-teror-orgutunun-propagandasi-ile-ilgili-iki-karari-uzerine-degerlendirilmeler.pdf> (Yayına giriş tarihi: 13.3.2021; Erişim tarihi: 19.10.2022)

- ¹⁸ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 8.7.1999 tarihli **Erdoğan ve İnce/Türkiye Kararı**na (BB. no. 25067/94; 25068/94) konu teşkil eden olayda; bireysel başvuruçulardan birincisinin yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı dergide, bireysel başvuruçulardan ikincisinin İsmail Beşikçi ile yaptığı bir röportaj yayımlanır. Bu röportajda şu açıklamalara yer verilir:

“S: Demirel «Kürt gerçeğini» nasıl ve hangi ölçüde kabul edecektir? Onun «gerçeklik» anlayışının Devlet politikasını temsil ettiği söylenebilir mi?

C: **Kürdistan’da şimdi bir silahlı direniş olması nedeniyle Hükümet bazı gerçekleri kabul etmeye zorlanacaktır. ... Türk kuvvetleri tarafından uygulanan şiddet PKK’nın yükseliş ve ilerlemesini durduramaz. ...**

S: Devlet, Kürdistan’a ilişkin yeni resmi politikasını nasıl şekillendirecektir? Resmi ideolojinin hangi hususları değişecek ve nasıl değiştireceklerdir? Bunun Kürt halkının günlük yaşamında nasıl etkileri olacaktır?

C: ... Türkiye’de Hükümet ve Devlet iki ayrı şeydir. Devlet, üyeleri atama ile gelen kurumlar ve organlar vasıtasıyla işlev görür. Bu kurum ve organlar Devlet’in gücünü temsil ederler. Hükü-

met, yani siyasi güç Devlet'in gücüne karşı çok hafif bir yük taşımaktadır. Hükümetler bu yüzden Devlet idaresi tarafından sık sık görevden alınabilmektedir. Resmi ideoloji sadece uzun vadede değiştirilebilir ve bunu değiştirmeye muktedir olan güçler hükümet dışı siyasi ve sosyal kuvvetler ve bunların mücadeleleridir. Örneğin **PKK'nın fikir ve eylemlerinin özü resmi ideolojiyi değiştirebilecek**, Türkiye'nin siyasi sahnesinin atanan kurumlarının etkisini indirgeyebilecek ve halk tarafından seçilen parlamentonun ağırlığını artırabilecek **durumdadır**.

Benim gayri resmi, kendi kanaatıma göre Kürtlerin ve özellikle **PKK'nın etkisi daha da artacaktır. PKK'nın hem Kürt hem de Türk toplumları üzerindeki etkisi genişleyecek ve derinleşecektir. Ve bu etki büyüdükçe, «Kürt gerçekliğinin» tanınması yönünde, politikalarında hükümetler tarafından daha ciddi adımlar atılacaktır.** Devletin, bu işlemde Hükümeti engellemeye çalışacağı ve bazı fikir ve politikaları saptırmayı deneyeceği barizdir. Ayrıca, Hükümet'in Devlet'in gücüne karşı koyabildiği ve atanmış olan kurum ve organları kontrol edemediği, yani gerçek güce sahip olduğu sürece hayatta kalacağı da ortadadır. Bu değişiklikler Kürtlerin günlük hayatlarına da yansiyacaktır.

İncelemeler ve araştırmalar Kürt dili, tarihi ve halk bilimi gibi alanlarda gelişecektir. Kürt toplumunun özgünlüğü Kürt kitleleri arasında daha da vurgulanacaktır. Ulusal bilinçlilik ve özgürlük isteği daha da güçlendirilecek ve yayılacaktır. Bağımsızlık fikri ve hissi gelişecektir.

S: Şimdiye kadar «Ben bir Kürdüm ve şimdiki ve gelecekteki yaşamım için politika ile ilgileniyorum» diyen insanların Kürdistan ve Türkiye'de «kendi çıkarları için politikaya atılmaya başladığı» gözlenmektedir. Bu durumu ne tür gelişmeler ortaya koymuştur? Hukuk alanında Kürtlerin bir siyasi konuya ihtiyacı var mıdır? Eğer varsa, bu nasıl bir şekil almalıdır?

C: Şüphesiz ki, bu gelişmelerin en önemli nedeni **PKK tarafından yaklaşık olarak sekiz yıldır sürdürülmekte olan silahlı mücadele** olmuştur. **Gerilla savaşı**, geleneksel Kürt toplumunda başlıca sosyal ve siyasi değişikliklere neden olmuştur. Geleneksel değerler bir kargaşa içindedir. **15 Ağustos 1984 tarihinden bu yana** halk arasında **Kürt gerilla savaşı** için yaygın bir destek sağlanmıştır. Ulusal bilinç şimdi Kürt toplumunda gelişmektedir ve bu süreç hızla yayılmaktadır. Ve, bu süreç içinde siyasi oluşumun **özerklik** ve **bağımsızlık** yönünde Kürt çıkarları için kullanıldığını görmekteyiz. Daha önceleri başkaları ve başka uluslara hizmet etmek üzere siyaset ile ilgilenen Kürtler şimdi Kürt halkına hizmet etmek için siyaset ile ilgilenmektedir. Türk ırkçılığı ve sömürgeciliğine karşı sağlıklı ulusal bilinç gelişmektedir. Tüm bunların, **15 Ağustos tarihindeki Kürt gerilla savaşının başlatılmasından sonra meydana geldiğini söylemek durumu aşırı basitleştirmek** olacaktır. Bu süreç, daha gerilere dayanan köklere sahiptir ve **belirleyici olan PKK tarafından başlatılan yeni süreçtir... Kürdistan'da yasadışı olan kimdir? Gerillalar mı yoksa Türk silahlı kuvvetlerinin özel timleri mi?**

S: Sağ kanat medyası ve MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi) tarafından teşvik edilen şovenist Türk milliyetçi dalgasına karşı koymak için neler yapılmalıdır? **Türk ve Kürt halkları arasında bir karşı karşıya gelme olasılığı** var mıdır? Bu nasıl engellenebilir?

C: **Kürtler ulusu için ölüyorlar. Türkler ne için ölüyor? Onların Kürdistan'da ne işi var?**

S: PKK'nın Kürdistan'daki hegemonyasının, artık «çift güçten» bahsedilebilecek düzeye geldiği bir süredir tartışılmaktadır. Öcalan, yazılarında Botan-Behdina bölgesinde «**Hükümet-Devlet oluşumundan**» bahsetmektedir. PKK'nın Kürdistan'daki ve Türk siyasetindeki gelecekteki müdahalelerine ilişkin herhangi bir işaret mevcut mudur?

C: Türk Devleti Botan gibi bazı bölgelerde şimdiden askerlerini çekmiş ve polis karakollarını tahliye etmiştir. ... Bu **bir Devlet oluşumunun başlangıcı** olarak adlandırılabilir. ...”

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 23.3.1992 tarihli iddianame ile, başvurucuların, söz konusu röportajı yayımlamak suretiyle “Devlet'in bölünmez bütünlüğüne karşı propaganda yapmak” suçunu işlediklerini iddia ederek, 3713 s. K. (bilahare mülga) m. 8 hükümlerine istinaden cezalandırılmalarını talep etmiştir.

Anadilde eğitim sorununun çözümü amacıyla çocukların okula gönderilmesi yönündeki çağrıyı desteklemek, teşvik etmek, bu çağrıya icabet etmek, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu değil, duruma göre başka bir suç veya kabahat¹⁹ oluşturabilir.

Türkçeyi iyi bilen ve kullanabilen kişilerin haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki savunmalarında, Türkçeyi kullanmama, Kürtçeyi kullanma yönündeki tutumlarının anadilde savunma hakkından ziyade, “anadilde yargılanma” talebini dile getirmek amacı taşıdığı izahıtan varestedir.²⁰ Ancak, böyle bir amacın güdülmesi, başlı başına bir suç oluşturmaz.

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, başvuruçuların 3713 s. K, (bilahare mülga) m. 8’de tanımlanan “Devlet’in bölünmez bütünlüğüne karşı propaganda yapmak” suçunu işlediklerini kabul ederek, haklarında mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Söz konusu mahkûmiyet hükmü, Yargıtay tarafından onanmasına karar verilerek (1.2.1994 tarihli karar), kesinleşmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu mahkûmiyet hükmüyle, şu gerekçelere (!?) işaret ederek, başvuruçuların her ikisinin de ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmiş olduğuna karar vermiştir:

“Suç konusu yayının, bir Türk sosyolog ile yapılan bir röportaj olduğunu ve yayınlanmış halile görüşlerinin, öncelikli olarak Türk toplumunda yer edinmeye başlayan PKK ideolojisini ve bir Kürt devletin temellerinin nasıl oluştuğu hususlarına ilişkin olduğuna işaret edilmektedir. PKK’nın Kürt bağımsızlık mücadelesindeki rolünü açıkça savunmaksızın, röportajın yapıldığı şahıs, bu durumu temelde sosyolojik açıdan Türk Devletinin tepkileri bazında analiz etmiştir.” (pn. 51).

“... Mahkeme, röportajın içeriğinin analitik nitelikte olduğu ve metnin, şiddete yönelik tahrik içermediği görülmüştür. ...” (pn. 52)

Söz konusu “röportajda belirtilen görüşler, şiddete tahrik şeklinde algılanamaz ve şiddeti tahrik edebilecek şekilde yorumlanamaz.” (pn. 52).

Söz konusu röportaj içeriğinde yer alan ifadeler, esasında terörizmin ve terör örgütünün propagandası mahiyeti taşımaktadır. Kendisiyle röportaj yapılan kişi, Devletin ülkenin güveneydoğusundaki egemenliğinin meşruiyetini sorgulamanın yanı sıra, PKK terör örgütünün 1984 yılından beri icra ettiği terör eylemlerini, Kürt halkının özerklik ve bağımsızlık elde etmek amacıyla güvenlik kuvvetlerine karşı verdiği bir “savaş”, bu eylemleri gerçekleştiren kişileri de “Kürt gerilla savaşçıları” olarak nitelendirmiştir. Söz konusu kişi, “fikir ve eylemlerinin özü” itibarıyla PKK’nın, “resmi ideolojiyi değiştirebilecek”, bu “ideoloji”ye bağlı olarak toplumda ortaya çıkan çeşitli hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel sorunların çözümünü gerçekleştirebilecek “durumda” olduğunu belirterek, PKK’nın toplumda teveccühe layık bir örgütlenme olduğu izlenimi oluşturmaya amaçlamıştır.

Belirtilen nedenle, başvuruçular hakkında Türkiye’de kurulan mahkûmiyet hükmündeki suç tanımına ilişkin niteleme, hukuki bakımdan sorunludur. Bu sorun da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin somut olay bağlamındaki değerlendirmelerine ve neticesine katılmadığımız kararı vermesine yol açmıştır.

¹⁹ 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, m. 55, 56.

²⁰ Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesinde değişiklik yapan 24.1.2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanuna (m. 1) ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında yapmış bulunduğu açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

“Bir kanuni düzenleme yapılırken önce bir sorun teşhisi yapılması lazım gelir. Yani uygulamada ortaya çıkan sorun nedir? Bu sorunu doğru bir şekilde teşhis ettikten sonra bu sorunun çözümünün uygulamayla mı yoksa bir kanuni düzenlemeyle mi yapılması gerektiği üzerinde düşünce üretme yoluna gitmekteyiz. Süreç itibarıyla böyle bir yol izlenmesi gerekir.

Bu süreçte ortaya konulacak olan alternatif çözüm modellerinden birisi eğer kanuni düzenleme ise önerilen kanuni düzenleme formülasyonlarının Anayasaya uygunluğu veya aykırılığı tartışma konusu yapılabilir.

Ama bu aşamaya gelmeden önce bizim önce iki hususu açıklığa kavuşturmamız lazım gelir. Birincisi, sorun var mı, yok mu ve bu sorun nereden kaynaklanıyor? **Savunma hakkının kullanılmasında kullanılan dil bağlamında bir sorunla karşı karşıyayız.** Ama bu sorun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesinin formülasyonundan kaynaklanan bir sorun değil. 202’nci madde 2005 yılında yürürlüğe giren bir maddedir. Bu maddenin formülasyonu yapılırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dil hakkının kullanılması bağlamında vermiş bulunduğu kararlar göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesinin formülasyonunda herhangi bir sorunla karşı karşıya bulunmuyoruz, yani böyle bir tespitimiz yok.

Fakat belirli mahkemelerde savunma hakkının kullanılması bağlamında ana dil kullanılması talepleriyle bağlantılı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle bir gerçekliğimiz var. Bu gerçeklik, davaların özellikle siyasi içerikli davalar olması itibarıyla kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Yani şunu bilmemiz lazım gelir ki: Siyasi içerikli olmayan davalardaki savunmalar bakımından dil yönü itibarıyla savunma hakkının kullanılmasında herhangi bir sorun bize yansımış değil. Ancak dil bağlamında, yani, savunma hakkının kullanılması bağlamında ileri sürülen birtakım taleplerle karşı karşıyayız. Ama bu taleplerin hiçbirisi somut davadaki savunmanın efektif bir şekilde yapılmasıyla ilgili de değildir. Bu davalardan bir tanesi, Diyarbakır’da yürüten davadır, şu veya bu isimle yürüten dava demek istemiyorum. Ama orada yürüten bir davadır. Bu davanın yürütülüşü sırasında yargı otoritesi etkinliği bakımından biraz zaafa uğramıştır; bu gerçekliği burada ifade etmem lazım idi.

Hukuk sistemimizde bir duruşma açıldığında bunun nasıl, hangi usul sırası itibarıyla icra edileceği kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Ama daha bir duruşmada henüz iddianame okunmadan önce, henüz daha sanıkların kimlikleri tespit edilmeden önce sanıklar temsilcisi diye sanıklar adına bir kişi kalkıp davanın esasıyla ilgili olmayan konularda saatlerce hatta günlerce anlatımda bulunmasına müsaade edilmesiyle **yargı otoritesi o davalarda zaafa uğratılmıştır.**

Şimdi, sorunumuz şu: Zaafa uğrayan bu yargılama faaliyetinde iddianame okunmadan önce yapılan bütün konuşmalar Türkçe yapılmaktadır ve bu sanıkların –bu konuşma yapan sanıkların- hiçbirisi Türkçeyi bilmediği yönünde, Türkçeyi yeterince bilmediği yönünde Kürtçeyi Türkçeden daha iyi bildiği yönünde bir iddia da bulunmamaktadır. Sadece tırnak içinde “ana dilde savunma hakkı” kavramını kullanmaktadırlar. Ama gerçekte dile getirdikleri husus, “**ana dilde yargılanma hakkı**”dır. Böyle bir hak var mıdır, yok mudur, o ayrı tartışma konusu olan bir husus. Ama dile getirilen husus ana dilde savunma hakkı değil, ana dilde yargılanma hakkıdır. Yani sadece meramlarını kendi ana dillerinde sözlü olarak ifade etmekle yetinmek istemiyorlar. Bütün bu **yargılama faaliyeti sırasındaki bütün yazılı, sözlü işlemlerin hepsinin kendi ana dilleri çerçevesinde icra edilmesi yönünde bir talepte** bulunuyorlar.

Şimdi, bu talep o davanın esasıyla ilgili bir talep değil. O davanın esası bakımından, kendilerine yöneltilen suçlamalarla bağlantılı eğer bir savunma yapacaksa bunu dinleyebiliriz ama o davadaki yargılama faaliyeti çerçevesinde **bir siyasi talep** dile getirilmektedir. Bu siyasi talep karşılanır, karşılanmaz, bu konu siyasetin bileceği bir konu; ama eğer **bu siyasi talep karşılanacaksa bunun karşılanacağı yer Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesi değil. Böyle bir talebin karşılanması bir anayasal sorun olarak karşımıza çıkar.** Yani bunu biz anayasa değişik-

Bu amaca yönelik tutum ve davranışların, savunma hakkının kullanılması bağlamında değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Keza, vahşiyane yöntemlerle insan öldürmekten çekinmeyen örgütsel yapılanmalarla ilişkilendirilmeksizin, “İslâm Devleti”, “Şeriat Devleti” özelemlerinin dile getirilmesinin suç oluşturan bir yönü bulunmamaktadır. Ancak bu özlemin gerçekleştirilmesi bağlamında, terör örgütü vasfını taşıyan örgütsel yapılanmalara “meşruiyet” ve “ulviyet” izafe edilmesi durumunda, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun işlendiğini kabul etmek gerekir.

Güvenlik görevlilerinin terörle mücadelede ölçsüz kuvvet kullandığından, yetkilerini kötüye kullanarak insanları katlettiklerinden söz etmek, güvenlik görevlileri tarafından savunmasız, sivil insanların katledildiğinden bahsetmek,

liğiyle ancak dile getirebiliriz ve bu konu resmî dil tartışması bağlamında ele alınması gereken bir konudur. Eğer biz, resmî dil konusundaki tartışmayı bir kenara iter de Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 202'nci maddesinde tasarı metninde olduğu gibi bir değişiklik yapma yoluna gittiğimizde bu birtakım sorunları belki çözüme yönünde bir illüzyon oluşturabilir. Ama gerçekte ise o düzenleme hayata geçtiğinde daha başka problemlerle karşı karşıya geleceğiz.

En basit karşılaştığımız problem şudur: Sadece belirli yargılama işlemleri bağlamında kişilere kendi “ana dilinde savunma imkânı” tanıyoruz. Tırnak içinde, “hak” demiyoruz ona çünkü madde “hak” kavramını kullanmıyor “imkân” diyor, “savunma imkânı” veriyoruz. Bu çerçevede mesela bir kişi iddianame okunduktan sonra sözlü savunması bağlamında kendi ana dilini veya istediği bir başka dili -Türkçe dışında bir başka dili- kullanabilecektir. Ama mesela bir bilirkişi raporuna diyeceği sorulduğunda “Onu hayır, onu Türkçe anlatacağsın.” diyeceğiz bu kişiye. Yani yargılama faaliyetinin başlangıcında Türkçe dışında bir dili savunma dili olarak kullanacak, yargılama faaliyeti devam ederken Türkçeye tekrar geri döneceğiz ve yargılama faaliyeti sonucunda Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra “Sen ne diyorsun?” diye sözün bağlanacağı bir noktada yine tercih ettiği bir başka dile geri döneceğiz. Bu başlangıçtaki dil olabileceği gibi onun dışında başka bir dil de olabilir. Böyle bir yargılama biçimi yok. Ve bu tartışma karşımıza yarın başka tartışmaları da çıkarmaktadır, o da şu: Neden bu sadece kovuşturma evresinde; soruşturma evresinde değil; neden mesela soruşturma evresinde tutuklanma talebiyle hâkimin huzuruna çıkarıldığında bu imkândan yararlanılmayacağı? şeklinde bir taleple karşı karşıya geleceğim. Yine bu çerçevede, neden bu sorun sadece ceza davasıyla sınırlı olarak tutuluyor. ... Özel hukuk davasında veya diğer bir başka davada ceza hukuku dışındaki diğer davalarda sözlü olarak özellikle taleplerin dile getirilmesi bağlamında bu hak nasıl kullanılacaktır? Sanık bakımından kabul ettiğimiz bu imkânın, tanık bakımından kabul edilebilir olup olmadığı konusu da tartışma konusu yapılabilir.

Sözün kıyası şu: Çok özür diliyorum, bu konularda aslında Alt Komisyonunda da düşüncemizi arz etme imkânı bulmuştuk. Ama orada kayıt edilme imkânı yoktu. Talebin ceza muhakemesi sürecinde ortaya çıkan bir sorunun çözümüne yönelik olmaktan ziyade siyasi bir talep olduğunu ifade etmekle yetinmek isterim.”

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 27.11.2012 tarihinde yapmış bulunduğu toplantıya ilişkin tutanaklar. Ayrıca Bkz. **Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, Cilt I, Kanunlar**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi [TÜRK-CE-MER] yayını, 26. bası, Ankara, Eylül 2020, sh. 736, dn. 1188).

iddialar gerçekte bağdaşmasa bile, suç oluşturmaz.^{21, 22} Ancak, güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren ve bu çatışma sırasında öldürülen terör örgütü mensuplarının “şehit” olduğunu iddia etmek, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu oluşturur.²³ Zira, bu suretle, terör örgütü mensuplarının güvenlik görevlileriyle giriştikleri silahlı çatışma, kutsanmaya çalışılmakta ve insanlar bu mücadeleye destek vermeye teşvik edilmektedirler.²⁴

Önemle belirtmek gerekir ki, bir ülkedeki hukuki, siyasi, sosyal veya ekonomik sorunlar, terörizmin ve terör örgütlerinin beslendiği ortamı oluşturur. Bu gerçeklik, mevcut olan sorunların hukuk zemininde ele alınıp çözümlenmesine yönelik çabaların önüne geçmek için bir sebep olarak telakkî edilmemelidir.²⁵

²¹ “Ülkenin bir bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan hendeklere ve silahlanmaya müdahale eden, bu anlamda da terörle mücadele eden devleti halka “katliam”, “kıyım” ve “işken-ce” yapmakla suçlayan bir açıklamaya katılmak elbette mümkün değildir. Bunlar, belki çok küçük bir grup dışında, toplumun kahir ekseriyetini rahatsız eden çok ağır ifadelerdir.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin hiçbir şekilde içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Bir ifade ya da açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilirken söz konusu ifadelerin doğru ya da rahatsız edici olup olmadıkları belirleyici olmaz. Bu noktada kullanılan sözlerin doğru ya da kabule şayan olup olmadığının değil, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.”: Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635 (Zübeyde Füsün Üstel ve Diğerleri) (RG: 19 Eylül 2019/30893), pn. 125, 126.

²² Bkz. AİHM, Gözel ve Özer/Türkiye Kararı, (BB no: 43453/04 ve 31098/05) 6.7.2010; AİHM, Şener/Türkiye Kararı, (BB no: 26680/95) 18.7.2000; AİHM, Ceylan/Türkiye Kararı, (BB no: 23556/94) 8.7.1999.

²³ Ancak uygulamada, güvenlik görevlileriyle girdikleri çatışmada öldürülen terör örgütü mensuplarının “şehit” olarak nitelendirilmesinin, terör örgütünün propagandası suçunu oluşturduğu kabul edilmektedir: Yargıtay 16. CD, **13.5.2015**, E. 2015/1972, K. 2015/1370; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 3. CD, **11.10.2016**, E. 2016/9, K. 2016/6.

²⁴ Ancak belirtmek gerekir ki, işlediği suç ne olursa olsun, suç işleyen kişi gene de bir insandır. İster suç işlediği sırada meşru müdafaa sebebiyle, ister başka herhangi bir sebeple öldürülmüş veya ölmüş olsun, gene de ortada bir insan cesedi bulunmaktadır. İnsan hatırasına duyulması gereken asgari saygıyı, bu kişilerin cesedine de göstermek gerekir.

Ülkemizdeki terörle mücadelede güvenlik görevlileriyle girdikleri silahlı çatışmada öldürülen örgüt mensuplarının cesedi, birileri tarafından “leş” olarak nitelendirilirken, diğerleri tarafından “şehit” cenazesi muamelesi görmektedir. Doğru olmayan bu iki yaklaşımın da, ülkemizdeki ayrılıkçı teröre destek vermekten başka bir mahiyet taşımadığını görmemiz gerekir.

²⁵ Kişilerdeki, toplumda mevcut olan sorunların hukuk zemininde çözümüne yönelik ümidin yitirilmemesi gerekir. Terörizmin ve terör örgütlerinin beslendiği sorunlar varlığını devam ettirdiği ve hukuk zemininde ele alınıp çözümler üretilmediği sürece, “terörist” olarak öldürülen kişi sayısı ne kadar fazla olursa olsun, terörizmin önüne geçilmesi mümkün değildir. Mevcut bir terör örgütünün kamu gücü kullanılarak faaliyet icra edemez hale getirilmesi, ancak bir örgüt mutasyonuna sebebiyet verebilir.

Bir terör örgütü olan PKK'nin ortaya çıkışındaki amaç, siyasîdir. Başka bir ifadeyle, PKK, Türkiye'deki Kürt sorununun ortaya çıkardığı ve bu sorundan beslenen bir terör örgütüdür. PKK'yi ortaya çıkaran irade, bu siyasi amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bir "askeri üstünlük" sağlayarak gerçekleştirme beklentisi içinde değildir; aksine, silah kullanmayı bir "propaganda" yöntemi olarak,²⁶ güdülen siyasi amacın gerçekleştirilmesinde, Kürt sorununun varlığının ve bunun çözümüne yönelik taleplerin kabulünü sağlamada yegâne araç olarak görmektedir.²⁷

Bu amacın bir ölçüde gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Daha önce Türklerden ayrı olarak bir Kürt ırkının varlığının ve Kürtlerin kültürel kimliklerinin tanınması gerektiği yönünde düşünce açıklamasında bulunulması, suç oluşturmakta idi.²⁸ Bugün artık bu talepler, ifade özgürlüğünün,

Terörizmin ve terör örgütlerinin beslendiği diğer bir faktör ise, "terörle mücadele" görüntüsü altında kamu gücü kullanılarak yapılan iş ve işlemlerde hukukun dışına çıkılmasıdır. Bu çerçevede, işkence, ölçsüz güç kullanılması, bir terör örgütünün bastırılmasında diğer bir terör örgütünün araç olarak kullanılması, birer örnek olarak zikredilebilir.

²⁶ "Silahlı propaganda" (BİRAND, Mehmet Ali: *APO ve PKK*, 6. bası, İstanbul 1992, sh. 124 vd., 135, 153.

²⁷ BİRAND, *APO ve PKK*, 6. bası, 152 vd.

²⁸ Terörle Mücadele Kanununun 15.7.2003 tarihli ve 4928 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 8. maddesinin birinci fıkrası hükmü şu şekilde idi:

"Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında ... cezası hükmolunur"

Bu maddede bilahare 6.2.2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu suç şu şekilde tanımlanmıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe ... cezasına hükmolunur."

Bu suç tanımına ilişkin olarak uygulamadan üç örnek verebiliriz:

I. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 3.4.1995 tarihli ve E. 1995/9-70, K. 1995/98 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; 8.9.1991 tarihinde usulüne uygun olarak düzenlenen açık hava toplantısında, kalabalığa hitaben birer konuşma yapan sanıklardan A,

"Kardeşler hepinize merhaba diyor ve S.yle selamlıyorum. 13 yıllık bir aradan sonra tekrar aranızda gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama bu mutluluğum eksik bir mutluluk. Çünkü, cezaevlerinde birlikte yaşadığımız, her şeyi paylaştığımız, birlikte direndiğimiz arkadaşlardan Kürt arkadaşlarımızı orada bırakarak geldim. Bu yarım bir hüzdür. Ama inanıyorum ki, halkın yükselen mücadelesi bir gün onları da cezaevinden çıkaracak, özgürlük alanlarına taşıyacaktır. Biliniyor, biraz önce ifade edildi. Anti- Terör Yasası, yükselen halk muhalefetine karşı şiddeti meşrulaştırmak için yürürlüğe sokulmuş bir yasadır. Bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ihtiyacın kaynakları, başlangıcı, sadece yasanın çıktığı tarihe ait değildir. 12 Eylül öncesinde 1980'lere gelindiğinde yükselen muhalefet karşısında yine Devlet şiddete başvurmak zorunda kalmıştır. Ve kendi Anayasa ve Yasalarını bir kenara iterek, beş tane cahil adamın kurduğu or-

taklık çerçevesi içinde iktidara el koymuştu. Ve toplum o günden sonra karanlıklara itildi. Şiddet önce toplumu sindirdi, bastırdı, Ondan sonra hükmünü icra etmeye başladı. Ve belirli bir dönem sadece cezaevleri muhalefetin toplumsal odağı haline geldi. Toplumsal odağı, muhalefetin odağı olmak demek aynı zamanda baskının, şiddetin de hedefi olmak anlamına geliyordu. İnsanlar di-rendiler. Sade içerdekiler değil, dışardakilerle birlikte bu tarih kesitinde insan onurunu hep bir-likte savundular. İnsanlık onurunu yükselttiler ve yücelttiler. İçerdekiler kadar dışardakiler de kahramandılar. Kardeşler, giderek toplumsal muhalefet yükselmeye başladı. **Kürdistan'da Kürt halkı** tarihinde ilk kez kendi özgürlük ve demokrasisini kazanmak üzere ayağa kalktı. Kendi ön-cüsüne ulaştı. **Binlerce yıllık ezilmişliğini ve içine itilmiş olduğu insanlık dışı şartları** reddede-rek özgürlüğü ve demokrasisini kazanmak üzere bugün de hepimizin yakından ilgilendiğimiz gibi olumlu bir noktaya geldi. Ama sadece bu kadar değil. Türkiye'de emekçi halk, işçi sınıfı yine ta-rihinde hiçbir dönem gözükmediği ölçüde kendi mücadelesini örgütledi. Bugün günlük yaşamda görüyoruz. Kendi eylemliliği içinde güncel mücadelenin şartlarını yerine getirmek suretiyle hak-larını kazanmak için bütün çabasını sarf ediyor. Dolayısıyla, bütün bunların yaşandığı şartlarda varlığını ilerletmek gücünden yoksun olan ve halka refah getiremeyen ekonomik gelişmeyi sağ-layamayan ve devlet içinde örgütlenmiş olan egemen güçler, yapabilecekleri son çareye başvuru-dular. Ve kendi şiddetlerini yasallaştırmak için Anti-Terör Yasasını getirdiler, gündeme koy-dular. Anti-Terör Yasası, toplumu daha önce halkı cenderelerde tutan, düşünceyi yasaklayan her türlü örgütlenme özgürlüğünü yok etmiş olan 141. 142'yi kaldırmışlar gibi gözükmesine rağmen, bölücülük adı altında halk muhalefetinin bugüne kadar aldığı yönü de hesaba katarak yeni bi-çimlerde ve çok daha yoğun olarak şiddeti yasallaştırmaya çalıştı. Ama, yasallık tek başına yet-miyor. Yasallığı meşru kılabilmek için yasallığın güçlü bir meşruiyete dayanması gerekir. İşte, Devletin bugün ihtiyacını duyduğu yasallığa rağmen hiçbir zaman kendisinde var olmayan şey meşruluktu. Yani bugün **Devlet bütün eylem ve işlemleriyle gayrimeşrudur**. Tarih dışıdır ve mutlaka **tarihten silinmek zorundadır**. Yine bugün için yükselen halk mücadelesi karşısında An-ti-Terör Yasasıyla yapmak istedikleri toplum çerçevelerine dahi sığmıyor. Bugün meşru olan tek şey halkın yükselttiği şeydir, mücadeledir. Ve halk kendi mücadelesini kendi yasallığıyla birlikte geliştiriyor. Görünüşte Anti-Terör Yasasına karşı yükselen mücadele Anayasa çerçevesine gir-memesine rağmen, onun karşısında tamamen meşru bir zemine oturmaktadır ve yasaldir. **Yasa dışı olan güç Devlettir** ve onun temsil ettikleridir. Bugün buralarda az gözüksek de hepimiz bili-yoruz ki, dağlarda kalabalığız ve giderek daha da kalabalık olacağı, teşekkür ediyorum"

sözlerini; sanıklardan B,

"Değerli insan hakları savunucuları, hepinize merhaba diyorum. Arkadaşlar, parsellenmiş bir Türkiye'de, demokrasinin var diye iddia edildiği bir Türkiye'de biz demokrasinin kavgasını veren yürekli insanlar olarak buraya dövmek için geldik. Buraya konuşmak için geldik. Bu-raya haykırmak için geldik. Buraya Türkiye'de nasıl bir demokrasi istiyoruz, onu insanlara söylemek için geldik. Ama görüyorum ki, burada özellikle de güvenlik güçlerinin engellemele-ri sonucunda toplanan şu azınlık kendi içimizde bizi konuşturmuyor. Bir suskunluk var içi-mizde. Bir suskunluk var hepimizde. Arkadaşlar, burada bulunanlar sayısal olarak az olabili-riz, üç beş parmak olabiliriz, ama şunu unutmayın! Bunlar bize televizyonu yasaklayan insan-lar. Bugün bizim sayımızdan değil, düşüncelerimizden korkuyorlar. Çünkü, onlar bunu çok iyi biliyor. Yıllardır kendi çıkarlarına hizmet eden, insan haklarıyla yıllardır en küçük demokra-tik haklarını arayan insanların üzerindeki **devlet terörü**yle, insanların özgürce düşünme yolu-nu kapattılar. İşte bu yasaklar zinciri altında, işte bu **devlet terörü** altında biz, yani yüreği se-vinçlerin ateşiyle çarpan insanlar, Mahir'lerin ateşleriyle çarpan insanlar, halen konuşmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Devlet terörü diyorlar, Anti -Terör Yasası diyorlar. Arkadaşlar, Anti-Terör Yasası çözüm ona Terörle Mücadele Yasası neyi kolluyor, neyi kolluyor, hiç dü-şündünüz mü? Burada terörist arıyorlar, fabrikada terörist arıyorlar, okulda terörist arıyor-lar, köyde terörist arıyorlar. Ama asıl teröristler Ankara'da meclisin duvarları içerisinde asıl teröristler. Neden ordalar? Arkadaşlarım, bugün, bugün özellikle de köşe bucak fikir kulisle-rinin yapıldığı Türkiye'ye nasıl geldik? Nasıl getirdiler bizi? Bunları hepimiz yaşayarak öğ-

rendik. Bugün Erken Seçim Yasası diyorlar, muhalefet yollarını kapatıyorlar, alanları kapatıyorlar. Sözüm ona özgür Türkiye'de insanların özgür iradelerine başvuruyorlar. Sizlere soruyorum arkadaşlar biz bu Anayasaya evet dedik mi? Peki o zaman Mecliste oturup bizi yönetme yetkisini, bizim adımıza bizi yönetme yetkisi zorla alan insanlar asıl teröristler değil mi? İşte arkadaşlarım, bunun içindir ki kendilerini saklayabilmek için, kendilerini gizleyebilmek için öylesine bir Terör Yasası çıkardılar. Sözüm ona ki, bu bozguncu düzende, bu yalancı düzende, bu asıl onları korumaktır. Bugün elleri ayakları titremeye başladı. İşte arkadaşlarım, biz kendi içimizde susmaya devam ettiğimiz sürece, kafamızdaki muhalefet anlayışını o zamanlar önünü görmekten aciz tarladaki, bahçedeki, fabrikadaki işçi(ye) bilinçli (bir şekilde) taşıyamadığınız sürece, onları, sınıfımız iktidara sahip olmalıdır telaffuzuna alıştırmadığınız sürece, bunlar bizi daha çok yönetecek. Biz yine buraya gelip bağıracağız, çağıracağız ama dağıldıktan sonra mevcut düzenin, o pis burjuva alışkanlıkları içinde yine günümüzü gün etmeye çalışacağız. Bizler eğer kendimize devrimci diyorsak, bugün Anayasaya hayır demek zorundayız. Seçim Yasasına hayır demek zorundayız, göstermelik demokrasiye hayır demek zorundayız, Kürt halkının bağımsızlık mücadelesini engelleyen insanlara hayır demek zorundayız, sendikalar üstündeki baskıya hayır demek zorundayız. Biz, kısacası biz bizim olmayan demokrasi dışındaki, şu andaki kapitalizme ve ABD. emperyalizmine hizmet etmekten başka hiçbir amacı ve çıkarı olmayan bu göstermelik demokrasiye işçisiyle-köylüsüyle, öğrencisiyle-sıradan vatandaşıyla, kısacası **Türk ve Kürt halklarıyla** birlikte hayır demek zorundayız"

sözlerini kullanırlar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, her iki sanığın bu açıklamalarının, "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8/1. maddesindeki hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun, T.C. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan sözlü propaganda suçunu" oluşturduğu yönünde içtihatla bulunmuştur.

II. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **3.10.1994** tarihli ve E. 1994/9-183, K. 1994/214 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; düzenledikleri çeşitli toplantılarda,

"... Parti, **Kürt ve Türk hakları** arasındaki tek köprü... Bu düzen **Kürt meselesinde** iflas etmiştir ve buradan çatır çatır çıkıyor. Sorun **Kürt halkının iradesine** saygı gösterilerek çözülür. Esas çözüm, **Kürt halkıdır. Kürtlere** ne istiyorsunuz diye soracağız, yok ayrılmak isterlerse iradelerine saygı duyacağız, bir referandum yapacağız, **Kürt halkına** soracağız. Hakkarî'den başlayıp, Antep'e kadar herkese soracağız. Bu topraklarda ayrı bir devlet kurmak istiyor musunuz? Evet mi?, Hayır mı? ... Parti **iki halkın** bir federasyonda birliğini, ortak iktidarını savunacak. ... Parti **Türk ve Kürt halkı** arasındaki son köprüdür Doğuda özel savaşa son vereceğiz, her **iki milleti** eşit düzeye getirerek sonunda biçim olarak bir federasyonda çözürek (soruna) son vereceğiz. ... **Kürt ve Türk milleti** bir halk cumhuriyeti kuracaklar. ... **Kürt halkı** yıllardır verdiği mücadeleyi ayağa kalkarak göstermeye başladı. **Kürt halkı** yeni bir devrim yapacak, biji serhildan, biji halkımız. **Kürt halkını** bu devlet o kadar ezmiş, adını bile silmiş ve yasaklamış; ama yasaklamakla olmuyor. ... Şimdi Fırat'ı bu rejim bir sınır haline getirmiştir. ... Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu, geçmez öte tarafa. Çünkü bu topraklarda milliyetçilik olmaz, bu bir **Kürt sorunudur**. ... **Kürt milletine** kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. ... Botan'ın Kürt köylüsü ayağa kalkmış ve kendisinin efendisi olmaya başlamıştır. Ey düzen sen **Kürtün** adını mı yasakladın, **Kürt halkı** ayağa kalkıyor. **Ezilen Kürt** Anayasa yapıyor, kanun yapıyor"

şeklinde açıklamalarda bulunan bir **siyasi parti genel başkanının** bu açıklamalarının "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8/1 maddesindeki hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun TC. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda suçunu oluşturduğu," kabul edilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.4.1999 tarihli ve E. 1999/9-58, K. 1999/69 sayılı kararına konu teşkil eden yayın içeriğinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında değerlendirilmektedir.²⁹ Ancak, başvuru yöntemin terör olması dolayısıyla, güdülen siyasi amaca rağmen, ortada bir suçluluk olgusu mevcuttur ve bu örgütsel oluşumu, güdülen amaç dikkate alınarak meşru görmek hukuken mümkün değildir ve meşrulaştırma girişiminde asla bulunulmamalıdır.

II. 3713 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasında, 7. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan terör örgütünün propagandası suçu ile yakın ilişkisi bulunan ayrı bir suç tanımına yer verilmiştir:

“Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

Bu suç tanımı sorunludur. Bu fıkra da seçimlik hareketli suç tanımı yapılmıştır. Bu suç oluşturulan seçimlik hareketlerden biri, “terör örgütünün bildiri

“Sivas coğrafya olarak hürdür. Halkların buluştuğu kavşaktır. Aynı zamanda Batıda doğuya geçiş yollarının kavşağı ve düğüm noktasıdır. Coğrafya olarak Sivas düğümünün çözülmesi ile halklar Sivas kavşağında Türkiye Cumhuriyetinden koparak Kürdistan halkı bağımsızlığa Anadolu halkları da demokrasi ve özgürlüğe kavuşacaktır. Anadolu halklarını demokrasi ve özgürlüğe kavuşturma politikası Türkiye Cumhuriyetini bitirme bu coğrafyadan söküp atma politikası ile özdeşleştirilmiştir. Egemen Türklük dışında Ermeni, Arap Türkmen, Laz, Gürcü, Çerkez egemen Türkün egemenliğinden kurtularak demokrasi ve özgürlüğe kavuşacak Anadolu halklarıdır ...

Demokratlar ve devrimciler, bugün, Kürtlerin boyun eğmeye zorlandıkları baskının nedeninin, Cumhuriyetin kendisinde değil, emperyalist politikaların uzantısı olan faşist uygulamalarda ve militer baskıcı politikalarda olduğunu, sorunun çözümünün ise, Türkiye’nin yıkılışında değil, demokratikleşmesinde ve devrimleşmesinde görülmelidir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu açıklamalarla, sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Kürtler, Ermeniler, Araplar, Türkmenler, Alevi Türkler, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler gibi halklardan oluştuğuna değinmek suretiyle çeşitli etnik kökene sahip vatandaşları ırk temelinde dayalı olarak ayrı halklar olarak göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti parçalanıp dağıldığında, yaşayan bu hakların soluk almaya başlayacağını ifade ederek Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda” suçunu işlediğini kabul etmiştir.

III. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “Türkiye Cumhuriyetinin Kürdistan’da Kürt halkına soykırım uyguladığı, Türk ulusalcılığının esas alınıp Kürt kimliğinin yasaklanarak bütün ulusal haklarının gasbedildiği, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmesinin engellendiği, kapsamlı şekilde ileri sürülüp, vurgulanarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyile bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda” yapan sanığın “eylemin(in) 3713 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamına giren suçu oluşturduğu” değerlendirmesinde bulunmuştur (Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 11.2.1993, E. 1992/11752, K. 1993/664. Ayrıca bkz. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 18.5.1994, E. 1994/3563, K. 1994/3266); Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 5.1.1994, E. 1993/11775, K. 1994/5; Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 1.5.2002, E. 2002/2263, K. 2002/5625).

²⁹ Bu konuda ayrıntılı tespit ve değerlendirmeler için bkz. Yargıtay CGK, 29.4.2008, E. 2007/8-244, K. 2008/92.

veya açıklamalarını” *basmak*, diğeri ise, bunları *yayımlamaktır*. Suçun konusu ise, “terör örgütünün bildiri veya açıklamaları”dır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, terör örgütünün her açıklamasını yayımlamak, suç oluşturmaz. Örgütün örneğin bir terör saldırısını üstlenme yönündeki açıklamasını yayımlamak, basın (haber verme) özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gereken bir husustur. Söz konusu suç bakımından önemli olan, terörizmin ve terör örgütünün propagandası mahiyeti taşıyan içerikteki “bildiri veya açıklamalarını”n basılması veya yayımlanmasıdır.

İçeriği propaganda mahiyeti taşıyan “terör örgütünün bildiri veya açıklamalarını” basmak, m. 7, f. 2’de tanımlanan propaganda suçu bakımından bir *hazırlık hareketidir*. Bu yönü itibarıyla söz konusu suç tanımında bir sorun bulunmamaktadır. Buna karşılık, içeriği propaganda mahiyeti taşıyan “terör örgütünün bildiri veya açıklamalarını” yayımlamak, aynı zamanda m. 7, f. 2’de tanımlanan suçun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Bu yönü itibarıyla 3713 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki suç tanımı ile 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki suç tanımı arasında bir mükerrerlik³⁰ ve özellikle nitelikli unsur bakımından **çelişki**³¹ bulunmaktadır.³²

Aslında bu çelişkili durum, **Alman Ceza Kanununda** da mevcuttur.

³⁰ “Terör örgütü PKK’nın amacı ve stratejisi doğrultusunda silahlı eylemlerde bulunan ve Halk Savunma Güçleri (HPG) olarak adlandırılan yapılanmanın ana karargah komutanı sıfatıyla konuşan kişinin ‘*Gabar Dağı kürk halkının gururu, iftiharıdır. Gabar Dağı yiğitlerin yeridir, öyle bir dağ ki Türk Ordusu on binlerce askerini oraya yağmasına rağmen hükmedemiyor, her gün ağır kayıplar veriyor. Gabar’da eylem yapan grubumuzu selamlıyoruz. Tüm Kürdistan dağları, Ağrı’dan Munzur’a, Siser’e, Andok’a kadar hepsi halkımızın umudunun yükseldiği yerlerdir.*’, ‘*Bahardan beri binlerce askerin bulunduğu taburların konuşlandığı bir yerde bu eylem oldu. Bu eylem bir kez daha gösterdi ki Türk Devletinin yaptığı propagandanın hepsi yalan, gerilla güçleri ne zaman nasıl ve hangi koşullarda olursa olsun Türk Ordusuna darbe vurabilir. Bu eylem askeri anlamda bunu gösterdi.*’ biçimindeki açıklamalarının açıklamayı yapan kişinin ideolojik ve örgütsel konumu da dikkate alındığında PKK terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullandığı şiddeti, silahlı çatışmayı özendirici ve teşvik edici nitelikte olduğu, bu açıklamalara ana karargah komutanı olarak adlandırılan kişinin fotoğrafı ile birlikte ulusal çapta yayın yapan bir gazetede yer verilmesinin 3713 sayılı Kanunun 6/2. maddesinde düzenlenen terör örgütü açıklamasını yayımlamak suçunu oluşturacağı anlaşılmıştır: Yargıtay 9. CD, **3.1.2012**, E. 2010/1679, K. 2012/140. Ayrıca bkz. ÖZBEK, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, sh. 93 vd.

³¹ Bkz. Yargıtay 9. CD, **10.6.2014**, E. 2013/14755, K. 2014/7125; Yargıtay 9. CD, **23.9.2008**, E. 2008/5842, K. 2008/10214.

³² 2006 yılında görev yaptığım 5532 sayılı Kanunun hazırlık çalışmaları sürecinde 3713 s. Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasının bu mülahazalarla yürürlükten kaldırılması yönünde yoğun çaba göstermiş olmama rağmen, bu çabalarımda başarılı olamadım. Bkz. ÖZGENÇ, *İzlet: Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, Eylül 2006, sh. 43 vd.; YILDIRIM, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, 2. bası, sh. 249.

Avrupa Birliği Konseyinin 13.06.2002 tarihli ve **2002/475/JI** sayılı Terörizmle Mücadele **Çerçeve Kararı**³³ ile üye devletler arasında terör suçlarının diğer suçlarla ilişkisine, terör örgütüne, terör suçlarından dolayı sorumluluğa ve bu suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin kanuni düzenlemelerde **yeknesaklığı sağlamak** amaçlanmıştır. Bu karar doğrultusunda Alman Ceza Kanununda yapılan 22.8.2002 tarihli değişiklikle³⁴ Kanunun terör örgütüne ilişkin hükümlerinin yabancı terör örgütleriyle ilgili olarak da uygulanmasını sağlamak amacıyla Kanuna §129b eklenmiştir. Keza Alman Ceza Kanununda yapılan 22.12.2003 tarihli değişiklikle³⁵ **Avrupa Birliği Konseyinin** söz konusu **2002/475/JI** sayılı **Çerçeve Kararı** hükümleri dikkate alınarak Alman Ceza Kanununun terör örgütü ile ilgili hükümlerine ilişkin § 129a yeniden düzenlenmiştir.³⁶

Bu değişiklikle, **Alman Ceza Kanununda, terör örgütünün desteklenmesi suçunun** (§129a, f. 5, birinci cümle) yanı sıra, **terör örgütüne üye veya destekçi temini çabasında bulunma suçu** tanımlanmıştır (Alman CK, §129a, f. 5, ikinci cümle; ayrıca bkz. §129, f. 1, ikinci cümle). Bu itibarla, terör örgütüne üye veya destekçi teminine **çabalamak, gayret etmek** (“werben”) fiili, suç oluşturmaktadır. Bu düzenlemeye göre, terör örgütüne veya örgütün ideolojisine sempati duyulmasına yönelik açıklamalar, artık suç oluşturmamaktadır.³⁷ Bu suçun oluşabilmesi için, örgüte üye olmayan bir kişiyi örgütle organik bağlantı kurmaya doğrudan teşvik etmek ve bu suretle, örgütün faaliyeti çerçevesinde planlanan suçların işlenmesini kolaylaştırmak, örgütün faaliyet ve hedefine ulaşma kabiliyetine pozitif bir katkı sağlamak, örgütün tehlikeliliğini tahkim etmek gerekir.³⁸

³³ Official Journal of the European Union / Amtsblatt der Europäischen Union, 22.6.2002, L 164/3.

³⁴ “34. Strafrechtsänderungsgesetz”: BGBl I, 2002, sh. 3390. Ayrıca bkz. Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – Drucksache 14/7025, Gesetzentwurf, 04.10.2001; Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – Drucksache 14/8893, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss), 24.04.2002.

³⁵ BGBl I, 2003, sh. 2836. Ayrıca bkz. Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – Drucksache 15/813, Gesetzentwurf, 08.04.2003; Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – Drucksache 15/1730, Beschluss und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss), 15.10.2003.

³⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. **Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu, 25.03.2019**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRK-CE-MER) yayını, sh. 3 vd.

³⁷ Münchener Kommentar zum StGB (Schäfer), § 129, kn. 96.

³⁸ BGH, Urteil vom 2.4. 2015, 3 StR 197/14, kn. 13, 14; BGH, Urteil vom 14.8.2009, 3 StR 552/08, kn. 138-141.

Fakat belirtmek gerekir ki, 3713 s. K, m. 7, f. 2, son cümle düzenlemesine benzer hükümler de Alman CK, § 86 ve § 86a'da yer almaktadır. Bu hükümlere göre, yasaklanmış olan bir örgütün propaganda araçlarını, tanıtım işaretlerini üretmek, bulundurmak, dağıtmak, kamuya açık olarak gösterime sunmak suç oluşturmaktadır.³⁹ Dikkat edilmelidir ki, bu suçun oluşabilmesi için söz konusu propaganda araçlarının içeriğinin herhangi bir somut suçla ilgisinin olmasına gerek bulunmamaktadır.⁴⁰

III. 3713 s. Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasında 11.4.2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanunla (m. 8) değişiklik yapılarak, fıkra metninin birinci cümlesi,

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak 3713 s. Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

“Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu düzenlemeye göre, terör örgütünün, faaliyeti çerçevesinde işlenen cebir, şiddet veya tehdit içeren fiillerden ve genel olarak suçlardan bahsetmeksizin, güttüğü siyasi, sosyal ve ekonomik amaçların müzakere edilmesi bağlamında Devlet tarafından muhatap alınması gerektiğini savunmak, bu yönde yayın yapmak suç oluşturmayacaktır.

Bu düzenleme ile, PKK'nin bir terör örgütü olmaktan çıkarılıp, güttüğü siyasi, sosyal ve ekonomik amaçlar itibarıyla Devlet tarafından muhatap alınmasının ve süreç içinde “meşruiyeti” konusunda izlenim oluşturulmaya çalışılan “taraf” statüsüne kavuşturulmasının yolu açılmış olmaktadır.

³⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. **Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu, 25.03.2019**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRK/CE-MER) yayını (Editörler: Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Cumhuriyet Şahin, Prof. Dr. İlhan Üzülmöz), Ankara, 2019, sh. 3 vd.

⁴⁰ BGH, Urteil vom 31.7. 2002, 3 StR 495/1, kn. 16 vd.

Ancak bu düzenlemede, terör örgütünün propagandası suçunun tanımlandığı 7. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile sonuncu cümlesi arasında **bilinçli** olarak bir **çelişki** oluşturulmuştur. Zira 6459 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısının müzakereleri sırasında bu çelişkili durumla ilgili olarak tarafımdan ilgili siyasiler bilgilendirilmiş olmasına rağmen, kayıtsız kalınarak Tasarı metninin kanunlaşması sağlanmıştır. Bu çelişkili düzenleme karşısında, “*cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek*” herhangi bir ifade kullanılmasa bile, örneğin terör örgütü lehine slogan atılması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin teşhir edilmesi suç olmaya devam etmektedir.⁴¹

Öncelikle belirtmek gerekir ki, doğru olmadığı izahtan vareste olan bu değişiklik, malum “çözüm süreci”nin bir “gereği” olarak yapılmıştır. Bu süreçte, malum terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen pek çok suç olgusu Devlet güçleri tarafından görmezlikten gelinmiş ve terör örgütünün palazlanması sağlanmıştır. PKK terörünü sonlandırmak amacıyla başlatılan malum “**çözüm süreci**”nde çıkarılan 10.7.2014 tarihli ve 6551 sayılı “**Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun**”la Hükûmete;

“a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirle(mek;)

b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar ver(mek) ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendir(mek;)

c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri al(mak)”

hususlarında yetki verilmiştir (m. 2, f. 1). Yine söz konusu Kanunun 4. maddesinde, **bu çerçevede verilen “görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz”** hükmüne yer verilmiştir (f. 2).

⁴¹ Ayrıca belirtmek gerekir ki, 3713 s. K, m. 7, f. 3’de tanımlanan fiillerin, terör örgütünün propagandası suçu ile ilişkilendirilmesi doğru olmamıştır. Örneğin düzenlenen bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne kişinin kimliği tespit edilemeyecek şekilde yüzünü kapatarak katılmasının, 2911 sayılı Kanunda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzeni ile ilgili bir suç veya kabahat olarak tanımlanması gerekirdi.

Buna göre, malum “çözüm süreci”nde, giydikleri üniforma görüntüsü arz eden kıyafetler ve hatta üzerlerinde taşıdıkları silahlar itibarıyla PKK terör örgütünün mensubu oldukları açıkça anlaşılan kişilerin, yurt dışına çıkmakta oldukları gerekçesiyle yakalanmaması yönünde talimat veren ve bu talimata uyarak, suçüstü haline rağmen, bu kişileri yakalamaktan sarfınazar eden kamu görevlileri **ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamayacaklardır!**

Amaç itibarıyla olmasa bile, izlenen yöntem itibarıyla hukuka aykırı olan bu sürecin oluşturduğu siyasi atmosferde PKK terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde düzenlenen hukuka aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında taşınan pankartlar ve atılan sloganlar içerikleri itibarıyla suç oluşturmaya rağmen, mülki amirler ve kolluk görevlileri tarafından bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar gerektiğinde zor kullanılarak dağıtılmamıştır.

Ancak, malum çözüm sürecinde palazlanan terör örgütünün 2015 yılında başlattığı silahlı **başkaldırı** hareketi ve bu başkaldırının bastırılması amacıyla yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında, terörizmin ve terör örgütünün propagandası mahiyeti taşıyan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine karşı müsamahadan tamamen vazgeçilmiş ve Terörle Mücadele Kanunu, m. 7, f. 2’de 6459 sayılı Kanunla yapılan söz konusu değişiklik, terör örgütünün propagandası suçu bakımından dikkate alınmamaya başlanmıştır.

IV. Aşağıda inceleme konusu yapmış bulunduğumuz Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları ile Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları, malum “çözüm süreci”nde işlenen terörizmin ve terör örgütünün propagandası fiilleriyle ilgilidir.

Birinci Karar: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, **6.2.2020** tarihli ve E. 2016/729, K. 2020/67 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Türkiye’de hukuki varlığı devam eden ve faaliyette bulunan bir siyasi partinin ilçe teşkilatı tarafından organize edilen yerel seçim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmiş olan 28.3.2014 tarihli açık hava toplantısına “*devrim şehitleri*”ne bir dakikalık saygı duruşu ile başlanır ve toplantı sırasında, “*şehit namırın*”, “*biji serok Apo*”, “*dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan*”, “*jin jıyan azadi*” ve “*faşizme karşı omuz omuza*” şeklinde sloganlar atılır; Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK’nin Suriye kanadı olan PYD’nin silahlı gücü YPG’nin (Yekiyenen Parastina Gel) flaması açılır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda, aşağıdaki gerekçe ile, terör örgütünün propagandası suçunun oluştuğunu oyçokluğuyla kabul etmiştir:

“3713 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 2. fıkrasındaki suçun oluşabilmesi için eylemin terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiş olup fıkranın son cümlesinde “Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır” şeklindeki düzenlemeyle; **toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, slogan atılması, ses cihazları ile yayın yapılması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi de bu fıkranın (b) bendinde maddeler hâlinde belirtilmiş olup yasa koyucu bu bentteki eylemleri gerçekleştiren sanığın cezalandırılabilmesi açısından Kanun’un 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen unsurları aramamış yalnızca ceza atfı amacıyla bir düzenleme yapmıştır. Sanığın eylemi, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmakla birlikte Kanunda yer almayan bir gerekçeyle unsur olarak aranamayacağı ve sanığın eyleminin hukuka uygun kabul edilmesinin toplum açısından meydana getireceği yakın tehlike de gözletildiğinde, sanığın PKK silahlı terör örgütüne ait bayrağı taşınmaktan ibaret eyleminin silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir”.**

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı, aşağıdaki gerekçe ile bu karara katılmamıştır:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, **şiddeti teşvik ve tahrik edici nitelikte olmayan silahlı terör örgütüyle ilgili propagandayı** istikrarlı bir şekilde **ifade özgürlüğü kapsamında** değerlendirilmesi üzerine bu kararlara uyum sağlama amacıyla 3713 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile her türlü terör örgütü propaganda suçuna; **terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek ya da teşvik etmek unsurunu** ilave etmiştir. Aynı fıkranın son cümlesinde “Aşağıdaki fiil ve davranışlarda bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır” şeklinde yapılan atıfla b bendinde sayılan fiil ve davranışlara hem ceza hem de unsur atfında bu-

lunulmuştur. Diğer bir ifadeyle silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılabilmek için b bendinde belirtilen eylemlerin aynı zamanda **örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermesi veya övmesi ya da teşvik etmesi gerekir**. Sözü edilen bu unsurları aramamak yasa değişikliğinin amacına da aykırıdır. Sözü edilen (b) fıkrasında sayılan fiillerde şiddeti meşru gösterme, övme veya teşvik etme özelliklerini aramadığımız takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince sözleşme kapsamında ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilen bir eylemi cezalandırmış oluruz. Bu da suçun genel unsurları içerisinde yer alan hukuka aykırılık unsurunu göz ardı etmek, kullanılan bir hakkı suç sayıp cezalandırmak demektir.

Somut olayda sanığın PKK silahlı terör örgütüne ait **bayrağı** açmaktan ibaret eylemi her ne kadar 3713 sayılı Kanun'un 7 maddesinin ikinci fıkrasının (b) başlığının 1. alt bendi kapsamında 'örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması' kapsamında kabul edilse de Kanun'un 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunmadığından silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kanaatindeyim.

İkinci Karar: Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **18.2.2020** tarihli ve E. 2016/1140, K. 2020/110 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; yapılan çağrılar üzerine 1.9.2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapıldığı alanda kurulu bulunan platformun çevresinde açıkça görünebilirliği sağlanacak büyüklükte **“Bir Eylül Onurlu Bir B. İçin Demokratik Çözüm ve Müzakere”**, **“Askeri ve Siyasi Operasyonlar Durdurulsun”** ibareli pankartlar asılır; meydana toplanan grup tarafından Abdullah Öcalan'ın posterleri açılır; PKK'nin sembolü olan işaretleri taşıyan pankartlar taşınır; **“Biji Serok Apo”** (Yaşasın Başkan Apo), **“Canımızla Kanımızla Seninleyiz Ey Başkan”** şeklinde Abdullah Öcalan'ı öven, Abdullah Öcalan'a bağlılığı ifade eden sloganlar atılır; terör örgütünü övücü mahiyette sloganlar atılır ve marşlar söylenir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda, yukarıda iktibas edilen birinci Karardaki gerekçe ile, terör örgütünün propagandası suçunun oluştuğunu oyçokluğuyla kabul etmiştir.⁴²

⁴² Aynı yönde diğer bir karar için bkz. Yargıtay CGK, **18.2.2020**, E. 2017/384, K. 2020/111.

Üçüncü Karar: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **11.6.2020** tarihli ve E. 2016/1159, K. 2020/280 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü münasebetiyle 15.2.2012 tarihinde düzenlenen ve aralarında milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve belediye meclisi üyelerinin bulunduğu izinsiz toplantıda katılımcılar tarafından, **“Be serok jiyan nabe, PKK halktır halk burada, Kürdistan faşizme mezar olacak, T.C. şaşırma bizi dağa taşıрма, T.C.’nin piçleri yıldırılmaz bizleri, Bulanık ovası Apocular yuvası, vur gerilla vur Kürdistanı kur, baskılar bizi yıldırılmaz, gençlik Aponun fedaisidir, geliyor geliyor apocular geliyor, AKP’yi basarız Erdoğan’ı asarız, disa disa serhildan serok’ime öcalan, em kine apo cine”** şeklinde sloganlar atılır; sarı zemin üzerine yeşil-kırmızı yazı ile yazılı **“Ya onurlu bir çözüm ya da görkemli bir direniş”**, siyah bez üzerine beyaz renk yazı ile; **“15 Şu-**

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **18.6.2020** tarihli ve E. 2017/600, K. 2020/306 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Adana Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşmasında, haklarında terör örgütü üyeliği ve sair suçlardan dolayı verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması üzerine, bütün sanıklar duruşma salonunda **“Biji serok Apo”** şeklinde slogan atarlar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu “olayda, duruşma salonunda, sanıkların topluluğa hitaben **“Biji serok Apo”** şeklinde söyledikleri sözlerin her ne kadar 3713 sayılı Kanun’un 7 maddesinin ikinci fıkrasının (b) başlığının 2. alt bendi kapsamında **“terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde slogan atılması”** şeklinde kabul edilse de ifadenin gerek içeriği gerekse açıklandığı ortam gözetildiğinde; **ifade özgürlüğü** kapsamında değerlendirerek sanıklara atılı silahlı **terör örgütünün propagandasını yapma suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı** yönünde içtihatla bulunmuştur.

Belirtmek gerekir ki, karara konu teşkil eden olayda, kişiler terör örgütü üyeliğinden ve sair suçlardan dolayı haklarında verilen **mahkûmiyet hükmünün açıklandığı sırada, bir tepki olarak**, bu sloganı atmışlardır. Atılan bu sloganla kişiler, haklarında verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmasına rağmen, işledikleri suçlardan dolayı pişmanlık duymadıklarını ve terör örgütüne bağlılıklarının devam ettiğini beyan etmişlerdir. Bu karar, sonuç itibarıyla doğrudur. Ancak, gerekçesi itibarıyla tutarsızdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçu, bir amaç suçtur, yani muhatabı etkilemek, terör örgütünün ve faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda muhatap nezdinde bir kanaat oluşturmak amacıyla işlenir. Oysa, kişiler sanık olarak yargılanmakta oldukları mahkeme salonunda **“Biji serok Apo”** şeklinde slogan atarken, haklarında verilmiş olan mahkûmiyet hükmüne tepki gösterdiklerini, işledikleri suçtan dolayı pişmanlık duymadıklarını beyan etmiş olmaktadır. Sanıklar bakımından bu tür fiillerin münhasıran duruşma disiplininin bozulması çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Kararda, **“ifadelerin açıklandığı ortam”**dan bahisle propaganda suçunun oluşmadığı yönündeki gerekçe, tutarsızlıkla maluldür (Aynı yöndeki gerekçe için ayrıca bkz. Yargıtay CGK, **23.6.2020**, E. 2017/943, K. 2020/311). Bir başka kararda da “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak suçundan” dolayı haklarında kurulan mahkûmiyet hükmüne tepki olarak sanıkların **“Biji serok apo”** şeklinde slogan atması fiilinin, **“olayın meydana geldiği yer ve muhatap kitle de”** dikkate alınarak propaganda suçunu oluşmadığı değerlendirilmesinde bulunulmuştur: Yargıtay 16. CD, **29.9.2016**, E. 2016/1297, K. 2016/4872. Ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **19.12.2016**, E. 2016/3839, K. 2016/7571; Yargıtay 16. CD, **28.2.2017**, E. 2017/304, K. 2017/937; Yargıtay 16. CD, **15.6.2017**, E. 2017/1334, K. 2017/4470.

bat Uluslararası Soykırım Gününü şiddetle kınıyoruz”, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil ve mor zemin üzerine kırmızı-siyah renk yazı ile “**Ji bo jiyanek bi ru-met an azadi an azadi**” şeklinde pankartlar taşınır. Keza bu toplantıda, belediye meclisi üyesi olan S tarafından,

*“Bilgi sahibi olmadığımız ancak tarihi araştırmalar sonucunda farklı halkların yaşadığı bir gerçektir. Bu halklar kendi dönemin egemenleri tarafından soykırıma uğratılmış ve yok edilmişlerdir. 15 Şubat 1923 Lozan Antlaşması bir savaş sürecinin bitirilmesiyle dönemin egemen devletlerarası bir anlaşmayla sonuçlanan tüm hazırlıkların coğrafyamızda oluşacak bir yapılanma Kürtler, Türkler ve diğer halkların varlığı dikkate alınarak planlanmıştır. Lozan’a giden Türk temsilcileri devre dışı bırakılarak bölgemizde sağlanacak bir barışın önüne geçmişlerdir. 15 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı ile bu Cumhuriyet Kürtlerin ve Türklerin Cumhuriyetidir sözü yerine getirilmediği için önce isyanlar sonrası katliamlar başlamıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse Dersim, Ağrı, Zilan, Koçgiri ve daha niceleri 15 Şubat 1999 tarihinde Kürt halk önderi sayın Öcalan’ın uluslararası bir komployle **esir** alınması ve bugüne kadar Kürtlere uygulanan katliamların devamında çıkar sağlayan emperyalistlerin planlamasıdır. Onun içindir ki bunu herkes uluslararası bir komplo olarak görür. Bugünkü Orta Doğuda var olan çıkar savaşları apaçık ortadadır. Orta Doğudaki tehlikeli gidişatları bilen Öcalan Orta Doğu için antiemperyalist demokratik Orta Doğu Halklar Federasyonu oluşturmasının bir zorunluluk olduğunu defalarca belirtmesi gerek bölgemizde gerekse Orta Doğuda... Bu çözümlülüğü bölge halklarına fayda sağlayamadığı gibi dünyada da fayda sağlayamayacaktır. Kürt sorununun çözümünün tek muhatabı PKK ve O’nun önderliğidir. 15 Şubat 1999 uluslararası komploda yer alan tüm devletleri kınıyor karşı durumumuzu tüm halkımıza beyan ediyoruz”*

şeklindeki bildiri metni okunur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, gösteri yürüyüşüne katılan ve toplantıda bu bildiriye alenen okuyan belediye meclisi üyesi S’nin fiilinin **terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmadığına** karar vermiştir.

Dördüncü Karar: Anayasa Mahkemesinin **3.10.2019** tarihli ve 2018/38143 Bireysel Başvuru sayılı kararına⁴³ konu teşkil eden olayda; X, bir siyasi parti

⁴³ “Sırrı Süreyya Önder Başvurusu”, RG: 8 Ekim 2019/30902.

il teşkilatının 17.3.2013 tarihinde düzenlediği açık hava toplantısında, aşağıdaki içerikte bir konuşma yapar:

*“Merhaba. Çewane (nasılsınız) halkım hoş geldiniz. Nevroz piroz be (nevruzunuz kutlu olsun). Size **Kürt halk önderi sayın Öcalan**’ın selamını getirdim. Bu soğuk havada güneş gibi içimizi ısıtsın diye sayın Öcalan’ın selam gönderdiği siz evlatlarımızın **kardeşlerimizin selamını** getirdim. Selam olsun.*

Halkların Demokratik Kongresi adına burayı dolduran bugüne kadar bütün mücadele alanlarında olduğu gibi bu alanı da dolduran, bütün temsiliyetlere, bütün HDK bileşenlerine, halkların temsilcilerine selam olsun. Hoşgeldiniz, Newrozunuz kutlu olsun. Barışa vesile olsun.

*Yoldaşlar, yeni bir sürece başlıyoruz. Bu, adına **barış** masası diyorlar, ama **masada kotarılan bir şey değildir**. Bu yeryüzüne ve gökyüzüne bütün Türkiye halklarının, başta Kürt halkı olmak üzere, Ermenilerin, Süryanilerin, Kafkas halklarının, Çerkezlerin mücadelesi ile yeryüzüne ve gökyüzüne yazıldı bu, masalarda kotarılmadı. Bu barış, başta Kürt halkı olmak üzere emekçiler, mazlumlar olmak üzer hepinizin eseridir. Barışınız da kutlu olsun.*

*Biz de HDK olarak **Kürdistan**’da onun **onurlu evlatlarıyla** onur duyuyoruz.*

*Yoldaşlar, çok değil, bundan 1 sene önce yine bu alanlardaydık, yine elimizde ve kalbimizde barış iradesi ile gelmiştik, bu alana sokulmadık. O gün de barış diyorduk, bugün de barış diyoruz, yarın da barış diyeceğiz. İşte halkların iradesi, işte yan yana durmanın erdemi ve kararlılığının eseri budur. Ne oldu, geçen yıl bu meydana almadılar, giremedik mi, girdik. İşte **barış masaların değil**, bu inadın bu iradenin sonucudur. Onun için barış size kutlu olsun, onun için bize kutlu olsun.*

*Biz, biz bir **mücadelenin** sonuna gelmedik, bir mücadele bitmiş değil. Biz bir mücadelenin en acı bölümünün sonuna geldik, en yakıcı bölümünün, **ölümlü kanlı bölümünün** sonuna geldik. Bundan sonrası artık yeni Türkiye’yi bütün halklarla birlikte inşa etmenin zamanıdır. Tam bir demokrasi ile emekçisi ile ezilenleri ile mazlumlarıyla bu mücadelemiz ta ki tüm halkların, tüm ezilenlerin kurtuluşuna kadar devam edecek. Ama, artık bu hikayenin, ki anlatılan bizim hikayemizdir, sizin hikayenizdir. Acıklı bölümün acılı bölümün sonuna geldik. Peki ne pahasına? Bu halk, siz bizi **öldürmekten** yorulacağınız güne kadar direneceğiz dedi, biz yorulmayacağız, biz direneceğiz dedi. İşte sonucu bu.*

*Biz, siz bizi kabristanla mı korkutuyorsunuz? Biz o kabristanı gülistan ederiz dedi, **ölerek** bu barışı getirdi. Siz, bizi zindanlarla mı korkutuyorsunuz; biz o zindanları bir mücadele alanı, bir Newroz alanı, 1 Mayıs alanı yaparız, yine getiririz dedi. İşte bu barış onun eseridir. Onun için de kıymetini en çok bizler bileceğiz, en çok sizler bileceksiniz, bütün Türkiye halkları bilecek. Bütün ezilenler bilecek. Dolayısıyla, bu barış iradesini, güvercin kasaplarının eline boğdurtmayacağız, boğdurtmayacağız, boğdurtmayacağız.*

***Sayın Öcalan**, hepinize iletmek üzere dedi ki; ne eskisi gibi **savaşa**cağız, ne eskisi gibi yaşayacağız. Bütün halklar, Türkiye halkları özgürleşene kadar, tam demokratik bir ortamda yaşayana kadar da **mücadelemiz**, barış azmimiz ve irademiz devam edecek dedi. Biz de bu iradeyi HDK olarak bu iradeyi güçlendireceğiz, bu iradenin yanında olacağız, bugüne kadar nasıl bu mücadelenin kavgasını verdiysek, bundan sonra da barış iradesini yere düşürmemek için bundan sonra da ne gerekiyorsa hep birlikte yan yana, omuz omuza yapacağız. Bu irademizi bir kez daha sizinle birlikte haykırmak istiyorum.*

'Biji bıratıya gelan, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın barış.'

Yoldaşlar, genel başkanımız (Y de) burada. Ben HDK adına hepinizi tekrar selamlıyorum. Esas konuşmayı sayın eş genel başkanımız yapacak. Ben sadece, hem HDK adına hem sayın Öcalan'ın ve onun yoldaşlarının selamını iletmek üzere çıktım.

Hep birlikte haykıralım; An serkeftin an serkeftin. An azadi an azadi. Yaşasın barış, Newroz piroz be! HEPİNİZİ SAYGIYLA SEVGİYLE SELAMLİYORUM. Hoşçakalın doştça kalın."

Bu konuşması dolayısıyla X hakkında kamu davası açılır.

Yapılan yargılama sonucunda X aşağıdaki gerekçe ile terör örgütünün propagandası suçunu işlediği kabul edilerek, 3713 s. Kanun, m. 7, f. 2 hükümlerine istinaden 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilir.

"3713 sayılı Yasanın 6459 sayılı Yasayla değişik 7/2 maddesinde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gös-terecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. AİHM'nin fikir hürriyeti konusunda sözleşmenin 10. maddesiyle ilgili verdiği kararlar da bu maddeyle aynı yöndedir. Bu madde ile bilinme-

si gereken önemli bir husus, propaganda kabul edilen eylemin bizzat kendisinin şiddet içerikli olması, nefret, cebir ya da tehdit içermesi gerekmediğidir. Propaganda olan eylemin kendisi şiddet, nefret, tehdit veya cebir içerikli olması ve terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olması halinde bu madde gereğince suç oluşur... Kaldı ki, terör örgütünün şiddet içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren veya teşvik eden eylemler bu haliyle zaten şiddeti teşvik eder hale gelir. Örneğin, **'PKK'nın yapmış olduğu eylemleri destekliyoruz.'** şeklinde atılan bir sloganda kullanılan kelimelerin hiçbirisi şiddeti çağrıştırmamaktadır. Ancak cümle bir bütün halinde değerlendirildiğinde bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerinin desteklendiği ve şiddeti övücü nitelikte olduğu sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla bu suç için önemli olan propaganda teşkil eden eylemin, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermesi veya övmesi ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmesidir. Bu bir slogan şeklinde olabileceği gibi, pankart taşımak, şarkı söylemek, basın açıklaması yazmak, yazı yazmak, resim çizmek gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. AİHM verdiği kararlarda özellikle nefret içerikli hiçbir eylemin AİHS 10. maddesi kapsamında korunmayacağını özellikle belirtmektedir. Yine şiddet çağrısı, silahlı ayaklanma çağrısı, isyan çağrısı içeren eylemler de 10. maddenin korumasından yararlanmaz ...

AİHM'e göre ağır eleştiri söz konusu olduğu durumlar ile şiddet çağrısının birbirinden ayrılması gerekir. Mahkemenin özellikle üzerinde durduğu husus, eylemin şiddeti övmesi, teşvik etmesi veya meşru göstermesidir. Hatta mahkeme, Karataş-Türkiye kararında şiirde geçen şiddet içerikli ifadeleri sanatsal özgürlük nedeniyle korunması gerektiğini belirtmiştir. Buna ilişkin diğer bir örnek Arslan-Türkiye kararıdır. Yine Gül ve Diğerleri-Türkiye kararında, yasal bir toplantıda atılan basmakalıp sol sloganların şiddet içerseler bile fikir hürriyeti bağlamında korunması gerektiğini belirtmiştir. Sürek 3- Türkiye davasında ise mahkemeye göre, başvurucunun makalesinde Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak nitelemesinde ve burası ile ilgili ulusal bir bağımsızlıktan bahsetmesi tek başına müdahaleyi haklı kılmaz, ancak aynı makalede kullanılan topyekun bir bağımsızlık mücadelesi istiyoruz TC güçlerine karşı yöneltilmiş bir savaş gibi sözlerin kendisini **PKK ile özdeşleştirdiği ve bağımsızlığı gerçekleştirmek için silahlı**

güç kullanmaya teşvik ettiği için fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilemez.

Bütün bu hususlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, bir eylemin terör propagandası olarak nitelendirilip cezalandırılması için mutlak surette şiddete veya silahlı direnişe ya da isyana teşvik ediyor olması, terör örgütünün varsa bu tarz eylemlerinin övülmesi ya da meşru gösterilmesi gerekir. Ağır eleştiri sınırında kalan, siyasi nitelikli söylemlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca şiddet içerseler bile sanatsal faaliyetlerin daha özel olarak değerlendirilmesi ve AİHS'nin 10. maddesinin bu durumlarda daha geniş yorumlanması gerekir. Kanun maddesinde her ne kadar cebir, tehdit ve şiddet ayrı ayrı belirtmiş, AİHM kararlarında ise şiddet olgusu üzerinde durulmuş ise de; cebir ve tehdit zaten şiddetin bir parçası olduklarından AİHM kararlarında belirtilen şiddet olgusunun tehdit ve cebiri de içerdiği kabul edilmelidir.

... kararımızda PKK'nın bir terör örgütü olduğu kabul edilerek bu konuda ayrıntıya yer verilmeyecektir. Yine Öcalan'ın bu örgütün lideri olması nedeniyle birçok kişinin ölümünden sorumlu tutulduğu, yargılandığı ve bu nedenle ceza aldığı ve cezasının kesinleştiği sabittir...

*...Sanıklar X ve Y'nin 17/03/2013 tarihinde ... yapılan nevruz kutlaması ve miting şeklindeki açık hava toplantısında konuşma yaptıkları, sanık X'in 'Size Kürt halkı önderi sayın **Öcalan'ın** selamını getirdim... Bugün de **Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz.**' şeklinde ... sözler söyledikleri sanıkların savunmalarından, dosyada mevcut tutanak ve görüntü kayıtlarından anlaşılmıştır...*

*Sanık X yönünden yapılan değerlendirmede; sanığın **terör örgütü lideri Öcalan'ın** fotoğrafının asılı bulunduğu sahnede gerçekleştirdiği konuşmasında söylediği 'Size Kürt halkı önderi sayın Öcalan'ın selamını getirdim.... Bugün de Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz.' şeklindeki sözleri ile **terör örgütü liderini Kürt halkının lideri olarak göstererek terör örgütü PKK'yı ve yöneticisini meşru göstermeye çalışmış**, ülke topraklarının bir bölümünü, terör örgütünün bölücü ideolojisinde yer aldığı şekli ile Kürdistan olarak tabir etmiş ve bu suretle terör örgütünün propagandasını yapmıştır.*

Bütün bu nedenlerle, her ne kadar sanıklar suçlamaları kabul etmemiş iseler de, sanıkların, hüküm fıkralarında belirtilen gerekçeler ile bir-

*likte yukarıda belirtildiği gibi, nevrüz kutlaması ve miting şeklindeki açık hava toplantısında yaptıkları konuşmalar sırasında bölücü silahlı terör örgütü **PKK ile yönetici ve üyeleri lehine, terör örgütü PKK'nın kullanmış olduğu şiddet yöntemini meşru gösteren, destekleyen ve öven, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı terörle mücadele operasyonları ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya çalışan** yukarıda yazılı olduğu şekilde sözler sarf ederek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarının bir kısmını sözde Kürdistan olarak nitelendirerek örgütün bölücü ideolojisini yaymaya ve meşru göstermeye çalışarak TMK'nın 7/2. maddesinde düzenlenen **terör örgütü propagandası suçunu işledikleri** anlaşılmakla, ... cezalandırılmalarına ... karar verilmiştir.”*

Anayasa Mahkemesi bu olayda, X'in yaptığı açıklamalarla ilgili olarak “*şiddete teşvik ettiği kabul edilemez*” değerlendirmesinde bulunmuştur.⁴⁴

Bu Kararlara İlişkin Hukuki Değerlendirmelerimiz:

1) Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında taşınan pankartlarda yer alan ifadeler, işaretler ve fotoğraflar ile, atılan sloganlar ve yapılan konuşmalar birbirinden müstakil olarak ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulamaz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında taşınan pankartlarda yer alan ifadeler, işaretler ve fotoğraflar ile, atılan sloganlar ve yapılan konuşmalar birlikte değerlendirilerek, terör örgütünün propagandası suçunun işlenip işlenmediğini tespit etmek gerekir. Bu itibarla, bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında atılan bir slogan, taşınan bir resim veya pankart müstakilen ele alınıp içeriğinin suç oluşturup oluşturmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmamalıdır. Keza, toplantıda yapılan konuşma bir bütün olarak ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.⁴⁵

2) İşlenen fiilin, taşınan pankartın, atılan sloganın içeriğinin suç oluşturup oluşturmaması ile, suç oluşturan propaganda fiillerini işleyen kişilerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği, bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında işlenen propaganda mahiyetindeki fiillerden dolayı kimlerin sorumlu tutulması gerektiği, birbirinden ayrı hususlardır.

⁴⁴ Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143 (Sırrı Süreyya Önder) (RG: 8 Ekim 2019/30912), pn. 73.

⁴⁵ TAŞTAN, CHD, cilt III, sayı 6, Nisan 2008, sh.108.

Eğer bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde terörizmin ve terör örgütünün propagandası yapılmış ise, ceza hukuku sorumluluğu bakımından bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü organize eden kişilerle bu toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan kalabalıkları birbirinden ayırmak gerekir.

Terörizmin ve terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan kalabalık içinde yer alan ve özellikle çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin, **kitle psikolojisinin** etkisiyle hareket ettikleri için, işledikleri fiillerden dolayı sorumluluklarını **kusurluluk** bağlamında ele alıp değerlendirmek gerekir. Başka bir ifadeyle, kalabalığı oluşturan kişilerin bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasındaki **davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneklerinin olmadığını** veya **ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmeyecek düzeyde azaldığını** kabul etmek gerekir.

Bu nedenle, terörizmin ve terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan kalabalık içinde yer alan ve özellikle çoğunluğu çocuklardan oluşan kişiler hakkında bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında işledikleri fiiller dolayısıyla,

- açılmış olan davalarda, kusurunun bulunmaması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığı,
- yürütülen soruşturmalarda, yine aynı gerekçe ile kovuşturmaya yer olmadığı,

kararının verilmesi gerekir. Keza, **suç siyaseti** gereğince, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçu ile ilgili olarak cumhuriyet savcılarının kamu davasını açma hususunda takdir yetkisiyle donatılması gerekir. Hatta, terörizmin ve terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma konusunda yönlendirilen çocukların, suç siyaseti gereğince, soruşturma işlemlerine dahi tabi tutulmaması gerekir. Belirtilen hususlarda Cumhuriyet savcılarının yetki kullanabilmesini sağlamaya yönelik olarak Ceza Muhakemesi Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmasına büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

3) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında atılan “*Biji serok Apo*” sloganından veya bu kişiye ait fotoğrafın taşınmasından hareketle, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun işlendiği sonucuna varılamaz.

Kişiler, Abdullah Öcalan’ı bir “lider” olarak kabul etseler bile, adı geçen kişi, mahkûm olduğu **cezasını infaz kurumunda elan çekmekte olan** bir

hükümlüdür. İnfaz mevzuatımız hükümleri dikkate alındığında, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan bir hükümlünün bir terör örgütüne fiilî liderlik yapması mümkün olmasa gerekir.⁴⁶ Buna rağmen kişi, terör örgütü mensupları tarafından “lider” olarak kabul edilebilir. Bu kabulü salt beyan, terör örgütü üyeliği veya terör örgütünün propagandası suçunun oluşumuna sebebiyet vermez.⁴⁷

Ancak, terör örgütünün ismi zikredilerek ve özellikle faaliyetleri çerçevesinde icra edilen fiillerden bahisle slogan atılması, bu örgütün ve faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda kişilerde izlenim oluşturma amacını taşımaktadır. Bu içerikte pankart taşınmasıyla, slogan atılmasıyla propaganda suçunun oluşacağında kuşku bulunmamaktadır.⁴⁸

4) Anayasa Mahkemesinin yukarıda iktibas etmiş bulunduğumuz 3.10.2019 tarihli ve 2018/38143 Bireysel Başvuru sayılı kararında, yapılan “açıklamalarının şiddete teşvik mahiyetinde olup olmadığı yönündeki değerlendirmenin ... açıklamada bulunan kişinin kimliğine, açıklamanın zamanına ve muhtemel etkilerine ... bir bütün olarak bakılarak yapılması gerektiği” belirtilmiştir.⁴⁹ Yapılan açıklamanın şiddet içerip içermediğinin tespitinde, açık-

⁴⁶ ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 13. bası, Ankara, Ocak 2020, sh. 61 vd.

⁴⁷ Bkz. Yargıtay 16. CD, **10.7.2017**, E. 2017/830, K. 2017/4745; Yargıtay 16.CD, **18.11.2020**, E. 2018/3952, K. 2020/5667.

⁴⁸ Nitekim, Anayasa Mahkemesi tarafından, “Türkiye’nin her bölgesinde yaşanan ve yaşanmakta olan ağır şiddet hareketlerinin faili, PKK’nın kurucusu ve söz konusu şiddet eylemlerinin birincil elden sorumlusu olan Abdullah Öcalan’ı **politik bir lider ve toplumsal sorunların demokratik yollarla çözümünde meşru bir aktör** olarak ilan eden söylemleri terör eylemlerinin failini öven ve dolayısıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik eden mesajlar olarak değerlendirmemiştir.”: Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 64; Anayasa Mahkemesi, **5.11.2020**, BB 2015/15672 (Candar Şafak Dönmez) (RG: 17 Aralık 2020/31337), pn. 67. Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, **8.1.2020**, BB 2015/15088 (Mehmet Mihdi Bala) (RG: 17 Mart 2020/31071), pn. 56.

Buna karşılık, “geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda PKK’nın kurucusu (Abdullah Öcalan’ın) lider olarak benimsendiğine ilişkin sloganlar ile dışa vurulan düşünce açıklamasının zamansal açıdan şiddet tehlikesine neden olduğu değerlendirilmiştir. ... çatışma ortamının bulunduğu bir durumda başka bazı sloganlar yanında PKK terör örgütünün kurucusu ve örgütün eylemlerinin birinci dereceden sorumlusu olan (Abdullah Öcalan’ın) lider olarak gören sloganların atılması ile dışa vurulan düşünce açıklamasının zamansal açıdan şiddet tehlikesine neden olduğu değerlendirilmiştir.”: Anayasa Mahkemesi, **8.1.2020**, BB 2015/15088, pn. 58; Anayasa Mahkemesi, **5.11.2020**, BB 2015/15672, pn. 67.

⁴⁹ Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 67; Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635, pn. 86; Anayasa Mahkemesi, **9.5.2019**, BB 2017/36722 (Ayşe Çelik) (RG: 10 Mayıs 2019/30770), pn. 50; Anayasa Mahkemesi, **24.6.2015**, BB 2013/568 (Ali Gürbüz ve Hasan Bayar) (RG: 13 Ağustos 2015/29444), pn. 64.

lamayı yapan kişinin kimliğinin dikkate alınması gerektiği yönündeki bu gerekçe, hukukilikten ve bilimsellikten uzaktır. Elbette ki **somut** tehlike suçlarında, **açıklamanın** muhtemel etkilerinin tespiti bağlamında **yapıldığı ortam, yer ve zaman** dikkate alınır.⁵⁰ **Açıklamayı yapan kişinin kimliği, açıklamanın şiddet içerip içermediğinin tespitinde değil, açıklamanın tehlikelilik boyutunun tespitinde dikkate alınabilir.**⁵¹ Ancak, suç oluşturup oluşturmadığının tespitinde açıklamayı yapan kişinin kimliğinin de ölçü alınmasını arayan bu “içtihat”, iyi bir kürsü örneği oluşturmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun bir “**somut tehlike suçu**” (!) olduğunu kabul etmektedir.⁵² Bu anlayışa göre, bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde yapılan açıklamaların içeriği ne olursa olsun, kalabalığın herhangi bir fiili saldırı olmaksızın ve hatta, bir somut saldırı tehlikesi doğmaksızın dağılması halinde, propaganda suçu oluşmayacaktır.⁵³ Anayasa Mahkemesinin kararında, terör örgütünün “meşruiyeti” ve verdiği mücadelenin “ulviyeti” yönünde yapılan açıklamanın “*şiddete yol açma potansiyelinin*”⁵⁴ bulunmadığının hangi ölçütler dikkate alınarak belirleneceği hususu muğlak bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararları verirken, malum 2012 yılı itibarıyla başlatılan “demokratik açılım” veya namı diğer “çözüm süreci”nin oluşturduğu “müsamaha” ve “hoşgörü” ortamından

Anayasa Mahkemesinin bir başka kararında, kitap içeriğinin şiddeti teşvik edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yapılan değerlendirmede, “*yazarının kimliği*”nin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir: Anayasa Mahkemesi, **25.6.2014**, BB 2013/409 (Abdullah Öcalan), pn. 100, 101.

⁵⁰ Bkz. AİHM, Sürek/Türkiye Kararı, 8.7.1999.

⁵¹ Bkz. AİHM, Zana/Türkiye Kararı, 25.11.1997. Ayrıca bkz. ARSLAN, İfade Özgürlüğü, İlkeler ve Türkiye, sh.190 vd.

AİHM bazı kararlarında siyasilerle ve hükümetle ilgili eleştirilerde ifade özgürlüğünün alanının daha geniş olduğunu belirtmektedir: Bkz. AİHM, Şener/Türkiye Kararı, (BB no: 26680/95) 18.7.2000; AİHM, Ceylan/Türkiye Kararı, (BB no: 23556/94) 8.7.1999. Dikkat edilmelidir ki, burada açıklamada bulunan kişinin kimliği değil, eleştiriye maruz bırakılan kişinin kimliği dikkate alınmıştır. Bu yönü itibarıyla söz konusu içtihatlar doğrudur.

⁵² Anayasa Mahkemesi, 5.11.2020, BB 2015/15672, pn. 67; Anayasa Mahkemesi, **9.1.2020**, BB 2015/19280 (Baver Mızrak) (RG: 17 Mart 2020/31071), pn. 47; Anayasa Mahkemesi, **8.1.2020**, BB 2015/15088, pn. 52; Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 64, 80; Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2015/4916 (Meki Katar) (RG: 18 Aralık 2019/30982), pn.5 3; Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635, pn. 84; Anayasa Mahkemesi, **9.5.2019**, BB 2017/36722, pn. 47. Aynı yönde görüş için ayrıca bkz. TOPÇU, CHD, cilt X, sayı 28, Ağustos 2015, sh.117.

⁵³ Bkz. Yargıtay 16. CD, 17.7.2015, E. 2015/2742, K. 2015/2316.

⁵⁴ Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 80; Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635, pn. 127, b.

yararlanarak iyice palazlanan terör örgütünün bir başkaldırı hareketi gerçekleştirdiği, bu başkaldırının bastırılması sırasında terör örgütü mensuplarının haricinde, çok sayıda kamu görevlisi ve sivil insanın hayatını kaybettiği, yaralandığı, şehirlerin harabeye döndüğü, insanların göçe zorlandığı vakıaları⁵⁵ göz ardı edilmiştir. Aksine, Anayasa Mahkemesinin kararlarında, söz konusu “*süreçte şiddet ve terör olayları önemli ölçüde azalmış*” olduğu belirtilerek,⁵⁶ sonuçları itibarıyla yanıltıcı bir ifade kullanılmıştır.⁵⁷

Anayasa Mahkemesinin kararına konu teşkil eden olayda, konuşmacının konuşmasında kullandığı “*Kürdistan’da* (Abdullah Öcalan’ın) *onurlu evlatları*” ifadesiyle PKK’nin faaliyeti çerçevesinde terör eylemlerinde bulunan silahlı kişileri övdüğü kuşkudan uzaktır. Keza konuşmada, malum “*çözüm süreci*”nin, esasında “*masa*”dan önce verilen silahlı mücadelenin bir başarısı olduğu ifade edilmiştir. Konuşmacı bu süreçle, mücadelenin “*ölümlü kanlı bölümünün sonuna*” geldiğini ve fakat mücadelenin henüz sona ermediğini ve devam ettiğini ifade etmiştir. Konuşma içeriğinde, “*savaşmak*”, “*ölmek*”, “*öldürmek*” ifadelerinin kullanılmasından çekinilmemiştir. Anayasa Mahkemesinin kabullerinin⁵⁸ aksine, konuşmacı bütün bu anlatımlarıyla, açıkça ismini zikretmemiş olmakla birlikte, PKK terör örgütünün bir halkın bağımsızlık ve özgürlük savaşı verdiği kanaatini dile getirmiştir.⁵⁹

⁵⁵ 2015 yılının ortalarından itibaren girilen başkaldırı hareketleri dolayısıyla çıkan karşılıklı silahlı çatışmalar sırasında ölen, yaralanan ve bu çatışmalar dolayısıyla göç etmek zorunda kalan kişi sayılarına ilişkin bilgi için bkz. Anayasa Mahkemesi, **9.5.2019**, BB 2017/36722, pn. 10-13; Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635, pn. 9, 18.

⁵⁶ Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 69, 73.

⁵⁷ Aslında Anayasa Mahkemesi, malum “*çözüm süreci*”nde PKK’nin Devletin hukuk dışı müsamahasından yararlanarak “*bazı şehirlerde silah ve mühimmat yığmağı yap*”tığını kabul etmektedir: Anayasa Mahkemesi, **26.7.2019**, BB 2018/17635, pn. 9.

⁵⁸ Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2018/38143, pn. 75, 79, 81, 82.

⁵⁹ Anayasa Mahkemesinin, **26.7.2019** tarihli ve 2018/17635 bireysel başvuru sayılı kararına konu teşkil eden olayda, çeşitli kişiler tarafından imzalanan **11 Ocak 2016** tarihli bildiri metninde, Türkiye’de terörü sona erdirmeye yönelik olarak ve fakat, hukuki temeli olmayan yöntemlerle başlatılan malum “*çözüm süreci*”nin oluşturduğu ortamdan yararlanılarak başlatılan terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların eleştirisine yer verilmiştir. Bu eleştiriler kapsamında, güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili olarak “*kasıtlı ve planlı kıyım*” ve “*katliam*” gibi ibareler kullanılmıştır.

Bu eleştiriler kapsamında dile getiriler güvenlik görevlilerine ve dolayısıyla Devlete izafe edilen uygulamaların gerçeklikle bağdaşıp bağdaşmadığına bakılmaksızın; bunların salt eleştiri konusu yapılması ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez. Bu eleştiriler bağlamında kullanılan ifadeler mübalağalı da olsa ve hatta, “*kasıtlı ve planlı kıyım*” ve “*katliam*” gibi ibareler kullanılmış olsa bile, salt bu nedenle ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemez. Bu eleştiri-

ler çerçevesinde “*Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından*” söz edilirken, güvenlik görevlileri tarafından, yani Devlet eliyle gerçekleştirilen uygulamaların terör örgütüne, bu örgütün mensuplarına yönelik olmaktan ziyade, genel olarak “*Kürt halkı*”nı hedef aldığı izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ancak, **Anayasa Mahkemesinin söz konusu bireysel başvuru kararında değerlendirme dışı bırakılan 10 Mart 2016** tarihli açıklamada ise, 2015 yılı ortaları itibarıyla bazı illerimizde başlatılan yaygın terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesine yönelik olarak güvenlik görevlilerinin uygulamaları “*Kürt illerindeki savaş*” olarak nitelendirilmiştir.

Bu açıklamalarla, PKK terör örgütünün suç işlemek amacıyla kurulmuş ve faaliyet icra eden örgüt görüntüsünden ziyade, *bir halkın bağımsızlığı için mücadele veren örgüt* olduğu izlenimi oluşturulmak istendiği açıktır. Bu alanda önemli bir gerekçeyi, bu örgüte karşı askeri güç kullanılarak verilen mücadelenin oluşturduğunu belirtmek gerekir. PKK’ye karşı *kara ve hava birlikleri* tarafından *askeri silahlar* kullanılarak verilen mücadele, milletlerarası kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu örgütle “*savaş hali*”nde olduğu hususunda bir izlenim oluşturmaktadır.

Söz konusu **11 Ocak 2016** tarihli bildiri içeriğinde PKK terör örgütünün yaygın terör eylemlerini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen özellikle sokağa çıkma yasağı uygulamalarının hukuki dayanaktan yoksunluğuna ilişkin olarak yer verilen eleştirilerin doğruluğuna rağmen; **10 Mart 2016** tarihli açıklamalar, dolaylı da olsa, “*terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapma*” suçunu oluşturmaktadır.

Bu suretle, Türkiye’nin özellikle güneydoğu illerindeki yaygın terör eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin uygulamalarının **savaş hukukuna ilişkin 12.8.1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve bu Sözleşmelere ek 8.6.1977 tarihli Protokoller** hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin yolu açılmak istenmektedir.

PKK mensupları, Avrupa’da barınma ve propaganda zemini buldukları ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvencilik kuvvetlerinin özellikle güneydoğu bölgemizde ve bu bölgedeki sınır boylarında gerçekleştirdiği operasyonların, söz konusu Sözleşmeler hükümlerine göre, “*bir devletin hükümet kuvvetleri ile hükümete karşı gelen silahlı gruplar arasında silahlı çatışmalar*” olarak kabulü yönünde yoğun propaganda faaliyetinde bulunmaktadır.

Özellikle 8.6.1977 tarihli Protokoller, **egemen ülke içinde, egemenlik kazanmak için yürütülen çatışmalar bakımından da, uluslararası nitelikte olmamalarına rağmen, savaş hukukuna ilişkin kuralların işletilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.**

Güvenlik kuvvetleri tarafından PKK’ye karşı yürütülen operasyonların “*savaş*” olarak nitelendirilmesinin ve silahlı çatışma hukukuna tabi kılınmasının en önemli sonucu, bu çatışmalarda yakalanan PKK mensuplarının, söz konusu Sözleşmeler hükümlerine göre “*esir*”, “*tutsak*” muamelesine tabi tutulmasıdır. Bu itibarla, **PKK mensubu olup da işledikleri suçlar sebebiyle halen tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin statüsü ve bu kişilere uygulanacak olan hukuk değişmiş olacaktır.**

Keza, bu yöndeki kabul, PKK mensuplarının ellerinde **rehin** olarak tuttukları kamu görevlileri bakımından “*esir mübadelesine*” ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.

Anayasa Mahkemesinin bu ayrıntıların göz ardı edildiği söz konusu bireysel başvuru kararı, Türkiye’de de, PKK’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik güçlerine karşı operasyonlarının **savaş hukuku** çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki propaganda faaliyetlerinin önünü açmış olmaktadır.

Bu bağlamda özellikle üzerinde durulması gereken nokta, güvenlik güçlerinin PKK’ye karşı operasyonlarının “*savaş*” olarak nitelendirilmesidir. Eğer bir savaştan söz ediliyorsa, bunun “ *tarafları*”nın olması gerekir. Söz konusu operasyonları “*savaş*” olarak nitelendirme çabası

Anayasa Mahkemesinin bu kararlarını esas alacak olursak, faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçlardan bahsetmeksizin, bu suçlarla ilişki kurmaksızın, sadece güttüğü siyasi, sosyal ve ekonomik amaçlardan hareketle, PKK'nın “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda düşünce açıklamasının, suç oluşturmadağını kabul etmek gerekecektir!

Anayasa Mahkemesinin kabulüne göre; “terör veya terör örgütü ile bağlantılı olsa bile içinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan, terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açmayan, terör örgütünün ideolojisi, toplumsal veya siyasal hedefleri, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin görüşleri ile paralellik taşıyan düşünce açıklamaları terörizmin propagandası olarak kabul edilemez. Toplumsal ve siyasal ortama veya sosyoekonomik dengesizliklere, etnik sorunlara, ülke nüfusundaki farklılıklara, daha fazla özgürlük talebine veya ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin, ... devlet yetkilileri veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa bile, açıklanması, yayılması, aktif, sistemli ve inandırıcı bir şekilde başkalarına aşılınması, telkin ve tavsiye edilmesi ifade özgürlüğünün koruması altındadır.”⁶⁰

Terör örgütünün amaçlarıyla örtüşse bile, terörle ve terör örgütüyle ilişkilendirilmeksizin birtakım siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların gündeme getirilmesinin ve hatta bu sorunların terör örgütünü doğurduğunu, terör örgütünün bu sorunlardan güç aldığını, beslendiğini ve kendisine “meşruiyet” zemini oluşturmaya çalıştığını ifade etmenin suç oluşturmayacağı, izahtan varestedir. Ancak bu sorunlardan hareketle, terör örgütünün varlığının ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda dolaylı da olsa açıklamalarda bulunulması, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu oluşturacaktır.⁶¹

içinde olanlar, **PKK**'yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında “**taraf**” konumuna yükseltmektedirler ve **PKK**'nin nihai amacının “**meşru**” olduğunu kabul etmektedirler.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu değerlendirmelerimden, güvenlik güçlerinin terörle mücadele çerçevesinde icra ettikleri operasyonların hukuk zemininde icra edildiğini aleltilak kabul ettiğim sonucu asla çıkarılamaz (ÖZGENÇ, Suç Örgütleri, 13. bası, sh. 138 vd.).

Keza belirtmek gerekir ki, terör örgütü, “pazarlık” malzemesi ve “canlı kalkan” olarak kullanılmak üzere, kamu görevlilerini kaçıracak, REHİN olarak tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden otorite tarafından, çoğunluğu güvenlik görevlisi bu kişilerle ilgili olarak “esir” ibaresinin kullanılması, Devlette bir akıl tutulmasının yansımasıdır.

⁶⁰ Anayasa Mahkemesi, **9.5.2019**, BB 2017/36722, pn. 44. Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, **3.10.2019**, BB 2015/4916, pn. 54.

⁶¹ Bkz. AİHM, Polat/Türkiye Kararı, (BB no: 23500/94) 8.6.1999.

Anayasa Mahkemesinin kararlarında bu ayırım göz ardı edilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçu, somut tehlike suçu değil, **soyut tehlike suçudur**.⁶² Hatta, bu suçun temel şekli bakımından aleniyet bir unsur olarak da kabul edilmemiştir. Anayasa Mahkemesi terörizmin ve terör örgütünün propagandası fiilinin suç oluşturmaya, her somut olay bağlamında bu suç nedeniyle kişilerin cezalandırılması gerekliliğini birbirinden ayıramamıştır. Anayasa Mahkemesine göre, terörizmin ve terör örgütünün propagandası, somut tehlikeye sebebiyet vermemiş ise, **düşüncüyü açıklama özgürlüğü** çerçevesinde değerlendirilmelidir.⁶³ Terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun somut tehlike suçu mahiyeti taşıdığı kabul edilecek olursa, iki hususu araştırmak gerekecektir.

Bunlardan birincisi, bu açıklamanın yapılması üzerine terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren eylemleri gerçekleştirmesi veya gerçekleştirme tehlikesinin ortaya çıkması gerekir.

İkinci ve en önemli husus ise, propaganda mahiyetindeki açıklamalar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen cebir, şiddet veya tehdit içeren fiiller veya bu tür fiillerin gerçekleşmesine ilişkin somut tehlike arasında nedensellik bağının bulunması ve bu bağın varlığının ispatlanması gerekir. Zira, somut tehlike suçunun oluşabilmesi için, failin gerçekleştirdiği fiilin bir objektif cezalandırılabilme şartı olan bu tehlikenin oluşumuna sebebiyet vermesi gerekir.⁶⁴ Bunun uygulama bakımından ortaya çıkaracağı

⁶² Bkz. YILDIRIM, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, 2. bası, sh. 273, 281 vd., 293; YURT-LU, Gazi Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XX, sayı 3, sh.425; ÖZBEK, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, sh.138.

⁶³ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, 17. bası, Ankara, Eylül 2021, sh. 751 vd.

⁶⁴ Anayasa Mahkemesi, 15.2.2010 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında aşağıdaki içerikteki bildiri okuyan kişi hakkında terör örgütünün propagandası suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında beraat kararı yerine davanın ertelenmesine karar verilmesiyle **düşüncüyü açıklama hürriyetinin ihlal edildiğini** kabul etmiştir (4.6.2015, BB 2013/9343 [Mehmet Ali Aydın] [RG: 1 Temmuz 2015/29403]):

“... Kürt sorununun çözümünde göstermelik, anayasal güvenceden yoksun, kolektif hakları tanımayan girişimleri kaygıyla izlemekteyiz. Kürtleri ve demokratik kamuoyunu kandırmaya yönelik hükümet sözcülerinin “Öcalan’ın muhatap alınması mümkün değil!...” açıklamalarına yabancı değiliz. Benzer açıklamaları yapanlar şu an nelerde? Bugün; AKP’nin keçi inadına, anlamsız yaklaşımlarına yani, görmek istememesine karşı, **Sayın Öcalan Kürt sorunda aktif bir siyasal öznedir ve çözüm gücüne sahiptir**. İstedığınız kadar muhatap değildir, olamaz deyin, dediklerini beğenin yada beğenmeyin, bu bir Türkiye gerçeğidir. Ortadoğu’yu kirli emelleri

güçlük, izahtan varestedir. Anayasa Mahkemesinin bu kabulü karşısında, faaliyeti çerçevesinde cebir, şiddet veya tehdit içeren suçların sıklıkla ve

doğrultusunda şekillendirmek isteyen uluslararası ve bölge güçleri **Kürtlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini** kendilerine engel gördükleri için 9 Ekim 1998 yılında **Sayın Abdullah Öcalan** 'a yönelik bir komplo tezgahladılar. Özünde Kürt halkına genelde Ortadoğu halklarına özgürlük istemlerine yönelik bu komplo halkları birbirine düşürüp iktidarlarını pekiştirme amaçlıydı. Mevcut egemen sistem kaos yaratıp, ortaya çıkan durumdan vazife çıkarıp, kurtarıcı rolünde çözüm adına çözümsüzlüğü geliştirmek, uygulana gelen klasik bir senaryodur. Ortadoğu'daki mevcut sistemin devam etmesi için, **halkların boğazlaşması oyunu** gerekiyordu! Bu doğrultuda **Sayın Öcalan** 'ı Türkiye'ye teslim ederek hedeflerine ulaşmak istediler. Ancak **Sayın Öcalan** 'ın geliştirmiş olduğu barışçıl çözüm önerileri ile bu süreç engellendi. Bütün olumsuz zindan yaşam koşullarına, geliştirilen komplolara rağmen, o günden bugüne **barış arayışı ve çabası** her zamankinden daha güçlü devam etmektedir. Bu sürecin 11 yılını geride bırakırken, 12. yıla girmiş bulunmaktayız. Baskı cenderesi olarak tanımladığımız İmralı Cezaevi sistemi; hukuk dışı bir Guantanamo cezaevidir hemen kapatılmalı, **Sayın Abdullah Öcalan** hemen serbest bırakılmalıdır. **Sayın Öcalan** 'ın avukatları aracılığıyla yaptığı cezaevi koşullarını içeren açıklamaları "Bir ölüm çukuruna atılmış gibiyim!...", "Solunum cihazına bağlanmış bir hasta gibiyim!.." sözlerini hatırlamayan yoktur. Yaşanan bu son durumun, toplumsal barışı ciddi bir biçimde tehdit ettiğini, büyük gerilimlerini sorumlu herkesin görmesi gerekir. İmralı, sıradan bir cezaevi. **Sayın Öcalan** da herhangi bir tutsak değildir. **Öcalan** 'ın sağlık koşulları, yaşamı ve güvenliği Türkiye'deki gelişmeleri derinden etkileyecek düzeyde kilit bir öneme sahiptir. Bu realitenin görülmesi ve buna göre hareket edilmesi, içinden geçmekte olduğumuz hassas sürecin en stratejik noktasını oluşturmaktadır. **Sayın Öcalan**, Türkiye'de tıkanmış olan siyasal sürecin önünün açılması için **barış gruplarının** gelişini ikinci kez önerdi. Habur sınır kapısında cenazeleri alan halkın **barış gruplarının** gelişine ilk defa çocuklarını kucaklaması, barışa sarılması ortaya koymuştur, bu yüzbinler, **çözümün muhatabının** bir kez daha **İmralı** olarak göstermiştir. Diğer yandan **barış gruplarının** gelişini hükümet çözüm olarak değerlendiremediği gibi asıl niyetinin tasfiye olduğunun açığa çıkması üzerine silbaştan açılımla ilgisi olmayan bir teslim olma sürecine girmiştir. Hükümetin Kürt açılımı sürecinde Kürtler devre dışı bırakılmak istenmektedir. **Üç buçuk milyon Kürdün irade olarak kabul ettiği Sayın Öcalan** 'ın koşullarının ağırlaştırılması, DTP'nin kapatılması, siyasi yasakların getirilmesi, operasyonlarla demokratik siyasetin tüm yollarının Kürtlere kapatılmak istenmesi düşündürücüdür, kabul edilmezdir. ...**Barış gruplarının** çözüm için getirdiği mektuplar neden muhataplarına verilmiyor? Kamuoyuna açıklanmıyor, başbakanın bunu açıklaması gerekir. Hedef açılım değil tasfiyedir. Seçimlere kadar AKP kendi yarattığı Kürtlerle sonuç almak istiyor. AKP hükümeti samimi değildir. Diğer hükümetler gibi inkâr ve imhaya dayalı cumhuriyet politikası deşifre olmuştur. Bu açılım geleneksel devlet politikalarını ifade ediyor. Bu açılımın, sorunu çözemeyeceği açıktır. **Sayın Öcalan** 'ın **yol haritasının** açıklanması, muhataplarına verilmesi her geçen süre daha da önem arz etmektedir. Çözüm için bunun Türkiye demokrasisine, halklarına önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Devlet aralıksız sürdürdüğü askeri operasyonları durdurmalı, seçilmişlere yönelik operasyonlar durdurulmalı. Türkiye'nin demokratikleşme zemininde **Kürt halkının özgür iradesi esas alınarak müzakere başlamalı**, Demokratik sivil bir anayasanın hazırlanması elzemdir. Sorunu cesaretle tartışarsak çözüme kavuşabiliriz. Eşit, özgür, huzurlu bir yaşam için Türkiye'nin kendi barışını getireceğine dair inancımız tamdır. **Sayın Öcalan**, 6 m2'lik alanda 11 yıl yılmadan barışın tesisi için çalıştı. **Sayın Öcalan** 'ın dikkate alınmadığı, onun yok sayıldığı, diyalog kanallarının kapatıldığı bir süreç, Kürt sorununun çözümüne hizmet etmez, aksine çözümsüzlüğü derinleştirir. Tecride ve yok etmeye dayalı Amerika Guantamosundan da geri İmralı sistemi halen ortadayken ve bu sistem daha da ağırlaştırılırken çözümün olması beklenemez. ...**Sayın Öcalan** 'ın **özgürlüğüne kavuşturulmasını** kamuoyundan talep ederken, bu konuda Türkiye'de yaşayan tüm demokrat insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz."

yaygın bir şekilde işlendiği, işlenmekte olduğu bir terör örgütünün propagandasının yapılması halinde, nasıl bir yol izleneceği konusu muğlak kalmaktadır. Zira, bu durumda, somut tehlike esasen mevcuttur ve failin propaganda mahiyeti taşıyan açıklamaları ile bu somut tehlikenin ortaya çıkışı arasında bir irtibat bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarında terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuyla ilgili olarak yapılan bu değerlendirmeler, ceza hukuku bilgisinden uzaktır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin de vermiş bulunduğu çeşitli kararlarda, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun oluşup oluşmadığının tespiti bağlamında yapılan değerlendirmede, açıklamada bulunan kişinin **kimliğinin** göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir. Keza, Dairenin kabulüne göre, yapılan açıklamanın “**açık ve yakın tehlike**” oluşturup oluşturmadığının araştırılması gerekmektedir.⁶⁵ Toplantı ve gösteri yürüyüşüne

⁶⁵ “Toplantı veya gösteri yürüyüşünde olsun veya olmasın; yazı veya sözler (atılan slogan, taşınan pankart veya giyilen üniforma) ile verilen mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olup olmadığı değerlendirilmeli, doğrudan veya dolaylı şiddete çağrı var ise sanığın kimliği, konumu, konuşulan yer ve zaman gibi açık ve yakın tehlike testi bakımından analize tabi tutulmalıdır.”: Yargıtay 16. CD, **7.12.2020**, E. 2020/6503, K. 2020/6027; Yargıtay 16. CD, **7.12.2020**, E. 2018/2814, K. 2020/6093; Yargıtay 16. CD, **30.3.2017**, E. 2015/6665, K. 2017/3586; Yargıtay 16. CD, **15.6.2017**, E. 2017/1334, K. 2017/4470; Yargıtay 16. CD, **7.3.2017**, E. 2016/1238, K. 2017/3434; Yargıtay 16. CD, **23.2.2017**, E. 2016/6853, K. 2017/1107; Yargıtay 16. CD, **19.12.2016**, E. 2016/3839, K. 2016/7571; Yargıtay 16. CD, **2.11.2016**, E. 2016/4798, K. 2016/5836; Yargıtay 16. CD, **29.9.2016**, E. 2016/1297, K. 2016/4872; Yargıtay 16. CD, **9.6.2016**, E. 2015/8605, K. 2016/3876; Yargıtay 16. CD, **19.4.2016**, E. 2016/437, K. 2016/2536; Yargıtay 16. CD, **23.2.2016**, E. 2015/8223, K. 2016/1218; Yargıtay 16. CD, **9.2.2016**, E. 2015/7842, K. 2016/945.

“somut olay değerlendirildiğinde “geliyor geliyor apocular geliyor” şeklinde attıkları sloganın ulusal güvenlik ve kamu düzeni üzerindeki potansiyel etkisinin sınırlı olduğu, ciddi bir tehlike yaratmadığı, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığı” sonucuna varılmıştır: Yargıtay 16. CD, 31.5.2017, E. 2017/1383, K. 2017/4393.

Ancak Daire benimsediği bu ölçüte rağmen, bir milletvekili adayının “seçim konvoyunda bulunan ve “**bişi serok apo**” (yaşasın önder apo), “**bi can bi hun emtereye ey serok**” (canımızla kanımızla sizinle ey başkan) şeklinde slogan atan” kişi hakkında terör örgütünün propagandası suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir: Yargıtay 16. CD, **8.11.2016**, E. 2016/1627, K. 2016/5889.

Keza, aynı Daire, “siyah spreylere boya ile (apartman) garaj kapısına “PKK” yazılarını yazma şeklindeki silahlı terör örgütünü öven maddi nitelikteki hareketlerin.. silahlı **terör örgütüne yardım** suçunu” oluşturduğunu kabul etmiştir: Yargıtay 16. CD, **27.2.2017**, E. 2016/6095, K. 2017/1063.

katılanların “*olaysız*” bir şekilde dağılmış olması, atılan sloganların ve taşınan pankart içeriklerinin somut tehlike oluşturmadığının dayanağı olarak gösterilmiştir.⁶⁶

5) Hukuk sistemimiz bakımından sorun, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun örgüt üyesi olan ve olmayan kişi tarafından işlenmesi arasında bir ayırım yapıp yapılmaması, bir ayırım yapılacaksa bunun ceza hukuku sorumluluğuna etkisidir.

Propaganda fiilinin ayrıca suç olarak tanımlanmadığı hukuk sistemlerinde, bu tür fiiller dolayısıyla, terör örgütüne yardım, terör örgütünü destekleme dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğunu cihetine gidilmektedir.⁶⁷

Yardım fiilinden ayrı bir suç olarak terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun tanımlandığı hukuk sistemlerinde, propaganda fiili terör örgütüne yardım mahiyeti taşımasına rağmen, **genel norm-özel norm ilişkisi**⁶⁸ çerçevesinde, özel normun uygulanması yoluna gitmek, terör örgütü üyesi değilse kişiyi terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçundan dolayı cezalandırmak gerekmektedir. Buna karşılık, terörizmin ve terör örgütünün propagandası fiilini işleyen kişi aynı zamanda terör örgütü üyesi ise, ceza hukuku sorumluluğunu belirleme bakımından bir sorunla karşı karşıya kalınmaktadır.

Terörle Mücadele Kanununun 2006 yılında 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemesine istinaden, terör örgütünün propagandası suçunun örgütün üyesi olan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, gerçek işitima hükümlerine göre, hem terör örgütü üyesi olmaktan hem de terör ör-

⁶⁶ Yargıtay 16. CD, **30.3.2017**, E. 2015/6665, K. 2017/3586; Yargıtay 16. CD, **29.5.2017**, E. 2017/1255, K. 2017/4604, Yargıtay 16. CD, **11.7.2017**, E. 2017/1384, K. 2017/4709; Yargıtay 16. CD, **11.9.2017**, E. 2017/1688, K. 2017/4856; Yargıtay 16. CD, **9.11.2017**, E. 2017/2046, K. 2017/5275; Yargıtay 16. CD, **20.11.2017**, E. 2017/2131, K. 2017/5379; Yargıtay 16. CD, **23.2.2016**, E. 2015/8223, K. 2016/1218.

Ancak, Dairenin bir kararında, aynı içerikte sloganların atıldığı bir toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında karşıt görüşteki kişilerle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlar arasında taşlı sopalı çatışma çıkması durumunda terör örgütünün propagandası suçu bakımından nasıl bir yol izleneceği konusu muğlak bırakılmıştır: Yargıtay 16. CD, **20.9.2017**, E. 2017/1874, K. 2017/4913.

⁶⁷ İtalyan hukukuna ilişkin açıklamalar için bkz. **Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu**, **25.03.2019**, sh. 63 vd. Amerika Birleşik Devletleri hukukuna ilişkin açıklamalar için bkz. aynı eser, sh. 52 vd.

⁶⁸ ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. bası, sh. 110.

gütünün propagandası suçunu işlemekten dolayı ayrı ayrı cezalandırılma yoluna gidilmekteydi.⁶⁹

Oysa, yukarıda belirtildiği gibi, terörizmin ve terör örgütünün propagandası fiili, esasında örgüte **maddi olmayan yardım** mahiyeti taşıdığı için, TCK'nın örgüte yardım edenin örgüt üyesi olarak cezalandırılması gerektiği yönündeki düzenlemesi (m. 220, f. 7) karşısında; **terör örgütü üyesi olan kişinin, bu suçtan dolayı cezalandırılmasının yanı sıra, ayrıca örgüt propagandası suçundan dolayı mahkûmiyeti yoluna gidilmemelidir.** Başka bir ifadeyle, **terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçundan dolayı mahkûmiyet için, kişinin örgüt üyesi olmaması gerekir.**⁷⁰ Örgüt üyesinin terörizmin ve terör örgütünün propagandası mahiyeti taşıyan fiilleri işlemiş olması, örgüt üyeliğinden dolayı verilecek cezanın belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir husustur.^{71, 72, 73}

⁶⁹ Zira, 3713 s. Kanun, m. 7, f. 2'nin 2006 yılında 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki metnine göre, terör örgütünün propagandasını yapanların, "**fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca**" bu fıkra hükmüne istinaden cezalandırılması gerekmekte idi.

⁷⁰ ÖZGENÇ, Suç Örgütleri, 13. bası, sh. 123; TAŞTAN, CHD, cilt III, sayı 6, Nisan 2008, sh.105. Aksi yönde fikir için bkz TOPÇU, CHD, cilt X, sayı 28, Ağustos 2015, sh.114; YILDIRIM, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, 2. bası, sh. 345; YURTLU, Gazi Ü.HFD, cilt XX, sayı 3, sh. 422; ÖZBEK, Terör Örgütünün Propagandası Suçu, sh. 169 vd. Suç Örgütleri kitabımızın eski basılarında, aynı yöndeki düşünceyi benimsemiştik. Ancak, bilahare bu düşüncemizin değişmesine rağmen, 13. bası, sh. 51, dn. 86'daki görüş değiştirilmeden kitapta kalmıştır.

⁷¹ Ancak belirtmek gerekir ki, örgüt üyesinin terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunu işlemesi halinde, hem üye olmaktan dolayı hem de propaganda suçundan dolayı cezaya hükmedilmesi yönündeki gerçek içtima uygulamasına devam edilmektedir. Bkz. Yargıtay 16. CD, **17.5.2018**, E. 2018/440, K. 2018/1836; Yargıtay 16. CD, **21.1.2019**, E. 2018/873, K. 2019/286; Yargıtay 16. CD, **11.4.2019**, E. 2018/3355, K. 2019/3523; Yargıtay 16. CD, **6.10.2020**, E. 2019/9328, K. 2020/4786

Buna karşılık Yargıtay bazı kararlarında terör örgütü propagandası niteliğindeki eylemleri terör örgütüne üye olma suçunun delili olarak kabul etmektedir: Yargıtay 16. CD, **12.11.2020**, E. 2020/4592, K. 2020/5505; Yargıtay 16. CD, **20.10.2020**, E. 2020/1484, K. 2020/5143. Bu son kararda, sanığın sosyal medyada yaptığı paylaşımların "**örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmaması, paylaşımların gerçekleştirildiği tarih, sanığın muhatap kitle üzerindeki etkisi, iddianame tarihi sonrası sanığın dosya içerisine yansıyan herhangi bir eyleminin olmaması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın propaganda suçuna konu edilen eylemlerinin örgüt üyeliği suçunun sübutuna esas teşkil eden süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetler kapsamında kalan eylemler olduğu anlaşılmakla sanık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi**" gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. İfade edelim ki, söz konusu olayda terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığının kabul edilmesi karşısında, bu suçtan dolayı "ceza verilmesine yer olmadığı" kararının verilmesi gerektiğinden bahsedilmesi, CMK'nın 223.maddesinde yer alan düzenleme ile açıkça çelişmektedir.

6) Terör örgütünün propagandasına dönüşen bir toplantı ve gösteri yürüyüşü bakımından ilk yapılması gereken, toplanan kalabalığın behemehal dağıtılması ve pankart gibi suç delili olabilecek nesnelere elkonulmasıdır.

Oysa, inceleme konusu yapmış bulunduğumuz Ceza Genel Kurulu kararlarına konu teşkil eden olaylarda kolluk görevlileri terör örgütünün propaganda-

⁷² Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **28.1.2019** tarihli ve E. 2018/4803, K. 2019/647 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; 24.6.2018 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili seçilen X, sosyal medya hesabından 20.1.2018 tarihinde yaptığı açıklamalarda, “*her yer Efrin her yer Direniş, Afrin yalnız değil*” yazılı fotoğrafı paylaşarak, altına “*yezit kavminin hükmü sürsün diye Kürt ve Türk gençleri ölecek anaların yüreği acıyla inliyecek, çocuklar aç kalacak sivil insanlar can verecek*”, “*yezit kavmi tecavüze devam ediyor, yüz elli çocuk hamile tarih böyle ahlaksızlık böyle kepezelik böyle rezalete tanık olmadı. Ahlaksızlığın her türlüsünü pervasızca yapıp yezit soylu din tüccarının fetvalarıyla kokuşmuş zihniyetlerini paklamaya çalışan yezit kavmi insanlığa karşı suç işliyor*” şeklinde ifadeler kullanır.

Bu açıklamaları dolayısıyla X hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 9.4.2018 tarihli iddianame ile,

- halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek,
- terör örgütünün propagandasını yapmak,

suçlarından dolayı TCK, m. 216, f. 1; 3713 s. TMK, m. 7, f. 2 hükümlerine istinaden cezalandırılması talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Mahkeme, X’e isnat edilen fiilin terör örgütünün propagandası suçunu değil, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinden hareketle, bilahare milletvekili seçilen X’in yasama dokunulmazlığından yararlandığını kabul ederek durma kararı vermiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütünün propagandası suçuna nazaran, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunun Anayasanın 14. maddesi kapsamına girmediği, bu nedenle X’in yasama dokunulmazlığı hükümlerinden yararlanması gerektiği, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin açılan davada vermiş bulunduğu durma kararının hukuka uygun olduğu yönünde içtihatla bulunmuştur.

Aynı şekilde Daire, pek çok kararında, terör örgütünün propagandası suçunun Anayasanın 14. maddesi kapsamına girdiğini kabul ederek, münnet fiilin bu suçu oluşturduğu iddiasıyla açılan davalarda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılamaya devam edilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur: Yargıtay 16. CD, **19.6.2020**, E. 2020/2705, K. 2020/3678; Yargıtay 16. CD, **17.1.2020**, E. 2019/11436, K. 2020/506; Yargıtay 16. CD, **25.10.2019**, E. 2019/5361, K. 2019/6434.

Keza, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin diğer bir kararına göre, “*milletvekili seçilmeden önce işlenen silahlı terör örgütünün propagandası suçu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. maddesinde işaret edilen ve 14/2. maddesinde gösterilen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması niteliğinde olduğu kabul edildiğinden yasama dokunulmazlığı kapsamında sayılmayacaktır. Eylemin TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu olarak nitelendirilmesi halinde yasama dokunulmazlığından yararlanacaktır.*”: Yargıtay 16. CD, **1.11.2019**, E. 2019/5366, K. 2019/6796.

Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. bası, sh. 736 vd.

⁷³ Terör örgütünün propagandası suçundan farklı olarak, terör örgütüne üyelik, bünyesindeki hiyerarşik ilişkiye dahil olarak örgütün desteklenmesini ifade etmektedir: BGH, Urteil vom 14.8.2009, 3 StR 552/08, kn. 13.

sına dönüşen bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahale etmemişlerdir. Kalabalıklar kendiliğinden dağılmıştır. Malum “demokratik açılım süreci”nde, namı diğer “çözüm süreci”nde terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak kolluğun yaptığı şey, toplantı ve gösteri yürüyüşünün icrasını sesli ve görüntülü olarak kayda almak olmuştur.

Bilahare, malum süreçte izlenen yöntemin yanlışlığının anlaşılması ve buna bağlı olarak siyasi atmosferin değişmesi üzerine, bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan kişilerden sadece bir veya birkaçı hakkında terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar başlatılmış ve mahkûmiyet hükümleri kurulmuştur.⁷⁴

⁷⁴ Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **25.1.2018** tarihli ve E. 2017/2948, K. 2018/162 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; yüzleri kapalı vaziyette kişilerden oluşan 20-25 kişilik grup, araç trafiğine açık cadde üzerinde lastik yakarak caddeyi araç trafiğine kapatır; olay yerine gelen güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunur. Kolluk görevlilerinin takibi sonucunda bu grup içinde yer alan sadece bir kişi, henüz **on üç yaşını tamamlamamış çocuk** Ç yakalanır.

İlk Derece Mahkemesi, Ç’nin,

- Terör örgütüne üye olmak (TCK, m. 314, f. 2),

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet (2911 s. Kanun, m. 32, f. 1; m. 33, f. 1, bent a),

- Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak (TCK, m. 179, f. 1),

- Görevi yaptırmamak için kamu görevlisine karşı direnme (TCK, m. 265),

suçlarını işlediğini kabul ederek, hakkında bu suçlardan dolayı mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, olayı sübut yönünden ele alarak, Ç hakkında kurulan bu mahkûmiyet hükümlerinin bozulmasına karar vermiştir (Ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, **10.12.2019**, E. 2019/7315, K. 2019/8218; Yargıtay 16. CD, **9.7.2019**, E. 2019/3056, K. 2019/4913; Yargıtay 16. CD, **3.4.2018**, E. 2017/2692, K. 2018/1117; Yargıtay 16. CD, **28.3.2017**, E. 2016/6696, K. 2017/4564; Yargıtay 16. CD, **14.11.2016**, E. 2016/5472, K. 2016/5655).

Aslında bu olay bakımından sorun, bir sübut sorunu değildir. Bu olayda, **on üç yaşında olan çocuk** Ç’nin içinde yaşadığı toplum kesiminin sosyal, siyasi ve ekonomik koşullarının, kitle psikolojisinin etkisiyle bu fiilleri işlemeye sevk edilmiş olduğu ve bu durumdaki çocuğun işlediği suçlar bakımından davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinin mevcudiyetinden söz edilemeyeceği gerçeği göz ardı edilmiştir.

Hatta bazı durumlarda çocuğun, katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünün hukuka aykırı olduğu, bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında taşıdığı pankartın, atılmasına iştirak ettiği sloganların içeriğinin suç oluşturduğu hususlarında bilinçten de yoksun olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Karara konu teşkil eden olay bakımından sorun, TCK, m. 31, f. 2 hükmünün yanlış uygulanmasından ibarettir.

Bu tür yanlış uygulamalar, terör örgütünün insan devşirmesine hizmet etmekten, henüz orta öğrenim çağının başında olan çocukların terör örgütünün kucağına itilmesini sağlamaktan ve

Sonuç:

Terörizmin, barış esasına dayalı toplumsal düzen, hukuk toplumu bakımından arz ettiği tehlikelilik dolayısıyla, **terör örgütünün propagandası** suçu, kanunlarda **soyut tehlike suçu** olarak tanımlanmıştır. Terör örgütünün propagandası fiili suç olarak tanımlanırken, muhatap alınan kişi sayısı, muhatap alınan kişilerin belirli veya belirsiz olması, muhataplar üzerinde etki meydana getirip getirmediği, alenen yapıp yapılmaması, etki alanı ve etkinliği gibi hususlar göz önünde bulundurulmaksızın, terör örgütünün varlığının ve faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda ikna çabasında bulunmak, alelittlak cezalandırmayı gerekli kılan bir fiil olarak değerlendirilmiştir (Strafwürdigkeit).

Buna karşılık, örneğin ahır duvarına “yaşasın PKK” sloganının yazılması halinde, **gerçekleşen haksızlığın failin cezalandırılması yoluna gidecek ağırlıkta olmadığı** değerlendirilerek, faile ceza vermeme yoluna gidilebilmelidir. Başka bir ifadeyle, somut olayda muhatap alınan kişilerin sayısının çok sınırlı olması, propaganda fiilinin etkinliğinin zayıflığı faile verilecek olan ceza miktarının belirlenmesi bakımından ve hatta, failin cezalandırılıp cezalandırılmaması bakımından göz önünde bulundurulmalıdır (Strafbedürftigkeit).⁷⁵

Bu teorik düşüncelere dayalı olarak TCK’da, örneğin hırsızlık suçunda, suçun konusunun değerinin azlığı halinde, gerçekleşen haksızlık içeriği göz önünde bulundurularak faile bu suçtan dolayı verilecek olan cezanın miktarında indirim yapmak ve hatta hiç ceza vermemek yönünde hakime takdir yetkisi verilmiştir (m. 145). Dikkat edilmelidir ki, **gerçekleşen haksızlığın failin cezalandırılması yoluna gidecek ağırlıkta olup olmadığını** her so-

geleceklerinin karartılmasından başka bir sonuç ortaya çıkarmaz. Unutmamak gerekir ki, terör örgütlerinin en belirgin özelliği, özellikle orta öğrenim çağındaki çocukları **istismardır**.

Bir şehir merkezinde cereyan eden ve 20-25 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu olayda sadece bir kişinin, on üç yaşındaki bir çocuğun yakalanabilmiş olması, ayrıca dikkati çeken bir durumdur.

Bkz. <https://izzetozgenc.com/data/contents/cocuk-hakkinda-verilen-terror-orgutune-uye-olmak-veya-terror-orgutunun-propagandasi-sucundan-mahkumiyet-hukmu-ile-ilgili-olarak-yargitay-16-ceza-dairesinin-bir-karari-uzerine-degerlendirmeler.pdf> (Yayına giriş tarihi: 13.1.2021; Erişim tarihi: 18.10.2022).

⁷⁵ Ancak belirtmek gerekir ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, içeriği esasında propaganda mahiyeti taşıyan yayının etki alanı sınırlı olduğu için, propaganda suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulmasıyla *ifade özgürlüğünün ihlal edildiği* yönünde içtihatlarla bulunmuştur: AİHM, Karataş/Türkiye Kararı, 8.7.1999; AİHM, Okçuoğlu/Türkiye Kararı, 8.7.1999; AİHM, Erdoğan ve İnce/Türkiye Kararı, (BB no: 25067/94; 25068/94) 8.7.1999.

mut olayın koşullarına göre belirlemek gerekir. Örneğin bir değneğin çalınması halinde de, hırsızlık suçu işlenmiş olur. Ancak değneğin değerinin azlığı dikkate alınarak, **gerçekleşen haksızlığın failin cezalandırılması yoluna gidecek ağırlıkta olmadığı** değerlendirmesi yapılabilir. Buna karşılık, değneğin çalınmasıyla yaşlı bir insanın yürümekte ihtiyaç duyduğu dayanaktan yoksun bırakılmış ise, bu değerlendirmeyi yapmaktan sarfinazar ederek, hırsızlık suçundan dolayı cezalandırma yoluna gitmek gerekir.

Kanunda bir hüküm bulunmamakla birlikte, aynı değerlendirmenin mala zarar verme suçu bakımından da yapılabilmesi gerekir. Dikkat edilmelidir ki, ceza hukukundaki kıyas yasağı bu değerlendirmenin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Terör örgütünün propagandası suçunda da, örgütün varlığının ve faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusundaki ikna çabasının ifade ettiği haksızlığın failin cezalandırılması yoluna gidecek ağırlıkta olmadığı durumlarda cezalandırmaktan sarfinazar edilebilmelidir.⁷⁶

Bu gibi durumlarda Cumhuriyet savcısına kamu davasını açmakta takdir yetkisi tanınarak, **kovuşturmaya yer olmadığı kararı** verilebilmesinin yolunu açmak gerekir.

Görülmekte olan davalarda ise, işlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine, terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmaya rağmen, haksızlık içeriğini cezalandırmayı gerektirecek ağırlıkta görmediği takdirde, mahkemenin CMK, m. 223, f. 4, bent d hükmüne istinaden sanık hakkında **ceza verilmesine yer olmadığı kararı** vermesi gerekmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki, terör örgütünün propagandası mahiyetindeki bir fiil, hiçbir zaman düşüncüyü açıklama hürriyetinin kullanılması bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.⁷⁷

Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinde 2013 yılında 6459 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle terör örgütünün propagandası suçunun uygulama alanının daraltılmak istendiği ve daraltıldığı muhakkaktır. Ancak, bu düzenlemeyle terör örgütünün propagandası suçu **somut tehlike suçuna dönüştü-**

⁷⁶ Bu itibarla örneğin apartmanın garaj kapısına, bahçe duvarına “PKK” veya “yaşasın PKK” şeklinde yazı yazılması halinde terör örgütüne yardım etmekten dolayı mahkûmiyet hükmü kurulması yönündeki Yargıtay uygulamamız, sorunludur.

⁷⁷ Ancak belirtmek gerekir ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları aksi yöndedir: AİHM, Gerger/Türkiye Kararı, 8.7.1999.

rülmemiştir. Doğru bulmadığımız bu değişikliğe göre, faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçlardan bahsetmeksizin terör örgütünün Türkiye’deki belirli hukuki, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların çözümünü arayışlarında Devletin muhatap alması gereken bir “siyasi süje” olduğu yönündeki açıklamalar artık suç oluşturmamaktadır.⁷⁸ Keza, terör örgütünün

⁷⁸ Önemle belirtmek gerekir ki, PKK terörüyle mücadeledeki hukuksuzluklardan, “Devlet eliyle, **hukuk** hiçe sayılarak yapılan katliamlar(dan), işlenen **faili meçhul** cinayetler”den bahsedilmesinin (örneğin CEMAL, Hasan: *Gare katliamı... PKK’yı suçluyorum, kanıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum*, in: T24.com.tr, 20 Şubat 2021), ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren bir yönü bulunmamaktadır.

Keza, Devlet eliyle maruz kalınan haksızlıkların, gözaltında, tutuklu veya hükümlü iken görülen işkence ve kötü muamelelerin, kişilerin “dağa çıkma” sebebini oluşturduğu yönündeki açıklamalar (örneğin CEMAL, Hasan: *İşkence... “Genç olsam dağa çıkardım!”*, in: T24.com.tr, 23 Şubat 2021), ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez.

Ancak, gazetecilerin terör örgütünün yöneticisi veya mensubu bulunan kişilerle yaptıkları röportaj içeriklerinin yayımlanmasının suç oluşturup oluşturmadığı üzerinde durmak gerekir (Bu konuda bkz. Yargıtay CGK, 20.9.1993, E. 1993/9-157, K. 1993/190). Bu röportajlara ilişkin yayın içeriklerinde, örgütün faaliyetlerinin “meşru” olduğu ve örgüt mensuplarının “meşru” bir iş yaptıkları izlenimi oluşturan ifadelerle yer verilmesi, propaganda suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Bu yayın içeriklerinde örgüt yöneticisi veya sair mensubu kişilerin kişisel özelliklerinden bahsedilirken, icra ettikleri faaliyetin “meşru” ve kendilerinin “saygın” kişiler olduğu yönünde bir izlenim oluşturmaya yönelik ifadelerden kaçınılması gerekmektedir (örneğin BİRAND, Mehmet Ali: *İşte Apo, işte PKK*, in: Milliyet, 14-15-16 Haziran 1988; BİRAND, Mehmet Ali: *APO ve PKK*, 6. bası, İstanbul 1992). Aksi takdirde, propaganda suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

Cemal’in, Abdullah Öcalan’la 1993 yılında yapmış bulunduğu röportaja ilişkin yayın içeriği, bu esaslar çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır: CEMAL, Hasan: *1993 Nisan ayı, Bekaa’da Apo’yla sohbet: “Silahlı mücadeleyle her iki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamaz”, Apo ekliyor: “Gelin şiddeti durduralım, siyasal çözüm yollarını devreye sokalım”*, in: T24.com.tr, 25 Şubat 2021 (Erişim tarihi: 25.02.2021).

Söz konusu makalede, terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı “**silahlı mücadele**” veren “**taraf**” sıfatı izafe edilmiştir. Röportaj mahiyetindeki makalede, PKK terör örgütünün Türkiye’de “**meşru**” (“**legal**”) bir siyasi yapı olarak tanınması isteği, Abdullah Öcalan’a izafe edilen bir ifadeyle dile getirilmiştir.

Keza, Röportajda, PKK’nin katkısı olmaksızın Kürt sorununun çözümünün “zor” olduğu fikri, Abdullah Öcalan’ın ağzından ifade edilmiştir.

Her ne kadar Abdullah Öcalan hakkında terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü verilmemiş ise de, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçunu işlediği kabul edilerek 765 sayılı TCK, m. 125 hükmüne istinaden mahkûm edilmiş bir hükümlüdür. Söz konusu röportajın yayımlandığı sırada adı geçen kişi hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunsaydı bile, röportaj içeriğinde örgütün yöneticisi olarak düşünceleri kamuya paylaşılmıştır.

Röportaj içeriğinde, Abdullah Öcalan’ın, toplumun Kürt kökenli kesiminin teveccühünü kazanmış, “küçük bir çocuğu bile” etkileyebilen “ikna” gücüne sahip, “peygamberane” kişiliğinden bahsedilmektedir.

Her ne kadar, 1993 yılında yapılmış bir röportaj ise de, 2021 yılının şubat ayında yayın konusu yapılan metinde, “**Dağların PKK denetiminde olduğunu**”, “**PKK’ya günlük mili-**

tan katılımının 50 civarında olduğunu, bunun kısa sürede 100'e çıkabileceğini” belirten Abdullah Öcalan’ın, “Operasyon yapmak için Kuzey Irak’a falan ihtiyacımız kalmadı. İçerdeyiz artık. Dağda 10 bin militan dolaşıyor. Kuzey Irak’taki kamplar bizim için dinlenme yerleri...” şeklindeki ifadeleri aktarıldıktan sonra, “Siyaseti Hakkârili çobanın gündemine soktum” diye övündüğünden bahsedilmektedir.

Röportajda Abdullah Öcalan’a izafeten “*ister silahla ister başka türlü barışı zorlayacağım*” ifadesi kullanılmıştır.

Röportajda, Devletin terörle mücadelesi, uluslararası savaş hukukunun uygulanması gereken bir “*silahlı çatışma*” olarak nitelendirilerek, Abdullah Öcalan’a izafeten “*savaş*”tan ve PKK’nin “*ateskes*” ilanından söz edilmiştir.

Bütün bu ifadelerin yanı sıra, Abdullah Öcalan’dan, “*Türkiye’nin başına tarihinin en kanlı terör ve şiddet belasını sarmış olan bir insan*” olarak bahsedilmiştir.

Röportajda, Abdullah Öcalan’a izafeten,

“*Sivillere mesajım: Siyasî tekliflerinizi peş peşe sıralayın. Demokrasi paketinizi bekliyoruz. Askerlere mesajım: Özel savaşı durdurun*”

dedikten sonra ekliyor:

“*Eğer üstümüze gelinmezse, yani operasyonlar durdurulursa... Yaygın kitle tutuklamaları, faili meçhul cinayetler durdurulursa... Köy boşaltmalarına son verilirse... O zaman bizim de şiddeti turmandırmak gibi bir politikamız olamaz. Çünkü bütün bunlar zımnen de olsa 'ateskes' yürürlüktedir' anlamına gelir.*”

Ateşkes süresi...

“*Geçen bir ay içinde iyi niyet görmedik. Eğer üstümüze sert gelinirse, kesinlikle misillemeler yapacağız. ‘Zayıflamışlardır; biraz daha bastırırsak işlerini bitiririz’ diye bir yaklaşım sezersek, meşru savunmamızı ve misilleme hakkımızı kullanacağız. Silahlarımız yerli yerinde duruyor. PKK silahını bu koşullar devam ettikçe bırakmaz. Sımsıkı elinde tutar. Fakat politika ya da en az bunun kadar ağırlık verir.*”

“*Mevcut şartlar değişmeden dağdan inmek, silah bırakmak intihar olur*”

diyor Apo;

“*Bu koşullarda ‘Dağdan in, teslim ol!’ lafına kargalar güler. Bu ülke kendi başbakanını asmış... ‘Ben bir koyunum, gel beni boğazla!’ diyemeyiz. ‘Dağdan in, teslim ol, biz senin için iyi düşünüyoruz.’ İnsem, beni lime lime etmez misiniz? Önce güvence ver! Önce demokrasi yap! O zaman silahlar köklü susar. Kürtler tarihlerinde çok kandırıldılar. Bize politika alanı açın. Bana inandırıcı güvenceler verin. Ama olmazsa, ben silahlı mücadelenin Allah’ını yaparım.*”

“*Silahlı mücadeleyle her iki tarafın da kesin bir üstünlük sağlaması olanaksız. Ama silahlı mücadeleyle bir yerde denge sağlanacak ve o noktada siyasal çözüm yolları devreye girecek. Gelin şiddeti durduralım! ... Türkiye sorunu böyle götürmez. Bu yolla iflasa gidiyor Türkiye.*”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Her ne kadar Abdullah Öcalan’a izafe edilmiş olsa bile, yapılan bu açıklamalarla PKK’nin faaliyeti çerçevesinde “*meşru savunma hakkı*”nın kullanıldığı ifade edilmiştir. Silahlı mücadelenin siyasi çözüm için kendileri bakımından vazgeçilmez bir yol olduğu vurgulanmıştır.

Ezcümle, yapılan bütün bu açıklamalar, terör örgütünün propagandası mahiyeti taşımaktadır.

Yazar, bu yazı dizisinin ilerleyen aşamalarında İsmail Beşikçi’ye izafeten, PKK’nin bir terör örgütü değil, meşruiyet zemininde oluşmuş bir siyasi organizasyon olduğu izlenimi oluşturan

yöneticiliğini yapmış veya yapmakta olan kişilerle, işledikleri, işlenişini organize ettikleri, işlenişine iştirak ettikleri suçlardan bahsetmeksizin, Türkiye’deki belirli hukuki, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunları müzakere etmek, bu kişilerin söz konusu sorunların çözümüne yönelik görüşlerini yayımlamak, artık suç oluşturmamaktadır.⁷⁹

İnceleme konusu yapmış bulunduğumuz yüksek mahkeme kararlarında ifade edildiği üzere, terör örgütünün propagandası suçunun bir “somut” tehlike suçu olduğu yönündeki hukuki temeli bulunmayan değerlendirmeye sadık kalınırsa, terörle mücadelede artık çok geç olan koşullarla karşı karşıya kalınacağı kaçınılmaz olur.

Gerçeklik temeli olsun veya olmasın, Türkiye’deki belirli hukuki, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarla ilgili müzakerelerde bulunmanın, belirli sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin paylaşılmasının düşünceyi açıklama hürriyetinin kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve suç oluşturmayaacağı, izahtan varestedir. Ancak, bu sorunlardan hareketle terör örgütüne “meşruiyet” kapısı aralamaya çalışmak, asla bir özgürlük sorunu olarak ele alınamaz.

Kişinin, terör örgütünün işaretlerini, örgüt yöneticilerinin fotoğraflarını, örgütün veya yöneticilerinin mesajlarını içeren matbu malzemeyi üzerinde veya evinde başlı başına bulundurması, terör örgütünün propagandası suçunu oluşturmadağı gibi, terör örgütü üyeliğinden dolayı sorumluluğunu gerek-

ifadelere yer vermektedir: “PKK’nin övgüye değil, eleştiriye ihtiyacı vardır”, “PKK’yi ilerletecek olan eleştiridir” gibi. Yazı içeriğinde sürekli olarak adeta uluslararası hukuk kavramları olan “taraf”lardan, “karşılıklı çatışma”dan ve karşılıklı “silah bırakma”dan söz edilmektedir: CEMAL, Hasan: *"PKK tek başına silah bıraksa, Kürt halkının mücadelesine hizmet eder; çünkü karşı tarafın elindeki silahı düşürür"*, *Devletle PKK arasında, iki ateş arasında kalan Kürt aydınları...*, in: T24.com.tr, 2 Mart 2021.

Oysa PKK bağlamında, bir karşılıklı çatışma değil, bir terör faaliyeti ve Devletin bu terör faaliyetine karşı mücadelesi söz konusudur. Önemle belirtmek gerekir ki, Devletin bu terör faaliyetine karşı elbette hukuk dışı uygulamaları olmuştur. Bkz. örneğin CEMAL, Hasan: *Gece yarısı telefon: "Olay doğru, jandarma hem dövmüş köylüleri hem de bok yedirmiş..."* *Günlüğümün sayfaları arasında, 37 yıl öncesi*, in: T24.com.tr, 27 Şubat 2021. Bu uygulamalar dolayısıyla sorumluluk tartışmaları yapılabilir. Ancak bu hukuk dışı uygulamalar, terör faaliyetine asla meşruiyet kazandırmaz.

⁷⁹ Anayasa Mahkemesinin 25.6.2014 tarihli ve 2013/409 Bireysel Başvuru sayılı kararı, bu bakımdan dikkat çekicidir. Karara konu teşkil eden kitabın Türkiye’de yayımlanması gündeme geldiğinde, ilgili Bakanın şahsıma sorusu üzerine, kendisine, söz konusu kitap çalışmasının “yazar” olarak adına izafe edildiği şahsın hükümlü olarak cezasını çekmek üzere uzun süreden beri infaz kurumunda bulunduğunu, Adalet Bakanlığından söz konusu kişinin bu süre zarfında infaz kurumunda böyle bir çalışma yapmış olup olmadığı hususunun sorulmasını önermiştim.

tirmez. Bu durum, kişinin terör örgütüne ve örgüt yöneticilerine olan sempatisini ifade etmektedir. Terör örgütüne, örgütün yöneticilerine, üyelerine, amaçlarına salt **sempati** duymak, örgüt bünyesindeki hiyerarşik yapıya dahil olunmadığı, örgüte yardım edilmediği veya örgütle bağlantılı bir suç işlenmediği takdirde, örgüt üyeliğinden dolayı sorumluluğu gerektirmez. Ancak, terör örgütünün işaretlerinin, örgüt yöneticilerinin fotoğraflarının, örgütün veya yöneticilerinin mesajlarını içeren matbu malzemenin dağıtılmak üzere, yani örgütün veya faaliyetlerinin “meşruiyeti” ve “ulviyeti” konusunda başkalarını ikna amacıyla kullanılmak üzere bulundurulması, teşebbüs aşamasında kalmış terör örgütüne yardımdan dolayı cezalandırılmayı gerektirir.

Terör örgütünün propagandası suçunun oluşup oluşmadığının belirlenmesinde failin kimliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Ancak, propaganda fiilinin etkinliğinin belirlenmesi bakımından muhatap alınan kişi sayısının fazlalığı, muhatap alınan kişilerin özellikleri ve fail ile muhatap aldığı kişiler arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır. Başka bir ifadeyle, terör örgütünün propagandası suçunun soyut tehlike suçu olmasına rağmen, bu suçtan dolayı verilecek temel cezanın belirlenmesinde propaganda fiilinin etkinliği ve dolayısıyla, fail ile muhatap aldığı kişiler arasındaki ilişki, failin sosyal numu göz önünde bulundurulmalıdır.

Terör örgütlerinin istismarına en fazla açık olan yaş grubunu çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar hakkında terör örgütüyle ilişkilendirilerek soruşturma ve kovuşturma yapılması, bu istismara, çocukların örgüte kazanılmasına önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için, çocuklar hakkında terör örgütüyle ilişkilendirilerek, özellikle terör örgütünün propagandası, hukuka aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapmamak gerekir. Terör örgütlerinin etki alanına giren çocukları topluma kazanmaya yönelik eğitim programlarına tabi tutmak, korumak ve desteklemek gerekir. Bu alanda mevzuat sorunumuz bulunmamaktadır. Bu alanda duyarlılığa, ilgiye, sorumluluk bilinciyle hareket eden kamu görevlilerine ihtiyaç bulunmaktadır.

§ 4. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÜMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER¹

GİRİŞ

Ceza hukuku, uygulama itibarıyla, siyasi rakiplerin meşru ve olağan siyaset yöntemleri dışında etkisiz kılınabilmesi bakımından istismara açık bir bilim disiplini. Yakın tarihimizde, **23. Cumhuriyet Hükümeti**, o tarihte yürürlükte olan Anayasa’da belirlenen olağan demokratik yöntemler dışına çıkılarak, **cebren iktidardan uzaklaştırılmıştır**.

Bu suretle o tarihte yürürlükte olan Anayasa da işlevini yitirmiştir. Hukuka aykırı bir yöntemle yönetimi devralan kadrolar, ayrıca kurdukları **özel mahkeme** marifetiyle, 23. Cumhuriyet Hükümetini oluşturan kadroları anayasal düzeni “cebren” değiştirmeye teşebbüs suçundan dolayı bu **olağanüstü mahkemede** yargılanmalarını ve mahkûm edilmelerini sağlamıştır. Bu yargılama sırasında iktidarı elinde bulunduran kadrolar, karşılaştıkları somut durumlar karşısında siyasi tercihlerine göre Türk Ceza Kanunundaki bazı hükümleri yürürlükten kaldırmış² ve bazı hükümlerinde değişiklik yapmış³.

¹ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “**Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali**” çerçevesinde 24- 29 Eylül 2011 tarihlerinde icra edilen “**Akademik Program**”da 27.09.2011 tarihinde sunulan bu tebliğ metni, *Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Bilimsel Tebliğler*, İstanbul, 23-30 Eylül 2011, sh. 45 vd.nda yayımlanmıştır.

² Söz konusu olağanüstü mahkemede sanık olarak yargılanan dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da idam edilebilmesini sağlamak için, 65 yaşını doldurmuş olan kişilerin işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olacakları cezada indirim yapılmasını gerektiren mülga 765 s. TCK’nın 56. maddesi yürürlükten kaldırılmıştı (15 s. Kanun, RG: 11 Temmuz 1960).

Yapılan bu değişiklik adı geçen kişinin aleyhine sonuç doğurduğu için, ceza hukukunun evrensel prensiplerinin gereği olarak, bu kişi bakımından, değişiklik öncesi kanuni düzenlemenin (yürürlükten kaldırılan 56. madde hükmünün) uygulanması gerekiyordu. Ancak, adı geçen kişinin değişiklik sonrası hukuki duruma göre cezalandırılabilmesini, yani bu kişinin de idam edilebilmesini sağlamak için, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan bir kısım öğretim üyelerinin “fetva”sına başvurulmuştu. “Fetva”nın arzu edilen istikamette temin edilmiş olmasına rağmen, bilahare ortaya çıkan koşullar nedeniyle bu “fetva” mucibince amel edilmemişti.

³ Mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesine üçüncü fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmişti (15 s. Kanun, RG: 11 Temmuz 1960).

Bir suça iştirak edilmesi halinde, suç ortaklarının iştirak statüleri ve mahkûm olacakları ceza miktarları, TCK’nın iştirake ilişkin genel hükümleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak, işlendiği iddia edilen Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçundan (mülga 765 s. TCK, m. 146) dolayı yargılanan kişilerden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar gibi önde gelenlerin dışında kalanların nispeten daha az cezalarla cezalandırılabilmelerini temin amacıyla bu fıkra madde metnine eklenmişti.

Keza, 12.9.1980 tarihinde anayasanın öngörmediği bir yöntemle ve cebren Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilmiş, görev başındaki 43. Cumhuriyet Hükümeti görevden uzaklaştırılmış ve yürürlükteki Anayasa işlevsiz kılınmıştır. İki yıl kadar bir süre iktidarı elinde bulunduran kadrolar, hazırlanan yeni Anayasaya göre yönetimi sivillere devretmeden önce, gerek iktidarı devralmalarında izledikleri yöntem gerek yönetimdeki tasarrufları itibarıyla sorumsuzlukları için 1982 Anayasasına hüküm konulmasını sağlamışlardır⁴.

Bu çalışma, ceza hukukunun siyasi rakiplerin meşru ve olağan siyaset yöntemleri dışında etkisiz kılınabilmesi bakımından istismar edilmesini önlemeye katkı sağlamak temennisiyle hazırlanmıştır.

I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)

A. Korunan Hukukî Değer

Söz konusu suçla korunan hukuki değer, **Millet iradesine dayanan demokratik rejimdir**⁵. Anayasanın “Başlangıç” kısmında “**Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu**” vurgulanmıştır.

TCK’nın 301. maddesinde **30.4.2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla** (Resmi Gazete: 8 Mayıs 2008/26870) yapılan değişikliğin gerekçesinde vurgulandığı üzere⁶;

*“Millet, geçmişten beri bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşama inancında, istek ve kararında olan; aynı vatana sahip; aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu toplumdur. Bir toplumun millet olma özelliğini taşıyabilmesi için, üzerinde hayat sürdürebileceği vatanının bulunması; bireyleri arasında **kültür ve tarih birliği** ile aynı devlet çatısı altında yaşama arzusunu ifade eden **ülkü birliğinin** bulunması gerekir.”*

⁴ 1982 Anayasasının Geçici 15. maddesinde, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen, 1961 Anayasasında belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde oluşturulmuş olan yasama, yürütme ve hatta yargı erklerine **askeri müdahaleye** gerçekleştiren komutanlarla, bu komutanların koyduğu “mevzuat” çerçevesinde oluşturulan “kurul” ve “organ”larda görev yapan kişiler hakkında “**her türlü karar ve tasarruflarından dolayı ... cezai, mali veya hukuki**” bakımdan “**sorumluluk iddiası ileri sürülemez**” denilerek, **istisnai bir sorumsuzluk hükmüne** yer verilmişti. Ancak bu madde, 7.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla (RG: 13 Mayıs 2010/27580) yürürlükten kaldırılmıştır (Bu hususa ilişkin değerlendirmeler için bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler; **12. bası**, sh. 639, dn. 1171).

⁵ CGK, **10.10.2017**, K. 2017/388 ilâ K. 2017/406 sayılı Kararlar.

⁶ TBMM, Dönem: 23 Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 215.

Millet iradesinin yansıdığı demokratik rejimin dayandığı ilkeler ile yapısı Anayasa’da belirlenmiştir. Söz konusu demokratik rejimin müesseselerinin yapısına ve işleyişine ilişkin Anayasa hükümlerinde yine Millet iradesine dayalı olarak değişiklik yapılabileceği hiç kuşkusuzdur. Ancak, bu değişiklikler, Millet iradesine sınırlama getirilerek ve Millet iradesi yok sayılarak yapılamaz. Bu nedenle, Millet iradesinin yansıdığı demokratik rejimin ve bu rejimin işleyişine ilişkin ilkelerin cebren, zorla değiştirilmeye teşebbüs edilmesi suç olarak tanımlanmıştır.

B. Suçun Maddi Unsurları

1) Suçun Konusu

Bu suçun konusu, madde gerekçesinde de vurgulandığı üzere, “**Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzen**” ve bu düzenin işleyişine egemen olan bu ilkeleri içeren kuralların bütünüdür⁷. Suçun konusu, “*ne sadece metin olarak Anayasa, ne de bu Anayasaya uygun olarak çıkarılmış olan kanunlardır*”. Burada söz konusu olan **devletin siyasî biçiminin ve kuruluşunun dayandığı ideolojik esaslardır**⁸ (Anayasal düzen)⁹.

2) Fiil

Söz konusu suçu oluşturan fiil, “**cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs**” etmektir. Madde gerekçesinde suçu oluşturan fiile ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁰:

⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

⁸ ÖZEK, Çetin: *Siyasî İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler*, İstanbul 1967, sh. 109,116, SOYASLAN, Doğan: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 11. bası, Ankara, 2016, sh. 772. Soyaslan, İtalyan hukukçu Manzini’nin görüşleri doğrultusunda, “*ülke hakimiyet ve bütünlüğü aleyhine suç*” (TCK, m. 302), “*düşmanla işbirliği yapmak*” (m. 303), “*Anayasayı ihlâl*” (m. 309), “*Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan*” (m. 313), “*Cumhurbaşkanına suikast ve saldırı*” (m. 310) gibi suçların “*vatana ihanet*” teşkil ettiği düşüncesindedir (SOYASLAN, Özel Hükümler, 11. bası, sh. 787). “*Vatana ihanet*” veya “*vatan hainliği*” kavramına ilişkin bilgi için bkz. SOYASLAN, Özel Hükümler, 11. bası, sh. 763 vd.

⁹ Mülga 765 s. «TCK’nın “Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir veya tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs edenler”i cezalandıran 146. maddesi, **anayasal düzeni ve bu düzene hakim olan ideolojik prensipleri korumak amacını taşımaktadır.**» Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 10.3.1983, 65/63 (Savaş/ Mollamahmutoğlu II, sh. 1518/1519. Aynı mealde Askeri Yargıtay 1.D, 27.6.1984, 294/325 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).

¹⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

“Maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, **cebir veya tehdit kullanılarak** Anayasal düzenin değiştirilmesine **teşebbüs** edilmesi gerekir. Bu nedenle, cebir ve tehdit bu suçun unsurunu oluşturmaktadır. Cebir ve tehdit kavramlarının hukukî anlam ve içeriği, bilinen bir husustur. Bu nedenle, Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik **teşebbüsün ancak cebir veya tehdit kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir**. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146. maddesinin kaynağını oluşturan 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesi, 146. maddede olduğu gibi, **cebir** (“Violentamente”) unsurunu taşımaktaydı. Ancak, 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu’nun aynı konuyu düzenleyen 283. maddesinde, suç tanımından cebir unsuru çıkarılmıştı. Faşizmin etkisiyle kaleme alınan bu 283. madde, bilahare 11.11.1947 tarihinde yeniden değiştirilerek; suç tanımında tekrar cebir unsuruna yer verilmiştir.

Maddede, maddî unsur olarak “teşebbüs edenler” ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi, cezalandırma için yeterlidir. Suç hem idare edenler hem de idare edilenler tarafından işlenebileceğinden teşebbüste aranılacak **elverişlilik**, suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir **tehlike suçu** olduğu dikkate alınarak, kullanılan cebir veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli olup olmadığının hâkim tarafından takdir edilmesi gerekir.”

Söz konusu suç, mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesinde düzenlenmişti.

Mülga 765 s. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlıklı Birinci Babı kapsamındaki suçların hemen hepsi 1936 yılında 3038 sayılı Kanunla¹¹ değiştirilmiş ve 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu hükümleri Türk Ceza Kanununa iktibas edilmişti. Bu itibarla, söz konusu hükümlerin kaynağını 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu oluşturmaktaydı¹².

¹¹ RG: 23 Haziran 1936 / 3377.

¹² ÖZEK, sh. 8.

Özek, hukukun amacının “devletin varlığını ve devamını korumak” olduğunu ifade etmektedir. Bu anlayışa göre, devletin varlığına karşı olmamakla beraber, devletin siyasî yapısında bir değişiklik yapmayı hedef alan fiiller dahi devletin varlığına karşı suç oluşturmaktadır (ÖZEK, sh. 38).

Bu Bap içinde bulunan 146. maddede tarif edilen suçla “*Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzeni*”nin korunması amaçlanmıştır.

Söz konusu suçun maddî unsuru; “*Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzeni*”ni “*tağyir ve tebdil veya ilgaya... cebren teşebbüs*” etmek olarak belirlenmiştir.

146. maddenin birinci fıkrasının kaynağı, 1274 (1858) tarihli Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun 55. maddesiydi. Bu hüküm, 27 Mayıs 1327 (1911) tarihinde yapılan değişikliklerle son halini almıştı. 1911 yılında yapılan bu değişiklikte, 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesi esas alınmıştı. Dolayısıyla, 146. maddenin birinci fıkrasının kaynağını da 1889 İtalyan Ceza Kanunu oluşturmaktaydı¹³.

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasada “*demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti*” olarak tanımlanmıştır (m. 2). Bu demokratik cumhuriyet rejimini meselâ totaliter bir cumhuriyet haline getirme amacına yönelik olan cibrî davranışlar TCK, m. 309’da (mülga 765 s. TCK, m. 146’da) tanımlanan suç oluşturur. Böylece, rejimin **demokratik** bir **rejim** olma vasfını değiştirmeye yönelik cibrî davranışlar, suç olarak tanımlanmıştır. **Demokratik esaslara uygun seçim sistemini ve hürriyetler rejimini değiştirmeye yönelik cibrî fiiller**, bu kapsamda mütalâa edilmelidir¹⁴.

Ancak, örneğin somut bir olayda seçime hile karıştırmak, seçim güvenliğini bozmak gibi fiiller, kanunlarda bağımsız birer suç olarak tanımlanmış olmaları itibarıyla; bunların genel olarak Türkiye’deki anayasal düzenin demokratik olma vasfını değiştirmeye yönelik fiiller olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir¹⁵.

Söz konusu suçun oluşabilmesi için, fiilin **cebren** yani **cebir veya tehdit** kullanılarak ika edilmiş olması gerekmektedir. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni, “**cebir veya tehdit kullanarak**” ibaresiyle başlamakta idi.

Ancak, yeni Türk Ceza Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri sırasında, **İktidar** ve **Anamuhalefet Partisine** mensup Milletvekilleri tarafından, maddenin birinci fıkrasında yer alan “*cebir veya*

¹³ ÖZEK, sh. 65.

¹⁴ ÖZEK, sh. 110, 111. Ancak işaret etmek gerekir ki; bu değişiklik teşebbüsünün totaliter bir yönetim biçimi oluşturmaya yönelik değil de, kişi hak ve özgürlüklerini geliştirmeye yönelik olması dahi, fiili suç olmaktan çıkarmamaktadır: ÖZEK, sh. 128.

¹⁵ ÖZEK, sh. 112.

tehdit kullanarak” ifadesinin “**cebir ve şiddet kullanarak**” şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak ortak **önerge** verilmiştir. Meclis’te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin uzlaşmasıyla, bu önerge **oybirliğiyle kabul** edilmiştir. Bu değişikliğin gerekçesi, önerge metninde şu şekilde ifade edilmiştir¹⁶:

“Anayasamızda güvence altına alınmış olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kullanılan hakların Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğinin daha açık biçimde vurgulanması ve bu bakımdan ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle bir değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür.”

Belirtmek gerekir ki, bu değişikliğin yapılmasında, bir **medya grubuna** (“*Samanyolu*”) ait basın ve yayın araçlarında yapılan yayınlar büyük ölçüde etkili olmuştur. Ancak, bu değişiklik, madde içeriğinde bir anlam farkı oluşturmamıştır. Bununla, fıkra metninin ifadesi bir ölçüde ahenksizleştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik, anlamsız olmuştur.

Keza, söz konusu suçun oluşumu için **icra hareketlerine** en azından **başlanmış olmalıdır**¹⁷. Yani **cebrî hareketlere bilfiil teşebbüs edilmiş olması**, suçun oluşumu için gereklidir.

Cebir, 146. maddede tanımlanan suçun bir *unsurunu* oluşturmaktadır¹⁸. Anayasal düzeni “*ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye*” **teşebbüsün ancak cebren, yani fertlerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir**. Bu durum karşısında; “anayasal düzen”i değiştirmek hususunda meselâ bir referandum yapılması, Mecliste müzakere açılması, anayasa veya kanun değişikliği teklifinde bulunulması gibi fiiller cebrîlik vasfını haiz olmadığı için; bu gibi hallerde incelenen suçun oluşmasından bahsetmek mümkün değildir. Bu tür fiiller, bunlara mevcut Anayasa ve kanunlar müsaade etmediği için, Anayasaya ve kanunlara aykırı fiiller olarak nitelendirilebilirler. Ancak, bunlara teşebbüs ile 309. maddedeki *cebrîlik* vasfı gerçekleşmediği için, söz konusu suç teşekkül etmez.

Ancak Türk doktrininde *Özek* tarafından benimsenen diğer bir görüşe göre; cebir, mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesindeki suçun “müstakil bir maddî

¹⁶ Kaynak için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi*, 3. bası, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, 2006, m. 309 altındaki açıklama.

¹⁷ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 5.

¹⁸ SOYASLAN, *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 2. bası, Ankara, Eylül 1997, sh. 645.

unsur”unu oluşturmamaktadır. Suçun oluşumu için “failin hukuka aykırı usullere veya cebre matuf bir iradesinin mevcudiyeti” yeterli olacaktır¹⁹. Bu fikre göre cebir “*faildeki kusurlu iradede de mevcut bulunabilir*”²⁰. “146. maddenin cezalandırmak istediği husus, Anayasa iradesine aykırı iradelerdir”²¹. Buna göre, “*anayasa iradesine aykırı, netice olarak, hukuka aykırı bulunan her türlü vasıta ve usul cebir unsuruna dahil olmak gerekir*”²² Meselâ Anayasanın 4. maddesine göre devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü ile laiklik ve demokratik olma gibi cumhuriyetin niteliklerinin ve ayrıca resmî dilin Türkçe olduğuna dair Anayasa hükmü değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Anayasadaki bu hükümlerin değiştirilmesine yönelik olarak bir milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi verilmesi 146. maddedeki suçu oluşturmayacaktır. Ancak bu değişiklik teklifinin “*gündeme alınarak meclis müzakerelerine konu yapılması, 146. maddeyi ihlâl edecek bir icra hareketi sayılır*”²³.

Bu görüşe göre suçun oluşması için cebrin bilfiil tahakkuk etmesine de gerek yoktur²⁴. Suçun oluşabilmesi için “*failin gayri hukukî vasıtalarla neticeye erişmek hususundaki kastının mevcudiyeti yeterlidir*”. Hatta kastın varlığını tespit için “*objektif birtakım emarelerin, maddî delillerin mevcudiyeti dahi şart değildir*”²⁵. Daha da ileri gidilerek, anayasal düzeni değiştirmek hususundaki “*gayeye erişilmesi için cebrin mevcudiyeti veya düşünülmesi* (dahi gerekli görülmemiştir). *Gayenin tahakkukunu engelleyebilecek reaksiyonları kırmak için kullanılacak hukuka aykırı usuller dahi yeterli sayılmaktadır*”²⁶.

Cebir kavramını bu şekilde geniş yorumlayan anlayışa göre; Anayasada öngörülmüş olan usule riayet etmeksizin bir anayasa veya kanun değişikliğinin yapılması teşebbüsünde bulunulması dahi, mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesindeki suçu oluşturacaktır²⁷. Anayasal düzeni değiştirmek için *başvurulan*

¹⁹ ÖZEK. sh. 136,137.

²⁰ ÖZEK, sh. 143.

²¹ ÖZEK. sh. 143/144. Aynı şekilde SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 638, 639.

²² ÖZEK. sh. 144.

²³ ÖZEK. sh. 144.

²⁴ ÖZEK. sh. 148.

²⁵ ÖZEK. sh. 149.

²⁶ ÖZEK. sh. 156/157.

²⁷ ÖZEK. sh. 130/131.

*yolun Anayasada öngörülen usul ve esaslara aykırı olması, söz konusu suçun oluşumu açısından yeterli görülmektedir*²⁸. Keza, “*Anayasaya aykırılığı açık olan bir kanunun meclisçe çıkarılması da*” 146. maddedeki suçu oluşturmaktadır²⁹. Bu anlayışa göre, 146. madde kapsamında düzenlenen suç, “*görevin suistimali, yetki gaspı, hile, keyfi işlemler yolu ile işlenebilir*”³⁰.

Bu görüşte olan yazarlardan Soyaslan, Anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüs suçunun ihmalî bir davranışla da gerçekleştirilebileceği düşüncesindedir. Yazara göre, “*Cumhurbaşkanının Anayasaya alenen aykırılığı sabit olan bir kanuna karşı Anayasa Mahkemesine gitmeyişi bu suçun ihmal suretiyle icra yoluyla işlenişinin tipik*” örneğidir³¹.

Mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesinin kaynağını teşkil eden 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesi, 146. maddede olduğu gibi, cebir (=“Violentement”) unsurunu taşımaktaydı. Ancak, madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi, 1930 faşist İtalyan Ceza Kanununun aynı konuyu düzenleyen 283. maddesinde, suçun tanımından cebir unsuru çıkarılmıştı. Bu düzenleme biçimine göre; “Devletin Anayasal Düzeni”ni Anayasa ve Kanunların müsaade etmediği usullerle ve fakat cebir, şiddet veya tehdit kullanılmaksızın değiştirilmesine teşebbüs edilmesi halinde dahi söz konusu suç oluşmuş olacaktır.

Faşizmin etkisiyle kaleme alınan bu 283. madde, bilahare 11.11.1947 tarihinde yeniden değiştirilerek; suç tanımına tekrar *cebir* unsuru ilâve edilmiştir.

Bu açıklamalarımız karşısında; 146. maddedeki “*cebren*” ibaresinin Anayasa ve kanunların müsaade etmediği her türlü usule teşmil edilmesini savunan görüşün isabetli olmadığı sonucuna varmak gerekir. Keza, bu anlayış kendi içinde çelişkilidir. Bir taraftan anayasal düzeni Anayasanın öngörmediği bir yolla değiştirmeye teşebbüs mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesindeki suçun

²⁸ ÖZEK. sh. 131/132; aynı şekilde SOYASLAN, Özel Hükümler, 11. bası, sh. 772, 774 vd.; SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU II, sh. 1503.

²⁹ SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 643, 646. Yazar, yeni TCK’nın 309. maddesi düzenlemesine rağmen, ayrı düşünceleri savunmaya devam etmektedir: SOYASLAN, Özel Hükümler, 11. bası, sh. 774 vd. Bu bağlamda Soyaslan, milletvekillerinin Anayasa’nın 83. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen “mutlak dokunulmazlık” (doğrusu, “sorumsuzluk”) hükümlerinden de yararlanamayacağı fikrindedir: SOYASLAN, Özel Hükümler, 11. bası, sh. 789.

³⁰ SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 644.

³¹ SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 643. Benzer değerlendirmeler için ayrıca bkz. Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 8.

oluşumu için yeterli sayılırken; diğer taraftan *devletin emniyetine karşı silahlı çete kurmak* (mülga 765 s. TCK, m. 168) ve hatta *devletin emniyetine karşı cürüm işlemeğe alenen tahrik* (mülga 765 s. TCK, m. 172) gibi suçlar 146. maddedeki suç açısından sadece bir *hazırlık hareketi* olarak görülmektedir.

Yeni TCK'ya ilişkin Hükümet Tasarısının aynı suç düzenleyen 363. maddesi *Özek* ve *Soyaslan* tarafından benimsenen görüş esas alınmak suretiyle formüle edilmişti³². Ancak, redaksiyon görevini üstlenen akademisyen olarak katıldığımız TCK Tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında madde metni düşüncemiz doğrultusunda değiştirilmiştir³³.

Anayasal düzeni koruyan 309. madde, bu düzeni değiştirmeye yönelik **icra hareketlerinin** varlığını aramaktadır³⁴.

309. maddedeki suç; bir **teşebbüs suçu** niteliğindedir³⁵. Yani, belirtilen maksada matuf fiillerin amacına ulaşması beklenmeksizin suç tamamlanmış olacaktır. Ancak, suçun bu karakteri karşısında, bu maksada matuf bütün fiillerin icra hareketi sayılacağı, bu suç açısından hazırlık hareketlerinin varlığından bahsedilemeyeceği doğrultusunda bir yargıya varılamaz³⁶.

³² “**Madde 363-** Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve **Anayasanın müsaade etmediği usullerle** Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.”

Hükümet Tasarısındaki madde **gereğince** şu açıklamalara yer verilmişti:

“Anayasanın müsaade ettiği usul ve yollarla Anayasa düzenine aykırı bir netice doğduğunda Anayasa Mahkemesine başvurulmak suretiyle düzeltilmesi mümkün olan bu hâllerin suç oluşturmayacağı göz önüne alınarak, **yürürlükteki maddedeki (cebiri) unsuru yerine (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve Anayasanın müsaade etmediği usullerle) ibaresi kullanılmış**, böylece cebri de içine alan hukuka ve kanuna aykırı her türlü yollar ifade edilmiştir. Bu suretle ayrıca cebir unsurunun var olup olmadığı, maddi ve manevi cebir gibi, 27 Mayıs 1960'dan sonra ortaya çıkan tartışmaların da giderilmesi arzulanmıştır.”

³³ Söz konusu suç tehditle de işlenebilir. İtalyan hukukunda manevi cebir olarak ifade edilen tehditle söz konusu suçların işlenebilmesi için, kullanılan tehdidin ulaşılmak istenen amaç bakımından elverişli olması gerekir. Ancak belirtelim ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 14.7.2017 tarihli ve E. 2017/1443, K. 2017/4758 sayılı Kararında bu hususa ilişkin olarak yer verilen aşağıdaki açıklamalar sorunludur:

“Manevi cebir kavramı, me’haz kanun bakımından Faşizmin, Türk Ceza Hukuku yönünden ise meşru siyasi iktidarın yargılanmasına gerekçe arayan 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra o gün iktidarda olanları yargılamak amacıyla kurulan Yüksek Adalet Divanı’nın eseridir.” sh. 9.

³⁴ ÖZEK, sh. 54; Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 5, 6.

³⁵ ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 568.

³⁶ SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 641.

Nitekim Askeri Yargıtay, verdiği pek çok kararda bu gerçeğe işaret etmiştir:

«Teşebbüs için, icra başlangıcı teşkil edecek bir fiile ihtiyaç vardır. Mehaş Kanunda “muayyen bir gayeye matuf fiil” ibaresi kullanıldığı halde, (mülga 765 s.) TCK’nın 146. maddesinde “teşebbüs” tabiri kullanılmıştır. Kanunumuz, icraya başlamayı ifade eden hareketlerin yapılması halinde teşebbüsün cezalandırılmasını kabul etmektedir. Bu madde ile cezalandırılan icra hareketleri olduğuna göre, Anayasayı ihlâl matuf cemiyet veya silahlı çete kurulması veya propaganda yapılması bu maddeyi ihlâl sayılmayacak, bu şekildeki hareketler, (şartları gerçekleşmiş ise, mülga 765 s.) TCK’nın 168-171. maddeleri gereğince cezalandırılacaktır.»³⁷.

Mülga 765 s. «TCK’nın 168. maddesi metninde yazılı suçları işlemek üzere kurulan bir çete mensubunun gaye doğrultusunda bir suç işlemesi halinde, (mülga 765 s.) TCK’nın 146. maddesine göre uygulama yapılması gerekir.»^{38, 39}.

«Gizli örgüt üyesi olan sanıkların (mülga 765 s.) TCK’nın 146. maddesindeki suça ait icra hareketlerine henüz başlamamaları halinde, eylemlerinin (mülga 765 s.) TCK’nın 168. ve 169. maddeleri içerisinde ve gaye edinilen suça ait icra hareketlerine başlamaları halinde ise, eylemlerinin (mülga 765 s.) TCK’nın 146. maddesi içerisinde değerlendirilmesi gerekir.»⁴⁰.

Mülga 765 s. «TCK’nın 146. maddesinin maddî hareketinin, örgüt mensubu kimselerin teorisyenlerin önerilerine uygun olarak uyguladıkları usul ve taktiklerin gayeye müteveccih olarak istenilen ortamı yaratacak ve arzulanan neticenin gerçekleşme tehlikesini doğurabilecek olan adam öldürme silahlı soygun, silahlı çatışma gibi kişi ve toplumları dehşete düşüren devlete karşı olan güveni sarsıcı nitelikte olan eylemler olduğu aşikârdır. Maddenin yaptırımı bağladığı suç, genellikle suç teşkil eden maddî vakıalar, diğer bir deyimle

³⁷ Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 24.4.1972, 30/29 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1498).

³⁸ Askeri Yargıtay 1.D., 27.6.1984, 294/325 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).

³⁹ Soyaslan da devletin emniyetine karşı silahlı çete kurmak (mad. 168) ve devletin emniyetine karşı cürüm işlemeğe tahrik (mad. 172) gibi suçların 146. maddede tanımlanan suç açısından **hazırlık hareketi** niteliğinde olduğu düşüncesindedir (SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 635/636).

⁴⁰ Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 17.6.1982, 138/135 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1520).

gayeye ulaşmak için ika edilen suçlar manzumesinden oluşmaktadır.»⁴¹.

309. maddedeki suçun oluşabilmesi için başvuru icra hareketlerinin güdülen amacı gerçekleştirmeye **elverişli** olması gerekir⁴². Bu nedenle, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik hazırlık hareketleri 309. maddedeki suçun kapsamı dışında mütalâa edilmelidir. Buna göre; **anayasal düzeni değiştirmeye yönelik örgüt kurulması veya propaganda yapılması 309. maddedeki suçun oluşumunu sağlamayacaktır**⁴³. 309. madde kapsamında mütalâa edilen **icraî hareketler**, güdülen amacı gerçekleştirmeye **elverişli** olmalıdır. Neticeyi doğurmaya elverişli olmayan bir hareket 309. madde kapsamında bir fiil sayılamaz⁴⁴. Bu nedenle, somut olayda gerçekleştirilen fiilin güdülen

⁴¹ Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 3.5.1984, 110/109 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1516/1517).

⁴² ÖZEK. sh. 121; SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 641.

⁴³ ÖZEK. sh. 122.

⁴⁴ Mülga 765 s. «TCK'nın 146. maddesindeki "teşebbüs edenler" sözünden anlaşıldığı üzere, suçun oluşması için gerekli olan bir hareket belirlenmiş değildir. **Anayasanın koyduğu usuller dışında hukuka aykırı yollar anlamına gelen** maddedeki "cebren" sözü de dikkate alınarak; TCK'nın 146. maddesinde cezalandıran hareketi, **anayasal düzeni ve bu düzene hakim olan ideolojik prensipleri ihlâl elverişli, yasaya aykırı yollarla ihlâlâ yönelen hareketlerdir** biçiminde tanımlamak mümkün olacaktır.

Terörist örgütlerin amacının, mevcut demokratik rejimi yıkarak yerine Marksist-Leninist bir düzenin kurulması olduğu; kurulmak istenen bu düzenin ise mevcut Anayasal düzenimize ve bu düzene hakim olan ideolojilere ters düştüğü tartışmasızdır.

Teorisyenleri, demokratik düzenin hakim olduğu ülkelerde, feodalizm, emperyalizm ve işbirlikçi üçlüsüne karşı geri kalan bütün sınıf ve tabakaların ortak ve birleşik mücadelelerini öngörürler ve ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal yapısına ilişkin bazı rahatsızlıkları ele alarak çoğunluğun yanında oldukları imajını yaratma amacına yönelik taraftar kazanmak için propagandalarla işe başlayıp, silahlı kuvvetlere kadar varan devlet dairelerine ve etkili devlet kurumlarına sızma, bundan sonra da kişiler veya insan toplulukları üzerinde korku yaratan, dehşete düşüren, devlet organlarına bezdirici sabotajlar, suikastlar ve silahlı saldırıların düzenlenmesini önerirler ve de bu dehşet havası içerisinde, toplumların istenilen yöne kolayca yönlendirilebileceğini, toplumun büyük bir kısmının kendilerinin yanında yer alacağını ve böylece başlayan iç savaşla beraber ihtilal ortamının kendiliğinden oluşacağını kabul ederler.

Dünyada da bu usul ve taktiklerle başarıya ulaşıldığına (dair) örnekler bulunduğuna göre, bu tür örgütlerin devamlı ve ısrarlı bir biçimde uyguladıkları bu usul ve taktiklerin bütünü TCK'nın 146. maddesinde yazılı suçla kastedilen neticeyi doğurmaya **elverişli hareketler** olarak düşünmek hatalı olmayacaktır.

Türkiye'de 1965-1966 yıllarından itibaren Üniversite ve Yüksek Okullarda masum öğrenci hareketleri biçiminde başlatılan hareketlerin, 1968-1969 yıllarında dersleri boykot etme sınavlara girmeme biçiminde geliştirildiği, daha sonraları da ideolojik olarak koşullandırılmış bir kısım militanlar tarafından bu eylemlerin asıl hedef olan siyasî ve ideolojik bir kapsamda bölücülüğe dönüştürüldüğü ve bu amaçla birtakım örgütlerin oluşturulduğu, bu örgütlerin 1978 yılında ülkenin her tarafına yayılan silahlı çatışmalar, sabotajlar, Malatya ve Sivas olaylarında

amacı gerçekleştirmeye elverişliliğinin araştırılması gerekir⁴⁵. Gerçekleştirilen hareketin neticeyi oluşturmaya yetecek kuvvette ve nitelikte bulunması gerekir⁴⁶.

olduğu gibi kitle hareketleri biçiminde gittikçe şiddetini artırdığı, bazı bölgelerde egemenlik sağlanarak “kurtarılmış bölgeler” ihdası ile devlet kuvvetleri ile açıktan çatışmaya gidilerek iç savaşın eşliğine gelindiği bilinen bir gerçektir.

Amaçları açık olan bu örgütlerin, teorisyenlerin önerdikleri usul ve taktikleri içeren stratejiyi uygulamak suretiyle gerçekleştirdikleri adam öldürme, sabotaj, soygun gibi eylemleri alelade eylemler gibi kabul ederek bu olaylara *normal kanun hükümlerinin* uygulanması, TCK’nın 146. maddesi ile himaye edilen hukukî menfaatlere ters düşecektir.

Silahlı çete mensubu bir kimsenin gayeye müteveccih hareketlerinin ne şekilde değerlendireceğine ilişkin tartışmalar, daha ziyade bu durumda yani bir çete mensubunun gayeye müteveccih eylemleri de olduğu takdirde hem bu eylemlerinden, hem de çeteye mensup olmaktan dolayı iki ceza verilip verilemeyeceğine ilişkin bulunmaktadır. Bu itibarla **çete mensubunun gayeye müteveccih eylemlerinin TCK’nın 146. maddesi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinde** tereddüt söz konusu değildir.

TCK’nın 146. maddesinin maddî hareketinin çete mensubu kimselerin teorisyenlerinin önerilerine uygun olarak uyguladıkları usul ve taktiklerin **gayeye müteveccih eylemler** olarak mütalâası ve bunlardan istenilen ortamı yaratma ve böylece **arzulanan neticenin gerçekleşme tehlikesini doğurabilecek olan adam öldürme, silahlı soygun, silahlı çatışma gibi kişi ve toplumlara dehşete düşüren devlete karşı olan güveni sarsıcı nitelikte olan hareketlerdir**. Yasadışı örgüte girmenin TCK’nın 146. maddesinin **hazırlık hareketini**, çetenin gayesine yönelik her türlü eylemlerin ise bu suçun **icra hareketlerini** teşkil etmektedir.

Anayasa nizamına yönelmiş gaye hareketlerinin mevcudiyeti, TCK’nın 146. maddesinde yazılı suçun teşekkülü için kafi olup; *birinci derecede önemi haiz eylemleri* işleyenler aslı fail, bunlarla doğrudan doğruya işbirliğinde bulunmayıp sadece aynı gayeyi paylaşarak *tali derecedeki fiillerle* onları destekleyip yardımcı bulunmak suretiyle gaye suçunun icrasını kolaylaştıranların da fer’i şerik sayılmaları gerektiği cihetle; fer’i şeriklerin hangi aslî şerikin fiiline yardımcı olduğunun araştırılmasına da lüzum ve zaruret bulunmamaktadır.» Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 10.3.1983, 65/63 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1518/1519. aynı mealde Askeri Yargıtay 1.D., 27.6.1984, 294/325 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).

⁴⁵ «Sanık M.Ç., 14.9.1980 tarihinde diğer sanıklar Ş.K., İ.O. ve H.D. ile birlikte, H.H.dan aldıkları talimat üzerine saat 14.00 sıralarında Kadıköy’de Ş.T.ye ait “Pak Tavuk Çiftliği” mağazasına girerek içerde bulunan E.S., M.E.Ş.yi hamili oldukları silâhlarla tehdit etmek suretiyle yazıhanede bulunan M.E.nin masasının gözünden 90.000,-TL civarındaki parayı aldıktan sonra mağaza sahibi Ş.T.ye ait çantadan “Mercedes” otomobilin anahtarlarını da alarak ve kapının önüne bomba koyup, kendilerini takip etmemelerini tehditle söyleyerek otoyola binip olay yerinden uzaklaşmışlardır. Aynı kişi, 16.4.1980 tarihinde yine H.H.nın talimatı ve Ş.K.nın planlaması ile saat 19.00 sıralarında S.B.ye ait kuyumcu dükkanına kapısını zorlayarak girmiş ve içerdekileri silâhla “bu bir soygundur” diye tehdit edip tesirsiz hale getirdikten sonra orada bulunan altınları torba içerisine koymak istediği sırada H.B.nin alarm ziline basması üzerine paniğe kapılarak ve olay yerinden herhangi bir şey almadan uzaklaşmıştır.

Diğer sanık B.İ., 5.9.1980 tarihinde saat 11.00 sıralarında “İnteks” iplik fabrikasına suç arkadaşları Ş.K. ve İ.O. ile birlikte gelmiş; fabrika bekçisi O.İ.yi tesirsiz hale getirdikten sonra üzerlerinde bulunan silahlarını çeken Ş.K. ve İ.O. ile birlikte fabrikaya girmişler. Sanıkların görevli Ş.O.dan kasayı açmasını istedikleri sırada saklandığı yerden kasasının anahtarlarını vermek için çıkan muhasebeci N.S., sanıklardan İ.O.nun silahının ateş alması sonucu ölmüştür. Sanıklar, akabinde bir miktar para, senet ve çekleri almak suretiyle fabrikadan uzaklaşmışlardır. Sanık B.İ., bu olaydan sonra uzun süre sahte kimlikle firarda gezip, birkaç defa da

yurtdışına mülteci ve eğitim kamplarına gitmiş, en son 9.5.1985 tarihinde Çemişkezek ilçesi Almageçidi yaylasında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sırasında yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte güvenlik güçleriyle giriştiği ve iki arkadaşının öldüğü silahlı müsademe sonucu yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Bu eylemlerin kişi ve toplumda panik ve dehşet havası yaratabilecek, anayasal düzenin yıkılması tehlikesini doğurabilecek nitelikte ve birinci derecede önemi haiz eylemler oldukları aşikârdır. Her iki sanığın örgüt içindeki yerleri, etkinlikleri, suç kasıtlarındaki yoğunluk ve gerçekleşen eylemlere doğrudan doğruya katılmış olmaları nazara alındığında hukukî durumlarının TCK'nın 146/1. maddesi içinde değerlendirilmesi gerekir.»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Kararı, 2.7.1987, 117/123 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1515/1516).

«30.10.1979 tarihinde sanık S.N., yanında diğer sanık Ü.Ç. ve daha başka kişiler olduğu halde sayısı belirsiz topluluk üzerine hamili bulundukları silahlarla ve topluluğu hedef alarak, birden ziyade ateş etmişler ve bu atış sonunda mağdurlardan S.Ö. sağ kalçasından aldığı kurşun itibarıyla yaralanmıştır. Topluluk üzerine silahla bir çok defa ateş edilmesi ve bir kişinin de bu atış sonucu yaralanması, ateş eden kişinin öldürmek gayesi ile hareket ettiğini gösterir. Sanık, önceden alınan karar gereği olay mahalline diğer failerle gelerek bu fiile aslı maddi fail olarak katılmıştır. Sanığın bu şekilde ortaya çıkan eylemi, müesses nizamın yıkılmasına elverişli ortamın doğmasına müessir ve TCK'nın 146/1'inci maddesinde ifadesini bulan "gayeye yönelik" suçlardandır.»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 19.3.1987, 41/49 (Savaş/ Mollamahmutoğlu II, sh. 1514/1515).

⁴⁶ Mülga 765 s. «TCK'nın 146. maddesinde yer alan **anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda**, hangi eylemlerin teşebbüs niteliğinde kabul edilebileceği konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Kanunda, nakıs ve tam teşebbüs ayırımı yapılmaksızın, "teşebbüs edenler" denilmekle iktifa edildiğine göre; nakıs teşebbüsün hukukî anlamı gereği, dış alemde gerçekleşen bir netice aranmayıp, **kastedilen neticenin gerçekleşebilme tehlikesinin varlığı** cezalandırma için yeterli görülmüş ve tehlike düşüncesine dayalı olarak da teşebbüs halinde dahi tamamlanmış suça ait ceza ile cezalandırma esası kabul edilmiştir.

Suçta teşebbüsün kabulü için aranan **elverişli vasıtalarla zorlayıcı eylemlere** başlanıp başlanmadığı araştırılırken ve vasıtanın elverişliliği takdir edilirken **tek tek yapılan eylemlerle amaçlanan hedefler arasında doğrudan doruya bağ kurma yoluna gidilirse TCK'nın 146. maddesinin hiçbir olaya uygulanamayacağı** ortaya çıkar. Bu sebeple, gerçekleştirilen eylemlerin ve bu eylemlerde kullanılan vasıtaların, yukarıda açıklanan **tehlikeyi doğuracak eylemin yapılmasına elverişli** olup olmadığının takdiri yeterli kabul edilmiştir.»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 25.3.1983, 70/73 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1520).

«Aşırı sol bir örgüt üyesi olan sanıklar mevcut anayasal düzeni yıkmak üzere silahlı cemiyet kurup, anayasal düzeni ve bu düzene hakim olan prensipleri yıkmak amacına yönelik olarak toplumda devlet otoritesini sarsmak, karşıt görüşte olanları yıldırma ve böylece mevcut düzenin yıkılmasına elverişli ortamın yaratılmasında fertler ve topluluklar üzerinde korku ve panik yaratıp toplumu istedikleri biçimde yönlendirebilmek için adam öldürmek, toplumda mal ve can güvenliğini sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerine karşı öldürme derecesine varan tecavüz, kendi tabirlerine göre "kamulaştırma" diye banka soygunları düzenleme, binaları kurşunlama, patlayıcı madde atmak gibi toplumda korku ve panik yaratma ve Devlet otoritesini sarsmada etkili olma bakımından aynı derecede sayılmayacak usul ve taktiklere başvurmuşlardır. /// Bu itibarla, sözkonusu eylemlerin amacının, fertler ve topluluklar üzerinde korku ve panik yaratarak toplumu istedikleri biçimde yönlendirebilmek olduğuna göre, **böyle bir ortamın oluşmasında etkin olabilecek eylemlerin** TCK'nın 146/1. maddesi; **daha az etkin eylemleri** 146/3. maddesi şümülünde değerlendirmek isabetli olacaktır. Örneğin; aynı amaçla adam öldüren kişinin eylemi ile patlayıcı atan kişinin eylemini, etkinlik bakımından aynı olmadığından aynı cezayı ihtiva eden hüküm içinde mütalâa etmek mümkün değildir. /// Dava

Söz konusu suç, madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, bir **tehlike suçu**-dur⁴⁷. Yani, madde metninde belirtilen amacın gerçekleşmesine matuf fiillere cebren teşebbüs edilmesi, suçun oluşması için gereklidir. Ancak, söz konusu suç bir somut **tehlike suçu**^{48,49} olduğu için; **teşebbüs edilen fiillerin “Devletin Anayasal Düzeni”nin değiştirilmesini mümkün kılabilen yoğunlukta olması gerekir**. Bu husus, *ex ante* olarak somut olayın şartları göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bu izahatımız karşısında; maddede belirtilen amacın gerçekleşmesine matuf olsa bile, bu neticenin gerçekleşmesi açısından somut bir tehlike arz etmeyen filler, başka bir suç oluştursa bile, 309. maddedeki suçu oluşturmaz⁵⁰.

konusu olayda sanığın gerekçesinde **bir patlayıcı atma ile nası ızzar suçu** yoğunluk ve etkinlik bakımından TCK’nın 146/3. maddesine uygun düştüğünden, 146/1. maddesine göre değerlendirilmesinde isabet görülmemiştir.»: Askeri Yargıtay 3.D., 31.7.1984, 308/338 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522).

⁴⁷ Ayrıca bkz. SOYASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 640.

⁴⁸ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 5.

⁴⁹ Ancak Yaşar/Gökcan/Artuç, söz konusu suçun bir “soyut tehlike suçu” olduğunu kabul etmektedir: YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu*, cilt VI, Ankara 2010, sh. 8461, 8464, 8467/8468. Yazarlar, aynı şekilde TCK’nın 311. maddesinde tanımlanan “*Yasama organına karşı suç*”un da “soyut tehlike suçu” olduğu fikrindedirler (sh. 8499). Ancak yazarların bu görüşü, icra edilen fiilin neticeyi meydana getirme bakımından elverişli olması yönündeki açıklamalarıyla (sh. 8465 vd.) çelişmektedir. Elverişlilik bakımından yaptıkları açıklamalara rağmen, adı geçen yazarlar, bu açıklamalarla çekişir bir şekilde, Özek’in görüşlerinden etkilenerek, “*icra hareketinin doğrudan cebir ve şiddet içermesi zorunlu olmayıp, bu öğeleri kapsar biçimde icraya başlandığının anlaşılmasının yeterli olur.*” demektedirler (sh. 8467).

⁵⁰ Mülga 765 s. «TCK’nın 146. maddesinde yer alan suç, niteliği itibarı ile bir **tehlike suçundan** ibarettir. Madde metninde yazılan kanunî unsurların ihlâline yönelik teşebbüsün elverişli vasıta ve icra başlangıcı yönünden değerlendirilmesinde, mevcut eylemlerin örgütsel bağlılığının ve Türkiye genelindeki organik bütünlüğünün de gözönünde tutulması gerekir.

Eylemlerin bu noktadan arzettiği vahamet derecesi ve sosyal, hukukî ve hatta toplumsal yansımaları ve çalkantılara yol açan psikolojik etkenliği, suç vasfının tayininde önemli bir etken olacaktır.

Adam öldürmeler, banka soygunları, bina kurşunlamalar, bomba atmak, sabotaj yapmak, korsan mitingler yapmak, bildiri dağıtmak gibi eylemler, münferit olaylar olarak elbette ki devletin varlığı ve rejimin işlerliği açısından başlı başına kesin ve yeterli bir tahrip vasıtası değildir. Ancak belirli bir plan içerisinde uygulamaya konulan ve muhtelif aşamalara göre bir ihtilal malzemesi olarak sistemli ve örgütlü bir bağlantı içerisinde organik bir bütünlük arz eden bu kabil eylemler, TCK’nın sistematiğine uygun bir **tehlike suçunun** oluşması için yeterli olacaktır. Unutulmamalıdır ki, 146. maddede tecrim edilen husus, **teşebbüstür**.

Bu itibarla; Sanıkların Bozkır ilçesinde ve civarında yürüttükleri faaliyetleri, “THKP/C-DEVİRİMCİ KURTULUŞ” örgütünün Türkiye genelindeki sistemli ve organik bir bütünlük arzeden, aynı amaca yönelik eylemlerinden soyutlanmağa, müstakil, münferit ve mahallî bir sınırlama içinde mütalâa etmeğe imkân yoktur.

Bu hususlar madde **gerekçesinde** de vurgulanmıştır⁵¹:

*“Maddede, maddî unsur olarak “teşebbüs edenler” ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi, cezalandırma için yeterlidir. Suç hem idare edenler hem de idare edilenler tarafından işlenebileceğinden **teşebbüste aranılacak elverişlilik**, suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir **tehlike suçu** olduğu dikkate alınarak, **kullanılan cebir veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli olup olmadığının hâkim tarafından takdir edilmesi gerekir.**”*

Nitekim Yargıtay’a göre;

«TCK’nın 146. maddesinde yer alan Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda, suçun tehlike suçu oluşunun tabîi sonucu olarak, ancak kastedilen neticenin gerçekleşebilme tehlikesini doğuran fiillerin teşebbüs kabulü mümkündür.

*Bu nedenle, fiilin kastedilen neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması ve **elverişli vasıtalarla zorlayıcı fiillere girilmiş bulunulması**, başka bir deyimle kastedilen neticeyi, yani Anayasa’yı tebdil, tağvir veya ilga sonucunu doğurabileceğine objektif olarak ihtimal verilen icraî hareket olarak belirmesi gereklidir.*

***Fiilin elverişli olup olmadığının ise, genel ve soyut bir belirleme dışında fiilin işlenme şekli, zamanı ve diğer bütün şartları birlikte değerlendirmek suretiyle tesbit edilmek gerekir.** Mezkûr fiilin elverişli vasıta ve icra başlangıcı yönünden yapılacak değerlendirilmesinde örgütsel bağlılığı ve ülke genelindeki organik bütünlüğü ve bu yönden taşıdığı vehamet derecesi ile toplumdaki etkinliği suç niteliğinin tayininde önem taşımaktadır.*

Kaldı ki, ideolojik amaçla adam öldürmeğe teşebbüs, bombalama, kurşunlama, silah ve patlayıcı maddeleri depolama gibi olayların o bölgede yaratacağı panik, terör ve anarşi, sonuçları ve yansıması itibarı ile devleti ve rejimi yıkmaya yönelik olaylar zincirinin etkin bir halkasını teşkil edecek düzeyde bulunmaktadır.

Bu nedenlerle, sanıkların sübuta eren suçlarının TCK’nın 146. maddesine göre tavsifi ve değerlendirmesi gerekirken, ayrı ayrı maddeler içerisinde kabul edilerek uygulama yapılmış olması kanuna aykırı görülmüştür»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 7.4.1983, 81/86 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1517).

⁵¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

Bu itibarla, Anayasayı cebren değiştirmek amacı yönünde olmakla beraber, bu amaca ulaşma tehlikesi doğurmayan yetersiz ve önemsiz fiiller TCK'nın 146. maddesi kapsamına girmez.»⁵².

*«Bir **tehlike suçu** olan Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda, suçun niteliğinin doğal sonucu olarak, ancak amaçlanan sonucun gerçekleşebilme tehlikesini doğurabilecek eylemlerin teşebbüs kabulü mümkündür. Bu nedenle, **eylemin** amaçlanan **neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması**, elverişli vasıtalarla zorlayıcı eylemlere girişilmesi **gerekir**. Belirli bir plan içerisinde uygulamaya konulan, sistemli ve örgütlü bir bağlantı içinde organik bütünlük arzeden eylemler, tehlike suçunun oluşması için yeterlidir. Eylemin işlenme şekli, zamanı, vehameti, etkisi, birlikte değerlendirilmelidir.»⁵³.*

Her iki kararda elverişlilik bakımından yer verilen açıklamalar, Yargıtay'ın da söz konusu suçu bir **somut tehlike suçu** olarak kabul ettiğini göstermektedir.

Söz konusu suç, kural olarak Devletin anayasal düzenini değiştirmek amacıyla kurulmuş bir silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenebilir. Ancak bu suç, Devletin silahlı kamu görevlileri tarafından, bir suç örgütü oluşturmadan, görevlerinin gereği olan hiyerarşik ilişkiye bağlı olarak da işlenebilir. Bu itibarla, söz konusu suçun işlenebilmesi için, mutlaka suç işlemek amacıyla kurulmuş bir silahlı örgüte ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, Devletin anayasal düzenini değiştirmek amacıyla silahlı örgüt kurulması, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve şiddet içeren fiillerin icrasına başlanmadığı sürece, 309. maddedeki suç bakımından bir **hazırlık hareketi** olup, bu suçun oluşturmaz.

3) Fail ve Mağdur

Söz konusu suçun faili olabilmek bakımından herhangi bir özellik aranmamaktadır. Söz konusu suçun **mağduru** ise, demokratik hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan ve suç oluşturan fiilin işlenmesiyle demokratik haklarına tecavüz edilen herkestir⁵⁴.

⁵² 9. CD, 12.5.1987, 739/2514 (YKD, Eylül 1987, sh. 1423 vd.).

⁵³ CGK, 23.11.1999, 9-274/284 (Kaban/Aşaner/Güven/Yalvaç, Yargıtay CGK Kararları, Eylül 1996-Temmuz 2001, Ankara 2001, sh. 229 vd., 230).

⁵⁴ Ancak Yaşar/Gökcan/Artuç, söz konusu suçun mağdurunun “toplum” olduğunu kabul etmektedir (YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı*

C. Suçun Manevi Unsurları

Anayasayı ihlal suçunun **kast** ve **amaç** olmak üzere iki manevi unsuru bulunmaktadır⁵⁵.

Söz konusu suç, **kasten** işlenebilen bir suçtur. Failin, maddedeki ifadeyle “cebir ve şiddet” kastıyla, doğru ifadeyle cebir veya tehdit kastıyla hareket etmesi gerekir.

Ancak, fail kasten kişilere “cebir ve şiddet” uygularken, **Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, bu düzen yerine başka bir düzen getirmek veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemek amacıyla** hareket etmesi gerekir. Amaç unsuru madde metninde açıkça ifade edilmiş olmamakla birlikte, söz konusu suçun “teşebbüs suçu” olma özelliğinden bu sonucu çıkarmak gerekir^{56,57}.

Kast kapsamındaki maddi unsurlardan farklı olarak, suçun tamamlanabilmesi için amaç kapsamındaki hususun gerçekleşmesine gerek bulunmamaktadır⁵⁸.

Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu

TCK’nın 35. maddesinin **gerekçesinde** vurgulandığı üzere, Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçu (m. 309) gibi “*teşebbüs hareketlerinin bağımsız suç tipi olarak düzenlendiği suçlara teşebbüs mümkün değildir*.”⁵⁹.

Türk Ceza Kanunu, cilt VI, Ankara 2010, sh. 8461). Adı geçen yazarlar, topluma “manevi şahsiyet” izafe etmektedirler. Belirtmek gerekir ki, toplumun süjelik özelliği yoktur. Bu nedenle, suçun mağduru, **toplumu oluşturan herkes** olabilir; ancak toplum, suçun mağduru olarak telakki edilemez.

⁵⁵ Suçun manevi unsurları bağlamında kast ve amaç unsurları hakkında farklı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 300 vd.

⁵⁶ Mülga 765 s. «TCK’nın 499/2. maddesi, ancak ideolojik olmayan ve bir Anayasa değişikliğini de gerektirmeyen siyasi ve sosyal maksatlarla, adam kaçırma fiillerine uygulanabilir. Buna karşılık, söz konusu hüküm, ideolojik nedenlerle, başka bir deyimle **Anayasa’yı zorla değiştirmeyi amaçlayan düşünce ile** adam kaçırma fiillerini kapsamaz. Bu fiillerin ancak TCK’nın 146. maddesinin 1. fıkrası kapsamında düşünülmesi zorunludur.»: 9.CD, 20.2.1975, 2-6/2 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 1529).

⁵⁷ Söz konusu “suç, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, bu düzen yerine başka bir düzen getirmek veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemek **amacına matuf** doğrudan genel kast ile işlenebilen **bir suçtur**.”: Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 9 vd.

⁵⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 301.

⁵⁹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 442 vd. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 568.

Bu itibarla, Anayasayı ihlal suçuna yönelik olarak ancak **hazırlık hareketlerinden** bahsedilebilir. Kişi, bu hazırlık hareketleri başka bağımsız bir suç oluşturuyorsa, ancak bu suç nedeniyle cezalandırılır; buna karşılık, Anayasayı ihlâl suçuna teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz⁶⁰.

D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu

Söz konusu suçun işlenişi sırasında, kasten öldürme suçu gibi başka suçlar da işlenebilir. Yeni TCK'nın **fiil sayısınca suç, suç sayısınca ceza** ilkesinden ibaret olan **gerçek içtima** ön plana çıkaran özelliği dolayısıyla, maddenin ikinci fıkrasında özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir:

“Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.”⁶¹

Belirtmemiz gerekir ki, maddedeki ifadeyle “cebir ve şiddet”, doğru ifadeyle cebir veya tehdit, bu suçun unsurdurlar. Bu itibarla, kişilerin iradesini etkilemek amacına matuf olarak gerçekleştirilen cebir veya tehdit fiillerinden dolayı ayrıca cezaya hükmedilemez. Ancak, kişilere iradelerini etkilemenin ötesinde cebir ve şiddet uygulanmışsa, örneğin kişiler işkenceye maruz bırakılmış, ağır şekilde yaralanmış, hürriyetlerinden yoksun bırakılmış veya öldürülmüş iseler, failer hakkında ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmedilmesi gerekir. Nitekim aynı yönde açıklamalara TCK'nın 311. maddesinde tanımlanan “*Yasama organına karşı suç*”un madde **gerekçesi**nde yer verilmiştir⁶²:

*“Bu suçun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, **kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri** gerçekleşmiş ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir.”*

⁶⁰ ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 549 vd.; Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 10.

⁶¹ “TCK'nun **“fiil sayısınca suç, suç sayısınca ceza”** ilkesinden ibaret olan **gerçek içtimayı** ön plana çıkaran özelliği dolayısıyla, aynı Kanunun **309, 311 ve 312. maddelerinin ikinci fıkralarında**, bu suçların işlenmesi sırasında diğer suçların işlenmesi halinde, ayrıca diğer suçlardan da ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunacağı belirtilerek, amaç suç niteliğindeki bu suçların, amaç suç ile korunan hukuki değere ulaşmak için işlenen araç suçlardan ayrı ve bağımsız olarak düzenlendikleri,” dikkate alınmalıdır: CGK, **10.10.2017**, K. 2017/388 ilâ K. 2017/406 sayılı Kararlar.

⁶² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, Anayasayı ihlâl suçunun, aynı anda Yasama organına karşı suç ve hatta, Hükûmete karşı suçla birlikte işlenmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda, her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırma yoluna gidilmeyecek, sadece Anayasayı ihlâl suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulacaktır.⁶³ Bu hususa ilişkin olarak TCK, m. 311 **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir:⁶⁴

"Anayasayı ihlal suçu, Anayasa düzenine hakim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu (Yasama organına karşı suçun tanımlandığı) madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirilebilmesi yeteneğini korumaktadır.

Anayasa düzenini ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırılar, Anayasayı ihlal suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında tanımlanan suç, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmesini engelleme halinde oluşacaktır."

Aynı değerlendirmeler, Hükûmete karşı suç bakımından da geçerlidir.⁶⁵

E. "Terör Suçu" Olarak Anayasayı İhlâl Suçu

Suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun veya olmasın, TCK'nın 309. maddesinde tanımlanan "*Anayasayı ihlâl*" suçu, bir **terör suçu** olarak nitelendirilmiştir. (3713 s. K, m. 3).

Bu nitelendirme, söz konusu suçtan dolayı soruşturma yapan mercilerin belirlenmesi, soruşturma sürecinde başvuru koruma tedbirleri ve bu suça ilişkin delil elde etme yöntemleri⁶⁶ ile yargılamanın yapılacağı mahkeme⁶⁷

⁶³ Bu hususa ilişkin değerlendirmeler için bkz. Yargıtay 16. CD, 5.7.2019, E. 2019/521, K. 2019/4769.

⁶⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

⁶⁵ Bkz. TCK, m. 312 gerekçesi, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

⁶⁶ CMK, m. 100, 134 -140; 3713 s. K, m. 10.

⁶⁷ CMK, m. 250.

bakımından olduğu gibi, hükmolunacak ceza miktarının belirlenmesi⁶⁸ ve cezanın infazı⁶⁹ bakımından da büyük önem taşımaktadır.

II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)

A. Korunan Hukuki Değer

TCK'nın 309. maddesinde tanımlanan “*Anayasayı ihlâl*” suçu ile korunan hukuki değer, aynı zamanda 311. maddede tanımlanan “*Yasama organına karşı suç*” ile korunan hukuki değeri oluşturmaktadır.

Korunan hukuki değerlerin müşterekliği nedeniyle, mülga 765 s TCK'da ve mehzazını teşkil eden 1889 İtalyan Ceza Kanununda bu iki suç tek suçmuş gibi düzenlenmişti.

Her iki suç bakımından korunan hukuki değer müşterek olmakla beraber bu suçların konuları birbirinden farklıdır. Örneğin üyelerine cebir veya tehdit uygulanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yapamaz hale getirilebilir. Bu durumda aynı zamanda Anayasal düzen de bozulmaktadır. Ancak, Anayasal düzen bozulmadan da Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellenebilir. Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin örneğin Anayasanın belli bir hükmünü değiştirmesi, belli bir konuda kanun çıkarması, bazı kamu görevlerini belirlemeye yönelik seçim yapması engellenmiş olabilir.

Bu durum söz konusu suç tanımına ilişkin madde **gerekçesinde** de vurgulanmıştır⁷⁰:

“Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktadır.

Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırı-

⁶⁸ 3713 s. K, m. 5.

⁶⁹ 3713 s. K, m. 17.

⁷⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

lar, Anayasayı ihlâl suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında tanımlanan suç, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmesini engelleme hâllerinde oluşacaktır.”

Bu nedenle, her ne kadar aralarında pek çok noktada müştereklik mevcut ise de, yeni TCK’da “Anayasayı ihlâl” suçundan ayrı olarak, “Yasama organına karşı suç” (m. 311) düzenlenmiştir.

B. Suçun Maddi Unsurları

1) Suçun Konusu

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu suçun konusu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organı olan **Türkiye Büyük Millet Meclisidir**.

Anayasa’ya göre, “**Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.**” (m. 6, f. 1). Türk Milleti’nin egemenliğinin bir tezahürü olan “**yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi**” tarafından kullanılır (m. 7).

“Anayasayı ihlâl” suçu ile “Yasama organına karşı suç” bakımından korunan hukuki değer müşterek olmakla beraber, bu suçların **konuları** farklılık arz edebilir. Örneğin üyelerine cebir veya tehdit uygulanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini tamamen yapamaz hale getirilebilir. Bu durumda Anayasal düzen de bozulduğu için, aynı zamanda “Anayasayı ihlâl” suçu oluşmaktadır. Ancak, Anayasal düzen bozulmadan da Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapması engellenebilir. Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin örneğin Anayasanın belli bir hükmünü değiştirmesi, belli bir konuda kanun çıkarması, bazı kamu görevlerini belirlemeye yönelik seçim yapması engellenmek istenmiş ve hatta engellenmiş olabilir. Bu durumda, “Anayasayı ihlâl” suçu oluşmamakla birlikte, 311. maddede tanımlanan “Yasama organına karşı suç” işlenmiş olmaktadır.

2) Fiil

“Anayasayı ihlâl” suçunun maddi unsurlarından fiile ilişkin olarak yapılan açıklamalar, “Yasama organına karşı suç” bakımından da göz önünde bulundurulmalıdır⁷¹. Bu hususa madde **gerekçesinde** de vurgu yapılmıştır.

⁷¹ 309. madde düzenlemesinde olduğu gibi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni, “cebir veya tehdit kullanarak” ibaresiyle başlamakta idi. Ancak, yeni Türk Ceza Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri sırasında, İktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından, maddenin birinci fıkrasında yer alan “ce-

Ayrıca işaret etmemiz gerekir ki, belirli bir milletvekiline ve milletvekillerine örneğin görüşülmekte olan bir kanun tasarısının oylamasında ret oyu vermeleri yönünde cebir veya tehdit uygulanabilir. Keza belirli bir milletvekiline veya milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelik görevlerinden (milletvekilliğinden) istifa etmelerini temin amacıyla cebir veya tehdit uygulanmış olabilir. Bu gibi durumlarda, uygulanan cebir veya tehdit, kurumsal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevini engellemeye yönelik olmadığı için, TCK'nın 311. maddesinde tanımlanan “*Yasama organına karşı suç*” oluşmaz. Verilen örneklerden birincisinde TCK'nın 106. maddesinde tanımlanan “*Tehdit*” veya 108. maddesinde tanımlanan “*Cebir*” suçu; ikinci örnekte ise, TCK'nın 114. maddesinde tanımlanan “*Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi*” suçu oluşacaktır⁷². Burada önemli olan ölçüt, **Anayasa ile düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevini yerine getirmeyi engelleme amacıdır**⁷³.

3) Fail ve Mağdur

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Yasama organına karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

C. Suçun Manevi Unsurları

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Yasama organına karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

bir veya tehdit kullanarak” ifadesinin “*cebir ve şiddet kullanarak*” şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak ortak önerge verilmiştir. Meclis'te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin uzlaşmasıyla, bu önerge kabul edilmiştir. Bu değişikliğin önerge metnindeki gerekçesi, 309. madde değişikliğinin gerekçesi gibidir (Bu hususta bkz. ÖZGENÇ, Gazi Şerhi, 3. bası, m. 311 altındaki açıklama).

⁷² TCK'nın 114. maddesi **gerekçesinde** de vurgulandığı gibi, bir milletvekiline “*karşı cebir veya tehdit kullanılarak, ... seçildiği (bu) görevden ayrılmaya zorlanması,*” söz konusu suçun oluşması için yeterlidir. “*Bu itibarla, söz konusu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide maruz kalan kişinin bu nedenle ... seçildiği görevi bırakması gerekmemektedir.*” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 522 vd.).

⁷³ 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren komutanlar hakkında açılan davada hukuken tasvip edilemez gelişmeler olmuştur.

Henüz sanıklar mahkemede hazır bulundurulamadan, dolayısıyla, duruşmada henüz iddianame okunmadan, adeta ilanla müdahil aranır gibi yöntemlerle alınan davaya katılma talepleri mahkemeye kabul edilmiştir.

Hukukta böyle bir usul yoktur. Bu uygulamanın hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Bu hukuk dışı uygulamalar, 12 Eylül 1980 askeri darbesi dolayısıyla başlatılan adli tahkikatı en azından (!) akim kılmak sonucunu doğuracaktır. Bu uygulamalar, hukukun siyasallaştırılması görüntüsü vermektedir.

D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Yasama organına karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Yasama organına karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Yasama organına karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

III. HÜKÜMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)**A. Korunan Hukukî Değer**

TCK’nın 309. maddesinde tanımlanan “*Anayasayı ihlâl*” suçu ile korunan hukuki değer, aynı zamanda 312. maddede tanımlanan “*Hükûmete karşı suç*” ile korunan hukuki değeri oluşturmaktadır.

B. Suçun Maddî Unsurları**1) Suçun Konusu**

Madde **gerekçesinde** vurgulandığı gibi⁷⁴, bu suçun konusu “*Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun olduğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükûmet*”tir. Madde gerekçesinde hükûmet, “**Anayasa düzeninin temel organlarından biri**” olarak tavsif edilmiştir.

Hükûmet, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişikliği öncesinde **Bakanlar Kurulu** olarak tecessüm etmekte idi (6771 s. Kanunla yapılan değişiklik öncesinde Any, m. 109). Ancak, 6771 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile, parlamenter sistemden vazgeçilerek, kendine has özellikleri bulunan “başkanlık” sistemine geçilmiştir. Bu sistemde, yürütme adına kararları almaya münhasıran Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Bu sistemde bir karar alma organı olarak “bakanlar kurulu” bulunmamaktadır. Yönetim politikalarını belirleme yetkisi münhasıran Cumhurbaşkanına aittir. Bu sistemde bakanları Cumhurbaşkanı ata-

⁷⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

makta ve değiştirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bakanların atanmasında ve görevleri bağlamında denetlenmesi hususunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bakanlar, Cumhurbaşkanının aldığı kararları yerine getirmekle “memur” edilmişlerdir (Bkz. 6771 s. Kanunla değişik Any, m. 104).

Bütün bu özelliklerine rağmen bu sistemde de hükûmetin varlığı inkâr edilemez. Bu itibarla söz konusu sistemle ilgili olarak “**Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi**” ifadesini kullanmak yanlış olmaz.

Bütün bu özelliklere rağmen hükûmet, devletin anayasal düzeni içinde bir kurumsal yapıyı ifade etmektedir. Bu nedenle “*Anayasayı ihlâl*” suçu ile “*Hükûmete karşı suç*” bakımından korunan hukuki değer müşterektir. Ancak bu suçların **konuları** farklılık arz edebilir. Örneğin Cumhurbaşkanına cebir veya tehdit uygulanarak, görevini yapamaz hale getirilebilir; Cumhurbaşkanının belirli bir konuda karar alması engellenmek istenmiş ve hatta engellenmiş olabilir. Bu durumda Anayasal düzen de bozulduğu için, aynı zamanda “*Anayasayı ihlâl*” suçu oluşmaktadır. Ancak, Anayasal düzeni bozan her fiil, aynı zamanda “*Hükûmete karşı suç*” oluşturmaz. Örneğin yüksek mahkemelerden birinin belli bir konuda vereceği kararı etkilemek için cebir veya tehdit yöntemlerine başvurulması halinde, Anayasayı ihlâl suçu işlenir. Bu itibarla, bir siyasi partinin kapatılmasıyla ilgili olarak açılan davada verilecek kararı etkilemek için, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tehdit edilmesi halinde Anayasayı ihlâl suçunun oluşacağı hususunda kuşku bulunmamaktadır. Hatta, hükûmeti oluşturan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından, örneğin yüksek mahkemelerden birinin belli bir konuda verecekleri kararı ya da yapılan bir meclis soruşturmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin vereceği kararı etkilemek amacıyla, cebir veya tehdit yöntemlerine başvurulması halinde, Anayasayı ihlâl suçu oluşur.

Bir bakanın veya Cumhurbaşkanı yardımcısının görevini yapmasını engellemek, istifa etmesini sağlamak amacıyla cebir veya tehdide başvurulması halinde, Anayasayı ihlâl suçunun değil, TCK, m. 265’de tanımlanan **görevi yaptırmamak için direnme** suçunun oluşacağını kabul etmek gerekir.

2) Fiil

“*Anayasayı ihlâl*” suçunun maddi unsurlarından fiile ilişkin olarak yapılan açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da göz önünde bulundurul-

malıdır⁷⁵. Madde **gerekçesinde** de vurgulandığı gibi⁷⁶, bu suç da bir **teşebbüs suç**u olarak tanımlanmıştır:

“Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan Hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam(amlanmış) suç gibi cezalandırılmaktadır.”

Mülga 765 s. TCK’daki düzenlemede ise, yeni TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan suça karşılık gelen suçun tamamlanabilmesi için ise *“Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cehren men”* edilmiş olması, yani neticenin gerçekleşmiş olması gerekmekte idi (m. 147. Bu bakımdan yeni TCK’nın düzenlemesiyle mülga 765 s. TCK’nın düzenlemesi arasında önemli bir fark bulunmaktadır⁷⁷.

Önemle belirtmek gerekir ki, çok sayıda bakana karşı cebir veya tehdit uygulanarak istifa etmeye zorlanmaları halinde, uygulanan cebir veya tehdit, hükûmetin kurumsal işlevini engellemeye yönelik olduğu takdirde, TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan *“Hükûmete karşı suç”* oluşur. Burada önemli olan ölçüt,

⁷⁵ 309. madde düzenlemesinde olduğu gibi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni, **“cebir veya tehdit kullanarak”** ibaresiyle başlamakta idi. Ancak, yeni Türk Ceza Kanunu-na ilişkin Tasarının TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri sırasında, İktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından, maddenin birinci fıkrasında yer alan *“cebir veya tehdit kullanarak”* ifadesinin *“cebir ve şiddet kullanarak”* şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak ortak önerge verilmiştir. Meclis’te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin uzlaşmasıyla, bu önerge kabul edilmiştir. Bu değişikliğin önerge metnindeki gerekçesi, 309. madde değişikliğinin gerekçesi gibidir (Bu hususta bkz. ÖZGENÇ, Gazi Şerhi, 3. bası, m. 312 altındaki açıklama).

⁷⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

⁷⁷ **Hükûmeti istifaya zorlamak** amacına yönelik olarak **cebri hareketlerde** bulunulmuş olmasına, örneğin tankların caddelerde yürütülmüş olmasına rağmen hükûmet istifa etmemiş olabilir. Bu durumda, 5237 s. TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan suç oluşur; buna karşılık, 765 s. mülga TCK’nın 147. maddesinde tanımlanan suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Ancak bunun kabulü için, **kullanılan cebirin hükûmetin istifası sonucunu doğurmaya objektif olarak elverişli olması gerekir**. Aksi takdirde, söz konusu suç hükümlerine istinaden cezalandırılma yoluna gidilemez.

Şayet henüz cebirin kullanılmasına başlanmamış olmakla birlikte, hükûmeti istifaya zorlamak amacıyla cebri hareketlerde bulunmak hususunda bir anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma çerçevesinde birtakım hazırlıklar yapılmaya başlanmış ise, aşağıda açıklanacağı üzere, 5237 s. TCK’nın 312. maddesi ile 765 s. mülga TCK’nın 147. maddesinde tanımlanan suç bakımından sadece **hazırlık hareketlerinin** varlığını kabul etmek gerekir. Hazırlık hareketleri ise, söz konusu suç hükümlerine göre cezalandırılmayı gerektirmemektedir. Şayet söz konusu hazırlık hareketleri başka bağimsız bir suç oluşturuyor ise, ancak bu suç nedeniyle cezalandırma yoluna gidilebilir. Başka bir ifadeyle, şayet hükûmeti istifa etmeye zorlamak amacına yönelik olarak cebri eylemlerde bulunma hususunda bir anlaşmaya varılmış ise, bu anlaşmaya katılan kişiler, sadece yeni TCK’nın 316. maddesi veya 765 s. mülga TCK’nın 171. maddesi hükümlerine istinaden cezalandırılabilirler.

Anayasa ile düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan hükûmetin işlevini yerine getirmeyi engelleme amacıdır. Bu itibarla, yukarıda belirttiğimiz gibi, belirli bir bakana karşı istifasını sağlamaya yönelik olarak cebir veya tehdit uygulanması halinde, uygulanan cebir veya tehdit, hükûmetin kurumsal işlevini engellemeye yönelik olmadığı için, TCK'nın 312. maddesinde tanımlanan “*Hükûmete karşı suç*” oluşmaz. Bu durumda TCK, m. 265’de tanımlanan **görevi yaptırmamak için direnme** suçuna ilişkin hükümlere göre cezaya hükmetmek gerekir. Buna karşılık, Cumhurbaşkanına karşı istifasını sağlamaya yönelik olarak cebir veya tehdit uygulanması halinde, uygulanan cebir veya tehdit, hükûmetin kurumsal işlevini engellemeye yönelik olduğu için, TCK'nın 312. maddesinde tanımlanan “*Hükûmete karşı suç*” oluşur.

3) Fail ve Mağdur

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

C. Suçun Manevi Unsurları

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

D. “*Hükûmete Karşı Suç*”a Teşebbüs Sorunu

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

E. “*Hükûmete Karşı Suç*” ve İctima Sorunu

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

F. “*Terör Suçu*” Olarak “*Hükûmete Karşı Suç*”

“*Anayasayı ihlâl*” suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, “*Hükûmete karşı suç*” bakımından da geçerlidir.

IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım altında yer alan “*Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar*” başlıklı Dördüncü Bölümü (m. 302-308)⁷⁸ “*Anaya-*

⁷⁸ Madde 302- “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu,
Madde 303- “Düşmanla işbirliği yapmak” suçu,
Madde 304- “Devlete karşı savaşa tahrik” suçu,

sal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölümünde (m. 309-316)⁷⁹ tanımlanan suçlardan birinin işlenmesine yönelik olarak kişiler arasında **anlaşmaya** varılması, **müstakil bir suç** olarak tanımlanmıştır:

Suç için anlaşma

MADDE 316- (1) **Bu Kısımın Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşılırsa, suçların ağırlık derecesine göre, üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.**

(2) **Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.**

Belirli bir suçu işlemek için kişiler arasında sadece anlaşmaya varılması, o suç bakımından sadece **hazırlık hareketi** oluşturmaktadır. **Bir suçun işlenmesine yönelik hazırlık hareketleri başka bağımsız bir suç oluşturmadığı takdirde, cezalandırılmaz**⁸⁰. Ancak, TCK’nın 302 ilâ 315. maddelerinde tanımlanan suçların işlenmesine yönelik hazırlık hareketleri, müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, anlaşmaya varan kişiler, ilgili suç tanımlarından dolayı cezalandırılmaz ise de, 316. maddede tanımlanan suçtan dolayı cezalandırılabilirlerdir.

Söz konusu suça ilişkin madde **gerekçesi**, madde içeriği bakımından yeterli açıklama içermektedir⁸¹:

“Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek

Madde 305- “Temel millî yararlar karşı faaliyetinde bulunmak için yarar sağlama” suçu,

Madde 306- “Yabancı devlet aleyhine asker toplama” suçu,

Madde 307- “Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma” suçu,

Madde 308- “Düşman devlete maddî ve malî yardım” suçu.

⁷⁹ Madde 309- “Anayasayı ihlâl” suçu,

Madde 310- “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” suçu,

Madde 311- “Yasama organına karşı suç”,

Madde 312- “Hükûmete karşı suç”,

Madde 313- “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan” suçu,

Madde 314- “Silâhlı örgüt” suçu,

Madde 315- “Silâh sağlama” suçu.

⁸⁰ ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 17. bası, sh. 568.

⁸¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 704.

birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir **tehlike suçunu** meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir **anlaşmanın** gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır.

Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenmesinde kullanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 171'inci maddesinde “gizlice ittifak” sözcükleri kullanılmıştır. Gizlice sözcüğü Kaynak Kanunda yoktur ve anlamsızdır. Bu nedenle yeniden meydana getirilen suç tanımında bu kelimeye yer verilmemiştir. Anlaşmanın açıkça yapılmış bulunması hâlinde fiilin suç teşkil etmemesinin anlamı olamaz.

Anlaşma konularından birisini oluşturan “elverişli vasıta”dan suçun işlenmesinde kolaylık sağlayan her türlü gereçleri anlamak gereklidir. Ancak suçun işlenmesinde anlaşanların, vasıtayı da saptamış olmaları gerekir.

Maddede yer alan anlaşmanın “**maddî olgularla** belirlenen bir biçimde olması” ibaresi, suçun oluştuğunu kabul edebilmek için bulunması gerekli **delillerin** niteliğine işaret etmektedir.

Bir suçun işlenmesi için sadece anlaşmaya varmak, anlaşma konusu suç açısından bir **hazırlık hareketidir**. Eğer anlaşma konusu suçun icrasına başlanmamışsa, bu anlaşma dolayısıyla iştirak ve teşebbüs hükümlerinden hareketle cezaya hükmedilemeyecektir. Ancak, bu madde kapsamına giren suçlar açısından farklı bir yol izlenmiştir. Madde kapsamına giren suçların işlenmesi hususunda anlaşmaya varılması, bu suçlardan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamına giren suçların icrasına başlanmamış olsa bile, bu suçları işlemeye yönelik bir hazırlık hareketi mahiyetindeki anlaşma dolayısıyla cezaya hükmedilebilecektir.

Anlaşmaya varanların sayı bakımından yeterli olup olmadıkları, anlaşanların toplumda işgal ettikleri yer, kişilikleri, temsil ettikleri güç bakımlarından neticeyi alabilecek durumda olup olmadıkları hâkim tarafından takdir edilecek ve saptanacaktır.

Maddenin ikinci fıkrası ile cezasızlığı sonuçlayan bir **etkin pişmanlık** hâli getirilmiştir: İşlenmesi kararlaştırılan **suçun icra hareketlerine**

geçilmesinden önce ve soruşturmaya başla(n)madan ittifaktan yani anlaşmadan çekilme hâlinde, çekilene ceza verilmeyecektir. Ancak, soruşturmaya başlandıktan sonra anlaşmadan çekilme hâlinde, bu et-kin pişmanlık hükmü uygulanamayacaktır.”

SONUÇ

Siyasi emeller uğruna **ceza hukuku** başka ülkelerde de bir **istismar aracı** olarak kullanılabilir. Bunun ülkemiz bakımından en büyük örneği, **Almanya Federal Yüksek Mahkemesinin** ülkemizde can almaya ve can yakmaya devam eden terörün kaynaklarından en önemlisini oluşturan **PKK** ile ilgili olarak verdiği bir karardır. **Almanya Federal Yüksek Mahkemesinin** iki yüzölçümünün ve hukuk adına yapılan sahtekârlığın aynı zamanda bir örneği olan bu **kararını** özetlemek istiyorum⁸²:

Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve fakat kendini Kürt olarak tanımlayan iki kişinin, **PKK** ve bu yapıyla bağlantılı olarak değişik isimler altında oluşturulan organizasyonlarla olan ilişkisi itibarıyla “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak” suçundan dolayı yapılan yargılamada Alman Ceza Kanununun 129. Paragrafına istinaden cezaya mahkûm edilmesine dair 20.10.2003 tarihli kararında, bu süreçte rağmen **PKK’nın Almanya’da her an cebir ve şiddet içeren fiiller işleyebileceği** tespitinde bulunmuştur.

Ancak, **Almanya Federal Yüksek Mahkemesi**, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesinin 20.10.2003 tarihli kararı ile ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesinde, somut olayda bu kabulün doğru olmadığı yönünde karar vermiştir. Federal Yüksek Mahkeme, **sanıkların PKK ve bu yapıyla bağlantılı olarak değişik isimler altında oluşturulan organizasyonların yönetim kadrosunda görev yaptıkları 2000 yılının Mayıs ayından 2002 yılının Mart ayına kadar devam eden zaman dilimindeki faaliyetleri göz önünde bulundurularak, yüklenen suçun oluşup oluşmadığını tespit etmek gerektiği** yönünde içtihatla bulunmuştur.

Federal Yüksek Mahkemenin kararına göre, örgütün organizasyonunun suç işlemek amacına yönelik olarak planlanması gerekir. Örgüt içinde **suç işleme yönünde ortak bir iradenin hakim olduğunun sabit olması** gerekir. **Örgüt mensupları arasında suç işleme yönünde açık ve belirgin bir irade**

⁸² 21.10.2004 tarihli ve 3 StR 94/04 sayılı Karar. Söz konusu Kararın tam metni için bkz. BGH St 49, sh. 268 vd.; NJW 2005, sh. 80 vd.

yoksa, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütü yönetmek veya bu örgüte üye olmak suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü tesis edilemez.

Federal Yüksek Mahkemeye göre, amacının ve faaliyetlerinin değişime uğramasıyla, örgütün özelliğinde de değişim gerçekleşir. Bu itibarla, suç işlemek amacıyla oluşturulmuş bir organizasyon, değişim süreci yaşayarak, bu özelliğinden kurtulabilir. Ancak bunu söyleyebilmek için, örgütün suç işlemek amacından samimiyetle ve nihai olarak sarfınazar ettiğinin, düzenli aralıklarla ve özenle araştırılıp tespit edilmesi gerekir. Sadece belirli koşulların varlığı nedeniyle geçici olarak bu amaçtan sarfınazar edilmiş görüntüsü verilmiş olmasının, örgütü suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt olma özelliğinden kurtarmaz.

Federal Yüksek Mahkemeye göre, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, 20.10.2003 tarihli kararında, PKK ve bu yapıyla bağlantılı olarak değişik isimler altında oluşturulan organizasyonların samimiyetle ve nihai olarak suç işlemek amacından sarfınazar mı ettiğini yoksa sadece “eski” liderleri Öcalan’ın tehditvari talimatları karşısında bir taktik olarak böyle bir görüntü mü verdiği hususunu yeterince araştırmamıştır.

Federal Yüksek Mahkemenin kanaatine göre, PKK’nın Almanya’daki yönetim kadrosu tarafından cebir ve şiddet içeren fiilleri işleme yönünde bir amaç artık güdülmemektedir. Gerçi PKK’nın durumunun çok kötüleşmesi halinde, bu duruma tepki olarak, örgüt içindeki karar organlarının “barışçıl” süreçten geri dönülmesi yönünde yeni bir karar almaları halinde, Almanya’da dahi, cebir ve şiddet içeren eylemlere tekrar geri dönülebilir. Ancak bu ihtimal, iki noktadan belirsizlik taşımaktadır. Birincisi, “**barışçıl**” yollarla “**Kürt halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi**”ni sürdürme yönündeki süreçten geri dönülüp dönülmeyeceği, ikincisi ise, dönülecekse bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değildir. Federal Yüksek Mahkemeye göre, somut olayda, sanıkların PKK ile bağlantılı organizasyonların yönetim kadrosunda görev yaptıkları 2000-2002 yılları arasındaki zaman diliminde, **örgüte suç işleme yönünde bir iradenin hakim olduğuna dair tespitte bulunulmamıştır. (!)**

Eyalet Yüksek Mahkemesi, kurduğu hükmün gerekçesinde, PKK’nın Türkiye’nin güneydoğusundaki faaliyetlerini de göz önünde bulundurmuştur. Ancak, Federal Yüksek Mahkemenin kanaatine göre, **Türkiye’nin güneydoğusundaki durum ile örgütün Almanya’da suç oluşturan fiilleri işleme yönündeki tutumu arasında somut bir irtibat bulunmamaktadır: PKK**

Türkiye'nin güneydoğusunda ve genel olarak Türkiye'de silahlı mücadeleye devam etse bile, bundan örgütün Almanya'da cebir ve şiddet içeren suçları işleme yönündeki tutumuna geri döneleceği sonucu çıkarılamaz. (!)

Bir faaliyet, örgütün yönetim kadrosunun faaliyeti olarak tezahür ediyorsa, ancak bu durumda örgüt bakımından bir önem taşıyacaktır. Bu itibarla, PKK'nın amaçları ve faaliyetleri bakımından önemsiz olan, örgütün Almanya'daki yönetim kadrosu bakımından sadece istisnai olarak ve tesadüfen işlenmiş görüntüsü veren suçlardan hareketle, örgütün tekrar suç işleme yönünde bir sürece girdiği sonucuna varılamaz. Bu sonuca, ancak **merkezden yönlendirilen suçlar ile uzun bir süreden beri sistematik olarak işlenen çok sayıda suçun** varlığı halinde, varılabilir.

İşlenen suçlar, örgüt içindeki disiplinin idamesine ve yönetim kadrosunun emir ve talimatlarının yerine getirilmesine hizmet ediyorsa, bunlarda sayı ve ağırlık itibarıyla daha önceki yıllarda işlenen suçlara nazaran bir azalma eğilimi görülsün bile, örgütün suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt olma özelliğini belirleme bakımından önemsiz sayılamazlar.

PKK tarafından 2001 yılı yaz başı itibarıyla tertiplenen “kimlik kampanyası” çerçevesinde “**Ben de bir PKK'lıyım**” mesajını içeren dövizlerin dağıtılması ve taşınması gibi eylemlerin, **Türk Hükûmetine karşı uyarı amaçlı açıklamalar** özelliği taşıdığını kabul etmek gerekir.

Söz Konusu gerekçelerle, Federal Yüksek Mahkeme, Eyalet Yüksek Mahkemesi 20.10.2003 tarihli kararının **bozulmasına** karar vermiştir.

Ancak, **Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi**, başka bir PKK üyesi ile ilgili olarak verdiği bir kararda, **PKK** Alman Ceza Kanununun 129a ve 129b paragrafları hükümlerine göre **terör örgütü** olarak **değil**, 129. paragrafı hükümlerine göre **suç işlemek için kurulmuş bir örgüt** olarak kabul edilmiştir⁸³. Bu değerlendirmede örgüt mensuplarının Türkiye'de işlemiş bulundukları suçlar dikkate alınmamaktadır. Başka bir ifadeyle, PKK ve bağlı organizasyonların (TCK'nın 220. maddesi hükümlerine karşılık gelecek şekilde) “suç örgütü” olarak kabul edilmesinin sebebini, örgüt mensuplarının işledikleri **Almanya'ya veya Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelere kaçak yollarla giriş yapılması**, bu amaçla **kimlik ve sair resmi belgelerde sahte-**

⁸³ Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaletinde bulunan Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 11.10.2006 tarihinde verilen ve 26.04.2007 tarihinde kesinleşen karar (yayımlanmamıştır).

cilik yapılması gibi suçlar oluşturmaktadır. Önemle işaret etmemiz gerekir ki, bu değerlendirmelerde sadece cebir veya tehdit kullanılarak para ve sair maddi yardım toplanması fiilleri dikkate alınmaktadır. Buna karşılık, “gönüllü” (?) yardım toplama faaliyetleri ise, “terörizmin finansmanı” ve dolayısıyla suç olarak değerlendirilmemektedir (!) Keza, bu değerlendirmelerde PKK’nın veya bağlı organizasyonların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile işgal ettiğine ya da kaçak yollarla silah ve sair askeri malzeme temin ettiklerine dair hiçbir belirlemede bulunulmuş değildir (!)

Aynı şekilde, Almanya Federal Savcılığının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve fakat kendisini Kürt olarak tanımlayan 43 yaşındaki (“Hamza” müstear adlı) Abdullah S. hakkında Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinin devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara bakan dairesi nezdinde **18 Şubat 2010** tarihinde açmış bulunduğu davada, sanık **suç işlemek için kurulmuş örgütün yöneticisi** olarak suçlanmaktadır. Düzenlenen iddianamede sanık, yukarıda sözünü ettiğimiz suçlar bağlamındaki gerekçelerle, Alman Ceza Kanununun (TCK’nın 220. maddesine karşılık gelen) 129. paragrafı hükümlerine istinaden cezalandırılması istenmektedir. Başka bir ifadeyle, söz konusu iddianamede **PKK** ve bağlı organizasyonlar **terör örgütü olarak nitelendirilmiş değildir**.

EKSKURS 18: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010/283 Esas sayı ile görülüp karara bağlanan davada Mahkemenin vermiş bulunduğu 21.9.2012 tarihli ve 2012/245 Karar sayılı Gerekçeli Kararın incelenmesi sonucunda yaptığımız tespit ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

A. TESPİTLERİMİZ

I. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.9.2012 tarihli ve E: 2010/283, K: 2012/245 sayılı Gerekçeli Kararında, sübuta ilişkin olarak şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

*“03 Kasım 2002 seçimleri ile ... hükümetin.. kurulmasının hemen ardından, demokratik yollarla işbaşına gelen yürütme organını anti demokratik yollarla idareden uzaklaştırma amacıyla **I. Ordu merkezli bir cunta yapılanmasının** harekete geçtiği, Harp Akademileri Komutanlığı komutasındaki Hava Kuvvetleri unsurlarının, Donanma Komutanlığı komutasındaki Deniz Kuvvetleri unsurlarının, İstanbul ve Bursa Bölge olmak üzere Jandarma unsurlarının birer ast birlik gibi bu **cunta yapılanması** içerisinde yer aldıkları, bu unsurların plan kapsamında eylem planları hazırlama, istihbari çalışmalar yapma ve personel görevlendirme gibi birçok konuda aktif görev aldıkları, Balyoz Darbe Planının hayata geçirilmesi için gereken ortam şekillendirmesini sağlamak üzere, Havacı unsurların Oraj ve Denizci unsurların Suga isimli harekât planları hazırladıkları, bu planlar vasıtasıyla **Ege’de Yunanistan ile gerginlik çıkartılıp, bu durumun yürütme organı üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasının istendiği, Jandarma unsurlarınca Fatih ve Beyazıt camilerine yönelik olarak Çarşaf ve Sakal isimli bombalı eylem planları hazırlandığı, bu eylemler sonrasında iltisaklı şahıslar aracılığıyla irticai görüntülü protesto eylemleri düzenlenip, kaos ve kargaşa ortamı oluşturulmak istendiği, gereken ortam şekillendirilmesinin ardından sıkıyönetim ilanına müteakip yürütme organının devrilip, devlet idaresinin cunta yapılanmasının istediği şekilde yeniden yapılandırılmasının planlandığı** anlaşılmaktadır.” (sh. 985).*

II. Gerekçeli Kararda, deliller arasında,

- ülkemizdeki çeşitli siyasi gelişmelere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı, “irticai faaliyetler” bağlamında **çeşitli görevlerde bulunan**

insanların bu görevlerden alınması ve belirli görevlere atanan kişilerle ilgili bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bilgisayar kayıtlarından (sh. 993),

- çeşitli sivil ve asker “*kişilerin şahsi durumlarına ilişkin notların*” yer aldığı bilgisayar kayıtlarından (sh. 985),
- “Sorumluluk bölgesinde bulunan **daha önce sakıncalı faaliyetleri gözlemlenen şahıs, parti, dernek üyeleri ile yönetici ve personeli gözetim altına alınacak**, gerekli görülenler hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Bu tür personelin listesi istihbarat ekinde belirtilmiştir” notlarının yer aldığı bilgisayar kayıtlarından (sh. 992),
- “*görevli subay ve astsubayların özel hayatlarının takibi*” ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgisayar kayıtlarından (sh. 987),
- “*harekât planına kamuoyu desteği sağlanmasında faydalanılacak medya mensupları*”na ilişkin bilgilerin yer aldığı yer aldığı bilgisayar kayıtlarından (sh. 984),
- “Beyazıt Camiine yönelik tedhiş eylemleri icra etmek üzere hazırlanan çalışma raporların”dan (sh. 986),

söz edilmektedir.

III. Gerekçeli Kararda, söz konusu darbe planlarının hazırlanmasında **gerçek isimlerin** kullanıldığı belirtildikten sonra, “*bunun amacının, darbe gerçekleştiğinde gözaltına alınacak, tutuklanacak kişiler gibi önceden yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen kişiler hakkında işlem yapılması, kurum, dernek veya vakıflar hakkında da işlem yapılması için bu isimlerin kullanıldığı sonucuna varılmıştır*” değerlendirmesinde bulunulmuştur (sh. 990).

Gerekçeli Kararda, “*darbe harekâtının planlarının sokak sokak dolaşarak yapıldığı, bu hususun sakal ve çarşaf eylem planları keşiflerinin yapıp bunun neticesinde iki caminin eyleme uygun olduğuna dair keşif sonuç raporlarını da doğruladığı sonucuna varılmıştır*” değerlendirmesinde bulunulmuştur (sh. 992).

Gerekçeli Kararda delil olarak değerlendirilen bazı bilgisayar kayıtlarında “*Balyoz K.lığı*”, veya “*Balyoz Sıkıyönetim K.lığı*” ibarelerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir (sh. 1000, 1043).

IV. Gerekçeli Kararda,

- “**Balyoz Güvenlik Harekât Planı**” kapsamında görevlendirilecek personel olarak; “Özel operasyon ve sorgulama timleri, Özel görevli toplama timleri, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, Darbe Harekâtı timleri, Gözaltı timleri, Hasar tespit timleri, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel listeleri”nin oluşturulduğu (sh. 1000 vd.),
- Anayasal sisteme uygun olarak kurulmuş olan Hükümetin devrilerek, yerine “**Milli Mutabakat Hükümeti**” adıyla tesis edilmesi amaçlanan hükümete ilişkin Çalışma Programının hazırlandığı,
- 1. Ordu Bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından **görevle ilişkisi kesilmesi planlananlarla ilgili olarak listelerin** hazırlandığı (sh. 1004),

kabul edilmiştir.

Keza, söz konusu Kararda, “**Suga Harekât Planı**” kapsamında, “*sıkıyönetim ilanını müteakip ülke sathında kamu görevlerini devralacak personel listelerinin oluştur*”ulduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerden ilişkisi kesilecek veya görev yeri değiştirilecek personele ilişkin listelerin oluşturulduğu (sh. 1004 vd.); “**Oraj Hava Harekât Planı**” kapsamında, “*bir kısım Hava Kuvvetleri personelinin plan kapsamındaki görev yerlerinin belirlendiği*” (sh. 1006), kabul edilmiştir.

Gerekçeli Kararda;

“**Oraj Hava Harekât Planı**” kapsamında,

- “*Hava orgeneral Cumhur Asparuk’un emniyet altına alınması konulu çalışmanın yapıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanının harekâtın başlamasını müteakip gözaltına alınacağı*”nın” planlandığı, “*büyük alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetimi ile ilgili çalışmaların yapıldığı*”, Kısa adı İDO olan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’ye “harekât anında el konulacağına dair çalışmanın yapılacağı,”
- “sıkıyönetim faaliyetlerinin icrası ile ilgili çalışmaların yapıldığı,”
- “*azınlıklar ve patrikhane konusunda çalışmaların yapıldığı*”, “*Fenerbahçe stadyumunun harekâtın başlangıcında toplanma yeri olarak be-*

*lirlendiği, daha sonra da açık hapishane olarak kullanılacağına belirtil-
tildiği”,*

- Yıldız Teknik Üniversitesinin yönetimine “*elkonulacağına, sıkıyönetim
komutanlığınca üniversite yönetiminin değiştirileceği*”nin planlandığı,

kabul edilmiştir (sh. 1012 vd.).

“Suga Harekât Planı” kapsamında,

- “*Suga harekât planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel
faaliyetlerini(n) tespit edilmesi maksadıyla 20 Aralık 2002 tarihinde
Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapıldığı, toplantıda Yunanistan
ile çatışmaya varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulması,
iç tehdide yönelik olarak gayri müslimlerin tahrik edilmesi, aşırı dinci
grupların kışkırtılması konularında çalışma grupları oluşturulduğu”,*
- “*Suga Harekât Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel
faaliyetlerin tespit edilmesi kapsamında iç tehdidin yönlendirilmesi
maksadıyla özellikle Adalar Bölgesinde yaşayan gayri Müslimlere yöne-
lik olarak provakatif eylem planlanmasının, Atatürkçü ve laik vatandaş-
larımızın gerici hareketin karşısında en az onun kadar örgütlü ve alter-
natif sunabilecek şekilde örgütlenilerek toplantı ve mitingler düzen-
lenmesi, böylece halkın bilinç düzeyinin arttırılması, iç tehdit konusun-
daki hassasiyetinin arttırılması, irticai grupların yoğun bulunduğu böl-
gelerde çağdaş olmayan bir kılık kıyafet taşıma ve radikal eylemler dü-
zenlenerek halkta irtica karşıtı algı oluşturulmasının **uygun olacağı**”
değerlendirmesinde bulunulduğu,*

kabul edilmiştir (sh. 1014).

- “*Müzahir subay ve astsubaylar” bağlamında, Suga Harekât Planına ta-
raftar olmamaları sebebiyle, Deniz Kuvvetlerinde üst düzeyde görev ya-
pan bazı komutanların “tevkif” edilmesini sağlamak üzere bazı asker ki-
şilerin “görevlendirildiği”,*
- “*suga herekat planı kapsamında personel ataması, harekât ortamının
şekillendirilmesi ve eylem safhalarının planlandığı”,*
- “*radio ve televizyonların, diğer iletişim araçlarının kontrolü, deniz tra-
fiğinin kontrolü konusunda belirlemelerin yapıldığı”,*
- “*İstanbul sıkıyönetim mahkemesinin kurulması için gerekli çalışmaların
yapıldığı”,*

- “sıkıyönetim komutanlıklarının oluşturulması konularında çalışmaların yapıldığı”,
- “Yassıada ve İmralı Ada’ya kontrol altına alınacak harekâta karşı personelin şevki amaçlı çalışma yapıldığı, ... kontrol altına alınacak kişilerin Yassıada ve İmralı Ada da tutulması bu adaya transferi konularında hazırlıklar yapıldığı”,

kabul edilmiştir (sh. 1014 vd.).

Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanında yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan bir kısım listelerde,

- “günlük, haftalık gazeteler, televizyon ve radyoların isimleri ile darbe harekâtının destekleyip desteklemeyeceklerinin yönünde düşüncelerin yer aldığı, bir kısım yönünden sahiplerinin **gözaltına** alınacağı yönünde notların bulunduğu”,
- “**arama** yapılacak dernek, vakıf okul ve kursların isim ve adreslerinin tek tek belirlendiği, bu yerlerin sahiplerinin **gözaltına** alınacağının belirtildiği”,
- isimleri belirlenen bir kısım kamu görevlerinin görevde kalmasının “sakıncalı olduğu” değerlendirilerek “bunların yerine ataması planlanan şahıslar”ın belirlendiği, “bölgedeki vali ve kaymakamların siyasi düşüncelerinin değerlendirildiği”,
- “bir kısım jandarma personelinin cezaevi müdürü, cezaevi tim komutanı, hasar tespit tim komutanı, hassas tesiste görevlendirilecek, sorgulama tim komutanı, toplama tim komutanı şeklinde belirlendiği”,
- “kritik görevleri icra edecek” asker kişiler ile “kritik görevlere ataması planlanan sivil şahısların” “Bursa ilinde gözaltına alınacak belediye başkanları”nın belirlendiği,
- “Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Yalova illerinde gözaltına alınacak irticai örgüt mensupları”nın belirlendiği,
- Bu illerde görev yapan vali, vali yardımcısı, kaymakam ve diğer üst düzeyde kamu görevlilerinden **gözaltına** alınması planlananların belirlendiği,
- Bu illerde görev yapan veya bulunan kişilerden **tutuklanması** planlananların belirlendiği,

- Jandarma personelinden emekliye sevk edilmesi planlananların belirlendiği,
- “*yıkıcı bölücü görüşlere sahip*” olduklarından bahisle üniversitelerle ilişkisi kesilmesi planlanan öğrencilerin belirlendiği,

kabul edilmiştir (sh. 1006 vd.).

İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanında yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan bir kısım listelerde,

- İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce ve Sakarya illerinde arama yapılacak öğrenci yurdu, Kur'an kursu, vakıf, pansiyon, dernek isim ve adreslerinin tek tek belirlendiği,
- Bu illerde, Jandarma personeli içerisinde “*cezaevi müdürü, gözaltı tim komutanı, hasar tespit tim komutanı, hassas tesislere atanacak toplama tim komutanı, sorgulama tim komutanı, operasyon tim komutanı olarak*” görevlendirilecek kişilerin belirlendiği,
- İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığında “*kilit görevlere atanacak personel*”in belirlendiği,
- Bu illerde “gözaltına alınacak kamu görevlileri”nin belirlendiği,
- İktidar Partisine veya “*irticai örgütlere*” mensubiyeti sebebiyle, bu illerde **tutuklanması planlanan** ve “*Harekâtın başlangıcında*” tutuklanması öngörülen kişilerin belirlendiği,
- Bu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden, “*yıkıcı bölücü görüşlere sahip*” oldukları gerekçesiyle üniversitelerle ilişkisi kesilmesi planlanan kişilerin belirlendiği,

kabul edilmiştir (sh. 1009 vd. Ayrıca bkz. sh. 1018 vd.).

Ayrıca, hazırlanan söz konusu “Harekât Planları” kapsamında,

- “*Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Başbakanlık, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, DPT Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Gümrük Müsteşarlığında görevli üst düzey kamu yöneticilerin darbe planının destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin belirleme ile bu kişiler hakkındaki siyasi görüşleri ve mezhepsel durumları hakkında tespitlerin*” yapıldığı (sh. 1011),
- “*İstanbul merkezli banka ve finans kurumları(na) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve altın borsasına atanması planlanan sivil şahıslar*” ile

“Gümrük Müsteşarlığında kilit görevlere atanması planlanan sivil şahıslar”ın belirlendiği (sh. 1011/1012),

- “Harekât planına kamuoyu desteği sağlanmasında faydalanan medya mensupları” ile, “gözümlene alınacak medya mensupları”nın isim isim belirlendiği (sh. 1012),
- 2003 yılında faaliyette bulunan Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan **hakim ve savcılardan emekliye sevk edilmesi, Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilmesi planlananların isimlerinin** belirlendiği (sh. 1012),
- **Yargıtay üyeleri ile ilgili** olarak, söz konusu harekât planına destek verip vermemesine göre **değerlendirmelerin** yer aldığı liste oluşturulduğu (sh. 1012),
- “Hazine Müsteşarlığında, Merkez Bankasında görevli bürokratların darbe harekâtında görevlendirilecek yerlerinin belirlendiği, ÖSYM’de çalışanlarla ilgili listeler hazırlandığı, Savunma Sanayi görevlendirilebilir personel listeleri ... kapsamında Savunma Sanayinde çalışan personelin durumunun ve yeni atanacakların görevlerinin belirlendiği” (sh. 1012),

kabul edilmiştir.

V. Bütün bu kabullere dayalı olarak, Gerekçeli Kararda aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

“2002 yılında Türkiye’de oluşan politik yapı ... nedeniyle, seçimler öncesinden başlanarak, demokratik yollarla işbaşına gelen yürütme organını anti demokratik yollarla idareden uzaklaştırma amacıyla sanık **Çetin Doğan liderliğinde 1. Ordu merkezli bir cunta yapılanmasının** olduğu, Harp Akademileri Komutanlığı komutasındaki Hava Kuvvetleri unsurlarının, Donanma Komutanlığı komutasındaki Deniz Kuvvetleri unsurlarının, İstanbul ve Bursa Bölge olmak üzere Jandarma unsurlarının bu cunta yapılanmasının içinde yer aldıkları,

Harp Akademileri Komutanlığı komutasındaki Hava Kuvvetleri unsurlarının başında Halil İbrahim Fırtına’nın, Donanma Komutanlığı komutasındaki Deniz Kuvvetleri unsurlarının başında ise sanık Özden Örnek’in, Jandarma unsurlarının başında suç tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan Halil Helvacıoğlu’nun bu-

lunduğu, bu unsurların plan kapsamında yukarıda belirtilen eylem planları hazırlama, istihbarî çalışmalar yapma ve personel görevlendirme gibi bir çok konuda aktif görev aldıkları, harekâtın Jandarma kuvvetleri vasıtası ile tüm yurdu kapsamının sağlanacağı, Ankara'daki Kuvvet Komutanlıklarının ve harekâta karşı olanların kontrol altına alınması için planların yapıldığı,

Balyoz Darbe Planının hayata geçirilmesi için gereken ortam şekillendirmesini sağlamak üzere, Havacı unsurların Oraj ve Denizci unsurların Suga isimli harekât planları hazırladıkları, bu planlar vasıtasıyla Ege'de Yunanistan ile gerginlik çıkartılıp, bu durumun **yürütme organı üzerinde çekilmeye yönelik baskı aracı olarak kullanılması-
nın istendiği**,

Jandarma unsurlarınca Fatih ve Beyazıt camilerine yönelik olarak Çarşaf ve Sakal isimli **bombalı eylem planları hazırlandığı**, bu eylemler sonrasında iltisaklı şahıslar aracılığıyla irticai görüntülü protesto eylemleri düzenlenip, kargaşa ortamı oluşturulmak istendiği,

Gereken ortam şekillendirilmesinin ardından **sıkıyönetim ilanını müteakip yürütme organının devrilip, devlet idaresinin cunta yapılmasının istediği şekilde yeniden yapılandırılmasının planlandığı**, bu kapsamda yukarıda belirtilen **hazırlıkların tamamlandığı, harekât planının düşünce aşamasından çıktığı**,

Muhtemel eylem yerlerinin keşfi, tutuklanacak kişiler (siyasi parti mensupları, belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin yönetici ve üyeleri, gazeteciler, aydınlar, bilim adamları, kanaat önderleri), okulundan atılacak öğrenciler, el konulacak araçlar, görevden uzaklaştırılacak, tutuklanacak, emekliye sevk edilecek, kullanılacak kamu görevlilerinin belirlenmesi, hassas olarak belirlenen kurum ve kuruluşların başına hangi askeri personelin atanacağı, zararlı olarak nitelenmesi sebebiyle ilişkisi kesilmesi planlanan askeri personelin belirlenmesi, polis teşkilatının ne şekilde yönlendirileceği ve kullanılacağı-
nın tespiti, basın- yayın kuruluşları ve çalışanlar hakkında yapılan planlamalar (kimlerin tutuklanacağı, kimlerin kullanılabileceğinin tespiti), **Milli Mutabakat Hükümeti** ismiyle harekât sonrasında **işbaşına getirilmesi planlanan hükümetin dizayn edilmesi gibi icra aşamasına geçildiği, ancak icra hareketlerinin tamamlanamadığı**, harekât planının Genelkurmay Başkanlığı ve Kara kuvvetleri Komutan-

lıınca öğrenildiği, bu hususun Yaşar Büyükanıt'ın seminer sonuç raporunu hukukçulara inceletmesi, **KKK'nın OEYTS'nin** ("Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo"'nın) oynanmaması **talimatları, Genelkurmay Başkanının sanık Çetin Doğan'ı bu konuda uyarması** ile belli olduğu, 2003 yılı Mayıs ayında sanık **Çetin Doğan'm kalp ameliyatı olması ve Ağustos 2003 de emekli edilmesi** gibi nedenlerle **sanık Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanmasının darbe harekâtını elle- rinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etme Suçunun eksik teşebbüs aşamasında kaldığı, suçta icra hareketlerinin yani teşebbüs aşamasının silahlı olarak sokağa dökülmekle başladığı yönündeki düşüncelere katılma olanağının bulunmadığı, zira darbe suçunun icra hareketlerinin tankların sokağa çıkmasıyla sınırlı olmadığı, aksine cunta yapılanmasına bağlı birimlerin sokağa çıkmasının neticeye en yakın son icra hareketi olduğu, yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı gibi suçun düşünce ve planlama aşamasından çıktığı, gözaltına alınacak, tutuklanacak, görevinden uzaklaştırılacak vb. kişilere, azınlık mensuplarına ilişkin kapsamlı çalışmalar yapıldığı, görevinden alınacak kişilerin yerine atanacak kişilerin bile tek tek isim isim belirlendiği, sokağa çıkılarak sivil kıyafetli olarak istihbari çalışmaların yapıldığı, darbe sonrası meşru hükümetin yerini alacak millî mutabakat hükümetinin de belirlendiği, bu şekilde oluşturulan listelerde binlerce kişinin listelendiği, tüm bu çalışmalarla suçun icrasının başladığı kabul edilmiştir.**

...

Sanık Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanması darbeyi gerçekleştirebilecek elverişliliğe ulaşmış, suçun icrası için elverişli, araç gereç ve personelle icra hareketlerini gerçekleştirmeye başlamış ancak cuntanın lideri konumundaki sanık Çetin Doğan'ın önce kalp ameliyatı olması ve ardından Ağustos 2003 te emekliye sevk edilmesi, yine aynı ayda bazı sanıkların tayinen görev yerlerinin değişmiş olması, Genelkurmay karargahının öncelikle muhtemel darbeye karşı çıkması, sonrasında da günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi sebebiyle cunta yapılanmasının darbe suçunu işleme elverişliliğini kaybettiği ve icra hareketlerinin tamamlanamadığı anlaşılmıştır. O nedenle suç tarihi mahkememizce suçu işleme elverişliliğinin kaybedildiği 2003 yılı Ağustos ayı ve öncesi olarak kabul edilmiştir.

*Bu tarihten sonra da Balyoz Darbe Planı çerçevesinde uygun ortam bulunduğu darbenin gerçekleştirilebilmesi, hukuki alanda haklarında takibata başlanma ihtimaline karşı gerekli hukuksal alt yapının hazırlanması gibi amaçlara yönelik olarak bir kısım sanıkların ve dava dışı kişilerin çalışmaları devam etmiştir. **Devam eden bu çalışmalar kapsamında listeler güncellenmiş ve yeni çalışmalar yapılmıştır.** Ancak cunta yapılanması haklarında soruşturmaya başlanılmasına kadar, bir daha Ağustos 2003 ve öncesi konumuna yani darbe suçunu gerçekleştirebilme yeterliliğine ve ortamına ulaşamamıştır. Bu tarihten sonraki belgeler faaliyetin gizlenmesine veya yeniden toparlanma amacına yönelik çalışmalar olarak kabul edilmiştir.” (Gerekçeli Karar, sh. 1021-1023).*

VI. Gerekçeli hükümde, lehe kanunun belirlenmesi bakımından şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Met Etmek suçundan mahkûm olan sanıklara atılı suç 5237 sayılı TCK'nın 312. maddesi ile 765 sayılı TCK'nın 147. maddelerinde tarif olunmuştur.

*5237 sayılı TCK'nın 312. maddesinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği öngörülmüştür. Anılan maddede hükümete karşı işlenen suç için teşebbüs yeterli görülürken, 765 sayılı TCK'nın 147. maddesinde suçun tamamlanması öngörülmüş olup Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik eyleyenleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmolunacağı belirlenmiştir. Sanıklara atılı **suç teşebbüs aşamasında kaldığından** 765 sayılı TCK'nın 61. maddesi uyarınca sanıklar hakkında 15 ya da 20 seneye kadar hapis cezası verilecektir.*

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 312. maddesindeki suçun tehlike suçü olarak düzenlenmesi ve teşebbüs halinde temel cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak belirlenmesi karşısında sanıklar hakkında aynı kanunun 35. maddesinin uygulanma imkanı bulunmamakta olup bu halde somut ceza takdiri indirim uygulanıp uygulanmamasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da müebbet hapis olacaktır. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesindeki suç zarara suçü olup

eylem eksik teşebbüs aşamasında kaldığından aynı kanunun 61. maddesinin uygulanması suretiyle, takdiri indirim uygulananlarda dikkate alındığında sonuç ceza 12 yıl 6 ay ile 20 yıl arasında olacağından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun sanıkların lehine olduğu sonucuna varılmıştır.” (sh. 1029).

VII. Mahkeme, söz konusu suçun işlediğinden bahisle, aralarında iştirak ilişkisinin bulunduğunu kabul ettiği suç ortakları hakkında hüküm kurarken ilginç bir yöntem izlemiştir:

*“Sanıklara atılı suçun lehe olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesindeki temel cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Eylem **eksik teşebbüs** aşamasında kaldığından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 61/1 maddesine göre 15 seneden 20 seneye kadar yapılacak indirimde hangi ölçülerin esas alınacağı 61. madde de açıkça düzenlenmemiş, bu husus 29. maddedeki düzenlemeye bırakılmıştır.*

*5237 sayılı Türk Ceza Kanununun teşebbüsü düzenleyen 35. maddesinde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre teşebbüse dayalı indirimde iki sınır arasındaki cezanın belirleneceği vurgulanmıştır. Bu yönde düzenlemenin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 61. maddesinde bulunmaması nedeni ile genel düzenlemeyi içeren aynı kanunun 29. maddesi esas alınacağı açıktır. Mahkememiz 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 61. maddesindeki 15 yıl ile 20 yıl arasındaki hapis cezasını belirlemede zarar ve tehlikenin ağırlığı, **kastların yoğunluğu, güttükleri amaç**, (suç ortağı olduğu kabul edilen kişilerin) **olaydaki konumlarını** dikkate almıştır.*

*Bu ölçü içerisinde cunta yapılanmasının lideri olan sanık Çetin Doğan ile ona bağlı olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki yapılanmanın lideri olarak suça katılan sanıklar Özden Örnek ile Halil İbrahim Fırtına için 20 yıl, suç tarihinde tugay komutanı, jandarma bölge komutanı, il jandarma komutanı olarak görev yapanlar, yapılanma içerisinde birlik komutanı, grup lideri konumunda olanlar, eylem planlarını hazırlayanlar, çalışmada ikinci derecede lider konumunda olanlar yönünden 18 yıl, diğer sanıklar yönünden ise 16 yıl olarak belirlenmiş, zararın ve tehlikenin ağırlığı temel ölçüsü dikkate alınarak tüm sanıklar yönünden teşdit uygulanmıştır. Diğer bir anlatımla zarar ve tehlikenin ağırlığına göre eksik teşebbüse dayalı indirimin alt sınırdan yapılmaması ölçüsü benimsenmiş, daha sonra da **sanıkların olaydaki***

konumları, kastlarının yoğunluğu, olaydaki konumlarına göre oluşturdıkları tehlikenin ağırlığı ölçü alınarak teşditte ayrıştırmalar yapılmıştır.” (sh. 1023/1024).

VIII. Söz konusu mahkûmiyet hükmünün temyizden incelenmesi sonucu verilen **Yargıtay 9. Ceza Dairesi**’nin 9.10.2013 tarihli ve E. 2013/9110, K. 2013/12351 sayılı Kararında da, subuta ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

İmza bloğunda Orgeneral ÇD’ın adının yazılı olduğu **Balyoz Güvenlik Harekat Planı** adlı 11 sayfalık belgenin “DURUM” başlıklı bölümünde;

“28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istifade edilememesi ve 2002 seçimlerinde AKP’nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber, ülkede hızlı bir zemin kayması yaşandığı, Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laiklik karşıtı ve irticai unsurların etkisine girmeye başladığı, son zamanlarda varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içinde bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini değiştirme gayretlerinin gizlenemeyecek kadar aşikâr ve had safhaya ulaştığı”,

İmza bloğunda Oramiral ÖÖ’in adının yazılı olduğu **Suga Harekat Planı** adlı 12 sayfalık belgenin “DURUM” başlıklı bölümünde;

“Türkiye’nin 2002 seçimlerinde AKP’nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber anti-laik ve irticai unsurların etkisine girmeye başladığı, özellikle ılımlı islam devleti oluşturulması yönündeki çabaların arttığı, gelinen noktada, bu tür eylemlerin artarak devam edeceği ve bunun Türkiye’nin egemenlik-birlik ve bütünlüğüne zarar verebilecek boyutlara taşınabileceği”,

İmza bloğunda Orgeneral HİF’nin adının yazılı olduğu **Oraj Hava Harekat Planı** adlı 5 sayfalık belgenin “DURUM” başlıklı bölümünde ise;

“İrticai faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyetinin anayasası ile belirlenen demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini tehdit etmekte olduğu, irticanın 2002 Kasım seçimleri ile beraber cesaret kazandığı, AKP hükümetinin 28 Şubat ile şekillendirilen ortamın bozulmasına neden olduğu”

şeklinde paralel durum değerlendirmesi yapıldığı anlaşılmakla;

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki teamüller gereği 2003 yılı Yüksek Askeri Şurasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak Donanma Komutanı Oramiral ÖÖ ve Hava Kuvvetleri Komutanı olacak Harp Akademileri Komutanı Orgeneral HİF ile mutabakata vardığı anlaşılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral ÇD’nin, 28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istenilen düzeyde istifade edilememesi ve ülkede hızlı bir zemin kayması yaşandığı gerekçesiyle, serbest demokratik seçimlerle iş başına gelmiş **siyasi iktidarı hükümetten uzaklaştırma ve bu amaç doğrultusunda** kara, deniz ve hava unsurları olarak **harekat ve eylem planları hazırlama ve hazırlanan planları gerçekleştirebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yasal hiyerarşik yapısı dışında ayrı bir hiyerarşik yapılanmaya gitme kararını** aldıkları,

Bu kapsamda 1. Ordu Komutanı ÇD’nin, ittifak ettiği ast birlikleri olan 2, 3, 5 ve 15. Kolordu Komutanlarından, kara unsurlarına ait harekat ve eylem planlarında görev alacak askeri personelin belirlenmesini istediği; 2, 3, 5 ve 15. Kolordu Komutanlıkları ile 1.Ordu ve Harp Akademileri Komutanlığınca belirlenen isimler üzerinden Balyoz Güvenlik Harekat Planının eki olan “görevlendirmede yetkili personeli” belirleyen EK-A listesinin oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Balyoz Güvenlik Harekat Planına göre, “görevlendirmede yetkili personel” başlıklı EK-A listesinde yer alan askeri personelin statüsü, “kendilerine kişiye özel olarak görev tevdi edilen ve bu onurlu görevi kabul eden, harekatin kendi sorumluluk bölgelerinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasından sorumlu olan” şeklinde belirlenmiş olup, anılan listede yer alan personelin;

- a. Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel,
- b. Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel,
- c. Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel,
- ç. Darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel,
- d. Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel,
- e. Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel,
- f. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel,
- g. Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel,
- ğ. Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel,

h. Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel, listelerini oluşturması,

...

Dosya kapsamına göre de, 1. Ordu, 2, 3, 5 ve 15. Kolordu ile Harp Akademileri Komutanlıklarınca “görevlendirme kategorileri ve çizelgesi” başlıklı yukarıda “a”dan “h”ye kadar isimleri belirtilen “EK-B” listelerinin hazırlanarak 1. Ordu Komutanlığına gönderildiği ve ... “1 nci Ordu Komutanlığı Güvenlik Harekat Planının Uygulanması Kapsamında Görevlendirilecek Personel Listesi” başlığı altında “EK-M Lahika-1” adı ile birleştirildiği,

anlaşılmaktadır.

Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral MAG, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümamiral AFÖ, İstanbul Boğaz Komutanı Tümamiral TB ve Ege Deniz Bölge Komutanı HH ile **mutabakata vardığı anlaşılan** Donanma Komutanı Oramiral ÖÖ’in, deniz unsurlarına ait hareket ve eylem planlarında görev alacak askeri personelin belirlenmesi kapsamında, Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul Birlik Komutanlıkları ve bu komutanlıklar altında koordinatörlükler oluşturmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki **Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yasal teşkilat ve hiyerarşik yapılanması dışında amaç suçu işlemeye dönük ayrı bir yapılanmaya gitme kararı aldıkları ve bu doğrultuda Suga Harekat Planına ek “görev bölümü” başlıklı “EK-A” listesinin hazırlandığı**, sonrasında;

- Amirallere ait "HASSAS" listenin oluşturulması,
- Ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması,
- Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı bağlilarında görevli müzahir personel,
- Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci,
- Ankara, İstanbul, Gölcük, Çanakkale, Akdeniz, İzmir, Marmaris, Karadeniz, Deniz Hava Üs Komutanlığı ve Yurtdışı müzahir subay/astsubay listelerinin hazırlanması,
- İcra safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinin oluşturulması,
- TSK’dan ilişkisi kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel listesinin oluşturulması,

- Öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinin hazırlanması,

“çalışma grupları görev bölümü” başlıklı EK-B listesinde belirlenen askeri personelden istenmiş; “ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması” dışındaki diğer tüm görevlerin yerine getirildiği, tespit edilmiştir.

Hava unsurlarına ait hareket ve eylem planlarında görev alacak personel ile anılan personelin görev bölümleri ve çalışma gruplarını gösterir **Oraj Hava Harekat Planının** ana eklerine (ulaşılamamakla birlikte, dosya içeriğinden) Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral KP, Plan Prensipler Başkanı Tümgeneral BB, İstihbarat Başkanı Tümgeneral ZG ile **mutabakata varıldığı anlaşılan** Harp Akademileri Komutanı Orgeneral HİF’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki **Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yasal teşkilat ve hiyerarşik yapılanması dışında amaç suçu işlemeye dönük ayrı bir yapılanmaya gitme kararı aldıkları ve bu doğrultuda çalışmaya başladıkları**, ... anlaşılmaktadır.

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “İCRA” başlıklı bölümünde, “öncelikli ve acil olarak, AKP yönetiminin tasfiyesi ve işbirlikçilerinin saf dışı bırakılması maksadıyla, hareket alanının şekillendirilmesi de dahil olmak üzere, resmi/gayri resmi tüm yurtseverlerin seferber edilerek, başta Silahlı Kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri olmak üzere maddi ve manevi tüm güçlerin kullanılması”, yine aynı planın “HAZIRLIK SAFHASI” bölümünde, “AKP ve irticai gruplara yönelik istismara açık noktalar mevcut ve oluşturulması düşünülen yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek, gerektiğinde istismar noktaları oluşturulması için sızdırılan personelin kullanılması amacıyla alternatif planların oluşturulması”, “HAREKÂT ORTAMININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ SAFHASI” bölümünde ise, “İstanbul ve civarı başta olmak üzere hassasiyet arz eden şehirlerde iltisaklı kişilerin sevk ve idare ettiği halka yönelik eylemlerin yapılması” kararlaştırılmıştır.

...

Çarşaf Eylem Planına göre; “ölümden daha çok yaralanmaya sebep olacak şekilde hazırlanacak tahrip düzeneğinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş olarak Tahrip -A tarafından ... camii içerisinde caminin iç kısımlarındaki cemaate yakın ayakkabılığa bırakılarak kendisinin de cami çıkışında kapıya yakın bir yerde yerini alması, faaliyetin Cuma namazının farzının kılınmasından sonra icra edilmesi, Tahrip-A’nın farzın kılınmasını müteakip süratle camiden çıkması ve “Tahrip Hazır” işaretini vererek, “Tahrip hazır işaretini”

gören ve camii avlusunda bekleyen Tahrip-B'nin, camii avlusundan çıkıp 300 m. kadar uzaklaştıktan sonra ilgili telefon numarasını arayarak tahribi gerçekleştirmesi, patlama esnasında; Kayıt –A'nın camii üst katından, Kayıt-B'nin camii alt katından patlama anını ve sonrasında oluşan panik havasını çekerek, patlama sonrası önce camii avlusunda toplanan ve sonra ana caddeye intikal ederek caddeyi kapatan öfkeli kalabalığın camii avlusunda toplanmasını ve caddedeki eylemlerini hem Kayıt-A hem de Kayıt-B'nin birbirlerinden bağımsız ayrı noktalardan üzerlerindeki video kayıt cihazlarıyla kaydetmeleri ve görüntülerin ivedi olarak internet üzerinden yayılmasının sağlanması, Tahrik- A ve Tahrik-B'nin irtibatlı bulundukları ve halkın içerisine sızmış bulunan provokatörleri harekete geçirerek, böylece Cami cemaatinin, çoğunluğunu Fatihli esnafın oluşturduğu öfkeli radikal grupla ana cadde üzerinde birleşmesi sağlanarak, yapılacak manipülasyonlarla öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesinin sağlanacağı” kararlaştırılmıştır.

Sakal Eylem Planına göre; “ölümden daha çok yaralanmaya sebep olacak şekilde hazırlanacak tahrip düzeneğinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş olarak Tahrip -A tarafından abdest alınırken şadırvanda unutulmuş görüntüsü verilerek bırakılacağı, Tahrip-A'nın malzemeyi bırakmayı müteakip derhal Camii avlusundan çıkarak işaretini vereceği, Tahrip-A'nın işaretini gören Tahrip-B'nin sahaflar çarşısı içinden ilgili telefon numarasını arayarak tahribi gerçekleştireceği, patlama esnasında; Kayıt –A'nın, cami içerisinden özellikle patlama anını ve sonrasını, Kayıt –B'nin ise patlama sonrası camiden çıkarak ve patlama ile avluda oluşan panik havasını çekeceği, öfkeli kalabalığın meydana toplanmasını müteakip hem Kayıt-A hem de Kayıt-B'nin meydana kayıtlarına devam ederek, görüntülerin ivedi olarak internet üzerinden yayılmasının sağlanacağı, Tahrik-A ve Tahrik-B'nin irtibatlı bulundukları ve halkın içerisine sızmış bulunan provakatörleri harekete geçirerek, böylece Cami cemaatinin, çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu öfkeli radikal grupla İstanbul Üniversitesi Meydanında birleşmesi sağlanarak, öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesinin sağlanacağı” kararlaştırılmıştır.

Görüldüğü üzere, **Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal hiyerarşik yapılanması dışında, ayrı bir teşkilat ve hiyerarşik yapılanmaya gidilerek, serbest demokratik seçimlerle iş başına gelmiş siyasi iktidarı hükümetten uzaklaştırma amacıyla kara, deniz ve hava unsurlarının tam bir işbirliği ve eylemli paylaşım anlayışı ile hareket ettikleri**, bu kapsamda;

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “İCRA SAFHASI” başlıklı bölümünde, “Bölücü Terör Örgütü ve El Kaide’nin büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da eş zamanlı büyük eylemleri ve anılan eylemler sonrasında icra edilecek, STK ve üniversiteler ile koordine edilerek yönlendirilecek çok geniş katılımlı toplumsal gösteriler ve eylemler neticesinde oluşan kaos ve karmaşa nedeniyle öncelikle **olağanüstü hal** ve sonrasında **sıkıyönetimin** ilan edileceği, ... **olağanüstü hal ve sonrasında sıkıyönetim ilanını müteakip derhal, AKP Hükümetinin iktidardan zorla uzaklaştırılarak ve mevcut irticai yapılanmanın şiddetle bertaraf edilerek, belirlenen kadroların iktidara getirilmesinin yolunun açılacağı**” belirtilmektedir.

Buna göre, **hükümetin iktidardan uzaklaştırılması için öncelikle, hükümetin olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına mecbur bırakılmasının gerekte olduğu**, bu noktada oluşumun deniz unsurlarının “SUGA”, hava unsurlarının “ORAJ” adlı harekat planlarına bakıldığında;

Suga Harekat Planının “VAZİFE” başlıklı bölümünde, “SUGA Komutanlığı tarafından, Sıkıyönetim Kanunu’nda belirtilen yetkilerin kullanarak iç tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi **seferberlik ilan edilmesi** maksadıyla;

- a. EGAYDAAK’larda (Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmiş Ada, Adacık ve Kayalıklarda)Yunanistan’ın Türkiye aleyhine fiili uygulamalarının engelleneceği,
- b. Ege Denizi’nde icra edilen tatbikatlarda Yunanistan ile çatışmaya varmaya gerginliği tırmandırıcı durumların oluşturulacağı,
- c. Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterileceği,
- ç. Emredildiğinde Yunan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alınarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetlerin icra edileceği”,

“İCRA” başlıklı bölümünde, “Harekâtın maksadının; Ege Denizi’nde Yunanistan ile çatışmaya varmayan faaliyetler ve küçük çaplı çatışmalarla krizi tırmandırmak ve kısmi seferberlik ilan edilmesi için gerekli ortamın oluşturulması” olduğu belirtilmekte,

Oraj Hava Harekat Planının “VAZİFE” başlıklı bölümünde, “Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan edilmesini sağlamak ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını sağlamak maksadıyla; Yunanistan’la

gerginliğin artırılacağı ve irtica yanlılarının tahrik edilerek TSK aleyhine faaliyetlere başlamalarının sağlanacağı, envanterindeki mevcut silah sistemlerini kullanarak psikolojik etki yaratılarak **hükümet ve TBMM üzerinde baskı kurulacağı**” ifade edilmekte,

“İCRA” başlıklı bölümünde, “Türk Hava Kuvvetlerinin Ege Denizindeki uçuşlarının sayısının artırılacağı, Türk savaş uçaklarının Yunanistan tarafından engellendiği ve taciz edildiğinin gündeme getirileceği,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ve özellikle Filolarda Yunan Hava Kuvvetlerine yönelik husumet ve gerginliğin kontrollü olarak artırılarak, pilotların uçuşlarda daha agresif olmalarının sağlanacağı, benzer olaylarda meşru müdafaa kapsamında atış dahi yapabileceği gayri resmi olarak pilotlara deklere edileceği,

Hükümetin sıkıyönetim ilan etmesi sağlanıncaya kadar faaliyetlere aralıksız devam edileceği” belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

EGAYDAAK (Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar) çalışma gruplarının oluşturulduğu, grupların anılan konuya ilişkin çalışmalar yaptıkları,

Harekatın başlaması ile birlikte **gözetim altına alınacak bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu gibi hassas şahısların Yassıada ve İmralı Ada’ya transferlerinin nasıl gerçekleştirileceklerine ilişkin planlamaların yapıldığı,**

Planın uygulanmasına engel olabilecek komutanların harekatın başlaması ile birlikte gözaltına alınmalarının kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, bu kapsamda Jandarma, Kara ve Deniz Kuvvetlerine yönelik hazırlanan “GEN ETÜD” ve “HASSAS PERSONEL LİSTESİ EK-C” adlı listelerde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 293 **general ve amiralin plan ve harekata destek durumlarına ilişkin, “destekler, desteklemez, (+), (-)** şeklinde tespitler ile ayrıca kimi isimler için ise *“kişiliksiz, geçimsiz, şahsi menfaatlerini ön plana çıkarır”* şeklinde değerlendirmelere de yer verildiği,

anlaşılmaktadır. ...

Yine, oluşumun deşifre olması durumunda alternatif hareket tarzlarının geliştirilmesi, muhtemel adli ve idari soruşturmalara yönelik tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışma grupları oluşturulmuş, **“ihtimalat planları”**nın hazırlanması yoluna gidilmiştir.

Jandarma unsurlarının, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanının sağlanması amacıyla hareket ortamının şekillendirilmesine yönelik yukarıda izah edilen “sakal” ve “çarşaf” eylem planları dışında, imza bloğunda Jandarma Kurmay Binbaşı HY’nın isminin yazılı olduğu “sivil toplum kuruluşlarına yönelik eylem planı”nda ise, **“Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu bilinen Rum Patrikhanesinin süresiz kapatılacağı, Patrik Bartholomeos ve diğer yöneticilerin tutuklanacağı, Rum Patrikhanesi’nin tüm mal varlığının, Türk Ortodoks Patrikhanesine devredileceği, azınlıklara ait eğitim kurumları, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıfların faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulacağı, zararlı faaliyette bulundukları tespit edilenlere el konulacağı, zararlı faaliyette bulunmaları neticesi el konulan azınlıklara ait eğitim kurumu, hastane, basın yayın organı, dernek ve vakıf yöneticilerinin mal varlıklarına el konulacağı”** öngörülmüş, bu hususa ilişkin olarak, 3. Kolordu 52. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral MYY, 05-07 Mart 2003 tarihinde icra edilen 1.Ordu Plan Seminerinde, *“İstanbul da yaşayan azınlıklara ait ibadet, eğitim kurumlarıyla, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıflar yansıda sunulmuştur. Yasalarımıza bağlı gözükmekle beraber Rum Patrikanesi’nin Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir”* şeklinde açıklamada bulunduğu da görülmüştür.

1.Ordu Komutanlığının görev alanında bulunan İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarının sorumluluk sahaları içinde, **“kilit görevlere atanacak personel”, “görevlendirilecek personel”, “tutuklanacak AKP üyeleri”, “gözaltına alınacak belediye başkanları”, “gözaltına alınacak siyasi parti üyeleri”, “görevli mülki amir ve belediye başkanlarının durumları”, “kapatılacak dernekler”, “plana destek verecek dernekler”, “kiliseler ve sinagoglar”, “arama yapılacak yerler”, “gözaltına alınacak irticai örgüt mensupları” ve “tutuklanacak irticai örgüt liderleri”**ni gösterir listelerin hazırlandığı, ... anlaşılmış olup,

Dosya kapsamındaki çalışmalara ilgili oldukları alanlar bakımından rakamsal olarak bakıldığında, yaklaşık; **5.000 subay ve astsubayın** (Özel operasyon ve sorgulama timlerinde, özel görevli toplama timlerinde, sıkıyönetim mahkemelerinde, darbe hareketi timlerinde, gözaltı timlerinde, hasar tespit timlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hastaneler ve ilaç depolarında, gümrükler, depolar, ambarlarda, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personeller, müzahir personeller, operasyonel faali-

yetleri yürütecek personeller, öncelikli ve özellikli görevlendirilecek personeller ve sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personelin yaklaşık 3500 kişi olduğu) sicil ve görev yerleri ile, **13.000 sivil** (Çeşitli bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında çalışan üst düzey kamu personeli, Yargıtay ve Sayıştay üyeleri, hakim, savcı, vali, kaymakam, belediye başkanı, emniyet mensubu, siyasi parti üye ve yöneticileri, öğrenciler vs.) **kişinin** görev yerleri ve bazı kişisel bilgileri ile, **2.000 tüzel kişinin** adresleri ile birlikte belirlenmiş kategoriler içinde listelendiği görülmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; **yürütme organını cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek için hazırlanmış elverişli bir plan olan Balyoz Güvenlik Harekat, Suga Harekat ve Oraj Hava Harekat planları ile diğer planların** ve bunlara ilişkin organizasyon, görevlendirme ve bu görevlendirmelerin gereklerine dair çok geniş bir coğrafi alana yayılan, **yaklaşık 20.000 gerçek kişi ve kurumu ilgilendiren 2003 yılına ait bilgi ve değerlendirmeleri içeren çalışmaların**, ... suç tarihinde sanıklar tarafından **amaç suça yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir anlaşma ile bu anlaşmayı takiben gerçekleştirilmiş icra hareketlerini gösteren belgeler** olduğu sonucuna varılmıştır.

...

1. Ordu Komutanlığı (bünyesinde) 05-07 Mart 2003 tarihinde icra edilen plan seminerinde **görevden uzaklaştırılması düşünülen bazı yer belediye başkanlarının adları ile imam hatip lisesi müdürlerine** yer verildiği, ... görülmüştür.

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “AST BİRLİKLERE GÖREVLER” adlı bölümünde, “Balyoz Güvenlik Harekat Planı’nın, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” isimli jenerik bir plan şeklinde oynanacağı plan seminerine kadar, **irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara ait mevcut tüm listeler ile teşkil edilecek olan özel görev timlerinin listelerinin güncelleneceği**” belirtilmiştir(tir.)

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “HAREKAT TASARISI” adlı bölümünde, “Devlet otoritesi hâkim kılınıncaya kadar kamu görevlerinin ifası için asker ve sivil şahıslar atanacağı, bu maksatla; **bütün kilit görevleri Askeri personelin devralacağı**, anılan kilit personelin, Harp Akademileri Komutanlığı, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve su-

baylardan, yetmediği takdirde emekli general, subay ve astsubaylardan tefrik edilerek, bu personele ait hazırlanmış olan isim listelerinin güncellenerek hazır tutulacağı” belirtilmiş(tir.)

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “HAREKAT TASARISI” adlı bölümünde, “Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinde (EK-M) olası değişiklikler hassasiyetle takip edilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği” belirtilmiş(tir.)

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının, “İCRA SAFHASI” adlı bölümünde, “Hiçbir hak ve özgürlüğün mutlak ve sınırsız olmadığı gibi, *konu laik devletin bekası olunca **haber verme ve basın özgürlüğünün de sınırsız ve mutlak olmadığı**, harekâtın icrası ile birlikte her türlü yazılı, sözlü ve görsel basın yayın kuruluşlarının kontrol altında tutulacağı, önceden tespit edilen AKP, yıkıcı, bölücü ve irticai gruplara müzahir (EK-C) tüm basın yayın kuruluşlarının yayınlarının **derhal durdurulacağı***” belirtilmiş(tir.)

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “MAKSAT” adlı bölümünde, “**Harekâtın maksadının; ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve laik demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırmak**” olduğu belirtilmiş(tir.)

Bu konu, planın “VAZİFE” başlıklı bölümünde ise, “**laik demokratik düzenin işlemesine mani olan sebeplerin, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırılması maksadıyla; derhal, AKP Hükümetinin iktidardan uzaklaştırılacağı ve mevcut irticai yapılanmanın şiddetle bertaraf edilerek, belirlenen kadroların iktidara getirilmesi ile laik devlet otoritesi ve varlığının yeniden tesis edileceği**” şeklinde vurgulanmış(tir.)

...

Balyoz Güvenlik Harekat Planının “YENİDEN YAPILANDIRMA SAFHASI” başlıklı bölümünde, “*İktidardan düşürülecek olan AKP Hükümetinin yerine planlanan Hükümet ve bürokratik kadroların görevi devralmasının*

sağlanacağı, DP iktidarından beri devam ettirilen muhafazakâr iktidarlara devlete sızan ve devlet bürokrasisine sinen bütün çağdışı anlayış ve izlerinin silinebilmesi için, ekli programı uygulayacak uzun süreli bir milli mutabakat hükümetinin oluşturulmasının temin edileceği” belirtilmiştir(tir.)

...

Yukarıdaki açıklamalar ve dosya kapsamına göre; ... **Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal teşkilat ve hiyerarşik yapılanması dışında amaç suçu işlemeye dönük ayrı bir yapılanmaya giden oluşumun, planlama, bu planlamayı hayata geçirecek kapsamlı bir organizasyon, bu organizasyona uygun bir iş bölümü, bu iş bölümü dahilinde görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerin gereklerine uygun çalışmaları yaptığı** sonucuna ulaşılmıştır.

IX. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin söz konusu onama kararında, bu olayla ilgili olarak aşağıdaki **hukuki değerlendirmelerde** bulunulmuştur:

A- Genel Olarak;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, kendisine ait olan egemenliği Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliği kullanmaya ilişkin yetki ve görev Anayasa tarafından Yasama, Yürütme ve Yargı erklerine verilmiştir. Bu erkler, esasen millete ait olan egemenliği Anayasanın görevlendirme ve yetkilendirmesine dayanarak kullanırlar. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Anayasanın 8. maddesine göre, yürütme, kullanılacak bir yetki ve yerine getirilecek bir görev olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulunun kullandığı devlet yetkisi Anayasadan kaynaklanmaktadır.

Anayasal bir erk olan yürütme erkinin ceza hukuku bağlamında korunması tabiidir. 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi, yürütme organının icra fonksiyonlarını, bu organın üyelerinden bağımsız olarak korumak için düzenlenmiştir. Bu düzenlemedeki koruma, yürütme organının bütün olarak siyasi icra fonksiyonlarına yönelik olduğundan, **korunan** elbette tek tek yürütme organına mensup kimseler veya bu kimselerin başında bulundukları bakanlıkların idari fonksiyonları değil, siyasi icra fonksiyonlarını bir araya getirecek oluşturdukları **yürütme organının bütünü**, yani **hükümet ile hükümetin siyasi icra fonksiyonları** olmaktadır. Aynı doğrultuda, Anayasanın

112. maddesinde, Bakanlar Kurulu, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden birlikte sorumlu tutulmuştur.

Yasa koyucunun doğrudan doğruya yürütme organını korumak amacıyla yapmış olduğu düzenleme sadece bu maddeden ibaret değildir. Gerçekten yasa koyucu, “yürütme organını cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek veya bunları teşvik eylemek” suçunu 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi (5237 sayılı TCK’nın 312. maddesi) ile cezalandırırken, bu suçun icra hareketlerinin dahi başlamadığı safhada “bu suçu işlemek için birkaç kişinin gizlice ittifak etmesini” 765 sayılı TCK’nın 171/2. maddesinde (5237 sayılı TCK’nın 316. maddesinde), “halkı hükümet aleyhine silahlı isyana teşvik etmek” suçunu ise 765 sayılı TCK’nın 149. maddesinde (5237 sayılı TCK’nın 313. maddesinde) düzenlemiş bulunmaktadır. Sanıkların eylemlerine uyan yasal düzenlemenin değerlendirilmesinde, yasa koyucunun hukuki konuya verdiği önem ve korunması bakımından yaptığı diğer düzenlemeler ile bunların niteliği de dikkate alınmalıdır.

Demokratik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti/Bakanlar Kurulu demokratik seçimler sonucunda ve anayasal prensipler çerçevesinde oluşur ve görev yapar. Hükümet, demokratik teamüllere ve anayasal kurallara uygun olarak, demokratik zeminde sürdürülen yarış sonucunda seçmenlerin tercihinine göre belirlenen siyasi partilere mensup yasama organı üyeleri tarafından kurulur ve siyasi iktidar bu siyasi kadrolar tarafından üstlenilir. Seçimleri kazanan siyasi partiler, hükümetler üzerinden siyasi iktidarı anayasal çerçevede kullanırlar ve doğal olarak da kendi programları çerçevesinde icraatta bulunurlar. Nitekim, Anayasamızın 68/2. maddesine göre de, siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Anayasa Mahkemesinin 30.07.2008 tarih ve 2008/1 esas, 2008/2 sayılı (Siyasi Parti Kapatma) kararında da belirtildiği gibi;

“Temsili parlamenter sistemin etkinliğini ve işlevselliğini siyasi partiler sağlar. Özgür siyasi partilerin olmadığı bir sistemin demokrasi olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. Çünkü siyasi partiler olmaksızın, toplumsal talep ve beklentilerin siyasal direktifler biçiminde somutlaşması, ulusal iradenin oluşması, toplumsal barışın sağlanması ve devlet yönetiminin halka dayanması mümkün değildir.

...

Siyasi partilerin kendilerine göre öne çıkardıkları ülke sorunlarına ilişkin farklı çözüm önerileri getirmeleri, demokratik siyasi yaşamda

üstlendikleri işlevin doğal sonucudur. Siyasi partiler devlet erkine yönelik toplumsal talepleri yalnızca dile getiren kurumlar değil, toplumsal direktifleri somutlaştıran, yorumlayan ve devleti yönlendiren yaşımsal kurumlardır”.

Diğer yandan, AİHM’nin 30 Ocak 1998 tarihli Türkiye Birleşik Komünist Partisi vd-Türkiye kararında ulaşılan sonuçta da vurgulandığı gibi, tarafı olduğumuz AİHS bakımından da **demokrasi yegane politik modeldir** ve siyasi partilerin rejimin bütününe etkileme kapasitesine sahip olmaları, oynadıkları rolün gereğidir. "Hiç kuşkusuz **demokrasi Avrupa kamu düzeninin temel bir unsurudur**. ... Bu ilk önce, Sözleşmenin, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin, bir yandan gerçekten etkili bir siyasal demokratik rejime ve öte yandan ortak bir insan hakları kavramına ve insan haklarına ortak bir saygıya dayandığını bildirerek, sözleşme ile demokrasi arasında çok açık bir bağlantı kuran, dibacesinden çıkmaktadır. ... Demokrasi Sözleşme tarafından tasarlanan yegane politik modeldir ve sadece o Sözleşmeyle bağdaşabilir.

...

İktidara gelen yegane oluşumlar olarak siyasi partilerin ülkelerindeki rejimin bütününe etkileme kapasitesine sahip olmaları, oynadıkları rolün gereğidir. Siyasi partiler siyasi arenaya müdahale eden diğer örgütlerden, seçmenlere sundukları toplumsal model önerileriyle ve iktidara geldikten sonra bu önerileri uygulama yetenekleriyle ayrılırlar". Bu nedenle, bir programın uygulanması vaadiyle demokratik serbest seçimler sonucunda millet tarafından iktidara getirilen siyasi partilerin, siyasi iktidarı kullanma bağlamında siyasi icraatlarda bulunmaları tabiidir. Siyasi partilerin her türlü denetiminin nasıl, kimler ve hangi kurumlar tarafından yapılacağı ile iktidardan uzaklaştırılmalarına ilişkin hukuka uygun-meşru yol ve yöntemler de Anayasa ve yasalarda gösterilmiştir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağına göre, **meşru yollarla işbaşına gelmiş bir siyasi iktidarın buradan uzaklaştırılması ancak, ilgili kurallar çerçevesinde ve yetkisini Anayasadan alan kurumlar eliyle olabilecektir.** Bu husustaki meşruiyet ve yetki çerçevesi Anayasadan, hukuka uygunluktan ve demokrasiden başka bir yerde, başka bir anlamda aranmamalıdır.

B- 765 sayılı TCK’nın 171 ve 5237 Sayılı TCK’nın 316. Maddeleri(ne) İlişkin Açıklamalar:)

Yukarıda da değinildiği üzere, yasa koyucu suçun konusunu farklı açılardan korumak üzere farklı suçlar düzenlemiştir. Bu bağlamda kalan ve 765 sayılı TCK'nın 171/2 ile 5237 sayılı TCK'nın 316. maddelerinde düzenlenmiş bulunan gizli ittifak suçu, “hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçunu hususi vasıtalarla işlemek konusunda gerçekleştirecek bir irade birliği ile tamamlanacaktır. Buradaki amaç suç cebren işlenecek olduğundan, **ittifak iradesinin de cebir içermesi gerektiği** tabiidir. **İttifakın; vasıtaları tespit etmiş olması, ciddi, amaca yakın ve korunan hukuki değeri tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması gereklidir.** Suçun oluşması için vasıtaların temin edilmiş olması gerekmez.

Bu ittifakın sağlanması ve ittifak edenlerin iradelerinin tek bir irade haline gelmesi ile bu suç oluşacağından, cebir de içeren bu ittifakın icabı olarak, bu ittifakı takiben amaç suçun icrası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, amaç suçun, yani hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme suçunun icra hareketleri sayılacaktır. Askeri Yargıtay Daireleri Kurulunun 05.11.1987 tarih ve 1987/103-161 sayılı kararında da belirtildiği gibi, “TCK'nun 171. maddesinde belirtilen ittifak suçu: İttifaka dahil kişiler arasında fikir uygunluğunun belirli, programlı bir şekle girmiş olması, vasıtaların tespit edilmesi ve gayeye yakın, ciddi ve tehlikeli olmasıdır. Teşekkül eden ittifakın gayeye ait birtakım faaliyetlerde bulunmuş olması halinde ise, esas suça ait icra hareketlerine başlanılmış olmaktadır.”

“Hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçunun işlenebilmesi için elverişlilik bakımından gerekli olan unsurlardan biri de, **bu suçu işleyecek olan elverişli sayıdaki failin, elverişli bir biçimde bir araya gelmiş ve elverişli vasıtalarla harekete geçmiş olmasıdır.** Bu bir araya gelme olgusu hem elverişlilik bakımından hukuksal bir gereklilik hem de icra hareketlerinin neticeye ulaşması bakımından fiili bir zorunluluktur. Dolayısıyla sanıklara yüklenen suçun işlenmesi bakımından gerekli olan icra hareketlerinin başlangıcında, bu icra hareketlerini amaç suç istikametinde yönetecek, yönlendirecek bir anlaşmanın bulunması zorunludur.

Bu açıdan bakıldığında; **Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Suga Harekat Planı ve Oraj Hava Harekat Planının hedef, yöntem ve içerikleri, bu planların birbirleri ile uyumları, ortaya koydukları amaç, organizasyon ve çalışmalar, diğer belgeler ve seminer konuşmaları ile tüm dosya kapsamından, sanıkların meydana getirdikleri oluşumun, icra hareketleri başlamadan önce amaç suçun işlenmesine ilişkin bir ittifakı içerdiği açıkça görülmektedir.**

Sanıklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik organizasyonu içerisinde hareket etmeyip illegal bir oluşum olarak faaliyet gösterdiklerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru emir komuta zinciri dışına çıkabilen, gizliliğe, güvenliğe, denetime önem veren **ayrı bir hiyerarşik yapı** oluşturduklarından, oluşum çerçevesindeki **görevlerin** Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru hiyerarşik yapısı yerine **bu illegal hiyerarşi kapsamında verildiği** ve bu nedenle görevlerin tebliği ve kabulünün yasal askeri hiyerarşi ve bu hiyerarşiye ilişkin teamüller yerine, bu yasadışı oluşuma ilişkin hiyerarşi kapsamında ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır. **Amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevlerin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,** yapılan görevlendirmelerin kendi içerisinde ve sanıkların görev ve konumları ile uyumlu olduğu, planın diğer asli ve tali belgeleri ile paralellik gösterdiği, bu görevlendirmelere dair gereklerin pek çoğunun planın icrası kapsamında yerine getirilmiş olduğu da nazara alınarak; gizlilik, güvenlik ve denetime önem veren böyle bir yasadışı oluşumda, önceden tebliğ yapılmadan ve görevin kabulüne ilişkin teyitler alınmadan, belirli derecelerdeki görevlendirmelerin yapılmayacağını ve kayda geçirilmeyeceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Buna göre; **gerçekleşen ittifak olgusunun 765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312. maddelerinde düzenlenen suçu işlemeye yönelik olduğu,** bu suçu hususi/elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin bulunduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve **amaç suça yönelik olarak harekete geçmekten başka yapacak bir şey kalmayacak şekilde tamamlandığı** görülmektedir. Sanıklarca gerçekleştirilen ittifak, suçun hem 765 sayılı TCK'daki hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurlarını taşımaktadır.

Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı kararında da belirtildiği gibi, ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir. Buna göre; amaç suça yönelik icra hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen, ancak; amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde saptanamayan sanıkların hukuki durumunun, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince ittifak suçu kapsamında kaldığının kabulü gerekmiştir.

Mütemadi bir suç olan ittifak suçunda, suç tarihi temadinin kesildiği tarihtir. Buna göre; gerçekleştirilen ittifak sonrasında bir kısım sanıklarca başlatılan icra hareketlerinin elde olmayan nedenlerle tamamlanamadığı somut olayda, icra hareketlerinde bulundukları kesin olarak saptanamayan bir kısım sanıkların ittifak halinin de, aksi kanıtlanmadığı sürece; icra hareketlerinin yarıda kaldığı bu aşamaya kadar temadi edeceği kabul edilmelidir. Somut olayın özellikleri nazara alındığında olaydaki ittifakın; birleşen iradeleri, hususi ve elverişli vasıtaları, gizliliği ve maddi olgularla belirlenme ölçütünü koruyacak biçimde soruşturmanın başlangıcına kadar temadi ettiğinin kabulü, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda, “Hükûmeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçunu işlemek üzere oluşan ittifaka dahil olup da bu yönde icrai bir faaliyette bulunmayan bir kısım sanıkların soruşturmanın başlamasından evvel bu ittifaktan çekilmiş olduklarının kabulü gerekir.

Bu kapsamda, 765 sayılı TCK’nın gizli ittifak suçunu düzenleyen 171. maddesinin son fıkrasında “Cürmün icrasına ve kanuni takibata başlanmazdan evvel bu ittifaktan çekilenler ceza görmezler” ve 5237 sayılı TCK’nın 316. maddesinin 2. fıkrasında “Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez” denilmek suretiyle etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir. Yukarıda da açıklandığı gibi, somut olaydaki suçun icrasına başlanmasından sonra, ancak; “soruşturmaya başlanmadan önce” gerçekleşen ve çekilme olarak kabul edilmesi gereken halin, 5237 sayılı TCK’nın 316. maddesinin 2. fıkrasına uyduğu ve bu düzenlemenin ittifak suçunu işledikleri kabul edilen sanıklar bakımından lehe olduğu anlaşılmaktadır.

C- Cebir/Şiddet ve Elverişlilik Unsuru(na İlişkin Açıklamalar:)

Amaç suça ilişkin maddede aranan **cebir/şiddet**, her durumda ve her aşamada dar anlamıyla **maddi cebir, fiziki kuvvet kullanımı olarak anlaşılmalıdır. Suç, elverişli olmak kaydıyla manevi nitelikteki bir cebirle de işlenebilecektir.** Buradaki cebrin, suçun konusu, suçla korunan hukuki yarar da dikkate alındığında; hukuka aykırı iradede mevcut, cebirle ulaşılabilecek hukuka aykırı amaçlara cebir içeren zorlayıcı iradeyle yönelmiş ve gerektiğinde fiziki cebir kullanacağı, fiziki cebirle sürdürüleceği duraksamaya yer vermeyecek biçimde ortaya çıkmış hareketler olarak anlaşılması zorunludur. Dolayısıyla maddedeki cebir geniş anlamıyla kabul edilmelidir.

Cebrin/şiddetin niteliği ve mevcudiyeti somut olay çerçevesinde belirlenirken, failin kullandığı vasıtalar, suçun konusu olan hükûmet ile konumu ve

ilişkisi, kullandığı cebren şekli, kaynağı, etki alanı, düzeyi, cebir kullanmaya ilişkin olarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile mümkün olan engel sebepler de dikkate alınmalıdır. Siyasi iktidar düzeni ve fonksiyonları aleyhine suçların, genel olarak devlet düzeni dışında kalan kimseler, terörist gruplar gibi suç örgütleri tarafından işlenmesine girileceği düşünülebilirse de; başka ülkelerdeki örneklerde de görüldüğü gibi, özellikle yürütme erkini cehren ıskatı suçunun, genellikle o ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup faillerce işlendiği görülmektedir. Zaten yasal düzenlemede bu suç, failer bakımından bir özellik göstermemekte, **devlet düzenine dahil faillerce de bu suçun işlenebileceği** görülmektedir. Önemli olan, hukuka aykırı bir biçimde, cebri nitelikteki amaç suça yönelen yasadışı oluşumun, bu suçu işlemek bakımından gerekli elverişliliğe sahip olup olmamasıdır.

Dava konusu olayda, hükümeti cehren ıskat veya vazife görmekten cehren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu ittifakın sağlanmasından sonra, amaç suçun icrasına başlanmasından tüm neticelerinin gerçekleşmesine kadarki safhaları belirleyen bir planlama, bu planlamayı hayata geçirecek kapsamlı bir organizasyon, bu organizasyona uygun bir iş bölümü, bu iş bölümü dahilinde görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerin gereklerine uygun görüşmeler, çalışma grupları, fişlemeler, takipler, keşifler, istihbarat faaliyetleri ile özel operasyon ve sorgulama, özel görevli toplama, darbe harekatı, gözcülük ve hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personeller, sıkıyönetim mahkemelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hastaneler ve ilaç depolarında, gümrükler, depolar, ambarlarda, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personeller, operasyonel faaliyetleri yürütecek, öncelikli ve özellikli görevlendirilecek personeller, müzahir subay ve astsubaylar, keşif timleri, tahrip timleri, hassas personel, ilişkisi kesilecek personel, tutuklanacaklar, toplama merkezleri, gıda depoları vb. yerlerin belirlenmesine kadar Balyoz Güvenlik Harekat Planındaki ifadesiyle “harekat ortamının şekillendirilmesi”, maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin kolaylaşması, aksamadan yürütülmesi ve amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını sağlayacak binlerce belgeyi bulan çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren ve artık karşı koymanın mümkün olmadığı “sokağa çıkma” diye tabir edilen hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir birimde bulunmayan zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü başta plan kapsamındaki istihbarat çalışmaları olmak üzere diğer çalışmalar sırasında da kul-

landıkları görülmektedir. Sanıklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı, görev ve yetki sınırları içerisinde kaldıkları sürece, anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç güvenlik görevleri doğrultusunda meşru bir cebri kullanabilecek olan kimselerdir. Ancak, sanıklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı dışında ve mensubu olmakla sahip oldukları silahlı güce ve kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana getirdikleri oluşumla, icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etmeye girişmişlerdir. Esasen yurt savunması ile görevli olan, sahip olduğu teşkilat, teçhizat ve personeliyle uluslararası alanda bile caydırıcı bir gücü bulunan, Devlet düzeni dışındaki suç örgütlerinden gelecek saldırılara karşı iç güvenlik kapsamında emniyet ve asayişin temini de görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup sanıkların kullanabilecekleri cebre karşı, icra organının mukavemet edebilme imkan ve kabiliyeti bulunmamaktadır. Zira, planlama doğrultusunda, emniyet kuvvetlerini de etkisiz hale getirip sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik imkanlarını kullanacak olan sanıkların, amaç suça öngörülen neticeyi elde etmek yolunda hiçbir maddi engelle karşılaşmayacakları açıktır. Kaldı ki; bu yasadışı oluşum tarafından bu oluşuma yakınlıkları değerlendirilerek hazırlanmış bulunan “Gen Etüd” listesi ve benzeri listeler ile müzahir listeleri de dikkate alındığında, sanıkların amaç suçu işleme ve mümkün olan engel sebeplerin ve kişilerin bertaraf edilmesi yönünde aldıkları mesafe göz önünde bulundurulmalıdır. Suçun oluşumu için gerekli olan cebir/şiddet ve elverişlilik gibi unsurların değerlendirilmesinde, bu hususlar da nazara alınmalıdır.

Bu kapsamda; **sanıklara yüklenen eylemin kanıtlanan şekliyle 765 sayılı TCK’nın 147. ve 5237 sayılı TCK’nın 312. maddelerinde düzenlenen suçları oluşturduğu** ve mahkemece yapılan lehe yasa değerlendirmesinin sonucu itibariyle isabetli olduğu neticesine varılmış, eylemlerinin neticeyi oluşturmaya elverişli olmadığı ve cebir/şiddet içermediğine ilişkin olarak ileri sürülen itirazlar yerinde görülmemiştir.

Ayrıca, sanıklara yüklenen suçun niteliği ve işleniş şekli itibariyle; amaç suçu birlikte işlemeye yönelmiş icra hareketlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi zorunludur. Pek çok sanık bizzat işledikleri araç eylemler/suçlarla, hep birlikte yöneldikleri amaç suçu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Gerçekleşen ittifakın amacına uygun, aynı zamanda sanıkların görev ve konumlarıyla uyumlu bir iş bölümü; suçun niteliği ve işleniş şekli bakımından bir gerekliliktir. Bu nedenle **amaç suç bakımından suçun işle-**

nişine 765 sayılı TCK'nın 65/3 ve 5237 sayılı TCK'nın 39. maddelerinde düzenlenen iştirak hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Yüklenen amaç suçun işlenmesi bağlamında gerçekleştirilecek eylemlerin ayrı bir suç oluşturması halinde bu suçlara anılan biçimde iştirak mümkündür. Ancak bu tür bir iştirakin mümkün olduğu araç suçlar, 765 sayılı TCK bakımından amaç suç içerisinde fikri içtimaya uğrayacağından ayrıca cezalandırılmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı, amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içerisinde oldukları tespit edilen sanıklar arasında amaç suça gösterilen biçimde iştirak bakımından bir ayırıma gidilmeyip, **asli fail** olarak sorumlu tutulmalarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Nitekim konu, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.02.1992 tarih, 1991/364 esas ve 1992/23 sayılı ve 22.12.2009 tarih, 2009/93-308 sayılı kararlarında **765 sayılı TCK'nın 125. maddesi bakımından tartışılmış ve aynı Kanunun 65/3. maddesinde düzenlenen iştirak hükümlerinin uygulanma imkanının bulunmadığı** sonucuna varılmıştır.

B. HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ:

I. Yapmış bulunduğumuz incelemeler sonucunda, İlk Derece Mahkemesi olarak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen söz konusu mahkûmiyet hükmünde kısaca “darbe suçu” olarak ifade edilen suça, bu suç bağlamında hazırlık ve icra hareketleri ayırımına ilişkin olarak yer verilen açıklamalar ile olayın tavsifi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde önemli hukuka aykırılıkların ve hataların olduğu tespit edilmiştir.

Baştan belirtmemiz gerekir ki, açıklamalarımız bağlamında,

a) sübut yönünden,

b) delillerin elde ediliş yöntemleri itibarıyla hukuka uygun olup olmadığı hususunda,

değerlendirme yapılmamıştır.

Söz konusu olaylarla ilgili hukuki değerlendirmeler bağlamında, Kitabımızın Anayasayı ihlal suçu, Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç ve Suç için anlaşma suçu ile ilgili 8. Praragrafındaki açıklamalara bakılmalıdır.

Söz konusu açıklamalarımız karşısında, **Gerekçeli Karardaki**, “darbe suçu” olarak ifade edilen mülga 765 s. TCK'nın 147. maddesinde ve yeni TCK'nın 312. maddesinde tanımlanan **suçun icrasına başlandığı yönündeki kabullün bilimsel dayanağının olmadığı** sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Gerekçeli Kararda belirtildiği gibi, harekât planlarının hazırlanmasıyla suçun düşünce aşamasından çıktığı doğrudur. Ancak, söz konusu suça yönelik olarak yapılan planlama faaliyetlerinin “icra hareketi” olarak değerlendirilmesi, yukarıda ortaya koymuş bulunduğumuz hazırlık – icra hareketi ayırımına yönelik ölçütler karşısında doğru olmamıştır.

Gerekçeli Kararda yer verilen *“darbe suçunun icra hareketlerinin tankların sokağa çıkmasıyla sınırlı olmadığı, aksine cunta yapılanmasına bağlı birimlerin sokağa çıkmasının neticeye en yakın son icra hareketi olduğu,”* değerlendirmesi de doğrudur. Ancak, bu tespit, mülga 765 s. TCK’nın 147. maddesinde ve yeni TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan suçun icrasına başlanabilmesi için cebri fiillerin varlığının gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir ifadeyle, söz konusu suçun icrasına başlayabilmek için, tankların sokağa çıkması şart değilse de, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye elverişli tarzda “cebir ve şiddet” (doğru ifadeyle, cebir veya tehdit) kullanılması şarttır.

Gerekçeli Kararda yer verilen şu açıklamalar doğrudur:

“765 sayılı TCK’nın 147. maddesinde suçun tamamlanması için ıskat veya men neticelerinden birinin varlığı aranırken. 5237 sayılı TCK’nın 312. maddesinde maddi bir neticenin doğumu aranmamış, teşebbüs edilmesi yeterli görülmüştür. Cebir maddi veya manevi zor kullanma olabilir. Fakat **cebir ve şiddet kullanılarak hükümetin varlığına son verilmesine veya görevinin kısmen de olsa engellenmesine yönelik eylemler** bu suçu oluşturmaktadır. Eylem hükümetin ortadan kaldırılmasına yönelmemekte veya buna elverişli bulunmamakta ve fakat **kısmen de olsa elverişli hareketle görevini yapmasını engellemeye teşebbüs edilmekteyse** 5237 sayılı TCK’nın 312. maddesinde tarif edilen suçun oluştuğu kabul edilir.” (sh. 997)

Ancak, Gerekçeli Kararda yer verilen şu açıklamalar, **çelişkilerle** maluldür:

*“Hükümetin ortadan kaldırılması veya görevinin engellenmesi, failin suçla elde etmeye çalıştığı amaçtır. Amacını gerçekleştirmek için **cebir ve şiddetle icraya başladığı takdirde suç oluşur.** Fakat amaca yönelik olarak icrasına başlanılan hareketin, amaca yönelik tehlike oluşturmaya uygun ve elverişli bulunması gerekir. **Elverişli hareketin belirlenmesinde hareketin ortadan kaldırma veya engelleme neticelerine elverişliliğini değil bu neticeler bakımından tehlike oluşturma oluşturmadiğının incelenmesi gerekir. Failin korunan değeri tehli-***

keye düşürmeye elverişli bir hareketle icraya başlaması yeterlidir. Diğer yandan, suçun cebir ve şiddetle işlenmesi gerekliyse de icrasına başlanılan hareketin de mutlaka cebir ve şiddet içermesi zorunlu değildir. Failin amacına yönelik olarak başladığı icra hareketinden hareketi tamamlamaya yönelik biçimde devam edecek olan davranışlarının cebir ve şiddet içereceğinin anlaşılması yeterlidir.” (sh. 997)

“Asıl fiile oldukça uzak olan failin gerçek amacı bakımından belirsizlik arz eden hareketler hazırlık hareketleridir. Failin suç kastından şüphe edilmeyecek derecede fiile yaklaşmış olduğunu anlatan hareketler icra hareketleridir.” (sh. 998)

Görülmektedir ki, Gerekçeli Kararda yer verilen hazırlık ve icra hareketleri arasındaki ayırım ile elverişlilik konusundaki açıklamalar, suç teorisinin günümüzde ulaşılmış bulunduğu gelişmişlik düzeyi itibarıyla artık kabul görmeyen **sübjektif teoriyi** esas almaktadır⁸⁴. Oysa yukarıda açıkladığımız gibi, yeni TCK’nın hazırlık ve icra hareketleri arasındaki ayırım ile elverişlilik konusundaki hükümleri, objektif teoriyi esas almıştır. Bu itibarla, Gerekçeli Karar, yeni TCK’nın ilgili suç hükümleri ile teşebbüse ilişkin hükümleri göz ardı edilerek kurulmuştur.

Gerekçeli Kararda,

“Suç işlemeye elverişli vasıta ve imkanlarına sahip olmak ve bunu henüz kullanmaya başlamadan göstermek suçun icra hareketlerine başlaması olarak değerlendirilebilir.”

açıklamasına yer verilmiştir (sh. 998). Bu kabule göre, örneğin B’yi öldürmeye karar vermiş olan A, bunun için ihtiyaç duyduğu silah ve mermileri temin etmiş olması halinde, kasten öldürme suçunun icrası başlamış olacaktır. Çünkü A, B’yi öldürme konusunda kararını vermiştir ve her ne kadar kullanmaya başlamamış ise de öldürmek için elverişli olan vasıta ve imkanlara sahiptir. Günümüz ceza hukuku anlayışında bu kabulün yeri yoktur.

Gerekçeli kararda yer verilen şu açıklamaların da bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır:

“Fail yaptığı hareketleri yapılmamış addettirmek imkanına sahip ve yaptığı hareketin bütün iz ve eserlerini silebilecek durumda bulun-

⁸⁴ Söz konusu teori hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SOYASLAN, Doğan: *Teşebbüs Suçu*, Ankara, 1994, sh. 31 vd.; SÖZÜER, Adem: *Suçta Teşebbüs*, İstanbul 1994, sh. 79 vd.

yorsa icra bitmemiştir, ... Buna karşılık, fail ne yaparsa yapsın yapılmış olan hareketlerin bütün eser ve izlerini ortadan kaldıramıyor bu hareketlerin yapılmamış sayılmasını sağlayamıyor, sadece zararlı neticenin gerçekleşmemiş ise icra bitmiştir, ...” (sh. 998/999)

Bilinmesi gerekir ki, gerçekleşmiş olan bir fiili icra edilmemiş duruma irca etme imkânı bulunmamaktadır. İcra edilmemiş bir duruma irca edilemeyen fiilin iz ve eserlerini de ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Gerekçeli Kararda, karara konu teşkil eden olay bağlamında lehe kanunun belirlenmesinde mülga 765 s. TCK’nın 147. maddesi düzenlemesiyle yeni TCK’nın 312. maddesi düzenlemesinin karşılaştırılmasının yapılmasının doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bu karşılaştırma ancak “darbe suçu” olarak ifade edilen Hükûmete karşı suça ilişkin icra hareketlerinin gerçekleşmesi halinde mümkün olabilirdi. Oysa **Gerekçeli Karara konu teşkil eden olayda**, yukarıda da belirttiğimiz gibi, “**darbe suçu**” olarak ifade edilen Hükûmete karşı suça ilişkin icra hareketlerinin varlığından söz edilemez⁸⁵.

⁸⁵ İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.9.2012 tarihli ve E: 2010/283, K: 2012/245 sayılı Kararını temyizi amacıyla hazırlanmış olan dilekçe Duygun Yarsuvat tarafından kitaplaştırılmış (1. Baskı – Mayıs 2013, ISBN 978 - 605 - 125 - 987 - 1) ve bu kitaba “sunum” yazısı yazılmıştır. Sayın Yarsuvat, söz konusu “sunum” yazısıyla bağlantılı olarak isminin önünde “Prof. Dr.” unvanlarını kullanmış ise de, bu yazının kaleme alınmasında akademik bir üslup kullanmamıştır.

Sayın Yarsuvat, söz konusu “sunum” yazısında;

“Almanya’da Max-Planck Enstitüsünde lisansüstü çalışmalarını yapan bazı genç hukukçuların da, Türk Ceza Kanunu ve Ceza muhakemesi Kanununu yazarken (Alman ceza hukukçusu Günter Jakobs’un ortaya attığı DÜŞMAN CEZA HUKUKU’ndan bahisle) bu görüşün etkisi altında kalarak Türk Ceza Hukukuna düşman ceza hukuku prensiplerini geçirdiklerini izlemekteyiz”

ifadelerine yer vermiştir.

Sayın Yarsuvat, bu yazısında özellikle yeni Türk Ceza Kanununun TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında yazım görevini ifa etmiş bir kişi olarak şahsını hedef almıştır.

Sayın Yarsuvat’ın, “*düşman ceza hukukunda failin kusurunun önemi yoktur*” belirlemesinde bulunduktan sonra, yeni Türk Ceza Kanununda hangi düzenlemelerin kusura dayalı sorumluluk ilkesiyle çelişerek, ya da malum “düşman ceza hukuku”na ilişkin hangi “ilke”ler esas alınarak kaleme alındığını somut olarak göstermesi gerekmez miydi?

Aslında bu “sunum” yazısında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Bir yandan “Düşman ceza hukuku”ndan bahsedeceksiniz, öte yandan bu hukuka ilişkin “ilkeler”den söz edeceksiniz. Aslında malum “düşman ceza hukuku” telakkisi, ceza hukukuna ilişkin pek çok prensibin ihlali ni meşrulaştırma çabasını ifade etmektedir. Kural ihlallerine dayalı bir düşüncenin “ilkeler”inden bahsedilmesi doğru olmamıştır.

Keza, söz konusu “sunum” yazısı ile temyiz dilekçesinin içeriği arasında da çelişki bulunmaktadır. Temyiz dilekçesinin hazırlanmasında eserlerine atıfta bulunulan akademisyenlerden bahisle, “*ülkemin tanınmış ceza hukukçuları*” nitelemesinde bulunulmuştur. Sayın Yarsuvat,

Bu durumda, Gerekçeli Karara konu teşkil eden olayın mülga 765 s. TCK'nın 171. maddesiyle yeni TCK'nın 316. maddesi düzenlemeleri itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Her ne kadar Gerekçeli Kararda, suçun “*icra*”sına başlanıldığı ve fakat 2003 yılı Ağustos ayı itibarıyla “*cunta yapılanmasının darbe suçunu işleme el-verişliliğini kaybettiği ve icra hareketlerinin tamamlanamadığı*” kabul edilmekte ise de; “*bu tarihten sonra da Balyoz Darbe Planı çerçevesinde uygun ortam bulunduğu darbenin gerçekleştirilebilmesi, hukuki alanda haklarında takibata başlanma ihtimaline karşı gerekli hukuksal alt yapının hazırlanması gibi amaçlara yönelik olarak bir kısım sanıkların ve dava dışı kişilerin çalışmaları devam etmiştir. Devam eden bu çalışmalar kapsamında listeler güncellenmiş ve yeni çalışmalar yapılmıştır. Ancak cunta yapılanması haklarında soruşturmaya başlanılmasına kadar, bir daha Ağustos 2003 ve öncesi konumuna yani darbe suçunu gerçekleştirebilme yeterliliğine ve ortamına ulaşamamıştır. Bu tarihten sonraki belgeler faaliyetin gizlenmesine veya yeniden toparlanma amacına yönelik çalışmalar olarak kabul edilmiştir*” tespit ve değerlendirmesinde bulunulmuştur (sh. 1023, ayrıca bkz. 1036 vd.). Gerekçeli Kararda olgu olarak kabul edilen güncellemeler de, bu fiillerin 5237 s. TCK'nın 316. (765 s. TCK'nın 171.) maddesinde tanımlanan suç bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu durumda suçun icrasının tamamlandığı tarih olarak, söz konusu Harekât Planlarında **son güncellemenin yapıldığı tarihi** dikkate almak gerektiğini düşünmekteyiz.

Gerekçeli Hükümde, “*1. Ordu merkezli cunta yapılanması*” (sh. 985) ve “*sanık Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanması*” (sh. 1023) gibi ibareler kullanılmış ise de, sanıklar arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında mevcut olan hiyerarşik ilişkinin dışında bir hiyerarşik yapılanmanın

“sanık müdafii” sıfatıyla altına imza attığı temyiz dilekçesinde eserlerine atıfta bulunulan ceza hukukçuları arasında yeni TCK ve CMK'nın TBMM'deki hazırlık çalışmalarında görev yapan akademisyenlerin de yer aldığını görememiştir. Keza Sayın *Yarsuvat*, “sanık müdafii” sıfatıyla altına imza attığı temyiz dilekçesinde yer alan, sanıklara yöneltilen suçlamalar bağlamında 5237 s. TCK hükümlerinin mülga 765 s mülga TCK hükümlerine nazaran daha lehte olduğu yönündeki açıklamalardan habersizdir.

Aslında Sayın *Yarsuvat*'ın yeni Türk Ceza Kanunu ile ilgili rahatsızlığının temelinde, Kanunun **dava zamanasını kesmeye ilişkin hükümleri** yatmaktadır. Bu bağlamda, TCK'nın 67. maddesinin iki ilâ dördüncü fıkralarında düzenlenen dava zamanasının kesilmesine ilişkin hükümlere yönelik olarak **Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler**, (8. bası Ankara, Ocak 2013, sh. 820 vd.) künyeli kitabımda yer alan açıklamalara bakılmasını öneririm.

varlığından söz edilmemiştir. Bu durum karşısında, Gerekçeli Hükümde suç örgütünü çağrıştırır biçimde “cunta yapılanması” ibaresinin kullanılması doğru olmamıştır.

Gerekçeli Hükümde, “*özellikle darbe hazırlıklarının güncelleneceğine ilişkin talimatları içeren belgeler*” göz önünde bulundurularak, delil olarak kullanılan bu bilgisayar kayıtlarının “*sanıkların ya da sanıklardan bu çalışmaları devralmış dava dışı kişilerin elinde*” tutulmuş olduğu kabul edilmiştir (sh. 1040). Mahkemenin bu kabulüne göre, söz konusu plan çalışmaları, 2003 yılının Ağustos ayı itibarıyla son bulmuş değildir. Bu tarihe kadar oluşturulmuş olan bilgisayar kayıtları üzerinde bu tarihten sonra da güncelleme faaliyetinin icra edildiği, mahkemece kabul edilmiştir. Ancak, Mahkeme Kararında kullanılan “*sanıklardan bu çalışmaları devralmış **dava dışı kişiler***”den kimlerin ve neyin kastedildiği anlaşılamamıştır. Önemle belirtmemiz gerekir ki, ceza muhakemesi hukukunda “*dava dışı kişi*” diye bir kavram mevcut değildir. Darbeye teşebbüs edildiğinin, fakat “icra”sının 2003 yılının Ağustos ayında akamete uğradığının, söz konusu hareket planlarına ilişkin bilgisayar kayıtları üzerinde bu tarihten sonra da güncelleme faaliyetinde bulunulmuş olduğunun kabulü karşısında, bu faaliyetleri icra eden ve sanıklar dışındaki kişilerin de ceza hukuku sorumluluğunun olup olmadığının tartışılmamış olması, Mahkeme Kararı bakımından önemli bir eksikliktir.

Gerekçeli Hükümde, içeriklerinde çelişkiler bulunan bilgisayar kayıtlarının hukuken geçerli delil olma özelliği taşıyıp taşımadığı konusunda yapılan değerlendirmede, bu çelişkilerin “*yakalanmaları halinde kullanılmak üzere **biz-zat sanıklar tarafından bilerek yapıldığı ihtimali***”ne dayanılmış olması (sh. 1040), **hatalı hüküm** bakımından önemli bir **kürsü örneği** oluşturmaktadır.

II. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu mahkûmiyet hükmünü onaylayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, TCK’nın 316. maddesinde tanımlanan “Suç için anlaşma” suçunun bir somut tehlike suçu olduğu yönündeki değerlendirmelerinin doğru olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre, işlenmesi amaçlanan “suçu işleyecek olan elverişli sayıdaki failin, elverişli bir biçimde bir araya gelmiş ve elverişli vasıtalarla harekete geçmiş olması” gerekmektedir.

9. Ceza Dairesinin kararında, somut olayda sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında bulunan emir komuta zincirinin dışına çıkarak “ayrı bir hiyerarşik yapı oluşturdukları” kabul edilmiştir. Ancak bu hiyerarşik yapıya ilişkin olarak karar içeriğinde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Ayrı bir hiyerarşik yapıdan söz edebilmemiz için, meydana getirilen yapılanmada görev alan askerler arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde mevcut olan hiyerarşik ilişkinin dışına çıkılması; yani ast konumundaki bir asker kişinin emir veren, üst konumunda bulunan bir asker kişinin de emirleri yerine getiren konumuna getirilmiş olması gerekmektedir.

Hatta ayrı bir hiyerarşik yapıdan söz edebilmemiz için, meydana getirilen yapılanmada Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde herhangi bir görevi bulunmayan kişilerin de, darbe teşebbüsü bağlamında askerlere emir ve talimat verebilecek bir konuma getirilmiş olması gerekmektedir.

Aslında Dairenin bu kararı içinde bir çelişki bulunmaktadır. Şöyle ki, bir yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında bulunan emir komuta zincirinin dışına çıkıldığı kabul edilmiş; diğer yandan da “*yapılan görevlendirmelerin kendi içerisinde ve sanıkların görev ve konumları ile uyumlu olduğu*” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Daire bu kabullerine rağmen, İlk Derece Mahkemesi gibi, sanıklar hakkında ayrıca TCK’nın 314. maddesine istinaden hüküm kurulması gereğine ihtiyaç hissetmemiştir. Bu kabulün hukuki dayanağının bulunmadığını belirtmek gerekir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İlk Derece Mahkemesi gibi, söz konusu darbe planlarıyla ve bu planların uygulamaya konulmasına yönelik olarak “seminer çalışması” adı altında yapılan toplantılarla, TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan “**Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs**” suçunu işlediklerini kabul etmiştir.

Daire, söz konusu onama kararında, sanıklar tarafından “**gerçekleşen ittifak olgusunun 765 sayılı TCK’nın 147. ve 5237 sayılı TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen suç** ... hususi/elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin bulunduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve **amaç suça yönelik olarak harekete geçmekten başka yapacak bir şey kalmayacak şekilde tamamlandığı**” değerlendirilmesinde bulunmuştur.

TCK’nın 309, 311 ve 312. maddelerinde tanımlanan suçların, sadece maddi anlamda “cebir ve şiddet” kullanılarak değil, “manevi cebir” kullanılarak da, yani tehditle de işlenebileceği yönündeki değerlendirmeler, doğrudur. Ancak, yargılama konusu olayda, yapılan darbe planları ve bu planların uygu-

lanmasına yönelik “seminer” çalışmaları ile, TCK’nın 312. maddesinde tanımlanan **“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”** suçunun “icra” hareketlerinin başladığı kabul edilmiştir. Daire’ye göre, **“amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını sağlayacak binlerce belgeyi bulan çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren ve artık karşı koymanın mümkün olmadığı ‘sokağa çıkma’ diye tabir edilen hareketlerin kaldığı** anlaşılmaktadır.”

Daire kararına göre, “dosya kapsamından, **sanıkların** Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir birimde bulunmayan **zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü başta plan kapsamındaki istihbarat çalışmaları olmak üzere diğer çalışmalar sırasında da kullandıkları görülmektedir.**” İstihbarî faaliyet sırasında, darbe planlarının hazırlanması evresinde de cebir ve tehdidin kullanıldığı yönündeki bu kabulün maddi dayanağı anlaşılamamıştır.

Sonuç itibarıyla şunu söyleyebiliriz: Hazırlık – icra hareketi ayırımında 19. yüzyıl ceza hukukunda kabul gören sübjektivist görüşün etkisinde verilen söz konusu mahkûmiyet hükmünün yanlışlığı, bu teorinin dayanaktan yoksun olması sebebiyle değil, delillerin hukuka aykırı bir yolla elde edildiği kabulüne dayanılması, bir suçluluk olayının örtülmesi, suç işleyen kişilerin “mağdur” izlenimiyle ortalıkta dolaşması sonucunu doğurmuştur.

Nitekim söz konusu onama kararından sonra, bu hükmün dayanağını oluşturulan delillerin “hukukiliği” zemininde başlatılan bir tartışma üzerine, bu davada **yargılamanın yenilenmesi** yoluna gidilmiş ve yeniden yapılan yargılama sonucunda, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2015 tarihli kararı ile sanıkların tamamıyla ilgili olarak **beraate** hükmedilmiştir.

Söz konusu beraat hükmü, temyizen incelenerek karar verilmek üzere, halen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin önünde beklemektedir.

EKSKURS 19: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE

1. Bir gazetecinin 2008 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınır. 70 sahifeden ibaret olan ve esasında gizli olması gereken bu ifade tutanağı, kısa bir süre sonra, belirli kişilere e-posta adresi üzerinden servis edilir. Bu şekilde söz konusu ifade tutanağı bana da gönderilir. Bunun üzerine, ilgili gördüğüm Emniyet Genel Müdür Yardımcısını ararım; durumu anlatırım. Sayın Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bu işlere vaziyet eden Müdür Yardımcısı ile benim görüşmemi sağlar. Bu görüşmede sayın Müdür Yardımcısına hukuken gerekli anlatımlarda bulunurum. Ancak, **bu** anlatımlarım hiçbir sonuç vermez.

2. İstanbul’da söz konusu davaya ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, “Ergenekon Terör Örgütü” olarak bir terör örgütünün bulunup bulunmadığına dair bilgi ister. Durumdan bir şekilde bilgi sahibi olurum. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde, bir örgütsel yapının mevcut olup olmadığı, şayet mevcut ise, bunun bir terör örgütü mahiyetinde olup olmadığı hususundaki tespit ve değerlendirmenin kolluğun görevi olmadığını, bilakis bizzat Cumhuriyet savcısı ve hakimnin görevi olduğunu belirterek, bu yazıya cevap verilmemesini öneririm. Ancak, Devletin üst düzey yönetiminde kısa bir süreliğine bir iç krize neden olan bu önerim, neticede dikkate alınmaz.

3. Söz konusu davanın soruşturması sürecinde bir üniversite rektörü ifadesi alınmak üzere derdest edilerek kolluk eşliğinde Ankara’dan İstanbul’a götürülür. Bu sırada Yükseköğretim Kurulu Başkanvekilliği görevini deruhte etmem dolayısıyla, basın mensupları tarafından bana bu konuda bir soru yöneltilir. Bu soruya cevap olarak, **“görevi başında bulunan ve Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından çağrıldığında derhal icabet edebilecek durumda olan bir rektör, kolluk tarafından derdest edilerek götürülemez”** mealinde açıklamada bulunurum. **Bu açıklama dolayısıyla**, bilahare söz konusu görevden istifaen ayrılmama kadar gelişen tepkilere maruz kalırım.

4. 2012 yılının ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Devletinde icra ettiği Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekli olan bir kişi, **“terör örgütü yöneticisi”** olmakla suçlanır ve bu gerekçeyle tutuklanır. İstanbul’da bir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu tutuklama kararında, suçun işlenmeye başlandığı tarih olarak, kişinin Genelkurmay Başkanlığı görevine atandığı

tarih; suçun icrasının tamamlandığı tarih olarak ise, kişinin bu görevden emekli olduğu tarih gösterilir. Bu karar üzerine, behemehal Devletin en üst düzeyde yetkililerine düşüncelerimi arz etme fırsatı bulurum. Bu çerçevede, söz konusu kararın bu hakimler tarafından verilmesinin mümkün olmadığını, bu kararın başka bir merci tarafından verilmiş olacağını, bu hakimlere sadece tasdik ettirildiğini ve hatta, bu kararın bir **akıl tutulması** ürünü olduğunu bütün açıklığıyla izah ederim. Bu izahatım, ancak 2014 yılının mart ayında aksülamel bulur.

5. Söz konusu davada mahkûmiyet hükmü açıklanır. Bu hükmün açıklanmasından kısa bir süre sonra ve fakat gerekçesi henüz yazılmadan, kararı veren hakimlerin ataması gerçekleştirilir. Bu hakimlerin, atama kararının resmi gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde bu mahkemeden ayrılıp, yeni atandıkları adliyede göreve başlamaları, kanunen gerekmektedir⁸⁶. Bu nedenle, söz konusu hakimler “kes yapıştır” yöntemiyle bütün dosya münderecatını bir “metin” haline getirerek dünyada eşi benzeri görülmemiş 17.000 sahifelik “gerekçeli karar” yazarlar. Açıkça belirtmem gerekir ki, utanç verici bu duruma zamanın “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” tarafından **bilinçli** olarak sebebiyet verilmiştir.

Amacım, birilerini suçlu ve sorumlu addetmek veya tezkiye etmek değil, Devlet eliyle, kamu gücü kullanılarak icra edilen bazı bilinçli yanlışlara işaret etmektir. Hukuk, zaman zaman siyasi mülahazalarla bir manivela olarak kullanılabilmekte, bir araç durumuna irca edilmektedir. Kaygı verici olan, amaç olması gerekenin araç durumuna irca edilmesidir.

⁸⁶ Mevzuat temeli olan bu uygulamanın hukuki temeli bulunmamaktadır.

Gerekçe, kararın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Hukukta bir karar ancak gerekçesi oluşturulduktan sonra verilebilir ve açıklanabilir. Gerekçesi oluşturulmadan verilen karar, hukuken sorunludur.

Ancak bizim hukuk uygulamamız, bu kuralı dikkate almamaktadır. Önce karar verilip açıklanmakta, gerekçesi de bilahare yazılmaktadır. Bu uygulamanın ortaya çıkardığı ilk sorun, 1980’li yıllarda yaşanmıştır: Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bir davada verdiği mahkûmiyet hükmünü duruşmada sanığa tefhim eder ve durumu duruşma tutanağına derç eder. Ancak hakim, bu karara ilişkin gerekçeyi henüz yazmadan vefat eder. Mahkemeye yeni hakim atanır. Gelen yeni hakim, başkası tarafından verilmiş olan bu kararın gerekçesini yazmaktan imtina eder. ve bu tutumu bir hukuki soruna yol açar. Yargıtay, bu sorunu hukuki temeli olmayan bir “içtihatla” halletmişti. Bu “içtihat” ile mahkemeye yeni atanan hakime ölen hakimin verdiği kararın gerekçesini yazma “görevi” yüklenmişti.

5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunuyla bu yanlış uygulamaya “hukuki temel” oluşturulmaya çalışılmıştır (m. 231, f. 1; m. 232, f. 3).

EKSKURS 20: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU - II

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe teşebbüsü bağlamında ceza sorumluluğu için bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir.

I. 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerin iştirakiyle gerçekleştirilmiştir⁸⁷. Ancak, bu suçun icrası bağlamında askerler arasında mevcut **kanuni hiyerarşik ilişkinin** dışına çıkmıştır. **Askerler** arasında ast konumunda kişilerin üst konumunda kişilere emir ve talimat verecek şekilde görev dağılımının yapıldığı gözlemlenmiştir. Hatta, asker olmayan kişilerin de askerlerle birlikte bu suçun işlenişine iştirak ettiği, bu **sivil kişiler** arasında sair bir kamu görevi ile görevli kişilerin bulunduğu öğrenilmiştir. Söz konusu darbe teşebbüsüne iştirak eden asker ve sivil kişiler arasında **fiili bir hiyerarşik ilişki** tesis edilmiştir. Bu hiyerarşik ilişki, söz konusu darbe teşebbüsünün hazırlık ve icrası aşamasında cari olduğu gibi, yönetime vaziyet edildikten sonra gerçekleştirilmesi planlanan görev dağılımı bakımından da kendisini tezahür ettirmektedir. Bu görev dağılımının içinde, yüksek mahkeme başkanlıklarına kadar bütün sivil kamu görevlerinin girdiğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bu nedenle, söz konusu darbe teşebbüsüne iştirak eden kişiler arasındaki ilişki, ani suça özgü olmayan bir mahiyet taşımaktadır.

Bu itibarla söz konusu suçu işleyen kişilerin ayrıca örgütlü suçluluk içinde olduğunu, söz konusu darbe teşebbüsünün bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Başka bir ifadeyle, söz konusu suçu işleyen kişiler hakkında ayrıca silahlı örgüt yöneticisi veya üyesi olmaktan dolayı TCK, m. 314 hükümlerine istinaden mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir.

⁸⁷ Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **14.7.2017** tarihli ve E. 2017/1443, K. 2017/4758 sayılı Kararında, söz konusu darbe teşebbüsüne ilişkin tespitler, tarih ve sayısı belirtilmeksizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "*Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırmaları Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu*"na dayandırılmıştır (sh. 29 vd.).

Keza, Daire'nin bir temyiz mercii olarak verdiği bu kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bir iddianamede yer verilen vakıa tespitine ilişkin bilgiler, esas alınmıştır (sh. 32, 33 vd.).

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu iddianameyle açılmış olan kamu davasına ilişkin **yargılama** ilk derece mahkemesinde **devam etmekte** olup, bu davada henüz hüküm kurulmamıştır.

İlginçtir ki, bu darbe teşebbüsünde bulunan kişilerden öldürülenlerin sayısı verilirken Başbakan'ın açıklamasına dayanılmıştır (sh. 32).

Bu yöntemin yargılama faaliyetiyle telifinin kabil olmadığını belirtmekle yetinmek isteriz.

Ancak belirtmek gerekir ki, mülga 765 sayılı TCK uygulamasının bir yansıması olarak, 5237 sayılı TCK yürürlüğe girdikten sonra da Yargıtay 9. Ceza Dairesi verdiği pek çok kararında, “geçitli suç” oluşturduğu gerekçeyle, TCK’nın 309, 311 ve 312. maddelerinde tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, “amaç suç” sebebiyle cezaya hükmedildikten sonra, 314. maddesinde tanımlanan ve “araç suç” mahiyeti taşıyan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmedilmeyeceği yönünde içtihatla bulunmuştur (9. CD, **30.12.2013**, E. 2013/7932, K. 2013/16704; 9. CD, **7.6.2011**, E. 2011/4205, K. 2011/3247; 9. CD, **4.11.2010**, E. 2010/9657, K. 2010/11417; 9. CD, **25.1.2010**, E. 2009/11204, K. 2010/855).

Bu uygulamanın TCK’nın 220. maddesinin dördüncü fıkrası düzenlemesiyle çeliştiğini belirtmekle yetinmek gerekir. Önemle belirtmek gerekir ki, amaç suç araç suç ilişkisinin söz konusu olduğu hallerde farklı neviden fikri içtima hükümleri uygulanmaz. Belli bir suçu işlemek amacına yönelik araç suç işlendikten sonra ayrıca amaçlanan suç işlendiği takdirde, her iki suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekir. TCK, m. 220, f. 4 ile m. 309 f. 2 hükümleri, farklı neviden fikri içtima hükmünün uygulanması bağlamında birer istisna hükmü değildir⁸⁸.

II. Söz konusu darbe teşebbüsünün icrası sırasında birden fazla suçun işlenmesi dolayısıyla içtima sorunu ile karşı karşıya kalınabilir.

TCK’nın 309, 311 ve 312 maddelerindeki suç tanımları büyük ölçüde benzerlik arz etmektedir. Bu suçlar arasındaki fark, konu ve amaç unsurları itibarıyla ortaya çıkmaktadır.

Konu unsuru itibarıyla söz konusu suçlar arasındaki farklar, yukarıdaki sayfalarda açıklanmış bulunmaktadır.

Amaç unsuru itibarıyla aralarındaki farka gelince, kasten işlenebilen bu suçlardan;

- 309. maddede tanımlanan suçu işleyen kişilerin, **Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, bu düzen yerine**

⁸⁸ Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 14.7.2017 tarihli ve E. 2017/1443, K. 2017/4758 sayılı Kararının gerekçesinde farklı anlaşılmaya müsait açıklamalarda bulunulmuştur:

“Araç fiilin işlenmesine yönelik icra hareketi, hem araç suçun hem de tehlike suçu niteliğindeki amaç suçun icra hareketini oluşturduğundan sanık hukuki anlamda tek bir fiil ile kanunun birden fazla hükmünü ihlal etmekle, Türk Ceza Kanununun 44. maddesinin uygulanması gerekmekte ise de, TCK’nın 309/2. maddesindeki düzenleme, fikri içtima kurumunun uygulanmasının önlenmesine getirilen bir düzenleme olduğundan araç ve amaç suçlar yönünden her olayda kural olarak gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır.” (sh. 10).

başka bir düzen getirmek veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemek amacıyla,

- 311. maddede tanımlanan suçu işleyen kişilerin, **Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek amacıyla,**

- 312. maddede tanımlanan suçu işleyen kişilerin ise, **Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek amacıyla,**

hareket etmesi gerekmektedir.

Buna göre somut olayda kişiler;

- a) münhasıran Hükûmete karşı suç (TCK, m. 312) işlemek amacıyla,
- b) Yasama organına karşı suç (TCK, m. 311) işlemek amacıyla,
- c) Anayasayı ihlal amacıyla (TCK, m. 309),

hareket etmiş olabilirler.

Anayasayı ihlal suçunu işleyen kişilerin zorunlu olarak Yasama organına karşı suçu da işleyeceği aşıkardır. Bu durumda bir “*geçitli suç*” halinden söz etmek gerekir. Anayasayı ihlal suçunu işleyen kişiler, aynı zamanda Hükûmete karşı suçu da işleyebilirler. Her iki durumda, **farklı neviden fikri içtima** hükümlerini (TCK, m. 44) göz önünde bulundurarak, sadece TCK, m. 309 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir⁸⁹.

Buna karşılık, Yasama organına karşı suç, münhasıran işlenebileceği gibi, Hükûmete karşı suçun yanı sıra da işlenebilir. Yasama organına karşı suçun Hükûmete karşı suçla birlikte işlenmesi halinde de **farklı neviden fikri içtima** hükümleri göz önünde bulundurularak, faillere sadece TCK, m. 311 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir.

Dikkat edilmelidir ki, somut olaya ilişkin olarak kurulan mahkûmiyet hükmünde, faillerin hangi suçu veya suçları işlediğinin ve içtima durumlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün icrası bağlamında işlenen fillerin büyük bir kısmı, Türk Ceza Kanununda

⁸⁹ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 10, 35.

tanımlanan kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme gibi çok sayıda suçun oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Keza, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün icrası bağlamında askerler arasındaki kanuni hiyerarşik ilişkinin dışına çıkılarak işlenen filler, aynı zamanda Askeri Ceza Kanununda tanımlanan itaatsizlik (m. 86 vd.), mukavemet (m. 90), fiili taarruz (m. 91) ve fesat (m. 97 vd.) gibi suçları oluşturmaktadır.

Yeni TCK'nın **fiil sayısınca suç, suç sayısınca ceza** ilkesinden ibaret olan **gerçek içtimaı** ön plana çıkaran özelliği dolayısıyla, 309, 311 ve 312. maddelerinin ikinci fıkralarında özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir:

“Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.”

Cebir veya tehdit, söz konusu maddelerde tanımlanan suçların unsurudur. Bu itibarla, söz konusu suçların işlenmesi bağlamında kişilerin iradesini etkilemek amacına matuf olarak gerçekleştirilen cebir veya tehdit fiillerinden dolayı ayrıca cezaya hükmedilemez. Ancak, kişilere iradelerini etkilemenin ötesinde cebir ve şiddet uygulanmışsa, örneğin kişiler işkenceye maruz bırakılmış, ağır şekilde yaralanmış, hürriyetlerinden yoksun bırakılmış veya öldürülmüş iseler, failer hakkında ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmedilmesi gerekir. Nitekim aynı yönde açıklamalara TCK'nın 311. maddesinde tanımlanan “*Yasama organına karşı suç*”un madde **gerekçesi**nde yer verilmiştir⁹⁰:

“Bu suçun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hâlleri gerçekleşmiş ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir.”

Söz konusu suçların işlenmesi sırasında TCK, m. 310'da tanımlanan **Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı** suçunun işlenmesi halinde, bu suç işleyen, bu suçun işlenişine iştirak eden kişilerin de ayrıca bu suçtan dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

⁹⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

III. Bazı asker kişilerin, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe teşebbüsünün gerek hazırlık aşamasında gerek icrası aşamasında olup bitenlerden haberdar olmasına rağmen, duruma ses çıkarmaması, ilgili mercileri durumdan haberdar etmemesi dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu da bir sorun teşkil etmektedir.

Sorunu önce askeri hiyerarşi bakımından ele almak gerekir.

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa göre,

“Disipline aykırı gördüğü her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir.” (m. 24).

Keza,

“Her rütbe sahibi, kanunların, nizamların ve amirlerin kendisine tahmil ettiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeye, vazifeli olduğu yerlerde öğretmeye ve bu hizmet ve vazifeleri eksiksiz yapmaya ve takibederek yaptırmaya ve daima ve her yerde disiplini tesis ve muhafazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve astın şahsi teşebbüsünü inkişaf ettirmeye ve kendisine teslim olunan silah, araç, gereç ve sair bütün askeri eşyayı, yapıları ve ağaçları ve hayvanatı korumaya me-mur ve mecburdur.” (TSK İç Hizmet K, m. 75).

Bu hükümler, **askeri hiyerarşide üst konumundaki kişiye, amir olsun veya olmasın, asker kişinin işlemekte olduğu suçu önleme yükümlülüğü** yüklemektedir. Söz konusu yükümlülüğün varlığı için, asker kişi tarafından işlenmekte olan suçun ağırlığının bir önemi bulunmamaktadır.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işlenen suçtan dolayı sorumluluk rejimi, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 139. maddesinde belirlenmiştir:

“Bir askeri karakolun veya bir müfrezenin veya hususi bir vazife ile mükellef olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nöbetçi iken mani olabileceği ve vazifeten men'e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz yumarsa faili kendisi yapmış gibi ceza görür.”

Buna göre, asker kişi, amir veya üst konumunda olması ya da nöbetçi olması dolayısıyla önlemek yükümlülüğü altında olduğu ve önleyebileceği bir suçun işlenmesine muttali olmasına rağmen, işlenmekte olan suçu önlemekte ihmal göstermesi halinde, bu suçun **faili** olarak cezalandırılacaktır.

Söz konusu hükmün uygulanabilmesi için, birinci koşul, asker kişi tarafından işlenmekte olan bir suçun varlığıdır. Başka bir ifadeyle, **asker kişi tarafından icrası devam eden ve işlenmesi henüz tamamlanmamış olan bir suç** söz konusu olmalıdır.

İkinci koşul, asker kişinin bu **suçun işlenmesini önleme yükümlülüğünün** olması gerekir. Bu yükümlülük, TSK İç Hizmet Kanununa göre (m. 24, 75), amir konumunda olsun veya olmasın **üste** terettüp etmektedir. Ancak, Askeri Ceza Kanunu, söz konusu yükümlülüğü, bir askeri karakolun veya müfrezenin subaylarına ve hatta nöbetçi askerlere de teşmil etmektedir (m. 139).

Üçüncü koşul, **üstün** asker kişi tarafından **işlenmekte olan bir suçun varlığını bilmesi, yani kastının olması** gerekir. Başka bir ifadeyle **üst**, somut bir **suçun** asker kişi tarafından **işlenmekte olduğu bilgisine muttali olmalıdır**.

Dördüncü koşul, işlenmekte olan suçu önleme yükümlülüğü altında olan **üstün** fiilen bu **suçun işlenmesini önleme imkanının** olması gerekir. Şayet üst, işlenmekte olan suçun önlemeye fiilen muktedir değilse, **kusuru olmadığı için**, işlenen suçtan dolayı sorumlu tutulmaz. Üst bir şekilde hürriyetinden yoksun bırakılmış olmakla, işlenmekte olan suçu önleme imkanını kaybetmiş olabilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, asker kişinin darbenin icrasına engel olmaya ve bu çerçevede durumdan ilgili mercileri haberdar etmeye çalışması halinde herhangi bir kötülükle karşı karşıya kalmak tehlikesinin bulunması ya da **tehdit** edilmiş olması, söz konusu suçun önlenmesine yönelik girişimde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından bir **mazeret sebebi oluşturmaz**. Çünkü asker kişiler, TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre kendilerine terettüp eden görevleri yerine getirme uğruna, gerektiğinde “seve seve hayatımı feda eyle”meyi kabul etmiştir (TSK İç Hizmet K, m. 37).

Keza, asker kişinin herhangi bir sebeple izinli olması ve birliğinin dışında bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi bakımından bir mazeret sebebi oluşturmaz.

Beşinci koşul, yukarıda sayılan dört koşulun varlığına rağmen üst, işlenmekte olan **suçun icrasını önlemeyi ihmal** etmiş olmalıdır.

Bu durumda üst, asker kişinin işlemekte olduğu suçun işlenişine ihmali davranışla iştirak etmiş olmaktadır. Ancak, bu suçun işlenmesinden dolayı şerik sıfatıyla değil, (müşterek) **fail** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. Asker kişinin işlemekte olduğu suç, icrai bir suç olmasına rağmen, bu suçun işlenmesini

önlemeyi ihmal eden üst de söz konusu suçtan dolayı **müşterek fail** sıfatıyla cezalandırılacaktır⁹¹.

IV. 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe teşebbüsü, bir merkezin yönlendirmesiyle planlanan, bir merkezden sevk ve idare edilen bir suç olgusudur⁹². Bu suçun icrası bağlamında verilen bir görevin kabul edilmesi, söz konusu suçtan dolayı **müşterek fail** sıfatıyla cezalandırılmayı gerekli kılar. Hatta kişi, bu darbe teşebbüsünün icrası bağlamında kendisine verilen görevi kabul etmekle birlikte, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe teşebbüsünün icrası sırasında henüz harekete geçmemiş olabilir. Kişinin, yapılan planlama çerçevesinde söz konusu darbe teşebbüsünün icrası sırasında veya icrası sonrasında yönetime vaziyet edildikten sonra kendisi için uygun görülen görevi kabul etmesi, bu suçtan dolayı müşterek fail sıfatıyla sorumluluğunu gerektirir. Bu tespitimiz, söz konusu darbenin hazırlık planlarında darbe gerçekleştikten sonra, darbeciler tarafından yönetime vaziyet edildikten sonra sivil yönetimlerin oluşturulması bağlamında herhangi bir görevi kabul eden sivil kişilerin söz konusu darbe teşebbüsünden dolayı sorumluluğunun belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Dikkat edilmelidir ki, müşterek fail ve yardım eden (şerik) olarak sorumluluk için en önemli fark, yardım etmede, yardı karamınınm eden şerik suçun icrasını bir başkasının, failin inisiyatifine havale etmektedir. Buna karşılık, müşterek faillikte ise, suçun icrasının bir başkasının inisiyatifine tevdi söz konusu değildir; aralarındaki müşterek karar gereğince her müşterek fail kendisi için uygun görülen görevi uygun görülen zaman ve yerde ifa etmektedir. Bu iş bölümü gereğince bazı suç ortakları için uygun görülen görevin yerine getirilme sırasının henüz gelmemiş olması, müşterek fail sıfatıyla cezalandırılmalarına engel teşkil etmemektedir.

V. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, söz konusu darbe teşebbüsü, bir merkezin yönlendirmesiyle planlanan, bir merkezden sevk ve idare edilen bir suç olgusudur. Bu itibarla ortada tek bir suç mevcuttur. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaların sağlıklı yapılabilmesi için mevzuatta özel

⁹¹ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 36.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, TCK'nın 309, 311 ve 312. maddelerinde tanımlanan suçlar ihmalî davranışla işlenemezler. Ancak icrai davranışla işlenebilen bu suçların işlenişine ihmalî davranışla iştirak edilebilir ve hatta, bu suçların işlenişine ihmalî davranışla iştirak eden kişi müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutulabilir. Bu iki farklı durum, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin söz konusu kararında birbirine karıştırılmıştır (sh. 4).

⁹² Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 36.

düzenleme yapılmıştır (5235 s. K, m. 15, f. 4). Buna göre, söz konusu suçun işlenişine iştirak eden bütün suç ortakları hakkında bir mahkeme değil, bu suçun icrasına iştirak eden kişilerin iştirak katkılarını gerçekleştirdikleri “ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesi” yetkili kılınmıştır. Bu suçun işlenişine iştirak eden kişiler bakımından farklı mahkemelerin yetkili kılınması, işlenen darbe teşebbüsü suçunun sayısının fazlalığına işaret etmemektedir.

EKSKURS 21: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

Gönüllü vazgeçme icrası devam eden, icrası henüz tamamlanmamış olan bütün suçlar bakımından söz konusu olabilir. Bu itibarla alelittlak teşebbüs suçlarında gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağını ileri sürmek, tutarlılık arz etmez. Örneğin rüşvet suçu, bir teşebbüs suçudur. Söz konusu suç, rüşvet olarak mutabık kalınan haksız menfaatin temin edildiği anda tamamlanmaktadır. Ancak, rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmedilir (TCK, m. 252, f. 3). Rüşvet konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, rüşvet olarak anlaşılan miktar temin edilmeden taraflardan biri veya her ikisi rüşvetten vazgeçebilir. Bu durumda, gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri uygulamak gerekir. Keza, işinin gördürülmesi için rüşvet vermeyi teklif eden kişinin bu teklifi kamu görevlisi tarafından henüz ret veya kabul edilmeden önce, bu teklifinden vazgeçmesi, gönüllü vazgeçme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Keza, TCK, m. 277’de tanımlanan “*Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs*” suçu, adından da anlaşıldığı gibi bir teşebbüs suçudur. Bu suç, belirli bir hususta, belirli bir yönde karar verilmesi, görüş açıklanması veya beyanda bulunulması amacına matuf meramın söz konusu kişilere iletilmesiyle suç tamamlanmış olmaktadır. Ancak, bu durumdan, söz konusu suça teşebbüsün mümkün olmadığı ve dolayısıyla bu suçla ilgili olarak gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağı yönünde bir sonuç çıkarılamaz. Bir hakime hitaben yazılıp postaya verilmiş veya bir aracı marifetiyle gönderilmiş olan ve belirli bir yönde karar vermesini temin zımında meramı içeren mektubun, pişmanlık duyularak hakimine eline ulaşmasının engellenmesi halinde, gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Hatta işaret etmek gerekir ki, belirtilen içerikteki mektubun içeriğine muttali olan aracı tarafından pişmanlık duyularak, muhatap hakime değil de, suç duyurusu zımında Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilmesi halinde, mektubu yazan kişi bakımından söz konusu suça teşebbüs etmekten dolayı cezaya hükmetmek ve aracı bakımından ise gönüllü vazgeçme hükümlerini uygulamak gerekir.

Anayasayı ihlâl suçu ile yasama organına ve hükümete karşı suçlar (TCK, m. 309, 311, 312), mahiyetleri itibarıyla teşebbüs suçudurlar. Bu suçların tamamlanması için, anayasanın değiştirilmiş olması, TBMM’nin veya hü-

kümetin görevlerini kısmen de olsa yapamaması gibi bir neticenin meydana gelmesi gerekmez. Keza bu suçların işlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen hazırlık hareketleri, bağımsız bir suç olarak tanımlandığı için (TCK, m. 316), ancak “cebir ve şiddet” kullanılarak, bu suçların icrasına başlanabilir ve icraya başlamakla suç tamamlanmış olur. Madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi, söz konusu suçlar bağlamında “*teşebbüsün ancak cebir veya tehdit kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir.*”⁹³ Söz konusu suçların oluşabilmesi için, icra hareketlerine en azından başlanmış olmalıdır⁹⁴. Yani, **cebrî hareketlere bil-fil teşebbüs edilmiş olması**, suçun oluşumu için gereklidir.

İcrasına başlanmış olan söz konusu suçların icra hareketleri işlenmeye devam ederken, yani icra hareketleri henüz sonuçlanmadan, kişiler gönüllü olarak bu suçları işlemekten vazgeçebilirler. Bu bağlamda vazgeçmenin gönüllü olup olmadığı her somut olayın koşullarına göre mahkemece takdir edilmesi gerekir. Başarısız olduğu artık anlaşılan bir darbe girişiminden vazgeçme halinde, gönüllülüğten söz etmek mümkün değildir. Ancak, **darbe teşebbüsü henüz akim bırakılmadan önce, darbe teşebbüsünü bastırmaya yönelik fiziki güç kullanılmadan önce, bu girişimin içinde bulunan kişiler, çeşitli çağrılara icabet ederek, söz konusu suçların icrasına devam etmekten vazgeçebilirler. Bu koşullarda vazgeçmenin gönüllü olduğunu kabul etmek ve TCK’nın gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümlerini uygulamak gerekir.**

İşaret etmek gerekir ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 22.3.2019 tarihli ve E. 2018/7103, K. 2019/1953 sayılı kararının gerekçesinde yer verilen, gönüllü vazgeçme hükümlerinin Anayasayı ihlal suçu bakımından alelittlak uygulanamayacağı yönündeki açıklamalar (sh. 41), bu konudaki sorunlu olan doktriner açıklamalara dayanmaktadır. Ancak, bu sorunlu açıklamalara rağmen Dairenin karara konu teşkil eden olaydaki bir kısım sanıklarla ilgili olarak gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağı yönündeki değerlendirmesi doğrudur.

Karara konu teşkil eden olayda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen “darbe teşebbüsü” çerçevesinde Gaziemir’den Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gelen ve gerekli silah ve mühimmatla teçhiz edilmiş vaziyette pistte hazır bulunan

⁹³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

⁹⁴ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 5.

iki helikopterin mürettebatı, bu harekâtın hukuksuz olduğunu anlayınca, kontrollerindeki helikopterlerin arıza yaptığı bahanesiyle, diğer suç ortaklarının sevk ve idaresindeki helikopterlere eşlik ederek havalanmazlar.

Diğer üç helikopterin mürettebatı ise icraya devam ederek, Marmaris'e gider ve Cumhurbaşkanının maiyeti ile birlikte konakladığı otele baskın gerçekleştirebilirler. Bu baskın sırasında güvenlik görevlisi çok sayıda kişi ölür ve yaralanır. İlk derece mahkemesinin kararında olduğu gibi, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, söz konusu mürettebatın bu baskın ameliyesi sırasında yakıtları azalan helikopterlerine yakıt ikmali için gelişen süreçteki tutum ve davranışları ile ilgili olarak gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağı yönündeki değerlendirmesi doğrudur.

Buna karşılık, söz konusu davada, Çiğli hava üssünden hiç hareket etmeyen diğer iki helikopter mürettebatı ise, sanık değil tanık olarak dinlenmişlerdir. Bu da göstermektedir ki, söz konusu helikopter mürettebatı, Gaziemir'den Çiğli hava üssüne gelinceye kadar Türkiye'de bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunun farkında olmadığı için, kastlarının olmadığı gerekçesiyle haklarında kamu davası açılmamıştır.

Sonuç itibarıyla, her ne kadar söz konusu darbe teşebbüsü bilahare akim kalmış ise de, icrasına iştirak eden kişiler giriştikleri fiilin icrasına devam etmekten herhangi bir zorlamaya binaen alıkonulmuş değillerse, haklarında TCK'nın, iştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçmeye ilişkin 41. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekir.

EKSKURS 22: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

I. Olayın Gelişim Süreci:

Milletvekili E. Berberoğlu hakkında, 27.5.2015 tarihinde işlediği bir fiil sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılır ise de, yasama dokunulmazlığı bulunduğu için soruşturmaya devam edilemez.

Ancak, adı geçen milletvekilinin dokunulmazlığı, 20.5.2016 tarihli ve 6718 sayılı Kanunla Anayasaya eklenen Geçici Madde 20 hükmü ile kaldırılır ve bunun üzerine kişi tutuklanır. Adı geçen milletvekili hakkında “*Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme*” suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılır (2016/34071 sayılı İddianame).

Davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, adı geçen kişiyi mûsnet suçtan mahkûm eder (14.06.2017 tarihli ve Esas 2016/205, Karar 2017/97 sayılı Karar).

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yaptığı istinaf incelemesi sonucunda, suçun vasfının yanlış belirlendiği gerekçesiyle adı geçen kişi hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünü kaldırır ve yeni bir mahkûmiyet hükmü kurar (13.02,2018 tarihli ve Esas 2017/2075, Karar 2018/287 sayılı Karar)

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin söz konusu kararı temyiz edilerek, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilir.

Bu arada, 24.6.2018 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde E. Berberoğlu, yeniden milletvekili seçilir. E. Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Anayasanın 83. maddesinin dördüncü fıkrasına göre hakkında açılan davaya devam edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dokunulmazlığının yeniden kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek, görülmekte olan davada durma kararı verilmesini talep eder.

Ancak, Yargıtay 16.Ceza Dairesi, oyçokluğu ile bu talebi reddeder (19.7.2018 tarihli ve Esas 2018/2088, Değişik İş Karar 2018/10 sayılı Karar).

16. Ceza Dairesi bilahare 20.09.2018 tarihinde E. Berberoğlu hakkındaki mahkûmiyet hükmünün yine oyçokluğuyla onanmasına karar verir.

Daire aynı zamanda, E. Berberoğlu'nun milletvekilliği düşünceye kadar cezasının infazının mümkün olmadığı gerekçesiyle, derhal tahliyesine karar verir ve bu karara istinaden E. Berberoğlu serbest bırakılır.

II. Hukuki Değerlendirmemiz:

A- Bir muhakeme engeli olan “dokunulmazlık, kişinin milletvekili seçildikten sonra veya milletvekili seçiminden önce işlediği iddia edilen suçlardan dolayı bu sıfatı taşıdığı sürece hakkında sadece belli muhakeme işlemlerinin yapılması açısından bir engel teşkil etmektedir. Dokunulmazlığın sebebi, kişinin milletvekili sıfatını iktisap etmesi ve taşımasıdır. Kişi milletvekili sıfatını taşıdığı sürece dokunulmazlıktan yararlanır. Bu nedenle dokunulmazlık, sürekli değil, geçici niteliktedir. Milletvekilliği sona erince, dokunulmazlık da kendiliğinden kalkar.

Milletvekili ile ilgili dokunulmazlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılabilir (1982 Any, m. 83, f. 2). Dokunulmazlığın kaldırılması, kişinin milletvekilliği sıfatını sona erdirmemektedir. Dokunulmazlığın kaldırılması, somut bir veya birkaç fiile münhasır olabilir. Dokunulmazlığın kaldırılması, belirli bir fiil veya fiiller dolayısıyla, milletvekili sıfatının devam etmesine rağmen, kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

20.5.2016 tarihli ve 6718 sayılı Kanunla Anayasaya eklenen “Geçici Madde 20” hükmüyle, belli bir tarihe kadar işlemiş oldukları fiillerden dolayı bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

Anayasaya göre bir milletvekiliyle ilgili dokunulmazlık, salt çoğunlukla alınmış **Meclis kararıyla** kaldırılabilir (m. 83, f. 2). Ancak, bu defa dokunulmazlık, Anayasa'ya bir geçici madde eklemek suretiyle ve herhangi bir kişi belirlemesi yapılmaksızın, bütün milletvekilleri ile ilgili olarak kaldırılmıştır.

Hukukçular arasında Anayasa hukuku yönünden bu şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasının hukukiliği tartışılmıştır. Bu tartışmalar, tebliğin konusu dışında tutulmuştur.

Söz konusu Geçici 20. Maddeye göre, işledikleri fiillerden dolayı “**milletvekilleri hakkında Anayasanın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.**” Buna göre, ilgili milletvekilleri hakkında yakalama, tutuklama, arama ve elkoyma gibi soruşturma işlemleri yapılabilecektir.

Bu nedenle, söz konusu Geçici 20. Madde, bir genel düzenleyici hüküm değil; 20.5.2016 tarihi itibarıyla işlenmiş belirli fiillerle sınırlı olarak ilgili milletvekilleri hakkında **dokunulmazlığın kaldırılması kararı** mahiyeti taşımaktadır.

Buna göre, söz konusu Geçici Madde kapsamına giren fiillerle ilgili olarak, bir milletvekili gözüaltına alınabilir, **sorguya çekilebilir, tutuklanabilir ve yargılanabilir.**

Bu durumda, Anayasanın 83. maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulama kabiliyeti bulacağında hiçbir kuşku bulunmamaktadır:

“Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.”

Faraziye (varsayım) olarak bir an için söz konusu geçici madde hükmünün genel düzenleyici bir hüküm olduğu kabul edilse bile, getirilen istisna sadece 83. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesine ilişkin olduğu için, karara konu teşkil eden olay bakımından maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulama kabiliyeti bulacaktır.

Bu itibarla, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin E. Berberoğlu hakkında yargılamaya devam edilmesi yönündeki ara kararını hukuken doğru bulmamaktayız.

B- E. Berberoğlu’nun işlediği kabul edilen suçun oluşup oluşmadığı hususundaki tartışmalar, tebliğin konusu dışında tutulmuştur.

E. Berberoğlu hakkında verilen 5 yıl hapis cezasına mahkûmiyet hükmünün onanmasıyla, bu mahkûmiyet kesinleşmiş olmaktadır.

Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesiyle bu mahkûmiyete bağlı hak yoksunlukları kişi bakımından doğar (TCK, m. 53).

Ancak, milletvekilliği yeterlilik şartlarını yitirmeyi sonuçlayan mahkûmiyet halinde, bu hükmün kesinleşmesiyle milletvekilliği kendiliğinden sona ermemekte, kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla milletvekilliği sona ermektedir (Anayasa, m. 84, f. 2).

Belirtmek gerekir ki, bu düzenleme, tutuklu bulunan milletvekilinin hapis cezasına mahkûmiyet hükmünün onanması üzerine tahliye edilmesini gerektirmemektedir.

Milletvekili hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün infazının milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesini (bırakılmasını) öngören Anayasa

hükmü (m. 83, f. 3), ancak milletvekilliği yeterliliğini yitirmeyi sonuçlamayan mahkûmiyetlerle sınırlı olarak uygulama kabiliyetini haizdir.

Bir kanuni düzenlemedeki kurallar, içinde yer aldığı kanunun diğer hükümlerinden mücerret bir şekilde ele alınarak değerlendirmeye tabi tutulamaz. Örneğin Anayasada yer alan bir hüküm, Anayasanın diğer ilgili bütün hükümleri ile birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak bir sonuca varılmalıdır.

Bu itibarla Anayasanın 83. maddesinin üçüncü fıkrasının “Milletvekili seçilme yeterliliği” başlıklı 76. maddesi hükümleriyle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Başka bir ifadeyle, infazı milletvekilliğinin sonuna bırakılan cezai mahkûmiyet, ancak milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmayan cezai mahkûmiyet olabilir.

Milletvekilliği yeterliliğini yitirmeyi sonuçlayan bir cezaya mahkûmiyet halinde, bu mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesine rağmen, tutuklu olan hükümlünün tahliye edilmesi, bir çelişki oluşturmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, dokunulmazlığın kaldırılması kararı, milletvekili hakkında belirli bir fiille bağlantılı olarak soruşturma ve kovuşturma yapılmasının yolunu açtığı gibi, bu fiil nedeniyle hükmolunan cezanın infazını da kapsamaktadır. Tutuklu bulunan milletvekili hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesiyle, tutukluluk durumu, kendiliğinden hükümlülük durumuna dönüşür. Milletvekilliği sıfatının bilahare düşürülmesinin bu hukuki durum üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu gerekçelerle Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 5 yıl hapis cezasına mahkûmiyet hükmü kesinleşen E. Berberoğlu’nun tutukluluk halinin sona erdirilmesine (tahliyesine) yönelik kararını da hukuken doğru bulmamaktayız.

EKSKURS 23: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUIYETİ

I. Bir devlet bir başka devlet ülkesine;

a) her iki devlet arasında akdedilen anlaşma çerçevesinde,

b) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karara istinaden oluşturulan uluslararası güç çerçevesinde,

c) bu ülke topraklarından kendisine yönelik olarak terör saldırılarının gerçekleşmesi veya somut saldırı tehlikesini varlığı halinde, bu saldırıları etkisiz kılmak, bu saldırı kaynaklarını bertaraf etmek için,

asker gönderebilir.

Birinci duruma, Türkiye'deki NATO birlikleri, Suriye'deki Rus askerî varlığı, örnek olarak gösterilebilir.

İkinci duruma, Eski Yugoslavya'nın parçalanması üzerine özellikle Bosna'ya bu çerçevede gönderilen askerî birlikler, örnek olarak gösterilebilir.

Sorun, üçüncü ihtimaldedir. Hemen belirtmek gerekir ki, “Birleşmiş Milletler Andlaşması”⁹⁵ bu ihtimalde de, meşru savunma hakkı çerçevesinde askerî harekâta izin vermektedir (m. 51).

Bu müdahalelerin meşruiyeti için, öncelikle ülke devletinden ve ilgili milletlerarası örgütlerden gerekli tedbirlerin alınmasının istenmesi gerekir. Bunun sağlanamaması durumunda, yapılması planlanan askerî harekâtla ilgili olarak ülke devletine bilgi verilmesi gerekir. Bu bilgilendirmenin fayda vermeyeceği durumlarda ise, Suriye örneğinde olduğu gibi, bilgilendirmeye gerek olmadan da harekât gerçekleştirilebilir. Ancak her halde durumdan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bilgilendirmek gerekir (Birleşmiş Milletler Andlaşması, m. 51)

Ancak bu harekâtın gerçekleştirilişi sırasında, herhangi bir hukuki temeli olmaksızın, oluşturulmuş yerel örgütlenmelerin silahlandırılması ve bu örgütlenmelerin silahlı çatışmalarda desteklenmesi, bir sorundur. Meşru olsun veya olmasın, yerel örgütlenmelerle istihbarat alanında işbirliği yapılmasında sorun bulunmamaktadır.

Bugün Suriye'de ABD'nin yaptığı gibi, bir devletin, uluslararası hukuk bakımından herhangi bir meşruiyeti olmayan örgütsel yapılanmalarla işbirliği yap-

⁹⁵ Türkiye, söz konusu Sözleşmeyi, 15.8.1945 tarihli ve 4801 sayılı Kanunla onaylamıştır. Sözleşme metni için bkz. RG: 24 Ağustos 1945/6092.

masının, bu örgütlenmeyi en azından özerk yönetim olarak yapılandırmasının, işgal ettiği bölgelerdeki ekonomik kaynaklardan bu örgütsel yapılanmanın yararlanmasına imkan sağlamasının ve nihayetinde kendisinin yararlanmasının Birleşmiş Milletler Andlaşması çerçevesinde meşruiyeti bulunmamaktadır.

Belirtmek gerekir ki, halkı Müslüman olan ülkelerde "İŞİD", "DAEŞ" veya başka herhangi bir adla olsun, meydana gelen silahlı örgütsel yapılanmaların tamamı, kendilerine biçilen "görev" tamamlanıncaya kadar, yabancı devletlerin sağladığı desteklerle varlıklarını sürdürmektedirler.

Türkiye'nin yapması gereken, bu tür örgütsel yapılanmalarla silahlı işbirliği yapmaması ve başka devletlerce yapılan bu tür işbirliklerine engel olmak için uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi konusunda bir çaba içinde olmasıdır.

Meşru savunma amacıyla da olsa, gerçekleştirilen sınır ötesi askerî harekât sırasında yerel örgütlenmelerle silahlı işbirliğine girmenin, bu silahlı çalışmalar sırasında meydana gelen öldürmeler, yaralamalar ve hürriyetten yoksun bırakmalar bakımından ceza hukuku alanında sorumluluk tartışmalarını tetiklemesi kaçınılmaz olur.

II. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonlarının meşruiyeti, Türk kamuoyu tarafından tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Ancak, bu çerçevede bir sorun hiç gündeme getirilmemektedir. Bu operasyonlar, bir savaş mıdır, yoksa terörle mücadele bağlamında bir adli iş ve işlemler bütünü müdür?

Söz konusu operasyonların bir savaş olmadığı, dolaylı bir şekilde ima edilmektedir. Bu tutum, doğru bir yaklaşımdır. Aksi takdirde, bu operasyonların savaş hukukuna ilişkin Birleşmiş Milletler Cenevre Mukaveleleri hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin yolu açılmış olur.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu operasyonların, suçlulukla mücadele bağlamında bir kolluk faaliyeti olarak kabul edilmesi, ilerleyen süreçte Türkiye bakımından uluslararası ilişkilerde çok önemli sorunların tartışılmasının yolunu açmaya zemin oluşturacaktır.

Hukuki bakımdan temel sorun, bu operasyonlar sırasında öldürülenler bir yana, sağ olarak ele geçirilenlerle ilgili olarak bir adli işlem tesis edilip edilmediği sorunudur.

Edindiğim bilgiye göre, söz konusu operasyonlar sırasında yakalanan, yani sağ olarak ele geçirilen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adli mercileri tarafından haklarında herhangi bir işlem yapılmaksızın, "ÖSO" olarak ifade edilen Suriye yapılanmasına teslim edilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, “Özgür Suriye Ordusu” (“ÖSO”) olarak ifade edilen Suriye yapılanmasının uluslararası alanda bir hukuki tanınmışlığı söz konusu değildir. Suriye’de mevcut yönetime bağlı kuvvetlerle silahlı çatışma halinde bulunan, “ÖSO” benzeri yapılanma özelliğine sahip çok sayıda oluşum bulunmaktadır.

Bu yapılanmaların hukuki meşruiyeti gibi, Türkiye’nin bunlardan biriyle veya birkaçıyla “iş tutması”nın hukuki bir temele oturtulması önemli bir milletlerarası sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugünün karışık ortamında pek gündeme getirilmeyen bu sorunun, bir gün hukuk aleminde önemli bir vaka olarak ele alınacağından kuşku duymamak gerekir. Dilerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına söz konusu operasyonlar bağlamında gerekli hukuki alt yapı şimdiden oluşturulur⁹⁶.

Bilmemiz gerekir ki; HUKUKSUZLUK, NİHAYETİNDE HİÇ KİMSENİN YANINA KÂR OLARAK KALMAMAKTADIR.

Aynı sorun, “PKK” ve “YPG” gibi örgütlerin elinde bulunduğu belirtilen asker, polis ve sair kamu görevlilerinin hukuki statüsü ile ilgili olarak da söz konusudur. Bazı siyasilere atfen medyada yer alan haberlerde, bu asker, polis ve sair kamu görevlileri “esir” olarak nitelendirilmektedir. Bu nitelendirmenin önemli bir yanlışlık olduğunu ve bilahare Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından önemli sakıncalara yol açabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bu kişilerin “esir” olarak nitelendirilmesi, Türkiye’nin bir savaş halinde olduğunun PKK ve YPG gibi örgütlerin de bu savaşın tarafı olduğunun kabulü anlamına gelecektir. Asker ve polis gibi kamu görevlilerini ve hatta basın mensuplarını kaçıran terör örgütlü mensupları uluslararası camiada “İNSAN HIRSIZLARI”, elinde tuttukları kişiler ise “REHİNE” olarak tavsif edilirler. Ancak bu kişiler hiçbir zaman “esir” olarak nitelendirilmezler. Bu kişilerin “esir” olarak nitelendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlarının, savaş hukukuna ilişkin Birleşmiş Milletler Cenevre Mukaveleleri hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin yolu açılmış olur.

⁹⁶ Türkiye’nin Suriye’deki sorunla ilgilenirken “kârlı” çıkıp çıkmamasını gündeme getirmek, abesle iştigal etmektir. Suriye’yi iç çatışma ortamına iten asıl sorun, kamuda istihdam ve kamu kaynaklarından yararlanma bakımından vatandaşları arasında ayırım gözetilmesidir. Bu durum, yabancı güçler tarafından istismar edilmiştir. Türkiye’nin, diplomasi kanallarını kullanarak ve özellikle halkın bilinçlendirilmesiyle, Suriye’deki siyasi yapının demokratikleşmesine katkı sağlaması gerekirdi. Suriye’nin içine sürüklendiği iç çatışma ortamı, göçü tetikleyerek, ülkedeki demografik yapıyı olumsuz etkilemiştir.

§ 5. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU¹

I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ

Gizlilik, bir bilgi bakımından söz konusu olabilir. Bu bilgi, bir kişinin özel hayatına, haberleşme içeriklerine, banka hesaplarına, ticari faaliyetlerine veya kişisel verilerine ilişkin olabileceği gibi, bir adli veya idari soruşturma işlemlerinin içeriğine ya da devletin güvenliği bakımından önem arzeden belirli **olgulara**, **nesnelere** veya **tecrübelere** ilişkin olabilir.

II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

Hukuk, kişilere ilişkin belirli bilgilerin ilgisiz kişiler bakımından gizli tutulmasını emretmektedir.

Anayasa'ya göre,

“Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” (m. 20, f. 1, ikinci cümle),

“Haberleşmenin gizliliği esastır.” (m. 22, f. 1, ikinci cümle),

“Kimse, ... dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz...” (m. 24, f. 3),

“Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz...” (m. 25, f. 2).

Haberleşme ile özel hayatın ve aile hayatının gizliliği, Anayasa'da belirtilen sebeplerle ve kanunda gösterilen esas ve usullere uygun olarak kaldırılabilir. Bu istisnaların dışında, kişilerin haberleşme içeriklerinin, aile ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğinin ihlali, TCK'da tanımlanan çeşitli suçları oluşturmaktadır (m. 132, 133, 134).

Keza, TCK'da, *“kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine, ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri”*n gizliliğinin ihlali suç olarak tanımlanmıştır (m. 135).

¹ “Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi”nde (Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in the Turkey, 26 Mayıs/May 2010,) tebliğ olarak sunulan bu çalışma, Kongre Kitabı, cilt I, sh. 63 vd.nda yayımlanmıştır.

TCK'da ayrıca, *“ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi”*ler ile *“fennî keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler”*in gizliliğinin ihlali de suç olarak tanımlanmıştır (m. 239).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Kurumun sair personeli, *“görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz(lar) Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.”* (5411 s. Bankacılık Kanunu, m. 73, f. 1).

Keza, *“Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personel, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.”* (5411 s. K, m. 86, f. 4; ayrıca, m. 115, f. 4).

Ayrıca, *“Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.”* 5411 s. K, m. 73, f. 3).

Bankacılık Kanunundaki gizliliğe ilişkin bu yükümlülüklerin ihlali halinde; ilgililerin, yine aynı Kanunun *“Sırların açıklanması”* başlıklı 159. maddesinde tanımlanan suça ilişkin hükümlere göre ve bu hükümlerin eksikliği nedeniyle (!) TCK'nın 239. maddesinde tanımlanan suça ilişkin hükümlere göre cezai sorumlulukları cihetine gidilecektir.

Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip, kendisine Kanunla verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası *“mensupları, sıfat ve görevleri dolayısıyla Bankaya veya Banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere bildikleri sırların gizliliğine riayet eylemek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla yükümlüdürler.”* (1211 s. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, m. 35). Bu yükümlülüğün ihlali halinde; ilgililerin, yine aynı Kanunun 68. maddesinin II. fıkrasının a bendi hükümlerine göre cezai sorumlulukları cihetine gidilecektir.

III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ

Kamu görevlilerinin görevleri gereğince muttali oldukları bilgiler bakımından çeşitli nedenlerle gizlilik söz konusu olabilir. Kamu görevlisi, görevinin gereği olarak bir kişiye ait örneğin kişisel verilere veya ticari bilgilere muttali olabilir. Bu bilgilerin gizliliğinin ihlali halinde, ilgisine göre TCK'nın 135 ila 137. maddelerinde ya da 239. maddesinde tanımlanan suç oluşur.

Örneğin, kişilere ait parmak izi, Kanunda belirlenen esas ve usullere uygun olarak kayda alınabilmektedir. Bu parmak izi kayıtlarına ilişkin bilgiler, kişisel veri olması itibarıyla gizli tutulmuştur (2559 s. PVSK, m. 5). Bu verilere ilişkin gizliliğin ihlali, TCK'nın 135 vd. maddelerinde tanımlanan suçlardan birinin oluşumuna sebebiyet verecektir.

Kamu görevlisi, görevi gereğince muttali olduğu bir işleme ilişkin bilgiyi başkalarına karşı gizli tutması gerekirken, bu gizliliği ihlal etmiş olabilir. Örneğin bir soruşturma sürecinde telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususunda alınmış bir karara ve bu kararın icrasına ilişkin bilginin, niteliği itibarıyla gizli tutulması gerekir (CMK, m. 135, f. 5). Keza bir soruşturma sürecinde görevlendirilen gizli soruşturmacının kimliğine ilişkin bilgilerin, gizli tutulması gerekmektedir (CMK, m. 139, f. 3). Bu bilgilerin açıklanması, başvuru koruma tedbirini akim bırakabilir veya görevlendirilen kişinin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle, söz konusu bilgilere ilişkin gizliliğin ihlali, suç olarak tanımlanmıştır (TCK, m. 285). Gizlilik ihlalinin, bu bilgilere görevi gereğince muttali olan kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, TCK'nın 258. maddesinde tanımlanan suç oluşacaktır.

Keza, CMK'nın “*Soruşturmanın gizliliği*” başlıklı 157. maddesine göre, “*Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.*”². Bu iti-

² Bu madde **gereğince**inde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“*Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve yetkileri Tasarıda saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. ...*

Soruşturma evresinin gizliliği, ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelere örneklerine rastlandığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk karinesi böylece lafta kalmaktadır.

...

barla, soruşturmanın gizliliği mutlak değildir. Soruşturma evresindeki işlemler kural olarak gizlidir. Ancak, “savunma haklarına zarar vermemek” kaydıyla³ soruşturma işlemleri gizli tutulacaktır. Bu nedenle, soruşturma işlemlerinin gizliliği, soruşturmanın süjeleri bakımından kural olarak söz konusu değildir. Ancak, kanunlarda soruşturma evresindeki belirli işlemlerin soruşturmanın belirli süjeleri bakımından da gizli tutulması gerektiği hususunda hükümler bulunmaktadır (CMK, m. 135, f. 5; m. 139, f. 3; m. 153, f. 2; m. 234, f. 1, bent a, alt bent 2; 3713 s. K, m. 10, f. 1, bent d)⁴. Bu istisna hükümlerinin savunma hakkının kullanılmasını kısıtlamayacak şekilde uygulanması, Türk hukuk uygulayıcılarının ortak görevidir. Keza, 157. maddenin ifadesine göre, kanunda aksine hüküm bulunan hallerde soruşturma evresindeki belirli işlemler bakımından gizlilik söz konusu olmayacaktır. Ancak, kanunlarda bu yönde bir hüküm bulunduğu dair bir bilginiz bulunmamaktadır. Bu yönü itibarıyla, söz konusu madde metninin ifadesi sorunludur.

Görevlerinin gereği olarak, bu soruşturma işlemlerinin içeriğine muttali olan kamu görevlilerinin, bunların gizliliğini ihlal etmeleri halinde, TCK’nın 285 ve 258. maddeleri hükümlerine istinaden cezai sorumlulukları cihetine gidecektir.

CMK’nın 157. maddesi hükmünde “*soruşturma evresindeki usul işlemleri*”nin gizliliğinden söz edilmiştir. Soruşturma evresinde örneğin şüpheli hakkında zorla getirme veya yakalama emri veya kararı ya da tutuklama kararı verilmiş olmasının haber konusu yapılmış olması halinde, bunun cezai sorumluluğu gerektirmediği, izahtan varestedir. CMK’nın 157. maddesi gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, gizlilik, “*ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluk*” olduğu gibi, “*suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir.*” Bu nedenle, savunma hakkının kullanılmasına engel oluşturmaya bile, masumluk karinesinin gereği olarak, soruşturma evresindeki belirli işlemlerin içeriğinin, soruşturmanın süjesi konumunda

Soruşturma evresinde gerçekleştirilen işlemlere katılanlar, gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiklerinde Türk Ceza Kanununun bu fiilleri cezalandıran hükümlerine göre cezalandırılacaklardır.” (Gerekçe için bkz. ŞAHİN, Cumhuriyet, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara, 2005, sh. 497).

³ Madde metninde yer alan “*koşuluyla*” ibaresi yerine “*kaydıyla*” ibaresi konulsaydı daha doğru bir ifade olurdu.

⁴ Bu nedenle, soruşturmanın gizliliğinin esas itibarıyla “*üçüncü kişiler ve kamuoyu bakımından geçerli*” olduğu ifade edilmiştir (ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, sh. 498).

olmayan kişilere karşı gizli tutulması gerekmektedir. Örneğin soruşturma evresinde **delillerin tespiti ile ilgili işlemlerin içeriğinin masumluk karinesini ihlal eder biçimde açıklanması**, TCK'nın 285. maddesinde tanımlanan suç bağlamında gizlilik ihlali olarak değerlendirilmelidir.

IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, "DEVLET SIRRİ" KAVRAMI

Demokratik toplumlarda devletin işleyişine dair işlemlerin **açık ve şeffaf** olması esastır. Bu itibarla, kişiler, devletin işleyişine dair bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelidirler. Devletin işleyişine dair işlemlerin açık ve şeffaf olmasının, kamu gücü kullanılarak suç işlenmesinin ve bu bağlamda yolsuzlukların önlenmesi bakımından önemli bir etki doğurduğu kuşkusuzdur.

Ancak, yukarıdaki başlık altında da belirtildiği üzere, belirli kamu görevlerinin yerine getirilmesi bağlamında bazı bilgilerin bu görevlerin yürütülmesine katkıda bulunanlar dışındaki kişilere karşı gizli tutulması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bilgilerin belirli kişilerden başkası tarafından öğrenilmesi, belirli bir kamusal faaliyetin yerine getirilmesini engelleyecekse veya engellenmesi tehlikesini ortaya çıkaracaksa, bu bilgilerin ilgili kamusal faaliyetin yürütülmesine katkıda bulunanlar dışındaki kişilere karşı gizli tutulması gerekmektedir. Örneğin, devletin güvenliği bakımından icra edilen istihbarat faaliyetinin usulüne, yöntemine ve bu faaliyetin yürütülmesine katkıda bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgiler ile bu faaliyet çerçevesinde toplanan bilgiler, gizlidir.

Kamu yönetimindeki açıklık ve şeffaflık kuralına rağmen, belirli **olgulara, nesnelere veya tecrübeler** ilişkin bilgilerin, devletin güvenliği ve milletlerarası ilişkileri bakımından gizli tutulmasına ihtiyaç olduğu da aşîkârdır. Bu nedenle, devletin işleyişiyle bağlantılı belirli **olgulara, nesnelere veya tecrübeler** ilişkin bilgilerin **gizliliği**, ancak **istisnai hallerde** kabul edilebilir.

Bu çerçevede gizli tutulması gereken bilginin **devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önem arz eden bilgi** olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, **gizli tutulmasının devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önemi varsa**, bu bilgiye "devlet sırrı" niteliği izafe edilebilir. Bu nedenle, "devlet sırrı" niteliği kazandırılmış olan bir bilginin açıklanması, **devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından** en azından bir **zarar tehlikesinin** meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu tehlike, **soyut bir tehlike**dir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, gizli tutulabilecek bilgiler, ancak belirli **olgula-**ra, **nesnelere** veya **tecrübelere** ilişkin bilgiler olabilir. Örneğin, sahip olunan silahların, araç ve gerecin teknik özelliklerine, miktarına, bunların muhafazasına ve kullanılmasına ilişkin bilgiler; yeni silahların, araç ve gerecin üretilmesine dair çalışmalar, planlar, teknik bilgiler; görevleri veya sıfatları gereği olarak bu bilgilere muttali olan kişilere ilişkin bilgiler, devletin güvenliği bakımından gizli tutulabilirler. Keza, diğer devletlerle yapılan savunma işbirliğine ilişkin anlaşma içerikleri ve bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamalar, gizli tutulabilirler.

Bu itibarla, yetkili makam veya merciler tarafından açıklanmak suretiyle aleniyet kazanmış olanlar veya mahiyeti bakımından aleniyet taşıyanlar hariç olmak üzere, **askeri bilgiler**, askeri faaliyetlere ilişkin belgeler, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmış olan gizli bilgilerdir.

Devletin güvenliği ve milletlerarası ilişkileri bakımından önem taşımaları dolayısıyla, **istihbarat faaliyetine** ve bu faaliyet neticesinde elde edilen verilere ilişkin bilgiler de “devlet sırrı” niteliğini taşımaktadır.

Devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından icra edilen istihbarat faaliyetinin mutlaka **kanuni dayanağının** bulunması gerekmektedir. Kanuna dayanmayan, esas ve usulleri kanunla belirlenmemiş istihbarat faaliyeti, “Devletin güvenliği” gerekçesiyle icra edilmiş olsa bile, hukuka aykırı faaliyet olarak değerlendirilmek gerekir.

Devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından icra edilen **istihbarat faaliyetine ilişkin bilgilerin gizliliği**, kural olup, bunların hangi hal ve şartlarda açıklanabileceğinin ve aleniyet kazanabileceğinin mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.

İstihbarat faaliyetinin gizli olması, bunların hukuka uygun olarak icra edilip edilmediğinin yargısal olarak denetimine engel teşkil etmemelidir. İstihbarat faaliyetinin, gizliliği ihlal edilmeden **yargısal denetiminin** mümkün kılınması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu faaliyetin toplumda bir fobi olarak algılanması kaçınılmazdır.

Devletin **iç güvenliği** bakımından icra edilen ve “devlet sırrı” olarak koruma altına alınması gereken **istihbarat faaliyetinin** münhasıran **suç işlenmesini önlemek** amacına yönelik olması gerekir. “Devletin güvenliği” gerekçesiyle de olsa, suç işlenmesini önlemek amacına hizmet etmeyen, örneğin kişilerin “*siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine* (ya da) *ırkî kökenlerine*” ilişkin bilgi toplamak şeklindeki faaliyetin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Aksine bu tür faaliyet, kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuk kurallarının ihlali olarak değerlendirilmelidir.

Dikkat edilmelidir ki, somut bir suç olgusu dolayısıyla soruşturma başlatılmış olması halinde, bu soruşturma sürecinde yapılan ve mahiyeti bakımından gizli tutulması gereken belirli işlemlere ve bunların içeriklerine ilişkin bilgiler, “devlet sırrı” kavramı kapsamında değerlendirilmemelidir.

Bilimsel bilgiler de, devletin dış güvenliği bakımından gizli tutulabilirler. İçeriğine başkalarının muttali olmadığı ve münhasıran devletin güvenliği bakımından kullanılmasında yarar görülen belirli bilimsel bilgiler, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilirler. Uzay teknolojisi aracılığı ile ulaşılan veya belirli yeraltı zenginliklerine ilişkin bilimsel veriler, bu hususta örnek olarak gösterilebilir.

Bir bilginin “devlet sırrı” olarak muhafaza altına alınabilmesi için, bunun gizli tutulmasının fiilen mümkün olması gerekir. Aleniyet kazanmış bilgilerin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmasının bir anlamı olmaz.

Devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önem arz ettiği için “devlet sırrı” olarak gizli tutulması gereken bilgilerle yukarıdaki başlıklar altında açıkladığımız gizliliği söz konusu olan diğer bilgiler arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Yukarıdaki diğer başlıklar altında açıklanan bilgilerin gizliliği ile kişi hak ve özgürlükleri arasında uyumluluk ve doğru orantı mevcuttur. Buna karşılık, devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önem arz eden belirli olgulara, nesnelere veya tecrübelerle ilişkin bilgilerin gizliliği (devlet sırları) ile kişi hak ve özgürlükleri arasında ve özellikle, düşüncüyü açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve bilgi edinme hakkı arasında çatışma ve ters orantı söz konusudur.

Yukarıdan beri yaptığımız açıklamalar göstermektedir ki, bir bilginin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilmesi, bunun devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önemi olmasına bağlıdır. Bu husus, belirli bir usul çerçevesinde yapılacak bir **değerlendirmeyi** gerekli kılmaktadır. Bazı kanunda esasen “devlet sırrı” niteliğini taşıyan bilgilerin gizli tutulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsama giren bilgilerin gizliliği ve “devlet sırrı” olarak koruma altına alınması hususunda ayrı bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bunların dışında, bir bilginin örneğin devletin milletlerarası ilişkileri bakımından önem arzetmesine binaen gizli tutulmasının ve “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmasının gerekli olması halinde, bu konuda belirli bir usul çerçevesinde bir idari kararın verilmesi gerekmektedir.

Bir bilgiye “devlet sırrı” niteliğinin izafe edilmiş olması, bunun gizliliğinin ihlali halinde **devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından** en azından bir **zarar tehlikesinin** meydana geldiğini kabul etmeyi gerektirir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu tehlike **soyut bir tehlike**dir. Söz konusu tehlike, bir bilginin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınması hususunda bir ölçüt olmayıp, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmış olan bir bilginin açıklanmasının ortaya çıkaracağı **sonuçtur**.

V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER

Anayasaya göre, düşüncüyü açıklama ve yayma hürriyeti, “*Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması*” amacıyla sınırlanabilir. Anayasada devlet sırrının bir **bilgiye** ilişkin olduğu açıkça belirtilmiştir. Keza, hangi bilgilerin bu kapsamda gizli tutulması gerektiği “*usulünce*” belirlenecektir (m. 26, f. 2).

Ayrıca, Anayasaya göre, “*Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazarlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.*” (m. 28, f. 5). Bu hükümde, “*Devlete ait gizli bilgi*” ibaresi kullanılmıştır.

Bir önceki başlık altında açıkladığımız üzere, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilecek bilgilerin devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önem taşıyan bilgiler olması gerekmektedir. Pozitif hukuk düzenimiz bakımından en üst norm olan Anayasada “devletin güvenliği” ibaresi kullanılmamıştır. Buna karşılık, Anayasanın pek çok hükmünde, “*milli güvenlik*” ibaresine yer verilmiştir. “*Milli Güvenlik*” kavramı, 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı “**Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu**”nda tanımlanmıştır. Söz konusu Kanuna göre; “*Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını, ... İfade eder.*” (m. 2, f. 1, bent a). Bu tanım itibarıyla “milli güvenlik” kavramının “devletin güvenliği” kavramını da içeren ve fakat bundan daha geniş bir anlam ifade ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Buna karşılık, Türk Ceza Kanununda yer alan hükümlere göre, bir bilgiye “devlet sırrı” vasfının izafe edilebilmesi için, bunun “*devletin güvenliğine (emniyetine) ilişkin*” bilgi olması gerekmektedir.

Mülga 765 s. TCK’da,

“Devletin emniyetine veya dahilî, yahut beynelmilel siyasî menfaatlerine taallûk eden” bilgiler (m. 132, f. 1),

“Devletin emniyeti veya dahilî veya beynelmilel siyasî menfaatleri icabından olarak gizli kalması lâzım gelen malûmat” (m. 133, f. 1),

“Gizli kalması Devletin emniyeti ve yukarıda (132. maddenin birinci fıkrasında) yazılı (dahilî, yahut beynelmilel siyasî) menfaatleri icabından olan malûmat” (m. 132, f. 2),

“devlet sırrı” olarak koruma altına alınmıştı⁵.

Keza, “Devletin menfaatleri namına gizli kalması lâzım gelen malûmat arasında, dahilî veya beynelmilel siyasî sebeplerle neşrolunmayan hükûmet muamelelerinin ihtiva ettiği malûmat da dahildir.” (m. 132, f. 2).

Ayrıca, “Salâhiyetli makamların neşir veya işaasını menettiği malûmat”ın (mülga 765 s. TCK, m. 132, f. 3; m. 133, f. 3; m. 137, f. 1) veya “Devletin emniyeti icabı olarak gizli kalması lâzım gelen fenni keşif veya ihtiraları(n) yahut sınaî yenilikler”in (mülga 765 s. TCK, m. 138, f. 1) gizliliğinin ihlali de, “devlet sırrı” bağlamında ceza yaptırımına altına alınmıştı.

Yeni TCK’da da benzer hükümlere yer verilmiştir.

Buna göre, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler”, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmıştır (m. 327, f. 1; m. 328, f. 1; m. 329, f. 1; m. 330, f. 1; m. 339, f. 1),

Eski ve yeni TCK’da yer alan bu hükümlerde, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilecek bilgiler, devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önemi haiz olan bilgilerle sınırlı tutulmamıştır.

Yeni TCK’nın 327. maddesi gerekçesinde, “Sırdan maksa(dın), yetkili bulunmayan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmaları hâlinde ‘Devletin güvenliğinin, millî varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya

⁵ Yargıtay, bir kararında, “Kıbrıs olayları” ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yazdığı 5.6.1964 tarihli mektubun içeriğinin, devlet sırrı oluşturduğu yönünde içtihatta bulunmuştur. Bu içtihatta, Cumhuriyet Senatosunda yapılan bir görüşmede dönemin Dışişleri Bakanının bu mektup içeriğinin devlet sırrı oluşturduğu yönündeki açıklamasına dayanılmıştır: 1. CD, 20.4.1967 (Savaş, Vural/Mollamahmutoğlu, Sadık: Türk Ceza Kanunu, cilt II, 3. bası, Ankara, Mayıs 1999, sh. 1775 vd.).

dış siyasal yararlarının tehlikeye düşebileceği bilgiler” olduğu belirtilmiştir⁶. Muğlak olması nedeniyle eleştiriye açık olan bu açıklamalarda, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilecek bilgiler bakımından madde metinlerine göre daha geniş bir ölçüte yer verilmiştir. Buna göre, açıklanması halinde “**Devletin güvenliğinin, millî varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya dış siyasal yararlarının tehlikeye düşebileceği bilgiler**”, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilecektir.

328. madde gerekçesine göre ise, “*gizliliği gerekli kılan husus **Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlarıdır. Bu itibarla bilgilerin, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları ile yakından ilgili bulunma ve bunların elde edilmelerinin söz konusu değerleri tehlikeye sokabilecek nitelikte olması gereklidir.***”⁷.

326. maddenin gerekçesinde “**Devletin güvenliği**” ve “**Devletin iç ve dış yararları**” kavramlarının içeriğine “açıklık” (!) getirilmeye çalışılmıştır⁸. “**Devletin güvenliği**” kavramı ile ilgili olarak gerekçede “*Devletin varlığının korunması, tehlikeye karşı karşıya bırakılmaması demektir. Devletin varlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki fiiller Devletin güvenliğini ihlâl eder.*” açıklamasına yer verilmiştir. Bu açıklamalardan hangi nitelikleri taşıyan bilgilerin Devletin güvenliğine ilişkin bilgi olduğu hususunda bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. “**Devletin iç ve dış yararları**” kavramı ile ilgili olarak ise, gerekçede şu açıklamalara yer verilmiştir: “*bir büyük örgütlenme olarak Devletin elbette ki, yararları ile güvenliği arasında da sıkı bir ilişki vardır. Yararlarını koruyamayan Devletin güvenliği de tehlikeye düşebilir. Madde, Devlet yararları arasında ‘siyasal’ olanları göz önüne almış bulunmakta; bu nedenle, ekonomik, kültürel ve benzerî nitelikteki yararlarla ilişkin belge veya vesikalar, bu suçun konusunu oluşturmamaktadır. Söz gelimi Devletin dış ilişkilerinin iyi tarzda sürdürülmesi hususundaki yarar gibi.*”

Bu hükümlere göre “**Devletin ... iç ... siyasal yararları**” (“**Devletin ... dahili ... siyasî menfaatleri**”) bakımından gizli kalması gereken bilgiler de “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilecektir. “**Devletin iç siyasal yararları**” ibaresi ile ilgili olarak madde gerekçelerinde yer alan açıklamalar, yol gösterici içerik taşımamaktadır. İtiraf etmemiz gerekir ki, bu ibareden neyin anlaşılması gerektiği hususunda hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır (!)

⁶ TCK, m. 327 gerekçesi, in: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 712.

⁷ TCK, m. 328 gerekçesi, in: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 712.

⁸ TCK, m. 326 gerekçesi, in: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 710.

Keza, mülga 765 s. Kanunda olduğu gibi, “Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları(n) veya sınaî yenilikleri”n (m. 333, f. 1) veya “Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri”n (m. 334, f. 1; m. 335, f. 1; m. 336, f. 1; m. 337, f. 1; m. 339, f. 1) gizliliğinin ihlali de, “devlet sırrı” bağlamında ceza yaptırımını altına alınmıştır.

334 ve devamı maddelerin birinci fıkraları hükümleri karşısında, “yetkili makamlarca kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği yetkiye dayanarak,” belirli bilgilerin açıklanması yasaklanabilecek ve gizli kalması sağlanabilecektir. Hangi türden bilgilerin bu kapsamda açıklanmasının yasaklanabileceği ve gizli tutulabileceği konusunda söz konusu maddelerde herhangi bir ölçüt belirlenmemiştir. Bu konudaki ölçütlerin herhangi bir kanunla veya yönetmelik gibi sair düzenleyici bir işlemle belirlenebileceği kabul edilmiştir. Keza, açıklama yasağının hangi makam veya merci tarafından alınacağı konusunda da bir açıklık bulunmamaktadır. Gizlilik konusunda hangi makam veya mercin karar verebileceği, yönetmelik gibi düzenleyici bir işlemle de belirlenebilecektir⁹. Gizlilik, ilişkin olduğu bilginin mutlaka “devlet sırrı” olmasını gerektirmez. Bu nedenle, TCK’nın söz konusu hükümleri “devlet sırrı” kavramının kapsamını ölçüsüz bir şekilde genişletmiştir. Hatta, diyebiliriz ki, bu hükümler karşısında, TCK’nın 258. maddesinin uygulanabilirliği kalmamıştır. Çünkü, 258. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan bütün gizli bilgiler, “yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgiler” kapsamında değerlendirilebilecektir¹⁰.

Yeni TCK’nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devlet Sırlarına Karşı suçlar ve Casusluk” başlıklı Yedinci Bölüm altında yer alan suç tanımları, mülga 765 s. TCK’nın ilgili hükümleri dili sadece güncellenerek Hükümet Tasarısına alınmış ve esas itibarıyla Tasarıdaki şekliyle kanunlaşmıştır¹¹.

⁹ Bu konuda bkz. TCK, m. 334 gerekçesi, in: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 716.

¹⁰ Bu konuda eleştirel bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Gerekçeli Türk Ceza Kanunu*, Ankara, 2004, sh. 33.

¹¹ “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı Bölüm altında yer alan 326. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suçun oluşabilmesi için, “devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasi yararlarına ilişkin” bilgilerin gizli tutulması şart değildir (madde 326 gerekçesi). Bu itibarla, “devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasi yararlarına ilişkin” bilgiler, devlet sırrı olarak gizli tutulan ve devlet sırrı oluşturmadığı için gizli tutulmayan bilgiler olarak ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Kanunda bu ayırımın hangi ölçüte göre gerçekleştirileceğine dair bir açıklık bulunmadığı gibi, bu konuda doktrinde ileri sürülmüş bir fikirden de haberdar değiliz.

Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında bu suç tanımlarının değiştirilmesi yönündeki girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır¹².

326. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suç, mülga 765 s. TCK'nın 132. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun günümüz Türkçesine uyarlanmasından ibarettir. Bu suçun konusunu “devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasi yararlarına ilişkin” bilgilerin yer aldığı “belge veya vesikalar” oluşturmaktadır. Aslında bu suç tanımında, belirli nitelikteki bilgileri taşıyan belgelerin yok edilmesi, tahrip edilmesi, bozulması, içeriklerinin tahrip edilmesi, değiştirilmesi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması gibi fiiller, ceza yaptırımına altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu suç, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgeyi yok etme suçlarıyla irtibatlıdır. Suçun konusunu oluşturan belge içeriklerinin gizliliği şart olmadığı için, bu suçun devlet sırlarının ihlalini ceza yaptırımına altına alan bölüm içinde yer almasının bir anlamı bulunmamaktadır.

Yeni TCK'nın “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı Bölümü altında yer alan suçların karşılığını oluşturan mülga 765 s TCK'nın ilgili maddeleri, bu Kanunda 1936 yılında 3038 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1930 Faşist İtalyan Ceza Kanunundan iktibas edilmişlerdir.

- ¹² Bu girişimlerimiz çerçevesinde, TCK'nın devlet sırlarına ilişkin hükümlerini sadeleştiren ve 258. maddede tanımlanan suçla aralarındaki sınırı açık bir şekilde ortaya koyan önerge taslakları hazırlamıştık. Ancak, Komisyon çalışmalarına Yargıtay'ı temsilen katılan Keskin KAYLAN'ın hazırladığımız metinlerle devlet sırlarının “korumasız” bırakıldığı yönündeki itirazları üzerine ve Komisyon Başkanı Köksal TOPTAN'ın bu itirazlara itibar etmesi nedeniyle bu önergelerimiz işleme konulmamıştır. Bu önerge taslaklarının içerikleri aşağıdaki şekilde idi:

Birinci önerge taslağı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Türk Ceza Kanunu Tasarısının “Göreve ilişkin sırrın açıklanması” başlıklı 258. maddesi ile, 335, 336, 337, 338 ve 340. maddeleri birleştirilerek, aşağıdaki şekilde 258. madde olarak kabulünü arz ve teklif ederiz.

Göreve ilişkin sırrın açıklanması

MADDE 258- (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle vakıf olduğu ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgi, belge, karar veya emirleri yetkisiz kişilere açıklayan, veren veya ifşa eden kamu görevlisi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de, bu fıkra göre cezaya hükmolunur.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkra yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren bilgi, belge, karar veya emirlerin gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması dolayısıyla yetkisiz kişilerin eline geçmesine neden olan kamu görevlisi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE: Tasarının tamamen kazüistik bir yöntemle tanımlanmış olan hükümlerinin birleştirilerek belirlilik ilkesine uygun olarak anlaşılır bir şekilde tanımlanması gerektiği düşüncesiyle işbu önergenin verilmesi uygun görülmüştür.

İkinci önerge taslağı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Türk Ceza Kanunu Tasarısının İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı Yedinci Bölüm altında yer alan 327, 328, 329, 330, 331, 332 ve 334. maddelerin birleştirilerek, aşağıdaki şekilde 325. madde olarak kabulünü, diğer madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Devlet sırrının açıklanması, elde edilmesi ve casusluk

MADDE 325- (1) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere açıklayan, veren veya ifşa eden kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri, yetkisiz olarak elde eden kişi, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(3) Yabancı bir güç lehine, devlet sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri elde etmeye yönelik gizli istihbarat faaliyetlerinde bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Kişi, bu fiilleri işlemek hususunda hazır olduğunu yabancı güce veya aracısı olan kişilere beyan ederse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Devlet sırrı, ancak belirli görevliler tarafından vakıf olunabilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliği ve milli savunma bakımından yetkisiz kişilere karşı gizli tutulması gereken bilgi veya belgelerdir. Bu kapsamda ayrıca, güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan teknik donanımlara ya da askeri bakımdan önem arzeden üretim tesislerine ilişkin bilgi veya belgeler, devlet sırrı niteliği taşımaktadır. Ancak, bir suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgeler, hiçbir surette devlet sırrı olarak koruma altına alınmaz.

(6) Bir ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin;

a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına veya savaş sırasında işlenmesi,

b) Devletin savaş hazırlıklarını savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokması,

halinde, verilecek ceza yarisından iki katına kadar artırılır.

GEREKÇE: Tasarının tamamen kazüistik bir yöntemle tanımlanmış olan hükümlerinin birleştirilerek belirlilik ilkesine uygun olarak anlaşılır bir şekilde tanımlanması gerektiği düşüncesiyle işbu önerenin verilmesi uygun görülmüştür.

Üçüncü önerge taslağı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Türk Ceza Kanunu Tasarısının “Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi” başlıklı 339. maddesi hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilerek 326. madde olarak kabulünü ve diğer madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Devlet sırrının ele geçirilmesine taksirle neden olma

MADDE 326- (1) **Gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması dolayısıyla devlet sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine neden olan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.**

GEREKÇE: Madde metninde devlet sırlarının taksirli davranışla ele geçirilmesine neden olma suçu belirlilik ilkesine uygun olarak yeniden tanımlanmıştır.

Dördüncü önerge taslağı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Türk Ceza Kanunu Tasarısının “Askeri yasak bölgelere girme” başlıklı 333. maddesi hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilerek 327. madde olarak kabulünü ve diğer madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Askerî yasak bölgelere girme

MADDE 327- (1) **Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, bu özelliğini bilerek, gizlice veya hile ile giren kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.**

(2) **Fiil, savaş zamanında işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılır.**

GEREKÇE: Değişiklik önergesiyle söz konusu suçun cezasının fiille orantılı hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Bu girişimlerimiz sonuçsuz kalmakla birlikte, Kanuna bir hüküm olarak eklemeyi düşündüğümüz **“Bir suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgeler, hiçbir surette devlet sırrı olarak koruma altına alınmaz.”** kuralını TCK’nın 227. maddesinin Tasarının TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen metninin gerekçesine dercetmeyi sağlayabilmiş bulunmaktayız: Bir **“suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgeler, bir hukuk toplumunda hiçbir surette devlet sırrı olarak koruma altına alınmaz.”**¹³.

Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısında **“Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin”** bilgiler, tanıklıktan çekinme hakkı çerçevesinde “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmıştı (m. 49, f. 1). Tasarının TBMM Adalet Alt Komisyonunda kabul edilen metninde ise, sadece “devlet sırrı” ibaresi kullanılmıştı; ancak, hangi bilgilerin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabileceği hususunda herhangi bir hüküm içermemekteydi (m. 47). Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında Alt Komisyonunda kabul edilen maddenin birinci fıkrasına ikinci bir cümle eklenmiştir. Buna göre, **“Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır.”** Bu cümlemin formülasyonunda, halen TBMM Adalet Komisyonunun gündeminde olan **“Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı”**nın **“Devlet sırrı”** başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasındaki tanım esas alınmıştır. Eklenen bu cümlede yer alan ibareler, büyük ölçüde bizim belirlediğimiz ölçütle örtüşmektedir. Ancak, **“açıklanması Devletin anayasal düzeni(nde) tehlike yaratabilecek nitelikte olan bilgiler”**den neyin kastedildiği taarfımızdan anlaşılmamıştır.

“Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı”nın 3. maddesinin birinci fıkrasında **“Devlet sırrı; açıklanması veya öğrenilmesi, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerdir.”** şeklinde tanımlanmış olmakla birlikte; Tasarının genel gerekçesinde, **“Tasarıyla, iç ve dış güvenlik, askerî ve siyasî alanlar dışında ekonomik alanlardaki devlet sırları ve gizlilikler de kapsama alınmıştır. Koşullarının varlığı halinde devlete ait bir kısım ekonomik bilgi ve belgeler de devlet sırrı ya da gizlilik kavramları içersinde nitelendirilebilecektir.”** şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

¹³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 712.

Ekonomik alandaki bilgiler, “*ticari sır*”, “*bankacılık sırrı*” veya “*müşteri sırrı*” adı altında koruma altına alınabilirler. Ancak kanımızca, ekonomik faaliyete ilişkin bir bilgiye “devlet sırrı” niteliği izafe edilemez. Çeşitli kamu kurumlarının bünyesinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde yabancı devlet veya kamu kurumları ile ticari sözleşmeler imzalanmaktadır. Örneğin doğal gaz alımı konusunda yapılan sözleşmelere, fiyat unsuru gibi sözleşme içeriklerinin gizliliği yönünde hükümler konulmaktadır. Akdedilen sözleşme gereğince gizli tutulması gereken bu bilgiler, “devlet sırrı” olarak değil, **ticari sır** oldukları için koruma altına alınmaktadır.

Mevzuatımızda belirli olgulara, belirli faaliyetlere veya belirli tecrübelere ilişkin bilgilerin gizliliği, bu gizliliğin ihlalinin suç olarak tanımlandığı, bu bilgilerin ne suretle kullanılacağı hususlarında çeşitli kanunlarda hükümler bulunmaktadır.

1) TBMM Genel Kurulunda 5.3.1973 tarihinde 584 sayı ile kabul edilen ve 13 Nisan 1973 tarihli ve 14506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan **Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü**nün “*Kapalı oturumlar*” başlıklı 70. maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda “*Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır.*” (f. 5).

Keza, “*Kapalı oturum tutanakları*” başlıklı 71. maddesine göre, “*Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir.*” (f. 2)

Hatta TBMM komisyonlarında da kapalı oturum düzenlenebilir (İçtüzük, m. 32). Bu durumda komisyonda yapılan görüşmeler, “sır olarak” saklanacaktır (m. 32, f. 3). Ancak, gizli tutulan bu görüşmelerin içeriğinin hukuki mahiyetine ilişkin olarak İçtüzükte bir belirleme yapılmamıştır.

2) Bir anayasal kurum olan “*Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.*” (Any., m. 118, f. 3). Keza, “*Millî Güvenlik Kurulu, 2 nci maddede belirtilen millî güvenlik ve Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinas-*

yonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.” (9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı “**Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu**”, m. 4, f. 1). Bu görevlerin yerine getirilmesi bağlamında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmelere ilişkin “*tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.*” (2945 s. K, m. 10, f. 2). Bu düzenlemeler itibarıyla, MGK toplantılarında yapılan **müzakereler** ile bu müzakereler sonucunda alınan **kararlar**, kural olarak **gizlidir**. Ancak, MGK, bu kararlardan bir kısmıyla ilgili olarak gizlilik kararını kaldırma yönünde karar alarak, bunların açıklanmasına veya yayımlanmasına izin verebilmektedir.

3) Askerlik faaliyeti bakımından hangi bilgilerin gizli kalması gerektiği hususu ile bu gizliliğe ilişkin esas ve usuller, ilgisine göre çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı “**Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu**”nda, “*sır saklamak*” askerin görevleri arasında sayılmıştır (m. 39, f. 2). Bunun dışında söz konusu Kanunda hangi bilgilerin gizli tutulması gerektiği hususunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır.

4) 29.6.2004 tarihli ve 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri İle Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”da bu Kanun kapsamına giren silahlar ile diğer malzemenin teknik özelliklerine, üretimine, muhafazasına, miktarına, ihracına, ithaline ilişkin bilgilerin **gizliliği** hususunda herhangi bir hüküm bulunmamasıyla birlikte; belirtilen hususlarla ilgili gizliliğin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılı hükümler, 29.6.2004 tarihli ve 5202 sayılı “**Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu**”nda belirlenmiştir.

5) Askeri bilgilerin gizliliği bağlamında hüküm, 17.7.1972 tarihli ve 1612 sayılı “**Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun**”da yer almaktadır. Söz konusu Kanunun “Kararların gizliliği” başlıklı 8. maddesine göre; “*Yüksek Askeri Şüra toplantıları **gizli** olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına **Yüksek Askeri Şüranın kararıyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.***” (f. 1). Keza, “*Yüksek Askeri Şürada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile alınan kararların **gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.***” (f. 2).

6) 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı “**Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu**”nda, “*Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında **milli güvenlik istihbaratını** Devlet çapında **oluşturmak** ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.*” Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri arasında sayılmıştır (m. 4, f. 1, bent a). Bu Kanunda, “*Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine taallük eden*” bilgilerin gizliliğini ihlal eden fiiller karşılığında, bunların diğer kanunlarda daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturulmaması halinde, uygulanacak ceza yaptırımları belirlenmek suretiyle (m. 27), söz konusu istihbarat faaliyetinin ve bu faaliyet çerçevesinde elde edilen bilgilerin gizli olduğu hüküm altına alınmıştır; keza, Milli İstihbarat Teşkilatının personeline ilişkin atama işlemlerinin Resmi Gazetede yayımlanmayacağı ve gizli tutulacağı hükmüne yer verilmiştir (m. 13, f. 4)¹⁴. Ayrıca, bu Kanunun 6. maddesine 3.7.2005 tarihli ve 5397 sayılı Kanunla eklenen fıkralarda, devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bağlamında icra edilen istihbarat faaliyeti çerçevesinde, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti ve teknik araçla izlemenin icrasına dair esas ve usullere, bu konuda alınan kararların ve icra edilen faaliyetin gizliliğine ve bu faaliyet çerçevesinde elde edilen bilgilerin ne amaçla kullanılabileceği hususlarına dair düzenlemeler yapılmıştır (f. 2 – 10)¹⁵.

¹⁴ Bu çerçevede ayrıca söz konusu Kanunun “Tanıklık” başlıklı 29. maddesi hükmüne işaret etmek gerekir. Buna göre; “*Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine bağlıdır.*”. CMK’nın 47. maddesi düzenlemesi karşısında, bu hükmün zımnen ilga edildiğini kabul etmek gerekir.

¹⁵ “*Bu Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7’nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun*

7) 31.7.1970 tarihli ve 1324 sayılı “Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun”da Genelkurmay Başkanının görevleri, “**Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, hareket, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprog-ramlarını tespit**” etmek olarak belirlenmiştir (m. 2, f. 1). Söz konusu Kanunda, “**Silahlı Kuvvetlerin istihbarat hizmetleri**” ibaresinden neyin anlaşılacağı konusunda bir açıklık bulunmadığı gibi, bu istihbarat faaliyetinin icrasının esas ve usullerine, bu faaliyetin icrasında istihdam edilen personele ilişkin olarak bir hüküm bulunmamaktadır. Kanımızca bu istihbaratın, **askeri faaliyetlerle sınırlı bir istihbarat** olması gerekmektedir¹⁶.

135’inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.” (f. 2).

“Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250’nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” (f. 3).

“Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespiti imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, casusluk faaliyetlerinin tespiti ve terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.” (f. 4).

“Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.” (f. 5).

“**Bu fıkra(lar) hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir.** Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.” (f. 6).

“Hâkim kararları ve yazılı emirler, MİT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.” (f. 7).

“Bu maddede yer alan faaliyetlerin **denetimi**, sıralı kurum amirleri, **Başbakanlık teftiş elemanları (...)** tarafından yapılır.” (f. 8).

“Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.” (f. 9).

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” (f. 10).

¹⁶ Bu itibarla, ülke içindeki veya dışındaki **siyasi gelişmelere ilişkin bilgi toplamaya yönelik faaliyet**, askeri istihbarat faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. **Siyasi gelişmelere** ilişkin olarak asker kişiler tarafından icra edilen istihbarat faaliyeti, devlet sırrı olarak koruma altına alınamaz.

8) Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7. maddesi hükümlerine göre, “Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, **emniyet ve asayişini sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır.** Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.” (f. 1). Söz konusu Kanunda, bu istihbarat faaliyetinin ne suretle icra edileceği, bu faaliyet çerçevesinde kimlerin ve ne suretle istihdam edilebileceği, bu faaliyetten elde edilen bilgilerin gizliliği, hangi amaçla ve ne suretle kullanılabilirliği hususlarında bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu maddeye 5397 sayılı Kanunla eklenen fıkralarda, devletin iç güvenliğini korumaya yönelik istihbarat faaliyeti çerçevesinde, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti ve teknik araçla izlemenin icrasına dair esas ve usullere, bu konuda alınan kararların ve icra edilen faaliyetin gizliliğine ve bu faaliyet çerçevesinde elde edilen bilgilerin ne amaçla kullanılabilirliği hususlarına dair düzenlemeler yapılmıştır (f. 2 – 12)¹⁷.

¹⁷ “Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı **suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyâl bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir.** Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli **hâkimin onayına** sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.” (f. 2)

“**Yetkili ve görevli hâkim**, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibarıyla yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250’nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” (f. 3)

“Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tesbite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usülle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.” (f. 4)

“Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.” (f. 5)

“**İstihbarat faaliyetlerinde**, bu maddede belirtilen **suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı** alınmak koşuluyla, **teknik araçlarla izleme** yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanıla-

İstihbarat faaliyetinin devletin dış veya iç güvenliğine yönelik olması, mevzuatımızda kurumlar arasındaki görev bölüşümü bakımından bir kıstas olarak dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı alanda istihbarat faaliyetinde bulunabilmektedir.

Devletin iç güvenliğine ilişkin istihbarat faaliyetinin münhasıran suç işlenmesinin önlenmesi amacına yönelik olması gerekmektedir. Ancak, belirtmek gerekir ki, ülkemizde istihbarat toplamakla görevlendirilmiş olan kamu kurumlarında, iç güvenlik bakımından suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla sınırlı olmaksızın, kişilerin düşünce ve kanaatlerine ve bu bağlamda dini inançlarına ilişkin bilgiler başta olmak üzere, belirli kişisel verilerin de kayıt altına alındığına tanık olunmaktadır.

bilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.” (f. 6)

“Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.” (f. 7)

“Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.” (f. 8)

“Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ... tarafından yapılır.” (f. 9)

“Bu maddede belirtilen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135’inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı” adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur. Bu Başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir. ... Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.” (f. 10)

“Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.” (f. 11)

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” (f. 12)

Bu hükümlere benzer düzenlemeler, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı “Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu”na 5397 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5’te yer almaktadır.

Hatta hiçbir kanuni dayanağı olmadığı halde bazı kamu kurumlarında kişilerin dini, siyasi veya felsefî düşünce ve tercihlerine ilişkin bilgilerin toplandığı ve bu bilgilerin atama ve görevlendirme gibi çeşitli idari işlemlerin tesisinde göz önünde bulundurulduğu hususlarına tanık olunmaktadır¹⁸.

Yukarıda da açıkladığımız üzere bir bilgi, devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından önem taşıması nedeniyle gizli tutulduğu takdirde, “devlet sırrı” niteliği kazanmaktadır. Bilginin gizli tutulması çoğu zaman ilgili kanun hükümlerine dayanmaktadır.

Ancak devletin askeri faaliyetine ilişkin bilgiler, kural olarak gizlidir¹⁹. Askeri faaliyete ilişkin olmakla birlikte, yetkili makam veya mercilerce açıklanan ya da mahiyeti bakımından aleniyet kazanmış olan bilgiler, gizlilik koruması dışında tutulmak gerekir.

Keza, kanuni dayanağı olan, esas ve usulleri kanunla belirlenmiş olan istihbarat faaliyeti, bu faaliyetin icrasında istihdam edilen kişilerin kimliği, bu faaliyetten elde edilen veriler, bu verilerin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, devletin güvenliği bakımından önem taşıdıkları için, “devlet sırrı” olarak koruma altına alınması gereken bilgi niteliği taşımaktadır. Ancak, bu bilgilere hangi kamu görevlilerinin, hangi şartlar altında ve ne ölçüde muttali olabileceğinin de ilgili kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgili kurum personelinin kontrolsüz bir şekilde içeriğine muttali olabileceği bilgi, gizlilik kaydı taşısa bile, gizliliği kontrol edilemeyen bir

¹⁸ Bu bilgiler, kim tarafından hazırlandığı belirtilmeksizin ve herhangi bir kamu kurumu ile ilişkilendirilmeksizin imzasız bir “bilgi notu” şeklinde işlem dosyasına dercedilmektedir. Örneğin Yükseköğretim Kurulunda Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ’ün başkanlığı döneminde öğretim üyelerinin siyasi ve dini tercihleri ile ilgili olarak toplanan bilgilerin yer aldığı bir arşiv oluşturulmuştur. Gizli tutulan bu arşiv bilgileri, örneğin rektör seçimi ile dekan seçimi ve ataması işlemlerinde kullanılmıştır. Hatta bu bilgilerden hareketle, GÜRÜZ’ün başkanlığındaki YÖK yönetimi tarafından çok sayıda öğretim üyesi, başka illerdeki üniversitelere gönderilmek ve çalışmak mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu görevlendirmelerle aile parçalanmalarına ve ruh sağlığı bozulmuş kişiliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verilmiştir. Bu görevlendirmeler sırasında kadro aktarımı da yapılmış olması dolayısıyla bu öğretim üyelerinin geri dönüşünün sağlanmasında büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Günümüzdeki YÖK yönetimi tarafından bu bilgilerin kullanılmasından sarfınazar edilmiştir. Ancak, YÖK bünyesinde halen muhafaza edilen bu kayıtların akibeti ile ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği hususunda henüz bir karar verilebilmiş değildir. Hukuka aykırı olarak tutulmuş olan bu kayıtların bir an önce imha edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

¹⁹ Yargıtay’ın bir kararında, “Devletin harp kudret ve kabiliyetine dair bilgi” niteliğinde olduğu için Türkiye’ye yapılan askeri yardımlara ilişkin bilgiler, devlet sırrı olarak kabul edilmiştir.: 1.CD, 9.1.1973, 4640/19 (Savaş/Mollamahmutoğlu II (3. Bası), sh. 1778).

bilgi olması nedeniyle, “devlet sırrı” olarak nitelendirilemez²⁰. Her somut olayda, gizlilik kaydı taşısa bile, bilgi içeriklerine kurum personelinin kontrolsüz bir şekilde muttali olabilip olamayacağının, “devlet sırrı”nın ihlali suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi ve tespiti bağlamında araştırılması gerekmektedir.

Hukuk uygulamamızda, bir bilginin içeriği itibarıyla gizli tutulması gereken bilgi olup olmadığının, gizlilik kaydı içeren bilginin “devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığının tespiti, bilirkişi marifetiyle yapılmaktadır²¹. CMK’nın 63. maddesinin birinci fıkrası hükmü karşısında, bu uygulamayı doğru bulmaktayız. Bir bilginin (“devlet sırrı” olarak) gizli tutulması gereken bir bilgi olup olmadığının tespiti hukuki bir değerlendirmeyi gerektirdiği için ancak mahkeme tarafından yapılabilir. Aksi takdirde bizzat hakim tarafından yapılması gereken iş, bilirkişiyeye havale edilmiş olacaktır. Ancak, örneğin yabancı dille yazılmış bir belgenin içeriğinin Türkçe olarak ifadesi için tercüman, belge içeriğindeki şifrelerin çözümü için bilirkişi, görevlendirilebilir.

Keza, gizlilik kaydı altına alınmış olsa bile, mahiyeti bakımından aleniyete kavuşmuş olan devletin askeri faaliyeti ile ilgili bilgilerin basın ve yayın organlarında haber veya yorum konusu yapılması halinde, “devlet sırrı” niteliği taşıyan bilginin gizliliğinin ihlali artık söz konusu olmayacaktır. Ancak, mahiyeti bakımından “devlet sırrı” niteliği taşıyan ve bu nedenle koruma altına alınan örneğin askeri bilgilerin gizliliğinin ihlal edilmesi, bunların “devlet sırrı” niteliğini ortadan kaldırmaz.

Devletin milletlerarası ilişkileri bakımından önem taşıması itibarıyla hangi bilgilerin gizli tutulması gerektiğinin Dışişleri Bakanlığı yetkililerince belirlenmesi gerekmektedir²². Bu itibarla, Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Görev

²⁰ Askeri Yargıtay bir kararında “kursiyer subayların dahi” içeriğine muttali olabildikleri bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıyıp taşımadığının irdelenmesi gerektiği içtihadında bulunmuştur: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 21.6.2007, 83/81 (Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa: *Türk Ceza Kanunu*, cilt VI, Ankara, 2010, sh. 8674 vd.).

²¹ Aşağıdaki kararlara konu teşkil eden bilgilerin “devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığının tespiti, bilirkişiyeye yaptırılmıştır: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 21.6.2007, 83/81; Askeri Yargıtay Üçüncü Dairesi, 6.1.2009, 1/1; Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesi, 13.1.2009, 1/1. Buna karşılık, Askeri Yargıtay Birinci Dairesinin 18.6.2008 tarihli ve 1890/1886 sayılı Kararında, gizliliği ihlal edilen bilgilerin devlet sırrı niteliğinde olup olmadığının bilirkişiyeye tespit ettirilmemiş olması, bir bozma sebebi olarak görülmemiştir.

²² Yargıtay’ın bir kararında, Büyükelçilik bünyesindeki gizli bilgilerin muhafaza edildiği kasaya ve bu kasanın bulunduğu odanın kapısına ait şifre bilgileri de, devlet sırrı kapsamında değerlendirilmiştir: 9. CD, 14.1.1975, 6/1 (Savaş/Mollamahmutoğlu II (3. Bası), sh. 1778).

ve Yetkilerine Dair Kanunda, devletin milletlerarası ilişkileri bakımından önem taşıması itibarıyla gizli tutulması gereken bilgilerin belirlenmesine, muhafazasına, kullanılmasına ve açıklanmasına dair esas ve usullerin düzenlenmesi gerektiği kanısındayız²³.

²³ Başbakanlık tarafından, 21.10.2011 tarihli ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü B.02.0.KKG.0.10/101-1218/1761 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığına gönderilen **Devlet Sırrı Kanun Tasarısının** TBMM Adalet Komisyonunda müzakeresi sonucunda hazırlanan 15.6.2012 tarihli ve Esas 1/484, Karar 13 sayılı Raporda, Devlet sırrı ile ilgili olarak şu bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir:

“Mevcut uygulamamıza göre, Devletin işleyişi bağlamında belirli bilgi, belge ve kayıtların devlet sırrı niteliğini taşıyıp taşımadığı ancak, bir uyumsuzluk bağlamında bu bilgi belge ve kayıtların mahkemeye sunulmasının istenmesi veya bilgi edinme hakkının kullanılması halinde tartışma konusu yapılmaktadır. Bu uygulamada Devletin işleyişi bağlamında gizli tutulan bilgi, belge ve kayıtlardan hangilerinin devlet sırrı niteliğini taşıdığı, bir uyumsuzluk bağlamında bu bilgi belge ve kayıtların mahkeme veya ilgili kişiler tarafından talep edilmeden önce belirlenmemektedir. İşaret etmek gerekir ki, Devletin işleyişi bağlamında gizli tutulan her türlü bilgi, belge ve kayıt, devlet sırrı niteliğini taşımamaktadır.

Kamu görevlilerinin görevleri gereğince muttali oldukları bilgiler bakımından çeşitli nedenlerle gizlilik söz konusu olabilir. Kamu görevlisi, görevinin gereği olarak bir kişiye ait örneğin kişisel verilere veya ticari bilgilere muttali olabilir. Bu bilgilerin gizliliğinin ihlali halinde, ilgisine göre TCK’nın 135 ila 137. maddelerinde ya da 239. maddesinde tanımlanan suç oluşur.

Örneğin, kişilere ait parmak izi, Kanunda belirlenen esas ve usullere uygun olarak kayda alınabilmektedir. Bu parmak izi kayıtlarına ilişkin bilgiler, kişisel veri olması itibarıyla gizli tutulmuştur (2559 s. PVSK, m. 5). Bu verilere ilişkin gizliliğin ihlali, TCK’nın 135 vd. maddelerinde tanımlanan suçlardan birinin oluşumuna sebebiyet verecektir.

Kamu görevlisi, görevi gereğince muttali olduğu bir işleme ilişkin bilgiyi başkalarına karşı gizli tutması gerekirken, bu gizliliği ihlal etmiş olabilir. Örneğin bir soruşturma sürecinde telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususunda alınmış bir karara ve bu kararın icrasına ilişkin bilginin, niteliği itibarıyla gizli tutulması gerekir (CMK, m. 135, f. 5). Keza bir soruşturma sürecinde görevlendirilen gizli soruşturmacının kimliğine ilişkin bilgilerin, gizli tutulması gerekmektedir (CMK, m. 139, f. 3). Bu bilgilerin açıklanması, başvurulacak koruma tedbirini akim bırakabilir veya görevlendirilen kişinin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle, söz konusu bilgilere ilişkin gizliliğin ihlali, suç olarak tanımlanmıştır (TCK, m. 285). Gizlilik ihlalinin, bu bilgilere görevi gereğince muttali olan kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 258’inci maddesinde tanımlanan suç oluşacaktır.

Keza, Ceza Muhakemesi Kanununun “*Soruşturmanın gizliliği*” başlıklı 157’nci maddesine göre, “*Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.*” Soruşturma işlemlerinin gizliliği, soruşturmanın süjeleri bakımından kural olarak söz konusu değildir. Ancak, kanunlarda soruşturma evresindeki belirli işlemlerin soruşturmanın belirli süjeleri bakımından da gizli tutulması gerektiği hususunda hükümler bulunmaktadır (CMK, m. 135/f. 5; m. 139/f. 3; m. 153/f. 2; m. 234/f. 1, bent a, alt bent 2; 3713 s. K, m. 10/f. 1, bent d).

Görevlerinin gereği olarak, bu soruşturma işlemlerinin içeriğine muttali olan kamu görevlilerinin, bunların gizliliğini ihlal etmeleri halinde, TCK’nın 285 ve 258. maddeleri hükümlerine istinaden cezai sorumlulukları cihetine gidilecektir.

Demokratik toplumlarda devletin işleyişine dair işlemlerin açık ve şeffaf olması esastır. Bu itibarla, kişiler, devletin işleyişine dair bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelidirler. Devletin işleyi-

şine dair işlemlerin açık ve şeffaf olmasının, kamu gücü kullanılarak suç işlenmesinin ve bu bağlamda yolsuzlukların önlenmesi bakımından önemli bir etki doğurduğu kuşkusuzdur.

Ancak, belirtildiği üzere, belirli kamu görevlerinin yerine getirilmesi bağlamında bazı bilgilerin bu görevlerin yürütülmesine katkıda bulunanlar dışındaki kişilere karşı gizli tutulması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bilgilerin belirli kişilerden başkası tarafından öğrenilmesi, belirli bir kamusal faaliyetin yerine getirilmesini engelleyecekse veya engellenmesi tehlikesini ortaya çıkaracaksa, bu bilgilerin ilgili kamusal faaliyetin yürütülmesine katkıda bulunanlar dışındaki kişilere karşı gizli tutulması gerekmektedir. Örneğin, devletin güvenliği bakımından icra edilen istihbarat faaliyetinin usulüne, yöntemine ve bu faaliyetin yürütülmesine katkıda bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgiler ile bu faaliyet çerçevesinde toplanan bilgiler, gizlidir.

Kamu yönetimindeki açıklık ve şeffaflık kuralına rağmen, belirli olgulara, nesnelere veya tecrübelerle ilişkin bilgilerin, devletin güvenliği ve milletlerarası ilişkileri bakımından gizli tutulmasına ihtiyaç olduğu da aşikardır. Bu nedenle, devletin işleyişiyle bağlantılı belirli olgulara, nesnelere veya tecrübelerle ilişkin bilgilerin gizliliği, ancak istisnai hallerde kabul edilebilir.

Bu çerçevede gizli tutulması gereken bilginin Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önem arz eden bilgi olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, gizli tutulmasının Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önemi varsa, bu bilgiye “devlet sırrı” niteliği izafe edilebilir. Bu nedenle, “devlet sırrı” niteliği kazandırılmış olan bir bilginin açıklanması, Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından en azından bir zarar tehlikesinin meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu tehlike, soyut bir tehlikedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, gizli tutulabilecek bilgiler, ancak belirli olgulara, nesnelere veya tecrübelerle ilişkin bilgiler olabilir. Örneğin, sahip olunan silahların, araç ve gerecin teknik özelliklerine, miktarına, bunların muhafazasına ve kullanılmasına ilişkin bilgiler; yeni silahların, araç ve gerecin üretilmesine dair çalışmalar, planlar, teknik bilgiler; görevleri veya sıfatları gereği olarak bu bilgilere muttali olan kişilere ilişkin bilgiler, milli güvenlik bakımından gizli tutulabilirler. Keza, diğer devletlerle yapılan savunma işbirliğine ilişkin anlaşma içerikleri ve bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamalar, gizli tutulabilirler.

Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önem taşıyan istihbarat faaliyetine ve bu faaliyet neticesinde elde edilen verilere ilişkin bilgiler de “devlet sırrı” niteliğini taşımaktadır.

Buna karşılık, Devletin iç güvenliği bakımından icra edilen istihbarat faaliyeti mahiyeti itibarıyla gizli olmakla birlikte, “devlet sırrı” niteliği taşımamaktadır.

Bilimsel bilgiler de, Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önem arz etmeleri halinde “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilmelidir.

İşaret etmek gerekir ki, bir bilginin “devlet sırrı” olarak muhafaza altına alınabilmesi için, bunun gizli tutulmasının fiilen mümkün olması gerekir. Aleniyet kazanmış bilgilerin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmasının bir anlamı olmaz.

Yukarıda açıklanan çeşitli kamusal faaliyetler bağlamında belirli bilgilerin gizliliği ile kişi hak ve özgürlükleri arasında uyumluluk ve doğru orantı mevcuttur. Buna karşılık, Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önem arz eden belirli olgulara, nesnelere veya tecrübelerle ilişkin bilgilerin gizliliği (devlet sırları) ile kişi hak ve özgürlükleri arasında ve özellikle, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve bilgi edinme hakkı arasında çatışma ve ters orantı söz konusudur.

Bir bilginin “devlet sırrı” olarak koruma altına alınabilmesi, bunun Devletin uluslararası ilişkileri veya milli güvenlik bakımından önemli olmasına bağlıdır. Bu husus, belirli bir usul çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmeyi gerekli kılmakta ve bu konuda belirli bir usul çerçevesinde bir idari kararın verilmesi gerekmektedir.” (TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 287, sh. 32 vd).

Bu değerlendirmeler ışığında **Devlet Sırrı Kanun Tasarısına** ilişkin olarak TBMM Adalet Komisyonu'nun kabul ettiği metin aşağıdaki gibidir:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi, belge ve kayıtların ne şekilde belirleneceğini, korunacağını, açıklanacağını ve bu hususlara ilişkin yükümlülükleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi, belge ve kayıtları bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Devlet sırrı

MADDE 3- (1) Devlet sırrı, yetkisiz **kişilere açıklanması** Devletin uluslararası ilişkilerine veya milli güvenliğe zarar verebilecek mahiyetteki gizli bilgi, belge ve kayıtlardır.

(2) Birinci fıkra hükmü, hukuk devleti ilkesine ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı biçimde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Devlet Sırrı Değerlendirme Kurulu

MADDE 4- (1) Devlet Sırrı Değerlendirme Kurulu, Başbakanın başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşur. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Kurul, **Başbakanın** daveti üzerine toplanır.

Bilginin devlet sırrı olarak koruma altına alınması

MADDE 5- (1) Bir bilgi, belge ve kaydın, devlet sırrı niteliğinde olması sebebiyle, koruma altına alınmasına **Kurul** karar verir.

(2) Bilgi, belge ve kaydın devlet sırrı olarak belirlenmesi teklifi, görev veya faaliyet alanı itibarıyla ilgili bulunulan bakanlık aracılığıyla yapılabilir. Başbakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşları bakımından bu teklif, Başbakanlık aracılığıyla yapılabilir. Başbakanlık veya bakanlıklar, yapılan teklifi uygun görmedikleri takdirde, Kurula iletmezler.

(3) Teklifte bulunulması halinde, aksine karar verilmediği takdirde ve her halde teklifin ilgili kurum veya kuruluş tarafından yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süreyle bu bilgi, belge ve kaydın gizliliği korunur.

(4) Bilimsel bir buluş, milli güvenlik bakımından önem arz eden bir mahiyet taşıması halinde birinci fıkra hükümlerine göre, devlet sırrı olarak koruma altına alınabilir. Bu durumda, buluş sahibi gerçek veya tüzel kişinin her türlü fikrî ve sınai hakkı saklı tutulur.

(5) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu ve içeriğinin gizli olması sebebiyle Resmi Gazetede yayımlanmayan ikili veya çok taraflı antlaşmaların içeriğinin devlet sırrı niteliği taşıyıp taşımadığına, birinci fıkra hükümlerine göre Kurul tarafından karar verilir.

(6) Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli oturum kararı alması üzerine, bu oturumda açıklanan bilgilere ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri saklıdır.

(7) Cumhurbaşkanlığına ait bilgi, belge ve kayıtların niteliğini Cumhurbaşkanı takdir eder.

Devlet sırrı niteliği taşıyan bilgileri içeren belge ve kayıtların tutulması

MADDE 6- (1) **Devlet sırrı niteliği** taşıyan bilginin yer aldığı belge ve sair kayıta, bu belge veya kaydın kimin tarafından düzenlendiği, içeriğine Kurul ve ilgili bakan dışında kimin mutali olduğu ve kimler tarafından görülebileceği açıkça yazılır.

Devlet sırrı olmaktan çıkarma

MADDE 7- (1) Kurul, devlet sırrı olarak koruma altına alınan bir bilginin bu özelliğini kaybetmesi sebebiyle, devlet sırrı olmaktan çıkarılmasına karar verebilir. Ancak, bir bilgi, Kurul kararının verildiği tarihten itibaren elli yıl geçtikten sonra devlet sırrı olarak korunmaz.

VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU

“Devlet sırrı” niteliği kazandırılmış olan bilgilerin gizliliğinin ihlali ceza sorumluluğunu gerektirmektedir. Ceza hukukunun güvence fonksiyonunun gereği olarak, hangi bilgilerle ilgili gizlilik ihlalinin bu suç tanımlarıyla ceza yaptırımı altına alındığının açıkça belirlenebilmesi gerekmektedir (belirlilik ilkesi). Bir önceki başlık altında yapmış bulunduğumuz açıklamalar göstermektedir ki, Türk Ceza Kanununun devlet sırlarının gizliliğinin ihlalini ceza yaptırımı altına alan hükümlerinde hangi bilgilerin “devlet sırrı” olarak ko-

Bilgi, belge ve kayıtların mahkemelere verilmesi

MADDE 8- (1) Mahkemeler tarafından talep edilen devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi, belge ve kayıtlar, Kurulca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, verilmeyen bilgi, belge ve kayıtlar, davada ilgili aleyhine sonuç doğurmaz.

(2) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır.

(3) Cumhurbaşkanı bilgi, belge ve kayıtları mahkemeye gönderme hususunu kendisi takdir eder.

Koruma yükümlülüğü

MADDE 9- (1) Bu Kanuna göre mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesine karar verilen bilgi, belge ve kayıtların mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sürecinde yetkili makam veya merci, teslim edilmelerinden sonra ise mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları bunların yetkisiz kişilerce elde edilmesini veya açıklanmasını önlemek için her türlü tedbiri alır.

Yönetmelik

MADDE 10- (1) Devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi, belge ve kayıtların tabi olacağı esas ve usuller ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 11- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlem görmüş olup, yeniden işleme alınması gereken bilgi, belge ve kayıtlardan 3 üncü maddede belirtilen nitelikleri haiz olanlara **Kurul** tarafından devlet sırrı niteliği verilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10 uncu maddede belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 287, sh. 44 vd).

Söz Konusu Tasarının TBMM Genel Kurulunda 2012 yılının Haziran ayında görüşülmesine başlanmış ve toplam 13 maddeden oluşan Tasarının 7 maddesi kabul edilmiş olmakla birlikte, 8. madde konusunda oluşan tereddüt sebebiyle, Tasarının diğer maddeleri görüşülmemiş ve Tasarı kadük kalmıştır.

ruma altına alındığı, açık bir şekilde belirlenebilir değildir. Bu hükümlerle, “devlet sırrı” niteliği taşımayan bilgilerle ilgili gizlilik ihlalleri de ceza yaptırımına altına alınmıştır. TCK’nın, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki **“Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk”** başlıklı Yedinci Bölümde yer alan suç tanımlarının konusunu oluşturan bilgilerin nelerden ibaret olduğu hususundaki belirsizlik, keyfi uygulamaya son derece müsait bulunmaktadır. Şöyle ki gizliliği ihlal edilen bilginin bir kamu görevlisinin “*görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeler(e), kararlar(a) ve emirler(e) ve diğer tebligat*”a ilişkin bilgi olarak değerlendirilmesi halinde, TCK’nın, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki **“Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”** başlıklı Birinci Bölümde yer alan 258. maddesine istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir. Buna karşılık, gizliliği ihlal edilen bilginin “*yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgi*” olarak değerlendirilmesi halinde ise, TCK’nın, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki **“Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk”** başlıklı Yedinci Bölümde yer alan 334. maddesine istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, TCK’nın **“Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk”** başlıklı Bölümü altındaki suçlar, gereksiz tekrarların yer aldığı kazüistik bir yöntemle tanımlanmıştır.

Yukarıda da açıkladığımız üzere, “devlet sırrı” niteliği izafe edilmiş olan bilginin gizliliğinin ihlali, devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından en azından **soyut** bir zarar **tehlikesi** meydana getirmektedir. Gizlilik ihlalinin devletin güvenliği veya milletlerarası ilişkileri bakımından **somut** bir zarar **tehlikesini** meydana getirmesi veya devletin güvenliğinin veya milletlerarası ilişkilerinin bozulmasına (**zarara**) sebebiyet vermesi halinde, failin suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması gerekmektedir (TCK, m. 327, f. 2; m. 328, f. 2; m. 329, f. 2; m. 330, f. 2; m. 333, f. 2, 3; m. 334, f. 2; m. 335, f. 2; m. 336, f. 2; m. 337, f. 2; m. 338, f. 2).

“Devlet sırrı” niteliği izafe edilmiş gizli bilgiler, bunların bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılmasına getirilen sınırlamalarla da koruma altına alınmaktadır.

1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 1412 sayılı **“Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”**nun **“Devlet Esrari Hakkında Alakadarların Şahitliği”** başlıklı 49’uncu maddesi hükümlerine göre;

“Devlet memurları memuriyetten çekildikten sonra bile, saklamakla mükellef oldukları vakıalar hakkında **sırrın ait olduğu makam amirinin izni olmaksızın şahit sıfatıyla dinlenemezler.**” (birinci fıkra)

“Bu gibi hallerde İcra Vekilleri azası hakkında Reisicumhur ve Büyük Millet Meclisi azası hakkında Meclis tarafından izin verilir.” (ikinci fıkra)

“**Şahitlik, Devletin selametine zarar verecek derecede olmadıkça bu izin verilir.**” (üçüncü fıkra)

“Reisicumhur mahremiyeti kendisi takdir eder ve şahitlikten çekinebilir.” (dördüncü fıkra)

“Bu hüküm, reisliği zamanında hadis veya reisliği sebebiyle malûmu olan vakılardan dolayı eski Reisicumhurlar hakkında dahi caridir.” (beşinci fıkra)

Keza, söz konusu Kanunun “Teslim olunmiyacak vesikalar” başlıklı 88. maddesi hükmüne göre; “Resmi dairelerde saklı evrak ve sair vesikalar münderecatının ifşası memleketin selametine zarar vereceği o **dairenin en büyük amiri tarafından beyan** edilirse bu **evrak ve vesikaların gösterilmesi ve teslimi istenmez.** Şu kadar ki bu beyan kafi görülmezse o dairenin men-sup olduğu vekalet müracaat olunabilir.”

Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısında da esas itibarıyla benzer hükümlere yer verilmişti²⁴.

²⁴ Tasarının “**Devlet sırları hakkında ilgililerin tanıklığı**” başlıklı 49. maddesine göre;

“Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, görevlerinden ayrıldıktan sonra da, **saklamakla yükümlü oldukları Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin sırlar** hakkında tanıklık yapabilmeleri, sır ile ilgili **makam âmirinin yazılı iznine** bağlıdır. Hâkim veya mahkeme, bu tanıklığın davanın sonuçlandırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle âmirin olumsuz beyanına karşı ilgili bakana başvurabilir.” (f. 1)

“Birinci fıkra da açıklanan hâllerde bakanlar hakkında Bakanlar Kurulu; milletvekilleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından izin verilir. Cumhurbaşkan, gizliliği kendisi takdir eder ve tanıklıktan çekinebilir.” (f. 2)

“Yukarıdaki fıkra hükümleri, adı geçenler hakkında, görevleri sona ermiş olsa da uygulanır.” (f. 3)

Tasarının bu maddesinin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmişti:

“Madde Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle öğrendikleri ve saklamakla yükümlü oldukları **Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin sırlar** hakkında, ne gibi koşullarla tanıklıkta bulunabileceklerini göstermektedir.

Adı geçenlerin tanık sıfatıyla dinlenmeleri **sırrın ait olduğu makam âmirinin iznine** bağlıdır. Âmirin olumsuz beyanına karşı mahkeme, bu tanıklığın davanın sonuca ulaştırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle ilgili bakana başvurabilir. **Âmirin veya onun olumsuz beyanına**

Buna karşılık, Ceza Muhakemesi Kanununda, bu Kanuna ilişkin Tasarının TBMM adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasındaki katkılarımızla, bir bilginin içeriğinin mahkemeye karşı gizli tutulması, idari makam veya mercilerin takdirine bırakılmaktan çıkarılmıştır. CMK'nın yeni sisteminde **bir bilgi “devlet sırrı” olarak koruma altına alındığı gerekçesiyle mahkemeye karşı gizli tutulamaz**. Ancak bu prensibin kabul edilmesi, “devlet sırrı” niteliği taşıyan bilgilerin gizliliğinin ortadan kaldırılması sonucunu da doğurmamalıdır. Bu prensibin doğurduğu sonuç şudur.

Bir soruşturma ve kovuşturma sürecinde tanık olarak dinlenmek istenen kamu görevlisi, açıklaması istenen bilgilerin “devlet sırrı” olduğunu ileri sürmesi halinde, hakim veya mahkeme heyeti duruşma dışında ve başkalarının bulunmadığı bir ortamda bu kamu görevlisini dinleyecektir. Kamu görevlisi, aleni olmayan ve sadece hakim veya mahkeme heyetinin hazır bulunabileceği bir ortamda kendisinden istenilen açıklamaları yapmaktan kaçınmaz. Bu suretle ilgili kamu görevlisini dinleyen hakim veya mahkeme

karşı başvurulanan bakanın izni olmadıkça hâkimin bu kişileri dinlemek yetkisi yoktur. Hâkimin izin almadan saptayacağı tanık anlatımı hukuka aykırı olarak elde edilmiş olacağından hükme esas teşkil edemeyecektir.

Bütün bu değişikliklerin amacı, etkin bir ceza sisteminin oluşturulmasıdır. Bu yapılırken, Devlet sırrı da korunmakta ve yararların dengelenmesine çalışılmaktadır.

Maddenin son fıkrasında izinle tanıklıkta bulunabilecek kişilerin, görevleri sona ermiş olsa da, bu koşul ile bağlı kalmakta devam edecekleri açıklanmıştır.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 698, sh. 29 vd.).

Keza, Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısının “**Verilemeyecek veya gösterilemeyecek dosya veya belgeler**” başlıklı 93. maddesine göre;

“Kamu kurum veya kuruluşunun bağlı veya ilgili bulunduğu bakan, dosya veya belge içeriğinin aleniyete çıkmasının Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracağını bildirirse, bu dosya veya belgelerin ilgili makam ve memur tarafından verilmesine veya gösterilmesine karar verilemez.” (f. 1)

“Ancak, hâkim veya mahkeme, bu dosya veya belgelerin incelenmesinin davanın sonuçlandırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Başbakanlığa başvurabilir.” (f. 2)

Tasarının bu maddesinin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmişti:

“Bu madde, resmî dairelerdeki dosya ve diğer belgelerin delil olarak mahkemelerde kullanılabilmesi açısından önemli değişiklikler getirmiş ve öncelikle Devletin güvenliği veya temel dış yararları unsurları kullanılmıştır.

Ayrıca, izin verme konusu netleştirilmiş ve doğrudan doğruya ilgili bakana yetki verilmiştir. Ayrıca bakanın kararına karşı itiraz yolu da açılarak, Başbakanlığa başvurulabilmesi kabul edilmiştir.

Bütün bu yeniliklerin amacı, etkin bir ceza yargılama sisteminin oluşturulmasıdır. Bu yapılırken, Devlet sırrı da korunmakta ve yararların dengelenmesine çalışılmaktadır.

İlgili makam veya resmî memur, bakanın kararı olmadan Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar meydana getirecek dosya ve belgeleri verecek olursa, mahkeme bunları hükme esas alamayacaktır.”

heyeti, verilen bilgilerin içerik itibarıyla “devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığının kendisi takdir edecektir. Hakim veya mahkeme heyetinin yapılan bu açıklamaların “devlet sırrı” niteliğinde olduğuna kanaat getirmesi halinde, bu kamu görevlisi soruşturma ve kovuşturmada tanık olarak dinlenmeyecektir. Bu suretle “devlet sırrı” niteliğindeki bilgilerin ifşası önlenmiş olacaktır.

Tanık olarak dinlenmek istenen kamu görevlisinin duruşma dışında ve başkalarının bulunmadığı bir ortamda yaptığı bu açıklamalar karşısında, hakim veya mahkeme heyetinin bu bilgilerin bir suç olgusuna ilişkin olduğu ve dolayısıyla, “devlet sırrı” niteliğinde olmadığı kanaatine varması halinde, bu kamu görevlisi tanıklık yapmaktan kaçınamayacaktır²⁵. Çünkü, **“Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulmaz.”** (CMK, m. 47, f. 1).

Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakaraları sırasında 49. maddenin değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanmış bulunduğumuz önerge metninin 47. madde olarak kabul edilmesiyle²⁶; TCK’nın 327. maddesine bir fıkra olarak eklemeyi önerdiğimiz hüküm, CMK’nın 47. maddesinin birinci fıkrasına dercetmeyi başarmış bulunmaktayız²⁷.

Keza, bir soruşturma ve kovuşturma sürecinde delil olması veya delil olarak değerlendirilmesi itibarıyla bir kamu kurumundan belge istenmesi ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin bu belge içeriklerinin “devlet sırrı” olarak koruma altına alındığını ileri sürmesi halinde, hakim veya mahkeme heyeti

²⁵ Kolluğun suç işlenmesini önleme amaçlı olarak icra ettiği istihbarat faaliyetinde istihdam edilen kişiler, bu faaliyet çerçevesinde işlenmesine muttali oldukları suç vakası ile ilgili soruşturma ve kovuşturmada tanıklık yapmaktan kaçınamazlar. Ancak bu kişiler, CMK’nın 58. maddesinin iki ila beşinci fıkraları hükümlerine istinaden **kimliği saklı tutulmak suretiyle** dinlenebilirler.

²⁶ TBMM Adalet Komisyonunun Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısına ilişkin 1.12.2004 tarihli ve Esas: 1/535, 1/292, Karar: 65 sayılı Raporu (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 698, sh. 278).

²⁷ Şahin, CMK’nın 47. maddesindeki düzenleme ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulunmaktadır:

*“Bu hüküm, gerek 1412 sayılı CMUK’nun 49. maddesindeki gerekse Tasarının 49. maddesindeki yaklaşımın aksi yönde bir düzenleme öngörmektedir. Bahsi geçen düzenlemelerde asıl olan, devlet sırrı nedeniyle tanıklıktan kaçınmak olduğu halde, CMK’nun bu hükmü ile, **devlet sırrı gerekçesiyle dahi tanıklıktan kaçınılamayacağı** esası benimsenmiştir. Ancak önemi nedeniyle, **devlet sırrı niteliği taşıyan tanıklık konusu bilgiler, özel bir usule göre alınabilecek ve tutanağa geçirilecektir.** Ayrıca, bu hüküm, ancak ceza miktarı itibarıyla belli bir ağırlığa ulaşmış suçlar bakımından uygulanabilecektir.”* (ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, sh. 175 vd.).

duruşma dışında ve başkalarının bulunmadığı bir ortamada bu belgeleri inceleyebilecektir. İlgili kamu kurumu yetkilileri, içeriklerinin “devlet sırrı” oluşturduğu gerekçesiyle bu belgelerin hakim veya mahkeme heyeti tarafından görülmesine ve incelenmesine engel olamazlar. Bu suretle belgeleri inceleyen hakim veya mahkeme heyeti, bunların içerik itibarıyla “devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığını **kendisi** takdir edecektir²⁸. Hakim veya mahkeme heyetinin bu belge içeriklerinin “devlet sırrı” niteliğinde olduğuna kanaat getirmesi halinde, bunlar dosyaya konulmayacaklardır.

Buna karşılık, istenen belgelerin duruşma dışında incelenmesi sonucunda hakimin veya mahkeme heyetinin bunların içeriğinin bir suç olgusuna ilişkin olduğu ve dolayısıyla, “devlet sırrı” niteliğinde olmadığı kanaatine varması halinde, bunlar delil olarak değerlendirilmek üzere dosyaya konulacaklardır²⁹. Çünkü, **“Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.”** (CMK, m. 125, f. 1)³⁰.

Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında 93. maddenin değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanmış bulunduğumuz önerge metninin 125. madde olarak kabul edilmesiyle³¹; TCK’nın 327. maddesine bir fıkra olarak eklemeyi

²⁸ Bir suç olgusuna ilişkin olduğu için “devlet sırrı” olarak koruma altına alınmayan ve delil olarak değerlendirilmek üzere dosyaya konulan belge içeriği, soruşturma ve kovuşturmanın süjelerine karşı artık gizli tutulamaz. Sanık müdafii, bu belge içeriklerini inceleyebileceği gibi, bunlardan örnek alabilme hak ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesinin aksi yönde içtihatla bulunduğu 13.1.2009 tarihli ve 1/1 sayılı kararını doğru bulmuyoruz.

²⁹ Yukarıda da açıkladığımız üzere, hukuk uygulamamızda, bir bilginin içeriği itibarıyla gizli tutulması gereken bilgi olup olmadığının, gizlilik kaydı içeren bilginin “devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığının tespiti, bilirkişi marifetiyle yapılmaktadır. CMK’nın 63. maddesinin birinci fıkrası hükmü karşısında, bu uygulamayı doğru bulmamaktayız. Bir bilginin (“devlet sırrı” olarak) gizli tutulması gereken bir bilgi olup olmadığının tespiti hukuki bir değerlendirmeyi gerektirdiği için ancak mahkeme tarafından yapılabilir. Aksi takdirde bizzat hakim tarafından yapılması gereken iş, bilirkişiyeye havale edilmiş olacaktır. Ancak, örneğin yabancı dille yazılmış bir belgenin içeriğinin Türkçe olarak ifadesi için tercüman, belge içeriğindeki şifrelerin çözümü için bilirkişi, görevlendirilebilir.

³⁰ Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan bu hükümlere yönelik tutarsız eleştiriler için bkz. FEYZİOĞLU, Metin: *Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Devlet Sırrı içeren Beyanların ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması*, in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich, Yayına hazırlayanlar/Hrsg. HILGEN-DORF, Eric/ÜNVER, Yener; Yeditepe Üniversitesi yayını, İstanbul 2010, sh. 889 vd.

³¹ TBMM Adalet Komisyonunun Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısına ilişkin 1.12.2004 tarihli ve Esas: 1/535, 1/292, Karar: 65 sayılı Raporu (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 698, sh. 295).

önerdiğimiz hükmü, CMK'nın 125. maddesinin birinci fıkrasına da dercetmeyi başarmış bulunmaktayız³².

Önemle belirtmemiz gerekir ki, uygulamada “devlet sırrı” tartışması çoğunlukla devletin işleyişi sürecinde yapılan belirli işlemlere ve gerçekleşen belirli olaylara ilişkin olarak yapılmaktadır. Örneğin terör gibi belirli suçlulukla “mücadele” adı altında icra edilen kamusal faaliyet çerçevesinde, önlenmesi amaçlanan suçlardan en azından daha hafif olmayan önemli suçlar işlenebilmekte veya işletilebilmektedir. Bu ağır suçları işleyen kişiler, kamu görevlisi olsun veya olmasın, kamu gücü ve kamu imkanları kullanılarak himaye edilebilmektedir. Bu himaye çerçevesinde, terör gibi belirli suçlulukla “mücadele” adı altında icra edilen kamusal faaliyet çerçevesinde işlenen suçlara, bu suçların işleyen ve işlenişine iştirak eden kamu görevlilerine ve sair kişilere ilişkin bilgiler, “devlet sırrı” olduğundan bahisle soruşturma ve kovuşturma makamlarına karşı gizli tutulabilmişlerdir.

Keza, örneğin özelleştirme uygulamaları çerçevesinde satışı gerçekleştirilen bir kamu bankasının satışı sürecinde tesis edilen bazı işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilebilmesi ve tespiti için bu süreçte görev yapmış üst düzey kamu görevlileri tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye davet edildiklerinde, açıklama istenilen hususla ilgili bilgilerin “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle bu kamu görevlilerinin tanıklık yapmaktan kaçınabilmesi girişiminde bulunulmuştur.

Toplumumuzun bir **hukuk toplumu** olma yönündeki gelişim sürecine katkı sağlamak için, **bir suç olgusuna ve hatta bir haksızlığa ilişkin bilgilerin, hiçbir zaman devlet sırrı olarak koruma altına alınamayacağını** mevzuatımıza bir hüküm olarak kazandırmak gerekmiştir. CMK'nın 47. ve 125. maddelerinin birinci fıkralarına konulan hükümler, bu ihtiyacı bir ölçüde karşılamıştır. Bu maddelerin birinci fıkralarında yer alan hükmün kanunlaşmasıyla, hukuk uygulamamızda bir çığır açılmıştır. Ancak, delil olarak değerlendirilmek üzere istenilen belgenin içerdiği bilgilerin veya tanık olarak dinlenilmek istenen kişinin vakıf olduğu bilgilerin bir suç olgusuna ilişkin olup olmadığının ve dolayısıyla, “devlet sırrı” niteliği taşıyıp taşımadığının

³² TBMM Adalet Komisyonunun Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısına ilişkin Raporunda bu değişiklik **gerekçesi** olarak şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Maddenin birinci fıkrasında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 328 inci (doğrusu 327'nci) maddesinin gerekçesinde vurgulanan düşünceye paralel olarak, bir suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgelerin, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 698, sh. 172).

tespitine yönelik olarak izlenecek yöntem bakımından söz konusu maddeler hükümlerinin sorunsuz olmadığı muhakkaktır³³. Yönteme ilişkin bu sorunların, uygulamada içtihat yoluyla giderilebileceği kanısındayız.

³³ Doktrinde bazı yazarlarca ve bunların etkisiyle uygulamada CMKnın 47 ve 125. maddelerinde (f. 3) yer alan “*Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.*” hükmünün ters bir mantıktan hareket edilerek yorumlandığı gözlemlenmektedir (Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesi, 13.1.2009, 1/1). Bu yorumlamada, söz konusu fıkra hükmünden ziyade, bu maddelere ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçede yer alan ifadelerle dayanılmıştır.

Bu hükmün konuluş amacı, “devlet sırrı” niteliği taşıdığı için gizli tutulması gereken bilgilerin ve bu bilgileri içeren belgelerin herhangi bir suçtan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılmasının önüne geçmektir. “Devlet sırrı” niteliği taşıdığı için gizli tutulması gereken bilgiler ve bu bilgileri içeren belgeler, ancak belirli bir ağırlık derecesine sahip olan bir suçtan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılabilir. Buna karşılık, soruşturma ve kovuşturma konusu suçun kanuni tarifindeki cezanın alt sınırının beş yıldan az olması halinde, örneğin görevi kötüye kullanma suçundan dolayı yapılan bir soruşturma ve kovuşturmada, “devlet sırrı” niteliği taşıdığı için gizli tutulması gereken bilgileri içeren belgenin, içerdiği bilgiler itibarıyla bir suç olgusuna ilişkin olup olmadığına bakılmaksızın, delil olarak kullanılması yoluna gidilemeyecektir.

Doktrin ve uygulamada yapılan yorumlamada, söz konusu fıkralarda yer alan hükümden ziyade, 125. maddeye ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçede yer alan şu cümleye dayanılmıştır: “*Bu itibarla, belirlenen ağırlık ölçüsüne ulaşmayan suçlardan dolayı bir bilgi veya belgenin devlet sırrı olduğundan bahisle soruşturma ve kovuşturma sürecinde tartışılmasına sınırlama getirilemeyecektir.*” Söz konusu fıkralarda yer alan hüküm amaçlı bir yoruma tabi tutulduğunda, bundan belirtilen anlamın çıkarılamayacağı kuşkusuz bir şekilde anlaşılacaktır.

Kaynakça

- BABA**, Yasemin: *Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık*, İstanbul, 2013.
- BARTON**, Stephan: *Das Tatobjekt der Geldwäsche: Wann rührt ein Gegenstand aus einer der im Katalog des § 261 I Nr.1-3 StGB bezeichnenden Straftaten her?*, in: NStZ 4/1993, sh. 164 vd.
- BAYRAKTAR**, Köksal: *Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü*, İstanbul, 1997.
- BOCKELMANN**, Paul/**VOLK**, Klaus: *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, München, 1987.
- COŞKUN**, Neslihan: *Karaparanın Aklanması Suçu*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2003.
- DEGEN**, Andreas: *Gesetzliche Mitwirkungspflichten der Kreditwirtschaft bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Eine verfassungsrechtliche Betrachtung aus Sicht der Bankkunden am Beispiel des Konten Screenings und des Kontendatenabrufverfahrens*, Frankfurt am Main, 2009
- DÜLGER**, Murat Volkan: *Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar*, Ankara, 2011.
- Entschliessungen des XVIII. Internationalen Strafrechtskongress in Istanbul 2009**, in: Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (122(2010), Heft 2, s. 473 vd.
- ERDEM**, Mustafa Ruhan: *Suç Bildirmeme Suçu [TCK, m. 278]*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, yıl 21, sayı 80, Ocak-Şubat 2009.
- EREL**, Kemalettin: *Yargıtay Kararları Işığında Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK. m. 220)*, in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich, Yayına hazırlayanlar/Hrsg. HILGENDORF, Eric/ÜNVER, Yener; Yeditepe Üniversitesi yayını, İstanbul 2010, sh. 379 vd.
- EREM**, Faruk: *Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler*, cilt III, 3. bası, Ankara 1985.
- ERGÜL**, Ergin: *Kara Ekonomi ve Aklama Suçu*, Ankara, Eylül 2005.
- ERGÜL**, Ergin: *Karaparanın Aklanması ve Suçları*, Ankara 1998.
- EVİK**, Vesile Sonay: *Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu*, in: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, cilt 19, sayı 2, İstanbul 2013, sh. 672 vd.
- FEYZİOĞLU**, Metin: *Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Devlet Sırri İçeren Beyanların ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması*, in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich, Yayına hazırlayan-

lar/Hrsg. HILGENDORF, Eric/ÜNVER, Yener; Yeditepe Üniversitesi yayını, İstanbul 2010, sh. 889 vd.

GERÇEKER, Hasan: *Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu*, Ankara, 2011.

GÖDEKLİ, Mehmet: *Terörizmin Finansmanı Suçu*, Ankara, Haziran 2017.

GÖKCAN, Hasan Tahsin/**ARTUÇ**, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Şerhi*, cilt V, Ankara 2021.

HERZBERG, Rolf Dietrich: *Mittelbare Täterschaft bei rechtmäßig oder unverboden handelndem Werkzeug*, Berlin, 1967.

JAKOBS, Günther: *Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, Berlin/New York, 1983.

JEKEWITZ, Jürgen: *Nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 59 vd.

JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, 1988.

KOCASAKAL, Ümit: *Karapara Aklama Suçu* (yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2000.

KRÄMER, Gregor: *Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Die Tätigkeit der FATF als internationale Standardsetter*, Baden-Baden 2008.

KUNTER, Nurullah: *Ceza Hukukunda Zamanaşımı* (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul, 1946.

LEIP, Carsten: *Der Straftatbestand der Geldwäsche, Zur Auslegung des § 261 StGB*, 2. Aufl., Berlin, Baden-Baden, 1999.

LEIPZIGER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch, Band 5, 12. Auflage, Berlin/New York, 2010 (§ 129: Mathias KRAUß).

LEIPZIGER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch, Band 8, 12. Auflage, Berlin/New York, 2010 (§ 261: SCHMIDT, Wilhelm/KRAUSE, Juliane).

MACKE, Julia: *UN-Sicherheitsrat und Strafrecht, Legitimation und Grenzen einer internationalen Strafgesetzgebung*, Berlin, 2010.

MALKOÇ, İsmail: *Açıklamalı İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu*, cilt 2, Ankara 2008.

MÜLHAUSEN, Dieter: *Bekämpfung der Geldwäsche in der Kredit- und Finanzdienstleistungswirtschaft*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 351 vd.

- MÜNCHENER KOMMENTAR**, Strafgesetzbuch, Band 3, München, 2003 (§ 261: NEUHEUSER, Stephan).
- NESTLER**, Cornelius: *Der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB)*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 97 vd.
- OSWALD**, Katharina: *Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland*, Freiburg, 1997
- ÖNOK**, R. Murat: *Yapısal Suçlarda Failin Tespiti: Müşterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik Doktrinleri*, Ankara, Mart 2019.
- ÖZEK**, Çetin: “Devletin Korunması”, “Terörle Mücadele Yasası” ve “Bilgilenme Hakkı”, in: Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, Edip F. Çelik’e Armağan, İstanbul 1995.
- ÖZEK**, Çetin: *Adliye Karşı Suçların Hukuksal Konusu*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LV, sayı 3, İstanbul, 1997.
- ÖZEK**, Çetin: *Organize Suç*, in: Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul, 1998.
- ÖZEK**, Çetin: *Terör ve “Terörle Mücadele Kanunu”*, in: İstanbul Barosu Dergisi (İBD), cilt 65, yıl 1991, sayı 4-5-6.
- ÖZEK**, Çetin: *Siyasî İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler*, İstanbul 1967.
- ÖZGEN**, Eralp: *Terörizmle Mücadele Yasasının Değerlendirilmesi*, in: İstanbul Barosu Dergisi (İBD), cilt 65, yıl 1991, sayı 4-5-6.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “Terörizmin ve Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve Ceza Hukuku Sorumluluğu”, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXV, sayı 2, Nisan 2021, sh. 373 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “Anayasayı İhlâl Suçu, Yasama Organına Karşı Suç, Hükûmete Karşı Suç ve Suç İçin Anlaşma Suçu Üzerine Değerlendirmeler”, in: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Bilimsel Tebliğler, İstanbul, 23-30 Eylül 2011, sh. 45 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “Devlet Sırrı ve Ceza Hukuku”, in: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in the Turkey, 26 Mayıs/May 2010, Kongre Kitabı, cilt I, sh. 63 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “Non bis in idem” Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK’nın 10/A Maddesi Hükmüne ilişkin Değerlendirme, in: Yargıtay Dergisi, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğünün Kapsam ve Sınırları”, in: SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Aralık-Ocak-Şubat 2007-2008, sayı 5.

- ÖZGENÇ**, İzzet: *Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku*, in: 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu 22-23 Ekim 1998, Diyarbakır.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, cilt LV, yıl 1997, sayı 3.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukuki Sonuçları*, in: Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), yıl 1995, cilt 9, sayı 1-3.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç İştirakin Hukukî Esası ve Faillik*, İstanbul 1996.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 6. bası, Ankara, Eylül 2011.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 12. bası, Ankara, Eylül 2016.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 17. bası, Ankara, Eylül 2021.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, (Genel Hükümler)*, 3. bası, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, Ocak 2006.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, Eylül 2006.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Zimmet Suçu*, 2. bası, Ankara, Temmuz 2012.
- ÖZGENÇ**, İzzet/ŞAHİN, Cumhur: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 3. bası, Ankara, 2000.
- PARLAR**, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: *5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu*, cilt II, Ankara, Şubat 2007.
- PASSAS**, Nikos: *Terrorism Financing, General Report*, in *Revue Internationale de Droit Penal*, 79 (2008), 3, 4, sh. 325 vd.
- PASSAS**, Nikos: *Terörizmin Finansmanı*, in: 18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, İstanbul 20-27 Eylül 2009, The 18th. International Congress of Penal Law, İstanbul 20-27 September 2009, Hazırlık Hareketleri ve İştirakin Genişlemesi, Terörizmin Finansmanı, Özel Yargılama Tedbirleri ve İnsan Haklarının Korunması, Evrensel Yargı Yetkisi, Sorular, Ulusal Raporlar, Genel Raporlar, Karar Taslakları, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, İstanbul, Mart 2009, sh. 146 vd.
- ROBERTS**, Marc: *Terrorismusfinanzierung, Zugleich ein Beitrag zum internationalen Verwaltungsrecht*, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, 2011.
- ROSSI**, Matthias, *Gemeinschaftsrechtlicher Grundrechtsschutz gegen europarechtlich umgesetzte VN-Sanktionen*, in: *Zeitschrift für das Juristische Studium (ZJS)*, 5, 2008, sh. 551 vd.
- ROXIN**, Claus: *Bemerkungen zum "Täter hinter dem Täter"*, in: *Festschrift für Richard Lange*, 1976.
- ROXIN**, Claus: *Täterschaft und Tatherrschaft*, 4. Auflage, Berlin/ New York, 1984.

- SARITAŞ**, Erkan: *Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları (TCK m. 220-221)*, İstanbul, 2018.
- SCHMIDHÄUSER**, Eberhard: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 2. Auflage, Tübingen, 1975.
- SCHÖNKE**, Adolf/**SCHRÖDER**, Horst: *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 17. Auflage, München, 1974; 23. Auflage, München, 1988.
- SCHMALENBACH**, Kirsten: *Bedingt kooperationsbereit: Der Kontrollanspruch des EuGH bei gezielten Sanktionen der Vereinten Nationen, Zum Urteil des EuGH von 3.9.2008, Rs. C 402/05 u. C 415/05 – Kadi und Al Barakaat*, in *Juristenzeitung (JZ)* 2009, sh. 35 vd.
- SCHROEDER**, Friedrich Christian: *Der Täter hinter dem Täter*, Berlin, 1965.
- Section II, Criminal Law, Special Part, Financing of Terrorism**, in: *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft* (122(2010), Heft 2, s. 477 vd.
- SOTIRIADIS**, Georgios: *Die Entwicklung der Gesetzgebung über Gewinnabschöpfung und Geldwäsche, Unter Berücksichtigung der Jeweiligen Kriminalpolitischen Tendenzen*, Berlin, 2010.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 2. bası, Ankara, Eylül 1997.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 11. bası, Ankara, 2016.
- SOYASLAN**, Doğan: *Teşebbüs Suçu*, Ankara, 1994.
- SÖZÜER**, Adem: *Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu Suçlulukla Mücadele İle İlgili Gelişmeler*, in: *Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını)*, cilt 9, yıl 1995, sayı 1-3.
- SÖZÜER**, Adem: *Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Muhakemesi Tedbirleri* (yayınlanmamış Doçentlik Çalışması), İstanbul 2000.
- SÖZÜER**, Adem: *Suç Teşebbüsü*, İstanbul 1994.
- STRATENWERTH**, Günter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat*, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn, 1981.
- SYSTEMATISCHER KOMMENTAR** zum Strafgesetzbuch, 4. Auflage, 1983 ve müteakip yıllar.
- SYSTEMATISCHER KOMMENTAR** zum Strafgesetzbuch (RUDOLPHI, Hans Joachim/HORN, Eckhard/GÜNTHER, Hans-Ludwig/SAMSON, Erich) (§261: HOYER, Andreas).
- ŞAHİN**, Cumhur: *Türk Ceza Kanunu ve Tasarısında Suçlunun Kayrılması Suçları*, in: *Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi*, sayı 102, 15 Mayıs 1999.
- ŞAHİN**, Cumhur: *Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi*, Ankara, 2005.
- ŞEN**, Ersan/**ERYILDIZ**, H. Sefa: *Suç Örgütü*, 4. bası, Ankara, 2021.

- TEICHMANN**, Helmut/**ACHSNICH**, Gernot: *Das Geldwäschegesetz – Überblick*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 239 vd.
- TEICHMANN**, Helmut/**ACHSNICH**, Gernot: *Geldwäscheregelungen in anderen Gesetzen*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/ MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 315 vd.
- Terörle Mücadele Kanunu, Değişiklikler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Raporları**, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Yayını [yayın yılı belirtilmemiş].
- TELLENBACH**, Silvia: *Bericht über die Verhandlungen der II. Sektion: Strafrecht Besonderer Teil: Terrorismusfinanzierung*, in: Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (122(2010), Heft 2, s. 458 vd.
- Terörizm Suçlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Çalışma Raporu, 25.03.2019**, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRK-CE-MER) yayını.
- TOZMAN**, Önder: *Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu*, Ankara, Haziran 2017.
- ÜNVER**, M. Naci: *Uygulamada Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ve Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak*, Ankara, 2001.
- VOGT**, Sabine: *Begriff, Phänomen und Erscheinungsformen der Geldwäsche*, in: Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Hrsg. HERZOG, Felix/MÜLHAUSEN, Dieter, München, 2006, sh. 1 vd.
- VOß**, Marko: *Die Tatobjekte der Geldwäsche*, Köln, Berlin, München, 2007.
- WERNER**, Gerhard: *Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft*, Freiburg i. Br., 1996.
- WESSELS**, Johannes: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 19. Auflage, Heidelberg, 1989.
- YAŞAR**, Osman/**GÖKCAN**, Hasan Tahsin/**ARTUÇ**, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu*, cilt VI, Ankara 2010.
- YENİDÜNYA**, Ahmet Caner/**İÇER**, Zafer: *Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu*, in: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, cilt 19, sayı 2, İstanbul 2013, sh. 822 vd.
- YILDIRIM**, Zeki: *Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi*, Ankara, 2012.
- YILDIRIM**, Zeki: *Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma*, Ankara, 2013